

LUIZ GUILHERME MARINONI
DANIEL MITIDIERO

**COMENTÁRIOS
AO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL** | **XVI**

ARTIGOS 976 AO 1.044

LUIZ GUILHERME MARINONI

DIRETOR

SÉRGIO CRUZ ARENHART

DANIEL MITIDIERO

COORDENADORES



THOMSON REUTERS

**REVISTA DOS
TRIBUNAIS™**

2019 - 04 - 06

Comentários ao CPC - v. XVI - Marinoni - Ed. 2018

PRIMEIRAS PÁGINAS

COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL

VOLUME XVI – ARTIGOS 976 AO 1.044

Autores

Luiz Guilherme Marinoni

Daniel Mitidiero

© desta edição [2018]

Thomson Reuters Brasil

Juliana Mayumi Ono
Diretora responsável

Rua do Bosque, 820 – Barra Funda
Tel.: 11 3613-8400 - Fax: 11 3613-8450
CEP 01136-000 - São Paulo

Todos os direitos reservados. Proibida a reprodução total ou parcial, por qualquer meio ou processo, especialmente por sistemas gráficos, microfilmicos, fotográficos, reprográficos, fonográficos, videográficos. Vedada a memorização e/ou a recuperação total ou parcial, bem como a inclusão de qualquer parte desta obra em qualquer sistema de processamento de dados. Essas proibições aplicam-se também às características gráficas da obra e à sua editoração. A violação dos direitos autorais é punível como crime (art. 184 e parágrafos, do Código Penal), com pena de prisão e multa, conjuntamente com busca e apreensão e indenizações diversas (arts. 101 a 110 da Lei 9.610, de 19.02.1998, Lei dos Direitos Autorais).



Visite nosso site: www.rt.com.br

Central de Relacionamento RT (atendimento, em dias úteis, das 8 às 17 horas)

Tel. 0800.702.2433

e-mail de atendimento ao consumidor: sac@rt.com.br

Fechamento desta edição: [15.08.2018]



ISBN 978-85-5321-194-4

© desta edição [2018]

2019 - 04 - 06

Comentários ao CPC - v. XVI - Marinoni - Ed. 2018

FICHA CATALOGRÁFICA

Ficha Catalográfica

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)

(Câmara Brasileira do Livro, SP, Brasil)

Marinoni, Luiz Guilherme

Comentários ao Código de Processo Civil : [livro eletrônico] (arts.976 ao 1.044) / Luiz Guilherme Marinoni, Daniel Mitidiero. -- 2. ed. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2018. -- (Coleção comentários ao código de processo civil ; V. XVI / coordenação direção Luiz Guilherme Marinoni ; coordenação Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero)

6 Mb ; ePUB

2. ed em e-book baseada na 2. ed. impressa rev. e atual.

Bibliografia

ISBN 978-85-5321-194-4

1. Processo civil - Legislação - Brasil I. Arenhart, Sérgio Cruz. II. Título. III. Série.

18-19537 CDU-347.9(81)(094.46)

Índices para catálogo sistemático:

1. Brasil : Código de Processo Civil comentado 347.9(81)(094.46))

2. Código de Processo Civil : Comentários : Brasil 347.9(81)(094.46)

Cibele Maria Dias - Bibliotecária - CRB-8/9427

© desta edição [2018]

2019 - 04 - 06

Comentários ao CPC - v. XVI - Marinoni - Ed. 2018

EXPEDIENTE

Expediente

Diretora de Conteúdo e Operações Editoriais

Juliana Mayumi Ono

Editorial: Andréia Regina Schneider Nunes, Cristiane Gonzalez Basile de Faria, Diego Garcia Mendonça, Karolina de Albuquerque Araújo, Marcella Pâmela da Costa Silva e Thiago César Gonçalves de Souza

Assistente Editorial: Francisca Lucélia Carvalho de Sena

Produção Editorial

Coordenação

Iviê A. M. Loureiro Gomes

Líder Técnica de Qualidade Editorial: Maria Angélica Leite

Analista de Projetos: Larissa Gonçalves de Moura

Analistas de Operações Editoriais: Damares Regina Felício, Danielle Castro de Moraes, Felipe Augusto da Costa Souza, Gabriele Lais Sant'Anna dos Santos, Maria Eduarda Silva Rocha, Mayara Macioni Pinto, Patrícia Melhado Navarra, Rafaella Araujo Akiyama e Thaís Rodrigues Sampaio

Analistas de Qualidade Editorial: Carina Xavier e Daniela Medeiros Gonçalves Melo

Estagiários: Angélica Andrade, Miriam da Costa Leite, Nicolas Eugênio Almeida Bueno e Sthefany Moreira Barros

Capa: Chrisley Figueiredo

Adaptação da Capa: Linotec

Projeto Gráfico: Carla Lemos

Equipe de Conteúdo Digital

Coordenação

Marcello Antonio Mastro Rosa Pedro

Analistas: Ana Paula Cavalcanti, Jonatan Souza, Luciano Guimarães e Rafael Ribeiro

Administrativo e Produção Gráfica

Coordenação

Mauricio Alves Monte

2019 - 04 - 06

Comentários ao CPC - v. XVI - Marinoni - Ed. 2018

SOBRE OS AUTORES

Sobre os Autores

Luiz Guilherme Marinoni

Professor Titular de Direito Processual Civil – *com defesa de tese* – na UFPR.

Pós-Doutorado na Universidade Estatal de Milão e na Columbia University. Tem dezessete livros publicados na América Latina e na Europa e mais de trinta livros publicados no Brasil. Diretor das Revistas *Iberoamericana de Derecho Procesal* e de *Processo Comparado* – ambas publicadas pela Ed. Revista dos Tribunais.

Diretor do Instituto Iberoamericano de *Derecho Procesal*. Membro do Conselho da *International Association of Procedural Law*. Recebeu o Prêmio Jabuti em 2009 e em 2017, tendo sido indicado ao mesmo prêmio em diversas outras ocasiões. Ex-Procurador da República. Ex-Presidente da OAB-Paraná. Advogado e Parecerista, com intensa atuação nos Tribunais e nas Cortes Supremas.

Daniel Mitidiero

Pós-Doutorado pela *Università degli Studi di Pavia*. Doutor em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS. Professor Associado de Direito Processual Civil nos cursos de Graduação, Especialização, Mestrado e Doutorado da Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS. Publicou 30 livros publicados – quatro deles no exterior (Espanha, Itália e Peru) – e diversos artigos em revistas especializadas nacionais e estrangeiras, dentre as quais o *International Journal of Procedural Law*, a *Revista Argentina de Derecho Procesal*, a *Revue Internationale de Droit Comparé* e a *Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile*. Membro da *International Association of Procedural Law* – IAPL, do Instituto Iberoamericano de *Derecho Procesal* – IIBDP, e do Instituto Brasileiro de Direito Processual – IBDP. Recebeu o Prêmio Jabuti em 2009 e em 2017. Advogado e Parecerista, com intensa atuação nas Cortes Supremas.

Apresentação

Desde a formação da ciência jurídica como a conhecemos, a prática do direito orientou-se pela doutrina formada em torno de textos dotados de autoridade – primeiro com a *Glosa* e logo em seguida com os *Comentários*. Esse hábito de argumentar invocando a *communis opinio doctorum* é particularmente tão arraigado na tradição luso-brasileira que a glosa de Accursio e opinião de Bartolus constituíam fonte subsidiária do direito nas Ordenações Afonsinas e Manuelinas, tendo inclusive mantido esse mesmo patamar nas Ordenações Filipinas – com a única diferença de que a glosa de Accursio e a opinião de Bartolus não poderiam ser contrárias à *communis opinio doctorum* para então figurarem como fonte do direito.

Nesse cenário, em que se refletem as mais fundas raízes da cultura jurídica brasileira, é natural que os *Comentários* tenham tido grande proeminência na conformação da prática do direito brasileiro. Especialmente no campo do processo civil, não só o Código de 1939 despertou a atenção para a redação de textos com intenção sistemática, mas também o Código de 1973 experimentou idêntico interesse.

Atenta à tradição – e ao mesmo tempo ciente de seu compromisso em renová-la à luz das necessidades atuais – a Editora Revista dos Tribunais/Thomson Reuters organizou não só duas coleções de *Comentários ao Código de 1973* (a primeira organizada por Sérgio Bermudes e a segunda por Ovídio Baptista da Silva), mas igualmente se preocupou em convidar-nos para coordenar estes *Comentários*, os primeiros a constituírem uma coleção completa entregue à cultura jurídica nacional a respeito do Código de 2015. A fim de que o seu conteúdo pudesse espelhar os diferentes fios que se entrelaçam para dar sustentação ao processo civil brasileiro, a coleção é composta de autores do mais alto nível de formação acadêmica, atuantes em diferentes segmentos da prática jurídica e pertencentes a todos os quadrantes do nosso país.

Estes *Comentários* estão voltados a todos aqueles que trabalham diariamente com o Código de Processo Civil. É por essa razão que é uma grande alegria apresentar esta coleção de *Comentários ao Código de Processo Civil de 2015*, ao mesmo tempo em que agradecemos a confiança depositada pela Editora em nosso trabalho, pelos nossos coautores em nossa capacidade de levar adiante o projeto e pelo público interessado em torná-los seus instrumentos de trabalho. Enredar-se na tradição a fim de torná-la sempre viva e comprometida com a prática do direito é motivo de enorme felicidade para nós – ainda mais quando o seu objeto é o processo civil, ramo das leis mais rente à vida, sem o qual a tutela dos direitos não passa de uma mal-acabada impressão.

Luiz Guilherme Marinoni

Sérgio Cruz Arenhart

Daniel Mitidiero

SUMÁRIO

CAPÍTULO VIII - Do Inc. de Res. de Demanda Repetitiva [Art. 976 a 987]

CAPÍTULO IX - Da Reclamação [Art. 988 a 993]

TÍTULO II - DOS RECURSOS

CAPÍTULO I - Disposições Gerais [Art. 994 a 1.008]

CAPÍTULO II - Da Apelação [Art. 1.009 a 1.014]

CAPÍTULO III - Do Agravo de Instrumento [Art. 1.015 a 1.020]

CAPÍTULO IV - Do Agravo Interno [Art. 1.021]

CAPÍTULO V - Dos Embargos de Declaração [Art. 1.022 a 1.026]

CAPÍTULO VI - Dos Recursos para o STF e para o STJ [Art. 1.027 a 1.044]

Capítulo VIII. Do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas

1. Decisão de Questão Idêntica, Coisa Julgada Erga Omnes e Participação mediante Representação Adequada

1.1. Objetivo do incidente de resolução de demandas repetitivas. O incidente de resolução de demandas repetitivas surgiu como meio para facilitar e acelerar a resolução de demandas múltiplas, que dependem da análise e decisão de uma “mesma” questão de direito (art. 976, I, do CPC/2015). Pretendeu-se, igualmente, evitar decisões diferentes para uma mesma questão, frisando-se que a instauração do incidente depende de “risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica” (art. 976, II, do CPC/2015).

Na verdade, a isonomia e a segurança jurídica não constituem propriamente requisitos para a instauração do incidente, mas a justificativa do legislador para a sua previsão no Código de Processo Civil. É que, havendo centenas ou milhares de demandas que dependem da solução de uma mesma questão de direito, sempre há possibilidade de decisões diferentes para casos iguais.

Parte-se da premissa de que, como há apenas uma única questão a atingir todos os demandantes, cabe resolvê-la em separado, outorgando-se à decisão eficácia perante todos os litigantes das diversas ações individuais. Como é fácil perceber, o incidente, ao excluir a participação de todos em nome da otimização da resolução das demandas, exige grande esforço interpretativo.

1.2. A justificativa da exclusão dos litigantes das demandas individuais. O legislador, para justificar a instituição de um procedimento que exclui a participação dos titulares da questão a ser resolvida, apegou-se à ideia de decisão que deve ser, obrigatoriamente, observada pelos juízes. Afirma o art. 927, III do CPC/2015, que “os juízes e os tribunais observarão” os “acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos”.

Trata-se de clara suposição de que a decisão proferida em incidente que julga questão de direito de titularidade de muitos pode a eles ser naturalmente estendida, como se fosse um precedente obrigatório. O incidente de resolução de demandas repetitivas, ao afastar os litigantes das ações individuais da discussão da mesma questão de direito (art. 976, I, do CPC/2015), supõe que a decisão desta questão nada mais é do que um precedente que se aplica aos casos pendentes.

Note-se, aliás, que o art. 985 do CPC/2015 traz confissão neste sentido, afirmando não só que a decisão – chamada de “tese jurídica” – “será aplicada” a “todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem na área de jurisdição do respectivo tribunal, inclusive àqueles que tramitem nos juizados especiais do respectivo Estado ou região” e “aos casos futuros que versem idêntica questão de direito e que venham a tramitar no território de competência do tribunal, salvo revisão na forma do art. 986” (art. 985, I e II, do CPC/2015), mas também que, “não observada a tese adotada no incidente, caberá reclamação” (art. 985, § 1.º, do CPC/2015).

Um precedente fixa o sentido do direito e, por isso, naturalmente diz respeito a todos, enquanto

que uma decisão que resolve questão de direito que constitui prejudicial à tutela jurisdicional do direito de muitos, além de ter valor enquanto resolução de uma específica questão de direito, tem eficácia de coisa julgada em relação aqueles que têm os seus direitos discutidos. Torna-se necessário, assim, distinguir precedente de coisa julgada que recai sobre questão e pode atingir terceiro (arts. 503, § 1.º e 506, do CPC/2015).

1.3. Coisa julgada sobre questão. A decisão do incidente aplica-se em todos os processos pendentes que versem sobre idêntica questão de direito (art. 985, I, do CPC/2015); vale dizer, impede que os litigantes destes processos voltem a discutir a questão resolvida. De modo que a única dificuldade está em esclarecer o que significa proibir ou rediscutir questão já decidida.

Como é possível chamar a decisão que, ditada no processo de um para os casos de muitos, impede-os de relitigar a questão resolvida, submetendo-os? Perceba-se que a decisão tomada no referido incidente constitui uma nítida proibição de relitigar a questão já decidida, que, nos casos de decisão negativa àqueles que não puderam participar e discutir, assemelha-se a um inusitado e ilegítimo *collateral estoppel*.

Assim, na hipótese de decisão tomada em incidente de resolução de demandas repetitivas, há, embora não dito, coisa julgada sobre a questão presente nos vários casos repetitivos. A coisa julgada está a tornar indiscutível uma questão imprescindível para se chegar ao alcance da resolução dos vários casos pendentes.

Note-se que o novo código não limita a coisa julgada à parte dispositiva, mas admite a sua incidência sobre a questão, afirmando em seu art. 503, § 1.º que a coisa julgada “aplica-se à resolução de questão prejudicial, decidida expressa e incidentemente no processo, se: i) dessa resolução depender o julgamento do mérito; ii) a seu respeito tiver havido contraditório prévio e efetivo, não se aplicando no caso de revelia; e iii) o juízo tiver competência em razão da matéria e da pessoa para resolvê-la como questão principal”. Enquanto isso, diz o art. 506 que “a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros”.

No caso de resolução de demandas repetitivas, a questão é pinçada dos casos pendentes e submetida a decisão do órgão julgador incumbido do incidente. Significa que se está diante de coisa julgada que afeta terceiros. Para que isso seja legítimo, na medida em que uma decisão não pode prejudicar a quem não pode participar, é indispensável viabilizar a participação do representante adequado dos litigantes excluídos.

Na verdade, o incidente de resolução, se bem visto – admitindo a participação do representante adequado –, é uma técnica processual absolutamente atrelada à coisa julgada em benefício de terceiros. Veja-se que tanto aquele que pode ser beneficiado pela coisa julgada, quanto aquele que pode ser excessivamente exposto à necessidade de se defender para não ser prejudicado por decisão que possa produzir coisa julgada em benefício de todos os seus adversários, pode requerer a instauração do incidente: i) para que a questão de todos seja discutida em processo conduzido por representante adequado que efetiva e, vigorosamente, defenda os direitos e ii) para que a questão de direito não venha a ser discutida e decidida, inúmeras vezes, sempre com a possibilidade de produzir coisa julgada em benefício de terceiros. De modo que o incidente tem importância para evitar que a coisa julgada, em benefício de terceiros, possa gerar abusos.

1.4. A possibilidade de o terceiro alegar a proibição de rediscutir a questão já decidida. Non-mutual collateral estoppel. Interessa lembrar que a proibição de relitigar questão já decidida surgiu no direito inglês e, posteriormente, foi bastante desenvolvida no direito estadunidense. Apenas mais tarde foi vista como útil por alguns doutrinadores da Europa continental.¹ O que se chama de *collateral estoppel* no *common law* é, em substância, o que se denomina de coisa julgada sobre questão no *civil law*. Mas a lembrança da origem do instituto é importante para demonstrar que o *collateral estoppel* é um instituto que, antes de mais nada, está preocupado em preservar a autoridade da decisão. Poder rediscutir a questão que está à base do dispositivo da decisão implica poder obscurecer a sua essência, fragilizando-se, significativamente, a sua autoridade.

Contudo, se a proibição de voltar a discutir questão determinante do resultado faz parte de orientação presente há muito no *common law*, só mais recentemente, em meados do século XX, surgiu nos Estados Unidos a discussão a respeito da possibilidade de o terceiro – que não participou do processo – poder invocar a proibição da relitigação da questão já decidida. Antes disso, o *collateral estoppel* só podia ser alegado em ação posterior entre as mesmas partes – por qualquer das partes que discutiu a questão decidida – e, nesse sentido, falava-se em mutualidade do *estoppel*. O debate acerca da possibilidade de proibir a parte de relitigar decisão diante de outro adversário foi iniciado no célebre caso *Bernhard v. Bank of America National Trust and Savings Association*,² decidido pela Suprema Corte da Califórnia no início dos anos 40.³

A Suprema Corte estadunidense tratou pela primeira vez do assunto apenas em 1971, em *Blonder-Tongue Laboratories Inc. v. University of Illinois Foundation*.⁴ Em *Blonder-Tongue*, a Universidade de Illinois alegou violação da sua patente. Porém, a Universidade já alegara, em ação anterior em que litigou com outra parte, que a sua patente teria sido infringida, quando se declarou a invalidade da patente. Diante disso, discutiu-se na Suprema Corte se a Universidade poderia ser impedida de rediscutir a decisão que, anteriormente, declarara a invalidade da sua patente. A Suprema Corte fez importantes considerações quanto às consequências econômicas da abertura à relitigação da validade da patente e, com base nelas, revogou parcialmente o precedente firmado em *Triplett v. Lowell*, alegando que a mutualidade do *estoppel* estava “out of place”.⁵ Entretanto, para deixar de lado o princípio da mutualidade firmado em *Triplett*, lembrou a Suprema Corte que a proibição de a parte voltar a litigar uma questão já decidida dependeria da verificação de se ela teve “full and fair opportunity” para litigar no processo anterior. Diante deste ponto, disse a Suprema Corte que, se as questões em ambas as ações devem ser idênticas, torna-se fácil decidir se a parte teve oportunidade de litigar de modo completo e adequado a questão.⁶

Tanto em *Bernhard* quanto em *Blonder-Tongue* firmaram-se os seguintes requisitos para a admissão da proibição de rediscussão: i) a questão que se pretende discutir deve ser idêntica (*the issue is identical*) àquela que já foi discutida; ii) deve ter ocorrido julgamento final de mérito (*a final judgments on the merits*) na ação anterior; iii) o litigante que se pretende proibir de discutir a questão deve não só ter sido parte na ação anterior, mas nela deve ter tido ampla e justa oportunidade de participar.⁷ Nessas condições, o *collateral estoppel* passou a ser designado de *non-mutual collateral estoppel*, exatamente para evidenciar a possibilidade de terceiro poder invocar a proibição de rediscussão contra aquele que participou.

O *non-mutual collateral estoppel* foi pensado, inicialmente, em perspectiva defensiva e, apenas posteriormente, enquanto *offensive collateral estoppel*.⁸ *Blonder-Tongue* é um caso típico de *defensive collateral estoppel*, já que *Blonder-Tongue* se defende mediante a alegação de proibição de relitigação da questão da validade da patente.

Mas existem vários casos em que terceiro invoca a proibição de rediscussão para obter condenação daquele que, num primeiro processo, foi responsabilizado e condenado a pagar indenização em virtude do acidente que também o vitimou. Fala-se, nesse caso, de *offensive collateral estoppel*.⁹ A Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu em favor do uso ofensivo do *collateral estoppel* em 1979, ao julgar *Parklane v. Shore*.¹⁰ É interessante que, nesta ocasião, a Suprema Corte teve oportunidade de distinguir *Parklane* em face de *Blonder-Tongue*, não só para demonstrar a distinção conceitual entre o *offensive* e o *defensive collateral estoppel*,¹¹ mas, sobretudo, para evidenciar a diferença de consequências concretas e práticas, entre o uso de um e de outro.¹² De qualquer forma, a Corte concluiu que nenhum dos argumentos que poderiam justificar a rejeição do uso do *offensive collateral estoppel* estariam presentes no caso sob julgamento e, assim, decidiu que as partes estavam *collaterally estopped* de relitigar a questão.

Do problema e da discussão levada a efeito no direito estadunidense¹³ retiram-se consequências muito importantes para o direito brasileiro, especialmente para a sobrevivência do incidente de resolução de demandas repetitivas: i) o *collateral estoppel* proíbe a rediscussão de questão já decidida; ii) o *non-mutual collateral estoppel* permite que terceiro invoque a proibição de discussão de questão já decidida desde que a questão posta no novo processo seja idêntica, tenha sido julgada mediante sentença final de mérito, e que aquele que se pretende proibir de

voltar a discutir tenha adequadamente participado do primeiro processo; iii) os terceiros, quando a decisão não os beneficia, sempre conservam o direito de propor as suas ações sem qualquer limitação de discussão. Claramente significa que a proibição de relitigar questão já decidida jamais pode prejudicar aquele que não teve oportunidade de discuti-la. Isso porque, como foi assentado em *Parklane v. Shore*, não há como atingir quem não participou do processo e, portanto, não teve oportunidade de ser ouvido, sem violar o *due process*.¹⁴

1.5. O desenvolvimento do collateral estoppel. Das questões de fato às questões de direito e a sua colocação em face da class action. A proibição de relitigar questão, surgida no ancestral direito inglês, limitou-se num primeiro momento aos fatos. É interessante recordar que a tradição da cultura inglesa foi particularmente marcada pelos valores do calvinismo e do protestantismo ascético¹⁵. Esses valores não só apontaram para um modo de vida que impunha a previsibilidade do direito¹⁶ e, por consequência, colaboraram para o surgimento do mecanismo do *stare decisis*¹⁷, como também tiveram influência nas bases daquilo que, mais tarde, veio a ser concebido como *collateral estoppel*. É possível dizer que no direito inglês, as preclusões, compreendidas como formas de proibição de retorno a algo já afirmado ou decidido, têm como fundamento a ideia de que o homem não pode negar as situações para as quais contribuiu com a sua própria conduta¹⁸.

Esse princípio, de ordem religiosa e moral, tomou forma jurídica e teve grande repercussão sobre o desenvolvimento do direito processual. Importa aqui ter em conta que a ideia de *estoppel* constituía uma vedação de a parte, depois de proferida a decisão, negar ou colocar em dúvida os fatos por ela alegados e discutidos. Essa ideia foi relacionada ao sistema de registro ou gravação por escrito das atividades desenvolvidas pelas partes no processo. Da transcrição por escrito (*recorded*) das alegações realizadas pela parte no curso do processo decorria uma presunção de verdade, cancelada por meio do que se designou *estoppel by record*¹⁹. Tratava-se de uma técnica que impedia a parte de pôr em dúvida as alegações e as conclusões que deram origem à decisão de resolução do litígio, mas que era vista como regra de prova. Assim, não é de espantar que o mais antigo e célebre sinal histórico-jurídico de *collateral estoppel* em favor de terceiro esteja num parágrafo de Bentham escrito em *Rationale of Judicial Evidence*. Disse Bentham, na célebre obra publicada em 1827, que há razão para dizer que um homem não deve perder a sua causa em consequência de uma decisão proferida em processo de que não foi parte; mas não há qualquer razão para dizer que ele não deve perder a sua causa em consequência de uma decisão proferida em um processo em que foi parte, simplesmente porque o seu adversário não foi²⁰.

A introdução do conceito romano de *res judicata* no direito inglês fez com que o *estoppel*, concebido como exigência de presumir verdadeiras as alegações de fato deduzidas e declaradas no processo, aproximasse-se da ideia de coisa julgada, de modo que a preclusão sobre os fatos passou a ser aceita como uma consequência da coisa julgada. Basicamente, entendeu-se que, se a coisa julgada faz recair efeitos preclusivos sobre o resultado final do processo ou sobre a parte dispositiva da decisão, o *estoppel* acobertava as passagens ou as questões de fato solucionadas pelo juiz para chegar ao desenlace do litígio²¹. Daí o motivo pelo qual se passou a falar em *estoppel by judgment*.

Porém, ainda que concebido como *estoppel by judgment*, o instituto prosseguiu relacionado apenas com os fatos e, inclusive, influenciou a inserção da coisa julgada no espaço teórico da “prova dos fatos”²². Deixando-se de lado as diversas teorizações que demonstraram que a coisa julgada se situa em lugar diferente, em que a definição dos fatos não tem qualquer importância teórica²³, interessa, desde logo, lembrar que o problema da preclusão da rediscussão das questões de direito era encoberto pelo *stare decisis*, suficiente para impedir uma Corte a retornar a uma questão de direito que já decidira.

Não obstante, devido à percepção de que na grande maioria dos casos concretos a distinção entre questão de fato e questão de direito era artificial²⁴, tanto a doutrina, quanto as Cortes estadunidenses, inclusive a Suprema Corte, passaram a entender que o *collateral estoppel* também se aplica às “issues of law”²⁵, evidenciando-se que os efeitos preclusivos derivados de uma decisão desfavorável sobre questão de direito não se confundem com a autoridade dos precedentes²⁶.

Sobre o tema do *collateral estoppel* diante de questão de direito, é interessante considerar a decisão da Suprema Corte estadunidense em *Montana v. U.S.*, proferida em fevereiro de 1979²⁷. Nesse caso, o governo dos Estados Unidos, enquanto responsável por exigência fiscal imposta pelo estado de Montana, recebeu decisão desfavorável da Suprema Corte deste estado. Num segundo processo, o governo dos Estados Unidos voltou a questionar a constitucionalidade da imposição fiscal perante Corte do Distrito de Montana, que, após declarar que o governo não estava proibido de voltar a discutir a questão de constitucionalidade em virtude da primeira decisão da Suprema Corte do estado, reconheceu que a exigência fiscal feria a Constituição. Porém, em razão de *appeal* do estado de Montana, a Suprema Corte dos Estados Unidos declarou que a primeira decisão da Suprema Corte de Montana proibia a rediscussão da constitucionalidade da exigência fiscal, declarando a legitimidade do *collateral estoppel* em face de uma questão de direito²⁸.

Frise-se que a Suprema Corte dos Estados Unidos, nesse caso, claramente considerou que estava diante de uma proibição de relitigar questão de direito em virtude de anterior decisão, ou seja, não supôs que havia impossibilidade de rediscussão da questão por existir um precedente. Tanto é que analisou se o governo dos Estados Unidos teve “full and fair opportunity” no primeiro processo e, por conta disso, decidiu que o governo estava *estopped* de buscar uma decisão contrária à questão num segundo processo²⁹. Como é evidente, esta análise seria completamente desnecessária caso a Suprema Corte tivesse admitido que estava diante de um precedente, quando, obviamente, não importaria quem teve “full and fair opportunity” de participar.

Em 1996, a Suprema Corte estadunidense não só voltou a afirmar o *collateral estoppel* diante de questão de direito, como declarou que o *collateral estoppel* não poderia obstaculizar a participação de quem não foi adequadamente representado na primeira ação. Em *Richards v. Jefferson County*,³⁰ após três contribuintes terem arguido a inconstitucionalidade de uma taxa de ocupação estabelecida pelo condado – *Jefferson County* –, que restou reconhecida constitucional pela Corte estadual, outro grupo de contribuintes, mediante *class action*, voltou-se contra a constitucionalidade da mesma taxa. A Suprema Corte estadual decidiu que o segundo grupo de contribuintes estava proibido de discutir a questão em virtude do *collateral estoppel*, ou seja, dos efeitos preclusivos da decisão proferida na primeira ação – que ficou conhecida como “Bedingfield action”. Mas a Suprema Corte dos Estados Unidos, ao julgar o caso, declarou que a decisão da Corte estadual, ao proibir os contribuintes que não participaram do processo de discutir a mesma questão de constitucionalidade, negou o precedente firmado em *Hansberry v. Lee* – célebre por ter firmado a necessidade da “representação adequada” para compatibilizar a *class action* com a garantia constitucional de participação no processo³¹ –, além de ter violado o *due process*³².

Ao decidir a partir da *opinion* do Justice Stevens, a Suprema Corte dos Estados Unidos lembrou ser pacífica a ideia de que ninguém pode ser prejudicado por uma decisão proferida em processo de que não foi parte, advertindo que esta ideia faz parte de uma tradição histórica profundamente enraizada nos Estados Unidos, de que todos têm direito a um dia perante a Corte. Ao adentrar no argumento de que a Suprema Corte estadual, para aceitar o *collateral estoppel* em face do grupo de contribuintes presente no segundo processo, admitiu que os contribuintes presentes no primeiro processo teriam representado adequadamente os contribuintes do segundo processo³³, a Suprema Corte estadunidense passou a tratar da inexistência de “representação adequada” na “Bedingfield action”³⁴.

A Suprema Corte lembrou que, em *Hansberry v. Lee*, declarou que subordinar litigantes a uma decisão proferida num processo em que não foram partes, e em que não foram “adequately represented”, viola a cláusula do *due process*, prevista na 14.a Emenda. A Suprema Corte, então, advertiu que a decisão da Corte do Alabama estava a apresentar a mesma questão num diferente contexto. Observou que os contribuintes que participaram do primeiro processo não falaram em nome da classe de contribuintes presente no segundo processo. A *opinion* do Justice Stevens afirma que, como os autores da segunda e da primeira ação são mais bem descritos como “strangers” uns aos outros, não há como pensar em representação adequada, de modo a tornar o alcance dos contribuintes do segundo processo de acordo com o *due process*³⁵. Como os contribuintes da primeira demanda atuaram em nome próprio, negou-se ter ocorrido cuidado em tutelar os interesses dos membros da classe na forma determinada em *Hansberry v. Lee*. Assim, a Suprema

Corte dos Estados Unidos concluiu que a decisão que estava sob análise, ao declarar que as partes estavam subordinadas à decisão tomada em “Bedingfield”, violou a garantia do *due process of law*³⁶, demonstrando que a circunstância de alguns poderem discutir uma questão de direito, que também diz respeito ao direito de outros, jamais pode excluir o direito dos últimos de falar direta ou indiretamente – mediante representação adequada – perante a Corte.

1.6. A aproximação entre o *collateral estoppel* e o *stare decisis*. Quando o *collateral estoppel* é relacionado às questões de direito, como, por exemplo, à questão de se saber se uma determinada imposição fiscal é constitucional, também resta preclusa a parte que plenamente participou do processo a possibilidade de voltar a discutir a questão em outra demanda, ainda que diante de litigante diverso. Vale aqui a já lembrada advertência de Bentham, no sentido de que não há razão para sustentar que alguém não deve perder a sua causa em consequência de uma decisão que proferida em processo em que foi parte, simplesmente porque o seu adversário não foi³⁷. Frise-se que a ideia do *non-mutual collateral estoppel* é exatamente a de que, se alguém já teve o devido espaço para discutir uma questão, não há motivo para ter outra oportunidade para discuti-la, pouco importando se diante da mesma parte com quem anteriormente litigou, ou diante de um novo litigante.

Mas o *stare decisis* também impõe uma decisão (*rectius*: *ratio decidendi*) que resolve questão de direito. Assim, é possível ver uma superposição parcial entres os efeitos do *stare decisis* e do *non-mutual collateral estoppel*. Em razão do *stare decisis*, todos restam vinculados ao precedente, enquanto que, em razão do *collateral estoppel*, a decisão da questão de direito vincula as partes que puderam discuti-la em pleno contraditório.

Isso sucede em razão de o *stare decisis* e de o *collateral estoppel* terem objetivos semelhantes. Ora, se o *stare decisis* objetiva resguardar a coerência do direito, a igualdade e a segurança jurídica, é certo que impedir a busca de uma decisão diferente acerca de uma mesma questão diante de outro litigante tutela os mesmos valores, embora, como é óbvio, com uma intensidade distinta. Lembre-se, aliás, que o primeiro artigo do Capítulo “Do incidente de resolução de demandas repetitivas” – o art. 976 do CPC/2015 –, afirma que o incidente de resolução pode ser instaurado quando houver, simultaneamente, “efetiva repetição de processos” em que se controverta “a mesma questão” de direito e “risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica”.

Porém, o *collateral estoppel* tem grande particularidade em relação ao *stare decisis*. O *collateral estoppel* apenas pode prejudicar os litigantes que participaram do processo em que a decisão foi proferida, ao passo que o *stare decisis* vincula todos os juízes e tribunais, afetando todos os jurisdicionados.

1.7. O equivocado uso da ideia de “precedente” para justificar a decisão de questão prejudicial de muitos em incidente destituído de possibilidade de participação em contraditório. O legislador brasileiro tentou legitimar a não participação no incidente de resolução de demandas mediante uma norma confusa e contraditória, que, ao elencar decisões de diferentes espécies como se fossem “precedentes”, afirma que “os juízes e tribunais observarão” o acórdão em incidente de resolução de demandas repetitivas (art. 927, III, do CPC/2015).

Obrigar a observar uma decisão proferida em local em que o litigante do caso sob julgamento não participou só tem sentido quando se pensa em sistema de precedentes ou *stare decisis*. De fato, o legislador, equivocadamente, pensou que poderia suspender o exercício do direito de ação para fomentar a criação de um precedente aplicável a todos. Raciocinou como se precedente fosse um nome mágico, capaz de legitimar a imposição de uma decisão a quem não teve oportunidade de participar. Tanto é verdade que disse, no art. 985 do CPC/2015, que, julgado o incidente, a tese jurídica também será aplicada “aos casos futuros” (art. 985, II, do CPC/2015).

Deixando-se de lado – por enquanto – a diferença entre as preclusões relativas a um precedente e à coisa julgada sobre questão, importa, sobretudo, perceber que não há como paralisar o direito de influir sobre a Corte para formar um precedente, dando-lhe efeito retroativo.

Um precedente surge naturalmente do exercício do direito de ação e dos casos que são

submetidos à Corte. Suspender o exercício do direito de participar para formar um precedente retroativo é, sem qualquer dúvida, não só ignorar que o jurisdicionado tem direito a um dia perante a Corte, mas, também, não perceber que o objetivo do sistema de precedentes é regular o modo de ser do direito e não resolver casos de massa.

Uma técnica de resolução de casos múltiplos não pode considerar situações jurídicas de massa para privilegiar o encontro de uma decisão sem a participação dos membros do grupo afetado. Isso constituiria uma ilegítima priorização da otimização da prestação jurisdicional sobre o direito fundamental de participar do processo.

1.8. Distinção entre resolver “questão” de terceiros e firmar precedente. As Cortes Supremas, nos termos da Constituição Federal, têm a incumbência de outorgar sentido ao Direito, propiciar o seu desenvolvimento e garantir a unidade da sua aplicação. Portanto, o sistema de precedentes tem o objetivo de outorgar autoridade às *rationes decidendi* firmadas pelas Cortes Supremas. Diversos casos, marcados por diferenças razoáveis, podem ser resolvidos por um precedente que define o sentido do direito. Porém, as decisões firmadas nos incidentes de resolução de demandas repetitivas não têm qualquer preocupação em orientar a sociedade, ou a regular o modo de ser do direito, mas objetivam resolver uma mesma questão litigiosa prejudicial à solução de inúmeros casos pendentes. O incidente de resolução é uma técnica processual destinada ao encontro de uma decisão para a questão replicada nas múltiplas ações pendentes. Bem por isso, como é óbvio, a decisão proferida no incidente de resolução de demandas repetitivas apenas resolve questões idênticas. Essa é a distinção básica entre o sistema de precedentes das Cortes Supremas e o incidente destinado a dar solução a uma questão prejudicial a múltiplos casos.

A circunstância de o incidente de resolução tratar de “idêntica questão” (art. 985, I e II, do CPC/2015) tem clara repercussão sobre o raciocínio que dá origem à decisão judicial. Essa decisão, obviamente, não é elaborada a partir da regra da universabilidade, ou seja, da regra que determina que um precedente deve ser aplicável ao maior número de casos possíveis³⁸. A decisão de resolução de demandas repetitivas objetiva regular uma “mesma questão” (art. 976, I, do CPC/2015) infiltrada em casos que se repetem ou se multiplicam.

Assim, a técnica da distinção não tem a mesma relevância em se tratando de resolução de demandas repetitivas. Nesses casos, caberá a distinção apenas para demonstrar que determinada questão é diferente daquela que foi já resolvida ou submetida ao incidente. Mas aí jamais se utilizará a técnica da distinção para limitar, ou ampliar, o alcance do precedente em razão de circunstância não considerada no momento da sua elaboração. Isso só pode ocorrer quando o precedente revela o direito que é racionalmente aplicável a determinada situação concreta, o qual, assim, pode não ser aplicável em face de certa situação ou ser racionalmente aplicável diante de outra.

Ademais, um precedente pode ser revogado, daí importando as situações que surgiram com base na confiança nele depositada. No entanto, a decisão proferida no incidente produz coisa julgada *erga omnes*, podendo ser “revista” para os casos futuros apenas por legitimado adequado que não litigou a questão ou por litigante que foi representado, mas não havia proposto demanda individual, sempre com base em fundamento que não foi decidido, ou seja, com base em fundamento que poderia ter sido deduzido – mas não foi – para a discussão da questão decidida e objeto de revisão. Frise-se que a questão decidida não é apenas de titularidade dos litigantes dos casos pendentes, mas, também, daqueles que podem litigar no futuro. Para os últimos, há atenuação do efeito preclusivo da coisa julgada que recaiu sobre a questão decidida.

Os litigantes afetados pela decisão tomada no incidente têm uma possibilidade de argumentar em face da aplicação da decisão que é muito mais restrita do que a do litigante diante do precedente. E isso pela razão de que a questão decidida no incidente é idêntica; ou seja, é a mesma. Se a questão é a mesma, a decisão será, inapelavelmente, aplicada em todos os casos pendentes. Como já dito, a lógica da aplicação do precedente, por ser outra, não impede o litigante do caso sob julgamento de demonstrar que a questão sob julgamento, apesar de formalmente parecer igual, tem particularidades que a diferenciam, impedindo a aplicação do precedente.

Como também já lembrado, há sempre possibilidade de a parte argumentar no sentido do desgaste ou da necessidade da superação do precedente, sendo isto impossível no caso de decisão de questão tomada para casos pendentes. Aliás, no caso de precedentes são admitidas técnicas de operação que consistem em distinções inconsistentes ou que se destinam à manutenção formal do precedente para a adequada resolução do caso, ou para a não violação da confiança justificada³⁹. Bem vistas as coisas, o litigante não tem seus direitos processuais preclusos em virtude de um precedente; esse, vincula o juiz. Preclusão propriamente dita ocorre no caso de decisão de questão, pois esta proíbe que a parte afetada – mas que participou do processo – volte a relitigá-la.

Note-se que não há como tomar em conta uma situação conflitiva, de que podem surgir inúmeras pretensões à tutela de direitos individuais, e instaurar processo para firmar precedente destinado a vincular a todos. O precedente é consequência da tarefa jurisdicional de atribuir sentido ao direito e regular casos futuros; não pode ser visto como técnica de resolução de demandas que derivam de um específico caso conflitivo concreto.

Para que fique mais claro, convém um exemplo: a decisão do Superior Tribunal de Justiça que declarou a responsabilidade objetiva da LATAM diante de um acidente aéreo, ao observar determinados critérios, constitui precedente capaz de regular caso relativo a acidente da GOL. Porém, a decisão desfavorável – que declarou não existir responsabilidade – a familiares de passageiro envolvido no acidente da GOL não pode ser invocada por esta companhia aérea para proibir os familiares de outro passageiro envolvido no mesmo acidente de discutir a responsabilidade. Todos os familiares dos mortos em acidente aéreo têm direito de reivindicar seus direitos e, assim, de discutir perante o Tribunal as questões que lhes dizem respeito. A menos que prefiram ter à frente representante adequado, capaz de efetivamente discutir, e postular, os seus direitos mediante ação coletiva.

Se o precedente firmado no caso LATAM pode orientar o julgamento do caso GOL, isso não quer dizer que os familiares das vítimas estejam proibidos de discutir questões ou tenham seus direitos constitucionais de ação limitados. Têm eles o direito de argumentar mediante a técnica da distinção e de apontar para a necessidade de revogação do precedente, embora possam ter que se render ao sentido do direito delineado pela Corte Suprema, na medida em que, como é óbvio, todos estão subordinados à ordem jurídica.

Tudo isso significa, de modo inquestionável, que a decisão do incidente não pode ser compreendida como um precedente, mas como inusitada decisão de questão de muitos em local que veda a participação em contraditório. Exatamente por isso, é preciso resgatar a constitucionalidade do incidente de resolução (a seguir, itens 1.15 e 1.16), abrindo-se oportunidade para a participação dos representantes adequados dos litigantes excluídos.

1.9. O direito fundamental de ação enquanto direito de discutir a questão e influenciar o convencimento do juiz. O direito fundamental de ação, garantido pelo art. 5º, XXXV, da CRFB/1988, tem como corolário o direito de efetivamente participar em contraditório do processo para influir sobre o convencimento do juiz. Não fosse assim, de nada valeria afirmar que ninguém pode ser lesado ou privado dos seus bens sem o devido processo legal, ou melhor, sem poder ser ouvido pela Corte.

Não é por outro motivo que, nos Estados Unidos, não se admite que alguém possa ser prejudicado por uma decisão relativa a questão prejudicial que não teve oportunidade de discutir em contraditório. Ora, o contrário estaria ferindo o direito de todo e qualquer cidadão a um dia perante a Corte ou o direito ao devido processo, que também pode ser visto como direito de influenciar a Corte, corolário do nosso direito fundamental de ação.

Como é óbvio, não é apenas nos Estados Unidos que todos têm “right to a day in Court”. Portanto, não há como ter como legítima, no direito brasileiro, a afetação da esfera jurídica de alguém que não teve oportunidade de discutir uma questão de direito que é prejudicial à solução do seu caso. Retenha-se o ponto: se o CPC/2015 admite falar em coisa julgada sobre questão (art. 503 do CPC/2015) e, igualmente, em coisa julgada em benefício de terceiro (art. 506 do CPC/2015), assemelhando o sistema brasileiro ao estadunidense, isto, certamente, não quer dizer que alguém

possa ser prejudicado por uma decisão de questão proferida em processo em que não foi chamado a participar. Na verdade, isto negaria a própria mensagem do art. 506 do CPC/2015, no sentido de que “a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros”.

Por identidade de razões, não há como suspender processos pendentes, em que jurisdicionados estão exercendo o seu direito fundamental de ação, para vinculá-los a uma decisão proferida em “incidente” que não lhes confere o direito de falar e de influenciar a Corte.

1.10. A questão da afetação de terceiro pela decisão de questão (*non-mutual collateral estoppel*) nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos é obviamente pacífica a ideia de que ninguém pode ser afetado por decisão tomada em processo de que não participou⁴⁰. Exige-se para a admissão do alcance da parte não apenas a sua citação para poder participar do processo, mas também que tenha tido “full and fair opportunity” para litigar⁴¹.

Assim, por exemplo, se um procedimento não deu à parte oportunidade de discutir plenamente a questão, não há racionalidade em proibi-la de discuti-la em nova ação. Até porque a lógica do *collateral estoppel*, obviamente, desejar negar não só a possibilidade de discutir “questão decidida”, mas, antes de tudo, questão efetivamente discutida. Em *Parklane*, a Suprema Corte analisou se existiam outros meios processuais que, não tendo sido oportunizados no procedimento do primeiro caso, poderiam ter gerado um resultado diverso. A partir desta e outras considerações, declarou a propriedade da invocação do *collateral estoppel* por ter a parte tido “full and fair opportunity do be heard”⁴².

Porém, é preciso também observar que a busca de otimização da prestação jurisdicional obrigou a distinções teóricas e levou à elaboração de teses destinadas a justificar o alcance de pessoas que, a princípio, não estariam na posição de partes. Uma conhecida limitação à impossibilidade de a decisão afetar “não-partes” está na chamada “rule of privity”. Admite-se que “não-partes” possam ser afetadas por uma decisão quando têm uma relação especial com as partes, ou seja, quando têm com as partes uma relação de “privity”⁴³. Assim, por exemplo, um beneficiário da herança poderia ser afetado pela decisão tomada numa ação em que apenas o seu administrador foi parte.

Também se pretendeu, no direito estadunidense, justificar o atingimento de “nonparties” com base na ideia de “virtual representation”. Bastaria, em uma perspectiva larga da aplicação desta ideia, que parte e “não partes” estivessem diante de um mesmo quadro de fato e com interesse num mesmo resultado. Contudo, a tese da representatividade virtual, nestes termos, foi forte e amplamente rejeitada pelas Cortes estadunidenses⁴⁴. A Suprema Corte dos Estados Unidos teve oportunidade de declarar, em *Martin v. Wilks*, que “nonparties” não podem ser alcançadas por uma decisão, simplesmente, porque os seus interesses são “essentially identical” aos daqueles que participaram do processo⁴⁵.

1.11. Participação e representação adequada: não há qualquer preocupação com “representação adequada” no incidente de resolução de demandas repetitivas. A decisão proferida em *Martin v. Wilks*, é certo, poderia ser vista de outra forma. Este caso envolve uma decisão estrutural, voltada à eliminação de discriminação racial contra negros no corpo de bombeiros de Birmingham. Em *Martin v. Wilks*, um grupo de bombeiros brancos, que não participara do processo, postulou a invalidade da decisão estrutural sob o argumento de que esta impunha à municipalidade a prática de ações inconstitucionais. Alegou-se que a decisão estrutural, ao afirmar e impor um sistema de preferência por negros, teria criado uma discriminação inversa. A decisão da Suprema Corte não tratou da questão da discriminação contra os negros ou mesmo do argumento da segunda ação, no sentido de que decisão estrutural estava a impor condutas inconstitucionais à municipalidade. Decidiu-se que os bombeiros brancos, por não terem participado do processo, tinham direito a uma decisão sobre a sua demanda, ou seja, tinham direito de saber se a decisão estrutural estava a impor ações inconstitucionais.

A pretensão exercida em *Martin v. Wilks* colocou em jogo a efetividade de uma *injunction* estrutural, ou seja, da mais importante forma de tutela de direitos civis nos Estados Unidos, mediante a qual se pode buscar reestruturar uma organização burocrática para torná-la de acordo

com a Constituição. Decisão desta natureza, além de carregada de relevante impacto social, atinge grande número de indivíduos e mesmo diferentes grupos de sujeitos.

Nessa dimensão, é possível questionar se a ideia de direito de participação dos bombeiros brancos, prejudicados pela decisão estrutural, poderia inviabilizá-la. Perceba-se, em outras palavras, que se poderia até dizer que a decisão proferida em *Martin v. Wilks* contém um fundamento que, quando visto em face da natureza da decisão estrutural destinada a remover um estado de discriminação racial, tem um caráter individualista que o deslegitima⁴⁶.

Porém, ainda que se possa distinguir participação de representação para efeito de legitimar a decisão proferida em face de quem não participou, há que se ter em conta que a representação, para poder suprir o direito de participar, deve ser necessariamente adequada. Nessa altura dos estudos sobre a tutela coletiva, não se pode negar que o direito fundamental de ser ouvido pela Corte é totalmente compatível com a representação adequada. Nesse caso, a participação, indispensável para a legitimação do exercício do poder, é indireta, e, por isso mesmo, exige a aferição da qualidade da representação, que, certamente, não pode ser qualquer uma.

Lembre-se que a *class action* do direito estadunidense, embora possa ser proposta por qualquer um do grupo, depende de representação adequada⁴⁷. Tem legitimidade para a *class action* aquele que, ao propor a ação, é declarado representante adequado. A adequação da representação é aferida, e declarada, no caso concreto. A representação é adequada não só quando o representante tem motivo e razão para tutelar os direitos dos membros do grupo, mas, também, quando o seu advogado e assistentes técnicos têm capacidade técnica para exercer a defesa dos direitos.

Ademais, se o representante é automeado, os membros da classe têm que ter oportunidade para impugnar a adequação da representação. É por isso que se faz a notificação dos membros, comunicando-lhes o que está para ocorrer perante o juiz e a respeito das qualidades do representante. Desta forma, abre-se oportunidade para a impugnação da representação e à Corte melhor espaço para o cumprimento do seu dever de zelar pelo devido processo legal, analisando rigorosamente a capacidade do representante para encabeçar a ação e defender os direitos da classe. A notificação pretende assegurar que o automeado representante seja um defensor efetivo, e vigoroso, para todos os membros do grupo. Afinal, o *due process*, ao deixar de depender da participação direta, requer adequação da representação para que o exercício do poder jurisdicional não se constitua em arbítrio.

No direito brasileiro, a representação adequada também é imprescindível nas ações voltadas à tutela de direitos transindividuais e individuais homogêneos. Na verdade, a representação adequada é indispensável em qualquer sistema que tutele direitos sem a participação direta dos seus titulares. Tratando-se de compensação da participação direta e, portanto, de mecanismo destinado a permitir a participação em local em que o poder estatal é exercido, a representação adequada é elemento integrante da estrutura do processo civil democrático.

O que pode variar, assim, é apenas a forma para alcançá-la. No direito estadunidense, qualquer membro do grupo, efetivamente compromissado com os direitos da classe e apto a defendê-los com vigor, pode automear-se representante. Porém, além da notificação que deve ser feita aos membros do grupo, de modo a informá-los sobre o que ocorrerá perante o juiz e a respeito das funções e qualidades do representante, há oportunidade para impugnação da representação, bem como para requerimento de exclusão do grupo (*right to opt out*). No Brasil, como é sabido, a representação adequada é definida em lei, especialmente na Lei da Ação Civil Pública (Lei 7.347/1985) e no Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990), mas também em outros microssistemas, como, exemplificativamente, no Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/1990), na Lei de proteção da mulher contra a violência doméstica (Lei 11.340/2006), na Lei de tutela do idoso (Lei 10.741/2003), na Lei de tutela das pessoas portadoras de deficiência (Lei 7.853/1989), na Lei de tutela dos negros contra a discriminação racial (Lei 12.228/2010) e na Lei de tutela dos investidores do mercado de valores mobiliários (Lei 7.913/1989).

No direito brasileiro, quando os direitos individuais homogêneos estão *em jogo*, é impossível pensar em excluir o representante adequado, sob pena de violação ao devido processo legal.

Portanto, o incidente de resolução de demandas deveria ter previsto, nos moldes da tradição do direito brasileiro, a participação dos legitimados adequados à tutela dos direitos dos litigantes excluídos. Contudo, o incidente nada previu em termos de representação adequada. Como já dito, o legislador partiu da premissa de que o incidente não estaria a resolver questão da titularidade dos litigantes das demandas repetitivas, mas, simplesmente, abrindo oportunidade à elaboração de precedente obrigatório (art. 927, III, do CPC/2015) sobre questão de direito – curiosamente do interesse dos litigantes excluídos.

Olhando-se o incidente à luz da representação adequada, seria possível dizer que qualquer litigante das demandas que se repetem pode se autonear representante ou imputar a outro litigante este encargo, nos moldes do sistema estadunidense. Ocorre que, nos Estados Unidos, confere-se aos membros da classe oportunidade para impugnar a representação adequada – que, frise-se, também se estende à possibilidade de impugnação da capacidade técnica do advogado –, além de sair do grupo. Mais do que isso: no direito estadunidense o juiz tem dever de, rigorosamente, controlar a adequação da representação no caso concreto, evitando não só exercer poder em face de pessoas ou grupos destituídos de voz, mas, também, afetar sujeitos ou classes que não têm condição de influenciar o seu convencimento.

Em contrapartida, no incidente pouco importa se o litigante que se coloca como autor, ou a quem é imposta a condição de réu pelo seu adversário, tem vontade e capacidade técnica para estar à frente dos litigantes excluídos. Esta é uma questão ignorada pela lei processual. Assim, certamente, não se verifica, por exemplo, se o autor ou o réu que se coloca no lugar dos excluídos sustentou suas razões no julgamento do incidente, nos termos do art. 984, II, *a* do CPC/2015, que confere ao autor e ao réu do processo originário o prazo de trinta minutos para tanto. Também se ignora se o advogado da parte que faz as vezes dos excluídos é habituado a sustentações orais no tribunal, ou se a parte tem condições financeiras para sustentar a viagem do seu advogado à sede de Tribunal Regional Federal, quando o processo originário é oriundo de comarca sediada em outro estado. Estes são apenas exemplos para evidenciar o completo descaso em relação à representação adequada da parte do processo originário, o qual pode se tornar ainda mais dramático quando se tem em conta que o processo originário, que deu início ao incidente, pode ser estrategicamente identificado pelo litigante que é parte em todas as demandas repetitivas para ter a oportunidade de se defrontar perante o tribunal com parte cujo advogado não vem se esforçando na defesa do seu constituinte, ou já apresentou peças processuais com argumentação insuficiente.

No incidente também não importa a vontade dos litigantes excluídos, que não podem deixar de se submeter à decisão, estando, aliás, numa posição muito mais difícil do que a dos titulares de direitos individuais homogêneos representados na ação coletiva pelos legitimados *ope legis* à propositura da ação coletiva. É que, na ação coletiva para tutela de direitos individuais homogêneos, a coisa julgada não prejudica os representados em caso de improcedência do pedido (art. 103, III, do CDC). Anote-se que o art. 103, § 2.º do CDC afirma que, “na hipótese prevista no inciso III, em caso de improcedência do pedido, os interessados que não tiverem intervindo no processo como litisconsortes poderão propor ação de indenização a título individual”.

Por fim, sequer se imagina a possibilidade de os excluídos não concordarem ou impugnarem a presença de determinado litigante como representante adequado no incidente. Na verdade, todo o raciocínio antes desenvolvido foi realizado apenas para demonstrar que o legislador, obviamente, não viu a parte presente no incidente como um representante adequado.

Se a participação é imprescindível para a legitimação do exercício do poder jurisdicional, nos processos em que direitos são reivindicados à distância da presença dos seus titulares, a representação adequada é a fórmula que dá corpo ao devido processo legal. No incidente de resolução de demandas repetitivas sequer se pensou na necessidade de representação adequada, seja na representação adequada *ope legis*, prevista, especialmente, na Lei da Ação Civil Pública e no CDC, seja numa eventual – e em desacordo com a tradição do direito brasileiro – representação adequada *ope judicis*. Isso fica absolutamente claro em face do modo como o incidente trata da participação das partes do processo originário no incidente, que não podem ter a sua condição de representante adequado sequer aferida pelo tribunal ou impugnada pelos litigantes não-partes do

incidente. Assim, não obstante se possa deixar de lado a ideia de que o devido processo legal depende, necessariamente, de participação direta, admitindo-se a suficiência da representação adequada em caso de processo coletivo, não há qualquer possibilidade de sustentar que o incidente de resolução de demandas repetitivas, nos termos em que estruturado pelo CPC/2015, está de acordo com o *due process*.

1.12. Incidente de resolução de demandas enquanto justiça dos demandantes “sem rosto e sem fala”. O incidente de resolução de demandas repetitivas parte do pressuposto de que os interessados na decisão a ser proferida, e que, portanto, indiscutivelmente, têm o direito constitucional de discutir a questão a ser decidida, não precisam ser representados. É absurdo, porém verdadeiro. O Código de Processo Civil alude apenas àqueles que podem requerer a instauração do procedimento (art. 977 do CPC/2015) e à possibilidade de manifestação de “pessoas, órgãos e entidades com interesse na controvérsia” (art. 983 do CPC). Nada diz sobre aqueles que estariam representando os interessados, num bizarro esquecimento do significado de processo civil democrático e de tutela coletiva dos direitos.

O incidente de resolução de demandas, nos termos em que está posto pelo Código de Processo Civil, constitui uma técnica que nega o direito fundamental de ação, ou seja, o direito a um dia perante a Corte, dando origem a uma espécie de “justiça dos cidadãos sem rosto e fala”, para a qual pouco importa saber se há participação ou, ao menos, “representação adequada”.

1.13. Ilegítima e inconstitucional opção por quem viola direitos em massa. Mas a situação é ainda pior. O incidente não apenas cala os interessados, que na verdade são as pessoas que tiveram os seus direitos violados em massa e, assim, necessitam propor ações individuais que contêm questões prejudiciais idênticas. Bem vistas as coisas, o incidente privilegia aqueles que violam direitos ou produzem danos em massa.

É interessante retornar ao direito estadunidense para demonstrar a que ponto de ilegitimidade constitucional chegou o procedimento do incidente. Nos Estados Unidos, utiliza-se o *collateral estoppel* em casos de acidentes que dão origem a múltiplos danos. Assim, por exemplo, em casos de acidentes aéreos e ferroviários. Num acidente deste tipo, se existem centenas de prejudicados, a derrota da empresa dita responsável na primeira ação pode torná-la responsável perante os demais prejudicados – obviamente que considerada, entre outros pontos, a devida oportunidade de participação da empresa no processo em que a decisão foi tomada.

Contudo, como a decisão não pode prejudicar aquele que não participou do processo, uma decisão em favor da empresa, que negue a sua responsabilidade no acidente, não se estende aos demais acidentados, impedindo-os de relitigar a questão da responsabilidade. Essa circunstância, que obviamente não poderia ser pensada de outro modo sob pena de violação do “right to a day in Court”, levou a doutrina estadunidense a afirmar que o *offensive collateral estoppel*, nos casos de danos múltiplos, estaria a impor um excessivo ônus de defesa àquele a quem a responsabilidade é atribuída. O dito responsável, para se livrar do dever de indenizar, teria que se defender em todas as ações individuais.

Quando alguém pode ser responsabilizado diante de muitos em razão de uma decisão desfavorável, mas nenhuma vantagem tem em face dos demais ao obter uma decisão positiva, surge aos membros do grupo inúmeras chances – a dar origem a diversas estratégias – para a obtenção de decisão favorável; ao passo que aquele que pode ser responsabilizado assume uma pesada posição, considerando-se a necessidade de o procedimento e a técnica processual tratar as partes de modo equilibrado.

Para resolver o problema, foram apresentadas várias alternativas⁴⁸. Entre elas, argumentou-se que a parte que pode ser afrontada por muitos pode requerer a chamada de todos para participar da primeira ação proposta. Mas, se não há chamamento por desídia do sujeito dito responsável, esse continua sujeito a tantas demandas quantos forem os prejudicados, sempre se sujeitando aos efeitos da questão preclusa ou da proibição de relitigar.

Lembre-se que, como o terceiro prejudicado não pode ser proibido de discutir a questão

decidida, o *non-mutual collateral estoppel* apenas pode ser invocado em face da parte que adequadamente participou em contraditório. Porém, quando um conflito envolve centenas de lesados em face de uma empresa dita responsável, advertiu-se, para evitar um pesado ônus ao afirmado infrator, que esse pode requerer o chamamento de todos aqueles que podem demandá-lo (mandatory joinder⁴⁹). A convocação dos terceiros ocorre para que o dito infrator não seja excessivamente exposto à necessidade de se defender e, assim, para que os seus direitos processuais não sejam tratados de forma desequilibrada diante dos direitos dos seus adversários. Perceba-se que o direito estadunidense transforma a ação individual numa ação coletiva, em que todos os lesados participam, para preservar o grande benefício da proibição de relitigação de uma mesma questão⁵⁰.

No Brasil o raciocínio é exatamente oposto, capaz de estimular os interesses dos violadores de plantão. Opta-se por uma estratégia em que se nega participação aos lesados e se confere ao infrator a oportunidade incondicional de estar presente no único local em que a questão será resolvida. O incidente simplesmente prefere ignorar os lesados, dando oportunidade para o afirmado violador ou responsável, participar sem ter qualquer adversário capaz de representar aqueles que entendem que os seus direitos foram violados. Diante do incidente, ao invés de se privilegiar o direito constitucional de participar dos lesados, consagra-se a oportunidade de o infrator sempre estar presente, concentrando esforços num único local.

1.14. O descaso em relação à ação coletiva e a preferência pelo incidente de resolução de demandas repetitivas. A sociedade contemporânea é uma sociedade de massa – de produção em massa. Os conflitos de massa nada mais são do que uma particularidade deste modelo de sociedade. Nestes conflitos, um dos polos é sempre ocupado pelo produtor ou fornecedor e o outro pelos vários usuários, consumidores ou simplesmente lesados. Essa relação fez surgir o que foi designado pelo legislador de “direitos individuais homogêneos”, para os quais foi estabelecido um modelo procedimental diferenciado, caracterizado por uma nova ideia de legitimidade para a causa – dos legalmente definidos como representantes adequados (art. 5.o da Lei 7.347/1985 – Lei da Ação Civil Pública –, e art. 82 do CDC) – e de coisa julgada material – *erga omnes* (art. 103, III, CDC).

A coisa julgada *erga omnes* é sustentada pela outorga de legitimidade a entes vistos pelo legislador como capazes de efetivamente representar, e tutelar, os direitos das pessoas que não participam diretamente do processo. Embora a outorga de legitimidade *ad causam* a entes capazes constitua o ponto chave da aprovação do procedimento legal em face do *due process*, o sistema faz questão de afastar a coisa julgada *erga omnes* quando o pedido é julgado improcedente. Em caso de improcedência, como diz o art. 103, § 2.º, do CDC, os interessados que não tiverem intervindo no processo como litisconsortes poderão propor as suas ações individuais.

Este sistema, além de preservar e garantir os direitos processuais constitucionais dos litigantes – que têm a garantia de serem adequadamente representados e, portanto, têm preservado o direito de participar e ser ouvido –, ainda representa um mecanismo que favorece uma posição ativa da sociedade diante do Estado⁵¹.

É difícil entender o motivo pelo qual o legislador tem sido indiferente à ação coletiva, como recentemente aconteceu quando deixou de considerar o projeto de reforma da Lei da Ação Civil Pública e, após, quando desprezou a importância da regulação de um adequado sistema coletivo de tutela de direitos no CPC/2015.

O legislador tem o dever de criar canais de comunicação entre a sociedade e o Judiciário, ou melhor, canais que viabilizem a participação do povo na reivindicação da tutela judicial dos seus direitos, sob pena de violar o seu dever normativo de tutelar os direitos fundamentais, especialmente, o direito fundamental de participação do cidadão no poder, ou seja, no processo em que os seus direitos são definidos.

Note-se que isto apenas pode ser feito mediante um canal ou procedimento que abra oportunidade à participação, vale dizer, ao exercício do direito de falar e de influir sobre a Corte, para o que, tratando-se de direitos de membros de grupos ou de direitos individuais homogêneos,

é obviamente imprescindível pensar em representação adequada ou na outorga de legitimação a entes capazes de representar os titulares dos direitos que deixam de participar diretamente.

Tudo evidencia, portanto, que o legislador de modo ilegítimo e inconstitucional preferiu instituir um incidente para a definição de direitos múltiplos sem que os seus titulares tivessem qualquer possibilidade de participação, ainda que indiretamente, mediante a representação dos entes capazes de representá-lo, como os já definidos na Lei da Ação Civil Pública e no CDC. Mas a pretensão do legislador torna-se ainda mais reprovável quando se vê que ele “facilitou as coisas” exatamente àqueles que não podem ser privilegiados em face dos direitos fundamentais, ou seja, àqueles que, frequentemente, se colocam na posição de violadores dos direitos em massa.

1.15. Correção da inconstitucionalidade. A doutrina tem sério e inafastável compromisso com os direitos fundamentais. Assim, obviamente, não pode dizer “amém” a um procedimento que, sob o pretexto de dar otimização à resolução das demandas, viola claramente o direito fundamental de ser ouvido e de influenciar o juiz.

Não há como negar a realidade: no incidente de resolução de demandas repetitivas julga-se questão de muitos em processo de alguns. Como é óbvio, se no Estado Democrático de Direito a participação é indispensável requisito de legitimação do exercício do poder, não há como imaginar que uma decisão – ato de positivação do poder estatal – possa gerar efeitos em face de pessoas que não tiveram oportunidade de participar ou não foram adequadamente representadas.

Contudo, a invalidade constitucional de um procedimento é resultado extremo, que deve ser evitado quando se pode corrigi-lo de modo a dar-lhe legitimidade constitucional. Admitindo-se que o legislador cometeu um equívoco, ou seja, que não quis excluir a possibilidade de participação indireta do litigante, porém apenas se esqueceu de regulá-la, há como aceitar a possibilidade de a doutrina e os tribunais, mediante interpretação, corrigirem o desvio do legislador, evitando-se, assim, a simples proclamação da invalidade ou da inconstitucionalidade do incidente, cuja repercussão sobre o novo sistema processual civil certamente não seria boa.

1.16. A ressurreição da força da representatividade adequada. Como já dito, o legislador limitou-se a definir aqueles que podem requerer a instituição do incidente de resolução: o juiz ou o relator, de ofício, as partes, o Ministério Público e a Defensoria Pública (art. 977 do CPC/2015). A norma mistura juiz e relator com partes de um caso repetitivo e com o Ministério Público e a Defensoria Pública. Evidentemente, os últimos, mas jamais os primeiros, podem ser vistos como representantes adequados dos litigantes excluídos de participação direta. Porém, o que faz a norma falar em Ministério Público e em Defensoria, evidentemente, não é o dever de tutela dos direitos dos membros do grupo, mas um mero interesse “público” de otimizar a administração da prestação jurisdicional.

Por outro lado, a ideia de ouvir “interessados” na solução da controvérsia, posta no *caput* do art. 983 do CPC/2015, nada tem a ver com a necessidade de dar voz aos excluídos, ou seja, com “representatividade adequada. Tem, isto sim, relação com a amplificação do debate em torno de questões de “interesse geral”. Note-se que o § 1.º do mesmo art. 983 diz que, “para instruir o incidente, o relator poderá designar data para, em audiência pública, ouvir depoimentos de pessoas com experiência e conhecimento na matéria”. Há aí nítida alusão à função exercida pelos *amici curiae* em Cortes vocacionadas à definição de questões jurídicas de interesse da sociedade. A instituição da técnica que abre oportunidade à intervenção de *amici* num incidente destinado à resolução de questão repetitiva – na maioria das vezes de simples solução e, unicamente, do interesse dos litigantes excluídos – é surpreendente, pois pretende incentivar o diálogo sobre questão que está proibida de ser discutida pelas próprias partes que têm o direito constitucional de litigá-la.

De qualquer forma, o art. 984 do CPC/2015 deixa ainda mais claro que as únicas partes que participam do incidente são o autor e o réu do processo originário. O art. 984, II, afirma que poderão sustentar suas razões, sucessivamente: a) o autor e o réu do processo originário e o Ministério Público, pelo prazo de trinta minutos, bem como b) os demais interessados, no prazo de trinta minutos, divididos entre todos. De acordo com o art. 976 do CPC/2015, o Ministério Público

tem obrigação de intervir como fiscal da lei. De modo que a norma claramente supõe que a participação do autor ou do réu seria suficiente. Porém, como já demonstrado, o código não vê a parte como “representante adequado”.

Quer dizer que, realmente, é preciso elaborar um raciocínio interpretativo sofisticado para salvar a constitucionalidade do procedimento. É necessário resgatar a força da representatividade adequada, considerando-se as normas da Lei da Ação Civil Pública e do Código de Defesa do Consumidor, que conferem legitimidade para a representação dos membros dos grupos perante as ações coletivas ou, mais especificamente, para a tutela dos direitos individuais homogêneos mediante a via coletiva.

Lembre-se que, de acordo com o art. 5. da Lei 7.347/1985 – Lei da Ação Civil Pública –, têm legitimidade para a ação civil pública: i) o Ministério Público; ii) a Defensoria Pública; iii) a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios; iv) a autarquia, empresa pública, fundação ou sociedade de economia mista; v) a associação que, concomitantemente: a) esteja constituída há, pelo menos, um ano nos termos da lei civil; e b) inclua, entre suas finalidades institucionais, a proteção ao patrimônio público e social, ao meio ambiente, ao consumidor, à ordem econômica, à livre concorrência, aos direitos de grupos raciais, étnicos ou religiosos ou ao patrimônio artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. Com o mesmo objetivo, o art. 82 do CDC define como legitimados à tutela dos direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos: “i) o Ministério Público; ii) a União, os Estados, os Municípios e o Distrito Federal; iii) as entidades e órgãos da Administração Pública, direta ou indireta, ainda que sem personalidade jurídica, especificamente, destinados à defesa dos interesses e direitos protegidos por este código; e iv) as associações legalmente constituídas há pelo menos um ano e que incluam entre seus fins institucionais a defesa dos interesses e direitos protegidos por este código, dispensada a autorização assemblear”.

Dentre os entes legitimados, merecem destaque o Ministério Público, a Defensoria Pública e as associações. Esses têm poder, estabelecido tanto na Lei da Ação Civil Pública quanto no CDC, para defender os grupos cujos direitos são violados em massa, ou seja, os “decorrentes de origem comum”. Vale dizer: os direitos que dependem da análise de se há responsabilidade pelos danos, responsabilidade em virtude dos inadimplementos ou dever decorrente dos ilícitos. Lembre-se, aliás, que o art. 95 do CDC afirma que, “em caso de procedência do pedido, a condenação será genérica, fixando a responsabilidade do réu pelos danos causados”.

Tanto a responsabilidade pelos danos ou pelos inadimplementos, quanto o dever legal em face dos ilícitos, devem constituir uma “questão comum” a todos os danos, inadimplementos ou ilícitos, ou seja, uma “mesma questão” ou uma “questão idêntica” em relação a todas as pretensões individuais. Significa dizer que a questão idêntica, objeto do incidente de resolução de demandas, nada mais é do que a questão prejudicial que dá corpo aos direitos individuais homogêneos, abrindo oportunidade à tutela dos direitos individuais na forma coletiva.

O fato de o incidente limitar as “questões idênticas” às questões de direito, obviamente, não repercute sobre a legitimidade dos entes habilitados a tutelar os direitos individuais homogêneos. Os definidos como legitimados à tutela dos direitos individuais homogêneos pela Lei da Ação Civil Pública e pelo CDC devem ser vistos como aqueles que podem representar os excluídos no incidente e, assim, resgatar a sua legitimidade constitucional.

Na verdade, as limitações que muitas vezes são feitas à legitimidade do Ministério Público e da Defensoria Pública para proteger determinadas espécies de direitos individuais homogêneos, necessariamente, devem ser deixadas de lado diante do incidente. Embora o ideal, em termos de amadurecimento da sociedade civil, seja a participação cada vez maior das associações, certos tipos de direitos podem não contar com associações organizadas voltadas à sua tutela. Não fosse isso, o fato é que, diante do incidente, o problema não está, propriamente, na busca de alguém que tenha relação com o direito discutido, mas na participação de alguém que tenha legitimidade para suprir a não participação dos excluídos ou dos litigantes que ficam à espera da decisão a ser tomada.

Daí a razão pela qual a Defensoria Pública deve ter grande espaço para atuar em favor dos

litigantes que não podem ser ouvidos, desconsiderando-se se estes, economicamente, necessitam ou não da tutela de um Defensor Público. Por identidade de razões, na falta de participação de associação legitimada ou da Defensoria Pública, o Ministério Público, necessariamente, deve assumir a posição de parte, ou seja, de defensor dos direitos individuais dos litigantes que não podem falar perante a Corte, de nada importando se os direitos têm natureza tributária etc.

Perceba-se que a força da representação adequada, no incidente, tem que ser mais vigorosa do que a presente na ação coletiva destinada à tutela de direitos individuais homogêneos, regulada pela Lei da Ação Civil Pública e pelo CDC. É que a sentença de improcedência, nesta ação coletiva, não prejudica os representados que não ingressaram no processo coletivo na qualidade de litisconsortes (art. 103, § 2.º, do CDC). Ao contrário, no incidente, os litigantes excluídos podem ser prejudicados, uma vez que a coisa julgada sobre a questão é *pro et contra*. Ora, quando os representados apenas podem ser beneficiados, sobrando-lhes sempre a ação individual em caso de improcedência, a adequação da representação acaba tendo importância muito menor.

Outra alternativa para a correção da constitucionalidade estaria no controle da representação adequada no caso concreto, nos moldes da *class action* do direito estadunidense. Admitir-se-ia que a parte do processo originário pode autonear-se ou ser nomeada pelo seu adversário representante dos litigantes das demandas repetitivas. Nesse caso os litigantes excluídos teriam a possibilidade de impugnar a parte enquanto representante adequado e o tribunal possuiria a grave incumbência de controlar a representação, considerando, atentamente, as circunstâncias do caso e a capacidade da parte – e de seu advogado – para sustentar, de maneira vigorosa e adequada, as razões também pertencentes aos demais litigantes⁵².

O art. 979 do CPC/2015, ao advertir que a “instauração e o julgamento do incidente serão sucedidos da mais ampla e específica divulgação e publicidade, por meio de registro eletrônico no Conselho Nacional de Justiça”, deve ser invocado para abrir oportunidade para a participação dos entes legitimados ou, na outra opção para a correção da inconstitucionalidade, para que os litigantes excluídos possam impugnar a parte enquanto representante adequado e, eventualmente, requerer o ingresso no incidente.

Essa “ampla e específica divulgação e publicidade” deve dar aos vários legitimados à tutela dos direitos em disputa, nos termos da Lei da Ação Civil Pública e do Código de Defesa do Consumidor, a possibilidade de ingressar no incidente para a efetiva defesa dos direitos. Cabe-lhes, afinal, a tutela dos direitos dos membros dos grupos, ou seja, dos direitos daqueles que têm casos pendentes que reclamam a solução de “questão idêntica”⁵³.

A falta de intervenção na qualidade de parte de qualquer associação ou da Defensoria Pública, que, igualmente, deverá ser intimada com base no art. 979, CPC, impõe, inevitavelmente, a intervenção do Ministério Público na qualidade de legitimado à tutela dos direitos dos litigantes. Aliás, se não for assim, o incidente estará retirando não só do Ministério Público, mas também da Defensoria Pública e dos demais legitimados à tutela dos direitos individuais homogêneos o poder-dever de tutelá-los⁵⁴.

2. Fixação das premissas para os comentários dos artigos subsequentes. Está claro que o incidente de resolução de demandas depende de representação adequada. É indiscutível que, para a sorte democrática do incidente – ou melhor, do processo –, pouco importa uma opção de concentração do julgamento da questão por parte do juiz, relator, partes, Ministério Público ou Defensoria Pública.

Tendo em vista que a legislação brasileira optou pelo modelo de representação adequada *ope legis*, ou melhor, escolheu pela definição legal daqueles que são representantes adequados, entre as duas formas de interpretação – antes propostas – do incidente de resolução de demandas repetitivas conforme a Constituição prefere-se aquela que tem em conta a Lei da Ação Civil Pública e o CDC. Afinal, tanto a Lei da Ação Civil Pública quanto o CDC consagraram um modelo de representação adequada incompatível com a interpretação que faz brotar a parte como representante que pode ser impugnado pelos demais litigantes, e controlado pelo tribunal em face das circunstâncias do caso concreto. Ou seja, ainda que a representação adequada *ope judicis* seja

constitucional, a extração desta forma de representação das normas que regem o incidente estaria em contradição com o sistema que regula a ação coletiva.

Assim, os comentários às normas seguintes terão como base a necessidade de participação indireta dos litigantes, ou melhor, de representação adequada mediante a participação dos legitimados à tutela dos direitos individuais homogêneos. Daí deriva o cuidado em enfatizar a presença de um dos representantes adequados no processo, de modo a fazer os litigantes das ações individuais ouvidos em todas as fases processuais.

Por outro lado, também restou claro que a decisão tomada no incidente não pode ser vista como um “precedente”, a despeito do equívoco do legislador em sustentá-la como uma decisão que obriga a todos os juízes e tribunais (art. 927, III, do CPC/2015). Há julgamento de questão prejudicial à resolução das demandas individuais de muitos, o que significa que é preciso cuidado em esclarecer a qualidade em que os litigantes são atingidos pela decisão, assim como pensar de forma compatível os efeitos preclusivos da decisão.

Art. 976. É cabível a instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas quando houver, simultaneamente:

I – efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito;

II – risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica.

§ 1.o A desistência ou o abandono do processo não impede o exame de mérito do incidente.

§ 2.o Se não for o requerente, o Ministério Público intervirá obrigatoriamente no incidente e deverá assumir sua titularidade em caso de desistência ou de abandono.

§ 3.o A inadmissão do incidente de resolução de demandas repetitivas por ausência de qualquer de seus pressupostos de admissibilidade não impede que, uma vez satisfeito o requisito, seja o incidente novamente suscitado.

§ 4.o É incabível o incidente de resolução de demandas repetitivas quando um dos tribunais superiores, no âmbito de sua respectiva competência, já tiver afetado recurso para definição de tese sobre questão de direito material ou processual repetitiva.

§ 5.o Não serão exigidas custas processuais no incidente de resolução de demandas repetitivas.

1. Julgamento de questão. O incidente propõe-se a julgar uma “questão”, e não, propriamente, as demandas repetitivas. Isso tem grande importância, pois as demandas repetitivas, embora dependam do julgamento de uma mesma questão, certamente, podem exigir a consideração de outras circunstâncias, que podem variar conforme cada uma das ações individuais.

Pense-se, por exemplo, num caso em que os atingidos por um mesmo fato danoso propõem centenas de ações individuais. Diante dessas ações individuais, em que o demandado não nega o seu comportamento, mas apenas a sua responsabilidade, a questão da “existência de responsabilidade” pode ser individualizada para ser decidida no incidente.

Note-se que a questão da responsabilidade é prejudicial à resolução dos pedidos de indenização, de modo que declarar a responsabilidade não basta para a resolução das várias ações de indenização. Embora a decisão que reconhece a responsabilidade tenha eficácia sobre todos os litigantes e, nesse sentido, seja “transportada” para as ações individuais, ela constitui uma decisão sobre uma questão prejudicial. As ações individuais, obviamente, ainda ficam na dependência da solução dos pedidos de indenização, que dependem da aferição do impacto do fato danoso sobre a esfera de cada um dos litigantes. O julgamento da questão “bastaria” se declarasse que o demandado não tem responsabilidade.

Na verdade, a resolução das demandas pode, conforme o caso, orientar-se apenas pela decisão

do incidente. Mas a questão, ainda assim, é sempre prejudicial à solução dos pedidos individuais. A decisão do incidente é sempre declaratória – positiva ou negativa. Bem por isso, a declaração positiva “basta” quando os pedidos individuais forem declaratórios, e será insuficiente quanto mais os pedidos constitutivos e condenatórios dependerem da análise de circunstâncias específicas.

2. Questão unicamente de direito. A tentativa de separação entre questão de direito e questão de fato sempre esteve centrada numa preocupação funcional. Nesse sentido, a busca desta separação não decorre de uma compreensão teórica que supõe que um fato, quando afirmado no processo, não constitui direito, nem que o direito pode existir enquanto algo isolado de qualquer elemento fático. Ou melhor, a distinção entre questões de fato e de direito não diz respeito a categorias ontologicamente diferentes, mas, apenas, supõe *standards* com base nos quais se pode decidir.

A busca de distinção entre fato e direito, no âmbito do *civil law*, relacionou-se, especialmente, com as Cortes Supremas. Como estas não devem tratar de fatos, afirmou-se que não há como admitir que o recorrente possa fundar o seu recurso em uma questão que não seja de direito. No *common law*, em que sempre se separou as funções do júri e do juiz na perspectiva “fact-law”, tornou-se necessário delimitar as questões de direito que poderiam ser decididas pelo juiz. Ademais, como a decisão de primeiro grau, no que diz respeito aos fatos, não pode ser reapreciada pela Corte de *common law*, mais uma vez, foi necessário identificar as questões que não podem fundar o recurso. Lembre-se, ainda, que o *collateral estoppel* foi, por muito tempo, relacionado apenas, e tão somente, às questões de fato⁵⁵.

A necessidade de separar fato e direito para legitimar a função de um órgão judicial, ou de uma técnica processual, fez surgir a suposição de que a questão é de direito se apenas um fundamento de direito é posto em dúvida no processo e, depois, deu origem à noção de que existiria questão de direito quando, não obstante a clara e estreita relação do direito com os fatos, esses não necessitassem ser provados ou valorados. Recorde-se, aliás, que se diz que o Superior Tribunal de Justiça pode julgar o recurso especial quando a questão de direito envolver fatos, mas não for necessário perguntar sobre a sua existência ou valorar provas.

Frise-se que a dificuldade em separar fato e direito levou a doutrina estadunidense a aludir a questões mistas (*law-fact*) e, finalmente, a ver a distinção entre *law* e *fact* como um “myth”⁵⁶. Não foi por outro motivo que se deixou de lado a ideia de que o *collateral estoppel* só poderia proibir a relitigação de uma questão de fato⁵⁷.

Não há questão de direito que, por estar mesclada por fatos, deva ser conceituada de outra forma. Bem vistas as coisas, o que realmente importa é que uma questão não pode ser discutida quando é “idêntica” a outra que já foi decidida, quando pouco interessa se a questão é, de fato, puramente de direito (*pure law*) ou mista (*law-fact*).

Tendo em vista que o incidente de resolução está preocupado com a definição de “questões idênticas” (art. 985 do CPC/2015), é certo que o art. 976 do CPC/2015, ao aludir a “questão unicamente de direito”, não quis proibir a resolução de questões de direito que repousem sobre fatos, mas desejou evidenciar que o incidente não pode ser invocado quando é necessário elucidar matéria de fato.

O incidente supõe a individualização ou o isolamento de uma questão de direito que pode estar claramente apoiada em fatos, mas que não pode exigir investigação probatória. Fatos incontroversos abrem oportunidade para o surgimento de uma mesma questão de direito. Mas há situação distinta quando, para a solução de uma questão jurídica, fatos devem ser elucidados. O art. 976 do CPC/2015, ao falar em questão unicamente de direito, está aberto à solução de questões de direito fundadas em fatos incontroversos, mas rejeita as questões que exigem produção de prova.

Portanto, há “questão unicamente de direito”, para efeito de incidente de resolução, quando a questão reclama mera interpretação de norma ou solução jurídica com base em substrato fático

incontroverso. Assim, por exemplo, o incidente pode ser instaurado quando se discute a respeito da legalidade de um ato ou quando se indaga sobre a responsabilidade de uma empresa em vista da prática de fatos sobre os quais não pende controvérsia.

3. Questão constitucional. Uma vez que a questão constitucional é uma questão de direito que pode se apresentar como prejudicial ao julgamento de demandas repetitivas, torna-se importante analisar o cabimento do incidente de resolução em face de questão de constitucionalidade.

O tema não mereceria especial atenção não fosse o “incidente de arguição de inconstitucionalidade”, disciplinado entre os arts. 948 e 950 do CPC/2015. Lembre-se que o incidente de inconstitucionalidade deve ser instaurado quando, arguida a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, esta for acolhida pela turma ou câmara (arts. 948 e 949, II, do CPC/2015). O incidente de inconstitucionalidade é um peculiar mecanismo para a formação de precedentes constitucionais, assim legitimado pelo art. 97 da CRFB/1988.

Importa esclarecer que o objetivo e os efeitos da resolução de questão diante de demandas repetitivas, obviamente, não se confundem com a razão de ser e com os efeitos da decisão proferida no incidente de inconstitucionalidade. O incidente de inconstitucionalidade objetiva resolver a questão de constitucionalidade com eficácia aos órgãos submetidos ao tribunal, impedindo-os de decidir a questão de constitucionalidade de modo diverso em qualquer caso ou recurso. O incidente de resolução de demandas apenas resolve questão afeta ao julgamento de um grupo de demandas, impedindo a relitigação da questão apenas aos litigantes das demandas repetitivas. Os efeitos da decisão de inconstitucionalidade têm uma extensão muito mais larga do que os efeitos da decisão da questão posta no incidente.

Ainda que o requerimento de instauração seja subscrito pelo juiz, pela parte, pelo Ministério Público ou pela Defensoria Pública, esteja a demanda em primeiro grau ou no tribunal, o julgamento da questão de direito, mediante o incidente, será realizado por órgão definido pelo regimento interno do tribunal (art. 978 do CPC/2015). Ocorre que, quando qualquer órgão de tribunal se depara com dúvida sobre a constitucionalidade, deve, necessariamente, submetê-la à apreciação do plenário ou órgão especial, sob pena de violação do artigo 97 da CRFB/1988⁵⁸.

Contudo, ao considerar-se que o incidente de resolução, em caso de questão constitucional, está obstaculizado pelo incidente de inconstitucionalidade, admite-se que a discussão da questão constitucional não pode ser deflagrada enquanto as demandas estão em primeiro grau, nem pode ser arguida, ainda que em segundo grau, pelos legitimados a requerer o incidente de resolução. Porém, como não é correto restringir os benefícios de uma técnica processual sem racionalidade, não é legítimo dizer que uma questão constitucional, imprescindível à resolução de demandas repetitivas, não pode ser resolvida desde logo, nem muito menos submeter a questão de constitucionalidade ao modelo individualista, em que a questão não pode surgir de um conflito coletivo.

A ideia de resolver uma questão prejudicial à resolução de demandas repetitivas não convive com aquela outra que supõe que a questão constitucional só pode ser decidida quando aflora em um caso entre A e B. Se há incidente de resolução de demandas repetitivas, em que se define questão de direito prejudicial ao julgamento de diversas ações individuais, o incidente de inconstitucionalidade deve se ajustar a esta realidade e não o contrário.

Note-se que o problema é parecido com aquele que surgiu quando se questionou a respeito da possibilidade de discutir questão de constitucionalidade na ação coletiva. A discussão de questão constitucional, em ação cuja decisão produz efeitos *erga omnes*, nada tem de diferente da arguição de questão constitucional em ação que almeja decisão que produz efeitos apenas em relação às duas partes que litigam. O que não é possível, em ação coletiva, é pretender como tutela jurisdicional a declaração de inconstitucionalidade de norma ou o controle da constitucionalidade da norma em abstrato. Mas nada impede arguir a inconstitucionalidade de norma como fundamento de pedido que recai sobre uma situação concreta que diz respeito à coletividade ou a direitos individuais homogêneos. O Supremo Tribunal Federal já firmou posição sobre o ponto. O entendimento pacífico da Corte pode ser captado, por exemplo, na Rcl 1.898, de relatoria do Min.

Celso de Mello, em que se declarou a legitimidade da utilização da ação coletiva como instrumento idôneo de fiscalização incidental de constitucionalidade de quaisquer leis ou atos do Poder Público, desde que, neste processo coletivo, a controvérsia constitucional, longe de identificar-se como objeto único da demanda, qualifique-se como simples questão prejudicial, indispensável à resolução do litígio.⁵⁹

Como há clara possibilidade de discutir questão de constitucionalidade em ação que se pede a tutela de direitos individuais homogêneos, obviamente, também há possibilidade de individualizar uma mesma questão de constitucionalidade como prejudicial ao julgamento de demandas repetitivas, e submetê-la ao incidente de resolução de demandas.

Portanto, se o verdadeiro problema não está na discussão de questão de constitucionalidade, mas na impossibilidade da sua discussão por órgão diferente do plenário ou do órgão especial e sem a garantia de quórum qualificado, cabe ao relator, ao se deparar com pedido de solução de questão constitucional prejudicial à solução de demandas repetitivas, submetê-la ao órgão colegiado competente para o incidente de resolução para que este decida se a questão posta no incidente, efetivamente, requer controle de constitucionalidade.

Lembre-se que, uma vez arguida a inconstitucionalidade de lei perante órgão fracionário do tribunal, esse só deve reconhecer a arguição e, assim, enviá-la ao plenário ou órgão especial, quando houver dúvida fundada sobre a constitucionalidade da norma. Caso se entenda que a norma é constitucional, devendo ser interpretada de acordo, obviamente, não há instauração de incidente de inconstitucionalidade. Na verdade, a questão pode ser decidida no incidente de resolução quando pode ser resolvida sem a declaração de que lei é inconstitucional, de que a interpretação proposta à lei é inconstitucional ou de que a aplicação de lei é inconstitucional na situação proposta⁶⁰. Portanto, é obviamente possível julgar mediante o incidente, por exemplo, a questão em que se discute a constitucionalidade de uma conduta em face da Constituição Federal ou a questão que requer a consideração de lei que, muito embora dita inconstitucional, permite ao colegiado afirmar que poderá resolver a questão de direito sem ter que pronunciar a inconstitucionalidade.

Note-se que a evidência de que o incidente de resolução está aberto ao recebimento de pedido de solução de questão constitucional está na circunstância de que o incidente de inconstitucionalidade destina-se ao julgamento de questão que aflora no controle incidental (art. 948 do CPC/2015), de modo que a questão de natureza constitucional, prejudicial à solução de demandas repetitivas, jamais poderia ser decidida mediante o incidente de constitucionalidade caso não fosse posta em incidente de resolução.

Quer dizer que o colegiado competente para o incidente de resolução, ao decidir que a questão é de controle de constitucionalidade, deve encaminhá-la ao juízo do plenário ou do órgão especial, nos termos do art. 949, II, do CPC/2015. Aliás, isto também deve ocorrer quando, não obstante a questão de direito não tenha sido delineada no requerimento de instauração do incidente de resolução como “questão constitucional”, decida o colegiado que a questão abre oportunidade para uma provável decisão de inconstitucionalidade.

Nestes casos, participam do incidente de constitucionalidade as partes do incidente de resolução de demandas repetitivas, ou seja, aqueles que devem participar do incidente de resolução na qualidade de representantes dos litigantes excluídos e as partes do processo originário, que, igualmente, devem necessariamente participar do incidente de resolução (art. 984, II, *a*, do CPC/2015). É o que acontece, similarmente, quando a questão que requer controle de constitucionalidade, na ação coletiva, é encaminhada à decisão do plenário ou do órgão especial.

4. Mesma questão. Como a questão de direito pode estar mais ou menos ligada a fatos, cabe indagar quando há uma mesma questão de direito. Note-se que o art. 976 do CPC/2015 fala em “mesma questão”.

Quando a questão é “puramente” de direito ou meramente interpretativa, os fatos que estão por detrás da questão não têm relevância; trata-se de fatos não importantes para a configuração da

questão. Porém, quando a questão de direito depende de fatos incontroversos, é preciso verificar se há um mesmo substrato fático ou se há circunstâncias fáticas que, diante da questão a ser resolvida, são equivalentes apesar de serem naturalmente distintas.

Quando se discute sobre a questão da responsabilidade de uma empresa que produziu danos múltiplos a moradores situados em determinada área, considera-se um único fato com impactos diferenciados. Saber se a empresa tem responsabilidade por esse único fato – cuja prática não é contestada – constitui uma mesma questão de direito para a empresa e para todos aqueles que se julgam lesados pelo fato.

Contudo, quando se tem em conta, por exemplo, responsabilidade pelo fato do produto, podem existir diversos atos de compra e venda e diferentes modos mediante os quais os produtos foram utilizados. Quando tais fatos não são controvertidos e surge a questão de saber se o produtor é responsável pelos danos provocados pelo uso do produto, há uma mesma questão de direito. Embora os fatos das demandas repetitivas possam ser visualizados como diferentes na perspectiva do que acontece na realidade, há identidade jurídica entre eles, na medida em que todos fazem ver um fato danoso decorrente do uso do produto. Resta daí, apenas, uma questão de direito, a de se saber se a empresa tem responsabilidade pelos danos derivados do uso do produto. É claro que, para existir uma mesma questão de direito, terá que ser desnecessário elucidar fato para concluir sobre a responsabilidade.

Perceba-se, ainda, que se em determinada ação o produtor contestar a relação entre o uso do produto e o dano, afirmando, por exemplo, que o dano alegado não poderia ter sido produzido mediante o uso do produto, não haverá como supor que esta ação reclama apenas a resolução de uma mesma questão de direito. Essa questão só se tornaria importante para esta específica demanda se a prova produzida – então necessária na ação individual – determinasse que o dano efetivamente decorreu do uso do produto. Significa que, num caso como esse, não há como pensar em demandas repetitivas.

5. Questão determinante ou essencial. A questão de direito, para dar origem ao incidente, não apenas deve ser a mesma ou idêntica. É preciso, ainda, que ela seja determinante ou essencial para o julgamento das demandas repetitivas. Veja-se outro exemplo: discutindo-se sobre a responsabilidade pela venda de determinado remédio que causou deformidade fetal é possível perguntar i) se o remédio contém substância proibida por norma, ii) se a substância, ainda que não proibida por norma, resultou num remédio que afetou o desenvolvimento do feto, e iii) se a constatação de que a fórmula do remédio afetou o desenvolvimento do feto pode redundar na responsabilização da empresa que, na época da comercialização, tinha autorização legal para a sua fabricação.

É interessante notar que o exemplo deixa clara a possibilidade de produção de prova para a análise do conteúdo do remédio e para a constatação da sua lesividade. A prova pode ser necessária para a verificação de se o remédio contém substância proibida por norma e, especialmente, para a conclusão de se o remédio afetou o desenvolvimento dos fetos. Nessas hipóteses, diante da clara locução “questão unicamente de direito”, não há como pensar em individualizar qualquer das duas questões para julgamento mediante incidente. É uma pena, pois, especialmente na segunda hipótese, em que se pergunta sobre a lesividade de um remédio que pode ter causado múltiplos danos, é fundamental isolar a produção da prova, dada a sua complexidade e alto custo envolvido. Não é qualquer perito ou assistente técnico que pode tratar de assunto desta espécie e não é qualquer jurisdicionado que pode pagar pelo preço da prova produzida por um profissional tecnicamente preparado e idôneo. Na realidade, só a relevância social desta prova é suficiente para não a deixar num “ambiente comum” – de uma ação individual –, sem os olhares atentos de todos aqueles que nela têm interesse, e o devido acompanhamento dos legitimados à tutela dos direitos individuais homogêneos e de todos os interessados que podem intervir como *amici curiae*.

Mas é possível perguntar se o incidente caberia na última hipótese, ou seja, quando se deseja apenas saber se empresa pode ser responsabilizada pela venda do remédio, ainda que na época da sua comercialização houvesse autorização para a sua fabricação e venda. Essa questão de direito

não reclama a produção de prova. Note-se, contudo, que essa questão só seria determinante do julgamento das ações individuais caso não houvesse controvérsia sobre se o remédio produziu os danos. Do contrário, como a prova requerida em um processo, obviamente, pode ser produzida de modo distinto e ter resultado e valoração diferentes em outro, simplesmente, não haveria demandas repetitivas. Não haveria como isolar uma questão de direito como determinante ou essencial para a resolução das demandas.

6. Incidente com mais de uma questão de direito. No caso em que dezenas de demandas se repetem trazendo questões de direito – que não requerem produção de prova – idênticas e essenciais para a sua solução, há repetição das mesmas questões de direito enquanto prejudiciais das múltiplas ações ajuizadas.

Assim, a mesma razão que abre oportunidade para a instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas quando há uma questão de direito, está também a justificar a instauração do incidente. Ora, o incidente de resolução requer, apenas, a presença de questão idêntica – que não reclama produção de prova –, essencial ao julgamento das demandas repetitivas.

Portanto, existindo duas questões de direito idênticas e essenciais para o julgamento de múltiplas ações, essas assumem a qualidade de repetitivas para o efeito de incidente de resolução. A própria justificativa do incidente de resolução impõe a instauração do incidente quando há uma ou mais questões de direito iguais e essenciais ao julgamento de demandas que estão a se repetir.

7. Mesma questão diante de diferentes demandados. Além disso, pode haver uma mesma questão de direito em face de atos praticados por pessoas diversas. Suponha-se, por exemplo, produtos iguais fabricados por diferentes empresas ou atos de mesmo conteúdo praticados por diferentes empresas de telefonia.

Nessas hipóteses, vários consumidores podem ingressar com ações individuais contra uma ou outra empresa. Não há dúvida que, nesses casos, os produtos e os atos são distintos conforme as diferentes vontades que estão por detrás de cada um deles. Porém, ainda que praticados ou produzidos por pessoas diferentes, os atos ou produtos têm um mesmo significado jurídico: os produtos e os atos podem estar ou não de acordo com o direito.

Em qualquer uma das situações é possível isolar uma mesma questão de direito como prejudicial à resolução das demandas repetitivas propostas contra ambas as empresas. Mas será preciso evidenciar que, tanto diante de uma empresa, quanto da outra, a questão de direito a ser solucionada é a mesma, é idêntica. Apenas não se pode dizer que a questão é uma só quando se tem em conta as vontades que lhes deram origem. Mas como essa diversidade não importa para resolver uma questão com eficácia para uma pluralidade de demandas, bastará evidenciar que, diante de quadros fáticos iguais, mas, historicamente, diferentes, indaga-se sobre uma mesma questão de direito.

Em casos assim, deverão participar do incidente todas as empresas identificadas como partes, ou um representante adequado⁶¹. Caso contrário, haverá violação do contraditório.

8. Imprescindibilidade do delineamento exato da questão a ser debatida. Tendo em vista que o incidente reclama uma “mesma questão ou uma questão idêntica”, torna-se importante delimitar, com exatidão, a questão que deve ser debatida e decidida.

Uma questão não efetivamente debatida ou decidida, obviamente, não legitima a extensão da coisa julgada aos litigantes das ações individuais repetitivas. Por isso, a instauração do incidente requer, como pressuposto, o delineamento da questão de direito a ser julgada, evitando-se o desbordamento da discussão e da própria decisão.

A definição da questão deve ser feita a partir da análise dos casos repetitivos. O requerente da instauração do procedimento deve demonstrar, mediante os casos repetitivos, qual é a questão de direito que exatamente constitui prejudicial ao julgamento de todas as demandas repetitivas.

Isso é relevante para que não se defina uma questão destituída de efetiva importância para a

resolução dos casos e, igualmente, para que não se decida questão diversa daquele que realmente interessa para a solução das demandas que se repetem.

E não é só isso: a exata delimitação da questão é também imprescindível para que uma parte não seja beneficiada em detrimento da outra, uma vez que um pequeno desvirtuamento da questão pode ser do interesse de uma delas. Por esse motivo é que as partes litigantes, inclusive obviamente os legitimados à tutela dos direitos dos excluídos, devem ter um espaço reservado para a discussão da delimitação da questão logo no início do desenvolvimento do processo. Isto é fundamental para a garantia do contraditório.

9. Questão e fundamentos. Uma questão de direito pode ser resolvida mediante mais de um fundamento. Quanto mais ampla é a questão de direito, maior é a possibilidade de utilização de diversos fundamentos para resolvê-la.

Assim, por exemplo, a questão da responsabilidade por danos é mais ampla do que a questão da responsabilidade objetiva por danos. Mas é na perspectiva da profundidade da indagação sobre a questão – e não da sua amplitude – que se pode ver vários fundamentos para a sua solução.

É possível questionar se é preciso individualizar, no requerimento de instauração do incidente, o fundamento ou os fundamentos que devem ser debatidos e, até mesmo, pensar se a própria decisão da questão deve tomar em conta os fundamentos em separado.

A necessidade de decisão em separado dos fundamentos pode ser facilmente deixada de lado, uma vez que não há motivo para não juntar fundamentos diversos quando se tem em mira a resolução de uma questão de direito que importa à resolução de ações repetitivas e não à elaboração de precedente, ou melhor, de *ratio decidendi*.

Lembre-se que se as Cortes Supremas não devem mais se limitar a corrigir a aplicação do direito; não basta mais conhecer apenas a conclusão do julgamento, sendo, imprescindível, identificar as razões que justificam a decisão ou a escolha interpretativa. São essas razões que dão corpo ao precedente, tornando-o racionalmente aceitável e aplicável aos casos futuros. É a *ratio decidendi* ou as razões determinantes da solução do caso que assumem relevo quando se tem em conta uma decisão que, além de dizer respeito aos litigantes, projeta-se sobre todos e passa a servir de critério para a solução dos casos futuros⁶².

A afirmação majoritária do fundamento pelo qual se resolve uma questão de direito tem relevância apenas quando se pensa em *ratio decidendi*. Afinal, é a *ratio decidendi* que regula os casos futuros e, exatamente por isso, não há como pensar em uma *ratio* definida pela minoria do colegiado.

Não obstante, embora não seja preciso decidir em separado os fundamentos para resolver a questão de direito que é prejudicial à solução das demandas repetitivas, é importante delimitá-los para que o contraditório e o debate não se percam em meio a uma discussão confusa, que, assim, pode não só prejudicar o direito de influência das partes como também obscurecer o adequado enfrentamento da questão de direito pelo colegiado.

Assim, após o oferecimento dos fundamentos pelo requerente da instauração do incidente, as demais partes devem ter oportunidade para negar o cabimento da discussão de determinado fundamento e de apresentar outros fundamentos relevantes para a resolução da questão de direito. Note-se que as partes da demanda originária e os legitimados que representam os excluídos não apenas podem negar os fundamentos. Como estão a discutir uma questão de direito, podem entender que, para a sua resolução, seja indispensável o enfrentamento de outro fundamento.

Isso não quer dizer, de qualquer modo, que o tribunal esteja vinculado aos fundamentos alegados pelas partes. O relator do caso pode colocar à discussão fundamento não lembrado, da mesma forma que o colegiado, quando da discussão da questão em sessão, pode invocar fundamento até então não discutido. Isso, contudo, só terá legitimidade se as partes – inclusive,

obviamente, o representante adequado – tiveram a devida oportunidade para considerar e debater o fundamento. Assim, se o fundamento for lembrado durante a sessão de julgamento, as partes devem ter a devida oportunidade para sustentar as suas razões em relação ao novo fundamento. Tudo isso, como é sabido, está enfatizado e garantido nos arts. 9.o e 10 do CPC/2015, uma vez que não apenas não é possível proferir decisão contra uma parte que não tenha sido previamente ouvida, como o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

10. Significado da discussão dos fundamentos. A discussão dos fundamentos pelas partes e pelo colegiado não significa que um novo fundamento não possa ser utilizado para a rediscussão da questão de direito pelos representados no incidente – que não tinham proposto demandas que restaram suspensas – ou por outro legitimado à tutela dos direitos individuais homogêneos. Isso é possível em razão dos arts. 985, II e 986 do CPC/2015, que afirmam a possibilidade da “revisão” da decisão proferida no incidente para os casos futuros.

Quer dizer que os representados, em vista da ficção da representação adequada, não podem ser proibidos de rediscutir a questão de direito com base em fundamento que não foi alegado pelo representante. Isso poderá ser feito nas demandas individuais futuras à decisão proferida no incidente. Uma vez que há outra discussão quando se tem em conta outro fundamento, há de se concluir que, quando um fundamento não foi deduzido pelo representante, a questão não foi adequadamente discutida, acarretando uma representação inadequada, a abrir oportunidade para a rediscussão da questão de direito pelos representados excluídos ou por outro representante adequado. Deixe-se claro que isto é possível para permitir a “revisão” da decisão para os “casos futuros”, nunca para permitir a desconstituição da coisa julgada que pertine aos casos passados, ou seja, às demandas que eram pendentes à época da instauração do incidente em que proferida a decisão.

Perceba-se que esta construção, além de estar na linha do sistema coletivo de tutela dos direitos – articulado pela Lei da Ação Civil Pública e pelo CDC –, que diz que o representado não é prejudicado em caso de sentença de improcedência (art. 103, III, do CDC), constitui resposta adequada à possibilidade de “revisão” da decisão do incidente para os casos futuros (arts. 985, II e 986, do CPC/2015).

11. Isonomia e segurança jurídica. De acordo com o art. 976, II, do CPC/2015, é cabível a instauração do incidente de resolução quando houver, simultaneamente, “efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito”, e “risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica”.

Como está claro, o legislador misturou requisitos para a instauração do incidente com os seus objetivos ou com os fundamentos teóricos que o legitimam. O “risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica” não pode ser visto como requisito para a instauração do incidente, uma vez que é inevitável decorrência da repetição de processos em que se controverte uma mesma questão de direito.

A isonomia e a segurança jurídica são justificativas teóricas de um sistema de precedentes. O princípio *treat like cases alike* é a base secular do *stare decisis*. O *common law*, há muito tempo, cuida para que o produto da atividade judicial não viole a igualdade.⁶³ Já o *civil law*, por supor que o juiz poderia se limitar a descrever a norma contida no texto legislativo, deixou de se preocupar com a igualdade perante o Judiciário. Porém, sabe-se que, atualmente, o Judiciário tem papel mais relevante, pois deve colaborar com o Legislativo na tarefa de construção de um direito que responda às necessidades da vida em sociedade⁶⁴. Isso não apenas em razão de a evolução da teoria da interpretação ter colocado às claras que todo texto legislativo abre oportunidade para um significado atribuível pelo juiz e pela circunstância de que as normas abertas dependem de concretização judicial, mas, também, por haver consciência de que o direito deve estar em constante atualização e adaptação aos novos fatos sociais, para o que as normas constitucionais constituem uma ferramenta dotada da mais absoluta relevância.

Nessa dimensão, a Corte Suprema não pode mais ser vista como um órgão que visa a garantir uma mítica racionalidade do ordenamento, fruto de uma razão iluminista que outrora seduziu.⁶⁵ É preciso que o “sentido” do direito delineado pela Corte Suprema, por intermédio do precedente, pautar a solução dos casos iguais ou similares, vinculando os juízes e tribunais. A igualdade perante as decisões judiciais é fruto do dever de o Estado dar a todos que estão em uma mesma situação jurídica a solução que a Corte Suprema racionalmente delineou, oferecendo as melhores razões possíveis.⁶⁶ Afinal, todos os homens merecem – e apenas podem exigir – a melhor solução que o Estado pode obter para lhes garantir uma vida justa.

De modo que o valor constitucional tutelado pelo sistema de precedentes é exatamente a igualdade, realizada, empiricamente, mediante a vinculação dos tribunais e juízes ao “direito” delineado pela Corte Suprema, dependente da evolução da vida social, aberto ao dinamismo de um sistema voltado à atuação de princípios fundamentais munidos de inesgotável carga axiológica e atento à devida percepção das diferenças.⁶⁷

Mas, se a eficácia obrigatória dos precedentes das Cortes Supremas tutela a igualdade, a segurança jurídica também depende de um sistema que garanta que a solução dos casos futuros será pautada num mesmo direito, para o que também é imprescindível a obrigatoriedade dos precedentes das Cortes que têm atribuição constitucional de outorgar sentido ao direito.

A variação frívola do que o Judiciário diz acerca de um texto legal contradiz a segurança jurídica. O cidadão, para poder se desenvolver, tem que conhecer as consequências jurídicas das suas ações e dos comportamentos daqueles com quem convive. Essa previsibilidade pressupõe univocidade de qualificação das situações jurídicas.⁶⁸ Se essa qualificação depende das decisões judiciais⁶⁹ – que, em princípio, podem ser várias –, a sua univocidade está nas mãos das Cortes Supremas, cuja função é atribuir sentido ao Direito, garantindo-lhe a devida estabilidade. Nesse sentido, se pode falar em “ética do legalismo”, nos termos de MacCormick,⁷⁰ uma vez que a previsibilidade das decisões, vista como legalismo, constitui valor moral imprescindível para o homem, de forma livre e autônoma, desenvolver-se num Estado de Direito.⁷¹

Sem dúvida, se a previsibilidade pressupõe univocidade, ela, igualmente, depende da efetividade do sistema jurídico enquanto capacidade de garanti-la.⁷² Isto é, depende de um sistema de precedentes obrigatórios. Na verdade, um ordenamento incapaz de permitir previsões e qualificações jurídicas unívocas e de gerar, assim, um sentido de segurança nos cidadãos, não merece sequer a qualificação de jurídico.⁷³

Contudo, há uma nítida diferença entre o objeto guardado por um sistema de precedentes e aquele tutelado por decisões de questões de direito que constituem prejudicial à resolução de demandas de massa. No primeiro caso há definição do sentido do direito que deve orientar a vida em sociedade e regular os casos futuros. A eficácia obrigatória, portanto, liga-se ao direito que deve ser aplicado pelos juízes e tribunais para a resolução dos mais variados casos. Em termos de igualdade e segurança jurídica, o precedente equipara-se à lei ou ao direito.

Já a resolução de uma questão, para poder alcançar outros casos, depende não só de a questão ser idêntica, mas, também, que aqueles que têm titularidade para reivindicar os direitos que dependem da solução da mesma questão possam discuti-la em contraditório ou sejam, adequadamente, representados no processo em que a questão é discutida e decidida. Afinal, trata-se de coisa julgada *erga omnes*.

É absurdo pensar que, quando se tem uma questão de direito que interessa a muitos, é possível resolvê-la para todos ao chamar a decisão de precedente ou ao proclamar, em norma (art. 927, III, do CPC/2015), que a decisão deve ser observada pelos juízes e tribunais. Ora, uma decisão que decide um caso ou uma questão de direito, obviamente, não pode prejudicar aqueles que têm direito constitucional de discuti-los. Estes, quando não podem pessoalmente participar, devem ser representados por legitimados capazes e idôneos.

Note-se que um precedente regula a aplicação do direito e, do mesmo que a norma legal, pode ser interpretado por todo e qualquer juiz ou tribunal quando da sua consideração em face de

determinado caso concreto. O precedente não se aplica “automaticamente” à resolução de casos. Até porque os casos, obviamente, não precisam ser iguais para ser regulados por precedentes, mas apenas similares. A adequada aplicação da técnica da distinção não apenas confere ao juiz do caso sob julgamento a possibilidade de não aplicar o precedente sob o argumento de que o caso é distinto, mas, principalmente, o poder de estender ou restringir a *ratio decidendi* para solucionar caso que, a princípio, não poderia ou deveria ser regulado pelo precedente.

Ao contrário, a resolução de questão só se aplica em face de questão idêntica, ou seja, que já foi discutida e decidida em processo em que aquele que deve ser atingido pela coisa julgada *erga omnes* teve oportunidade de participar, ao menos, de forma indireta. Nesse caso, como a questão é idêntica, a decisão obviamente não abre espaço para interpretação ou para a distinção típica à operação com precedentes. A decisão se aplica ou não. É que não se está perguntando se o precedente – visto como norma jurídica – aplica-se ao caso e, assim, deve regulá-lo, mas, simplesmente, se uma decisão já resolveu a questão.

Tudo isso quer dizer que a igualdade e a segurança jurídica são tuteladas pelo incidente de resolução de demandas de forma diversa. O incidente objetiva evitar que demandas repetitivas, dotadas de questões prejudiciais idênticas, sejam resolvidas ora em favor de um, ora em favor de outro, garantido, portanto, apenas a igualdade entre os litigantes envolvidos em determinado conflito de massa – que deu origem a demandas múltiplas ou repetitivas. Assim, o espaço em que a igualdade é tutelada também é sensivelmente menor.

Em termos de segurança jurídica, a distinção é ainda mais clara e intensa. Se é possível entender que a reiteração da mesma decisão nas demandas repetitivas favorece a estabilidade da ordem jurídica, não há problema de previsibilidade quando se tem em conta uma decisão já proferida em face de determinada questão. Nesse caso há coisa julgada *erga omnes*; a questão já foi decidida. De modo que não há como temer uma possível decisão diferente. No caso de precedente obrigatório, garante-se a aplicação da *ratio decidendi* quando da solução dos casos futuros; mas não há prévia decisão da questão ou caso, nem mesmo se deseja garantir que a resolução de determinado caso não poderá ser outra que não aquela constante da decisão já proferida. Essa garantia – que não é de previsibilidade, mas de imodificabilidade – só existe quando se pensa em coisa julgada *erga omnes*.

Lembre-se que a razão básica do precedente é orientar as relações sociais, conferindo ao cidadão segurança de que a sua conduta está amparada pelo Direito e, assim, será garantida pelo Judiciário. Ora, basta constatar que a decisão do incidente é posterior às condutas que deram origem aos casos pendentes e à solução da “questão idêntica” para se poder compreender, ainda com mais facilidade, que tal decisão não tem relação com a essência do sistema de precedentes, ainda que se tente “fabricar” uma ameaça à segurança jurídica para justificar uma decisão que atinge pessoas que não podem participar do processo, nem mesmo por meio de representante adequado.

12. A posição do Ministério Público no incidente. O Ministério Público pode requerer a instauração do incidente (art. 977, III, do CPC/2015). Porém, diante do déficit de participação dos litigantes individuais, não há racionalidade em pensar que o Ministério Público, nesse caso, é um mero interessado na otimização do julgamento das demandas repetitivas. Assim, para requerer a instauração do incidente, o Ministério Público deve ter optado por tutelar os direitos dos litigantes excluídos. Afinal, muito mais do que alguém interessado na efetividade do instrumento estatal de resolução dos conflitos, o Ministério Público é um representante da sociedade ou daqueles que não podem ter os seus direitos tutelados sem a sua participação em juízo.

No caso em que a Defensoria Pública, enquanto legitimada à tutela dos direitos, requereu a instauração do incidente, ou essa foi requerida pelo juiz ou pelo relator ou mesmo por um dos litigantes (art. 977, I, II e III, do CPC/2015), o Ministério Público poderá se colocar ao lado da Defensoria Pública enquanto co-legitimado ou – na segunda hipótese – assumir a titularidade exclusiva da representação dos excluídos.

Frise-se que a instauração do incidente deve ser publicizada de modo a dar aos legitimados

previstos na Lei da Ação Civil Pública e no CDC, especialmente às associações, oportunidade de ingressar no processo para a proteção dos direitos. Quando um legitimado abandona o processo ou desiste de participar, o Ministério Público deve, obrigatoriamente, assumir a tutela dos direitos dos litigantes individuais. É o que está expressamente determinado no § 2.º do art. 976 do CPC/2015.

No caso em que o Ministério Público não assumiu a representação dos excluídos e, assim, não está exercendo a defesa dos seus direitos, cabe-lhe intervir no processo como fiscal da lei. Isso pode ocorrer quando a Defensoria Pública tomou a iniciativa de requerer a instauração do incidente e de tutelar os direitos dos excluídos ou quando outro legitimado apresentou-se para tutelar os direitos dos litigantes nas demandas repetitivas.

13. Desistência ou abandono do processo. Segundo o art. 976, § 1.º, do CPC/2015, “a desistência ou o abandono do processo não impede o exame do mérito do incidente”. Diante da dicção da norma, é possível perguntar se o mérito do incidente pode ser julgado quando a parte que requereu a instauração do incidente desistiu ou abandonou o processo.

Quando o litigante de uma das demandas repetitivas abandona o processo, estando representado pelo legitimado à tutela dos direitos dos excluídos, não há qualquer problema na perspectiva do contraditório ou do direito de participar. Ademais, se o legitimado à tutela dos direitos dos litigantes excluídos desiste ou abandona o processo, o Ministério Público deve assumir a titularidade da defesa dos direitos em conformidade com o § 2.º do art. 976 do CPC/2015. Portanto, o § 1.º do art. 976 do CPC/2015 se aplica quando o incidente é instaurado a partir de requerimento de litigante que está presente em todas as demandas repetitivas – geralmente como réu. O litigante habitual ou comum a todas as demandas repetitivas, não pode desistir ou abandonar o processo de modo a inviabilizar o julgamento da questão de direito.

14. Reiteração da instauração do incidente para a resolução de igual questão. De acordo com o art. 976, § 3.º do CPC/2015, “a inadmissão do incidente de resolução de demandas repetitivas por ausência de qualquer de seus pressupostos de admissibilidade não impede que, uma vez satisfeito o requisito, seja o incidente novamente suscitado”.

Alude-se aí ao julgamento de questão de direito posta à discussão em incidente em que a sua análise não foi feita. É claro que, se o julgamento da questão tivesse ocorrido, não haveria como submetê-la a novo incidente. Uma questão de direito, já apresentada à decisão por meio de incidente, só pode vir a ser julgada em novo incidente quando o primitivo foi encerrado sem o julgamento da questão.

Isso pode ocorrer quando o incidente não é admitido por ausência de um dos “pressupostos de admissibilidade”. Lembre-se que, nos termos do 981 do CPC/2015, após a distribuição do incidente ao órgão colegiado competente, esse deverá proceder “ao seu juízo de admissibilidade, considerando a presença dos pressupostos do art. 976”.

Como o incidente depende de uma questão que tenha sido controvertida e, além disso, que possa ser individualizada como essencial ou determinante do julgamento das demandas repetitivas, o incidente não deverá ser admitido quando requerido antes da apresentação de contestação nas várias demandas.

Note-se que, antes da contestação, além de não se saber se a questão é controvertida, não se pode admiti-la como essencial ou bastante para o julgamento das demandas. Nada impede que, diante de determinada demanda, controverta-se sobre fato ou outra questão de direito que faça com que a questão de direito individualizada no incidente se torne uma questão não essencial ao julgamento desta específica demanda, que assim perde a característica de “demanda repetitiva”.

Quer dizer que o requerimento de instauração do incidente, antes da apresentação de contestação, simplesmente, impede que se possa aferir a existência de uma questão controvertida e essencial ao julgamento de várias demandas repetitivas.

É igualmente possível pensar em falta de pressuposto de admissibilidade quando o

requerimento de instauração é feito quando ainda não existem processos em número suficiente para caracterizar “demandas repetitivas” ou “efetiva repetição de processos”.

Quando o incidente deixa de ser processado, inviabilizando-se o julgamento da questão, seja por não delineamento de questão controvertida e essencial ao julgamento de demandas repetitivas, seja por não ter sido demonstrada a existência de um número de processos que configure a ideia de “repetição”, a mesma questão pode ser submetida a julgamento por meio de novo incidente, desde que satisfeito o requisito faltante.

Assim, por exemplo, quando se tornar possível a demonstração da controvérsia ou da essencialidade da questão, ou quando tiverem sido propostas ações capazes de representar número suficiente para configurar “processos repetitivos”, a satisfação do requisito que faltou abrirá oportunidade para a instauração de novo incidente para o julgamento da questão.

Frise-se que aqui não se está a cogitar de instauração de incidente por outro legitimado para o julgamento da questão decidida. Quando uma questão não foi decidida em virtude de ausência de pressuposto de admissibilidade, o mesmo ou outro legitimado ao requerimento de instauração de incidente (art. 977, I, II e III, do CPC/2015) pode postular a sua deflagração para o julgamento da questão.

15. Descabimento do incidente em caso de afetação de recurso para a solução de questão repetitiva no Superior Tribunal de Justiça ou no Supremo Tribunal Federal. Segundo o § 4.º do art. 976 do CPC/2015, “é incabível o incidente de resolução de demandas repetitivas quando um dos tribunais superiores, no âmbito de sua respectiva competência, já tiver afetado recurso para definição de tese sobre questão de direito material ou processual repetitiva”.

A norma afirma que, quando o Superior Tribunal de Justiça ou o Supremo Tribunal Federal resolvem analisar determinada questão de direito, respectivamente nas perspectivas do direito federal infraconstitucional e do direito constitucional, a mesma questão de direito não pode abrir oportunidade para incidente no âmbito de tribunal.

Ressalte-se que não há como pensar que a questão pode ser discutida no tribunal mediante fundamentos de direito federal infraconstitucional quando a questão foi delineada para decisão no Supremo Tribunal Federal. Não há sentido em limitar a matéria com base na qual a questão de direito pode ser discutida quando esta já foi elevada ao conhecimento de uma Corte Suprema. A decisão na perspectiva constitucional pode tornar desnecessária a decisão com base em fundamento de direito federal infraconstitucional.

Porém, isso não quer dizer que, uma vez definida a constitucionalidade de determinada conduta, não possa ser ela questionada com base em fundamento de direito federal em ações diversas, ou mesmo que, uma vez definida determinada interpretação para a lei federal, essa não possa ser impugnada em outras ações futuras com base em fundamento de direito constitucional. Note-se que o que não é possível é instaurar incidente no tribunal para discutir a mesma questão de direito, essencial ao julgamento do grupo de demandas repetitivas que lhe deu origem.

Quando se tem em conta outras demandas, derivadas de outros fatos danosos, inadimplementos ou atos contrários ao direito, pode surgir uma questão de direito dotada de outro conteúdo, a justificar novo incidente de resolução. Nessa hipótese, a decisão antes tomada pela Corte Suprema só pode ser vista como precedente capaz de regular casos similares e, assim, até mesmo o julgamento da questão de direito derivada das novas demandas repetitivas.

O surpreendente é que as Cortes Supremas são vistas pelo § 4.º do art. 976 do CPC/2015, como Cortes voltadas a definir questões idênticas, ou seja, questões prejudiciais à resolução de demandas repetitivas. A função das Cortes Supremas é atribuir sentido ao direito, definindo-o, e colaborar para o seu desenvolvimento de acordo com a evolução da sociedade. Questões de direito que dizem respeito a demandas de massa serão importantes para o Superior Tribunal de Justiça se relacionadas a uma questão de direito federal que reclama solução em vista de interpretação inadequada da lei ou de divergência entre os tribunais acerca da sua interpretação. De outra

parte, questões constitucionais que envolvem demandas repetitivas podem ser importantes para o Supremo Tribunal Federal quando dotadas de repercussão geral. Ora, demandas repetitivas podem envolver uma questão constitucional sem qualquer relevância.

Misturar incidente de resolução de questão prejudicial a demandas repetitivas com recurso destinado à resolução de questão federal ou constitucional é algo extremamente problemático. O legislador, obviamente, não vislumbrou o problema da relação entre incidente de resolução e o que denominou de recurso repetitivo, até porque não soube sequer definir o que é precedente ou instituir um incidente voltado à resolução de questões prejudiciais às demandas de massa em conformidade com o *due process*.

A função das Cortes Supremas e, por consequência, das suas decisões, é desenvolver o direito e outorgar-lhe unidade mediante a instituição de precedentes que, naturalmente, são dotados de autoridade e eficácia obrigatória. Isso significa que, embora a Corte Suprema possa eventualmente decidir uma questão prejudicial à solução de demandas repetitivas, a decisão desta questão apenas realmente importa ao instituir um significado ao direito que passa a servir de base para a orientação da sociedade e para a regulação dos casos futuros.

É por isso que os precedentes das Cortes Supremas não são carimbos para a solução de demandas repetitivas, mas, ao contrário, destinam-se a regular casos dotados de particularidades fáticas próprias ou que se colocam diante de uma outra lei, mas que não têm razão para serem resolvidos por *ratio decidendi* ou fundamento determinante diverso.

Portanto, não obstante se possa dizer que as Cortes Supremas podem definir questões prejudiciais ao julgamento de demandas repetitivas, a razão de ser de admissibilidade do recurso para a definição de questão não pode estar na sua resolução para o favorecimento do julgamento das demandas repetitivas, mas na própria função constitucionalmente atribuída às Cortes Supremas.

16. A gratuidade no incidente de resolução de demandas repetitivas. De acordo com o § 5.º do art. 976 “não serão exigidas custas processuais no incidente de resolução de demandas repetitivas”. Considerando-se a intenção do legislador, de resolver demandas idênticas que se repetem de modo a otimizar a produção estatal, a dispensa do pagamento de custas só pode ser vista como um incentivo para os cidadãos, mansamente, admitirem o mecanismo de solução em massa ou, na medida em que não há motivo para o Estado cobrar do Ministério Público e da Defensoria Pública, como mera declaração do óbvio.

Porém, caso o incidente seja compreendido em sua devida dimensão constitucional, em conformidade com os direitos fundamentais processuais, respeitando-se os direitos dos litigantes excluídos, o não pagamento de custas pode ser visto como incentivo à atuação dos representantes adequados – legitimados à tutela dos direitos individuais homogêneos –, à semelhança do que ocorre na ação coletiva, conforme o art. 18 da Lei 7.347/1985 – Lei da Ação Civil Pública – e o art. 87 do CDC.

Art. 977. O pedido de instauração do incidente será dirigido ao presidente de tribunal:

I – pelo juiz ou relator, por ofício;

II – pelas partes, por petição;

III – pelo Ministério Público ou pela Defensoria Pública, por petição.

Parágrafo único. O ofício ou a petição será instruído com os documentos necessários à demonstração do preenchimento dos pressupostos para a instauração do incidente.

1. Competência para julgar a questão prejudicial. O art. 977 do CPC/2015 deixa claro que a competência para julgar a questão prejudicial posta no incidente é do tribunal – de Justiça ou Regional Federal –, seja quando as demandas repetitivas que dão origem ao delineamento da questão estão em primeiro grau de jurisdição, seja quando já estão no tribunal, em vista da

interposição de recursos de apelação.

O requerimento de instauração sempre deve ser dirigido ao presidente, procedendo-se, após, à distribuição ao órgão competente no tribunal para o julgamento da questão, nos termos do art. 978 do CPC/2015 e do regimento interno do respectivo tribunal.

2. Legitimidade para requerer a instauração do incidente e legitimidade para ser parte. As normas que regulam o incidente de resolução de demandas repetitivas não tratam de quem tem legitimidade para ser parte. O art. 977 do CPC/2015 apenas anuncia aqueles que podem requerer a instauração do incidente. É como se este não fosse um procedimento em que o Estado exerce poder que interfere sobre a esfera jurídica dos litigantes, mas, simplesmente, uma espécie de técnica – indiferente aos jurisdicionados – destinada a otimizar o julgamento das demandas que se repetem. Na verdade, talvez o incidente tenha sido equivocadamente visto desta maneira ou, pior ainda, como um mecanismo capaz de facilitar a vida dos litigantes habituais ou daqueles que, habitualmente, violam os direitos – como determinadas empresas privadas e o próprio Poder Público.

Adverte-se que o incidente pode ser requerido pelo juiz ou pelo relator, pelas partes ou ainda pelo Ministério Público ou pela Defensoria Pública. É óbvio que o juiz e o relator apenas podem ter interesse na consequência que o incidente gera em proveito da administração da justiça. O Ministério Público e a Defensoria Pública não são vistos como entes preocupados em tutelar os direitos controvertidos. As coisas se passam – tomando-se em conta a letra da lei – como se, espantosamente, o incidente tratasse de direitos que não necessitam de tutela e, assim, não reclamam a participação dos seus titulares nem dos seus representantes adequados.

O que mais chama a atenção é o fato de as partes, o autor de uma das demandas repetitivas ou o réu que pode estar em todas elas, terem expressa autorização para requerer a instauração do incidente. Ora, se aquele a quem são atribuídos os ilícitos que deram origem às demandas repetitivas pode requerer a instauração do processo e dele participar, mas a mesma autorização de requerimento só oportuniza a participação do litigante-lesado de uma das demandas repetitivas; o incidente, certamente, é o procedimento “dos sonhos” daquele que, habitualmente, viola direitos em massa, que, assim, deve estar muito agradecido à generosidade do legislador. Uma das partes, aquela que é ré em todas, ou em grande parte, das demandas repetitivas, participará efetivamente do incidente, enquanto que as centenas ou milhares de litigantes lesados que exerceram o direito fundamental à tutela jurisdicional, estarão excluídos da discussão.

Não é por outra razão que, para a correção da constitucionalidade do procedimento, torna-se vital tratar da legitimidade para ser parte no incidente. Nos casos em que a instauração do incidente é requerida pelo Ministério Público ou pela Defensoria, esses tornam-se partes legitimadas à tutela dos direitos dos litigantes excluídos, tendo o dever de participar do processo de modo a adequadamente defendê-los. E, ainda assim, deverá ser aberta oportunidade para a eventual participação das associações de proteção dos direitos dos litigantes.

No caso em que o incidente é instaurado em razão de requerimento de parte de uma das demandas repetitivas, a chamada à participação das associações legitimadas à tutela dos direitos individuais homogêneos é ainda mais importante. A participação de um legitimado à tutela destes direitos – nos termos da Lei da Ação Civil Pública e do CDC – é, absolutamente, imprescindível para que o direito fundamental de ação, visto como direito de influir sobre o convencimento da Corte, não seja violado. De modo que o não ingresso de qualquer legitimado redundará na necessidade de intervenção do Ministério Público na qualidade de parte, ou seja, de representante adequado dos litigantes excluídos.

Além disso, as partes do processo originário são também partes do incidente, como, aliás, afirma o art. 984, II, *a* do CPC/2015.

3. A situação em que há litigantes diferentes nos dois polos das várias demandas que se repetem. Mas se a legitimidade da exclusão da participação dos litigantes das demandas repetitivas depende de estes serem adequadamente representados no incidente, há que se pensar

na situação em que as várias demandas que se repetem contêm múltiplos litigantes nos dois polos do processo.

É certo que, tratando-se de ilícitos ou danos em massa, pode haver, de um lado, inúmeros litigantes que se dizem lesados e, de outro, uma única parte acusada de ter praticado as violações. Contudo, não há como descartar a possibilidade de atos contrários ao direito ou danos terem sido praticados por várias, ainda que poucas, empresas. Nem mesmo se pode ignorar a eventualidade de algumas instituições estarem a utilizar uma mesma cláusula abusiva em seus contratos com o público consumidor. Nesses casos, as demandas dos sujeitos que foram lesados podem ser endereçadas contra várias pessoas jurídicas, ainda que estejam a exigir a solução de uma mesma questão de direito.

Assim como os litigantes que se afirmam lesados não podem ser proibidos de falar à Corte e, exatamente por isso, devem ser adequadamente representados no incidente, aqueles que são ditos violadores não podem ser obrigados a aceitar calados uma decisão que interfere em suas esferas jurídicas.

Portanto, a representação adequada, nestas hipóteses, pode ter que estar presente em ambos os polos do incidente. Significa que, quando a instauração do incidente é requerida a partir de demanda em que é autor um dos litigantes lesados, também pode surgir a necessidade de representação adequada no polo passivo.

Na verdade, tendo em vista o significativo menor número de litigantes que pode se encontrar no polo passivo de tais demandas, na maioria dos casos, bastará ao relator do incidente determinar a citação de todos aqueles que estão presentes no polo passivo das demandas repetitivas, tornando-se desnecessário pensar num representante adequado.

Contudo, tendo em vista a facilidade de organização – inclusive de contratação de advogados e assistentes técnicos e delineamento de estratégias comuns – inerente a empresas pertencentes a um mesmo setor, certamente, todas podem dialogar para eleger uma como representante adequado. Também será fácil às empresas indicarem um ente que as represente adequadamente. Não obstante, nada impede que o relator indique um ente dotado de representatividade para exercer a defesa dos litigantes excluídos, deixando a estes a possibilidade de impugnar, justificadamente, a nomeação. Pense-se, por exemplo, na Febraban diante de um incidente envolvendo vários bancos ou em outros entes dotados de plena capacidade de representação. Note-se apenas que tais entes deverão funcionar no incidente como representantes adequados, exercendo a defesa dos direitos dos litigantes excluídos, e não como *amici curiae*.

Tudo isso quer dizer que pouco importa que a Lei da Ação Civil Pública e o CDC não prevejam a legitimidade passiva para a tutela de direitos individuais homogêneos. A necessidade de representação adequada é algo que deriva, natural e necessariamente, do incidente de resolução de demandas, haja vista a exclusão da viabilidade de participação direta dos litigantes que sustentam suas razões nas demandas que restam paralisadas. Só a representação adequada legitima a suspensão do exercício dos direitos de ação e de defesa, tornando o incidente conforme os direitos fundamentais processuais.

Lembre-se, aliás, que o Superior Tribunal de Justiça já admitiu a figura da ação coletiva passiva, declarando que determinados entes podem ser citados como representantes adequados de grupos de pessoas e, exatamente por isso, que a coisa julgada pode, legitimamente, prejudicá-los, ainda que não tenham participado diretamente do processo. Isso ocorreu em ações em que se pedia a inibição da continuação da greve de servidores públicos, propostas contra Confederação de trabalhadores, Sindicato ou Associação⁷⁴.

Portanto, o incidente de resolução pode contar com representantes adequados em ambos os polos, tornando-se um processo em que a discussão é articulada a partir de uma dimensão coletiva bilateral.

4. Preenchimento dos pressupostos para a instauração do incidente. O requerimento de

instauração do incidente deve evidenciar o preenchimento dos seus necessários pressupostos. Assim, será necessário demonstrar a “efetiva repetição de processos”, ou seja, a existência de processos pendentes em número razoável. O requerente, neste sentido, deve apresentar os “documentos necessários”.

Também será preciso evidenciar que em todos os processos pendentes há controvérsia sobre uma mesma questão de direito. Além de a questão ter sido contestada, deve constituir uma mesma prejudicial que não depende da produção de provas, e é essencial ao julgamento de todas as demandas repetitivas. Quando as demandas afirmadas repetitivas contiverem outras questões de direito – que requeiram ou não a produção de prova –, não haverá como admitir que há como isolar e julgar uma questão essencial ou determinante à solução das demandas repetitivas, a menos que seja possível individualizar duas ou mais questões de direito comuns (as mesmas) – que não dependem de prova – às demandas repetitivas.

Art. 978. O julgamento do incidente caberá ao órgão indicado pelo regimento interno dentre aqueles responsáveis pela uniformização de jurisprudência do tribunal.

Parágrafo único. O órgão colegiado incumbido de julgar o incidente e de fixar a tese jurídica julgará igualmente o recurso, a remessa necessária ou o processo de competência originária de onde se originou o incidente.

1. Os regimentos internos dos tribunais e a mistura entre decisão de questão de muitos e uniformização de jurisprudência. Os regimentos internos dos tribunais devem instituir órgão colegiado, dentre aqueles responsáveis pela uniformização de jurisprudência, para julgar o incidente. Na linha da confusão entre decisão de questão de muitos e precedente, a norma acaba por misturar incidente de resolução de demandas repetitivas com uniformização de jurisprudência.

Como é evidente, a razão de ser do incidente nada tem a ver com a que recomenda uniformização de jurisprudência. O incidente se presta a decidir questão prejudicial às demandas propostas por muitos. O seu objetivo é diminuir os custos da administração da justiça e dos jurisdicionados diante da litigação múltipla e repetida de uma mesma questão de direito.

Na verdade, a unificação do julgamento da questão de direito tem um sentido oposto ao da uniformização da jurisprudência. A jurisprudência é uniformizada quando, em razão de vários julgados divergentes, há de se definir uma orientação que represente o entendimento da Corte. No caso de incidente de resolução de demandas repetitivas, decide-se antes do brotar de qualquer julgado ou entendimento. A decisão impede o surgimento de julgados diversos e, deste modo, torna desnecessária a uniformização de jurisprudência.

E não se pense que essa inversão é benéfica. Não se pode obter unidade antes do afloramento da discussão e do surgimento de decisões divergentes. A busca da uniformidade é passo que supõe prévio debate e divergência. Esse é o processo natural de maturação da jurisprudência das Cortes de Apelação.

Assim, a justificativa de uma decisão única para questões dotadas de plurititularidade só pode estar na vedação à multiplicação da litigação; não no encontro de uma decisão que possa significar “jurisprudência uniforme”.

2. Competência para julgar “o recurso, a remessa necessária ou o processo de competência originária de onde se originou o incidente”. O parágrafo único do art. 978 do CPC/2015 afirma que o órgão definido como competente para julgar a questão prejudicial também será competente para julgar as demandas repetitivas. Segundo a norma, cabe ao órgão que julga o incidente também julgar “o recurso e o reexame necessário” da decisão proferida pelo juiz nas demandas repetitivas ou, ainda, “o processo de competência originária de onde se originou o incidente”.

Se o órgão que julga a questão, além de julgar o recurso e o reexame necessário, deve também julgar “o processo de competência originária”, isso quer dizer que o juiz de primeiro grau não abre

mão da sua competência para resolver a demanda que tem a questão de direito resolvida no incidente como prejudicial, mas o órgão competente para julgar a questão de direito assume a competência para julgar, por exemplo, o mandado de segurança que, de competência originária do tribunal, constitui uma das demandas caracterizadas como repetitivas.

A opção do legislador não é adequada. A questão definida no incidente é prejudicial ao julgamento das várias demandas, de modo que a resolução das demandas repetitivas não é uma mera consequência automática do julgamento da questão. Ademais, não há relação de causa e efeito entre competência para solucionar questão prejudicial e competência para resolver demandas.

Art. 979. A instauração e o julgamento do incidente serão sucedidos da mais ampla e específica divulgação e publicidade, por meio de registro eletrônico no Conselho Nacional de Justiça.

§ 1.o Os tribunais manterão banco eletrônico de dados atualizados com informações específicas sobre questões de direito submetidas ao incidente, comunicando-o imediatamente ao Conselho Nacional de Justiça para inclusão no cadastro.

§ 2.o Para possibilitar a identificação dos processos abrangidos pela decisão do incidente, o registro eletrônico das teses jurídicas constantes do cadastro conterà, no mínimo, os fundamentos determinantes da decisão e os dispositivos normativos a ela relacionados.

§ 3.o Aplica-se o disposto neste artigo ao julgamento de recursos repetitivos e da repercussão geral em recurso extraordinário.

1. A opção pela lógica do precedente obrigatório. O art. 979 do CPC/2015 evidencia a premissa que sustenta a equivocada lógica do incidente de resolução de demandas repetitivas. É fácil perceber a alusão a conceitos próprios à teoria dos precedentes. Assim, por exemplo, fala-se em registro das “teses jurídicas” e em “fundamentos determinantes da decisão”. Trata-se de um erro derivado da suposição de que o alcance dos litigantes excluídos é legitimado pela criação de um precedente, nos termos do art. 927, III do CPC/2015.

Como já dito, a decisão de questão prejudicial às demandas dos litigantes excluídos não se subordina ao tipo de preclusão inerente aos precedentes, na medida em que não abre oportunidade para a revogação e para a elástica forma de distinção que lhes é peculiar. Isso para não falar que a função dos tribunais não é firmar precedentes. Esta função, nos termos da Constituição Federal, é outorgada às Cortes Supremas, a quem cabe definir ou atribuir sentido ao direito.

No incidente de resolução há decisão de questão; há coisa julgada *erga omnes*. Não há motivo para pensar em tese ou em fundamentos determinantes da decisão quando o que se tem é decisão de questão idêntica. A decisão de uma mesma questão, ou de uma questão idêntica, gera a impossibilidade de relitigá-la e não a regulação de casos por meio da consideração da *ratio decidendi* ou dos fundamentos determinantes, que conferem ampla latitude ao juiz do caso para dizê-los capazes de regulá-lo. Aliás, nem mesmo é possível associar “tese” com “fundamentos determinantes”. Num sistema de precedentes há apenas fundamentos determinantes ou *ratio decidendi*. Essa deve ser identificada na fundamentação da decisão, exigindo o confronto dos fatos do caso com as razões adotadas pela maioria do colegiado para decidir. “Tese”, contudo, nada mais é do que o enunciado do resultado da interpretação levada a efeito pela Corte. Com a tese corre-se o risco de cair no mesmo problema das súmulas, que, como se sabe, são simples enunciados abstratos de pouca valia para quem está preocupado com Corte que deve regular os casos futuros.

O art. 979 do CPC/2015 realça algo fundamental para a compreensão da inteligência que deve ser dada ao incidente de resolução. O legislador realmente imaginou que bastaria tratar a decisão do incidente como precedente ou dizer que esta deve ser observada por todos os juízes e tribunais (art. 927, III, do CPC/2015) para legitimar, por passe de mágica, o alcance de jurisdicionados destituídos de participação ou de representação adequada no processo em que os seus direitos são definidos.

2. Divulgação e publicidade da instauração e do julgamento do incidente: o chamamento dos representantes adequados. O art. 979, *caput*, do CPC/2015, afirma que “a instauração e o julgamento do incidente serão sucedidos da mais ampla e específica divulgação e publicidade, por meio de registro eletrônico no Conselho Nacional de Justiça”.

O motivo pelo qual o legislador exige ampla divulgação e publicidade da instauração do incidente, além de estar relacionado aos casos pendentes, a princípio, é o de comunicar os eventuais interessados para intervir como *amici curiae*, nos termos do art. 983 do CPC/2015. Contudo, essa ampla e incisiva comunicação da instauração do incidente, quando conjugada a sua necessária interpretação conforme o devido processo legal, oferece aos legitimados à tutela dos direitos individuais homogêneos oportunidade para intervir no processo como representantes adequados. Essa interpretação é conforme a Constituição, pois não há como ignorar a necessidade de os litigantes excluídos participarem mediante representantes adequados.

Mas não é só a instauração do incidente, mas também o seu julgamento, que deve ser amplamente divulgado e tornado público. Se o § 2.o do art. 979 do CPC/2015 encarrega-se de dizer que a decisão do incidente deve ser tornada pública, o *caput*, ao falar de julgamento do incidente, alude à decisão proferida pelo tribunal, ainda sujeita a recurso especial ou extraordinário. A divulgação da decisão do tribunal confere mais uma vez aos legitimados à ação coletiva a possibilidade de intervir no processo na qualidade de representantes adequados, colocando-se ao lado de outro legitimado já presente.

O registro eletrônico no Conselho Nacional de Justiça, porém, pode não ser suficiente para dar divulgação e publicidade suficientes à instauração e ao julgamento do incidente de resolução. É necessário, assim, a determinação da intimação dos legitimados ou mesmo a divulgação do ocorrido por meio de jornais de grande circulação ou de outros veículos de penetração no círculo em que presentes os legitimados definidos em lei como representantes adequados.

3. Banco de dados das questões de direito. Afirma-se que os tribunais devem manter bancos de dados eletrônicos das questões de direito e informá-las ao Conselho Nacional de Justiça para inclusão em cadastro. Esta previsão relaciona-se com a ideia de que a resolução de questão de direito significa a elaboração de uma regra de direito para a solução de múltiplos casos, nos moldes de um precedente obrigatório.

A resolução de uma questão de direito que pertine a um grupo de pessoas só pode atingi-las quando estas participaram diretamente do processo ou foram adequadamente representadas. Significa que a decisão só pode alcançar os membros do grupo que foram representados adequadamente no incidente. Esta decisão pode afetar os litigantes dos casos pendentes ou futuros, desde que os casos futuros discutam a mesma questão de direito solucionada no incidente que contou com um representante adequado de todos os litigantes, inclusive daqueles que ainda não haviam apresentado as suas ações – que, portanto, não eram pendentes.

A pretensão do banco de dados eletrônico, obviamente, não pode ser a de registrar o direito – ou mesmo as teses – que vai regular os casos futuros. O banco de dados pode servir tão somente para registrar as decisões proferidas em face daqueles que foram devidamente representados nos incidentes de resolução.

4. Identificação dos casos submetidos ao incidente. A norma do § 2.o do art. 979 do CPC/2015 mostra-se preocupada com a “identificação” dos processos abrangidos pela decisão do incidente. Diz a norma que, para permitir esta identificação, o registro das teses jurídicas deve conter, no mínimo, os “fundamentos determinantes da decisão” e os “dispositivos normativos a ela relacionados” (art. 979, § 2.o, do CPC/2015).

Deseja-se saber quais são os casos que exigem a decisão já proferida no incidente. Supõe-se que, para a identificação destes casos, é necessário conhecer os fundamentos determinantes da decisão e os dispositivos normativos por ela aplicados.

Em determinada perspectiva, a lógica do raciocínio implícito na regra está ligada à falsa

suposição de que o incidente produz precedente – e, assim, fundamentos determinantes ou *ratio decidendi* –, a partir do qual é possível meditar para concluir se determinado caso está ou não abrangido pelos fundamentos determinantes da decisão.

Pensa-se em fundamentos determinantes ou *ratio decidendi* quando se está diante de decisão que tem o potencial para regular casos futuros, ou seja, casos que, apesar de distintos, possuem particularidades que reclamam a adoção da mesma solução jurídica. Numa situação como essa, considera-se o caso sob julgamento para saber se o precedente é aplicável.

Frise-se que o incidente não apenas trata de “questões idênticas”, mas, sobretudo, de questões idênticas que dizem respeito a determinadas pessoas ou litigantes, pertencentes a determinado grupo. Quando se está diante de uma questão idêntica, não é preciso identificar a *ratio decidendi* da decisão que a resolveu para saber se outro caso deve ser regulado por ela. É preciso somente ter clara a solução outorgada à questão. Se a questão é idêntica, o caso está submetido pelo simples fato de a questão prejudicial que lhe diz respeito já ter sido decidida no incidente. De modo que basta saber se a questão de direito, que constitui prejudicial à resolução da demanda, é a mesma. Assim, o cadastro, se precisa conter alguma coisa, deve delinear a questão de direito e a solução que lhe foi dada.

A ideia de fundamentos determinantes, obviamente, não importa para a identificação da solução dada à questão de direito. Tratando-se de questões idênticas, em que releva saber se um caso requer a discussão da mesma questão de direito e, assim, submete-se à decisão já prolatada, apenas uma maior sofisticação teórica levaria à necessidade da identificação dos fundamentos determinantes da decisão do incidente.

Na verdade, a identificação dos fundamentos determinantes só tem relevância quando se pensa na possibilidade da rediscussão da questão decidida a partir de outro fundamento. Realmente, ainda que a questão seja discutida pelo representante adequado – até porque, se não for assim, a solução da questão não pode ter validade perante terceiros –, os representados não ficam submetidos ao princípio que cobre o dedutível, ou seja, não sofrem a preclusão quanto aos fundamentos que poderiam ter sido discutidos pelo representante, mas não foram.

Se outro fundamento equivale a ter outra discussão da questão de direito e a representação adequada é sempre uma ficção, é possível dizer que, quando não houve discussão de fundamento que poderia ter sido discutido, presume-se não ter ocorrido representação adequada quanto à sua discussão.

Nesse contexto, o cadastro deve conter os fundamentos determinantes da decisão para evidenciar os fundamentos que foram discutidos para se chegar à solução da questão. Mas para que se torne possível saber se outro fundamento, diverso dos já discutidos, pode abrir oportunidade para a rediscussão da questão e, assim, para o afastamento do caso da decisão proferida no incidente. E não, obviamente, para se saber se a decisão contém fundamentos determinantes que regulam determinado caso, como se a decisão fosse um precedente obrigatório.

5. Aplicabilidade aos “recursos repetitivos e à repercussão geral em recurso extraordinário”. Afirma-se que o art. 979 do CPC/2015 aplica-se aos recursos repetitivos e à repercussão geral. Aqui há claro reforço do grave equívoco cometido pelo legislador. Como várias vezes já dito, não há como confundir decisão de questão prejudicial à solução de demandas repetitivas – ou de jurisdicionados que integram um grupo de titulares de direitos individuais homogêneos – com precedente obrigatório.

Os recursos repetitivos, embora tratem de questões prejudiciais ao julgamento de diversos recursos individuais, abrem oportunidade a decisões de Cortes Supremas, que podem ou não configurar precedente obrigatório, conforme se tenha chegado ou não a uma *ratio decidendi*. Ademais, as Cortes Supremas, especialmente o Supremo Tribunal Federal, decidem em prol do desenvolvimento do direito, e não com o objetivo de resolver casos concretos. Isso quer dizer que há enorme dificuldade para comparar recurso especial ou extraordinário com incidente de resolução.

Bem vistas as coisas, não há como compará-los. A repercussão geral, certamente, nada tem a ver com solução de questão de direito para casos de massa. A sua função é completamente diversa. A razão da repercussão geral é a de permitir ao Supremo Tribunal Federal velar pela unidade do direito mediante o exame de casos significativos para a ótima realização dos fins do Estado constitucional, sem sobrecarregá-lo com o exame de casos destituídos de relevância e transcendência, cujas soluções não importam contribuição para o desenvolvimento do direito brasileiro⁷⁵.

Perceba-se que, para efeito de repercussão geral, ao contrário do que acontece em face do incidente de resolução, tem grande importância os fundamentos determinantes ou *a ratio decidendi* da decisão.

Art. 980. O incidente será julgado no prazo de 1 (um) ano e terá preferência sobre os demais feitos, ressalvados os que envolvam réu preso e os pedidos de *habeas corpus*.

Parágrafo único. Superado o prazo previsto no *caput*, cessa a suspensão dos processos prevista no art. 982, salvo decisão fundamentada do relator em sentido contrário.

1. Prazo para o julgamento do incidente e preferência sobre os demais feitos. O julgamento do incidente deve ocorrer no prazo de um ano. Define-se prazo para o julgamento em razão de que os casos pendentes ficam suspensos, nos termos do art. 982, I, do CPC/2015. Segundo este artigo, basta a admissão do incidente para o relator ter que determinar a suspensão dos “processos pendentes, individuais ou coletivos”, que tramitam no estado ou na região – conforme o incidente tenha sido instaurado em Tribunal de Justiça ou em Tribunal Regional Federal. O prazo de um ano, assim, logicamente, deve ser contado da suspensão dos processos pendentes.

A previsão do prazo de um ano, ao lado da importância da definição da questão de direito prejudicial ao julgamento dos diversos casos pendentes, fez com que o legislador conferisse a qualidade de preferencial ao incidente. Na dicção do *caput* do art. 980 do CPC/2015, o julgamento do incidente terá preferência sobre os demais feitos, ressalvados os que envolvam réu preso e os pedidos de *habeas corpus*.

2. Não observância do prazo de um ano. Caso o julgamento do incidente não ocorra no prazo de um ano, cessa a suspensão dos processos pendentes. Passado tal prazo, os processos só poderão ser mantidos suspensos em casos excepcionais, justificados pelo relator.

Isso poderá ocorrer quando, não obstante o desenvolvimento adequado do processo do incidente, dificuldades imprevisíveis – de ordem externa ou interna ao tribunal – impediram o julgamento do incidente a tempo e ainda se mostra oportuno o julgamento da questão de direito em virtude do grande número de demandas repetitivas pendentes. Tais dificuldades, bem como a subsistência da oportunidade do julgamento da questão de direito, devem ser justificadas pelo relator quando decidir manter os processos suspensos depois de passado o prazo de um ano.

Art. 981. Após a distribuição, o órgão colegiado competente para julgar o incidente procederá ao seu juízo de admissibilidade, considerando a presença dos pressupostos do art. 976.

1. Juízo de admissibilidade. O incidente de resolução deve ser dirigido ao presidente do tribunal (art. 977 do CPC/2015) e, então, distribuído ao desembargador-relator que compõe o órgão colegiado definido como competente pelo regimento interno do tribunal (art. 978 do CPC/2015).

Feita a distribuição, o colegiado – e não apenas o relator – fará o juízo de admissibilidade, considerando os termos do art. 976 do CPC/2015, que diz ser cabível a “instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas quando houver, simultaneamente: i) efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito; e ii) risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica”.

Como dito quando dos comentários ao art. 976 do CPC/2015, há risco de ofensa à isonomia toda vez em que existe efetiva repetição de demandas que dependam da resolução de uma mesma questão de direito. A decisão do incidente tutela a igualdade perante a jurisdição de modo mais

limitado do que os precedentes obrigatórios – que se dirigem a todos os casos –, mas também tem importância para tanto. Do mesmo modo, a decisão do incidente favorece a estabilidade da ordem jurídica, embora não seja correto pensar que garanta a previsibilidade do direito ou das decisões judiciais. A decisão do incidente torna a previsibilidade uma questão não importante. É que a previsibilidade é essencialmente ligada ao futuro ou aos casos que estão por vir. A decisão proferida no incidente já é a decisão da questão dos casos pendentes e dos eventuais casos futuros. A decisão do incidente evita tratamento desigual e descontinuidade da aplicação do direito – e, assim, favorece a estabilidade –, mas não garante a previsibilidade, tornando-a na verdade desnecessária.

De qualquer forma, os requisitos do inciso II do art. 976 do CPC/2015 são justificativas teóricas do incidente e não pressupostos que devem estar presentes em cada caso concreto. A tutela da igualdade e da estabilidade do direito são consequências da decisão do incidente. O risco à igualdade e à segurança jurídica descende, diretamente, da existência de uma mesma questão de direito prejudicial à solução de múltiplas demandas. Assim, basta ao colegiado concluir que há efetiva repetição de processos em que há controvérsia sobre uma mesma questão de direito⁷⁶.

Frise-se que, se em alguns processos há necessidade de solução da mesma questão de direito associada a outra questão de direito, não existe uma mesma questão de direito essencial e determinante ao julgamento das demandas, pelo que não se pode pensar em demandas repetitivas, ou melhor, em demandas que exigem a solução de uma mesma e única questão de direito. Será possível pensar em repetição de processos, numa situação desta, apenas se forem invocadas, para o julgamento mediante o incidente, duas ou mais questões de direito idênticas como prejudiciais ao julgamento das demandas repetitivas.

Quando algumas demandas, além da questão de direito idêntica, reclamam a produção de prova para a solução de outra questão de direito, jamais será possível agrupá-las enquanto uma classe de demandas repetitivas. Aliás, não é possível pedir o julgamento de questão de direito que depende de prova mediante o incidente de resolução. Nessa linha, quando há uma questão de direito idêntica ladeada por outra que depende de prova, simplesmente, não há questão de direito determinante à resolução das demandas, de modo que está ausente o requisito da efetiva repetição de demandas que dependem da solução de uma mesma e essencial questão de direito.

Por fim, o fato da mesma questão de direito estar sendo discutida mediante fundamentos diversos nas várias demandas não elimina a possibilidade de se falar em questão idêntica e, portanto, em demandas repetitivas. Idêntica deve ser a questão de direito; basta que exista uma mesma questão de direito, não sendo necessário que esta esteja sendo discutida com base nos mesmos fundamentos nas diversas demandas.

Art. 982. Admitido o incidente, o relator:

I – suspenderá os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam no Estado ou na região, conforme o caso;

II – poderá requisitar informações a órgãos em cujo juízo tramita processo no qual se discute o objeto do incidente, que as prestarão no prazo de 15 (quinze) dias;

III – intimará o Ministério Público para, querendo, manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1.º A suspensão será comunicada aos órgãos jurisdicionais competentes.

§ 2.º Durante a suspensão, o pedido de tutela de urgência deverá ser dirigido ao juízo onde tramita o processo suspenso.

§ 3.º Visando à garantia da segurança jurídica, qualquer legitimado mencionado no art. 977, incisos II e III, poderá requerer, ao tribunal competente para conhecer do recurso extraordinário ou especial, a suspensão de todos os processos individuais ou coletivos em curso no território nacional que versem sobre a questão objeto do incidente já instaurado.

§ 4.o Independentemente dos limites da competência territorial, a parte no processo em curso no qual se discuta a mesma questão objeto do incidente é legitimada para requerer a providência prevista no § 3.o deste artigo.

§ 5.o Cessa a suspensão a que se refere o inciso I do *caput* deste artigo se não for interposto recurso especial ou recurso extraordinário contra a decisão proferida no incidente.

1. Requisição de informações aos órgãos judiciais em que tramitam as ações repetitivas. O relator do incidente pode requisitar informações aos órgãos judiciais em que tramitam as demandas repetitivas. Isso para que o órgão colegiado tenha maiores subsídios para compreender a discussão em torno da questão de direito.

Ter a possibilidade de requerer informações sobre as demandas repetitivas está muito longe de garantir aos litigantes a possibilidade de influir, ao menos mediante representante adequado, sobre o convencimento do colegiado. É realmente como se o incidente fosse um procedimento alheio aos litigantes. Os casos não importam pelo fato de constituírem conflitos que devem ser resolvidos pelo Judiciário, mas por representarem fontes para a afirmação da adequada solução de uma questão de direito. Como se vê, mais uma vez, resta claro que o incidente foi idealizado para ser um local de elaboração de precedentes, como se fosse possível afastar os litigantes cujas demandas têm a questão de direito como prejudicial aos seus julgamentos.

2. Intimação do Ministério Público para se manifestar. O relator deve intimar o Ministério Público para, querendo, manifestar-se no prazo de quinze dias. Neste caso, o Ministério Público é chamado a falar como fiscal da lei, considerando-se, assim, que o procedimento detém um interesse público.

Este interesse, a princípio, não se relaciona com a existência de direitos individuais de litigantes que estão afastados do processo – na medida em que o legislador parte da premissa de que pode afastá-los por estar a criar um mecanismo de elaboração de precedente. O interesse público adviria da otimização do julgamento de demandas repetitivas mediante uma única solução de questão de direito e, por consequência, da necessidade de zelar pela sua adequada discussão e decisão.

3. Suspensão dos processos pendentes como consequência da admissão do incidente. A admissão do incidente pelo colegiado gera ao relator o dever de determinar a suspensão dos processos pendentes, sejam individuais ou coletivos. Assim, o relator ordenará a comunicação dos órgãos jurisdicionais de que os seus processos, em que se discute a mesma questão de direito, foram suspensos em virtude da admissão do incidente de resolução (art. 982, § 1.o, do CPC/2015).

De qualquer forma, o § 2.o do art. 982 do CPC/2015 esclarece que o requerimento de tutela de urgência, de natureza antecipada ou cautelar, que se mostrar necessária após a instauração do incidente, deverá ser endereçado ao juízo em que tramita o processo suspenso.

A suspensão dos processos cessa quando não interposto recurso especial ou extraordinário contra a decisão do tribunal. Significa que a suspensão prossegue na pendência do recurso às Cortes Supremas. É curioso que o § 5.o do art. 982 do CPC/2015 evita falar em decisão definitiva do incidente, o que seria muito mais simples. Isso deve ter ocorrido por terem os artigos 985, II e 986 do CPC/2015 previsto a possibilidade de revisão da decisão proferida no incidente. Porém, o fato de um precedente poder ser revisto, obviamente, não retira o caráter de definitividade da decisão que o firmou. Na realidade, a decisão do incidente, além de não constituir “verdadeiro precedente”, produz coisa julgada sobre a questão, de modo que a revisão da decisão do incidente nada mais é do que a possibilidade de rediscutir a questão de direito com base em fundamento não deduzido, excluindo-se o dedutível da eficácia preclusiva da coisa julgada.

4. Suspensão das demandas individuais e coletivas repetitivas. O art. 982 do CPC/2015 fala de suspensão de processos individuais e coletivos no seu inciso I e no § 3.o. Supõe-se que a questão de direito pode constituir prejudicial não só de julgamento de ações individuais, mas, também, de ações coletivas. Como a questão de direito deve ser prejudicial de “demandas repetitivas” para

legitimar o incidente de resolução, as ações individuais e coletivas devem ter características comuns, idôneas para permitir-lhes assumir a natureza de repetitivas.

É possível que, ao lado de inúmeras ações individuais, tenha sido proposta ação coletiva por determinado ente legitimado pela Lei da Ação Civil Pública ou pelo CDC. Isso pode ocorrer, a princípio, quando são propostas ações individuais por pessoas que estariam representadas no processo coletivo. A ação coletiva não impede o ajuizamento de ações individuais por aqueles que, em tese, estão representados pelo autor da ação coletiva de tutela de direitos individuais homogêneos. Quando isto ocorre – ou quando nas ações já propostas não é requerida a suspensão do processo no prazo de trinta dias contado da ciência do ajuizamento da ação coletiva – os autores das demandas individuais se excluem do processo coletivo e, assim, deixam de poder ser beneficiados pela eventual sentença de procedência.

Também podem existir ações individuais paralelas a uma ação coletiva de tutela de direitos individuais homogêneos quando esta é proposta por ente que representa parcela dos sujeitos titulares do direito controvertido. Nesse caso, as ações individuais dos não representados podem ser vistas como comuns à ação coletiva. Note-se que igualmente nesta hipótese pode haver uma mesma questão de direito prejudicial ao julgamento das demandas individuais e da demanda coletiva.

Há ações individuais e coletivas ou coletivas repetitivas, quando se postula igual direito e se controverte, enquanto prejudicial, sobre uma mesma ou idêntica questão de direito. Além disso, para que se possa ter demandas repetitivas, em nenhuma das ações individuais e coletivas pode haver questão de direito distinta a ser solucionada e, em nenhuma delas, pode ter sido questionado fato que não torna a questão unicamente de direito. Se o réu invocou questão de direito diferente ou um fato que torna a questão que seria unicamente de direito uma questão de direito que depende de produção de prova, esta ação individual ou não depende de uma questão de direito essencial ou não depende de uma questão unicamente de direito, requisitos para que se tenha incidente de resolução para o julgamento de uma mesma questão unicamente de direito prejudicial à resolução de demandas repetitivas.

Contudo, é preciso alertar para a contradição de ter ação coletiva como ação capaz de gerar o incidente de resolução – tal como delineado pela letra do código. Isso porque a ação coletiva é legitimada pela “representação adequada”, mas o incidente despreza a participação e a representação, imaginando-se como um procedimento mágico em que são instituídos precedentes que podem excluir o direito constitucional de o jurisdicionado discutir os seus direitos. Como na ação coletiva encontra-se o representante adequado, o deslocamento da ação coletiva para o âmbito do incidente de resolução – nos termos desenhados pela lei processual – aborta a participação indireta dos representados no processo coletivo, deixando-os completamente desamparados e desprotegidos.

5. Suspensão dos processos repetitivos em todo o território nacional. O incidente toca às raízes do absurdo nos §§ 3.o e 4.o do art. 982 do CPC/2015. Os parágrafos dizem ser possível a suspensão de demandas que dependem do julgamento da mesma questão de direito em todo o território nacional, desde que haja requerimento de parte de uma demanda repetitiva, ou mesmo do Ministério Público ou da Defensoria Pública, independentemente do local do país em que a questão está sendo discutida.

Afirma-se no § 3.o que qualquer parte de demanda repetitiva ou o Ministério Público ou a Defensoria Pública podem requerer ao Superior Tribunal de Justiça ou ao Supremo Tribunal Federal, conforme a questão seja de direito federal infraconstitucional ou constitucional, a suspensão de todos os processos individuais e coletivos que dela dependam em todo o território nacional. No § 4.o frisa-se que o requerimento de parte de demanda repetitiva pode ser feito independentemente dos limites da competência territorial.

Entende-se, assim, que uma vez instaurado incidente em determinado tribunal, torna-se possível requerer a suspensão no território nacional de todas as demandas repetitivas que dependam da solução da mesma questão. Sendo a questão de direito idêntica e essencial, admite-

se o requerimento de suspensão de todos os processos que se desenvolvem no território brasileiro, independentemente do local do país em que esteja a demanda repetitiva.

O legislador entende que tudo isso deve ocorrer em nome da segurança jurídica. Uma única decisão seria indispensável à segurança jurídica, mas essa poderia ser alcançada a despeito dos litigantes, que, na lógica do legislador, independentemente do local do país em que se encontram, podem ter o exercício dos seus direitos constitucionais de ação suspensos sem com que qualquer representante adequado seja chamado a atuar em seus nomes. O legislador inverte a lógica das coisas, pois ao negar qualquer possibilidade de participação aos litigantes, parte da premissa de que os jurisdicionados são um obstáculo à prestação jurisdicional adequada.

Não fosse isto, é preciso ter claro que é pouco mais do que absurdo supor que a segurança jurídica clama por uma mesma decisão para todos os jurisdicionados que discutem uma mesma questão de direito. Direito à igualdade perante as decisões judiciais é algo completamente diferente de direito a uma única decisão para casos iguais. Direito a uma mesma e única decisão depende, necessariamente, de um processo em que haja participação direta de todos os litigantes ou representação adequada. Não há como idealizar a edição de uma única decisão por uma Corte Suprema – competente para a questão de direito federal infraconstitucional ou constitucional – para resolver as demandas de jurisdicionados situados em diferentes locais do país, como se estes pudessem ser mantidos alheios a tudo ou, ainda, fossem empecilhos à atuação da jurisdição.

Perceba-se que a lógica do precedente considera especialmente o futuro, enquanto está se pretendendo, sob a artificial afirmação de que a decisão do incidente deve ser observada pelos juízes e tribunais (art. 927, III, do CPC/2015), simplesmente regular casos conflitivos concretos que já eclodiram no seio social. Isso, diga-se mais uma vez, não é elaborar precedente obrigatório, mas editar uma única decisão para todos os casos.

O legislador justificou a suspensão das demandas repetitivas em todo o território nacional sob o argumento de que a segurança jurídica requer uma única decisão para demandas repetitivas, mas não foi nem mesmo capaz de perceber que as decisões proferidas em recurso extraordinário com repercussão geral constituem precedentes indispensáveis à regulação da vida social e dos casos futuros. Significa que, realmente, não sabe do que fala quando alude à segurança jurídica e aponta para as decisões do art. 927 do CPC/2015, que, além de excluir os verdadeiros precedentes, descreve algumas decisões que nada têm a ver com precedentes obrigatórios⁷⁷.

Art. 983. O relator ouvirá as partes e os demais interessados, inclusive pessoas, órgãos e entidades com interesse na controvérsia, que, no prazo comum de 15 (quinze) dias, poderão requerer a juntada de documentos, bem como as diligências necessárias para a elucidação da questão de direito controvertida, e, em seguida, manifestar-se-á o Ministério Público, no mesmo prazo.

§ 1.º Para instruir o incidente, o relator poderá designar data para, em audiência pública, ouvir depoimentos de pessoas com experiência e conhecimento na matéria.

§ 2.º Concluídas as diligências, o relator solicitará dia para o julgamento do incidente.

1. Ouvida dos interessados: nem toda questão objeto de incidente é uma questão complexa ou de repercussão social; contradição entre participação de interessados e ausência de representação adequada. De acordo com o art. 983, “o relator ouvirá as partes e os demais interessados, inclusive pessoas, órgãos e entidades com interesse na controvérsia”. O relator, obviamente, deve ouvir as partes, sejam as partes do processo originário (demanda repetitiva que deu origem ao incidente), sejam os legitimados à tutela dos direitos dos litigantes excluídos, isto é, os representantes adequados. Mas também poderá ouvir “interessados”, isto é, “pessoas, órgãos e entidades com interesse na controvérsia”.

O interessado é o terceiro sem interesse jurídico, vale dizer, o terceiro que não pode ser atingido pelos efeitos reflexos da coisa julgada. Trata-se do terceiro que tem sempre interesse que prevaleça a posição de uma das partes. O terceiro, assim, intervém como *amicus curiae*.

A participação do *amicus* é importante quando se está a discutir questões de direito de amplo interesse, para cuja solução, não raramente, é preciso dissipar divergências presentes na sociedade, de conteúdo moral, religioso, econômico ou que afetam direitos fundamentais. É por isso que a figura do *amicus* tem relevância em face das discussões travadas no Supremo Tribunal Federal, dada a amplitude de significado das normas constitucionais, e a complexidade e a disputa entre valores que marcam os casos em que se busca a delimitação do sentido dos direitos fundamentais. Isso não quer dizer, porém, que a definição do sentido da lei federal também não possa exigir a intervenção do *amicus* em face de questões complexas, e relevantes, para a vida em sociedade.

É preciso perceber, apenas, que nem toda questão de direito, que se repete em demandas que se multiplicam, envolve disputas sociais ou mesmo tem alguma complexidade. Ao contrário, questões idênticas que se repetem em demandas de massa são, na maioria das vezes, de simples resolução, envolvendo apenas aspectos técnico-jurídicos ou dogmáticos. De modo que não se pode pensar que a participação do *amicus* tem relação necessária com demandas repetitivas.

Ademais, é indispensável lembrar que a participação do *amicus*, além de ser importante diante de questões que envolvem disputas morais etc., serve para justificar a tomada de uma posição pela Corte. Isso gera grande contradição, e desconforto, quando se pensa que os próprios litigantes excluídos do incidente poderiam não estar representados por alguém capaz de defendê-los.

Não há sentido em ter *amicus* e não ter representante adequado, pois, desta forma, há alguém falando em prol de uma posição social, mas ninguém argumentando em nome de quem possui direito concretamente em disputa ou em litígio. Percebe-se que o *amicus* é muito mais importante quando se tem em jogo a elaboração de um precedente, enquanto que o representante adequado é simplesmente indispensável quando se discute um direito pertencente a pessoas que não participam diretamente do processo.

2. Justificativa para a intervenção de interessados diante de questão de direito prejudicial a demandas repetitivas. A intervenção do interessado é parcial, objetivando favorecer terceiros que desejam determinada solução para a questão de direito. Não obstante a intervenção se dê para favorecer alguém, oferece-se à Corte um panorama mais amplo em relação àquele demarcado pelas partes, o que aproxima o *amicus* da sua primeira vocação⁷⁸, voltada ao auxílio da Corte e ao alcance da “justiça”.⁷⁹

Não há motivo para supor que o *amicus* só tem razão para intervir para tratar de ponto que não pôde ser esclarecido pelos litigantes⁸⁰. No incidente, o interessado pode intervir para auxiliar a vitória de uma das partes, trazendo argumentos capazes de influenciar a Corte na resolução da questão de direito. Trata-se de argumentos destinados a elucidar quaisquer pontos que possam influenciar a compreensão e o julgamento da questão de direito.

Mas esse modo de intervenção não se confunde com a participação dos representantes adequados nem, obviamente, pode substituí-la. A representação adequada é imprescindível para suprir a não participação direta dos litigantes excluídos ou dos membros do grupo, ao passo que a intervenção do interessado, a princípio, presta-se a auxiliar a posição de uma das partes, ou seja, o representante adequado ou o seu adversário.

Na representação adequada, defende-se os direitos dos excluídos em razão destes não terem oportunidade de participar diretamente; na intervenção do interessado, sustenta-se a tese de uma das partes para – na hipótese em que o interessado auxilia o representante adequado – beneficiar os representados e os terceiros interessados na decisão enquanto jurisprudência ou precedente. Note-se que quando há representante adequado, os beneficiados podem ser representados interessados na coisa julgada e terceiros interessados na jurisprudência ou no precedente⁸¹.

Portanto, a representação adequada é necessária para garantir o *due process*, ao passo que a intervenção do *amicus* destina-se, apenas, a auxiliar uma das partes e, conforme a hipótese, beneficiar os representados e os terceiros ou apenas os terceiros. Diante do representante adequado e do *amicus* existem interesses supraindividuais, mas se o representante adequado

possui a clara função de proteger os direitos dos representados, suprimindo a não participação direta, o *amicus* só pode argumentar para que a Corte considere-os. O *amicus* não pode pedir tutela direta dos direitos, ao passo que representante adequado tem o dever de participar firmemente do processo para que os direitos sejam devidamente tutelados. Como igualmente demonstra a experiência estadunidense, as figuras do *amicus curiae* e do representante adequado não se excluem, pois têm finalidades distintas, de modo que é compreensível que, ao lado do representante adequado, admita-se a participação de interessado para argumentar a seu favor e em benefício dos representados e daqueles que têm interesse na jurisprudência ou no precedente⁸².

3. Elucidação da “questão de direito controvertida”. Como o incidente de resolução não pode ter como objeto uma questão de direito que depende da prova, mas somente uma “questão unicamente de direito” – nos termos do art. 976 do CPC/2015 –, não há como admitir que as partes e os interessados possam juntar documento e requerer diligências para elucidar um fato litigioso, ou seja, um fato contestado cuja elucidação é imprescindível para a resolução da questão de direito. Afinal, as questões de direito que dependem de prova não podem ser objeto de incidente de resolução. E isso é, inclusive, reafirmado pelo art. 983 do CPC/2015, que não trata de produção de prova, mas apenas alude a “diligências necessárias para a elucidação da questão de direito controvertida”.

O art. 983 do CPC/2015, ao dar oportunidade para as partes e os interessados não apenas falarem, mas, também, juntarem documentos e requererem diligências, tem em consideração elementos que devem ser compreendidos pelo tribunal para a resolução da questão jurídica. Quanto mais a questão de direito se vincula a aspectos culturais, científicos, econômicos ou religiosos, mais o intérprete depende de um efetivo debate em torno deles. A elucidação da questão de direito – e não do fato litigioso indispensável para se saber se a norma se aplica ao caso concreto – está presa ao esclarecimento de circunstâncias necessárias para a compreensão da norma e, muitas vezes, da sua extensão a determinados sujeitos.

4. Audiência pública. O legislador confere ao relator a possibilidade de designar audiência pública para ouvir depoimentos de especialistas a respeito de pontos importantes para a resolução da questão de direito. Deixe-se claro, porém, que o fato de uma questão de direito constituir prejudicial ao julgamento de muitas demandas não a torna, só por isso, passível de investigação diferenciada, como se tivesse que, necessariamente, contar com o esclarecimento de especialistas. Ao contrário, estas questões podem ser de fácil solução.

Além disso, os esclarecimentos que devem ser feitos em audiência pública não são os que dizem respeito à elucidação sobre a ocorrência de fato de que depende o julgamento da questão de direito. Realmente, quando se fala em ouvir “depoimentos de pessoas com experiência e conhecimento na matéria” não se está pensando em buscar esclarecimentos sobre como os fatos se passaram, mas em abrir debate entre as posições divergentes mediante o auxílio de depoimentos de especialistas sobre circunstâncias que dizem respeito à inteligência da norma ou da questão jurídica, os quais devem ser confrontados e rigorosamente checados pelo juiz em todos os seus aspectos, inclusive o da idoneidade daquele que o produziu.

Art. 984. No julgamento do incidente, observar-se-á a seguinte ordem:

I – o relator fará a exposição do objeto do incidente;

II – poderão sustentar suas razões, sucessivamente:

a) o autor e o réu do processo originário e o Ministério Público, pelo prazo de 30 (trinta) minutos;

b) os demais interessados, no prazo de 30 (trinta) minutos, divididos entre todos, sendo exigida inscrição com 2 (dois) dias de antecedência.

§ 1.º Considerando o número de inscritos, o prazo poderá ser ampliado.

§ 2.o O conteúdo do acórdão abrangerá a análise de todos os fundamentos suscitados concernentes à tese jurídica discutida, sejam favoráveis ou contrários.

1. Discussão da questão de direito. O art. 984 do CPC/2015 trata do modelo de julgamento a ser observado no incidente de resolução de demandas. Afirma-se, em primeiro lugar, que o relator deverá fazer a exposição do objeto do incidente. Deve o relator descrever a questão de direito a ser julgada e situá-la no contexto das demandas repetitivas. Assim, além de delinear a controvérsia sobre a questão de direito, o relator deve demonstrar o modo como ela influi sobre a definição das demandas que se repetem, considerando as alegações das partes do processo originário e dos representantes adequados também presentes no incidente, vale dizer, das partes do incidente.

Logo após o relator deverá anunciar os fundamentos que foram apresentados pelas partes do incidente. Isso não quer dizer que não se possa tomar em conta outro fundamento para decidir a questão de direito. Se o relator vislumbrar fundamento importante para a resolução da questão que não tenha sido invocado por quaisquer das partes deverá anunciá-lo na abertura do julgamento. Todos os membros do colegiado devem ter a oportunidade de discutir a exposição inicial, especialmente, para que se conclua se outro fundamento – além dos definidos pelo relator – também deve ser discutido para a solução da questão. É claro que, ao ser definido fundamento para discussão colegiada que previamente não foi discutido pelas partes, deve-se conferir-lhes oportunidade para discuti-la em suas razões, inclusive, mediante a outorga de maior prazo para a sustentação. Aliás, se outro fundamento importante for identificado no meio do debate, ou seja, após a exposição do objeto do incidente pelo relator, é certo que o “novo” fundamento poderá ser tomado em consideração. Apenas se deverá dar oportunidade para todos os julgadores discutirem-no – inclusive aqueles que já tenham se pronunciado e votado – e, antes disso, para as partes do incidente debaterem-no.

Não só não é possível excluir os julgadores que já votaram da discussão do fundamento – como, equivocadamente, sempre se fez no julgamento dos recursos –, como não há como negar às partes do incidente o direito de debatê-lo, nos termos do art. 10 do CPC/2015, que veda a decisão baseada em fundamento que não pôde ser discutido pelas partes. É importante evitar decisões majoritárias que partam de um fundamento lembrado por julgador que vota no meio da ordem de votação, sem com que os julgadores que o antecederam tenham participado da sua discussão e as partes tenham tido oportunidade de debatê-lo.

É assim que deve ser compreendida a necessidade de o relator expor a questão do direito, sua inserção no contexto das demandas repetitivas e os fundamentos que deverão ser discutidos para se encontrar a decisão. Essa descrição e explicação são importantes não só para a deliberação colegiada, mas, também, para se dar às partes do incidente uma adequada oportunidade de influenciar os julgadores.

Realmente, não são raros os casos em que, após a sustentação oral, são invocados fundamentos que até então não tinham sido discutidos. O art. 984 do CPC/2015, ao aludir à “ordem” do “julgamento” e ao elencar, como primeira providência, a “exposição do objeto do incidente”, além de permitir que o direito de influir sobre o tribunal ganhe concretude, confere ao julgamento colegiado a devida dimensão deliberativa – que não existe quando os fundamentos são invocados ao bel-prazer do julgador, como se não deveriam ser discutidos por todo o colegiado, mas tivessem importância, apenas, para justificar um voto ou uma posição pessoal.

Note-se que não basta que o conteúdo do acórdão abranja a análise de todos os fundamentos suscitados, conforme exige o § 2.o do art. 984 do CPC/2015. Para que o acórdão possa, adequadamente, descrever os fundamentos debatidos é preciso, antes de mais nada, que eles sejam definidos no início do julgamento para que possam ser discutidos de modo ordenado e lógico e, além disso, para que não sejam negligenciados ou mal discutidos pelo colegiado.

2. Participação das partes. O art. 984, II, do CPC/2015, curiosamente, fala apenas em partes do processo originário, deixando de aludir às partes do incidente, como se esse pudesse ser um processo sem partes. Diz a referida norma que poderão sustentar suas razões, além dos interessados, “o autor e o réu do processo originário e o Ministério Público”, pensado como fiscal

da lei.

Na linha do que foi dito na fundamentação apresentada no início dos comentários aos artigos que regulam o incidente de resolução de demandas repetitivas, esse requer interpretação conforme a Constituição para poder frutificar. A paralisação do exercício do direito fundamental de ação do litigante de demanda repetitiva e a exclusão da sua participação na discussão da questão de direito que afeta diretamente a tutela do direito que reivindica, sem que lhe seja conferida participação mediante um representante adequado, viola claramente os direitos fundamentais processuais.

Assim, para que o incidente não seja dito inconstitucional, é preciso ler as normas que lhe dizem respeito, de modo a fazê-lo conforme aos direitos fundamentais processuais. Para tanto é imprescindível que os litigantes excluídos sejam adequadamente representados, ou seja, é necessário contar com a participação dos legitimados à tutela dos direitos individuais homogêneos e de outros “representantes adequados”.

Como já dito, dando-se divulgação e publicidade à instauração do incidente, confere-se oportunidade para ingresso no processo dos representantes adequados, especialmente, dos entes legitimados à tutela dos direitos individuais homogêneos, previstos na Lei da Ação Civil Pública e no CDC. É certo que o Ministério Público ou a Defensoria Pública, tomando contato com as demandas repetitivas, desde logo, podem pedir a tutela dos direitos dos litigantes em face da questão de direito que é prejudicial ao julgamento das suas demandas, quando posterior intervenção não é indispensável para conferir possibilidade de participação indireta aos litigantes excluídos. Não obstante, quando o incidente é instaurado a requerimento do juiz ou do relator, ou mesmo quando é instaurado por uma das partes de demanda repetitiva, seja ela qual for, a participação de um ente legitimado torna-se imprescindível. Nessa hipótese, à falta de ingresso no incidente de qualquer legitimado à tutela dos direitos individuais homogêneos, a iniciativa do Ministério Público não pode ser excluída. O Ministério Público, neste caso, necessariamente, deve tomar o local de representante adequado dos litigantes excluídos, não lhe sendo bastante, como é óbvio, a participação enquanto fiscal da lei.

De modo que a norma do inciso II, *a*, do art. 984 do CPC/2015 deve ser vista com cautela. Não basta dar às partes do processo originário e ao Ministério Público, na qualidade de fiscal da lei, oportunidade para “sustentar suas razões”.

3. Participação dos amici. O art. 984, II, *b*, do CPC/2015, confere aos “demais interessados” a possibilidade de sustentar suas razões, advertindo que, para tanto, é necessária inscrição com prazo de dois dias de antecedência, contando todos os inscritos com o prazo de trinta minutos.

O art. 984, II, ao tratar do prazo dos interessados (alínea *b*), afirma, expressamente, que o prazo de trinta minutos deve ser dividido “entre todos”, mas, ao cuidar do prazo para as partes e para o Ministério Público (alínea *a*), diz que estes podem sustentar as suas razões “pelo prazo de trinta minutos”, sem qualquer alusão a divisão de prazo. Nessa linha, adverte-se que o prazo dos “interessados” pode ser ampliado, considerando-se o número de inscritos (art. 984, § 1.o, CPC).

Interessados são “pessoas, órgãos e entidades com interesse na controvérsia” (art. 983 do CPC/2015). São, especialmente, as associações que, sem poder para intervir como representante adequado ou sem ter esta pretensão, na maioria das vezes, têm interesse na decisão enquanto jurisprudência (do Tribunal) ou precedente (do Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal), embora também possam ter interesse de que a decisão da questão de direito, enquanto coisa julgada, seja favorável a uma das partes do incidente e, por consequência, aos litigantes das demandas repetitivas.

Esclareça-se que os entes que podem intervir como interessados não necessitam estar do lado da grande massa de litigantes excluídos, ou seja, daqueles que afirmam que os seus direitos foram lesados. Também cabe a intervenção de interessados na vitória daqueles que se colocam como adversários dos litigantes que sustentam que os seus direitos foram violados nas várias demandas, especialmente, para a formação de jurisprudência ou precedente favorável.

De qualquer forma, sempre caberá ao interessado explicar o motivo da sua intervenção, declinando o seu interesse na vitória de uma das partes, a sua relação com aqueles que podem ser diretamente afetados pela resolução da questão e o modo como estes podem ser atingidos. Não é preciso dizer que a admissibilidade da intervenção do interessado é subordinada à aferição da pertinência entre a sua função institucional, aqueles a quem diz representar e a questão de direito a ser dirimida pela decisão do incidente.

4. Discussão, decisão e justificativa dos fundamentos. Como já dito, os fundamentos que podem determinar a solução da questão de direito devem ser discutidos de maneira particularizada, evitando-se que um fundamento seja discutido por alguns membros do colegiado e outro; ou outros fundamentos somente pelos demais. Basicamente, o que não se quer é o fracionamento da discussão do colegiado entre os vários fundamentos, como se o fundamento não importasse à totalidade do colegiado, mas apenas ao julgador que o tem como relevante.

Para que os fundamentos não se percam em meio da discussão e dos votos dos membros do colegiado, importa o seu delineamento no início do julgamento, quando o relator faz “a exposição do objeto do incidente” (art. 984, I, do CPC/2015). Com isso, evita-se o esquecimento e a discussão deficiente dos fundamentos, desestimulando-se a praxe da análise do fundamento que cada julgador reputa relevante e enfatizando-se que os fundamentos, por princípio, devem ser analisados por todo o colegiado para que se tenha um julgamento integral das razões das partes, e para que ocorra uma verdadeira decisão colegiada, que não pode ser confundida com um ajuntamento de decisões individuais dos membros do colegiado.

Isto não quer dizer, porém, que os fundamentos devam ser decididos de maneira individualizada. Uma questão de direito pode e deve ser decidida em favor de uma das partes ainda que com base em diversos fundamentos, ou melhor, com base em fundamentos que, quando vistos isoladamente, não são acolhidos pela maioria do colegiado, mas que, quando agrupados, significam maioria suficiente para a decisão da questão de direito em favor de uma das partes.

A justificativa da decisão, no entanto, não pode ter em conta apenas os votos individuais como expressão das razões que levaram ao acolhimento deste ou daquele fundamento. Ou melhor, não é suficiente descrever o que cada desembargador ou grupo de desembargadores pensa sobre os fundamentos e, por consequência, sobre a questão de direito. Como percebeu ser necessário o § 2.o do art. 984 do CPC/2015, o conteúdo do acórdão deve abranger a análise de todos os fundamentos discutidos, sejam favoráveis ou contrários. Significa dizer, bem vistas as coisas, que a justificação está a se deslocar dos votos individuais para os fundamentos. Rompe-se com a tradição da fundamentação que, simplesmente, faz ver as decisões individuais, comumente subordinadas a uma ementa que nada retrata, na medida em que não busca um ponto comum nem nos votos que firmam a posição majoritária, nem naqueles que são divergentes.

Um acórdão que se preocupa em analisar todos os fundamentos discutidos, sejam favoráveis ou contrários, só pode ser um acórdão destinado a descrever os fundamentos discutidos e a justificar o fundamento que foi acolhido pela maioria, o fundamento que, eventualmente, concorreu para a decisão majoritária e o fundamento divergente, isto é, o fundamento sustentado pelos julgadores que decidiram de modo “contrário”, para usar a expressão do § 2.o do art. 984 do CPC/2015.

Art. 985. Julgado o incidente, a tese jurídica será aplicada:

I – a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem na área de jurisdição do respectivo tribunal, inclusive àqueles que tramitem nos juizados especiais do respectivo Estado ou região;

II – aos casos futuros que versem idêntica questão de direito e que venham a tramitar no território de competência do tribunal, salvo revisão na forma do art. 986.

§ 1.o Não observada a tese adotada no incidente, caberá reclamação.

§ 2.o Se o incidente tiver por objeto questão relativa a prestação de serviço concedido, permitido ou autorizado, o resultado do julgamento será comunicado ao órgão, ao ente ou à

agência reguladora competente para fiscalização da efetiva aplicação, por parte dos entes sujeitos a regulação, da tese adotada.

1. Significado de “tese jurídica”. O art. 985 do CPC/2015 fala em “tese” em três oportunidades. No *caput* afirma que a “tese jurídica” deve ser aplicada aos casos pendentes e aos futuros. No § 1.º adverte que, “não observada a tese adotada no incidente, caberá reclamação”. E no § 2.º alude à “fiscalização da efetiva aplicação” da “tese adotada”.

O art. 985, na linha da equivocada premissa que norteia o incidente de resolução de demandas repetitivas, utiliza uma expressão que supõe que a decisão proferida no âmbito do incidente é um precedente. Lembre-se que um precedente é caracterizado por ter *ratio decidendi*, ou melhor, por não poder ser explicado sem a consideração do fundamento que determina a resolução do caso ou a parte dispositiva da decisão. Isso ocorre, basicamente, porque um precedente não está preocupado apenas em resolver o caso ou dar uma solução às partes do litígio. Fala-se em precedente quando se sabe que a vocação do órgão judicial que profere a decisão é a de, ao lado de solucionar o litígio, dar desenvolvimento ao direito e, assim, orientar as pessoas e dar regulação aos casos que estão por vir. Assim, como a parte dispositiva nada diz sobre o direito e, portanto, nada informa à sociedade e àqueles que estão preocupados com os casos futuros, torna-se natural identificar na fundamentação a porção do conteúdo da “decisão” que incorpora o que foi afirmado, em termos de direito, pela Corte.

A *ratio decidendi* e os fundamentos determinantes, expressões tradicionalmente utilizadas para expressar a porção da fundamentação que identifica o modo como a Corte efetivamente resolveu a questão de direito, caracterizam os precedentes⁸³. Só há razão para falar em *ratio decidendi* ou em fundamento determinante quando se busca delinear o que orienta a vida social e os casos futuros. Quando se pensa apenas nos litigantes é completamente supérfluo, e até mesmo contraditório, aludir a *ratio decidendi* e a fundamentos determinantes – embora isto não seja incomum em decisões judiciais e passagens doutrinárias.

Assim como a *ratio decidendi* e os fundamentos determinantes dizem respeito às decisões que orientam a sociedade e os juízes dos casos futuros, a coisa julgada mostra-se ligada aos litigantes. Esclareça-se que a *ratio decidendi* detém, implicitamente, a ideia da sua obrigatoriedade, até porque pensar numa *ratio decidendi* que pode ou não ser adotada seria não só uma contradição em termos, porém uma verdadeira perda de tempo e de energia.

A ideia de “tese jurídica” é uma versão de *civil law* que, certamente, será inadequada para retratar a porção da fundamentação que revela o que a Corte pensa sobre uma questão jurídica se for confundida com o resultado do raciocínio interpretativo do colegiado, ou melhor, se for vista como um enunciado da interpretação-resultado ou um resumo da solução conferida à questão de direito. A ideia de tese jurídica, para bem funcionar, não pode ser outra coisa que não o fundamento – subscrito pela maioria do colegiado – que determina a solução do caso ou do recurso, considerada a moldura fática em que as razões determinantes da Corte estão inseridas. A não ser assim, a “tese jurídica” corre o sério risco de se transformar num enunciado abstrato tão incapaz de regular os casos quanto as velhas máximas do direito italiano e as súmulas do nosso direito. Enunciados abstratos de nada adiantam quando se pensa em regular casos que estão por vir. É que o juiz, para poder saber se uma “tese” ou “ratio” se aplica ao caso sob julgamento, não pode deixar de ter em conta a situação conflitiva concreta a partir da qual a Corte expressou as suas razões de direito⁸⁴. Fora desta dimensão uma *ratio decidendi* não apenas serve para qualquer caso, como também não oferece ao juiz dos novos casos quaisquer critérios que permitam a racionalidade da sua aplicação de modo restritivo ou extensivo⁸⁵.

Mas o verdadeiro problema é o de que, tratando-se de incidente de resolução de demandas repetitivas, não há como pensar em precedente e, portanto, nem em *ratio decidendi* nem em “tese jurídica”. No art. 985 do CPC/2015 o legislador, mais uma vez, dá clara demonstração de que imagina que o incidente pode dar origem a um precedente obrigatório. Tanto é assim que, ao invés de falar de decisão de questão ou de coisa julgada, grosseira, e equivocadamente, alude a “aplicação”, “não observância” e “fiscalização da efetiva aplicação” da “tese adotada”.

E um absurdo pensar em aplicar uma “tese” a casos de litigantes que não têm qualquer direito de participar por meio de representantes adequados simplesmente por ter sido firmada num processo chamado de “incidente de resolução de demandas repetitivas”. Aliás, o legislador nem mesmo conseguiu encontrar um nome adequado para traduzir o que pretendeu, pois, obviamente, não se está a resolver demandas, mas a resolver questão de direito prejudicial ao julgamento de demandas. Ora, essa questão de direito só tem motivo para ser resolvida pelo fato de constituir prejudicial ao julgamento de demandas de pessoas que, como se sabe, têm o direito constitucional de apresentá-las ao juiz. Portanto, decidir tal questão de direito como se os litigantes não existissem é um sério, e inexplicável, escárnio com as garantias constitucionais processuais.

A decisão de tal questão de direito, ainda que em incidente apelidado de resolução de demandas repetitivas, nada tem a ver com *ratio decidendi* ou mesmo pode ser concebida como tese que deve ser aplicada ou fiscalizada e pode não ser observada. O incidente pressupõe um conflito já instalado, de que derivam demandas pendentes ou que ainda podem ser apresentadas. Gera verdadeira decisão de questão prejudicial ao julgamento de pretensões que já foram exercidas (casos pendentes) ou que ainda poderão ser exercidas (casos futuros). Os litigantes excluídos, que desde a eclosão do conflito tinham direito constitucional de discutir a questão de direito, ficam proibidos de relitigá-la. Isso apenas pode acontecer quando os litigantes excluídos estão adequadamente representados perante o Tribunal.

2. Coisa julgada erga omnes sobre questão. É certo que a tradição de *civil law*, traduzida no CPC/1973, associa a coisa julgada à parte dispositiva da decisão, que responde ao pedido formulado na petição. A relação entre coisa julgada e dispositivo da decisão, assim, tem base no princípio da demanda, que circunscreve a decisão judicial àquilo que foi solicitado pelo autor.

No *common law*, ao contrário, desde tempos imemoriais as questões prejudiciais discutidas e decididas pelo juiz ficam proibidas de ser relitigadas pelas partes. Aí teve relevância, com certeza, a ideia de que não haveria racionalidade em admitir a rediscussão de questão já debatida pelos litigantes e definida pelo juiz, pouco importando se a sua solução não tivesse sido clara e, expressamente, pedida pelo autor da demanda. Mais do que a liberdade do litigante, importou a autoridade da decisão judicial e a estabilidade das relações sociais.

De qualquer forma, a ideia presente no *common law* não passou despercebida no *civil law*⁸⁶. O CPC/2015 encampou-a expressamente, advertindo que a coisa julgada se estende à “resolução de questão prejudicial, decidida expressa, e incidentemente, no processo, se: i) dessa resolução depender o julgamento do mérito; ii) a seu respeito tiver havido contraditório prévio e efetivo, não se aplicando no caso de revelia; e iii) o juízo tiver competência em razão da matéria e da pessoa para resolvê-la como questão principal” (art. 503, § 1.º, do CPC/2015).

Tendo em vista que o código firma que a decisão da questão prejudicial ao julgamento do mérito é coberta pela coisa julgada material, resta apenas perceber que o legislador, simplesmente, transferiu a análise e a decisão das questões prejudiciais ao julgamento das demandas repetitivas para o incidente – que, bem vistas as coisas, é de resolução de “questão idêntica”.

Como o incidente requer a participação dos representantes adequados dos litigantes excluídos, a decisão da questão idêntica produz coisa julgada *erga omnes*. A coisa julgada *erga omnes* não é apenas a favor, como acontece na ação coletiva de tutela de direitos individuais homogêneos (art. 103, III, do CDC), mas a sua eficácia preclusiva não atinge o dedutível. Isso assim ocorre em virtude de que os arts. 985 e 986 do CPC/2015 admitem a “revisão” da decisão da questão jurídica, que, racionalmente, apenas pode ser uma rediscussão da questão de direito já decidida a partir de um fundamento que, embora pudesse ter sido deduzido e discutido, não foi.

3. Decisão do incidente e resolução das demandas repetitivas. Afirma-se que a “tese jurídica” será “aplicada” aos casos pendentes e futuros (art. 985, I e II, do CPC/2015). Porém, a decisão da questão produz coisa julgada *erga omnes* e, nessa condição, atinge os processos que ficaram suspensos e os casos futuros.

Sublinhe-se que os casos pendentes não são resolvidos pela decisão do incidente. Isso porque as demandas repetitivas têm a questão objeto do incidente apenas como prejudicial. Os objetos das demandas repetitivas não se confundem com o objeto do incidente. Enquanto o objeto do incidente é uma mesma questão de direito, ou seja, uma questão idêntica, as demandas repetitivas têm os mais diversos objetos. Ainda que as demandas repetitivas estejam subordinadas à coisa julgada da decisão sobre a questão idêntica, exigem o julgamento do pedido ou de seu próprio mérito.

Uma vez decidida a questão prejudicial no incidente, o raciocínio do juiz para o julgamento da demanda pode ser mais ou menos trabalhoso e complexo. Assim, por exemplo, uma vez resolvida a questão da responsabilidade em favor dos autores das demandas repetitivas; determinadas demandas podem não necessitar de qualquer prova ou se contentar com a prova documental, enquanto outras podem exigir prova testemunhal ou prova pericial.

Lembre-se que o incidente de resolução não permite a produção de prova para o esclarecimento da questão de direito. Só pode ser objeto de incidente a questão de direito que não requer provas para ser decidida. Contudo, uma vez decidida a questão de direito, a demanda repetitiva requer julgamento, para o qual pode ser necessária a produção de prova.

É certo que a questão de direito objeto do incidente deve ser essencial, ou determinante, do julgamento das demandas repetitivas. Isso quer dizer que a demanda, para ser repetitiva, não pode depender, além da mesma questão de direito, de outra questão passível de excluir a razão de ser da decisão do incidente de resolução. Porém, há algo distinto quando, após a resolução da questão de direito, o julgamento das demandas repetitivas requer o esclarecimento de fatos que dizem respeito a algo que toma a coisa julgada como premissa, ou seja, como prejudicial decidida.

Está claro, portanto, não só que o incidente não resolve demandas, mas julga a questão de direito que lhes diz respeito, como também que as demandas repetitivas são singulares, exigindo cada uma um julgamento próprio, embora sempre dependente da solução de uma mesma questão de direito. Em termos práticos, a decisão da questão de direito pode ser, por assim dizer, apenas “transportada” para a definição das demandas repetitivas quando a decisão do incidente for desfavorável aos autores das demandas ou quando, sendo favorável, o julgamento das demandas repetitivas constituir mera consequência lógica da decisão do incidente.

4. Decisão do incidente e casos futuros. A decisão do incidente produz coisa julgada *erga omnes*, beneficiando ou prejudicando todos aqueles que participam por meio do representante adequado. Não há racionalidade em tomar em conta uma situação jurídica, sujeita a demandas que já pendem e que podem vir a ser propostas, sem com que aqueles que estão inseridos em tal situação concreta possam participar do processo em que é discutida a questão prejudicial à tutela dos seus direitos.

Para que a decisão do incidente seja aplicável a casos futuros, esses não só devem constituir demandas que tenham a questão de direito resolvida no incidente como prejudicial, como ainda devem ser demandas que derivem da mesma situação fático-concreta que fez surgir as demandas que pendiam quando foi instaurado o incidente. Não que os fatos devam ser historicamente os mesmos. Também pode haver demandas repetitivas quando a situação de fato se repete no tempo, de modo a fazer surgir inúmeros casos concretos delineados com base na mesma moldura fática e dependentes da solução de uma mesma questão de direito.

Porém, como já dito, só podem ser alcançados pela coisa julgada que recai sobre questão de direito solucionada em incidente aqueles que, além de terem tido a sua questão de direito posta à decisão, foram representados por um legitimado à tutela dos direitos individuais homogêneos, conforme a Lei da Ação Civil Pública e o CDC, assim como outras leis que outorgam legitimidade coletiva à tutela de específicos direitos. Litigantes de casos futuros, que não foram representados no incidente em que a questão de direito foi decidida, obviamente, não estão sujeitos à coisa julgada e, assim, têm liberdade e oportunidade de discutir amplamente a questão de direito e de exigir resolução em conformidade com os seus argumentos.

5. Reclamação. O § 1.º do art. 985 do CPC/2015 afirma que, caso “não observada a tese adotada no incidente, caberá reclamação”. O art. 988, IV do CPC/2015 afirma que cabe reclamação para “garantir a observância” de acórdão proferido em “julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas”.

O art. 988, IV, mais uma vez evidencia o equívoco do legislador, chamando a decisão do incidente de “precedente”. Entende-se que o precedente firmado no incidente de resolução não pode deixar de ser observado diante das demandas repetitivas.

Contudo, a decisão de “questão idêntica” nada mais é do que uma decisão de “questão de muitos”, que, só por isso, obviamente, não pode ser aplicada como um precedente. A decisão de uma “questão de muitos” aplica-se necessariamente. Um precedente, por não dizer respeito a ninguém de modo específico, sempre pode aplicar-se ou não, conforme as particularidades do caso sob julgamento.

Não é por outro motivo que a decisão proferida no incidente produz coisa julgada *erga omnes*. A decisão do incidente, ao resolver a questão de direito idêntica, não pode ser rediscutida nem deixar de ser observada nas demandas repetitivas, na medida em que os litigantes e o juiz do caso repetitivo estão submetidos à coisa julgada formada no incidente.

Por outro lado, eventual violação da coisa julgada, quando anterior ao trânsito em julgado, pode ser discutida mediante recurso; quando posterior, pode ser demonstrada por meio de ação rescisória (art. 966, IV, do CPC/2015). Aliás, uma das grandes novidades em tema de ação rescisória é a de que, a partir do Código de 2015, esta pode ser proposta com base em violação de coisa julgada sobre questão. Isso em virtude de que, com o novo código, passa-se a admitir a coisa julgada sobre questão (art. 503, § 1.º, do CPC/2015).

Assim, admitir reclamação em virtude da não observância da decisão proferida no incidente de resolução significa outorgar a esta decisão a mesma força conferida à decisão do Supremo Tribunal Federal no controle concentrado de constitucionalidade (art. 988, III, do CPC/2015).

6. Fiscalização pelo órgão regulador. Por fim, afirma o § 2.º do art. 985 do CPC/2015 que, “se o incidente tiver por objeto questão relativa a prestação de serviço concedido, permitido ou autorizado, o resultado do julgamento será comunicado ao órgão, ao ente ou à agência reguladora competente para fiscalização da efetiva aplicação, por parte dos entes sujeitos a regulação, da tese adotada”.

Trata-se aqui de uma decisão de questão de direito, “relativa a prestação de serviço concedido, permitido ou autorizado”, que diz respeito a “entes sujeitos a regulação”. Ora, se tais entes devem observar a decisão da questão de direito, devem ter participado direta ou indiretamente do incidente. Só assim podem se sujeitar à decisão ou responder à coisa julgada. Significa que o órgão regulador é comunicado para fiscalizar a observância da decisão da questão de direito por parte daqueles que, além de submetidos a tal decisão, estão sujeitos à sua regulação.

A previsão do § 2.º, portanto, destina-se a demonstrar que a decisão de questão de direito, “relativa a prestação de serviço concedido, permitido ou autorizado”, deve ter a sua observância fiscalizada pelo órgão regulador, evitando-se, assim, conflitos e ações judiciais derivados de uma postura inadequada dos entes regulados.

Note-se que, ainda que a decisão do incidente não reclame execução judicial, na medida em que constitui solução de questão prejudicial à decisão de demanda repetitiva, a fiscalização da observância, por parte do órgão regulador, funciona como uma espécie de “execução delegada” da decisão da questão de direito, lembrando-se que o órgão regulador pode impor sanções aos entes regulados.

Art. 986. A revisão da tese jurídica firmada no incidente far-se-á pelo mesmo tribunal, de ofício ou mediante requerimento dos legitimados mencionados no art. 977, inciso III.

1. Revisão de precedente de ofício ou por meio de requerimento do Ministério Público ou

da Defensoria Pública? O art. 986 do CPC/2015, partindo da premissa de que a decisão de questão idêntica é um precedente que vincula a resolução dos casos pendentes e futuros, afirma que a tese firmada no incidente pode ser revista de ofício ou mediante requerimento do Ministério Público ou da Defensoria Pública.

Um precedente, como é óbvio, é ditado para ter vida longa, para ter estabilidade e não surpreender a confiança nele depositada pelos jurisdicionados. É absurdo imaginar um precedente que está em condições de revogação logo após ter sido editado. Mas a tese firmada no incidente, diz o art. 985, II, do CPC/2015, pode ser revogada diante dos casos futuros, ou seja, pode ser revogada em face das demandas repetitivas que podem ser propostas logo depois do trânsito em julgado da decisão proferida no incidente. Equivale a dizer que a tese poderia ser revogada com base no argumento de que a questão de direito foi mal resolvida. Verifica-se, também por isso, que a tese firmada no incidente, realmente, não pode ser pensada como precedente.

Ora, um precedente não pode ser questionado apenas por se supor que não guarda a melhor solução jurídica. Deve ser revogado quando não mais corresponde aos padrões de congruência social e/ou de consistência sistêmica⁸⁷, quando há alteração da concepção geral sobre o direito – revelada em artigos, livros e decisões – bem como quando tem em sua base um claro equívoco. Mas a revogação do precedente, além de depender destas razões, deve, ao mesmo tempo, considerar os valores que sustentam a estabilidade, especialmente o da confiança justificada. A consideração deste valor importa para que os efeitos temporais da decisão não apanhem o jurisdicionado de forma injusta. O ônus de analisar os valores da estabilidade, na verdade, constitui um meio de prevenir a “surpresa injusta”.

Note-se que a decisão do incidente seria um precedente relacionado a uma situação passada que pode dar azo a demandas futuras. Trata-se de algo verdadeiramente absurdo, pois a razão de ser do precedente é orientar a sociedade e outorgar previsibilidade aos cidadãos, para que condutas possam ser praticadas com a segurança de que estão amparadas pelo Direito e serão referendadas pelo Judiciário. Uma situação que já ocorreu, certamente, não pode se beneficiar de um precedente. A decisão do incidente, equivocadamente imaginada pelo legislador como precedente, pode, apenas, servir para assegurar uma única decisão a casos múltiplos, o que foge das razões que inspiram um sistema de precedentes.

Quem faz parte de uma situação que ocorreu antes de um precedente ser firmado jamais poderá ser alvo de surpresa injusta em decorrência da sua revogação. Ora, ninguém pode ser surpreendido pela revogação de um precedente que não existia. Isso demonstra que a revogação de tese firmada em incidente nada tem a ver com revogação de “precedente obrigatório”. Esta revogação sequer precisa considerar os valores da estabilidade, muito menos o da confiança justificada. Toca às raias do absurdo imaginar que alguém pode ser surpreendido pela revogação de uma “tese” que sequer existia quando da prática da sua ação ou omissão.

Porém, o art. 986 do CPC/2015 ainda diz que a revisão da tese pode ser realizada de ofício pelo tribunal que a firmou ou mediante requerimento do Ministério Público ou da Defensoria Pública. É estranho que uma decisão que interessa a partes diversas possa ser revogada sem requerimento dos interessados, ou de seus representantes adequados. Também é muito estranho que a sorte da decisão possa ficar entregue ao Ministério Público e à Defensoria Pública enquanto entes preocupados apenas com a correção da decisão tomada no incidente, como se esta não afetasse concretamente a ninguém. Isso soa como uma previsão autoritária, típica dos regimes totalitários, em que o Estado e os órgãos que representam o “povo” se sobrepõem aos interesses das pessoas.

Ainda que a decisão fosse um precedente, não teria cabimento que este só pudesse ser revogado de ofício pelo tribunal que o instituiu ou somente mediante requerimento do Ministério Público ou da Defensoria Pública enquanto órgãos interessados na otimização e no aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. Um precedente pode ser revogado pela Corte que o editou a partir de debate entre partes interessadas na solução de um caso e, assim, do requerimento de uma destas partes para a não aplicação do precedente ao caso sob julgamento, em vista da sua superação ou equívoco manifesto na base do raciocínio que conduziu à sua elaboração.

Como será demonstrado nos próximos itens, a solução da questão de direito só pode ser revista mediante a invocação de outro fundamento – não discutido – por qualquer dos litigantes excluídos ou por qualquer legitimado à tutela dos direitos individuais homogêneos que não tenha participado do incidente. É certo que o Ministério Público e a Defensoria Pública poderão pedir a revisão da questão de direito, mas como representantes adequados dos prejudicados pela decisão, mediante atuação vigorosa em favor de litigantes excluídos, e não como entes descomprometidos com a tutela dos direitos daqueles que, de acordo com a lei – Lei da Ação Civil Pública e CDC –, devem defender em juízo.

2. Justificativa da possibilidade de rediscussão da questão de direito com base em fundamento que poderia ter sido deduzido. A questão de direito, como é óbvio, pode ser discutida e decidida a partir de diferentes fundamentos. É certo que a discussão e a decisão da questão de direito com base no fundamento “x” não equivale à discussão e à decisão da mesma questão de direito com base no fundamento “y”. No entanto, uma lógica de eficiência, que prioriza a eliminação dos litígios, permite sustentar que uma decisão tomada a partir de fundamentos livremente deduzidos obstaculiza a rediscussão da questão decidida com base em fundamentos anteriormente não deduzidos. Estes fundamentos estariam preclusos, seguindo-se a regra do “deduzido e do dedutível”.

A regra do deduzido e do dedutível está prevista no art. 508 do CPC/2015, segundo o qual, “transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido”. Porém, isso não quer dizer que essa regra tenha que se aplicar à coisa julgada sobre questão decidida no incidente.

Deixe-se claro, em primeiro lugar, que a regra que faz precluir o dedutível não é indissociável da coisa julgada material. Essa guarda autonomia em relação à sua eficácia preclusiva. Ademais, o fato de a regra estar presente no Código de Processo Civil não quer dizer que sempre deva estar associada à coisa julgada material. O art. 503, § 1.º, II, do CPC/2015, exclui a coisa julgada sobre questão prejudicial quando a seu respeito não tiver havido contraditório prévio e efetivo. Essa norma, ao afirmar que a questão prejudicial não devidamente discutida não faz surgir coisa julgada, confere à parte sucumbente oportunidade de voltar a discuti-la em processo futuro com base em qualquer fundamento ou prova. Ora, o mesmo motivo que exclui a coisa julgada sobre questão em virtude de discussão insuficiente ou quando há revelia pode eliminar a eficácia preclusiva da coisa julgada quando, apesar de a questão ter sido discutida em determinada perspectiva, não o foi a partir de outro fundamento.

Lembre-se, por ser extremamente oportuno, que o *collateral estoppel* depende de a questão ter sido discutida e decidida⁸⁸. Na verdade, a principal distinção entre o *collateral estoppel* – vedação de relitigar a questão – e a proibição de propor a mesma ação está em que o primeiro alcança, apenas, as questões debatidas e decididas no processo; enquanto que, na segunda hipótese, restam preclusas todas as alegações de fato e de direito que a parte poderia ter deduzido⁸⁹.

Nos Estados Unidos, a limitação dos efeitos preclusivos da coisa julgada sobre a questão – ou do *collateral estoppel* – está, nitidamente, fundada em razões centradas na imprevisibilidade da parte em relação à importância da questão num outro processo⁹⁰. Afirma-se, por exemplo, que o autor pode não discutir em toda a sua extensão uma determinada questão por considerar que a demanda proposta tem valor econômico incompatível com o custo para tanto, o que não justificaria o seu sacrifício numa demanda futura dotada de importância⁹¹. Na verdade, admite-se que os efeitos preclusivos da decisão da questão devem ser restritos pelo fato de o litigante ter dificuldade em saber o significado que a questão pode assumir num processo futuro⁹². É interessante lembrar que, em casos de *offensive collateral estoppel*⁹³, entende-se que a empresa ré, apesar de ter tido a sua responsabilidade reconhecida numa determinada demanda, pode voltar a discuti-la em demanda proposta por outra vítima do mesmo acidente se, anteriormente, não produziu todas as provas ou, simplesmente, deixou de se defender de maneira adequada em virtude da pequena indenização pleiteada⁹⁴. De qualquer forma, o que importa é que o efeito preclusivo é restrito ao discutido e decidido com base em valorações preocupadas em não

surpreender ou prejudicar o litigante⁹⁵.

No incidente de resolução há algo mais relevante, e claro, para justificar a limitação da eficácia preclusiva. Ora, se a parte que não discute a questão de forma adequada não fica sujeita ao *collateral estoppel*, por razão mais evidente o litigante excluído cujo representante não discutiu determinado fundamento não pode ser obstado de voltar a discutir a questão de direito. Enquanto no processo individual, diante do problema da coisa julgada sobre questão, evita-se prejudicar quem não teve oportunidade de efetivamente discuti-la, em face do incidente não é possível, a partir de uma suposição de que a parte não quis discutir o fundamento, eliminar a possibilidade de rediscussão da questão por quem participou apenas indiretamente do processo.

A ficção de que a parte abriu mão da discussão do fundamento ao não alegá-lo não vale no incidente, na medida em que os titulares dos direitos estão apenas representados e o representante deve deduzir todos os fundamentos válidos e importantes para a discussão da questão. Tendo em vista que a participação adequada do representante é indispensável para a preservação de direitos fundamentais processuais, a falta de discussão, e decisão, sobre fundamento capaz de propiciar decisão favorável aos representados é um déficit que, necessariamente, deve poder ser superado. Em outras palavras, a não apresentação de fundamento pelo representante não pode prejudicar os litigantes excluídos.

Reitere-se que a rediscussão de uma decisão com base em fundamento que era dedutível não atenta contra a ideia de coisa julgada. Como é sabido, o recrudesimento da decisão judicial, ápice do discurso jurídico, é imprescindível para que o discurso tenha razão de ser e, assim, realmente exista enquanto discurso jurídico. É por isto que um discurso aberto à eterna discussão jamais será um discurso jurídico ou um discurso do poder estatal, mas, tão somente, um discurso prático-geral.⁹⁶ A coisa julgada, portanto, é uma condição para que o discurso seja um discurso institucional limitado no tempo e, desta forma, um discurso jurídico propriamente dito. A coisa julgada é uma regra formal do discurso jurídico, cuja fundamentação é pragmático-transcendental, apresentando-se, desta forma, como uma condição de possibilidade do discurso jurídico⁹⁷.

Contudo, a eficácia preclusiva em relação ao dedutível é um elemento de garantia da estabilidade da decisão, mas não propriamente algo imprescindível para evitar a continuação do discurso. Para impedir o prolongamento do discurso basta impedir a rediscussão daquilo que já foi efetivamente discutido e decidido. Assim, como jamais se pode admitir a rediscussão do que já foi discutido e decidido, até para que o discurso do tribunal não deixe de ter razão de ser, a “revisão da tese jurídica”, de que fala o art. 986 do CPC/2015, só pode ser a revisão da tese com base em fundamento não discutido e decidido, capaz de ser invocado pelos excluídos ou por outro representante adequado atuando em seus nomes.

3. Relação do dever de justificar todos os fundamentos discutidos (art. 984, § 2.º, do CPC/2015) com a possibilidade de rediscussão da questão de direito: o problema da identificação do fundamento não discutido. Se a decisão da questão de direito pode ser rediscutida com base em fundamento que poderia ter sido deduzido, mas não foi, surge o problema de saber se determinado fundamento estava entre aqueles que foram discutidos no incidente em que se decidiu a questão.

Na verdade, o que realmente importa saber é se determinado fundamento foi discutido e decidido. Sabe-se que um fundamento discutido deve ser decidido, e um fundamento decidido não pode não ter sido discutido. Neste sentido, olhar para a discussão e para a decisão de um fundamento é apenas um exercício destinado a facilitar a identificação de se determinado fundamento está precluso. É que nem sempre é fácil verificar se determinado fundamento foi discutido pelas partes ou decidido pelo juiz. Equivale a dizer que os argumentos das partes e a fundamentação do acórdão podem auxiliar na identificação da prévia discussão de um fundamento.

Nestas condições, cabe ter em conta o § 2.º do art. 984 do CPC/2015, que diz que “o conteúdo do acórdão abrangerá a análise de todos os fundamentos suscitados concernentes à tese jurídica

discutida, sejam favoráveis ou contrários”. Esta norma estabelece uma clara relação entre a justificativa e a discussão dos fundamentos. Embora faça isso também para demonstrar que o direito de influir sobre o convencimento do tribunal depende de devida justificativa, na medida em que de nada adianta discutir um fundamento se o tribunal não justifica o motivo pelo qual o acolhe ou o rejeita, a imposição de um dever de análise e justificativa de todos os fundamentos discutidos tem grande importância quando o problema é exatamente o de saber qual fundamento está livre para abrir oportunidade para outra discussão da questão de direito.

A determinação da necessidade de análise de todos os fundamentos discutidos elimina, a princípio, o problema de buscar, nos argumentos das partes, amostras da discussão de determinado fundamento. Quando o réu alega, em ação em que se requer a rediscussão da questão de direito, que o fundamento invocado pelo autor já foi discutido, a resposta estará na justificativa do acórdão emanado do julgamento da questão de direito no incidente. Apenas quando o acórdão deixar de analisar determinado fundamento, violando o art. 984, § 2.º, CPC/2015, o réu terá necessidade de recorrer aos argumentos das partes para evidenciar a sua discussão. O vício de justificativa do acórdão, como é óbvio, não pode transformar um fundamento discutido em fundamento não discutido.

Fora daí, a necessidade de justificativa de todos os fundamentos resolve o problema da identificação daquilo que não pode ser invocado para a rediscussão da questão de direito. Porém, a lógica da relação entre justificativa e discussão dos fundamentos se completa com a imprescindibilidade do prévio delineamento dos fundamentos que devem ser debatidos pelo colegiado para a solução da questão de direito. Como diz o art. 984 do CPC/2015, o relator, ao fazer “a exposição do objeto do incidente”, deve definir, ouvindo os demais membros do colegiado, os fundamentos que serão objeto do debate.

A falta de delimitação dos fundamentos no início do julgamento torna possível o esquecimento dos fundamentos já discutidos pelas partes, a discussão de fundamento sem com que as partes tenham sobre ele discutido, assim como a fragmentação da discussão dos fundamentos, ou seja, a possibilidade de, por exemplo, um fundamento ser discutido por dois julgadores, outro por três, e um outro ser invocado apenas por um dos julgadores. Mediante a prévia delimitação dos fundamentos, evita-se que alguns julgadores desconsiderem um ou mais fundamentos, assim como que determinado fundamento apenas seja lembrado depois de vários membros do colegiado já terem votado.

Lembre-se que não é incomum, na prática, um julgamento que ignore fundamentos já discutidos, que considere fundamento nunca debatido ou ainda que se realize mediante votos que analisam fundamentos distintos. As três hipóteses estão expressamente vedadas pelo § 2.º do art. 984 do CPC/2015. Essa norma, além de exigir a análise de todos os fundamentos discutidos, obviamente, não permite a discussão de fundamento não debatido pelas partes – em consonância com os arts. 9.º e 10 do CPC/2015. Mas a sua verdadeira sofisticação está em impor a discussão de cada um dos fundamentos por todo o colegiado. Na verdade, como a discussão da questão de direito não pode ser dissociada do fundamento, caso o fundamento não tivesse que ser discutido por todo o colegiado haveria sempre apenas vários julgamentos individuais dos membros do colegiado. Nunca existiria deliberação colegiada. Isso não quer dizer que todos os membros do colegiado tenham que votar cada um dos fundamentos. Significa, somente, que todos devem debater sobre os fundamentos a partir de uma ordem lógica que considere cada um deles, evitando-se a sua dispersão em meio do julgamento. Afinal, não se está decidindo sobre o fundamento, mas sobre a questão de direito a partir dos fundamentos.

Só quando há julgamento colegiado, e não mero ajuntamento de julgamentos individuais, o acórdão pode justificar os fundamentos que realmente foram discutidos, deixando de ter necessidade de enfrentar argumentos de um ou alguns julgadores a respeito de fundamentos não postos à discussão. Sabe-se que estes argumentos são *obiter dicta*, ou seja, não são relevantes enquanto fundamentação⁹⁸. Não podem ser considerados nem fundamento majoritário, nem fundamento concorrente ou fundamento divergente exatamente por não terem sido discutidos pelos membros do colegiado. Devem ser vistos como argumentos expostos de passagem, ou melhor, como argumentos que trataram de fundamentos que não eram objeto de deliberação.

De modo que a individualização dos fundamentos que devem ser discutidos, além de importante para a racionalidade da discussão e uma efetiva deliberação colegiada, elimina o grave problema dos acórdãos que aludem a fundamentos irrelevantes. Isso faz perceber que a dificuldade da identificação do fundamento não discutido não estaria apenas na deficiência da justificativa, mas, também, na alusão a fundamentos que foram considerados apenas de passagem por alguns julgadores.

4. Quem pode rediscutir a questão de direito e de que forma. A questão de direito pode ser rediscutida por qualquer legitimado à tutela de direitos individuais homogêneos que não tenha participado do incidente ou por qualquer um dos representados.

Não há racionalidade em supor que apenas o Ministério Público e a Defensoria Pública podem rediscutir a questão de direito. Em primeiro lugar porque esses entes, caso tenham participado do incidente, não podem rediscutir a questão. Em segundo lugar porque não há motivo para limitar a discussão de uma questão que interessa a muitos a apenas dois dos vários legitimados à tutela de direitos individuais homogêneos. De modo que qualquer um desses legitimados, desde que não tenha participado da discussão que levou à decisão da questão de direito, pode propor a sua rediscussão com base em fundamento não discutido. A ação de revisão, por assim dizer, deve ser proposta pelo representante adequado – que não tenha participado do incidente – perante o mesmo tribunal em que se processou o incidente em que proferida a decisão, nos termos do art. 986 do CPC/2016.

Por outro lado, os próprios representados poderão rediscutir a questão de direito se tiverem à disposição fundamento que não foi discutido e decidido. Vale dizer que poderão propor as suas ações, cujo pedido dependerá do exame da mesma questão de direito, porém, a partir de um fundamento não discutido. Ou, inversamente, poderão se defender, contestando a decisão tomada no incidente, igualmente com base em fundamento que não foi discutido e decidido.

5. Rediscussão da questão de direito apenas para os casos futuros. O art. 985 do CPC/2015 afirma que a decisão proferida no incidente “será aplicada” a todos os processos que “tramitem na área de jurisdição do respectivo tribunal” e “aos casos futuros” que “venham a tramitar no território de competência do tribunal, salvo revisão na forma do art. 986”. Como está claro, permite-se a revisão da decisão apenas em face dos “casos futuros”, ou seja, dos casos que “venham a tramitar”.

Assim, a eficácia preclusiva da coisa julgada exclui o dedutível apenas para os casos futuros. A eficácia preclusiva da coisa julgada, englobando o deduzido e o dedutível, é voltada apenas aos processos que já existem. A preclusão do dedutível não vale para as ações que podem ser propostas a partir da formação da coisa julgada no incidente.

De modo que os legitimados que não participaram do incidente podem agir, a partir de fundamento não discutido e decidido, apenas em face dos casos futuros e não para impedir o julgamento das demandas pendentes com base na decisão da questão que lhes é prejudicial.

Os titulares de pretensão à tutela de direito que depende da resolução da mesma questão de direito e que, assim, ainda podem propor ações repetitivas, não ficam proibidos de agir enquanto não revista a questão de direito a seu favor. Note-se, em primeiro lugar, que caso fosse assim o motivo que justifica a instauração do incidente jamais estaria presente para impulsionar a ação dos legitimados adequados, já que nunca existiriam novas demandas repetitivas.

Na verdade, se os representados que não tinham casos pendentes quando da decisão proferida no incidente podem rediscuti-la por meio de representante adequado, não há como entender que eles não possam propor suas ações ou se defender quando um de seus representantes adequados age ou, ainda com mais razão, não age. A possibilidade de os indivíduos invocarem fundamento não discutido para renovar a discussão da questão em suas demandas individuais é mera consequência de se poder rediscutir a questão com base em outro fundamento, de modo que não pode estar obstaculizada pela não atuação ou mesmo pela ação dos representantes adequados. Nessa última hipótese, o que se pode sustentar é a suspensão dos novos casos pendentes enquanto

não resolvido o pedido de “revisão” formulado pelo legitimado à tutela dos direitos individuais.

Art. 987. Do julgamento do mérito do incidente caberá recurso extraordinário ou especial, conforme o caso.

§ 1.o O recurso tem efeito suspensivo, presumindo-se a repercussão geral de questão constitucional eventualmente discutida.

§ 2.o Apreciado o mérito do recurso, a tese jurídica adotada pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça será aplicada no território nacional a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito.

1. A configuração constitucional dos recursos especial e extraordinário. Afirma-se que diante do “julgamento do mérito do incidente” cabe recurso especial e recurso extraordinário, conforme o caso. Como nenhuma norma precisa reafirmar o cabimento destes recursos, parece que pode ter sido suposto que estes cabem apenas por haver decisão de “questão idêntica” prejudicial ao julgamento de demandas repetitivas, independentemente dos requisitos constitucionais específicos para a sua admissibilidade. Veja-se que o § 1.o do art. 987 do CPC/2015 chega a falar em “presunção” de repercussão geral da questão constitucional e o *caput* restringe o cabimento dos recursos ao “julgamento do mérito”.

Ocorre que um recurso cuja admissibilidade tem assento na Constituição não pode ser regulado de outro modo pela lei. Retenha-se o ponto: não há como raciocinar sobre os recursos especial e extraordinário à distância da sua configuração constitucional.

2. O recurso especial. Anote-se, em primeiro lugar, que não se pode afirmar, mediante lei, que o recurso especial apenas cabe quando for julgado o “mérito” do incidente. Ora, de acordo com o art. 105, III, da CRFB/1988, o recurso especial pode ser interposto nas causas decididas, em única ou última instância, pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios, quando a decisão recorrida: (i) “contrariar tratado ou lei federal, ou negar-lhes vigência”; (ii) “julgar válido ato de governo local contestado em face de lei federal”; e (iii) “der a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal”. Afirma-se que cabe à Corte julgar se decisão de Tribunal de Justiça ou Regional Federal contrariou tratado ou lei federal, ou negou-lhes vigência e também se decisão desses tribunais, ao aplicar lei local, afrontou lei federal. Ademais, está dito na Constituição que, mediante o recurso especial, o Superior Tribunal de Justiça tem a incumbência de definir a interpretação que deve prevalecer quando a decisão recorrida tiver dado à lei interpretação diversa da que lhe deu outro tribunal.

Portanto, a norma constitucional que atribui ao Superior Tribunal de Justiça, mediante recurso especial, a incumbência de definir o sentido da lei federal e a interpretação que deve prevalecer em caso de divergência entre tribunais, é clara evidência de que uma norma do Código de Processo Civil não pode, graciosamente, afirmar que, proferida uma decisão em processo de larga importância, como o incidente de resolução de demandas repetitivas, não é possível tentar discutir, mediante especial, decisão de caráter processual.

Ora, os requisitos de admissibilidade do incidente, previstos no art. 976 do CPC/2015, podem causar dúvidas interpretativas sérias e, assim, gerar decisões que, ao enfrentar o significado desta norma, devem ser revistas pelo Superior Tribunal de Justiça para a definição do seu sentido ou mesmo para a dissipação de dúvida interpretativa entre tribunais. Lembre-se, a título exemplificativo, que as ideias de “mesma questão” e “questão unicamente de direito” – insertas no inciso I do art. 976 do CPC/2015 – podem gerar disputas interpretativas e o Superior Tribunal de Justiça é a Corte incumbida pela Constituição de sepultá-las. É o que basta para esclarecer que o *caput* do art. 987 do CPC/2015 não pode ser lido como se limitasse o recurso apenas às hipóteses de “julgamento do mérito”.

Fora isso, como antes já dito, não é razoável imaginar que o recurso especial possa ser admitido apenas em virtude de ter sido proferida decisão sobre questão idêntica prejudicial ao julgamento de demandas repetitivas. Como é óbvio, uma questão de direito, ainda que suscetível de aparecer

como idêntica em demandas repetitivas, só pode abrir oportunidade para recurso especial quando a sua decisão estiver enquadrada na norma constitucional que prevê requisitos para a admissibilidade deste recurso. Portanto, a decisão do incidente, para ser passível de recurso especial, deve, por exemplo, ter dado à questão de direito federal infraconstitucional uma interpretação, ou uma solução, que é divergente de outra conferida à mesma questão de direito por outro tribunal.

3. O recurso extraordinário em face da questão de direito que não envolve pronúncia de inconstitucionalidade. Por outro lado, importa aqui voltar a lembrar do problema teórico imposto pela submissão de questão de direito constitucional ao incidente de resolução. Este problema decorre da circunstância de que há previsão constitucional de que a declaração de inconstitucionalidade, nos tribunais, apenas pode ser proclamada pela maioria absoluta dos membros do plenário ou do órgão especial (art. 97 da CRFB/1988)⁹⁹.

Como não há razão para não admitir discussão de questão de constitucionalidade como prejudicial ao julgamento de demandas repetitivas, cabe ao relator do incidente, ao se deparar com pedido de solução de questão constitucional, submetê-la ao órgão colegiado para que este decida se está diante de provável julgamento de inconstitucionalidade de lei¹⁰⁰. Decidindo-se que sim, e, portanto, admitindo-se a impossibilidade de a questão ser decidida por meio de incidente de resolução, a mesma deve ser encaminhada ao plenário ou órgão especial para a instauração do incidente de inconstitucionalidade, nos termos do art. 949, II do CPC/2015.

Lembre-se que a “interpretação conforme” e a “declaração parcial de nulidade sem redução de texto”, embora não declarem a inconstitucionalidade da lei, constituem técnicas de controle de constitucionalidade. A interpretação conforme preserva a lei mediante a afirmação de que esta tem um sentido – ou uma interpretação – conforme a Constituição. A interpretação conforme exclui a interpretação proposta ao texto legal e, para não reconhecê-lo inconstitucional, impõe uma outra conforme a Constituição. Porém, quando a impugnação é da aplicação da lei em determinada situação, o tribunal, ainda que reconhecendo a inconstitucionalidade da aplicação, pode admitir a sua aplicação em outras situações. Nestes casos há declaração parcial de nulidade sem redução de texto. O texto é preservado, declarando-se a nulidade ou a inconstitucionalidade da aplicação da norma na situação proposta. Perceba-se que, na hipótese de interpretação conforme, o problema está no âmbito de interpretação e, no caso de declaração parcial de nulidade, no âmbito de aplicação.

A mesma razão que reserva a declaração de inconstitucionalidade à maioria absoluta do plenário ou do órgão especial, proíbe que qualquer órgão fracionário de tribunal empregue as técnicas da interpretação conforme e da declaração parcial de nulidade sem redução de texto. É certo que a expressão “interpretação conforme à Constituição” é utilizada pela literatura em dois sentidos, ou seja, para descrever um princípio geral de interpretação e para definir uma técnica específica de decisão judicial em sede de controle de constitucionalidade¹⁰¹. Cabe esclarecer, portanto, que interpretar de acordo com a Constituição – ou “interpretar conforme” no primeiro sentido mencionado – obviamente, não só é possível como necessário a qualquer órgão do tribunal. Mas, assim como o órgão fracionário não pode afirmar a inconstitucionalidade de uma interpretação que é pressuposto para o julgamento de um recurso, descabe ao colegiado competente para o incidente de resolução assim também agir para resolver a “questão idêntica”.¹⁰²

Portanto, a questão pode ser decidida no incidente de resolução apenas quando a questão constitucional pode ser resolvida sem a declaração de que lei é inconstitucional, de que a interpretação proposta à lei é inconstitucional ou de que a aplicação da lei é inconstitucional na situação proposta. Assim, é possível julgar mediante o incidente, por exemplo, a questão de direito em que se discute a constitucionalidade de uma atividade ou de uma conduta em face de norma da Constituição Federal, ou a questão que requer a consideração de uma lei cuja constitucionalidade é posta em dúvida, mas permite ao colegiado dizer que poderá resolver a questão de direito sem ter que pronunciar a inconstitucionalidade.

Nestes casos, quando é possível afirmar que a decisão do incidente contrariou norma da Constituição Federal ou julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da

Constituição Federal (art. 102, III, *a e c*, CRFB/1988), cabe recurso extraordinário nos termos do *caput* do art. 987 do CPC/2015. Caso a questão seja resolvida mediante a afirmação da constitucionalidade da lei – desde que não de “governo local” –, cabível poderá ser o recurso especial, uma vez constatada que a decisão violou a lei federal ou deu à lei federal interpretação diferente da que já lhe deu outro tribunal.

No entanto, se o colegiado do incidente, equivocadamente, pronunciar a inconstitucionalidade da lei, ou mesmo de sua interpretação ou aplicação propostas, o recurso extraordinário não poderá pretender rediscutir a questão constitucional resolvida no incidente, mas, antes, invocar a inconstitucionalidade da decisão do colegiado por violação à cláusula de reserva do plenário, estabelecida no art. 97 da CRFB/1988. Esta é a interpretação que decorre do entendimento do Supremo Tribunal Federal, que não admite o recurso extraordinário para discutir a questão constitucional quando o órgão fracionário a decide sem remetê-la ao plenário ou ao órgão especial para a instauração do incidente de inconstitucionalidade. Neste caso, o recurso extraordinário deve demonstrar que foi proferida uma decisão que, apenas por ter sido proferida pelo órgão fracionário do tribunal, violou a Constituição Federal¹⁰³.

4. A repercussão geral não constitui mera consequência da existência de demandas repetitivas. O § 1.º do art. 987 do CPC/2015 diz que a questão constitucional decidida no incidente de resolução é presumida como de repercussão geral. Esta norma tem parentesco com a do revogado inciso II do § 3.º do art. 1.035 do CPC/2015, que afirmava a existência de repercussão geral no caso de o recurso impugnar “acórdão proferido em julgamento de casos repetitivos”.

A norma do § 1.º do art. 987 do CPC/2015 realmente suscita perplexidade, pois não apenas redesenha a norma constitucional que exige a repercussão geral da questão constitucional para a admissão do recurso extraordinário (art. 102, § 3.º, CRFB/1988¹⁰⁴), como ingressa na esfera de poder do Supremo Tribunal Federal de afirmar quando há repercussão geral no caso concreto. Quando a lei diz que a repercussão geral está presumida, de modo que o Supremo Tribunal Federal não tem alternativa senão reconhecê-la, o legislador não só ultrapassa o seu dever de apontar para as circunstâncias que devem estar presentes para a configuração de repercussão geral, como retira do Supremo Tribunal Federal o poder de aferir, em face das circunstâncias do caso, o preenchimento dos requisitos necessários à verificação de repercussão geral.

A previsão da aferição da repercussão geral da questão constitucional debatida no caso é indispensável para que o Supremo Tribunal Federal possa exercer a sua função¹⁰⁵. Trata-se de poder inerente a uma Suprema Corte cuja função deixou de ser a de resolver conflitos e corrigir decisões, e passou a ser a de “clarifier ou orienter le droit”¹⁰⁶ a partir da questão levada ao seu conhecimento.

Para que uma Suprema Corte possa colaborar para a frutificação do Direito e para a orientação da vida em sociedade, ela necessita ter a possibilidade de escolher os casos que lhe dão condições para tanto, de modo que a lei jamais pode dizer quando o Supremo Tribunal Federal deve admitir a repercussão geral. Significa que o § 1.º do artigo 987 do CPC/2015, quando lido no sentido de que o recurso extraordinário interposto da decisão proferida no incidente de resolução retira da Suprema Corte o poder de aferir a repercussão geral no caso, seguramente, não guarda compatibilidade com a Constituição Federal e com a função a ser desenvolvida pelo Supremo Tribunal Federal dos nossos dias. Aliás, não foi por outra razão que o inciso II do § 3.º do art. 1035 do CPC/2015 foi recentemente revogado pelo parlamento.

Portanto, para que o recurso extraordinário interposto em face de decisão proferida em incidente de resolução possa ser admitido, o Supremo Tribunal Federal deverá reconhecer a repercussão geral da questão constitucional discutida no caso. Como é evidente, uma questão que se repete em demandas de massa não é, apenas por isso, uma questão constitucional dotada de repercussão geral, ou seja, uma questão constitucional que recomenda a intervenção da Suprema Corte para o favorecimento do desenvolvimento do Direito. Uma questão constitucional, discutida em incidente de resolução, obviamente, pode não guardar qualquer relevância, além de já poder estar suficientemente iluminada por precedentes do próprio Supremo Tribunal Federal. Assim, para que o recurso extraordinário seja admitido, ainda que diante de decisão proferida em

incidente de resolução, a repercussão geral da questão constitucional debatida deve ser aferida pelo STF nos termos do § 1.º do art. 1.035 do CPC/2015, considerando-se a relevância da questão “do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico”.

5. Recurso com efeito suspensivo e inoperatividade da decisão provisória da questão de direito. O § 1.º do art. 987 do CPC/2015 afirma, ainda, que o recurso especial ou extraordinário interposto contra a decisão proferida no incidente “tem efeito suspensivo”. Na literatura processual, imaginou-se que apenas a sentença condenatória teria motivo para ser objeto de recurso dotado de efeito suspensivo. Supunha-se que os efeitos das decisões declaratória e constitutiva dependiam da coisa julgada material. Porém, não há motivo para admitir que apenas as sentenças condenatória, mandamental e executiva, mas não as sentenças declaratória e constitutiva, produzam efeitos antes do término do processo. A coisa julgada nada tem a ver com os efeitos da decisão. Qualquer decisão pode produzir efeitos independentemente da coisa julgada. Os efeitos das decisões declaratória e constitutiva não podem ser vistos como consequência da coisa julgada material, mas como decorrência de opção legislativa de abrir oportunidade para a produção de efeitos decisórios antes do encerramento do processo. Portanto, embora as decisões declaratória e constitutiva não tenham eficácia executiva; podem produzir efeitos na pendência de recurso recebido apenas no efeito devolutivo, como é o caso dos recursos especial e extraordinário.

A decisão proferida em incidente de resolução tem natureza declaratória; declara a solução da questão de direito. Como o art. 982, I do CPC/2015 afirma que, uma vez admitido o incidente, o relator “suspenderá os processos pendentes”, resolveu-se esclarecer que, caso interposto recurso especial ou extraordinário, os processos pendentes ainda restam suspensos. Mas o problema, bem vistas as coisas, não é o de obstaculizar ou suspender os efeitos da decisão. Nesse caso, a decisão, em termos teóricos, até poderia produzir efeitos desde logo, mas não teria qualquer utilidade para a resolução imediata das demandas repetitivas. A coisa julgada *erga omnes* é indispensável para que os litigantes e o juiz das demandas repetitivas fiquem sujeitos à decisão da questão de direito. A decisão da questão de direito só tem operatividade no que diz respeito ao julgamento das demandas repetitivas, depois da formação da coisa julgada. Bem por isso, neste sentido, é mais adequada a regra do § 5.º do art. 982 do CPC/2015, que diz que a suspensão dos processos pendentes cessa apenas quando não interposto recurso especial ou extraordinário.

6. Significado de decisão de Corte Suprema em recurso especial ou extraordinário interposto em face de decisão proferida em incidente de resolução de demandas. O § 2.º do art. 987 do CPC/2015 afirma que, apreciado o mérito do recurso interposto contra a decisão proferida no incidente, “a tese jurídica adotada pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça será aplicada no território nacional a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito”. O legislador, mais uma vez, confessa que imagina que a decisão do incidente é um precedente, mas agora vai além, sustentando que o incidente constitui uma forma processual destinada a regular demandas repetitivas em todo o território nacional.

É certo que as Supremas Cortes podem firmar precedentes. O Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal têm a função de atribuir sentido e unidade ao direito federal inconstitucional e constitucional e, exatamente por isso, as suas decisões, quando dotadas de determinadas características, destinam-se a orientar a vida em sociedade e a regular os casos futuros. A função das Cortes Supremas, exercida mediante pronunciamentos nos casos que lhes chegam às mãos, torna-os precedentes, ou seja, decisões que, impregnadas do poder de atribuir significado ao direito, não podem deixar de ser observadas pelos juízes dos casos futuros.

Antes de mais nada, é preciso esclarecer que tanto faz, para a configuração de precedente, ser ele oriundo de recurso extraordinário interposto contra decisão proferida em incidente de resolução ou de recurso extraordinário interposto contra decisão tomada em recurso de apelação. Aliás, o art. 927 do CPC/2015 comete um grosseiro erro ao ignorar as decisões proferidas em sede de repercussão geral.

Entretanto, se a decisão firmada em incidente não é um precedente que deve ser observado

pelos juízes e desembargadores do tribunal que a proferiu, a decisão da Corte Suprema em recurso interposto contra a decisão da questão de direito não pode, apenas em razão de ser proferida em incidente de resolução, ter que, obrigatoriamente, ser “aplicada no território nacional a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito”. Como é fácil perceber, a regra do § 2.º do art. 987 do CPC/2015 constitui uma potencialização do equívoco de supor que a decisão firmada em incidente de resolução é um precedente capaz de permitir a definição de todas as demandas repetitivas. Imaginou-se que, como o incidente estaria oportunizando uma decisão de Corte Suprema, não haveria motivo para não estender a eficácia da tese firmada no incidente a todo o território nacional.

Como é óbvio, decidida a questão de direito pelo Superior Tribunal de Justiça ou pelo Supremo Tribunal Federal, a decisão do recurso atingirá as partes e todos aqueles que foram adequadamente representados no incidente, em razão da coisa julgada *erga omnes*. No entanto, como a decisão de uma Corte Suprema pode, em certas condições, constituir precedente, a decisão firmada em recurso interposto contra decisão tomada em incidente de resolução pode ser aplicada não apenas em processos que versem sobre a mesma questão (idêntica) em outros estados ou regiões, mas, também, em casos que tratem de questões similares, marcadas por circunstâncias fáticas diferentes, mas que exijam a mesma *ratio decidendi*. Assim, por exemplo, tendo sido reconhecida a responsabilidade do fabricante em determinadas condições, não há motivo para afastar a responsabilidade de outro fabricante em condições distintas desde que, considerando-se as razões do precedente, a diversidade fática de circunstâncias não tenha qualquer relevância para afastar a responsabilidade no caso sob julgamento.

Significa, tudo bem visto, que a decisão tomada por Corte Suprema em recurso interposto contra decisão firmada em incidente de resolução, embora não se aplique de modo a proibir a discussão da mesma questão por parte de pessoas que não foram representadas no incidente, deve ser aplicada, caso configure precedente, a todos os casos que, idênticos ou não, reclamem a mesma razão que determinou a solução do recurso.

Note-se que a decisão de questão ou a coisa julgada *erga omnes* detém uma eficácia preclusiva muito mais rígida do que a de um precedente. A coisa julgada *erga omnes* elimina qualquer pretensão de discussão da mesma questão, ao passo que o precedente sempre confere às partes do caso sob julgamento a possibilidade de argumentar de modo a tentar evidenciar a distinção ou a superação, ou o desgaste, do precedente¹⁰⁷.

A decisão de Corte Suprema depende do preenchimento de determinados requisitos para constituir precedente. Como deveria ser óbvio, só há precedente, a princípio, quando existe *ratio decidendi* firmada pela maioria dos membros do colegiado¹⁰⁸.

Lembre-se que o *common law*, desde o momento em que concebeu o *stare decisis*, relacionou precedente com *ratio decidendi*, a qual, naturalmente, não podia deixar de contar com a adesão da maioria dos membros da Corte¹⁰⁹. As cortes inferiores sequer indagavam sobre precedente ou *ratio decidendi* quando se deparavam com decisões (resultados) alcançadas a partir de vários fundamentos, nenhum deles compartilhado por uma maioria. *Rationales* dotadas de autoridade, capazes de regular casos futuros, dependiam do suporte da maioria da Corte. O problema da extração da *ratio* de decisões que resolvem um caso ou recurso com base em fundamentos distintos, sem que nenhum deles esteja amparado por maioria, surgiu nos Estados Unidos apenas em meados do século XX, como demonstra importante artigo de Adam S. Hochschild, que enfrentou o problema das “decisões plurais”¹¹⁰ da Suprema Corte estadunidense em uma perspectiva histórica¹¹¹.

Para que se compreenda a razão pela qual só há precedente quando o fundamento que determina o resultado do recurso é amparado pela maioria, importa ter clara a função que a Corte exerce ao julgar o recurso. Perceba-se que saber qual foi o fundamento que permitiu a conclusão de que uma norma foi contrariada não tem relevância quando importa apenas o resultado de que a norma foi contrariada. Nesse caso, nada significa se a norma foi dita violada a partir de diversos fundamentos. Se a função da Corte é analisar a eventual contrariedade à norma, com o fim de resolver uma disputa entre recorrente e recorrido, uma maioria de votos que declare a negação da

norma, ainda que por motivos vários, é suficiente para o provimento do recurso.

Porém, quando a Corte, além de objetivar resolver o caso conflitivo, tem a função de atribuir sentido ao direito, declarando os motivos pelos quais uma norma deve ser interpretada na forma P diante da situação concreta Q, não há como se deixar de lado o significado dos fundamentos que oportunizaram o resultado final no sentido de que a norma X foi contrariada.

Nada impede que uma Corte de Precedentes firme decisão sem *ratio decidendi* – incapaz, portanto, de vincular os tribunais e juízes nos casos vindouros. As funções de resolver o recurso, e de elaborar a *ratio decidendi*, não conflitam e não se excluem. Podem estar presentes num só ou mesmo julgamento. Num julgado de Corte de Precedentes há necessariamente solução do recurso e, eventualmente, “*ratio decidendi*”. Se decisões que não detêm uma *ratio decidendi* podem prejudicar a função de desenvolvimento do direito, esse não é um problema que obstaculiza uma Corte de Precedentes a decidir o recurso sem alcançar maioria em relação a um dos fundamentos determinantes do resultado, embora esta não seja uma decisão ideal para este modelo de Corte¹¹².

Portanto, se as Cortes Supremas brasileiras devem produzir *rationes decidendi* que expressem o sentido do direito, isso não quer dizer que, quando em determinado caso for impossível o consenso para formar maioria em relação a um fundamento determinante, a Corte não possa resolver o recurso sem chegar numa *ratio decidendi*. Mas se isso pode acontecer, é também importante que todos estejam cientes de que nem toda decisão de uma Corte Suprema é um precedente. Para que o seja, a decisão terá que expressar um fundamento determinante (do resultado) compartilhado, ao menos, pela maioria dos membros do colegiado.

Contudo, para se pensar em precedente diante de recurso interposto contra decisão proferida em incidente de resolução há necessidade de enfrentar um ingrediente complicador, ou seja, um ponto que não está presente quando se pensa em precedente em face de recurso interposto contra uma decisão firmada, por exemplo, em recurso de apelação. É que a decisão do incidente não afirma uma conclusão sobre um conflito ou caso, mas uma conclusão sobre questão de direito que importa para a resolução de diversos casos.

A Corte Suprema, ao julgar o recurso, também estará presa à solução de uma questão de direito, embora não disponha da mesma liberdade do tribunal de origem para enfrentá-la. Significa que a Corte Suprema julgará a questão de direito a partir das hipóteses previstas nas normas constitucionais (arts. 102, III e 105, III da CRFB/1988) que oportunizam o conhecimento e o julgamento do recurso. O recurso especial, por exemplo, permite o julgamento da questão de direito enfrentada no incidente mediante a análise de contrariedade da decisão a determinada de lei federal (art. 105, III, “a”, da CRFB/1988). O provimento desse recurso, assim, depende de que fundamentos aptos a evidenciar a violação da norma sejam reconhecidos pela maioria do colegiado. A decisão de provimento do recurso – e não a eventual *ratio decidendi* da decisão – será suficiente para solucionar a questão de direito. Ocorre que, num colegiado de cinco Ministros, por exemplo, o recurso pode ser provido à unanimidade, porém com base em três fundamentos distintos, um sustentado por dois Ministros, outro por mais dois Ministros e o terceiro apenas por um Ministro; perfazendo o exemplo do resultado de “2+2+1”. Esse resultado é incapaz de dar origem a *ratio decidendi*, mas soluciona a questão de direito posta no incidente.

O fato de uma “simples” decisão de recurso – destituída de *ratio decidendi* – estar a resolver uma questão de direito pode sugerir uma aproximação do valor do resultado da decisão ao da *ratio decidendi*. Essa situação remete à discussão que ora se trava no direito estadunidense em torno da dificuldade de se encontrar *ratio decidendi* em algumas decisões da Suprema Corte dos Estados Unidos. O crescimento das decisões majoritárias destituídas de um fundamento ou de uma opinião compartilhada pela maioria da Suprema Corte, levou tanto os tribunais, quanto a Suprema Corte dos Estados Unidos, a tentar encontrar um critério destinado a permitir a extração da *ratio decidendi* das decisões plurais – decisões majoritárias instituídas com base em fundamentos sustentados por minorias¹¹³. A Corte Suprema, inicialmente, delineou o teste denominado de “*narrowest grounds*”, em que se buscava extrair dos fundamentos minoritários elementos compartilhados, capazes de permitir a configuração de uma razão comum. Este teste, embora aplicado com sucesso em alguns casos, acabou se mostrando inadequado diante de casos

mais complexos¹¹⁴. Na verdade, todas as tentativas para encontrar *ratio decidendi* em casos em que o resultado constituiu a soma dos votos que compartilharam dois ou mais fundamentos não foram capazes de resolver de modo adequado o problema, sendo possível admitir, portanto, que seria melhor reconhecer que a Corte nem sempre precisa instituir *ratio decidendi* ou precedente ao decidir.

Em *Cannon v. University of Chicago*, a Suprema Corte decidiu por 3+3-3 que uma mulher, não admitida numa Faculdade de Medicina, poderia propor ação civil por discriminação sexual com base no título IX do “Education Amendments Act” de 1972. As cortes inferiores entenderam que, em *Cannon*, a declaração de que o título IX garante um direito de ação, era dotada de autoridade, ainda que a Suprema Corte tenha chegado neste resultado por meio de dois fundamentos, cada um sustentado por três *Justices*¹¹⁵. Em *Cannon*, o resultado compartilhado por seis *Justices* (3+3), no sentido de que o título IX garantia direito de ação civil, foi admitido como suficiente para deixar claro que, em toda e qualquer outra situação similar sob a mesma lei, não se poderia negar o mesmo direito.

Afirmou-se, para justificar o uso excepcional do resultado com fim precedental, que o caso dizia respeito a uma “questão limite” – o direito de estar em juízo –, e não a pontos que envolviam o direito substancial ou o conflito de interesses, e mesmo que o caso produziu resultado específico que não era dependente ou limitado por particulares circunstâncias de fato.¹¹⁶

Note-se, contudo, que tal resultado não foi capaz de sustentar as razões pelas quais a Corte admitiu que o título IX do “Education Amendments Act” de 1972 garantia o direito de ação, de modo que a outorga de efeito de precedente ao resultado, obviamente, não respondeu à ideia que está à base das Cortes de Precedentes do mundo contemporâneo, inclusive da estadunidense: a de desenvolvimento do Direito. A não atribuição de sentido ao direito retira valor precedental da decisão, o que significa que o resultado da decisão proferida em *Cannon* jamais poderia ter sido visto como capaz de regular os casos futuros. Houve, diante de *Cannon*, falta de humildade para reconhecer que a Corte Suprema pode deixar de firmar precedentes ao julgar¹¹⁷.

Como é óbvio, referido julgado está muito longe de poder significar que o resultado de todo e qualquer recurso que soluciona questão de direito tem valor precedental. Perceba-se que uma questão de direito pode suscitar a discussão de mais, ou menos, fundamentos conforme a sua prévia delimitação. Toda questão de direito pode dar origem a questões de direito derivadas até se chegar a uma questão de direito cuja discussão não difere da discussão de um dos fundamentos que poderia servir para a discussão da questão de direito matriz. Enfim, o resultado do julgamento de um recurso interposto contra decisão proferida em incidente de resolução pode ter valor tanto maior quanto mais delimitada for a questão de direito.

Mas de qualquer forma, declarou-se em *Cannon v. University of Chicago* que o resultado pode ter valor precedental em face de outros casos que circundam a mesma lei, mas não diante de casos com configuração fática apenas similar ou que se colocam diante de outra lei. Sucede que o real valor do precedente não está em servir de carimbo para questões idênticas, mas em constituir critério jurídico para regular casos que, a despeito de suas configurações fáticas próprias, não tenham motivo para ser resolvidos por *ratio decidendi* diversa.

NOTAS DE RODAPÉ

1

Assim, por exemplo, Michele Taruffo, “Collateral estoppel” e giudicato sulle questioni, *Rivista di diritto processuale*, 1972, p. 290 e ss. Mais recentemente, ver Diego Volpino, *L’oggetto del giudicato nell’esperienza americana*, cit.

2

Nesse caso, concluiu-se que a regra de que (apenas) as partes podem invocar a proibição de relitigar questão já decidida poderia ser excepcionada com base na justificativa de que também seria injusto permitir que uma parte possa rediscutir a mesma questão já decidida apenas por estar diante de outro adversário. Ou seja, admitiu-se que o adversário, estranho ao caso em que decidida a questão, também pode invocar proibição de relitigar questão já decidida contra aquele que já a discutiu em processo anterior. “The case justify this exception on the ground that it would be unjust to permit one who has had his day in court to reopen identical issues by merely switching adversaries” (Bernhard v. Bank of America Nat. Trust & Saving Association, Supreme Court of California, 19 Cal2d 807, 122 P2d 892, 1942).

3

Austin Scott, Collateral Estoppel by judgment. *Harvard Law Review*. Vol. 56. 1942; Brainerd Currie, Mutuality of Collateral Estoppel: Limits of the Bernherd doctrine. *Stanford Law Review*. Vol. 9. 1957.

4

402 U.S. 313 (1971).

5

“An examination of the *economic consequences* of continued adherence to Triplett has two branches. Both, however, begin with the acknowledged fact that patent litigation is a very costly process”. (...) “*Economic consequences* like these, to the extent that they can be avoided, weigh in favor of modification of the Triplett mutuality principle” (...) “the *economic consequences* of continued adherence to Triplett are serious and any reduction of litigation in this context is by comparison an incidental matter in considering whether to abrogate the mutuality requirement” (...) “it is apparent that the uncritical acceptance of the principle of *mutuality of estoppel* expressed in Triplett v. Lowell is today out of place. Thus, we conclude that Triplett should be overruled to the extent it forecloses a plea of estoppel by one facing a charge of infringement of a patent that has once been declared invalid” (Blonder-Tongue v. University of Illinois Foundation, 402 U.S. 313, 1971).

6

“Economic consequences like these, to the extent that they can be avoided, weigh in favor of modification of the Triplett mutuality principle. Arguably, however, the availability of estoppel to one charged with infringement of a patent previously held invalid will merely shift the focus of litigation from the merits of the dispute to the question whether the party to be estopped had a full and fair opportunity to litigate his claim in the first action. It would seem sufficient answer to note that once it is determined that the issue in both actions was identical, it will be easier to decide whether there was a full opportunity to determine that issue in the first action than it would be to relitigate completely the question of validity. And, this does not in fact seem to have been a problem in other contexts, where strict mutuality of estoppel has been abandoned” (Blonder-Tongue v. University of Illinois Foundation, 402 U.S. 313, 1971).

7

“The Supreme Court, Mr. Justice White, held that in patent infringement suit, patentee is estopped to assert validity of patent that has been declared invalid in prior suit in federal court against a different defendant, unless patentee demonstrates that he did not have full and fair opportunity, procedurally, substantively, and evidentially, to litigate the validity of his patent in the prior suit” (*Blonder-Tongue v. University of Illinois Foundation*, 402 U.S. 313, 1971).

8

“Offensive use of collateral estoppel occurs when plaintiff seeks to foreclose defendant from litigating an issue the defendant previously litigated unsuccessfully in an action with another party, whereas defensive use occurs when defendant seeks to prevent plaintiff from asserting a claim plaintiff previously litigated and lost against another defendant” (*Parklane v. Shore*, 439 U.S. 322, 1979).

9

Lisa L. Glow, Offensive Collateral Estoppel in Arizona: Fair Litigation v. Judicial Economy. *Arizona Law Review*. Vol. 30. 1988; Ashley C. Perea, Broad discretion: a choice in applying offensive non-mutual collateral estoppel, *Arizona State Law Journal*, Vol. 40. 2008; Joshua M. D. Segal, Rebalancing fairness and efficiency: The offensive use of collateral estoppel in § 1983 actions. *Boston University Law Review*. Vol. 89. 2009; Eli J. Richardson, Taking issue with preclusion: reinventing Collateral Estoppel. *Mississippi Law Journal*. Vol. 65. 1995; Steven P. Nonkes, Reducing the unfair effects of nonmutual issue preclusion through damages limits. *Cornell Law Review*. Vol. 94. 2009.

10

“A stockholder’s class action was brought against corporation, its officers, directors, and stockholders who allegedly issued a materially false and misleading proxy statement. Before the action came to trial, the SEC sued the same defendants, alleging that the proxy statement was materially false and misleading in essentially the same respects. The District Court, after a nonjury trial, entered a declaratory judgment for the SEC, and the Court of Appeals affirmed. Plaintiff in the instant case then moved for partial summary judgment, asserting that defendants were collaterally estopped from relitigating the issues resolved against them in the SEC suit. The United States District Court for the Southern District of New York denied the motion, but the Court of Appeals, Second Circuit reversed, and certiorari was granted because of an intercircuit conflict. The Supreme Court, Mr. Justice Stewart, held that: (1) the petitioners had a ‘full and fair’ opportunity to litigate their claims in prior action brought by the SEC, and petitioners were therefore collaterally estopped from relitigating the question of whether the proxy statement was materially false and misleading, and (2) the use of offensive collateral estoppel by plaintiff respondent, predicated on a prior suit brought by the Securities and Exchange Commission, would not violate the Seventh Amendment jury trial right of petitioners (*Parklane v. Shore*, 439 U.S. 322, 1979).

11

“involved defensive use of collateral estoppel – a plaintiff was estopped from asserting a claim that the plaintiff had previously litigated and lost against another defendant. The present case, by contrast, involves offensive use of collateral estoppel – a plaintiff is seeking to estop a defendant from relitigating the issues which the defendant previously litigated and lost against another plaintiff. In both the offensive

and defensive use situations, the party against whom estoppel is asserted has litigated and lost in an earlier action” (Parklane v. Shore, 439 U.S. 322, 1979).

12

“Nevertheless, several reasons have been advanced why the two situations should be treated differently. First, offensive use (...) does not promote judicial economy in the same manner defensive use does. Defensive use (...) precludes a plaintiff from relitigating identical issues by merely ‘switching adversaries’ (...). Thus defensive collateral estoppel gives a plaintiff strong incentive to join all potential defendants in the first action if possible. Offensive use of collateral estoppel, on the other hand, creates precisely the opposite incentive. Since a plaintiff will be able to rely on a previous judgment against a defendant but will not be bound by that judgment if the defendant wins, the plaintiff has every incentive to adopt a ‘wait and see’ attitude, in the hope that the first action by another plaintiff will result in a favorable judgment (...). Thus offensive use (...) will likely increase rather than decrease the total amount of litigation, since potential plaintiffs will have everything to gain and nothing to lose by not intervening in the first action”. Em segundo lugar, o uso ofensivo “may be unfair to a defendant. If a defendant in the first action is sued for small or nominal damages, he may have little incentive to defend vigorously, particularly if future suits are not foreseeable (...). Allowing offensive collateral estoppel may also be unfair to a defendant if the judgment relied upon as a basis for the estoppel is itself inconsistent with one or more previous judgments in favor of the defendant. Still another situation where it might be unfair to apply offensive estoppel is where the second action affords the defendant procedural opportunities unavailable in the first action” (Parklane v. Shore, 439 U.S. 322, 1979).

13

Warren Freedman, *Res Judicata and Collateral Estoppel*, Westport: Quorum, 1988.

14

“It is a violation of due process for a judgment to be binding on a litigant who was not a party nor privy and therefore has never had an opportunity to be heard” (Parklane v. Shore, 439 U.S. 322, 1979).

15

Max Weber, *A ética protestante e o “espírito” do capitalismo* (edição de Antônio Flávio Pierucci), São Paulo: Companhia das Letras, 2004.

16

“A ideia de dever profissional, a que se associou um forte acento sobre a responsabilidade – resultante da necessidade de comprovação da eleição –, consiste em um modo de viver dotado de racionalidade. A busca da comprovação da eleição nos atos da vida intramundana, especificamente no exercício da profissão, não podia ocorrer sem um método capaz de permitir o controle racional sobre a ação humana. Para que essa pudesse gerar os melhores resultados era imprescindível a previsibilidade, sem a qual o sujeito jamais poderia saber se os seus atos produziriam efeitos positivos” (Luiz Guilherme Marinoni, *A Ética dos precedentes*, São Paulo: Ed. RT, 2014, p. 25-26).

Luiz Guilherme Marinoni, *A Ética dos precedentes*, cit., esp. cap. 1.

“... o cumprimento das obrigações como *dever religioso* geram ao calvinista um extremo rigor consigo mesmo, isto é, uma rigorosa e contínua inspeção da sua conduta profissional e pessoal. A comprovação da eleição, como nada tem a ver com a realização de obras meritórias isoladas, exigia uma auto-inspeção contínua e sistemática, capaz de propiciar ao homem a certeza de que fora eleito” (Luiz Guilherme Marinoni, *A Ética dos precedentes*, cit., p. 24-25). V. Max Weber, *A ética protestante e o “espírito” do capitalismo* (edição de Antônio Flávio Pierucci), cit., p. 106 e ss.

Robert Millar, The historical relation of estoppel by record to res judicata, *Ill L. Review*, 1940-1941.

Jeremy Bentham, *Rationale of judicial evidence*, cit., p. 579. Lembre-se que a opinião do Justice White, em *Parklane*, afirma que a admissão da discussão da mesma questão, apenas em razão de o adversário ser outro, traz péssimas consequências em termos econômicos. Porém, é interessante observar que o Justice White, para justificar a sua posição, alude à contrariedade de Bentham diante da regra da mutualidade do *collateral estoppel*: “the cases and authorities discussed above connect erosion of the mutuality requirement to the goal of limiting the relitigation of issues where that can be achieved without compromising fairness in particular cases (...). The broader question is whether it is any longer tenable to afford a litigant more than one full and fair opportunity for judicial resolution of the same issue (...). It encompasses the concern exemplified by *Bentham’s reference to the gaming table in his attack on the principle of mutuality of estoppel*. In any lawsuit where a defendant, because of the mutuality principle, is forced to present a complete defense on the merits to a claim which the plaintiff has fully litigated and lost in a prior action, there is an arguable *misallocation of resources*” (*Parklane v. Shore*, 439 U.S. 322, 1979).

Michele Taruffo, “Collateral estoppel” e giudicato sulle questioni, *Rivista di diritto processuale*, 1972, p. 275 e ss.; Diego Volpino, *L’oggetto del giudicato nell’esperienza americana*, cit., p. 291 e ss.

Giuseppe Chiovenda, Sulla cosa giudicata, *Saggi di diritto processuale civile* (reeimpressão), vol. 2, cit.

V. Ronald J. Allen e Michael S. Pardo, The myth of the law-fact distinction, *Northwestern University Law Review*, 2003.

“The doctrine of collateral estoppel is applicable not merely to questions of fact but also to questions of law” (Austin Scott, Collateral estoppel by judgment, *Harvard Law Review*, 1942, p. 3 e ss.); V. Geoffrey Hazard Jr., Preclusion as to issues of law: the legal system’s interest, *Iowa Law Review*, 1984, p. 81 e ss.

26

Fleming James Jr., Geoffrey Hazard Jr. e John Leubsdorf, *Civil Procedure*, cit., p. 585, 614.

27

Montana v. U.S., 440 U.S. 147 (1979).

28

“A government contractor, at the direction of the United States, filed suit in Montana courts attacking the constitutionality of Montana’s imposition of a one percent gross receipts tax upon contractors of public, but not private, construction projects. After the Montana Supreme Court upheld the tax, and at the Solicitor General’s direction, the contractor abandoned its request for review by the United States Supreme Court. Thereafter, in another suit challenging the constitutionality of the tax, also financed and directed by the Government, a three-judge panel in the United States District Court for the District of Montana, ruled that the United States was not bound by the Montana Supreme Court’s decision and that the tax violated the supremacy clause. On appeal by the State of Montana, the United States Supreme Court, Mr. Justice Marshall, *held that the prior judgment by the Montana Supreme Court upholding the tax precluded the United States from contesting its constitutionality*” (Montana v. U.S., 440 U.S. 147, 1979).

29

“Finally, the Government has not alleged unfairness or inadequacy in the state procedures to which it voluntarily submitted. We must conclude therefore that it had a full and fair opportunity to press its constitutional challenges in *Kiewit I*. Accordingly, the Government is estopped from seeking a contrary resolution of those issues here” (Montana v. U.S., 440 U.S. 147, 1979 – Opinion Mr. Justice Marshall).

30

Richards v. Jefferson County, 517 U.S. 793, (1996).

31

Hansberry v. Lee, 311 U.S. 32, 61 S.Ct. 115, 1940.

32

“Two classes of taxpayers brought state court declaratory judgment actions against county challenging constitutionality of statute authorizing county to levy occupational tax and ordinance levying tax. The Circuit Court, Jefferson County, John E. Rochester, J., entered summary judgment for county on state constitutional claims. Granting county permission to appeal denial of summary judgment on federal claims, the Supreme Court, Almon, J., reversed and remanded. On writ of certiorari, the Supreme Court,

Justice Stevens, held that: (1) prior litigation to challenge constitutionality of county's occupation tax did not bind different taxpayers and did not bar them from challenging allegedly unconstitutional deprivation of their property, and (2) county was not entitled to rely on assumption that prior litigation conclusively established constitutionality of tax" (Richards v. Jefferson County, 517 U.S. 793, 1996).

33

"The Alabama Supreme Court concluded that res judicata applied because petitioners were adequately represented in the Bedingfield action" (Richards v. Jefferson County, 517 U.S. 793, 1996).

35

Richards v. Jefferson County, 517 U.S. 793, (1996).

36

"the State Supreme Court's holding that the petitioners are bound by (...) Bedingfield *deprived them of the due process of law guaranteed by the Fourteenth Amendment*" (Richards v. Jefferson County, 517 U.S. 793, 1996).

37

Jeremy Bentham, *Rationale of judicial evidence*, cit., p. 579.

38

A universabilidade, ou seja, a necessidade de que um argumento de validez de uma conclusão seja capaz de sustentar igual resultado diante de narrativas análogas, constitui regra de racionalidade do discurso prático, de que o discurso jurídico é apenas um caso especial. Ninguém deve invocar um motivo para justificar uma ação sabendo que não poderá utilizá-lo para justificar ações similares, assim como ninguém pode invocar razão diversa para deixar de praticar ação com o mesmo conteúdo. Diante da impossibilidade de se ter uma *interpretação* ou uma decisão *substancialmente* correta e da consciência de que a tarefa das Cortes Supremas é outorgar sentido ao direito mediante as "razões apropriadas" ou as "melhores razões", a universabilidade constitui critério de correção da *racionalidade* da decisão, pois permite ver que as razões que justificaram a decisão não são "apropriadas" nem as "melhores", na medida em que inaplicáveis a casos similares, isto é, a casos que deveriam ser solucionados mediante as mesmas razões. V. Neil MacCormick. *Rhetoric and the Rule of Law*. Oxford: Oxford University Press, 1995. p. 131 e ss.; Paula Pessoa Pereira, *Legitimidade dos precedentes*, São Paulo: Ed. RT, 2015.

39

Os princípios institucionais do *overruling* justificam resultados diferentes em épocas distintas. Da mesma forma, princípios institucionais podem justificar resultados conflitantes diante de uma distinção inconsistente. Como demonstra Melvin Eisenberg (*The nature of the common law*, Cambridge: Harvard University Press, 1978), existem fortes razões a justificar a prática da distinção inconsistente. Quando o tribunal ainda não está plenamente convencido de que o entendimento anterior deve ser revogado ou deixado de lado, ele pode realizar distinção inconsistente como passo provisório para a revogação total.

Em outra hipótese, o tribunal pode formular exceção num nível de generalidade abaixo do necessário para restar totalmente de acordo com os princípios, como passo provisório à generalização completa. Ver Luiz Guilherme Marinoni, *Precedentes obrigatórios*, 4.ed., cit., Capítulo III, item 4.3.4. Para uma visão crítica, Daniel Mitidiero, *Precedentes*, cit.

40

A Suprema Corte dos Estados Unidos assim declarou em *Blonder-Tongue v. University of Illinois Foundation*: “due process prohibits applying collateral estoppel to one who has never appeared in prior action”. Em *Parklane v. Shore*: “it is a violation of due process for a judgment to be binding on a litigant who was not a party nor privy and therefore has never had an opportunity to be heard”. Em *Baldwin v. Iowa*: “doctrine of due process under Constitution does not involve right to litigate same question twice”.

41

“The doctrine of Collateral Estoppel will not be applied unless it appears that the party against whom the estoppel is asserted had a full and fair opportunity to litigate the issue in the prior proceeding, and that the application of the doctrine will not result in an injustice to the party against whom it is asserted under the particular circumstances of the case” (*Rachal v. Hill*, 435 F2d 59, 5th Cir., 1970).

43

O Segundo “Restatement of Judgments” assim afirma: “*privy* refers to a cluster of relationships under which the preclusive effects of a judgment extend beyond a party to the original action and apply to persons *having specified relationships to that party*”.

44

Richards v. Jefferson County, 517 U.S. 793, (1996); *Becherer v. Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith, Inc.*, 193 F3d 415, 428-429 (6th Cir, 1999).

45

“We granted certiorari (...) and now affirm the Eleventh Circuit’s judgment. All agree that ‘it is a principle of general application in Anglo-American jurisprudence that one is not bound by a judgement *in personam* in a litigation in which he is not designated as a party or to which he has not been made a party by service of the process [*Hansberry v Lee*] (...). This rule is party of our ‘deep-rooted historic tradition that everyone should have his own day in court (...). A judgement or decree among parties to a lawsuit resolve issues as among them, but it does not conclude the rights of strangers to those proceedings’ (...) ‘a party seeking a judgement binding on another cannot obligate that person to intervene; he must be joined’. ‘Joinder as a party, rather than knowledge of a lawsuit and an opportunity to intervene, is the method by which potential parties are subjected to the jurisdiction of the court and by a judgement or decree. The parties to a lawsuit presumably know better than anyone else the nature and scope of relief sought in the action, and at whose expense such relief might be granted. It makes sense, therefore, to place on them a burden of bringing in additional parties where such a step is indicated, rather than placing on potential additional parties a duty to intervene when they acquire knowledge of the lawsuit. The linchpin of the ‘impermissible collateral attack’ doctrine-the attribution of preclusive effect to a failure to intervene-is

therefore quite inconsistent with rules 19 and 24 [from Federal Rules of Civil Procedure]” (Martin v. Wilks, 490 U.S. 755, 1989).

46

Owen Fiss, The political theory of the class action, *Washington and Lee Law Review*, v. 53, 1996.

47

A Suprema Corte dos Estados Unidos, em *Hansberry v. Lee*, anunciou que o elemento que legitima a *class action* perante o *due process* é a representação adequada: “The Fourteenth Amendment does not compel state courts or legislatures to adopt any particular rule for establishing the conclusiveness of judgments in class suits nor does it compel the adoption of the particular rules thought by the United States Supreme Court to be appropriate for federal courts, but there is a failure of ‘due process of law’ only where it cannot be said that the procedure adopted fairly insures the protection of the interests of absent parties who are to be bound by it” (*Hansberry v. Lee*, 311 U.S. 32, 61 S.Ct. 115, 1940).

48

Eli J. Richardson, Taking issue with preclusion: reinventing Collateral Estoppel. *Mississippi Law Journal*, vol. 65, 1995; Steven P. Nonkes, Reducing the unfair effects of non-mutual issue preclusion through damages limits, *Cornell Law Review*, vol. 94, 2009.

49

Helen Hershkoff, Aggregation of parties, claims, and actions, *Civil litigation in comparative context*, New York: Thomson/West, 2007, p. 369 e ss.

50

Isso significa que a coletivização da demanda individual nada mais é do que uma garantia do litigante único e não algo que pode ser utilizado para abreviar, de forma indevida, a tutela dos direitos dos membros dos grupos.

51

Como escreve Denti, “sembra indubbio che l'utilizzazione delle azioni giudiziali a tutela di interessi collettivi vada inquadrata nell'ampio contesto della partecipazione pubblica...” (Vittorio Denti, *Un progetto per la giustizia civile*, Bologna: Il Mulino, 1982, p. 192).

52

É interessante que, desta forma, estaria superado o equívoco – presente no sistema formado pela Lei da Ação Civil Pública e pelo CDC – em não se prejudicar os representados em caso de sentença de improcedência. Na verdade, se o processo coletivo depende de representação adequada, os representados têm que ser beneficiados ou prejudicados, conforme a sentença seja de procedência ou de improcedência.

53

Ver Sérgio Arenhart, *A tutela coletiva de interesses individuais*, São Paulo: Ed. RT, 2013.

54

Sobre a hipótese em que as demandas repetitivas são propostas contra réus distintos, podendo-se falar em vários litigantes nos dois polos das demandas, ver comentários ao art. 977, item 3.

55

Diego Volpino, *L'oggetto del giudicato nell'esperienza americana*, cit., p. 302 e ss.

57

Geoffrey Hazard Jr., Preclusion as to issues of law: the legal system's interest, *Iowa Law Review*, 1984, p. 81 e ss.; Austin Scott, Collateral estoppel by judgment, *Harvard Law Review*, 1942, p. 3 e ss.

58

Segundo o art. 97 da CRFB/1988, “somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público”. A norma afirma a cláusula da reserva do plenário, que reflete a presunção de constitucionalidade das leis. A lei, por presumir-se constitucional, só pode ser declarada inconstitucional no tribunal mediante quórum qualificado. V. Luiz Guilherme Marinoni, *Curso de direito constitucional* (Sarlet, Marinoni, Mitidiero), 4. ed., São Paulo: Saraiva, 2015, p. 980 e ss.

59

Rcl 1.898, rel. Min. Celso de Mello, *DJ* 19.02.2004. V. Rcl 1.733, rel. Min. Celso de Mello, *DJ* 01.12.2000; Rcl. 664, Pleno, rel. Min. Ellen Gracie, *DJ* 21.06.2002; Rcl 600, Pleno, rel. Min. Néri da Silveira, *DJ* 05.12.2003; Rcl 602, Pleno, rel. Ilmar Galvão, *DJ* 14.02.2003; Rcl 1733, rel. Min. Celso de Mello, *DJ* 12.03.2003; RE 411156, rel. Min. Celso de Mello, *DJe* 03.12.2009.

60

Sobre o problema do emprego das técnicas decisórias da interpretação conforme e da declaração parcial de nulidade sem redução de texto, ver os comentários ao art. 987 do CPC/2015, item 3, que tratam do recurso extraordinário em face da questão decidida no incidente.

61

V. abaixo comentários ao art. 977 do CPC/2015, item 3.

62

Luiz Guilherme Marinoni, *O Julgamento nas Cortes Supremas*, cit. V. também Luiz Guilherme Marinoni, *O*

STJ enquanto Corte de Precedentes, 2a. ed., São Paulo: Ed. RT, 2014; Daniel Mitidiero, Cortes Superiores e Cortes Supremas, cit.; Id., Precedentes, cit.

63

V. Zenon Bankowski, Neil MacCormick, Lech Morawski e Alfonso Ruiz Miguel, Rationales for precedent. *Interpreting Precedents: a comparative study*. London: Dartmouth, 1997. p. 488.

64

Maria Rosaria Ferrarese, Dal “verbo” legislativo a chi dice l’“ultima parola”: le Corti Costituzionali e la rete giudiziaria. *Annuario di Diritto Comparato e di Studi Legislativi*, Nápoles: Edizioni Scientifiche Italiane, 2011, p. 63 e ss.

65

Gaetano Silvestri, Le Corti Supreme negli ordinamenti costituzionali contemporanei. *Le Corti Supreme*. Milano: Giuffrè, 2001. p. 45.

66

Jerzy Wróblewski, Legal syllogism and rationality of judicial decision, *Rechtstheorie*, Berlin: Duncker & Humblot, 1974. v. 5, parte 1, p. 35 e ss; Giuseppe Zaccaria, Complessità della ragione giuridica. *Questioni di interpretazione*, Padova: Cedam, 1996, p. 3-20; Pierluigi Chiassoni, *Tecnica dell’interpretazione giuridica*. Bologna: Il Mulino, 2007; Frank Michelman, Justification (and justifiability) of law in a contradictory world. *Nomos XXVIII: Justification*, New York, New York University Press, v. 71, 1986, p. 71-99.

67

Gaetano Silvestri, Le Corti Supreme negli ordinamenti costituzionali contemporanei. *Le Corti Supreme*, cit., p. 45.

68

“Ad esempio colui che, trovandosi nelle condizioni previste dall’ordinamento, compia regolarmente la serie di atti che la legge prescrive per la conclusione del negozio di compravendita in qualità di acquirente, può prevedere, in un ordinamento datato di effettività, che verrà riconosciuto come proprietario della merce, e che in caso di contestazione tale qualità gli verrà riconosciuta in giudizio: l’univocità della qualificazione giuridica della sua situazione, come si vede, è strettamente connessa con la prevedibilità delle reazioni del venditore, dei terzi e dell’eventuale giudice nei confronti del suo comportamento a proposito, per esempio, del pagamento. Pertanto la prevedibilità, unitamente alla qualificazione univoca delle situazioni, finisce per essere premessa indispensabile perchè si determini e sussista nella comunità il sentimento di sicurezza circa la soddisfazione effettiva della fondamentale esigenza di giustizia, ossia che il diritto prevalga sul torto. Quale sicurezza potrebbe sussistere, infatti, se fosse incerta la qualificazione delle situazioni in cui tali criteri dovrebbero operare, o se fossero imprevedibili le conseguenze giuridiche di un’azione?” (Massimo Corsale, *Certezza del diritto e crisi di legittimità*. Milano: Giuffrè, 1979. p. 32-33).

69

Como afirma Massimo Corsale, para que se possa realizar a certeza da ação através do Direito, o que conta, em última análise, não é tanto a fórmula escrita no código, a norma abstrata, mas a dita norma individual, a concretização da regra no caso específico (Massimo Corsale, *Certezza del diritto e crisi di legittimità*, cit., p. 34).

70

Neil MacCormick, The ethics of legalism. *Ratio Juris*, 1989, 2, p. 184-193 e ss. De acordo com a ‘ética do legalismo’, há valores morais e sociais específicos que dependem da manutenção e suporte de uma ordem normativa institucional, para o bem da paz e previsibilidade entre os seres humanos, e como condição (mas não garantia) para manter-se a justiça entre eles (Neil MacCormick, *Rhetoric and the rule of Law*, Oxford: Oxford University Press, 1995, p. 6).

71

“No que tange ao Estado de Direito, as pessoas podem ter, antecipadamente, razoável certeza a respeito das regras e padrões segundo os quais sua conduta será julgada, e sobre os requisitos que elas devem satisfazer para dar validade jurídica às suas transações. Elas podem ter razoável segurança em suas expectativas acerca das condutas das demais pessoas e, em particular, acerca daquelas que detêm posições de governo em relação ao Direito. Elas podem desafiar ações governamentais que afetem seus interesses exigindo bases jurídicas claras para a ação oficial, ou pleiteando a nulidade de atos praticados em desacordo com o Direito por meio do controle desses atos por um Judiciário independente” (Neil MacCormick, *Rethoric and the rule of Law*, cit., p. 18).

72

Costuma-se dizer, na literatura inglesa e estadunidense, que a previsibilidade constitui razão para seguir precedentes. Lembre-se que Hale disse que o *stare decisis* tinha como objetivo satisfazer a exigência de certeza formal. Mais do que isso, o célebre artigo de Arthur Goodhart, de 1934 (Precedent in English and Continental Law, *Law Quaterly Review*, v. 50, 1934), sustentou que a certeza jurídica seria a mais importante causa para a instituição do *stare decisis* ou para o estabelecimento de um sistema de precedentes vinculantes. V. ainda Theodore M. Benditt, The rule of precedent. *Precedent in Law*. Oxford: Clarendon Press, 1987, p. 89 e ss.

73

Massimo Corsale, *Certezza del diritto e crisi di legittimità*, cit., p. 40.

74

Em Agravo Regimental em Medida Cautelar interposto pela Confederação dos Trabalhadores no Serviço Público Federal, a 3.a. Seção firmou ementa com as seguintes passagens: “... O provimento agravado, mesmo que implicitamente, teve por legítima a indicação da Confederação no polo passivo da Medida Cautelar em vista de toda a sua atuação no acordo entabulado com o Governo Federal, tido por descumprido. (...) In casu, diante da representatividade da ora agravante, que a si mesma se intitula como a

maior entidade representativa de trabalhadores do serviço público federal da América Latina, a fixação de multa diária de cinquenta mil reais não atenta contra o princípio da razoabilidade (...)”. (STJ, AgRg na MC 14.857/DF, 3.ª. Seção, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 18.06.2009).

75

Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero, *Repercussão geral no recurso extraordinário*, 3. ed., São Paulo: Ed. RT, 2012, p. 25-26.

76

Sobre o conceito de “questão de direito”, para efeito de incidente de resolução de demandas repetitivas, ver comentários ao art. 976 do CPC/2015, especialmente os itens 1.2, 1.4 e 1.5.

77

O art. 927 do CPC/2015 diz que os juízes e tribunais devem observar hipóteses que não guardam qualquer homogeneidade. Mistura decisão do Supremo Tribunal Federal proferida em controle concentrado de constitucionalidade, súmulas, decisões tomadas em vias de solução de questões repetitivas e orientação do plenário ou do órgão especial, mas, surpreendentemente, nada diz sobre precedente, *ratio decidendi* ou fundamentos determinantes da decisão. Para que se conclua que os precedentes das Cortes Supremas devem ser observados pelos juízes e tribunais basta estar atento às normas constitucionais que atribuem ao Supremo Tribunal Federal e ao Superior Tribunal de Justiça a função de outorga de unidade ao direito constitucional e infraconstitucional. Portanto, o art. 927 do CPC/2015, *além de desnecessário, tem caráter meramente exemplificativo*. De lado as súmulas – que obviamente não são precedentes e só existem por terem que ser respeitadas –, decisões lembradas nos seus incisos I e III estão *situadas entre os precedentes* das Cortes Supremas. Precedente é gênero, que obviamente encarta os precedentes firmados em controle concentrado (art. 927, I, do CPC/2015) e os precedentes estabelecidos em “julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos” (art. 927, III, do CPC/2015). Já as decisões proferidas nos incidentes de resolução de demandas repetitivas – deixando-se de lado a questão da ilegitimidade constitucional das decisões que prejudicam os que não participaram –, devem ser observadas em razão de sua natureza *erga omnes*. Significa que a norma do art. 927 do CPC/2015 consiste apenas na lembrança de *alguns* precedentes, além de súmulas e controversas decisões tomadas em incidentes de natureza *erga omnes*. (Luiz Guilherme Marinoni, *Precedentes obrigatórios*, 4. ed., cit., Capítulo IV, item 1).

78

Lembre-se que, na tradição do direito inglês, o *amicus* intervém apenas para auxiliar a Corte ou esclarecer os fatos para que a Corte não decida de forma equivocada. V. Samuel Krislov, *The amicus curiae* brief. From friendship to advocacy. *Yale Law Journal*, 72, 1963, p. 694 e ss. Amplamente sobre o *amicus curiae* no direito brasileiro, Cássio Scarpinella Bueno, *Amicus Curiae* no Processo Civil Brasileiro – Um Terceiro Enigmático, 3. Ed. São Paulo: Saraiva, 2012.

79

Elisabeta Silvestri, *L'amicus curiae: uno strumento per la tutela degli interessi non rappresentati*, *Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile*, 1997, p. 693.

Michael K. Lowman, The litigating *amicus curiae*: when does the party begin after the friends leave? *The American University Law Review*, 41, 1992, p. 1243-1299.

A princípio, um tribunal de apelação não firma precedentes por uma razão muito simples. Não é função sua atribuir sentido ao direito e dar-lhe desenvolvimento, mas resolver os litígios. Os tribunais atuam de modo a revisar a “justiça” das sentenças de primeiro grau sem qualquer restrição. Isso não significa, como é óbvio, que os juízes e os tribunais não tenham que dedicar tempo e esforço para dar interpretação aos textos legais. Os juízes e tribunais tem aí a importante missão de colaborar para o amadurecimento da interpretação das leis e da solução das questões de direito. Se estes não podem negar o sentido atribuído ao direito pelas Cortes Supremas, cabe-lhes dar início à atividade interpretativa do Poder Judiciário, fornecendo os primeiros exemplos de interpretação e de solução das questões de direito. Assim, a função de resolver litígios deve dar aos tribunais a possibilidade de sedimentar os seus entendimentos sobre o direito para que as Cortes Supremas possam resolver os impasses interpretativos a partir de interpretações delineadas, ou seja, com base no “direito vivo” de cada um dos tribunais e não com base em decisões dispersas e incapazes de revelar os seus pensamentos. Ademais, quando a importância do julgamento é deslocada da resolução do recurso para as razões que determinam a solução do caso e a interpretação adequada, não apenas se torna relevante debater estas razões nas Cortes Supremas, mas igualmente perceber que o entendimento que pode levar a uma solução favorável por maioria pode ser incapaz de propiciar a elaboração de um precedente. Ou seja, é possível que, num colegiado composto por cinco julgadores, existam três votos favoráveis ao provimento do recurso ou à fixação de determinada interpretação, mas apenas dois julgadores compartilhem o mesmo fundamento ou estejam de acordo em firmar determinado entendimento, capaz de ser expresso em razões determinantes. Isso se torna problema quando se está diante da formulação do sentido do direito mediante precedente e não quando se pensa em jurisprudência (Luiz Guilherme Marinoni, *Precedentes obrigatórios*, 4. ed., cit., capítulo IV, itens 2 e 3; Luiz Guilherme Marinoni, *O Julgamento nas Cortes Supremas*, cit., passim). Ver também Daniel Mitidiero, Cortes Superiores e Cortes Supremas, cit.; Id., *Precedentes*, cit.

David L. Shapiro, Some thoughts on intervention before Courts. Agencies, and arbitrators. *Harvard Law Review*, 81, 1968, p. 752-753; Brian P. Goldman, Should the Supreme Court stop inviting *amici curiae* to defend abandoned lower court decisions? *Stanford Law Review*, vol. 63, 2011, p. 907-972; Elisabeta Silvestri, *L'amicus curiae: uno strumento per la tutela degli interessi non rappresentati*. *Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile*, 1997, p. 696.

A busca pela *ratio decidendi* é peculiaridade do processo judicial da Inglaterra, Escócia e dos países cujo sistema legal derivam do *common law* inglês (Rupert Cross e J. W. Harris, *Precedent in English law*, Oxford: Clarendon Press, 1991, p. 47). No *civil law*, em vista da primitiva função incorporada pelo Judiciário, não havia motivo para preocupação com razões de decidir, nem muito menos com a instituição, por parte das Cortes Supremas, de um precedente capaz de regular os casos futuros. Se a Corte Suprema objetiva apenas corrigir a decisão que aplica a lei, basta declarar o seu exato sentido, ou melhor, a exata norma contida no

texto legal. Sobre o conceito de *ratio decidendi* no *common law*, ver Eugene Wambaugh, *The study of cases: a course of instruction in reading and stating reported cases, composing head-notes and briefs, criticising and comparing authorities, and compiling digests*. 2. ed. Boston: Little, Brown & Co., 1894, p. 17 e ss.; Arthur L. Goodhart, Three cases on possession. *The Cambridge Law Journal*, n. 3, 1928, p. 195-208; Joseph Francis, Three cases on possession – Some further observations, *St. Louis Law Review*, n. 14, 1928, p. 11-16; J. L. Montrose, Ratio decidendi and the House of Lords, *The Modern Law Review*, 1957, vol. 20, p. 124 e ss.; J. L. Montrose, The ratio decidendi of a case, *The Modern Law Review*, 1957, vol. 20, p. 587 e ss.; A. W. B. Simpson, The ratio decidendi of a case, *The Modern Law Review*, 1957, vol. 20, p. 413 e ss.; A. W. B. Simpson, The ratio decidendi of a case, *The Modern Law Review*, 1958, vol. 21, p. 155 e ss. Acerca da função da Corte de Cassação, ver Piero Calamandrei, *La cassazione civile*, Milano: Fratelli Bocca, 1920.

84

As súmulas nunca conseguiram contribuir para a unidade do direito. Foram pensadas a partir de uma compreensão muito superficial do sistema em que as decisões têm efeito obrigatório ou a partir das máximas, uma lamentável e ineficaz tentativa de alguns sistemas de *civil law* para o encontro da uniformidade da interpretação. As súmulas foram concebidas como enunciados da interpretação das Cortes de correção e destinadas a facilitar os julgamentos dos recursos. Se a súmula é o enunciado da tese de direito, ela não pode, como é óbvio, explicar os motivos da adoção da tese em face de uma determinada situação concreta. Ao contrário, a *ratio decidendi* ou os fundamentos determinantes de uma decisão espelham não apenas uma tese de direito, mas, mais propriamente, a racionalidade da tese em face de determinada moldura fática. Uma súmula, obviamente, não tem condições de refletir a racionalidade da argumentação própria a um precedente. (Cf. Luiz Guilherme Marinoni, *Precedentes obrigatórios*, 4. ed., Capítulo IV, item 1.4)

85

O *distinguishing* ou a técnica da distinção, referida no inc. VI do § 1.º do art. 489 do CPC, não apenas permite a distinção do caso sob julgamento para a não aplicação do precedente, mas igualmente a distinção do caso para a ampliação do alcance do precedente. Isso ocorre quando o caso, a princípio, não se submete ao precedente, mas a racionalidade da *ratio decidendi* diante do caso que deu origem ao precedente evidencia que o caso sob julgamento também deve ser resolvido mediante a aplicação do precedente. Na última hipótese, a falta de ampliação do alcance do precedente violaria a igualdade perante o direito, fundamento do sistema de precedentes (Cf. Luiz Guilherme Marinoni, *Precedentes obrigatórios*, 4. ed., Capítulo IV, item 7.4)

86

Como demonstram, por exemplo, os trabalhos de Michele Taruffo, “Collateral estoppel” e giudicato sulle questioni, *Rivista di diritto processuale*, 1972 e Diego Volpino, *L’oggetto del giudicato nell’esperienza americana*, cit.

87

O precedente deixa de corresponder aos padrões de congruência social quando passa a negar proposições morais, políticas e de experiência. Não tem consistência sistêmica quando não guarda coerência com as decisões da própria Corte Suprema. Isso ocorre, especialmente, quando a Corte passa a decidir com base

em proposições incompatíveis com as que sustentaram o precedente. V. Luiz Guilherme Marinoni, *Precedentes obrigatórios*, 4. ed., Capítulo 4, item 9.1; Daniel Mitidiero, *Precedentes*, cit.; Melvin Eisenberg, *The nature of the common law*, Cambridge: Harvard University Press, 1998, p. 14, 26 e 37.

88

“Issue preclusion establishes in later trial on different claim identical issues resolved in earlier trial, if certain conditions are met: first, *issue must have been actually litigated, that is, contested by parties and submitted for determination by court*; second, *issue must have been actually and necessarily determined by court of competent jurisdiction in first trial*; and third, *preclusion in second trial must not work an unfairness*” (Otherson v. Department of Justice, I.N.S., United States Court of Appeals, District of Columbia Circuit, June 21, 1983, 711 F.2d 267, 228 U.S.App.D.C. 481). Em igual sentido: Canonsburg General Hosp. v. Burwell, United States Court of Appeals, District of Columbia Circuit, December 1, 2015, F.3d, 2015 WL 8051408.

89

A ideia está muito clara nos tribunais estadunidenses: “Although in broad, general sense ‘res judicata’ encompasses concept of collateral estoppel, *strictly speaking ‘res judicata’ bars second suit involving same parties and same cause of action on all matters that were part of first suit and all issues that could have been litigated, while doctrine of ‘collateral estoppel’ precludes relitigation only of issues that were actually litigated in initial suit*, whether or not second suit is based on same cause of action”. (Precision Air Parts, Inc. v. Avco Corporation, United States Court of Appeals, Eleventh Circuit, July 24, 1984, 736 F.2d 1499), No mesmo sentido, mais recente: Batchelor-Robjohns v. United States, United States Court of Appeals, Eleventh Circuit, June 5, 2015, 788 F.3d 1280.

90

Lisa L. Glow, Offensive Collateral Estoppel in Arizona: Fair Litigation v. Judicial Economy. *Arizona Law Review*. Vol. 30. 1988

91

Diego Volpino, *L’oggetto del giudicato nell’esperienza americana*, cit., p. 322-323.

92

“Issue preclusion is sometimes unfair if party to be bound lacked an incentive to litigate in first trial, especially in comparison to stakes of second trial” (Peavey v. United States, United States District Court, District of Columbia, August 26, 2015, F. Supp.3d, 2015 WL 5063164).

93

““Offensive use of collateral estoppel’ permits plaintiff who was not party to prior action to estop defendant from relitigating issues which defendant litigated and lost in prior action” (Kramer v. Showa Denko K.K., United States District Court, S.D. New York, June 20, 1996, 929 F. Supp. 733).

94

Ashley C. Perea, Broad discretion: a choice in applying offensive non-mutual collateral estoppel, *Arizona State Law Journal*, Vol. 40. 2008; Joshua M. D. Segal, Rebalancing fairness and efficiency: The offensive use of collateral estoppel in § 1983 actions. *Boston University Law Review*. Vol. 89. 2009

95

Como dito em *Otherson v. Department of Justice, I.N.S.*, “preclusion in second trial must not work an unfairness” (*Otherson v. Department of Justice, I.N.S.*, United States Court of Appeals, District of Columbia Circuit, June 21, 1983, 711 F.2d 267, 228 U.S.App.D.C. 481). Ver também *Yamaha Corp. of America v. United States*, United States Court of Appeals, District of Columbia Circuit, April 14, 1992, 961 F. 2d 245.

96

V. Robert Alexy, *Teoria da argumentação jurídica*, São Paulo, Landy, 2001.

97

Cf. Luiz Guilherme Marinoni, *A Intangibilidade da coisa julgada diante da decisão de inconstitucionalidade*, São Paulo: Ed. RT, 2016, especialmente capítulo 3.

98

De acordo com o Neil Duxbury, é possível entender como *obiter dicta* um argumento que não tem relação com o resultado, que não é conectado com os fatos do caso ou que é relacionado a ponto não suscitado por nenhuma das partes (Neil Duxbury, *The nature and authority of precedent*. New York: Cambridge University Press, 1991, p. 68). Segundo Robert Summers, a espécie de *dicta* mais comum no direito estadunidense consiste em declarações do tribunal sobre hipóteses que não foi chamado a decidir ou está realmente decidindo (Robert Summers, *Precedent in the United States* (New York). In: *Interpreting Precedents: a comparative study*. London: Dartmouth, 1997, p. 385).

99

De acordo com o art. 97 da CRFB/1988, “somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público”.

100

Ver comentários ao art. 976 do CPC/2015, item 1.3: “Questão constitucional”.

101

Perceba-se, por exemplo, como se expressa Canotilho: “O princípio da interpretação conforme à Constituição é um princípio geral de interpretação que, no domínio específico da jurisdição constitucional, remonta ao velho princípio da jurisprudência americana, segundo a qual os juízes devem interpretar as

leis *in harmony with the constitution*. (...) o princípio da interpretação conforme à Constituição é um instrumento hermenêutico de conhecimento das normas constitucionais que impõe o recurso a estas para determinar e apreciar o conteúdo intrínseco da lei” (J. J. Gomes Canotilho, *Direito constitucional e teoria da constituição*, 5. ed., Coimbra: Almedina, 2002, p. 1225). Canotilho, como se vê, refere-se a “interpretação conforme” no primeiro sentido.

102

Na Rcl 10.958, a Min. Ellen Gracie, ao analisar pedido de medida cautelar em Reclamação ajuizada pelo Município de Osório, assim *argumentou*: “O acórdão impugnado na presente Reclamação, na dificuldade que teve de encontrar, na lei, definição categórica do que deva ser entendido como ‘instalações terrestres de embarque e desembarque de óleo bruto ou de gás natural’ ou como ‘estações terrestres coletoras de campos produtores e de transferência de óleo bruto ou gás natural’, parece, a princípio, ter lançado mão de critério inovador, *de matriz constitucional*, que importou, no mínimo, *na parcial declaração de inconstitucionalidade, sem redução de texto, de um sentido mais literal e extensivo da norma legal, adotado pela própria Administração Pública por pelo menos uma década*” (MC na Rcl 10.958, rel. Min. Ellen Gracie, j. 21.12.2010).

103

Como decidiu a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, relator o Min. Dias Toffoli, “o reconhecimento incidental, por parte de órgão fracionário de tribunal, de inconstitucionalidade de lei, apenas enseja recurso extraordinário com fundamento no princípio da violação da reserva de Plenário, em afronta ao disposto no art. 97 da Constituição Federal. Para que seja viável o recurso com fundamento na alínea ‘b’, do permissivo constitucional, mister decisão formal do tribunal de origem acerca do tema, através do órgão competente, o que não aconteceu neste caso” (RE 550.539 AgR/SC, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, *DJe* 29.09.2011). No mesmo sentido, RE 334.723/AgR-RJ, Primeira Turma, Min. Cármen Lúcia, *DJe* 06.11.2006.

104

Art. 102, § 3.º, CRFB/1988: “No recurso extraordinário o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, *nos termos da lei*, a fim de que o Tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de dois terços de seus membros”.

105

Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero, *Repercussão geral no recurso extraordinário*, 3.ed., cit., p. 36 e ss.

106

André Tunc, La Cour Suprême idéale, *Revue Internationale de Droit Compare*, p. 445.

107

O juiz, para não aplicar precedente, deverá demonstrar que a questão de direito que reclama solução não

está resolvida na *ratio* ou que a questão de direito dirimida pela *ratio* assume outra configuração diante das circunstâncias fáticas do caso sob julgamento. O art. 489, § 1.o, VI do CPC evidencia um ônus argumentativo do juiz, dirigido a demonstrar que o precedente não é apto a resolver o caso ou que esse, por ser marcado por circunstâncias fáticas particulares, é distinto, ou seja, não se enquadra no tipo de caso que pode ser solucionado pelo precedente. A parte final do inciso VI do § 1.o do art. 489 alude à necessidade de demonstrar a “superação do entendimento” para se deixar de seguir precedente. Não é preciso dizer que, nem o juiz ou o tribunal podem revogar precedente de Corte Suprema. A revogação de precedente, como chega a ser intuitivo, é tarefa da Corte que o emitiu. Assim, para admitir que juiz ou tribunal deixem de aplicar precedente em virtude do que a regra chama de “superação do entendimento”, é preciso entender que a regra está a aludir para a não aplicação de precedente já revogado pela Corte Suprema ou, excepcionalmente, para a possibilidade de não aplicação de precedente em virtude de sua provável revogação iminente pela Corte que o elaborou. Essa última hipótese, denominada no direito estadunidense de *anticipatory overruling*, consiste, exatamente, em não aplicar precedente desgastado pelas decisões da própria Corte Suprema. A legitimidade da não aplicação do precedente está no dever de o tribunal se comportar de acordo com o direito e, assim, em conformidade com o comportamento da Corte Suprema. Significa dizer que não importa o entendimento do tribunal, mas, sim, a percepção do entendimento – ainda que não expresso – da Corte Suprema. As características do sistema brasileiro, particularmente do acesso às Cortes Supremas, dificilmente, poderão fazer surgir caso em que, dado o desgaste do precedente, haja necessidade *imediata* da sua não aplicação para não surgir dano à parte. De qualquer modo, na situação em que o tribunal adotou o precedente desgastado e, por conta disso, a decisão está a expor o vencido a prejuízo grave, poderá ser requerida a suspensão dos efeitos da decisão recorrida ou pleiteada a antecipação da tutela recursal. Cf. Luiz Guilherme Marinoni, *Precedentes obrigatórios*, 4. ed., cit., Capítulo IV, item 7.

108

Em 2010, no livro “Precedentes Obrigatórios”, foram apresentadas sugestões para auxiliar os membros do Parlamento na discussão do projeto do Código de Processo Civil. Com base nestas sugestões, a Câmara dos Deputados inseriu norma no código que esclarecia que a *ratio decidendi* depende da adesão da maioria dos membros do colegiado. Esta norma, como é evidente, não objetivava negar a possibilidade de se dar provimento a recurso com base em decisão majoritária dotada de diferentes fundamentos, mas evidenciar que as Cortes Supremas brasileiras têm a função de desenvolver o direito e, portanto, devem solucionar os recursos sem esquecer de buscar consenso para elaborar *rationes decidendi*. Para tanto, afirmou que só há *ratio decidendi* quando ao menos a maioria dos membros do colegiado sustenta um mesmo fundamento determinante do resultado do recurso. *É claro que essa norma não é indispensável para a existência de um precedente. A norma objetivava esclarecer algo que faz parte de um sistema jurídico que trabalha com precedentes e, portanto, um ponto que está na bagagem de qualquer boa teoria dos precedentes.* V. Luiz Guilherme Marinoni, *Precedentes obrigatórios*, São Paulo: Ed. RT, 2010.

109

Rupert Cross e J. W. Harris, *Precedent in English Law*, Oxford: Clarendon Press, 1991, p. 78 e ss; Eugene Wambaugh, *The study of cases: a course of instruction in reading and stating reported cases, composing head-notes and briefs, criticising and comparing authorities, and compiling digests*, 2. ed., Boston: Little, Brown & Co., 1894, 48.

Decisão plural é uma decisão majoritária que contém em si dois fundamentos determinantes, sem com que qualquer deles esteja amparado pela maioria do colegiado. Em outras palavras, uma decisão plural é majoritária quanto ao *resultado*, mas incapaz de gerar *ratio decidendi*, na medida em que nenhum dos fundamentos que nela estão contidos são sustentados pela maioria (Luiz Guilherme Marinoni, *O Julgamento nas Cortes Supremas*, cit., item 2.3).

Adam S. Hochschild, The Modern Problem of Supreme Court Plurality Decision: Interpretation In Historical Perspective, *Washington University Journal of Law & Policy*, vol. 4, p. 261 e ss.

“The Supreme Court performs two essential functions: it resolves the particular controversies that come before it and provides guidance for lower courts in deciding similar cases in the future. Although both of these functions are served to some extent by the mere issuance of a judgment, they are better served when the Court sets out a clear and persuasive rationale assented to by a majority of Justices. A majority rationale not only justifies the judgment reached in the particular case but also offers broader legal principles and policy considerations upon which lower courts can draw” (Linda Novak, The precedential value of Supreme Court Plurality Decisions, *Columbia Law Review*, vol. 80, n. 4 (May, 1980), p. 757).

John F. Davis e William L. Reynolds, Juridical Cripples: Plurality Opinions in the Supreme Court, *Duke Law Journal*, vol. 59, 1974, p. 67 e ss.; Adam S. Hochschild, The Modern Problem of Supreme Court Plurality Decision: Interpretation in Historical Perspective, *Washington University Journal of Law & Policy*, vol. 4 p. 279 e ss.; Linda Novak, The precedential value of Supreme Court Plurality Decisions, *Columbia Law Review*, vol. 80, n. 4 (May, 1980), p. 761 e ss.; Lewis A. Kornhauser e Lawrence G. Sager, The One and the Many: Adjudication in Collegial Courts, *California Law Review*, vol. 81, 1993, p. 11; Lewis A. Kornhauser e Lawrence G. Sager, The many as one: integrity and group choice in paradoxical cases, *Philosophy & Public Affairs*, vol. 32, 2004, p. 249 e ss.

Costuma-se associar o “*narrowest grounds*” com o caso *Marks v. United States*, decidido em 1977, embora se diga que a Suprema Corte anunciou a ideia pela primeira vez em 1972 ao julgar *Furman v. Georgia*, caso em que discutia sobre a constitucionalidade da pena da morte. A Suprema Corte, em *Marks v. United States*, declarou que, quando uma Corte fragmentada decide um caso e nenhuma *rationale* das que conduzem ao resultado é compartilhada por cinco *Justices*, a *ratio* deve ser vista como a posição adotada por aqueles que concorrem ao julgamento em termos de “*narrowest grounds*”. Porém, se em alguns casos mostrou-se fácil extrair uma *ratio* a partir de *rationes* diversas, o mesmo não ocorreu em outras situações, que, efetivamente, demonstraram a dificuldade de se empregar o “*narrowest ground*” em todos os casos. Embora a Suprema Corte tenha aplicado o “*narrowest grounds*” com facilidade em *City of Lakewood v. Plain Dealer Publishing Company* e em *Planned Parenthood of Southeastern Pennsylvania v. Casey*, reconheceu a limitação do teste em *Nichols v. United States*. A doutrina estadunidense admite que a Suprema Corte talvez tenha aprovado, implicitamente, uma “*selective application*” do “*narrowest*

grounds”, a depender de as cortes inferiores terem achado o teste adequado ou não para esclarecer a *ratio* de uma específica decisão. Lembre-se, aliás, que o teste só tem utilidade quando capaz de solucionar a dúvida das cortes inferiores diante da decisão da Suprema Corte. A racionalidade do teste do “*narrowest grounds*” está na admissibilidade da sua relatividade para a busca da *ratio* nas decisões plurais. Recorde-se que a doutrina frisa que a Suprema Corte não aplicou o *narrowest* em todos os casos em que ele seria aplicável. Assim, por exemplo, em *Texas v. Brown* a Suprema Corte decidiu, considerando decisão plural tomada em *Coolidge v. New Hampshire*, que aí não havia qualquer valor de precedente ou um “*binding precedent*”. No direito estadunidense, na verdade, não apenas se sustenta a relatividade do *narrowest test*, como igualmente se diz que ele só é útil nos casos em que a opinião majoritária e a opinião concorrente – que estão no interior da decisão plural – colocam-se numa relação em que uma está situada dentro da outra. V. Adam S. Hochschild, The Modern Problem of Supreme Court Plurality Decision: Interpretation In Historical Perspective, *Washington University Journal of Law & Policy*, vol. 4; Linda Novak, The precedential value of Supreme Court Plurality Decisions, *Columbia Law Review*, vol. 80, n. 4 (May, 1980); Luiz Guilherme Marinoni, *O Julgamento nas Cortes Supremas*, cit., Capítulo IV.

115

Linda Novak, The precedential value of Supreme Court Plurality Decisions, *Columbia Law Review*, vol. 80, n. 4 (May, 1980), p. 769-770.

116

Idem, p. 770.

117

V. Adam S. Hochschild, The Modern Problem of Supreme Court Plurality Decision: Interpretation In Historical Perspective, *Washington University Journal of Law & Policy*, vol. 4, p. 261 e ss.

22

Diego Volpino, L’oggetto del giudicato nell’esperienza americana, cit., p. 292 e ss.

34

“Because petitioners received neither notice of, nor sufficient representation in, the Bedingfield litigation, that adjudication, as a matter of federal due process, may not bind them and thus cannot bar them from challenging and allegedly unconstitutional deprivation of their property. (*Richards v. Jefferson County*, 517 U.S. 793, 1996).

42

Parklane v. Shore, 439 U.S. 322, 1979.

56

Ronald J. Allen e Michael S. Pardo, The myth of the law-fact distinction, *Northwestern University Law*

Review, 2003.

© desta edição [2018]

Capítulo IX. Da Reclamação

Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:

I – preservar a competência do tribunal;

II – garantir a autoridade das decisões do tribunal;

III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;

IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.

§ 1.º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.

§ 2.º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.

§ 3.º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.

§ 4.º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.

§ 5.º É inadmissível a reclamação:

I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;

II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em recurso extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.

§ 6.º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.

1. Reclamação. A reclamação é uma ação que visa a preservar a competência de tribunal, garantir a autoridade das decisões de tribunal e garantir a eficácia dos precedentes das Cortes Supremas e da jurisprudência vinculante das Cortes de Justiça (art. 988, CPC/2015).¹ Não se trata de incidente processual.

Em suas origens mais remotas, a reclamação remonta da *supplicatio* do período da *cognitio extra ordinem* do direito romano e das *sopricações*, *querimas* ou *querimônias* do antigo direito português. No regime das Ordenações Filipinas, a reclamação encontra similar no agravo de ordenação não guardada (por exemplo, Livro III, Título XX, § 46), tendo ainda um claro paralelo no Regulamento 737, de 1850, no agravo por dano irreparável (art. 669, § 15).² Ao longo dos Novecentos, a reclamação experimentou uma significativa evolução, especialmente embalada pelo

incremento do valor dos precedentes das Cortes Supremas. Trata-se de desenvolvimento nítido na sua criação pela jurisprudência a partir da teoria dos poderes implícitos do Supremo Tribunal Federal até a sua expressa previsão na Constituição de 1988 e no Código de 2015.³

2. Cabimento. Cabe reclamação sempre que se vislumbrar a usurpação de competência de tribunal, a violação de autoridade de decisão, a ofensa à autoridade de precedentes das Cortes Supremas (desde que esgotadas as instâncias ordinárias, art. 988, § 5.º, II, CPC/2015) e de jurisprudência vinculante. A opção legislativa a respeito do seu cabimento tem uma clara vinculação, portanto, não só com a prestação da tutela dos direitos em sua dimensão particular, isto é, para busca de uma decisão de mérito justa e efetiva para o litígio (arts. 6.º e 988, I e II, CPC/2015), mas também com a promoção da unidade do direito, isto é, com a tutela dos direitos em sua dimensão geral (arts. 926 e 988, III e IV, CPC/2015).

Rigorosamente, no entanto, a reclamação deveria constituir apenas e tão somente instrumento de tutela da decisão do caso concreto. Dito de outro modo: ela não deveria ser vista como meio de tutela do precedente ou da jurisprudência vinculante. Isso porque semelhante modo de ver o seu papel pode ocasionar o fenômeno inverso àquele que se pretende evitar com a instituição de filtros recursais: o abarrotamento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça com reclamações que, *per saltum*, visam a outorgar força ao precedente – essa, aliás, a razão pela qual a Lei 13.256, de 2016, deu nova redação aos incs. III e IV do *caput* do art. 988 e ao seu § 5.º, do CPC/2015.

Nada obstante, até que as Cortes Supremas, as Cortes de Justiça e os juízes de primeiro grau assimilem uma efetiva cultura do precedente judicial, é imprescindível que se admita a reclamação com função de outorga de eficácia de precedente. E foi com esse objetivo deliberado que o novo Código ampliou as hipóteses de cabimento da reclamação. Essa finalidade fica muito clara não só com a leitura dos incs. III e IV do *caput* do art. 988 do CPC/2015, mas também com a dos seus §§ 4.º e 5.º, inc. II, que expressamente destinam a reclamação ao controle da aplicação indevida de precedentes e da ausência de sua aplicação, desde que devidamente esgotadas as instâncias ordinárias. A propósito, embora o art. 988, § 5.º, inc. II, CPC/2015, fale em “acórdão” oriundo de julgamento de “recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida” e em “acórdão proferido em julgamento de recurso extraordinário ou especial repetitivos”, é certo que a reclamação tutela todo e qualquer precedente constitucional e federal, pouco importando a forma repetitiva. A restrição que interessa aí diz respeito à necessidade de esgotamento da instância ordinária para o cabimento da reclamação.

Diante do direito anterior, a Constituição permitia reclamação apenas diante das Cortes Supremas. O Supremo Tribunal Federal entendeu ainda que era cabível a reclamação diante dos Tribunais de Justiça, desde que as respectivas Constituições estaduais assim o permitissem. O novo Código permite a reclamação para preservação da competência e para garantir a autoridade da decisão de “qualquer tribunal” (art. 988, § 1.º, CPC/2015). Vale dizer: permite também reclamação diante dos Tribunais Regionais Federais.

No mais, a reclamação não constitui sucedâneo da ação rescisória: vale dizer, não serve para desconstituição da coisa julgada. Por essa razão, é inadmissível reclamação proposta após o trânsito em julgado da decisão da qual se pretende reclamar (art. 988, § 5.º, CPC).

3. Cabimento. Precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. Na linha do que observamos, a reclamação não pode ser vista – idealmente – como um instrumento para tutela da autoridade do precedente (como pretendeu o legislador, arts. 926 e 988, incisos III e IV, CPC). É claro que semelhante previsão teria como consequência inevitável um abarrotamento das Cortes Supremas e uma indevida acentuação da função de controle assinalada aos respectivos recursos.

A reação das Cortes Supremas diante desse quadro normativo está em restringir o acesso à reclamação, interpretando os seus dispositivos de maneira muito estreita. O Supremo Tribunal Federal tem decidido, por exemplo, que o cabimento da reclamação exige “pertinência subjetiva”, sendo “imprescindível que o reclamante aponte, como paradigma, processo de índole subjetiva

cuja relação processual tenha integrado”⁴. Em outras palavras: reclamação como meio para tutela da autoridade da decisão do caso concreto e não como meio para tutela da autoridade do precedente. O Superior Tribunal de Justiça tem seguido exatamente a mesma linha⁵.

4. Cognição secundum eventum probationis. Como todos os *writs* constitucionais que visam à viabilização do controle do exercício do poder do Estado (como o *habeas corpus*, o *habeas data* e o mandado de segurança), a reclamação tem o seu procedimento limitado em termos probatórios à prova documental (art. 988, § 2.º, CPC/2015). Vale dizer: a cognição e o debate que são suportados pelo processo da reclamação estão atados à prova documental. Daí a razão pela qual é correto afirmar que a reclamação tem cognição *secundum eventum probationis* – apenas as afirmações que podem ser demonstradas mediante prova documental é que podem ser examinadas no processo da reclamação. Nenhuma outra espécie de prova pode ser admitida. Qualquer alegação que dependa de prova diversa da documental para ser comprovada não pode ser examinada em reclamação⁶.

5. Autonomia. Refere o art. 988, § 6.º, do CPC/2015 que “a inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”. Isso quer dizer duas coisas: em primeiro lugar, que é possível atacar uma decisão simultaneamente por meio de recurso e por meio da ação de reclamação; em segundo lugar, que a reclamação é autônoma em relação ao recurso, isto é, a reclamação sobrevive e não perde o seu objeto por força da inadmissibilidade ou do julgamento do recurso.

6. Competência. A reclamação é dirigida ao Presidente do Tribunal competente para o seu conhecimento, que é aquele cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se procura garantir (art. 988, § 1.º, *in fine*, CPC/2015). Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator, que será, sempre que possível, o relator do processo do qual emanada a decisão, precedente ou jurisprudência vinculante que se procura garantir (art. 988, § 3.º, CPC/2015). No caso em que a reclamação visa à preservação de competência, a distribuição será em regra livre.

7. Esgotamento das Instâncias Ordinárias. O art. 988, § 5.º, inc. II, do CPC/2015 condiciona o cabimento da reclamação para as Cortes Supremas, em certas hipóteses, ao esgotamento das instâncias ordinárias. Isso se presta para evitar o acionamento das Cortes Supremas desnecessariamente e *per saltum*.

Excepcionalmente, porém, poderá o STF ou o STJ – diante da urgência da sua intervenção, da gravidade do caso e da inviabilidade do prévio esgotamento das vias ordinárias – relevar esse requisito e conhecer diretamente da reclamação. Na vigência do Código de Processo Civil de 1973, as Cortes Supremas em várias oportunidades reconheceram a necessidade de examinar diretamente pedidos de efeito suspensivo ou antecipação da tutela recursal sem que se houvesse ainda esgotado o papel das instâncias ordinárias. A mesma lógica deve ser aqui aplicada, de modo a permitir excepcionalmente a superação da exigência contida no art. 988, § 5.º, inc. II, do CPC/2015.

Art. 989. Ao despachar a reclamação, o relator:

I – requisitará informações da autoridade a quem for imputada a prática do ato impugnado, que as prestará no prazo de 10 (dez) dias;

II – se necessário, ordenará a suspensão do processo ou do ato impugnado para evitar dano irreparável;

III – determinará a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação.

1. Relator. Além dos poderes arrolados no art. 989 do CPC/2015, pode o relator indeferir a petição inicial (art. 330, CPC/2015) – quando o autor narrar como causa de pedir hipótese diversa daquelas constantes do art. 988 do CPC/2015, quando o direito alegado depender de prova diversa

da documental para sua comprovação ou quando a petição inicial contiver quaisquer dos vícios que levam ao seu indeferimento – ou julgar improcedente liminarmente o pedido de reclamação (art. 332, CPC/2015). Antes de indeferi-la, em sendo o caso, o relator viabilizará o direito à emenda da petição inicial (art. 321, CPC/2015).

Da decisão do relator caberá agravo interno (art. 1.021, CPC/2015).

2. Contestação. O beneficiário da decisão impugnada deverá ser citado para apresentar a sua contestação no prazo de 15 (quinze) dias. A defesa está limitada obviamente ao objeto da reclamação: o beneficiário da decisão poderá alegar motivos que levam tanto à inadmissibilidade como à improcedência da reclamação. Alegando motivos de inadmissibilidade, tem o reclamante de ter vista dos autos para oferecer réplica (analogamente, art. 351, CPC/2015).

Art. 990. Qualquer interessado poderá impugnar o pedido do reclamante.

1. Impugnação. Além do beneficiário da decisão impugnada, que tem direito de defender a decisão que lhe outorga determinada vantagem diante da ordem jurídica (art. 989, III, CPC/2015), qualquer interessado poderá impugnar o pedido do reclamante (art. 990, CPC/2015). Vale dizer: qualquer interessado poderá defender o ato impugnado.

2. Contraditório. Da defesa do ato impugnado terá vista o reclamante para réplica, acaso alegue motivos que conduzam à inadmissibilidade da reclamação (analogamente, art. 351, CPC/2015).

Art. 991. Na reclamação que não houver formulado, o Ministério Público terá vista do processo por 5 (cinco) dias, após o decurso do prazo para informações e para o oferecimento da contestação pelo beneficiário do ato impugnado.

1. Ministério Público. No processo da reclamação, não sendo parte, o Ministério Público terá vista dos autos por último. Em sendo o caso, portanto, terá vista dos autos após a réplica do reclamante. Se houver impugnação por qualquer interessado, dela também terá vista o Ministério Público antes do julgamento da reclamação.

Art. 992. Julgando procedente a reclamação, o tribunal cassará a decisão exorbitante de seu julgado ou determinará medida adequada à solução da controvérsia.

1. Competência. Quando a reclamação tiver por objeto a preservação de competência do tribunal, a decisão que julga procedente o pedido determinará medida adequada à solução da controvérsia. Obviamente, dentre as medidas adequadas inclui-se ordem para que cesse o exame da causa pelo órgão jurisdicional reclamado e a remessa dos autos para o juízo competente (art. 64, § 3.º, CPC/2015). A parte deve ser intimada para adequar a sua petição inicial às exigências legais inerentes ao exame do órgão jurisdicional reconhecido como competente (analogicamente, art. 968, § 5.º, CPC/2015).

2. Autoridade. Quando a reclamação tiver por objeto a garantia da autoridade de decisão, precedente ou jurisprudência vinculante, o julgamento de procedência do pedido leva à desconstituição da decisão contrária à orientação do tribunal, determinando-se a sua observância naquilo que pertinente ao caso concreto.

3. Medida adequada. Tendo em conta o sistema de atipicidade da técnica executiva adotado pelo novo Código (art. 139, IV, CPC/2015), a decisão de procedência emanada no processo da reclamação pode ser cumprida por qualquer medida que se mostre adequada: vale dizer, que promova o fim a que se destina a decisão (art. 991, CPC/2015). Obviamente, o emprego efetivo da medida adequada pode ser controlado pela necessidade de seu uso no caso concreto (regra do meio idôneo com menor restrição possível, analogamente, art. 805, CPC/2015).

Art. 993. O presidente do tribunal determinará o imediato cumprimento da decisão, lavrando-se o acórdão posteriormente.

1. Imediato cumprimento. O presidente do tribunal determinará imediato cumprimento da decisão. Subordinar o seu cumprimento à lavratura do acórdão ofende o art. 993 do CPC/2015.

NOTAS DE RODAPÉ

1

Amplamente, Marcelo Dantas, *Reclamação constitucional no direito brasileiro*, Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris Editor, 2000; Leonardo Morato, *Reclamação e sua aplicação para o respeito da súmula vinculante*, São Paulo: Ed. RT, 2007.

2

Sobre o tema, Egas Dirceu Moniz de Aragão, *A correção parcial*, Curitiba, 1958, p. 131.

3

Para uma esquematização da evolução do tema até a Constituição de 1988, José da Silva Pacheco, A “Reclamação” no STF e no STJ de acordo com a nova Constituição, *Revista dos Tribunais*, vol. 646, São Paulo: Ed. RT, 1989.

4

STF, 1ª Turma, AgRg na Rcl 27.258/DF, rel. Min. Luiz Fux, j. 11.05.2018, *DJe* 24.05.2018.

5

STJ, 2ª Seção, AgInt na Rcl 35.515/SE, rel. Min. Marco Buzzi, j. 23.05.2018, *DJe* 30.05.2018.

6

Igualmente nessa linha, Ricardo de Barros Leonel, in Cássio Scarpinella Bueno, (Coord.), *Comentários ao Código de Processo Civil*. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 242, vol. IV.

TÍTULO II - DOS RECURSOS

Capítulo I. Disposições Gerais

1. Recursos. O recurso é o “remédio voluntário idôneo a ensejar, dentro do mesmo processo, a reforma, a invalidação, o esclarecimento ou a integração de decisão judicial que se impugna”¹. Trata-se de clássica lição da doutrina brasileira, cujos traços ecoam os principais aspectos que costumam delinear o conceito de recurso na doutrina italiana e na doutrina alemã: o escopo de *reexame* de uma decisão *dentro* do mesmo processo².

De um ponto de vista comparado, costuma-se ainda falar que o recurso constitui um remédio que visa a viabilizar um reexame perante outro órgão jurisdicional hierarquicamente superior³. No direito brasileiro, porém, a circunstância de o legislador ter inserido os embargos de declaração e o agravo interno como recursos (art. 994, incisos III e IV, CPC/2015) faz com que semelhante traço não se aplique ao nosso conceito de recurso. Daí uma especificidade do conceito de recurso da nossa ordem jurídica.

O direito ao recurso é uma das posições jurídicas que compõem o direito de ação. Dito de outro modo: o direito ao recurso não é propriamente um prolongamento do direito de ação, mas é o próprio direito de ação – visto em uma perspectiva complexa e dinâmica⁴. Como posição integrante ao direito de ação, também conta na sua estruturação com posições que garantem tanto direitos a prestações – dentre as quais a mais óbvia está o direito à tutela jurisdicional – como direitos potestativos – dentre os quais se insere, por exemplo, o direito à desistência recursal. O direito ao recurso, assim, é um direito que se estrutura a partir de um complexo de posições jurídicas diferenciadas: não se trata nem de direito a simples prestações, nem de direito a simples sujeições⁵.

A irresignação diante de uma decisão é algo bastante natural, sendo por essa razão que os sistemas processuais normalmente apresentam formas de impugnação das decisões judiciais. Nada obstante, o direito ao recurso não pode ser visto como uma resposta natural ou mesmo como uma decorrência necessária dessa inconformidade. O contexto cultural em que o processo civil está inserido influencia a previsão ou não do direito ao recurso e a maneira como esse pode ser exercido – especialmente no que tange à sua configuração como um direito da parte ou não e no que concerne à sua extensão, isto é, à matéria que nele pode ser debatida.

No processo civil romano clássico, por exemplo, inexistia a *appellatio*⁶. A *sententia* dada pelo *iudex* consubstanciava-se no pronunciamento final do processo. A figura da *appellatio* só nasce com a passagem do período formulário ao período da *cognitio extra ordinem*, vale dizer, com a passagem do período clássico para o pós-clássico⁷, devido à assimetria do processo ocorrida por força da centralização do poder nas mãos do Imperador⁸.

É possível também perceber o ponto a partir da comparação entre as tradições jurídicas: de um lado, na história da família romano-canônica, o direito ao recurso sempre foi encarado como um direito da parte e como elemento fundamental à boa administração da justiça (o duplo grau de jurisdição – conceituado como direito à revisão *in totum* da sentença de primeiro grau – foi

percebido em regra como garantia de boa justiça); de outro, ao longo do desenvolvimento do *Common Law*, o direito ao *appeal* foi visto como algo raro, condicionado à expressa autorização judicial (*leave to appeal*), e normalmente ligado somente à revisão de questões de direito pelo órgão recursal, deixando-se ao primeiro grau de jurisdição, a princípio, a soberania no que tange à apreciação da prova⁹.

Isso dizer que a existência ou não do direito ao recurso, a sua configuração como um direito da parte, a sua extensão e mesmo a quantidade de recursos cabíveis são questões que não podem ser analisadas de forma dissociada da cultura em que se aloca determinado sistema processual civil, assim como dos objetivos por ele visados. A tutela dos direitos em sua dupla dimensão, ligada ao caso concreto e à unidade da ordem jurídica, a minimização dos erros judiciais e a duração razoável do processo combinam-se em um mosaico que muitas vezes chega a transparecer duas imagens bem diferentes e de algum modo extremadas: na expressão da doutrina, um “*anti-appeal*” e um “*pro-appeal fetishism*”¹⁰, nada obstante as conhecidas zonas de intersecção que vêm se formando com a aproximação dos dois grandes modelos de apelação das tradições romano-canônica e de *Common Law*, cujo exemplo mais eloquente é a *Berufung* alemã depois da Reforma de 2001¹¹.

Daí que é imprescindível afastar qualquer ideia de que a contingência de todos estarmos submetidos à falibilidade da condição humana por si só justifica a existência do direito ao recurso e a revisão irrestrita e constante das decisões judiciais por todas as instâncias do Poder Judiciário. A necessidade de diferenciar funcionalmente os órgãos jurisdicionais em uma ordem hierarquizada e o direito fundamental ao processo com duração razoável fornecem as bases constitucionais para uma adequada compreensão do sistema recursal brasileiro. É com base nesses dados, como veremos, que é possível classificar de forma apropriada os recursos e procurar reconduzi-los às respectivas *finalidades institucionais* de cada um dos tribunais aos quais ligados.

Ao lado dos recursos, costuma-se aludir a outros meios de impugnação às decisões judiciais. As demais formas de impugnação de decisão judicial que não se encaixam na definição de recurso são comumente chamadas de *sucedâneos recursais*. Assim, não são considerados recursos, mas sucedâneos recursais, a remessa necessária, a correição parcial, as ações autônomas de impugnação de decisões judiciais (por exemplo, mandado de segurança, reclamação, ação rescisória) e os incidentes processuais (por exemplo, incidente de uniformização de jurisprudência, incidente de inconstitucionalidade)¹².

2. Classificação dos Recursos. Os recursos podem ser classificados basicamente a partir de três critérios distintos: i) finalidade; ii) abrangência; e iii) autonomia¹³.

A classificação mais importante é aquela que diz respeito à *finalidade* do recurso – visto na perspectiva do nosso *sistema recursal*. É nesse critério que aparece a distinção entre recursos ordinários e recursos extraordinários¹⁴: os *recursos ordinários* visam à *justiça da decisão* e estão direcionados à interpretação e à aplicação do direito no caso concreto, ao passo que os *recursos extraordinários* visam à *unidade do direito* e estão vocacionados à interpretação do direito *a partir do caso concreto*.

Essas diferentes funções determinam abrangências distintas do ponto de vista da *matéria* que pode ser tratada nos recursos ordinários e nos recursos extraordinários: enquanto nos primeiros, a *causa* pode ser conhecida *em todos os seus aspectos*, nos segundos é *vedada a reapreciação da prova*¹⁵. Em todas as instâncias, dada a ontológica incindibilidade entre o fato e a norma, os fatos podem e devem ser levados em consideração no momento dos julgamentos: do contrário, aliás, seria impossível trabalhar com um sistema de precedentes obrigatórios e de jurisprudência vinculante (art. 927, CPC/2015), cujo pressuposto é a identidade ou similaridade fática para aplicação ou rejeição da norma judicial. O que se veda nas instâncias extraordinárias é, tão somente, a reapreciação da prova.

São recursos ordinários a apelação (arts. 1.009 a 1.014, CPC/2015) e o agravo de instrumento (arts. 1.015 a 1.020, CPC/2015), ao passo que são recursos extraordinários o recurso extraordinário, o recurso especial (arts. 1.029 a 1.041, CPC/2015), o agravo em recurso extraordinário ou em

recurso especial (art. 1.042, CPC/2015) e os embargos de divergência (arts. 1.043 e 1.044, CPC/2015). O agravo interno (art. 1.021, CPC/2015) e os embargos declaratórios (arts. 1.022 a 1.026, CPC/2015) são recursos que *ganham a função dos recursos a que ligados*: assim, poderão desempenhar a função de recursos ordinários ou recursos extraordinários, conforme interpostos de decisões a respeito de uns ou de outros.

Como a decisão pode ser impugnada no todo ou em parte (art. 1.002, CPC/2015), os recursos podem ser *totais* ou *parciais*. Os recursos totais abrangem toda a decisão recorrida, ao passo que os parciais se limitam a atacar apenas capítulos ou parcelas da decisão. São respostas recursais à impugnabilidade parcial das decisões os arts. 1.013, § 1.º, e 1.034, parágrafo único, CPC/2015: embora concernentes respectivamente à apelação e aos recursos extraordinário e especial, todo e qualquer recurso parcial tem a sua devolutividade vinculada apenas à parcela da decisão recorrida.

A distinção entre recursos totais e parciais ganharia em importância se o direito brasileiro tivesse adotado a tese do trânsito em julgado por capítulos – também chamado de trânsito em julgado progressivo ou fatiado¹⁶. Isso porque, a partir daí se poderia pensar em diferentes termos iniciais para a contagem do prazo para a propositura de ação rescisória. Nada obstante, na esteira da orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 401¹⁷), o novo Código expressamente refere que o trânsito em julgado ocorre apenas com a “última decisão proferida no processo” (art. 975, CPC/2015).

Do ponto de vista da autonomia, por fim, o recurso pode ser *autônomo* ou *adesivo* (art. 997, CPC/2015)¹⁸. Em certos casos, admite-se que, mesmo depois de findo o prazo para a interposição de recurso, possa a parte (e somente ela, não valendo essa hipótese nem para o Ministério Público, nem para o terceiro prejudicado) beneficiar-se de recurso interposto por seu adversário, contrapondo-se a ele a favor de seu próprio interesse. *É o que se chama de recurso adesivo*.

3. Normas Fundamentais. A dogmática tradicional do processo civil costuma caracterizar os princípios como os fundamentos normativos de outras regras, como as linhas fundamentais da matéria ou ainda como diretrizes para interpretação e aplicação do direito. Nesse sentido, os princípios são normalmente associados aos elementos que outorgam coerência às regras: daí a razão pela qual a doutrina alude aos princípios como garantia de sistematicidade do direito¹⁹.

Nada obstante, essa é apenas uma maneira de conceituar os *princípios com um sentido fraco* – não propriamente como normas, mas como fundamentos normativos. Esse modo de compreendê-los, porém, hoje integra apenas um *capítulo da história* do pensamento jurídico, na medida em que superado a favor de uma *compreensão forte dos princípios* – vistos aí como normas que outorgam finalidades que devem ser promovidas de maneira gradual²⁰.

Nada obstante, a doutrina permanece falando em princípios em um sentido fraco – e é justamente partindo dessa compreensão do tema que costuma arrolar as normas fundamentais dos recursos: daí a razão pela qual ainda fala em *princípios recursais* para tratar de normas que, analisadas sob um ponto de vista forte, devem ser caracterizadas como *regras* ou como *postulados normativos*. Para fugir a um uso impreciso do termo princípio, optamos por caracterizar essas normas simplesmente como *normas fundamentais*. Porém, dado o amplo emprego do termo, por vezes aludimos igualmente a princípios recursais com o fim de facilitação da comunicação.

Sendo parte do processo civil, os recursos são obviamente regidos pelos mesmos princípios que os regem como um todo. É fácil percebê-lo, porque, por exemplo, o *direito ao contraditório* (arts. 5.º, inciso LV, CF/1988, e 7.º, 9.º e 10, CPC/2015) e o *dever de fundamentação analítica das decisões judiciais* (arts. 10, 11 e 489, § 1.º, inciso IV, CPC/2015) obviamente se aplicam integralmente ao direito recursal. O mesmo vale para o *dever de colaboração judicial* (art. 6.º, CPC/2015): não por acaso, vários dispositivos do novo Código referem o dever de o órgão recursal primeiro *prevenir* a parte a respeito de problemas formais com o recurso, viabilizando a sanção de eventual vício, para tão somente depois declará-lo, em sendo o caso, inadmissível (por todos, confira-se o art. 932, parágrafo único, CPC/2015)²¹.

Existem, porém, determinados princípios que são específicos dos recursos: i) duplo grau de jurisdição; ii) taxatividade; iii) unirrrecorribilidade; iv) fungibilidade; v) proibição da *reformatio in pejus*; e vi) colegialidade. É importante analisarmos mais de perto essas normas fundamentais do direito recursal.

3.1. Duplo grau de jurisdição. O direito ao duplo grau de jurisdição decorre da previsão inespecífica de competência recursal para as Cortes de Justiça (Tribunais Regionais Federais e Tribunais de Justiça) pela Constituição. No entanto, não se trata de um direito fundamental: o legislador infraconstitucional pode dispor a respeito da sua conformação²². Em outras palavras, o direito ao duplo grau de jurisdição no processo civil não está inafastavelmente garantido pela Constituição.

Ter direito ao duplo grau de jurisdição significa ter direito a um duplo juízo a respeito de determinada questão submetida ao Poder Judiciário. O legislador infraconstitucional, porém, não se encontra obrigado a observar essa regra em todos os casos, tanto é assim que existem inúmeras exceções na lei processual. Assim é que algumas decisões, proferidas em determinadas ações, apenas contemplam excepcionalmente a possibilidade recursal, diante da existência de algum pressuposto específico, como acontece com as sentenças proferidas em execuções fiscais de valor igual ou menor a cinquenta ORTN²³ (art. 34, Lei 6.830/1980), que somente admitem uma espécie de pedido de reconsideração ao juiz prolator da decisão (chamado pela lei de “embargos infringentes”) e embargos de declaração, também para o mesmo magistrado, além de – em caso de violação à regra constitucional – recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal.²⁴ Seria também possível invocar a hipótese de decisões proferidas em ação de competência originária do Supremo Tribunal Federal (art. 102, I, da CF/1988), em que, da decisão dessa Corte, somente em casos excepcionalíssimos (no julgamento de ação rescisória e representação de inconstitucionalidade, em que a decisão se dê por maioria de votos) caberá recurso, dirigido para o próprio tribunal (embargos infringentes, conforme estabelece o art. 333, III e IV, do RISTF, ou eventualmente embargos de declaração).

De outra parte, a situação inversa – em que o tribunal (juízo ad quem) vem a conhecer de matérias não examinadas expressamente pelo juízo recorrido (*a quo*) – merece maior atenção, pois os casos em que isso poderia acontecer tendem a ser mais frequentes, exigindo da lei tratamento mais minucioso. A princípio, o tribunal (ad quem) não pode conhecer de matérias não abordadas pelo juiz recorrido (*a quo*), sob pena de supressão de instância.²⁵ Os temas, portanto, não expressamente abordados na instância que proferiu a decisão recorrida, não podem, como regra geral, ser examinados pelo tribunal. Isso porque, ainda que não se admita o duplo grau de jurisdição como direito fundamental, oferecer apenas diante do tribunal questões que deveriam, em face das regras ordinárias de competência, ser deduzidas perante o juiz de primeiro grau afrontaria o princípio do juiz natural.

Evidentemente, essa ideia sofre inúmeras restrições, determinadas seja pela própria natureza da decisão, seja por regras específicas que disciplinam o tema.²⁶ Assim é que prevê o art. 1.013, CPC/2015, relativamente à apelação, que serão “objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado”, acrescentando ainda que, “quando o pedido ou a defesa tiver mais de um fundamento e o juiz acolher apenas um deles, a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento dos demais” (§§ 1.º e 2.º). Vale dizer que, se o réu, ao defender-se de uma ação de cobrança, alegar nulidade do contrato, prescrição da dívida e compensação, ainda que o juiz de primeiro grau rejeite a demanda, acolhendo apenas um dos fundamentos (por suposição, a nulidade do contrato), sem examinar os demais, todos os outros poderão também ser objeto de apreciação pelo tribunal, ainda que, nesse caso, esse seja o primeiro juízo da matéria. O mesmo se diria para temas que competissem ao juiz conhecer em qualquer tempo ou grau de jurisdição, porque matéria de ordem pública: ainda que não se verifique, inicialmente, a manifestação expressa do juízo a quo, o tribunal pode conhecer diretamente da questão, sem que isso importe em conduta proibida. Ainda, o § 3.º desse mesmo dispositivo permite que o tribunal, se a causa estiver em condições de imediato julgamento, decida desde logo o mérito, quando reformar sentença terminativa, decretar a nulidade da sentença pela ausência de congruência, constatar

omissão no exame de um dos pedidos, hipótese em que poderá julgá-lo, decretar a nulidade da sentença por falta de fundamentação e quando reformar a sentença que reconheceu a prescrição ou a decadência, adentrando nas demais questões de mérito (art. 1.013, § 4.º, CPC/2015). Essas são algumas exceções ao duplo grau de jurisdição.

3.2. Taxatividade. Por força do art. 22, inciso I, CF/1988, só o legislador federal pode prever recursos, porque se trata de matéria processual. Isso quer dizer que somente a lei federal pode criar recursos, sendo vedada a qualquer outra esfera legislativa e administrativa, conceber figuras recursais. São recursos apenas as figuras previstas *taxativamente* pelo legislador federal.

Os recursos no sistema do novo Código estão previstos no art. 994 e são os seguintes: I – apelação; II – agravo de instrumento; III – agravo interno; IV – embargos de declaração; V – recurso ordinário; VI – recurso especial; VII – recurso extraordinário; VIII – agravo em recurso especial ou extraordinário; e IX – embargos de divergência. Como se vê, o novo Código suprimiu a figura dos embargos infringentes do sistema recursal do Código. Em seu lugar, porém, introduziu *técnica de ampliação de julgamento* em caso de decisão por maioria contrária à decisão de mérito do juízo de primeiro grau (art. 942, CPC/2015) – tem já tratado oportunamente.

Além desses recursos diretamente pelo Código, outros também estão ao abrigo da regra da taxatividade, porque previstos em lei federal. É o caso dos embargos infringentes (disciplinados pelo art. 34 da Lei 6.830/1980); do recurso inominado (arts. 41 a 43, Lei 9.099/1995); do agravo inominado, disciplinado, entre outros, pelo art. 4.º, Lei 8.437/1992.

3.3. Unirrecorribilidade. Ao estipular a lei processual quais são os recursos cabíveis, evidentemente há de indicar para cada um dos recursos uma função determinada e uma hipótese específica de cabimento. Dessa forma, a regra da unirrecorribilidade (ou também chamada de unicidade) indica que, para cada espécie de ato judicial a ser recorrido, deve ser cabível um único recurso.

É verdade que tais casos permitem a interposição, contra uma mesma decisão judicial, de mais de uma espécie recursal. Todavia, não se deve esquecer que cada um dos recursos cabíveis contra tais decisões tem função específica, que não se confunde com a finalidade prevista para a outra espécie recursal. Assim, contra determinado ato judicial e para certa finalidade específica – não abrangida pela finalidade de outro meio recursal – deve ser cabível um único recurso.

De todo modo, mesmo pensado dessa forma, a presente regra encontra exceções claras no direito brasileiro. Costuma-se apontar exceções a esse princípio, especialmente referentes aos embargos de declaração e à possibilidade de interposição concomitante de recurso extraordinário e de recurso especial (art. 1.031, CPC/2015). Especificamente no caso dos embargos de declaração fundados em omissão, vê-se a tendência da jurisprudência em entender que esse recurso é opcional, podendo a parte atacar este defeito do ato diretamente com o outro recurso eventualmente admitido (v.g., a apelação). Há, portanto, neste caso, previsão, para uma mesma função, de dois recursos admitidos contra o mesmo ato: os embargos de declaração e o outro recurso admitido pela legislação (o agravo de instrumento, a apelação etc.). Ademais, o direito atual resolveu expressamente *vexata quaestio* existente no direito anterior – e que era normalmente apontada como uma exceção à regra da unirrecorribilidade: da decisão que antecipa a tutela jurisdicional na sentença cabe tão somente recurso de apelação (art. 1.013, § 5.º, CPC/2015).

3.4. Fungibilidade. Se, como visto, somente deve ser cabível um único recurso contra cada espécie de decisão judicial, a escolha desse meio recursal assume importância ímpar. A utilização do recurso equivocado, a princípio, leva à inadmissibilidade recursal, sob pena de violar-se a taxatividade enumerada em lei, a regra da unirrecorribilidade e, ainda, as regras específicas que disciplinam os recursos – ressalvada, é claro, a possibilidade de correção do vício que deve ser viabilizada pelo relator em nome do princípio da colaboração e do dever de prevenção daí decorrente (arts. 6.º, 317 e 932, parágrafo único, CPC/2015).

Na normalidade dos casos, o erro na interposição do recurso adequado acarretará seu *não*

conhecimento, tendo em conta seu *não cabimento*, acaso não sanado o vício. Porém, situações podem ocorrer em que não se tenha *certeza* sobre qual recurso é adequado para enfrentar certo ato judicial. Muito embora sejam claras as figuras recursais e suas respectivas hipóteses de cabimento, algumas *dúvidas sérias* podem existir e para tais casos, diante da impossibilidade de se criar um sistema imune à dúvida, o escopo de tutela dos direitos que domina o processo recomenda maior maleabilidade no trato dos recursos.

A regra da fungibilidade presta-se exatamente para não prejudicar a parte que, diante de *dúvida séria*, derivada da existência de *discussões jurisprudenciais e doutrinárias* a respeito do cabimento de determinado recurso, interpõe recurso que pode não ser considerado cabível²⁷. Nesses casos, autoriza-se que o recurso incorretamente interposto seja tomado como o adequado, desde que preenchidas determinadas circunstâncias.

O Código de Processo Civil de 1939 era expresso em admitir esse princípio – especialmente diante da maneira assistemática com que tratava o tema dos recursos – prevendo, em seu art. 810, que, “salvo hipótese de má-fé ou erro grosseiro, a parte não será prejudicada pela interposição de um recurso por outro, devendo os autos ser enviados à Câmara, ou Turma, a que competir o julgamento”. O Código de Processo Civil de 1973 não previa regra semelhante. O novo Código seguiu a sua linha. Todavia, tem-se como parte do sistema, em especial dos princípios que o informam (notadamente, da duração razoável do processo, da colaboração, da instrumentalidade e da segurança jurídica), razão pela qual está positivado entre nós o uso do princípio da fungibilidade.

A fim de que possa ter aplicação o princípio da fungibilidade, é necessária a reunião de alguns critérios, tendentes a demonstrar a ausência de má-fé e de erro grosseiro. Nesse sentido é que se exige, para o conhecimento do recurso equivocado pelo correto: i) presença de dúvida séria a respeito do recurso cabível; e ii) inexistência de erro grosseiro.

Na medida em que a legitimação do princípio da fungibilidade reside precisamente no aproveitamento do ato processual praticado, ainda que equivocadamente e fora dos critérios legais, em situações em que seria excessivo exigir o acerto em sua forma específica. A fungibilidade não se destina a legitimar o equívoco crasso, ou para cancelar o profissional inábil – serve para aproveitar o ato que, diante das circunstâncias do caso concreto, decorreu de *dúvida séria*, oriunda do *estado da jurisprudência e da doutrina* a respeito de determinado caso. Note-se que não é qualquer dúvida que autoriza a aplicação da regra da fungibilidade: *a dúvida não pode ter origem na insegurança pessoal do profissional que deve interpor o recurso ou mesmo na sua falta de preparo intelectual, mas no próprio sistema recursal*. Assim, essa dúvida pode derivar: i) da lei processual, que denomina as sentenças de decisões interlocutórias ou vice-versa, induzindo a parte a errar na escolha do recurso idôneo; ii) da discussão doutrinária ou jurisprudencial a respeito da natureza jurídica de certo ato processual, como acontece com a decisão que, antes da sentença final da causa principal, decide ação declaratória incidental; e iii) do fato de ser proferido um ato judicial por outro, chamando-se e dando-se forma de sentença a uma decisão interlocutória ou vice-versa.

Outro dos pressupostos para a utilização do princípio da fungibilidade é a *ausência de erro grosseiro* na interposição do recurso. Não se pode aplicar o princípio em exame quando o recurso interposto *evidentemente* não tiver cabimento. Assim, embora em certas circunstâncias seja possível admitir a dúvida objetiva entre algumas espécies recursais (como o agravo e a apelação), não se pode admitir a incidência da fungibilidade, se o interessado se vale de recurso completamente incabível na espécie. Como já dito, o princípio da fungibilidade não se presta a legitimar a atividade do advogado mal formado, incapaz de atuar com os mecanismos processuais adequados. Serve para tornar o sistema operacional, mediante a admissão do recurso inadequado, *desde que a falta seja fundada em dúvida objetiva e não tenha origem em erro grosseiro*.

Ao tempo do Código de 1973, a jurisprudência nacional inclinou em exigir que o prazo em que foi interposto o recurso fosse o correto para a interposição do recurso adequado. É dizer que, por hipótese, se o recurso adequado no caso tinha prazo de dez dias para interposição, o recurso erroneamente oferecido somente poderia ser conhecido, por meio da aplicação do princípio da

fungibilidade, se fosse oferecido também no prazo de dez dias²⁸.

Já ao tempo do Código Buzaid esse último requisito, conforme bem observava a doutrina, parecia mal colocado. *Ora, se era razoável que, em face do caso concreto, o interessado utilizasse o recurso errado imaginando fosse o correto, exigir a adequação do prazo para o recurso correto não tinha sentido algum. Com efeito, se a dúvida séria era – como continua sendo – requisito para a aplicação da fungibilidade, não há como se pensar que o recorrente poderia interpor o recurso errado, porém no prazo do correto.*

Diante do novo Código, essa discussão tende a perder em importância, tendo em conta que o art. 1.003, § 5.º, CPC/2015, unificou os prazos recursais. Assim, com exceção dos embargos declaratórios, todos os demais recursos têm prazo de quinze dias – o que obviamente faz com que perca o sentido a discussão a respeito da subsistência desse requisito para aplicação da regra da fungibilidade.

A aplicação do princípio da fungibilidade suscita alguns problemas em matéria de procedimento, especialmente em se tratando de dúvida envolvendo a interposição dos recursos de apelação e de agravo de instrumento. Como se verá adiante, o procedimento previsto para esses recursos é distinto, desde a fase inicial, de oferecimento da impugnação – o agravo de instrumento é interposto diretamente no tribunal (art. 1.016, CPC/2015) e é acompanhado de cópias que permitem a contextualização imediata da controvérsia pelo tribunal, já a apelação é oferecida no juízo de primeiro grau (art. 1.010, CPC/2015), sem necessidade de formação de instrumento, sendo encaminhada, depois do contraditório, ao tribunal. A aplicação da fungibilidade nesses casos pode ser insuficiente, na medida em que a interposição da apelação, quando for cabível o agravo de instrumento, pode gerar também seu não conhecimento em face da desobediência de regras específicas impostas para regular a apresentação do agravo de instrumento (como é o caso da formação do instrumento, art. 1.017, CPC/2015). Nesses casos, como proceder?

Ao que parece, a solução mais adequada para tais situações é, ao aplicar o princípio da fungibilidade, determinar à parte recorrente a adequação da petição e da tramitação do recurso aos ditames corretos para o procedimento previsto para o recurso efetivamente cabível. Trata-se de solução decorrente do *princípio da colaboração judicial*, especialmente dos *deveres de prevenção e de auxílio* do juiz para com as partes. Intimado o recorrente a completar a petição (pela juntada, por exemplo, dos documentos necessários, art. 1.017, § 3.º, CPC/2015) ou a conformar o procedimento, terá então o recurso seguimento regular, na forma prevista para o recurso realmente adequado.

Em suma: tendo em conta o caráter instrumental do processo, que serve precipuamente para tutela dos direitos, eventuais equívocos na sua condução devem ser sobrelevados, sempre que possível, para que o processo possa alcançar a sua finalidade. Repugna ao Estado Constitucional que o direito material venha a soçobrar em face do uso inadequado do processo. Assim como o “erro de forma do processo” acarreta unicamente a “anulação dos atos que não possam ser aproveitados” (art. 283, CPC/2015), também o erro na interposição de determinado recurso só deve conduzir ao seu não conhecimento acaso não possa de modo algum ser conhecido.

3.5. Proibição da *reformatio in pejus*. Outro princípio importante para o sistema processual brasileiro diz respeito à proibição de que o julgamento do recurso, interposto exclusivamente por um dos sujeitos, venha a tornar sua situação pior do que aquela existente antes da insurgência. Ora, se o recurso é mecanismo previsto para que se possa obter a revisão de decisão judicial em termos mais favoráveis ao recorrente, tanto que legitimado pela sucumbência e pelo interesse em obter provimento mais apropriado (art. 996, CPC/2015), é intuitivo que sua finalidade deve cingir-se a *melhorar* (ou pelo menos manter idêntica) a situação vivida pelo recorrente.

Como remédio *voluntário*, o recurso é interposto no *interesse* do recorrente. Não pode, por isso, a interposição do recurso piorar a condição da parte, trazendo para ela situação mais prejudicial do que aquela existente antes do oferecimento do recurso. Tal é a formulação do princípio em exame, que proíbe a *reformatio in pejus*.

A proibição da *reformatio in pejus* é uma resposta moderna ao princípio antítese que vigorava a respeito da matéria ao longo de todo o direito comum luso-brasileiro: a possibilidade de a apelação beneficiar a qualquer das partes²⁹ – isto é, o princípio do *beneficium commune*. Mais profundamente, a adoção de um ou de outro acentua maior valor ao indivíduo (*reformatio in pejus*) ou à comunidade (*beneficium commune*). O direito brasileiro moderno – isto é, desde o Código Buzaid³⁰ – é expreso na adoção da proibição da *reforma in pejus*.

Não se aplica a ideia de reforma prejudicial quando há recurso interposto por ambos os polos do processo – em que evidentemente o acolhimento de um dos recursos virá em prejuízo da outra parte também recorrente – nem no caso em que o tribunal entenda por alterar a fundamentação da decisão recorrida, mantendo, porém, sua conclusão. Outra exceção diz respeito com as matérias que compete ao juízo conhecer de ofício, em qualquer tempo ou grau de jurisdição (como, por exemplo, aquelas enumeradas no art. 485, § 3.º, CPC/2015). Isso porque o domínio do princípio da proibição da reforma para pior é aquele concernente ao *efeito devolutivo* – que, como veremos, obedece ao *princípio dispositivo* e é formado exclusivamente pela *voluntária impugnação* da parte de determinadas questões. Quando, porém, o tribunal conhece de matéria que poderia *conhecer de ofício*, ele o faz por força do *efeito translativo*, o qual é informado pelo *princípio inquisitório*, a propósito do qual não vige a regra da proibição da reforma para pior. No Código de 2015, ainda, a proibição da reforma para pior encontra exceção no regime das despesas processuais: como é sabido, o art. 85, § 11, admite a majoração de honorários advocatícios no procedimento recursal.

3.6. Colegialidade. Tanto as Cortes de Justiça (Tribunais Regionais Federais e Tribunais de Justiça) como as Cortes de Precedentes (Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça) são compostas de *órgãos colegiados* responsáveis pelo julgamento das causas para as quais a Corte é competente, isto é, são compostas de órgãos julgadores integrados por três ou mais desembargadores ou ministros. Os recursos, como regra, são julgados por órgãos colegiados, o que proporciona tendencialmente um maior debate na formação da decisão.

O diálogo no processo – seja com as partes, seja com entre os próprios julgadores – necessariamente “amplia o quadro de análise, constrange à comparação, atenua o perigo de opiniões preconceituosas e favorece a formação de um juízo mais aberto e ponderado”³¹. Daí a razão pela qual os recursos são regidos pela regra da colegialidade: ressalvadas as exceções legais (art. 932, III, IV e V, CPC/2015), os recursos são decididos por um colegiado (art. 941, CPC/2015).

4. Juízo de Admissibilidade e Juízo de Mérito dos Recursos. Assim como acontece com qualquer espécie de ato ou de procedimento, também o ato recursal se submete a pressupostos específicos, necessários para que se possa examinar posteriormente o mérito do recurso interposto. Chama-se de *juízo de admissibilidade* – que pode levar ao *conhecimento* ou ao *não conhecimento*, à *admissão* ou à *inadmissão* – o *juízo preliminar* a respeito da *existência do direito de recorrer* e da *regularidade do seu exercício*. Apenas depois de admitido – ou conhecido – o recurso é que se poderá indagar a respeito da possibilidade de *provê-lo* ou *desprovê-lo*, isto é, de examiná-lo no mérito, de saber se o recorrente *tem razão ou não naquilo que alega* como motivo para revisão da decisão recorrida. Essa é a razão pela qual é necessário distinguir entre o juízo de admissibilidade e o juízo de mérito dos recursos³².

É possível dividir esses pressupostos em *intrínsecos* e *extrínsecos*, os primeiros atinentes à existência do direito de recorrer e os últimos ao seu exercício.

São *pressupostos intrínsecos* do direito de recorrer: i) cabimento; ii) interesse recursal; iii) legitimidade recursal; iv) inexistência de fato extintivo do direito de recorrer. Especificamente quanto ao recurso extraordinário e ao recurso especial, constituem pressupostos intrínsecos: i) a existência de decisão de única ou última instância e ii) o expreso enfrentamento da causa constitucional ou da causa federal no acórdão recorrido. Ainda, especificamente quanto ao recurso extraordinário, constitui pressuposto intrínseco de admissibilidade a existência de repercussão geral da questão constitucional debatida no recurso extraordinário.

São *pressupostos extrínsecos* do direito de recorrer: i) regularidade formal; ii) tempestividade; iii) preparo; e iv) inexistência de fato impeditivo do direito de recorrer. Especificamente quanto ao

recurso extraordinário e ao recurso especial, constitui requisito extrínseco a realização de um *cotejo analítico* entre os casos e as respectivas decisões.

Os requisitos intrínsecos e extrínsecos gerais serão analisados neste momento. Os requisitos intrínsecos e extrínsecos particulares aos recursos extraordinário e especial serão analisados oportunamente.

Quanto aos requisitos intrínsecos gerais, cumpre observar o que segue.

i) Cabimento: como visto anteriormente, só podem ser considerados recursos aqueles meios de impugnação expressamente arrolados em lei. Ao serem previstas pela lei processual, recebem essas formas de impugnação regime próprio, que determina em quais hipóteses e perante qual espécie de decisão judicial são cabíveis. Portanto, um recurso somente é cabível quando a lei processual indicar-lhe – diante de determinada finalidade específica e certo ato judicial – como o adequado para extravasar a insurgência. O cabimento diz respeito à adequação de determinado meio recursal para promover o ataque de dada decisão judicial.

Aparentemente, a questão do cabimento pode ser facilmente solucionada, bastando avaliar a relação posta na lei a propósito dos recursos. Assim, por exemplo, é taxativo o CPC/2015 em dizer que o recurso *cabível* contra sentenças é a apelação (art. 1.009, CPC/2015) e que o *cabível* contra decisões interlocutórias é o agravo de instrumento (art. 1.015, CPC/2015).

A solução, todavia, não é tão simples como parece. Eventualmente, é necessário conjugar outras regras, ou ainda verificar específico tipo de defeito, para examinar o cabimento de determinado recurso contra certo ato judicial. É o que se vê, por exemplo, na situação presente nos embargos de declaração, já que sua admissão está condicionada à existência, no ato judicial, de omissão, obscuridade, contradição ou sanção de erro material (isto é, inexistências materiais ou erros de cálculo, art. 1.022, CPC/2015).

Enfim, a avaliação do cabimento de certo recurso depende da análise, em abstrato, da previsão de certo recurso como sendo hábil a atacar determinada decisão judicial ou, mais precisamente, o vício apontado na decisão judicial.

ii) Interesse recursal: a fim de que possa o interessado socorrer-se do recurso, é fundamental que possa antever algum interesse na sua utilização, isto é, antever a possibilidade de o seu provimento levar à melhora de sua esfera jurídica. À semelhança do que acontece com o *interesse de agir*, é necessário que o interessado possa vislumbrar alguma *utilidade* na interposição do recurso, utilidade essa que somente possa ser obtida através da via recursal (*necessidade*). A fim de preencher o requisito “utilidade”, será necessário que a parte (ou o terceiro), interessada em recorrer, tenha sofrido algum prejuízo jurídico direto ou indireto em decorrência da decisão judicial ou ao menos que essa não tenha satisfeito plenamente a sua pretensão (uma vez que, sendo vencidos autor e réu, ambos terão interesse em recorrer). Em relação à “necessidade”, essa estará presente se, por outro modo, não for possível resolver a questão, alterando-se ou suplantando-se o prejuízo verificado.

A caracterização do interesse recursal pelo Ministério Público (que também pode ser titular do direito de recorrer, ainda quando atue como *custos legis*) supõe-se existente quando, em seu entendimento, tenha havido ofensa ao direito objetivo, ao interesse público (aí incluídos os interesses sociais e individuais indisponíveis) e ao regime democrático (art. 127, *caput*, da CF/1988).

Costuma-se questionar se o réu tem interesse recursal no caso de *sentença terminativa*, buscando *sentença definitiva* que venha a reconhecer a improcedência do pedido do autor. À luz do novo Código, a resposta tem de ser positiva: isso porque o art. 488, CPC/2015, é claro em afirmar que, “desde que possível, o juiz resolverá o mérito sempre que a decisão for favorável à parte a quem aproveitaria eventual pronunciamento nos termos do art. 485”. Em outras palavras, o novo Código institui direito à pronúncia de mérito ao réu, sempre que for possível ao juiz fazê-lo, em detrimento de soluções meramente processuais. Daí que há interesse recursal do réu em interpor

apelação para mostrar que, nada obstante a pronúncia terminativa, o juiz deveria ter decidido no mérito em sentido favorável à sua posição.

iii) Legitimidade recursal: nos termos do que prevê o novo Código em seu artigo 996, *caput*, “o recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica”. A caracterização do terceiro que efetivamente é prejudicado é dada pelo parágrafo único do art. 996, que refere que “cumprido ao terceiro demonstrar a possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atingir direito de que se afirme titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual”³³.

No que diz respeito ao Ministério Público, tem ele legitimidade para recorrer tanto no processo em que atua como parte, como naquele em que exerce a função de fiscal da ordem jurídica (arts. 177 e 178, CPC/2015).³⁴

Cumprido ressaltar que esses são os sujeitos legitimados a *atuar no recurso de forma principal*. Todavia, é possível que outros agentes participem, no curso da tramitação de certos recursos, ao menos de forma limitada. Assim ocorre com os chamados *amici curiae* – terceiros que participam no intuito de colaborar com o Poder Judiciário para lograr decisão mais perfeita (art. 138, CPC/2015) – ou ainda com terceiros que possam ser atingidos reflexamente pelos efeitos de Súmulas Vinculantes³⁵ ou no exame de repercussão geral em certos recursos.³⁶

iv) *Inexistência de fato extintivo do direito de recorrer*: certas circunstâncias, quando presentes no processo, acabam alterando os direitos processuais conferidos aos sujeitos do processo. Assim também pode acontecer com o direito de recorrer, que pode ser objeto de disposição de vontade capaz de extingui-lo. Tem-se nesse ponto a figura da *renúncia* ao direito de recorrer como principal instituto. A parte prejudicada por certa decisão judicial pode renunciar ao direito de interpor recurso, acelerando com isso o procedimento. Nesse caso, uma vez praticado o ato de disposição, opera-se preclusão da possibilidade de interpor recurso, não mais existindo o direito de recorrer.

Conforme prevê o art. 999, CPC/2015, “a renúncia ao direito de recorrer independe da aceitação da outra parte”, indicando que esse ato de disposição é potestativo, produzindo efeitos ainda que disso discorde a parte adversária. Note-se, todavia, que, em caso de *litisconsórcio unitário*, essa renúncia somente operará efeitos se corroborada pelos demais litisconsortes (art. 117, CPC/2015).

Também se equipara à causa extintiva do direito de recorrer a *aceitação*, expressa ou tácita, da decisão recorrida (art. 1.000, CPC/2015). Na aceitação expressa, tem-se manifestação específica da parte, concordando com os termos da decisão havida. Já a aceitação tácita é conduta indireta, em que a parte não manifesta expressamente seu desinteresse em utilizar a via recursal, mas se conforma por meio de atos que demonstram inequivocamente a concordância com a decisão, que poderia em tese ser recorrida (como o cumprimento da sentença sem qualquer ressalva – o Código é expresso, a propósito, em não considerar o depósito do valor da condenação em execução provisória como sua aceitação tácita, art. 520, § 3.º). Assim como ocorrer com a renúncia, havendo aceitação por apenas um dos litisconsortes sob o regime da unitariedade, a aceitação é ineficaz em relação ao todo. Vale dizer: a aceitação em caso de *litisconsórcio unitário* também só é eficaz se manifestada por todos os litisconsortes (art. 117, CPC/2015).

Quanto aos requisitos extrínsecos:

i) Regularidade formal: o exercício do direito de recorrer submete-se aos ditames legais para a interposição e tramitação do recurso. Não obstante possa o interessado ter direito a recorrer, o recurso somente será admissível se o procedimento utilizado se pautar estritamente pelos critérios descritos em lei. Assim, por exemplo, os recursos devem ser interpostos por escrito, a parte tem o ônus de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida e a interposição do agravo de instrumento exige a instrução da peça inicial com certos documentos exigidos em lei.

ii) Tempestividade: o prazo para interposição do recurso deve ser compatível com aquele previsto em lei. Como se sabe, o processo deve sempre significar marcha para frente, razão pela

qual os prazos fixados são em regra próprios, pelo que “decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial” (art. 223, *caput*, CPC/2015). O recurso, portanto, deve ser interposto no prazo previsto para tanto, sob pena de preclusão temporal – matéria que pode ser conhecida de ofício e a qualquer tempo, porque de ordem pública³⁷.

Vale lembrar que esse prazo se submete a regras especiais, decorrentes de certas circunstâncias subjetivas e objetivas específicas. Assim, havendo no processo litisconsortes com *advogados distintos e de escritórios de advocacia distintos*, os prazos para recurso são contados em dobro nos processos físicos (art. 229, § 2.º, CPC/2015)³⁸.

Assim como acontece com qualquer tipo de prazo, os recursais podem sujeitar-se a causas de suspensão e de interrupção. Ocorre suspensão do prazo para a interposição do recurso, por exemplo, diante de obstáculo criado pela parte contrária (art. 221, CPC/2015). Nesse caso, finda a causa da suspensão, o prazo para a prática do ato será devolvido ao interessado no quanto faltava para seu término. Já no caso de interrupção, tem-se causa que, uma vez finda, devolve ao interessado o *prazo integral* para a prática do ato processual. São exemplos de causas de interrupção, a interposição de embargos de declaração (art. 1.026, CPC/2015) e a superveniência de falecimento da parte ou de seu advogado (nos termos do arts. 110 e 313, CPC/2015).

iii) *Preparo*: o procedimento recursal exige, tanto como qualquer outro ato processual, certos gastos do Estado que devem, a princípio, ser suportados pelo interessado. Assim, a interposição de recurso exige que o interessado deposite os valores necessários à sua tramitação, aí incluída a importância destinada a promover a remessa e o posterior retorno do recurso (ou mesmo dos autos) ao tribunal. Conforme estabelece o art. 1.007, CPC/2015, “no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção”.

Note-se que a lei exige a *prova do preparo* do recurso no ato de sua interposição. A *ausência de preparo* ou a sua *insuficiência*, porém, só *leva ao não conhecimento do recurso* se a parte, devidamente intimada na pessoa de seu advogado, *não realizar o recolhimento em dobro do preparo inexistente ou não complementar o preparo insuficiente no prazo adequado* (art. 1.007, §§ 2.º e 4.º, CPC/2015). Trata-se de dever de prevenção, que é inerente ao dever de colaboração judicial (art. 6.º, CPC/2015). Vale dizer: é vedado ao órgão recursal, seja qual for a instância judiciária, não conhecer de recurso por falta de preparo ou por preparo insuficiente sem previamente indicar ao recorrente a necessidade de sua realização ou complementação.

No entanto, uma vez prevenido o recorrente da ausência do preparo ou de sua insuficiência, não há direito à nova oportunidade de preparo, ainda que para complementar o preparo antes inexistente realizado de forma insuficiente (art. 1.007, § 5.º, CPC/2015: “é vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4.º”). O equívoco no preenchimento da guia de custas, ademais, não implicará aplicação da pena de deserção, cabendo ao relator, na hipótese de dúvida quanto ao recolhimento, intimar o recorrente para sanar o vício no prazo de cinco dias (art. 1.007, § 7.º, CPC/2015). Por fim, provando o recorrente justo impedimento, o relator relevará a pena de deserção, por decisão irrecorrível, fixando-lhe prazo de cinco dias para efetuar o preparo (art. 1.007, § 6.º, CPC/2015).

Nem todos os recorrentes se submetem à regra do preparo. Conforme assevera a regra do art. 1.007, § 1.º, CPC/2015, “são dispensados de preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, os recursos interpostos pelo Ministério Público, pela União, pelo Distrito Federal, pelos Estados, pelos Municípios, e respectivas autarquias, e pelos que gozam de isenção legal”. Ainda, os embargos de declaração não se submetem a preparo (art. 1.023, CPC/2015).

iv) *Inexistência de fato impeditivo do direito de recorrer*: o interessado pode ter o direito de recorrer, mas esse direito pode estar inibido por alguma causa externa. São duas basicamente as situações que geram essa consequência no direito brasileiro: a desistência e o não pagamento de algumas multas previstas pelo Código de Processo Civil.

A desistência assemelha-se à renúncia, tendo como diferença básica em relação a essa última o fato de que se opera posteriormente ao oferecimento do recurso. Interposto o recurso, mas não tendo mais interesse em prosseguir na apreciação da insurgência, pode o recorrente desistir do recurso já interposto, mesmo sem a anuência da parte contrária ou de seus litisconsortes (ressalvada a hipótese de litisconsórcio unitário, art. 117, CPC/2015), conforme refere expressamente o art. 998, CPC/2015.

Ocorrendo a desistência do recurso, impede-se o *julgamento do recurso*, com o que a parte não poderá ser afetada por qualquer decisão tomada a partir das questões nele plantadas. Nada obstante, a desistência do recurso não impede a análise de questão cuja repercussão geral já tenha sido reconhecida e daquela que constitua objeto de julgamento de recursos extraordinário ou especiais repetitivos (art. 998, parágrafo único, CPC/2015). Analogamente, não impede o julgamento de questão em recurso extraordinário ou em recurso especial em que o relator do recurso tenha vislumbrado a possibilidade de, a partir de seu julgamento, formar-se um precedente³⁹.

Outro fator inibidor do exercício do direito de recorrer é o não adimplemento de multas fixadas em lei, que impedem a interposição de novos recursos. Tal é o que ocorre com as previsões concernentes ao agravo interno (art. 1.021, § 5.º, CPC/2015) e aos embargos declaratórios (art. 1.026, § 3.º, CPC/2015). Embora se possa duvidar da constitucionalidade desses dispositivos, enquanto não houver manifestação da instância própria a respeito, a parte condenada a pagar essas multas (pela interposição de recurso considerado protelatório) não pode utilizar-se de outros meios recursais enquanto não depositar os valores devidos.

Observe-se que os pressupostos recursais constituem a matéria preliminar do procedimento recursal. Vale dizer que, se não atendido quaisquer destes pressupostos, fica vedado ao tribunal conhecer do mérito do recurso. Atendidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, deve o tribunal conhecer do recurso para, a partir daí, concluir se o recorrente tem ou não razão naquilo que alega. Isto é, deve analisar se o recurso deve ser provido ou desprovido.

É importante perceber, porém, que a inadmissibilidade recursal deve ser vista como a *ultima ratio* dentro do sistema do Código de 2015⁴⁰. Como uma das normas fundamentais do processo civil é a colaboração, que implica dever de prevenção judicial e primazia do exame do mérito em detrimento de pronúncias meramente processuais sobre o caso, *antes de inadmitir o recurso deve o relator viabilizar que a parte corrija qualquer defeito sanável capaz de levar ao não conhecimento do recurso* – mesmo que envolva, por exemplo, *complementação das razões* expostas de forma vaga ou imprecisa pela parte⁴¹. Esse é conteúdo normativo mínimo que pode ser adscrito aos arts. 6.º, 317 e 932, parágrafo único, CPC/2015.

No mais, ao contrário do que ocorria em relação ao direito anterior, em que a maioria dos recursos tinha um juízo de admissibilidade bipartido, no novo Código o juízo de admissibilidade dos recursos deve ser feito *exclusivamente pelo órgão competente em tese para o seu julgamento*. Ainda que o recurso tenha sido interposto perante a instância de origem, o novo Código é expresso em determinar a sua remessa, em sendo o caso, para a instância recursal independentemente de juízo de admissibilidade (arts. 1.010 e 1.011, CPC/2015). A exceção à regra está no juízo de admissibilidade do recurso extraordinário e do recurso especial (art. 1.030, CPC/2015), que continua sendo tarefa compartilhada entre o tribunal *a quo* e o tribunal *ad quem*. Especificamente sobre o problema do juízo de admissibilidade dos recursos repetitivos, remete-se o leitor aos comentários ao art. 1.042, CPC/2015.

5. Efeitos dos Recursos. A interposição de recursos opera no plano processual inúmeros efeitos em maior ou menor intensidade. São basicamente seis os efeitos dos recursos: i) devolutivo; ii) translativo; iii) suspensivo; iv) expansivo; v) substitutivo; e vi) obstativo. Por vezes, esses efeitos são sentidos logo na interposição do recurso (como o efeito obstativo), eventualmente em momento anterior a esse (como o efeito suspensivo) e por outras vezes somente com o julgamento do mérito da impugnação (como os efeitos devolutivo, translativo, expansivo e substitutivo).

5.1. Devolutivo. A cognição do órgão recursal é formada por *questões impugnadas* pela parte e por questões que a lei, *independentemente de impugnação*, permite ao órgão competente conhecer por força da interposição do recurso. Diz-se que as primeiras questões são *devolvidas* ao órgão recursal, ao passo que as segundas são *transladadas*. A junção das questões devolvidas e das questões transladadas compõe o quadro da matéria que pode ser conhecida pelo órgão recursal.

Efeito dos mais característicos do sistema recursal, o efeito devolutivo é o que atribui ao juízo recursal o exame da matéria analisada na decisão recorrida e *expressamente impugnada* pelo recorrido. Por depender de expressa impugnação da parte, diz-se que constitui uma manifestação do *princípio da demanda* no âmbito dos recursos.

Recorde-se que o direito processual pátrio adota, como direito fundamental integral do direito ao processo justo, o direito ao juiz natural, razão pela qual, uma vez determinado o juiz competente para apreciar certa controvérsia, não é possível que dele se retire essa atribuição. Portanto, para que o tribunal possa ter acesso a aspectos ligados à controvérsia que é da competência do juiz de primeiro grau, não basta que ele entenda que a decisão é incorreta. O tribunal somente pode reapreciar a decisão do juiz de primeiro grau porque o efeito devolutivo, típico da maioria das espécies recursais, a ele *atribui* o poder de reexaminar as decisões anteriormente exaradas. Não fosse esse efeito, qualquer intromissão do tribunal sobre a decisão do magistrado inicialmente competente para apreciar a causa – de acordo com as regras de competência – seria indevida, violando o direito fundamental ao juiz natural.

Em razão de regra decorrente da aplicação do princípio da demanda, perante o direito brasileiro a interposição do recurso somente devolve à apreciação do tribunal *a matéria impugnada (tantum devolutum quantum appellatum* – é o que se denomina de *efeito devolutivo horizontal ou em extensão*). Assim, se em uma ação de despejo por falta de pagamento, cumulada com pagamento de aluguéis, recorre à parte autora apenas em relação ao não acolhimento da pretensão à cobrança (deixando de lado a pretensão ao despejo, também não acolhida pelo magistrado singular), ainda que o tribunal dê provimento ao recurso, reconhecendo o direito de receber os aluguéis não adimplidos, não poderá ser decretado o despejo, já que essa matéria ficou fora do âmbito de sua cognição, por não ter sido essa questão devolvida. Por esse motivo, tendo interesse no reexame de determinada questão, deve a parte recorrente especificar nas razões do recurso que interpõe o *pedido de nova decisão que pretende*, permitindo assim ao tribunal avaliar a extensão máxima que poderá dar à sua deliberação.

Se, todavia, de um lado, o tribunal fica vinculado ao pedido de nova decisão formulado pelo recorrente, de outro, *quanto aos fundamentos desse pedido*, é livre para examinar a todos, ainda que não tenham sido expressamente referidos nas razões do recurso interposto (*efeito devolutivo vertical ou em profundidade*). Observe-se que o pedido de nova decisão pode ter inúmeros fundamentos – por exemplo, o pedido de revisão de uma sentença de mérito pode calcar-se em argumentos como a errônea aplicação da regra sobre o ônus da prova, a não apreciação de uma prova nos autos, a admissão de confissão em casos em que ela seria inaceitável e por aí afora –, mas o recorrente pode servir-se de todos ou de apenas alguns deles.

Entretanto, ainda que a parte não tenha alegado, nas razões de seu recurso, todos os fundamentos, é lícito ao tribunal conhecer de todos eles – sem violação ao princípio da demanda –, *desde que se atenha, ainda por exemplo, ao pedido de revisão formulado pelo recorrente*. É certo que, se o réu, em sua defesa perante uma ação de indenização por danos materiais, alegar a ausência da prova do nexo de causalidade e ainda inexistência de dano indenizável, em sendo rejeitada a pretensão reparatória, por conta do reconhecimento da inexistência de prova do nexo de causalidade, o autor poderá oferecer apelação para afastar esse juízo negativo. Mas na apelação, ainda que se alegue apenas ausência de prova do nexo de causalidade, poderá o tribunal negar provimento ao recurso, observando também a inexistência de dano indenizável, sem que isso viole a regra em exame, porque não se extrapolou o limite do *pedido de reforma* formulado pelo recorrente.

A princípio, portanto, o tribunal deve se limitar a examinar as questões já decididas pelo juízo de primeiro grau – ainda que não tenham sido expressamente impugnadas pela parte recorrente.

Porém, existem situações em que a legislação expressamente admite que o tribunal decida desde logo questões anteriormente não conhecidas pelo juízo de primeiro grau, desde que estejam em condições de imediato julgamento (isto é, não dependem de produção de prova diversa daquela já constante nos autos para sua apreciação). O tribunal decidirá desde logo quando: I – reformar sentença terminativa; II – decretar a nulidade da sentença por não ser ela congruente com os limites do pedido ou da causa de pedir; III – constatar a omissão no exame de um dos pedidos, hipótese em que poderá julgá-lo; IV – decretar a nulidade da sentença por falta de fundamentação. Ainda, quando reformar sentença que reconheça a decadência ou a prescrição, o tribunal, se possível, julgará o mérito, examinando as demais questões, sem determinar o retorno do processo ao juízo de primeiro grau (art. 1.013, §§ 3.º e 4.º, CPC/2015).

5.2. Translativo. Semelhante ao efeito devolutivo, esse efeito também diz respeito à cognição do tribunal sobre a causa⁴². Todavia, ao contrário do efeito devolutivo, que depende de expressa manifestação da parte, já que somente se devolve ao conhecimento do tribunal a matéria impugnada, o efeito translativo opera *ainda que sem expressa manifestação de vontade do recorrente. Trata-se de efeito inspirado no princípio inquisitório*.

O efeito translativo é ligado à matéria que compete ao Judiciário conhecer em qualquer tempo ou grau de jurisdição, ainda que sem expressa manifestação das partes, a exemplo das questões enumeradas no art. 485, § 3.º, CPC/2015. Se esses temas devem ser examinados pelo juízo *em qualquer tempo e grau de jurisdição*, eles certamente poderão ser apreciados quando da análise do recurso. O tribunal é autorizado a conhecer esses temas de ordem pública, ainda que não tenham sido decididos pelo juízo *a quo* ou não tenham sido debatidos nas razões recursais.

No entanto, é claro que, inexistindo debate a respeito, deve primeiro submeter a questão ao contraditório para tão somente depois decidi-la (art. 10, CPC/2015), sob pena de surpresa injusta. Tais temas, então, não se submetem ao efeito devolutivo, e podem ser conhecidos pelo tribunal sempre, em qualquer circunstância, bastando que tenha sido interposto recurso sobre alguma decisão da causa e que esse chegue a exame do juízo *ad quem*.

5.3. Suspensivo. Há decisões que somente produzem efeitos depois de *escoado o prazo recursal* para sua impugnação – como, por exemplo, ocorre em regra com a sentença (art. 1.012, CPC/2015). Nesses casos, afirma-se que o recurso é recebido no efeito suspensivo, embora esse *não suspenda* propriamente os efeitos da decisão recorrida (uma vez que ainda não foram gerados), mas *evite* que a decisão produza efeitos até o julgamento do recurso. Em outras situações, a decisão produz efeitos desde logo – como, por exemplo, a decisão interlocutória concessiva de antecipação da tutela. Nessa situação, o eventual efeito suspensivo que o tribunal pode dar ao recurso de agravo por instrumento efetivamente suspende os efeitos da decisão recorrida (art. 1.019, I, CPC/2015). O mesmo ocorre com os acórdãos que decidem as apelações: como o recurso extraordinário e o recurso especial não têm efeito suspensivo (art. 995, CPC/2015), essas decisões possuem eficácia imediata, que pode, no entanto, ser suspensa em função da concessão de tutela antecipada recursal (art. 1.029, § 5.º, CPC/2015). Note-se que as duas últimas hipóteses são completamente diferentes da primeira. Entretanto, em ambas se costuma aludir a efeito suspensivo do recurso.

Na realidade, quando se afirma que determinado recurso possui efeito suspensivo, quer se dizer que a decisão impugnada não poderá produzir efeitos senão depois de escoado o prazo recursal. Isso quer dizer que a decisão não é eficaz justamente porque suscetível de recurso.

Em termos de política legislativa, é preciso notar que o chamado efeito suspensivo deve ser pensado como algo que deve conciliar dois polos: o da *segurança jurídica* – evitando que a decisão impugnada produza efeitos na pendência de recurso que pode revertê-la, com o que visa a prestigiar a *certeza jurídica* – e o da *tempestividade* – que objetiva impedir que o tempo do processo prejudique a parte que tem razão, estimulando a interposição de recursos sem qualquer fundamento. Se o efeito suspensivo privilegia a segurança, sua não previsão serve para dar ênfase à necessidade de tempestividade. São as circunstâncias do direito material debatido em juízo que devem iluminar a eventual dispensa do efeito suspensivo. Porém, como muitas vezes é necessário considerar as particularidades do caso concreto, costuma-se também deixar ao juiz a possibilidade de conferir efeito suspensivo ao recurso. Nesse caso, o efeito suspensivo é denominado *ope iudicis*

(por exemplo, a possibilidade de o juiz dar efeito suspensivo ao agravo de instrumento – art. 1.019, I, CPC/2015), em oposição ao efeito suspensivo que é atribuído pela lei a determinado recurso (efeito suspensivo *ex lege*, por exemplo, o efeito suspensivo atribuído ao recurso de apelação – art. 1.012, CPC/2015).

Nessa perspectiva, é preciso perceber que o novo Código perdeu uma oportunidade importante: poderia ter tolhido o efeito suspensivo da apelação, tornando-o sempre atribuível *ope judicis*. Isso sem dúvida outorgaria *maior coerência* ao nosso sistema, na medida em que decisões provisórias fundadas em cognição sumária têm eficácia imediata (tutelas provisórias, arts. 294 a 311, CPC/2015), ao passo que decisões definitivas fundadas em cognição exauriente não contam em regra com a mesma eficácia (art. 1.012, CPC/2015)⁴³. Vale dizer: *o processo civil brasileiro atribui maior peso em termos de efetividade e tempestividade a decisões provisórias do que a decisões definitivas – nada obstante o juízo que alicerça as primeiras seja evidentemente menos seguro que o juízo que embasa as segundas*. O ideal é que todas as decisões judiciais tivessem eficácia imediata, contrabalanceando-se com a possibilidade de sua suspensão *ope judicis*. Nesse particular, o legislador inadimpliu com o seu dever de desenhar um processo capaz de viabilizar tutela jurisdicional tempestiva (artigo 5.º, inciso LXXVIII, CF/1988), desmentindo o seu compromisso fundamental com a duração razoável do processo (art. 4.º, CPC/2015).

5.4. Expansivo. A decisão oriunda do julgamento do recurso pode atingir outras pessoas que não o recorrente e outros atos processuais que não o recorrido. O efeito expansivo subjetivo ocorre quando a decisão do recurso alcança pessoa diversa da pessoa do recorrente (por exemplo, art. 1.005, CPC/2015). O efeito expansivo objetivo acontece quando, em face da reforma ou anulação de determinada decisão, outros atos processuais são igualmente atingidos (por exemplo, art. 520, II e III, CPC/2015).

Nessa linha, o efeito *expansivo* tem nítida vinculação com a própria noção dos atos processuais e do tema das nulidades e das ineficácias no processo civil. Como se sabe, é uma característica marcante do ato processual sua interdependência – na medida em que participa de uma cadeia procedimental⁴⁴. Vale dizer: um ato processual é praticado no processo como decorrência de outro, anteriormente praticado, determinando a realização de outros, que lhe seguem formando o procedimento.

Por conta dessa vinculação necessária entre os atos do processo, o Código de Processo Civil, ao tratar da matéria das nulidades, deixa evidenciado que os atos dependentes do ato nulo também se reputam de nenhum efeito, isto é, são ineficazes (arts. 281 e 282, CPC/2015). Assim, a modificação ou mesmo a anulação de uma decisão judicial pode determinar, em cadeia, a declaração de ineficácia de outros tantos atos – dependentes do primeiro na sequência do procedimento. Dessa forma, por exemplo, se for anulada em grau de recurso uma decisão judicial que admitia para fins civis a interceptação telefônica, certamente essa decisão contaminará a prova colhida com base nessa interceptação e, ainda, a eventual sentença prolatada com fulcro nessa prova. Enfim, todos os atos judiciais que dependam do ato judicial atacado no recurso (e que tenha sido modificado ou anulado em sua decorrência) podem ter sua eficácia cortada ou ao menos alterada. A decisão do recurso *expande a sua eficácia* para além do ato recorrido.

5.5. Substitutivo. O efeito substitutivo indica que, uma vez conhecido o recurso, a decisão do juízo *ad quem*, qualquer que seja o seu conteúdo, substituirá a decisão recorrida. O efeito vem expressamente previsto pelo art. 1.008, CPC/2015, que prevê que “o julgamento proferido pelo tribunal *substituirá* a decisão impugnada no que tiver sido objeto de recurso”. Assim, ainda que a decisão do tribunal *confirme* a decisão recorrida sem nada alterar em sua essência, por esse efeito, uma vez conhecido e julgado o recurso, não mais existirá a decisão recorrida, mas apenas a do tribunal.

A noção desse efeito é relevante, seja para efeitos de propositura de ação rescisória (como se verá adiante), seja ainda para a impugnação da decisão por outras vias autônomas (por exemplo, mandado de segurança e reclamação), determinando-se em todos esses casos a competência para apreciação da nova insurgência. A decisão do tribunal substitui a decisão recorrida *naquilo que foi objeto de recurso* para todos os efeitos legais.

5.6. Obstativo. A interposição do recurso tem o condão de obstar a preclusão e a formação da coisa julgada, mantendo o processo pendente até o seu julgamento. Mais propriamente, aliás, até o momento do escoamento do último prazo recursal. A interposição do recurso – ou a existência de prazo recursal pendente – impede a preclusão e o trânsito em julgado das decisões judiciais. Todos os recursos têm o condão de impedir a preclusão e, em sendo o caso, a formação da coisa julgada.

Art. 994. São cabíveis os seguintes recursos:

I – apelação;

II – agravo de instrumento;

III – agravo interno;

IV – embargos de declaração;

V – recurso ordinário;

VI – recurso especial;

VII – recurso extraordinário;

VIII – agravo em recurso especial ou extraordinário;

IX – embargos de divergência.

1. Recursos: do Código de 1939 ao Código de 2015. Os dispositivos equivalentes ao art. 994, CPC/2015, são os arts. 808, Código de 1939, e 496, Código de 1973. A comparação entre esses dispositivos pode dar um bom panorama a respeito da evolução do tema no direito brasileiro.

Na passagem do Código de 1939 para o Código de 1973 o recurso de revista desapareceu, bem como o agravo de petição, cuja função foi absorvida pela apelação. Além disso, a “apelação necessária” recebeu o nome de remessa necessária, os “embargos de nulidade ou infringentes” passaram a ser designados simplesmente de embargos infringentes e o antigo “agravo nos autos do processo” acabou encontrando paralelo no agravo retido⁴⁵.

Com o advento do Código de 2015, os embargos infringentes saíram do rol dos recursos, nada obstante a função de ampliação subjetiva do debate na instância ordinária tenha encontrado lugar no art. 942, CPC/2015. Ademais, o legislador previu apenas o recurso de agravo de instrumento (art. 1.015, CPC/2015), postergando a recorribilidade das decisões interlocutórias não arroladas taxativamente para a apelação ou para as suas contrarrazões (art. 1.009, CPC/2015). Vale dizer: supressão do recurso de embargos infringentes e novo desbastamento da figura do agravo.

Entretanto, na esteira das *Reformas*, previu-se o recurso de agravo interno e bem assim o recurso de agravo em recurso extraordinário ou em recurso especial. Com isso, do Código de 1939 ao Código de 2015, o sistema recursal na verdade acabou ganhando apenas em *simplicidade* (na medida em que acórdãos não unânimes, nas hipóteses legais, e decisões interlocutórias não taxativamente arroladas são novamente debatidas sem recurso próprio), *mas não exatamente em diminuição da área de revisibilidade* das decisões judiciais.

2. Taxatividade. Os recursos processuais civis são tão somente aqueles expressamente indicados pela legislação federal (art. 22, I, CF/1988). Os recursos admitidos no processo civil constam taxativamente do art. 994, CPC/2015. Cada qual assume uma especial função no processo, tendo a sua própria hipótese de cabimento.

Por conta da taxatividade, importa registrar que inexistente previsão, no direito brasileiro, de cabimento de embargos de divergência no âmbito dos Tribunais Regionais Federais e dos Tribunais de Justiça dos Estados⁴⁶. Inexiste, igualmente, recurso cabível contra decisão do tribunal de origem que admite recurso extraordinário ou recurso especial⁴⁷. Ainda, cumpre observar que

“não cabe recurso contra despacho de mero expediente, que determina o arquivamento de petição”, a qual se insurgia contra “decisão proferida em agravo de instrumento, transitada em julgado”⁴⁸.

3. Convenções processuais relativas aos recursos. Por força da taxatividade legal (arts. 22, inciso I, CF/88, e 994, CPC), os recursos não podem ser criados por convenções processuais (art. 190, CPC). Por essa mesma razão não é possível ampliar suas hipóteses de cabimento⁴⁹.

Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.

Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.

1. Não impedem a eficácia da decisão. A interposição de recurso não impede que a decisão recorrida produza a eficácia que lhe é própria, salvo disposição legal ou judicial em sentido contrário (art. 995, CPC/2015). Daí que toda a eficácia da decisão recorrida pode ser liberada na pendência de recurso. Em outras palavras, o fato de eventual execução ser realizada na pendência de um recurso não retira – por si só – a possibilidade de essa ser uma execução completa.

A execução provisória (mais precisamente, a execução fundada em título executivo provisório) não se confunde tecnicamente com a execução incompleta. O direito brasileiro admite, durante a execução provisória, execução completa (arts. 520, IV, e 521, CPC/2015), embora a regra seja a execução provisória e incompleta (art. 520, IV, e § 5.º, CPC/2015).

A eficácia da sentença não se confunde com a autoridade da coisa julgada – daí porque pode a sentença produzir efeitos ainda que não transitada em julgado. Embora a questão seja tormentosa na doutrina, nada obsta que a decisão declaratória ou constitutiva possa ser eficaz na pendência de recurso. O mesmo se diga de decisão condenatória, mandamental ou executiva. Sendo possível retirar alguma consequência prática de decisão submetida a recurso, nada obsta a produção de seus efeitos.

Quando o legislador permite a execução provisória, admitindo a prática de determinados atos executivos, ele obviamente já realizou um juízo a respeito de *quem deve pagar pelo risco* no processo: se, em regra, o risco de o pedido ser julgado improcedente faz com que o autor não possa fruir do bem da vida até o julgamento da apelação (salvo a prestação de tutela provisória, arts. 294 a 311, CPC/2015), com a realização do duplo grau de jurisdição a responsabilidade pelo risco inverte-se, tendo o réu que suportá-lo até a apreciação do caso, em sendo o caso, por recurso extraordinário ou por recurso especial. Trata-se de necessidade inspirada no princípio da igualdade no processo civil (arts. 5.º, I, CF/1988, e 7.º, CPC/2015). Quando o legislador corta o efeito suspensivo da apelação, a redistribuição desse risco ocorre ainda antes: a inspiração aí, porém, não está apenas no princípio da igualdade, mas também na especificidade do direito material que constitui objeto do debate judicial, o qual, pela sua importância, pode justificar a sua realização durante a pendência do recurso de apelação, ressalvada decisão judicial em sentido contrário.

2. Disposição legal. Como regra, os recursos não têm efeito suspensivo. O legislador, porém, desde logo excepcionou dessa previsão a apelação (art. 1.012, CPC/2015). Os demais recursos não têm o condão de suspender a eficácia da decisão recorrida. Os embargos declaratórios não vedam a produção de efeitos da decisão embargada (art. 1.026, CPC/2015).

3. Decisão judicial. Afora a apelação, todos os demais recursos só neutralizam a eficácia da decisão recorrida mediante decisão judicial em contrário que outorgue efeito suspensivo (arts. 932, II, 995, parágrafo único, 1.019, I, 1.029, § 5.º, CPC/2015). O pedido de concessão de efeito suspensivo constitui rigorosamente hipótese de antecipação da tutela recursal.

A competência para concessão de efeito suspensivo é do relator (arts. 299, parágrafo único, 932, II, e 995, parágrafo único, CPC/2015), ressalvada a hipótese de outorga de efeito suspensivo em

recurso extraordinário ou em recurso especial, que, conforme a hipótese, deve ser requerido diante do tribunal recorrido ou do tribunal competente para o julgamento do respectivo mérito (art. 1.029, § 5.º, CPC/2015). Sobre a antecipação da tutela recursal em recurso extraordinário e em recurso especial, vide comentários ao art. 1.029, CPC/2015.

Como regra, se o recurso já foi interposto, o efeito suspensivo pode ser requerido na petição que veicula o recurso ou mediante simples requerimento nos autos; se ainda não foi, o efeito suspensivo pode ser postulado mediante ação que visa à tutela provisória de forma antecedente, que deve ser interposta diretamente no tribunal competente para o julgamento do recurso que será interposto (art. 299, parágrafo único, CPC/2015).

4. Suspensão da decisão recorrida. A suspensão da decisão recorrida por força de decisão judicial está subordinada à demonstração da probabilidade de provimento do recurso (probabilidade do direito alegado no recurso, o *fumus boni iuris* recursal) e do perigo na demora (*periculum in mora*).

Como o direito brasileiro admite expressamente tutela contra o ilícito (art. 497, parágrafo único, CPC/2015), é um equívoco imaginar que apenas a tutela de urgência contra o dano (“risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação”) justifica a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Se há iminência da prática, reiteração ou continuação de um ato ilícito ou se é urgente a remoção do ilícito, esses fatos servem igualmente para evidenciar a necessidade de tutela de urgência capaz de justificar a concessão de efeito suspensivo. O que interessa para a concessão de efeito suspensivo, além da probabilidade de provimento recursal, é a existência de perigo na demora na obtenção do provimento recursal.

Art. 996. O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica.

Parágrafo único. Cumpre ao terceiro demonstrar a possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atingir direito de que se afirme titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual.

1. Legitimidade e Interesse. De acordo com clássica lição, o problema da identificação da legitimidade reside na particularização do interesse. Em outras palavras, tem legitimidade que tem interesse⁵⁰.

No direito recursal, o interesse em recorrer pode ser aferido tanto a partir do *dispositivo* da decisão recorrida como da sua *fundamentação*. A caracterização do interesse – e, portanto, da legitimidade – a partir da discordância da conclusão obtida pelo órgão jurisdicional e exposta no dispositivo é a sua hipótese clássica de conformação. A ideia de parte *vencida*, pois, está vinculada normalmente à sucumbência constante do dispositivo.

A questão mais interessante a respeito do tema, porém, está na possibilidade de verificação do interesse de agir a partir das questões apenas resolvidas na fundamentação. A propósito, a doutrina clássica é refratária à possibilidade de configuração do interesse de agir pela discordância da solução de questões decididas apenas na fundamentação sob o argumento de que essas não fazem coisa julgada, não havendo daí interesse em impugná-las⁵¹.

Em primeiro lugar, é preciso desfazer a pressuposição de que o processo civil teria apenas um escopo ligado ao caso concreto – ou, o que ainda é mais reduzido, à simples formação da coisa julgada⁵². O processo civil tem uma dupla dimensão e visa alcançar igualmente um duplo escopo: uma dimensão particular e outra geral, um escopo ligado à justiça da decisão (art. 6.º, CPC/2015) e outro atinente à unidade da ordem jurídica (art. 926, CPC/2015). Se isso é verdade, então é possível desde logo vislumbrar interesse na interposição de recursos para as Cortes Supremas a fim de que essas apreciem especificamente determinadas questões constantes da fundamentação ou que nela não foram expressamente examinadas. Trata-se de interesse recursal justificado no interesse na formação do precedente.

Em segundo lugar, existe ao menos um recurso cujas hipóteses de cabimento dizem respeito diretamente à fundamentação da decisão: os embargos de declaração. Nessa hipótese, é claro que o interesse recursal acaba se formando a partir da fundamentação e não do dispositivo⁵³.

2. Parte vencida. Tem legitimidade recursal a parte vencida. Vale dizer: a parte prejudicada pela decisão – a parte sucumbente, no todo ou em parte, no processo. O interesse recursal, que outorga legitimidade ao recorrente, vai evidenciado aí a partir da ideia de potencial proveito que o provimento do recurso pode ensejar para a parte⁵⁴. Não tem interesse recursal, não sendo legítima para recorrer, a parte que não é vencida no processo⁵⁵.

Parte, no art. 996, CPC/2015, é um conceito amplo: é todo aquele que participa do processo. Daí que, por exemplo, se o assistente simples, que já participa do processo antes da prolação da decisão, é por ela prejudicado, pode dela recorrer na qualidade de “parte vencida”. O mesmo vale para o denunciado à lide e para o chamado ao processo.

3. Terceiro prejudicado. Tem legitimidade para recorrer o terceiro prejudicado. Terceiro é aquele que não é parte. Em nada altera essa legitimidade o fato de ter sido excluído do processo por ilegitimidade de parte⁵⁶. Para que seja admitido o seu recurso, cumpre ao terceiro demonstrar o nexo de interdependência entre o seu interesse de intervir e a relação jurídica submetida à apreciação judicial (art. 996, parágrafo único, CPC/2015). Vale dizer: tem de demonstrar a possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atingir direito de que se afirme titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual⁵⁷.

Vários são os exemplos. Consoante à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é terceiro prejudicado, tendo legitimidade para recorrer: a) o servidor nomeado, diante da decisão que anula o concurso no qual foi aprovado, proferida em processo de que não participou⁵⁸; b) o arrematante que não foi réu nos embargos à arrematação julgados procedentes⁵⁹; c) o credor que vê o bem penhorado para satisfazer seu crédito alienado em outro processo, em transação homologada pelo juiz⁶⁰; d) o fiador, diante da procedência do pedido de cobrança de aluguéis, proposta apenas contra o inquilino⁶¹; e) aquele que teve os seus bens constritos em processo judicial de que não participou⁶²; f) o banco que recebeu determinação judicial para corrigir valores de determinada maneira, resultantes de depósito feito em processo do qual não era parte⁶³; g) o sócio, diante da decisão que decreta a falência da sociedade que integrou⁶⁴; h) o proprietário atingido por ação civil pública julgada procedente, que impede a concessão de alvará para construir na zona territorial de sua propriedade⁶⁵; i) o endossatário da duplicata, diante da anulação do título em processo em que foi réu apenas o endossante⁶⁶; j) a convivente, na ação de investigação de paternidade contra o seu companheiro⁶⁷. De outro lado, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que não tem legitimidade para recorrer como terceiro prejudicado: a) o perito, no processo em que teve o seu lado tido como inservível⁶⁸; b) o depositário do juízo⁶⁹.

Julgando adequado e preenchendo os pressupostos legais, pode o terceiro prejudicado insurgir-se contra a decisão mediante mandado de segurança. Nesse caso, “a impetração de segurança por terceiro, contra ato judicial, não se condiciona à interposição de recurso” (Súmula 202, STJ).

4. Pessoas Jurídicas de Direito Público. Em determinadas hipóteses, admite-se que terceiro recorra ainda que não demonstre prejuízo jurídico em face da decisão recorrida. Assim, poderá a União intervir nas causas em que figurarem, como autoras ou rés, autarquias, fundações públicas, sociedades de economia mista e empresas públicas federais (art. 5.º, Lei 9.469/1997). As pessoas jurídicas de direito público poderão, nas causas cuja decisão possa ter reflexos, ainda que indiretos, de natureza econômica, intervir, independentemente da demonstração de interesse jurídico, para esclarecer questões de fato e de direito, podendo juntar documentos e memoriais reputados úteis ao exame da matéria e, se for o caso, recorrer, hipótese em que, para fins de deslocamento de competência, serão consideradas partes (art. 5.º, parágrafo único, Lei 9.469, de 1997).

5. Ministério Público. O Ministério Público tem legitimidade para recorrer assim no processo em que é parte, como naqueles em que oficiou como fiscal da ordem jurídica (art. 996, CPC/2015,

que encampou nesse particular o enunciado da Súmula 99, STJ: “o Ministério Público tem legitimidade para recorrer no processo em que oficiou como fiscal da lei, ainda que não haja recurso da parte”). Exemplo de situação em que o Ministério Público pode recorrer quando atua como fiscal da ordem jurídica está na ação de acidente de trabalho, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 226, STJ: “o Ministério Público tem legitimidade para recorrer na ação de acidente do trabalho, ainda que o segurado esteja assistido por advogado”).

Art. 997. Cada parte interporá o recurso independentemente, no prazo e com observância das exigências legais.

§ 1.º Sendo vencidos autor e réu, ao recurso interposto por qualquer deles poderá aderir o outro.

§ 2.º O recurso adesivo fica subordinado ao recurso independente, sendo-lhe aplicáveis as mesmas regras deste quanto aos requisitos de admissibilidade e julgamento no tribunal, salvo disposição legal diversa, observado, ainda, o seguinte:

I – será dirigido ao órgão perante o qual o recurso independente fora interposto, no prazo de que a parte dispõe para responder;

II – será admissível na apelação, no recurso extraordinário e no recurso especial;

III – não será conhecido, se houver desistência do recurso principal ou se for ele considerado inadmissível.

1. Recurso. Cada parte interporá o recurso independentemente, no prazo e com observância das disposições legais pertinentes (art. 997, CPC/2015). A admissão de recurso inadmissível constitui ofensa ao art. 997, CPC/2015.

2. Recurso Adesivo. Havendo sucumbência recíproca – sendo ao mesmo tempo “vencidos autor e réu” –, cada uma das partes pode interpor independentemente o seu próprio recurso, devendo observar o prazo e as demais exigências legais. Não recorrendo de modo principal, no entanto, pode a parte aderir ao recurso interposto pela parte contrária (art. 997, § 1.º, CPC/2015)⁷⁰. Rigorosamente, a parte não adere ao recurso da parte contrária – contrapõe outro recurso àquele já manifestado⁷¹. Observe-se que apenas a parte que não recorreu de modo principal pode manifestar recurso adesivo: ao recorrer de maneira principal dá-se a consumação da faculdade de recorrer de maneira adesiva⁷².

3. Admissibilidade. A admissibilidade do recurso adesivo liga-se tão somente ao atendimento dos requisitos postos no art. 997, CPC/2015. Havendo sucumbência recíproca, interposição de recurso principal, aderência a recurso suscetível de recurso adesivo, observância do prazo de contrarrazões, conhecimento do recurso principal e demais questões procedimentais, o recurso adesivo tem de ser admitido⁷³. Há direito da parte à admissão do recurso adesivo. É irrelevante que o recurso adesivo não verse sobre a mesma matéria do recurso principal⁷⁴.

4. Subordinação. O recurso adesivo é um recurso subordinado – a sua sorte está coarctada à sorte do recurso principal. Se o recurso principal não for conhecido – em face do não atendimento de qualquer de seus requisitos de admissibilidade, também não se pode conhecer o recurso adesivo. Não interessa qual a causa que deu lugar à inadmissibilidade do recurso principal⁷⁵. Nesse caso, diz-se que o recurso adesivo restou prejudicado⁷⁶.

5. Taxatividade. Só se pode aderir a recurso de apelação, recurso extraordinário e recurso especial (art. 997, § 2.º, II, CPC/2015). O rol é taxativo⁷⁷. Não se pode aderir, por exemplo, a recurso de embargos de divergência.

6. Interposição. O recurso adesivo será interposto perante a autoridade competente para admitir o recurso principal, no prazo de que a parte dispõe para responder (art. 997, § 2.º, I,

CPC/2015). Prova-se a tempestividade do recurso adesivo mediante a indicação ou juntada da certidão de intimação para contrarrazões⁷⁸. Sendo o caso de formar-se instrumento recursal, é imprescindível a cópia da certidão de intimação para contrarrazões, sob pena de não conhecimento do recurso⁷⁹. É irrelevante se a parte recorreu de maneira adesiva apenas porque perdeu o prazo para o recurso principal⁸⁰. O que interessa para aferição da tempestividade do recurso adesivo é a observância do prazo para contrarrazões e a prova de seu termo inicial.

7. Mesmas Regras. Ao recurso adesivo aplicam-se as mesmas regras do recurso principal quanto aos requisitos de admissibilidade e julgamento, salvo disposição em contrário.

Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso.

Parágrafo único. A desistência do recurso não impede a análise de questão cuja repercussão geral já tenha sido reconhecida e daquela objeto de julgamento de recursos extraordinários ou especiais repetitivos.

1. Desistência. A desistência do recurso ocorre depois de exercido o direito de recorrer. Só se pode desistir do que já se iniciou. Só pode desistir do recurso quem o interpôs. O recorrido evidentemente não tem legitimidade para requerer a desistência do recurso⁸¹. A desistência concerne apenas ao recurso interposto, independe de aceitação do recorrido e de homologação judicial para ser eficaz⁸². É irretratável, produzindo imediatamente a extinção do procedimento recursal (art. 200, CPC/2015). Não se confunde com a desistência da demanda (art. 485, VIII, CPC/2015) – que, depois da citação válida, depende da concordância do demandado e só surte efeitos depois de homologada judicialmente (art. 200, parágrafo único, CPC/2015).

A desistência do recurso pode ocorrer a qualquer tempo enquanto não ultimado o seu julgamento (art. 998, CPC/2015). Pode o recorrente desistir do recurso inclusive se já iniciada a sessão de julgamento e já iniciada a discussão da causa pelos julgadores⁸³. A desistência pode se dar de maneira escrita ou oral⁸⁴.

Tendo o recorrente desistido do recurso, observar-se-á quanto à disciplina jurídica da causa aquela estabelecida pela decisão recorrida⁸⁵. Como regra, ressalvadas as hipóteses abaixo, eventual julgamento do recurso prolatado depois de ter o recorrente manifestado a sua desistência é ineficaz. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a propósito, estima-o nulo⁸⁶.

2. Litisconsórcio. A desistência do recurso independe da anuência dos litisconsortes do recorrente. Essa é a regra para o caso de litisconsórcio simples (regime comum do litisconsórcio, art. 117, CPC/2015). Todavia, se há litisconsórcio unitário entre o recorrente e os seus consortes (regime especial do litisconsórcio), então a desistência só opera o efeito de extinguir o procedimento recursal se todos os litisconsortes anuírem à desistência. Do contrário, a desistência é ineficaz e não determina a extinção do recurso.

3. Precedentes. A função das Cortes Supremas – do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça – não é de controle, mas de interpretação. A função é prospectiva e não propriamente retrospectiva. Daí a razão pela qual os seus julgados têm eficácia de precedente (arts. 926 e 927, CPC/2015).

Assim, o recurso extraordinário e o recurso especial funcionam como meios pelos quais essas Cortes colhem a oportunidade de analisar questões jurídicas controversas a fim de outorgar unidade ao direito. É por essa razão que o art. 998, parágrafo único, CPC/2015, permite que o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça se pronunciem sobre questões recursais ainda que a parte tenha desistido do recurso. Nesse caso, obviamente que a pronúncia da Corte não poderá alcançar o recurso da parte. Servirá, porém, para outorgar unidade ao direito, valendo como precedente⁸⁷.

Art. 999. A renúncia ao direito de recorrer independe da aceitação da outra parte.

1. Renúncia. Constitui o ato pelo qual a parte manifesta a vontade de não interpor recurso que poderia apresentar diante de determinada decisão judicial. Independe de aceitação da parte contrária. A renúncia é necessariamente prévia ao ato de recorrer e nisso se distingue da desistência. A renúncia ao recurso pode ocorrer assim que surge o direito ao recurso. A renúncia é fato impeditivo do direito de recorrer – manifestada a renúncia, vê a parte logicamente preclusa a faculdade de recorrer (preclusão lógica), proibição de fundo ético decorrente da vedação ao *venire contra factum proprium* no processo.

A renúncia ao recurso nada tem que ver com a renúncia ao direito material posto em juízo (art. 487, III, c, CPC/2015): a renúncia ao recurso se passa no plano processual, ao passo que a renúncia ao direito concerne ao plano do direito material. A renúncia ao recurso pode ser manifestada por aquele que tem direito ao recurso, independe de forma específica e de homologação judicial para que seja eficaz (art. 200, CPC/2015).

2. Litisconsórcio. Se há litisconsórcio simples no polo do processo em que se verificou a sucumbência (regime comum do litisconsórcio), a renúncia ao recurso pode ocorrer por qualquer um dos consortes sem a aquiescência dos demais (art. 117, CPC/2015). Os litisconsortes que não renunciaram, conservam o direito de recorrer. Havendo, contudo, litisconsórcio unitário (regime especial do litisconsórcio), a renúncia ao direito de recorrer só é eficaz se manifestada por todos os litisconsortes; do contrário, não atinge a nenhum dos consortes, conservando cada um dos litisconsortes o direito de recorrer válido e eficaz.

Art. 1.000. A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer.

Parágrafo único. Considera-se aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer.

1. Aceitação. A parte, que aceitar expressa ou tacitamente a decisão judicial, dela não poderá recorrer. A aceitação da decisão configura fato impeditivo do direito de recorrer. Aceitando a parte a decisão judicial, vê logicamente preclusa a faculdade de recorrer, haja vista a proibição do *venire contra factum proprium* no processo. A aceitação da decisão ocorre quando a parte se conforma com ela. Pode ser total ou parcial. A aquiescência independe de forma específica (pode ser oral ou escrita) e de homologação judicial para que seja eficaz (art. 200, CPC/2015).

2. Expressa ou tácita. A aceitação pode ser expressa ou tácita. A aceitação tácita ocorre com a prática, sem reserva alguma, de um ato incompatível com a vontade de recorrer (art. 1.000, parágrafo único, CPC/2015). Feita a ressalva, não se configura a aceitação da decisão (por exemplo, art. 520, § 1.º, CPC/2015).

3. Depósito do valor da condenação e multa. Pode o recorrente, a fim de evitar a incidência da multa de 10% (dez por cento) a que alude o art. 523, § 1.º, CPC/2015, depositar o valor da condenação e recorrer. Para que não configure, no entanto, aceitação tácita da decisão, e o recurso interposto não seja conhecido, tem o recorrente de ressaltar expressamente que deposita para efeitos de evitar a incidência da multa. Do contrário, inexistindo ressalva, tem-se que entender que o condenado cumpriu a decisão sem reservas, aceitando-a tacitamente, sendo o recurso eventualmente interposto inadmissível.

4. Litisconsórcio. Se há litisconsórcio simples no polo do processo em que se verificou a sucumbência (regime comum do litisconsórcio), a aceitação da decisão pode ocorrer por qualquer um dos consortes sem a aquiescência dos demais (art. 117, CPC/2015). Os litisconsortes que não aquiesceram conservam o direito de recorrer. Havendo, contudo, litisconsórcio unitário (regime especial do litisconsórcio), a aquiescência à decisão só é eficaz se manifestada por todos os litisconsortes; do contrário, não atinge a nenhum dos consortes, conservando cada um dos litisconsortes o direito de recorrer válida e eficazmente.

Art. 1.001. Dos despachos não cabe recurso.

1. Irrecorribilidade. Os despachos ou despachos de mero expediente são atos judiciais que visam simplesmente a impulsionar o procedimento (art. 203, § 3.º, CPC/2015). Distinguem-se dos

acórdãos, das sentenças e das decisões interlocutórias porque nada decidem – são insuscetíveis de causar gravame a qualquer das partes. Daí a razão pela qual não desafiam qualquer recurso. Para aferição da natureza da manifestação judicial pouco importa o nome com que foi chamado pelo magistrado. Interessa, para esse fim, a análise do conteúdo do ato judicial.

2. Casuística. O ato que determina a citação da parte contrária constitui decisão interlocutória, mas não desafia o recurso de agravo de instrumento (art. 1.015, CPC/2015). O ato que posterga para depois da citação da parte contrária a análise de pedido de tutela de urgência é decisão interlocutória, porque decide, no mínimo, que não há urgência em prover naquele momento, desafiando recurso de agravo de instrumento (art. 1.015, I, CPC/2015)⁸⁸. O ato que dá vista à parte contrária de planilha de cálculos apresentada por outra constitui simples despacho⁸⁹. Já se decidiu igualmente, contudo, que o ato judicial que, “modificando o critério de liquidação determinado pela decisão cognitiva, imputou obrigação a uma das partes, a qual, acaso não cumprida, importaria o acolhimento dos cálculos apresentados pela outra parte”, constitui decisão interlocutória, não podendo ser classificado como simples despacho⁹⁰. O ato que dá vista à parte sobre conta elaborada no juízo de desapropriação constitui despacho⁹¹. O ato que simplesmente determina a expedição de ofício requisitório constitui despacho⁹².

Art. 1.002. A decisão pode ser impugnada no todo ou em parte.

1. No todo ou em parte. A decisão judicial pode ser impugnada no todo ou em parte. O recurso pode ser, assim, total ou parcial, consoante se dirija à decisão em toda a sua extensão ou apenas à parcela dela. A não impugnação de parcela da decisão, quando impugnável, não configura por si só aceitação tácita dessa mesma parcela. Ainda que o recurso tenha sido parcial, cumpre observar que o trânsito em julgado só ocorre com a última decisão proferida no processo (art. 975, CPC/2015).

Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão.

§ 1.º Os sujeitos previstos no *caput* considerar-se-ão intimados em audiência quando nesta for proferida a decisão.

§ 2.º Aplica-se o disposto no art. 231, incisos I a VI, ao prazo de interposição de recurso pelo réu contra decisão proferida anteriormente à citação.

§ 3.º No prazo para interposição de recurso, a petição será protocolada em cartório ou conforme as normas de organização judiciária, ressalvado o disposto em regra especial.

§ 4.º Para aferição da tempestividade do recurso remetido pelo correio, será considerada como data de interposição a data de postagem.

§ 5.º Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.

§ 6.º O recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso.

1. Fluência e contagem. O prazo para interposição de recurso flui da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão (art. 1.003, CPC/2015). Se a decisão é dada em audiência, então nesse momento se consideram intimadas as partes para o recurso (art. 1.003, § 1.º, CPC/2015). O prazo será contado a partir do primeiro dia útil subsequente (art. 224, § 3.º, CPC/2015).

Observe-se que fluência e contagem de prazo são conceitos que não se confundem – a fluência denota o exato momento em que o prazo existe; a contagem, o momento em que começa a ser computado para fins de própria extinção. O prazo começa a ser contado a partir do primeiro dia útil subsequente aos termos de fluência postos nos art. 1.003, CPC/2015 (art. 224, § 3.º, CPC/2015). Registra a jurisprudência que é irrelevante para efeitos de fluência e contagem de prazo para

impugnação de acórdão o fato de a ata da sessão de julgamento ter sido disponibilizada posteriormente à publicação do acórdão; o termo inicial, nesse caso, obedece igualmente ao art. 1.003, CPC/2015⁹³.

2. Antes da citação. Se a decisão é prolatada antes da citação do réu, o seu prazo recursal flui a partir dos termos constantes do art. 231, incisos I a VI, CPC/2015 (art. 1.003, § 2.º, CPC/2015).

3. Protocolo. O recurso será protocolado no cartório, na secretaria, ou onde determinar a norma de organização judiciária local, ressalvado o disposto em regra especial (art. 1.003, § 3.º, CPC/2016).

4. Correio. Para aferição da tempestividade do recurso remetido pelo correio, será considerada como data de interposição a data de postagem (art. 1.003, § 4.º, CPC/2015). Em outras palavras, problemas concernentes à demora na entrega do recurso ao tribunal competente não são imputáveis ao recorrente.

5. Prazo. Todos os recursos devem ser interpostos dentro do prazo de 15 (quinze) dias (art. 1.003, § 5.º, CPC/2015), exceto os embargos declaratórios, que devem ser interpostos no prazo de 5 (cinco) dias (art. 1.023, CPC/2015).

6. Feriado local. Deve ser comprovado pelo recorrente no ato de interposição do recurso (art. 1.003, § 6.º, CPC/2015). Não comprovado, deve o relator determinar a sua imediata comprovação (art. 932, parágrafo único, CPC/2015). Não atendida a ordem, cumpre-lhe não conhecer do recurso, acaso da comprovação do feriado dependa a tempestividade recursal.

O Superior Tribunal de Justiça, contudo, decidiu considerar “intempestivo” o recurso cuja comprovação do feriado local não foi realizada no ato da sua interposição⁹⁴. Trata-se de orientação equivocada que deve ser revista – em primeiro lugar, porque o problema não diz respeito propriamente à tempestividade recursal, mas sim à *prova* da tempestividade. O recurso interposto dentro do prazo, obviamente, não deixa de ser tempestivo pela inexistência de comprovação. Em segundo lugar, porque, não se situando no terreno da tempestividade, a comprovação do feriado local mostra-se plenamente passível de realização posterior – a fim de que prevaleça a orientação geral do Código a respeito da primazia das decisões de mérito em detrimento de decisões processuais. Enquanto não alterado o precedente, porém, deve-se comprovar a existência de feriado local no momento da interposição do recurso, sob pena de não conhecimento.

Art. 1.004. Se, durante o prazo para a interposição do recurso, sobrevier o falecimento da parte ou de seu advogado ou ocorrer motivo de força maior que suspenda o curso do processo, será tal prazo restituído em proveito da parte, do herdeiro ou do sucessor, contra quem começará a correr novamente depois da intimação.

1. Interrupção de prazo. Sobrevindo o falecimento da parte ou de seu advogado durante o curso do prazo para interposição de recurso ou ocorrendo motivo de força maior, que suspenda o curso do processo (art. 313, I e VI, CPC/2015), o prazo recursal será interrompido, sendo restituído posteriormente por inteiro à parte, ao seu herdeiro ou sucessor. O art. 1.004, CPC/2015, trata de hipóteses em que há interrupção do prazo. Não se dá a simples suspensão. A parte tem direito a ser intimada para que recorra dispondo de todo o prazo recursal novamente.

Art. 1.005. O recurso interposto por um dos litisconsortes a todos aproveita, salvo se distintos ou opostos os seus interesses.

Parágrafo único. Havendo solidariedade passiva, o recurso interposto por um devedor aproveitará aos outros quando as defesas opostas ao credor lhes forem comuns.

1. Efeito expansivo e litisconsórcio unitário. O recurso interposto por um dos litisconsortes unitários a todos aproveita, salvo se distintos ou opostos os seus interesses. O art. 1.005, *caput*, só se aplica ao litisconsórcio submetido a regime especial (litisconsórcio unitário), porque somente aí há a necessidade de manter-se, à vista da natureza incindível da relação jurídica material afirmada em juízo, a uniformidade da disciplina da sentença.

Ao litisconsórcio simples (regime comum do litisconsórcio) não se aplica o art. 1.005, *caput*, CPC/2015. A aplicação do art. 1.005, *caput*, CPC/2015, ao litisconsórcio simples viola o art. 116, CPC/2015. O efeito expansivo subjetivo dos recursos, por conta do *caput* do art. 1.005, CPC/2015, pressupõe a unitariedade do litisconsórcio. Pressupõe interesse comum entre os consortes. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se majoritariamente nesse sentido⁹⁵. Existem decisões, no entanto, que aplicam o art. 1.005, CPC/2015, quando, em litisconsórcio simples, todos os consortes possuem o mesmo advogado⁹⁶. Existem outros, ainda, que aplicam o art. 1.005, CPC/2015, em litisconsórcio simples, a fim de que litisconsortes que se encontrem em situações idênticas e possuam o mesmo interesse não tenham uma disciplina jurídica distinta, o que violaria a igualdade⁹⁷.

2. Solidariedade. A existência de solidariedade no que tange à relação jurídica material afirmada em juízo não impõe, por si só, a formação de litisconsórcio unitário no processo. Para que exista litisconsórcio unitário é imprescindível que se afirme relação jurídica material incindível em juízo; do contrário, o litisconsórcio é simples. O art. 1.005, parágrafo único, CPC/2015, estende os efeitos da interposição de um recurso por um litisconsorte, em regra, simples aos demais consortes, desde que se afirme entre eles solidariedade. Trata-se de caso particular em que há extensão subjetiva do recurso sem que exista litisconsórcio unitário. O art. 1.005, parágrafo único, CPC/2015, deve ser lido conjuntamente com o art. 274, CC: havendo solidariedade em um dos polos do processo, afirmando um dos consortes questão favorável comum, o julgamento benéfico a todos aproveita.

Art. 1.006. Certificado o trânsito em julgado, com menção expressa da data de sua ocorrência, o escrivão ou o chefe de secretaria, independentemente de despacho, providenciará a baixa dos autos ao juízo de origem, no prazo de 5 (cinco) dias.

1. Baixa dos autos. Transitado em julgado o acórdão – o que só se dá no direito brasileiro, consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, com a preclusão máxima da última decisão proferida no processo (art. 975, CPC/2015)⁹⁸ –, o escrivão, ou secretário, independentemente de despacho, providenciará a baixa dos autos ao juízo de origem, no prazo de 5 (cinco) dias. Trata-se de prazo impróprio, inenfo à preclusão.

Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

§ 1.º São dispensados de preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, os recursos interpostos pelo Ministério Público, pela União, pelo Distrito Federal, pelos Estados, pelos Municípios, e respectivas autarquias, e pelos que gozam de isenção legal.

§ 2.º A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias.

§ 3.º É dispensado o recolhimento do porte de remessa e de retorno no processo em autos eletrônicos.

§ 4.º O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

§ 5.º É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4.º.

§ 6.º Provando o recorrente justo impedimento, o relator relevará a pena de deserção, por decisão irrecorrível, fixando-lhe prazo de 5 (cinco) dias para efetuar o preparo.

§ 7.º O equívoco no preenchimento da guia de custas não implicará a aplicação da pena de

deserção, cabendo ao relator, na hipótese de dúvida quanto ao recolhimento, intimar o recorrente para sanar o vício no prazo de 5 (cinco) dias.

1. Preparo. Preparar o recurso significa custear as despesas inerentes ao seu processamento, aí incluído o porte de remessa e de retorno (Súmula 187, STJ: “é deserto o recurso interposto para o Superior Tribunal de Justiça, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos”). Cuida-se de requisito extrínseco de admissibilidade recursal. O preparo, quando exigido, deve ser comprovado no momento de interposição do recurso. Se o recurso foi interposto depois do encerramento do expediente bancário, tem-se que admitir a comprovação do preparo no primeiro dia útil subsequente, sob pena de indevido encurtamento do prazo recursal⁹⁹.

2. Dispensa. A lei dispensa expressamente de preparo os embargos de declaração (art. 1.023, CPC/2015). Ainda, estão dispensadas de preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, as pessoas mencionadas no art. 1.007, § 1.º, CPC/2015. É dispensado o recolhimento do porte de remessa e de retorno no processo em autos eletrônicos (art. 1.007, § 3.º, CPC/2015).

3. Deserção. Em uma estrutura de processo civil regido pela ideia de colaboração (art. 6.º, CPC/2015), jamais a ausência de preparo pode levar à deserção do recurso e conseguinte inadmissibilidade sem que o órgão jurisdicional, previamente, intime a parte para efetivação do depósito correspondente¹⁰⁰. Trata-se de dever de prevenção do órgão jurisdicional. Viola o dever de diálogo, cujo fundamento está no direito fundamental ao contraditório (art. 5.º, LV, CF/1988), a decretação de deserção de recurso sem que a parte tenha sido previamente intimada para efetivar o preparo.

É por essa razão que o art. 1.007, §§ 2.º e 4.º, CPC/2015, determinam a viabilização do preparo insuficiente ou inexistente pela parte. Na mesma linha, o equívoco no preenchimento da guia de custas não implicará a aplicação da pena de deserção, cabendo ao relator, na hipótese de dúvida quanto ao recolhimento, intimar o recorrente para sanar o vício no prazo de 5 (cinco) dias (art. 1.007, § 7.º, CPC/2015). Apenas quando não preparado o recurso depois de expressamente indicada a sua necessidade é que se legitima o seu não conhecimento. É vedada, no entanto, a complementação de preparo parcial realizado em decorrência do dever de prevenção judicial (art. 1.007, § 5.º, CPC/2015). Provando o recorrente justo impedimento, o relator relevará a pena de deserção, por decisão irrecorrível, fixando-lhe prazo de 5 (cinco) dias para efetuar o preparo (art. 1.007, § 6.º, CPC/2015).

Art. 1.008. O julgamento proferido pelo tribunal substituirá a decisão impugnada no que tiver sido objeto de recurso.

1. No que tiver sido objeto. O julgamento proferido pelo tribunal substituirá a decisão recorrida no que tiver sido objeto de recurso. Se o recurso é parcial, apenas a parcela da decisão a que se refere o recurso substituirá a decisão recorrida. Opera, aí, o efeito substitutivo do recurso.

É irrelevante que a decisão no recurso seja no mesmo sentido da decisão recorrida para efeitos de substituição – se a decisão do tribunal apreciou o mérito do recurso, há substituição. O que interessa para que se dê a substituição de uma decisão pela outra é que o recurso tenha sido conhecido¹⁰¹. Recurso inadmissível não opera o efeito substitutivo. O efeito substitutivo do recurso é fundamental, por exemplo, para fixação da competência para propositura de ação rescisória. Nesse sentido, “a competência para a ação rescisória não é do Supremo Tribunal Federal, quando a questão federal, apreciada no recurso extraordinário ou no agravo de instrumento, seja diversa da que foi suscitada no pedido rescisório” (Súmula 515, STF). A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça inclina-se igualmente nessa mesma direção¹⁰².

1

José Carlos Barbosa Moreira, *Comentários ao Código de Processo Civil*, 15. ed., Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 233, vol. V.

2

Para a doutrina italiana, Augusto Cerino-Canova, “*Impugnazioni Civili*”, *Studi di Diritto Processuale Civile*. Padova: Cedam, 1992, p. 242; para a doutrina alemã, Rosenberg, Schwab e Gottwald, *Zivilprozessrecht*, 17. ed., München: C. H. Beck, 2010, p. 766.

3

Prova disso é que a doutrina que se ocupa dos recursos desde o ponto de vista do direito comparado sempre ressalta como característica comum a necessidade de reexame por órgão jurisdicional distinto, organizando a partir daí o exame da matéria: entre outros, Dondi, Ansanelli e Comoglio, *Processi Civili in Evoluzione – Una Prospettiva Comparata*. Milano: Giuffrè, 2015, p. 291-306; Uzelac e van Rhee, “Appeals and Other Means of Recourse against Judgments in the Context of the Effective Protection of Civil Rights and Obligations”, in Uzelac e van Rhee (coords.), *Nobody’s Perfect – Comparative Essays on Appeals and Other Means of Recourse against Judicial Decisions in Civil Matters*. Cambridge: Intersentia, 2014, p. 3-13; Helen Hershkoff, “Appeal”, in Chase e Hershkoff (coords.), *Civil Litigation in Comparative Context*. St. Paul: Thomson-West, 2007, p. 327-328.

4

Luigi Paolo Comoglio, “Note Riepilogative su Azione e Forme di Tutela, nell’Ottica della Domanda Giudiziale”, *Rivista di Diritto Processuale*. Padova: Cedam, 1993. Sobre o direito de ação em geral, com amplas referências bibliográficas, Marinoni, Arenhart e Mitidiero, *Novo Curso de Processo Civil*. São Paulo: Ed. RT, 2015, vol. I.

5

A percepção dessa ausência de uniformidade na estrutura do direito ao recurso é oriunda de um debate que pode ser verificado em Alvaro de Oliveira e Mitidiero, *Curso de Processo Civil*. São Paulo: Atlas, 2012, p. 164, nota 2, vol. II, em Didier Júnior e Carneiro da Cunha, *Curso de Direito Processual Civil*, 13. ed., Salvador: JusPodivm, 2016, p. 87-89, vol. III, em Fredie Didier Júnior, “O Direito de Ação como Complexo de Situações Jurídicas”, *Revista de Processo*, São Paulo: Ed. RT, 2012, 210, e em Marinoni, Arenhart e Mitidiero, *Novo Curso de Processo Civil*, cit., vol. II.

6

José Rogério Cruz e Tucci e Luiz Carlos de Azevedo, *Lições de História do Processo Civil Romano*. São Paulo: Ed. RT, 2001, p. 163-174.

7

Clóvis Kemmerich, *O Direito Processual da Idade Média*. Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris Editor, 2006, p. 131-132.

8

Daniel Mitidiero, *Colaboração no Processo Civil* – Pressupostos Sociais, Lógicos e Éticos, 3. ed.; São Paulo: Ed. RT, 2015, p. 52-100. Amplamente sobre a apelação no direito romano, indicando-a logo de início como um dos traços mais importantes e típicos do processo da *cognitio extra ordinem*, consulte-se o clássico trabalho de Riccardo Orestano, *L' Appello Civile in Diritto Romano*, 2. ed., Torino: Giappichelli, 1953.

9

Vittorio Denti, *La Giustizia Civile*, 2. ed., Bologna: Il Mulino, 2004, p. 53-54; 62-63.

10

Uzelac e van Rhee, “Appeals and Other Means of Recourse against Judgments in the Context of the Effective Protection of Civil Rights and Obligations”, in Uzelac e van Rhee (coords.), *Nobody's Perfect* – Comparative Essays on Appeals and Other Means of Recourse against Judicial Decisions in Civil Matters. Cambridge: Intersentia, 2014, p. 4.

11

Sobre o assunto, Dondi, Ansanelli e Comoglio, *Processi Civili in Evoluzione* – Una Prospettiva Comparata. Milano: Giuffrè, 2015, p. 291-306; Remo Caponi, “*L' Appello nel Sistema delle Impugnazioni Civili (Note di Comparazione Anglo-Tedesca)*”, *Rivista di Diritto Processuale*. Padova: Cedam, 2009.

12

Araken de Assis, *Manual dos Recursos*, 7. ed., São Paulo: Ed. RT, 2015, p. 927 e ss.; Nelson Nery Júnior, *Teoria Geral dos Recursos*, 7. ed., São Paulo: Ed. RT, 2014, p. 90 e ss..

13

Notoriamente crítico quanto ao critério da finalidade, José Carlos Barbosa Moreira, *Comentários ao Código de Processo Civil*, 15. ed., Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 255-256, vol. V; ao que parece, seguem a mesma linha Didier Júnior e Carneiro da Cunha, *Curso de Direito Processual Civil*, 13. ed., Salvador: JusPodivm, 2016, p. 95-98, vol. III, na medida em que se limitam a arrolar como critérios para a classificação dos recursos a extensão da matéria (total ou parcial) e a fundamentação permitida (livre ou vinculada).

14

Na doutrina italiana, a distinção entre recursos ordinários e recursos extraordinários leva em consideração a existência ou não de trânsito em julgado da decisão sujeita à impugnação: recursos ordinários são aqueles que impedem o trânsito em julgado, ao passo que os recursos extraordinários são aqueles que o pressupõem (Piero Calamandrei, *La cassazione civile*, in *Opere Giuridiche*. Napoli: Morano Editore, 1976, p. 207-209, vol. VII). Essa maneira de compreendê-los, porém, não serve para sistematizar o direito brasileiro, em que todas as figuras recursais impedem o trânsito em julgado da decisão recorrida (José Carlos Barbosa Moreira, *Comentários ao Código de Processo Civil*, 15. ed., Rio de Janeiro: Forense,

2009, p. 255, vol. V; Ovídio Baptista da Silva, *Curso de Processo Civil*, 5. ed., São Paulo: Ed. RT, 2000, p. 411-412, vol. I). É tradicional na doutrina brasileira, porém, o emprego dessa divisão para ilustrar as diferentes funções que esses recursos desempenham (Araken de Assis, *Manual dos Recursos*. São Paulo: Ed. RT, 2007, p. 52-53; Sérgio Porto e Daniel Ustároz, *Manual dos Recursos Cíveis*. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2007, p. 135-136).

15

Nessa linha, amplamente, Luiz Guilherme Marinoni. *O STJ enquanto Corte de Precedentes*, cit.; Daniel Mitidiero, *Cortes Superiores e Cortes Supremas – Do Controle à Interpretação, da Jurisprudência ao Precedente*, cit.

16

Amplamente, José Henrique Mouta Araújo. *Coisa Julgada Progressiva & Resolução Parcial do Mérito, passim*.

17

Súmula 401, STJ: “o prazo decadencial da ação rescisória só se inicia quando não for cabível qualquer recurso do último pronunciamento judicial”.

18

Amplamente, Mônica Bonetti Couto. *Recurso Adesivo – Um Exame à Luz da Teoria Geral dos Recursos*. Curitiba: Juruá, 2007. Rigorosamente, a propósito, não se trata de recurso adesivo (a parte contrária não adere ao recurso da outra): trata-se de recurso contraposto (José Carlos Barbosa Moreira, *Comentários ao Código de Processo Civil*, 15. ed., Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 313, vol. V).

19

Mauro Barberis, *Manuale di filosofia del diritto*. Torino: Giappichelli, 2011, p. 159; Humberto Ávila, *Teoria dos Princípios*, 15. ed., São Paulo: Malheiros, 2014, p. 55-60.

20

Marinoni, Arenhart e Mitidiero. *Novo Curso de processo Civil*. São Paulo: Ed. RT, 2015, vol. I. Amplamente, Humberto Ávila, *Teoria dos Princípios*, 15. ed., São Paulo: Malheiros, 2014, p. 60 e ss..

21

Na esteira, aliás, do que se encontra em Daniel Mitidiero, *Colaboração no Processo Civil*, cit.

22

Assim, STF, 1.^a Turma, RE 357.311/SP, rel. Min. Moreira Alves, j. 19.11.2002, DJ 21.02.2003, p. 44; contra, Ingo Sarlet, “Valor de Alçada e Limitação ao Acesso ao Duplo Grau de Jurisdição: Problematização em Nível

Constitucional à Luz de um Conceito Material de Direitos Fundamentais”, Ajuris, Porto Alegre, 1996, n. 66; Sérgio Mattos, *Devido Processo Legal e Proteção de Direitos*, Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2009. Sobre o tema, ainda, Sarlet, Marinoni e Mitidiero. *Curso de Direito Constitucional*, 5. ed., São Paulo: Saraiva, 2016.

23

O índice não mais existe, tendo valor irrisório, de modo que a hipótese se tornou meramente acadêmica.

24

Súmula 640 do STF: “É cabível recurso extraordinário contra decisão proferida por juiz de primeiro grau nas causas de alçada, ou por turma recursal de juizado especial cível e criminal”.

25

Isso porque, como se verá diante, as cortes supremas (Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal), existentes após o julgamento do recurso de apelação pelo tribunal, somente são acessíveis em circunstâncias especiais, presentes certos requisitos constitucionais próprios, o que certamente restringe a possibilidade de recursos nesses casos.

26

Casos em que, por razão evidente, especialmente decorrentes da existência de lei expressa, não haveria ofensa ao princípio do juiz natural.

27

Sobre a fungibilidade recursal, Rita de Cássia Corrêa de Vasconcelos, *Princípio da Fungibilidade – Hipóteses de Incidência no Processo Civil Brasileiro Contemporâneo*, São Paulo: Ed. RT, 2007.

28

Nesse sentido, STJ, 4.^a Turma, rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, AGA 126734/SP, DJU 18.08.1997; STF, 2.^a Turma, rel. Min. Maurício Corrêa, RHC 74.044/CE, DJU 20.09.1996.

29

José Rogério Cruz e Tucci e Luiz Carlos de Azevedo. *Lições de História do Processo Civil Lusitano*, São Paulo: Ed. RT, 2009, p. 232-234.

30

No Código de 1939, a propósito, a questão não era pacífica. Entendia-se, porém, mesmo na ausência de norma expressa, pela proibição da *reformatio in pejus*, conforme José Carlos Barbosa Moreira. *Comentários ao Código de Processo Civil*, 15. ed., Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 435-436, vol. V.

Nicolò Trocker, *Processo Civile e Costituzione*. Milano: Giuffrè, 1974, p. 645.

Sobre o assunto, longamente, José Carlos Barbosa Moreira, *Comentários ao Código de Processo Civil*, 15. ed., Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 261 e ss., vol. V; aplicando a proposta ao processo como um todo, Fredie Didier Júnior, *Pressupostos Processuais e Condições da Ação – O Juízo de Admissibilidade do Processo*, São Paulo: Saraiva, 2005.

Assim, por exemplo, de acordo com o STJ, é terceiro prejudicado, e tem legitimidade para recorrer: 1. o servidor nomeado, diante da decisão que anula o concurso no qual foi aprovado, proferida em processo de que não participou (STJ, 5.^a Turma, RMS 18.858/MG, rel. Min. José Arnaldo da Fonseca, *DJU* 01.08.2005); 2. o arrematante que não foi réu nos embargos à arrematação julgados procedentes (STJ, 3.^a Turma, REsp 316.441/RJ, rel. Min. Antônio de Pádua Ribeiro, *DJU* 21.06.2004); 3. o credor que vê o bem penhorado para satisfazer seu crédito alienado em outro processo, em transação homologada pelo juiz (STJ, 3.^a Turma, REsp 415.962/SP, rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, *DJU* 10.03.2003); 4. o fiador, diante da procedência da ação de cobrança dos aluguéis, proposta apenas contra o inquilino (STJ, 6.^a Turma, REsp 361.738/RJ, rel. Min. Fernando Gonçalves, *DJU* 06.05.2002); 5. o sujeito que teve bens seus constritos em processo judicial de que não participou (STJ, 3.^a Turma, REsp 329.513/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, *DJU* 11.03.2002); 6. o banco que recebeu determinação judicial para corrigir valores de determinada maneira, resultantes de depósito feito em processo do qual não era parte (STJ, 4.^a Turma, REsp 154.675/SP, rel. Min. Barros Monteiro, *DJU* 27.03.2000); 7. o sócio, diante da decisão que declara a falência da sociedade que integrou (STJ, 3.^a Turma, REsp 177.014/SP, rel. Min. Nilson Naves, *DJU* 25.10.1999); 8. o proprietário atingido por ação civil pública julgada procedente, que impede a concessão de alvará para construir na zona territorial de sua propriedade (STJ, 1.^a Turma, REsp 193.846/SC, rel. Min. Milton Luiz Pereira, *DJU* 07.06.1999); 9. o endossatário da duplicata, diante da anulação do título em processo em que foi réu apenas o endossante (STJ, 3.^a Turma, REsp 40.185/MG, rel. Min. Cláudio Santos, *DJU* 28.03.1994). Na doutrina, amplamente, Fredie Didier Júnior, *Recurso de Terceiro*, 2. ed., São Paulo: Ed. RT, 2005.

Conforme a Súmula 99 do STJ, “o Ministério Público tem legitimidade para recorrer no processo em que oficiou como fiscal da lei, ainda que não haja recurso da parte”. Como se vê, o art. 996, *in fine*, CPC/2015, encampou expressamente a orientação jurisprudencial

Por exemplo, art. 3.º, § 2.º, da Lei 11.417, de 2006: “No procedimento de edição, revisão ou cancelamento de enunciado da Súmula Vinculante, o relator poderá admitir, por decisão irrecorrível, a manifestação de terceiros na questão, nos termos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal”.

Sérgio Cruz Arenhart, “O Recurso de Terceiro Prejudicado e as Decisões Vinculantes”, in Wambier e Nery Júnior (coords.), *Aspectos Polêmicos e Atuais dos Recursos Cíveis e Assuntos Afins*, São Paulo: Ed. RT, 2007, p. 424 e ss., vol. XI.

37

STJ: “Processual civil. Embargos de declaração. Erro material. Recurso especial intempestivo. Reconhecimento posterior. Possibilidade. Embargos acolhidos, com efeitos modificativos. 1. A tempestividade é um dos pressupostos recursais extrínsecos e, tratando-se de matéria de ordem pública, pode ser reconhecida a qualquer tempo pelo órgão julgador. 2. A intimação pessoal de representante da Fazenda Nacional, ainda que realizada por mandado judicial cumprido por oficial de justiça, terá como termo inicial do prazo recursal a data de sua efetivação, e não a data da juntada do mandado aos autos. Precedentes do STJ. 3. Verificada a intempestividade do recurso especial em sede de embargos de declaração, impõe-se a correção do erro material, com o não conhecimento do recurso e consequente anulação das decisões que analisaram o mérito recursal. 4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, restando prejudicadas as demais alegações deduzidas pela embargante” (STJ, 1.^a Turma, rel. Min. Denise Arruda, EAREsp 310435, DJ 20.09.2004).

38

A jurisprudência tem entendido, porém, que, ainda quando haja litisconsórcio, se apenas um deles sucumbiu na decisão, não se aplica a duplicação dos prazos para recursos, já que os outros não terão interesse recursal (v.g., STJ, 3.^a Turma, REsp 864.787/DF, rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, DJU 06.08.2007, p. 488; STJ, Corte Especial, EREsp 222.405/SP, rel. para o acórdão Min. Ari Pargendler, DJU 21.03.2005, p. 201). Semelhante solução foi expressamente adotada pelo novo Código a propósito do oferecimento de defesa (“cessa a contagem do prazo em dobro se, havendo apenas 2 (dois) réus, é oferecida defesa por apenas um deles”, art. 229, § 1.^o), o que analogamente sugere a adequação da mesma solução para o direito recursal.

39

Luiz Guilherme Marinoni, *O STJ enquanto Corte de Precedentes*, cit.; Id., *Precedentes Obrigatórios*, cit.; Daniel Mitidiero, *Cortes Superiores e Cortes Supremas*, cit.; Id., *Precedentes*, cit.

40

Daniel Mitidiero, *Colaboração no Processo Civil*, 3. ed., São Paulo: Ed. RT, 2015.

41

Nessa mesma linha, Eduardo Talamini e Felipe Wladeck, in Bueno, Cássio Scarpinella (coord.), *Comentários ao Código de Processo Civil*. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 293, vol. IV.

42

Nelson Nery Jr., *Princípios Fundamentais – Teoria Geral dos Recursos*, cit., p. 408 e ss..

43

Luiz Guilherme Marinoni, *Tutela Antecipatória, Julgamento Antecipado e Execução Imediata da Sentença*, cit.; Daniel Mitidiero, *Antecipação da Tutela*, cit.

44

Paula Costa e Silva, *Acto e processo*, p. 98 e ss.; Antonio do Passo Cabral, *Nulidades no Processo Moderno*, Rio de Janeiro: Forense, 2009.

45

José Carlos Barbosa Moreira, *Comentários ao Código de Processo Civil*, 15. ed., Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 277, vol. V.

46

STJ, 2.^a Turma, REsp 143.028/DF, rel. Min. Ari Pargendler, j. 03.11.1998, DJ 18.12.1998, p. 319.

47

STJ, 1.^a Turma, AgRg no Ag 744.929/PR, rel. Min. José Delgado, j. 20.06.2006, DJ 03.08.2006, p. 210.

48

STJ, 5.^a Turma, AgRg no Ag 697.826/RJ, rel. Min.. Hélio Quaglia Barbosa, j. 11.04.2006, DJ 15.05.2006, p. 275.

49

Nessa linha, Eduardo Talamini e Felipe Wladeck, in Cássio Scarpinella Bueno (Coord.), *Comentários ao Código de Processo Civil*. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 298, vol. IV.

50

Enrico Tullio Liebman, *Manual de Direito Processual Civil*, tradução de Cândido Rangel Dinamarco, Rio de Janeiro: Forense, 1984, p. 156, vol. I.

51

É a conhecida lição de José Carlos Barbosa Moreira, *Comentários ao Código de Processo Civil*, 15. ed., Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 301-302, vol. V.

52

Entendendo a coisa julgada como escopo do processo civil, James Goldschmidt, *Der Prozess als Rechtslage*, Berlin: Springer, 1925, p. 151 e ss.

53

Assim, Didier Júnior e Carneiro da Cunha, *Curso de Direito Processual Civil*, 13. ed., Salvador: JusPodivm, 2016, p. 117, vol. III.

54

STJ, 3.^a Turma, REsp 23.967/SP, rel. Min.. Waldemar Zveiter, j. 15.09.1992, *DJ* 03.11.1992, p. 19.764.

55

STJ, 1.^a Turma, REsp 853.139/RS, rel. Min.. Teori Zavascki, j. 24.10.2006, *DJ* 16.11.2006, p. 234.

56

STJ, 4.^a Turma, REsp 696.934/PB, rel. Min.. Hélio Quaglia Barbosa, j. 15.05.2007, *DJ* 04.06.2007, p. 358.

57

Amplamente, Fredie Didier Júnior, *Recurso de Terceiro*, 2. ed., São Paulo: Ed. RT, 2009.

58

STJ, 5.^a Turma, RMS 18.858/MG, rel. Min. José Arnaldo da Fonseca, j. 07.06.2005, *DJ* 01.08.2005, p. 479.

59

STJ, 3.^a Turma, REsp 316.441/RJ, rel. Min. Antônio de Pádua Ribeiro, j. 25.05.2004, *DJ* 21.06.2004, p. 214.

60

STJ, 3.^a Turma, REsp 415.962/SP, rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, j. 06.12.2002, *DJ* 10.03.2003, p. 190.

61

STJ, 6.^a Turma, REsp 361.738/RJ, rel. Min. Fernando Gonçalves, j. 18.04.2002, *DJ* 06.05.2002, p. 340.

62

STJ, 3.^a Turma, REsp 329.513/SP, rel. Min. Nancy Andrichi, j. 06.12.2001, *DJ* 11.03.2002, p. 254.

63

STJ, 4.^a Turma, REsp 154.675/SP, rel. Min. Barros Monteiro, j. 02.06.1998, *DJ* 27.03.2000, p. 107.

64

STJ, 3.^a Turma, REsp 177.014/SP, rel. Min. Nilson Naves, j. 16.08.1999, *DJ* 25.10.1999, p. 79.

65

STJ, 1.^a Turma, REsp 193.846/SC, rel. Min. Milton Luiz Pereira, j. 13.04.1999, *DJ* 07.06.1999, p. 57.

66

STJ, 3.^a Turma, REsp 40.185/MG, rel. Min. Cláudio Santos, j. 24.02.1994, *DJ* 28.03.1994, p. 6.319.

67

STJ, 4.^a Turma, REsp 696.934/PB, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, j. 15.05.2007, *DJ* 04.06.2007, p. 358.

68

STJ, 4.^a Turma, REsp 410.793/SP, rel. Min. Jorge Scartezzini, j. 28.09.2004, *DJ* 06.12.2004, p. 316.

69

STJ, 2.^a Turma, REsp 259.981/SP, rel. Min. Eliana Calmon, j. 18.04.2004, *DJ* 20.09.2004, p. 219.

70

Amplamente, Carlos Silveira Noronha, *Do Recurso Adesivo*, 2. ed., Rio de Janeiro: Forense, 1987.

71

José Carlos Barbosa Moreira, *Comentários ao Código de Processo Civil*, 15. ed., Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 314-316, vol. V.

72

STJ, 1.^a Turma, REsp 739.632/RS, rel. Min. Luiz Fux, j. 15.05.2007, *DJ* 11.06.2007, p. 268.

73

STJ, 2.^a Turma, REsp 591.691/BA, rel. Min. Franciulli Netto, j. 19.08.2004, *DJ* 01.02.2005, p. 495.

74

STJ, 5.^a Turma, REsp 467.110/MG, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 12.09.2006, *DJ* 09.10.2006, p. 339.

75

STJ, 2.^a Turma, AgRg no AgRg no Ag 849.560/MG, rel. Min. Herman Benjamin, j. 11.09.2007, *DJ* 22.10.2007, p. 236.

76

STJ, 2.^a Turma, REsp 970.502/CE, rel. Min. Castro Meira, j. 04.10.2007, *DJ* 18.10.2007, p. 343.

77

STJ, Corte Especial, AgRg no EREsp 611.395/MG, rel. Min. Gilson Dipp, j. 07.06.2006, *DJ* 01.08.2006, p. 333.

78

STJ, 2.^a Turma, AgRg no Ag 879.069/RN, rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 28.08.2007, *DJ* 17.09.2007, p. 241.

79

STJ, 5.^a Turma, AgRg no Ag 810.768/DF, rel. Min. Félix Fischer, j. 15.02.2007, *DJ* 02.04.2007, p. 302.

80

STJ, 2.^a Turma, REsp 864.579/SP, rel. Min. Eliana Calmon, j. 08.05.2007, *DJ* 29.05.2007, p. 276.

81

STJ, 1.^a Turma, AgRg no REsp 136.792/SP, rel. Min. Milton Luiz Pereira, j. 19.11.1998, *DJ* 09.08.1999, p. 153.

82

STJ, 1.^a Turma, REsp 7.243/RJ, rel. Min. Milton Luiz Pereira, j. 07.06.1993, *DJ* 02.08.1993, p. 14.214.

83

STJ, 1.^a Turma, RMS 20.582/GO, rel. Min. Francisco Falcão, rel. para acórdão Min. Luiz Fux, j. 18.09.2007, *DJ* 18.10.2007, p. 263.

84

STJ, 3.^a Turma, REsp 21.323/GO, rel. Min. Waldemar Zveiter, j. 16.06.1992, *DJ* 24.08.1992, p. 12.998.

85

STJ, 2.^a Turma, AgRg no REsp 382.236/RS, rel. Min. Eliana Calmon, j. 13.05.2003, *DJ* 02.06.2003, p. 256.

86

STJ, 1.^a Turma, EDcl no REsp 38.924/SP, rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j. 09.02.1994, *DJ* 14.03.1994, p. 4.478.

87

É a solução que sugerimos: Luiz Guilherme Marinoni, *O STJ enquanto Corte de Precedentes*, cit.; Daniel Mitidiero, *Cortes Superiores e Cortes Supremas*, cit.

88

Contra, STJ, 1.^a Turma, AgRg no Ag 725.566/DF, rel. Min. Luiz Fux, j. 06.06.2006, *DJ* 01.08.2006, p. 375.

89

STJ, 2.^a Turma, REsp 359.555/CE, rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 07.03.2006, *DJ* 06.04.2006, p. 253.

90

STJ, 1.^a Turma, AgRg no Ag 703.638/SP, rel. Min. Denise Arruda, j. 21.09.2006, *DJ* 23.10.2006, p. 262.

91

STJ, 2.^a Turma, REsp 193.201/SP, rel. Min. Franciulli Netto, j. 02.05.2000, *DJ* 29.05.2000, p. 140.

92

STJ, 2.^a Turma, AgRg no Ag 448.276/SP, rel. Min. Castro Meira, j. 26.06.2003, *DJ* 12.08.2003, p. 215.

93

STJ, Corte Especial, AgRg no EREsp 604.140/RJ, rel. Min. Paulo Gallotti, j. 23.11.2006, *DJ* 18.12.2006, p. 277.

94

STJ, Corte Especial, AgInt no AREsp 957.821/MS, rel. Min. Raul Araújo, rel. para Acórdão Min. Nancy Andrighi, j. 20.11.2017, *DJe* 19.12.2017.

95

STJ, 6.^a Turma, REsp 209.336/SP, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 08.03.2007, *DJ* 26.03.2007, p. 291.

96

STJ, 2.^a Turma, REsp 181.788/SC, rel. Min. Paulo Gallotti, j. 06.04.2000, *DJ* 15.05.2000, p. 150.

97

STJ, 2.^a Turma, REsp 292.596/RJ, rel. Min. Franciulli Netto, j. 25.11.2003, *DJ* 10.05.2007, p. 362.

98

STJ, Corte Especial, EREsp 404.777/DF, rel. Min. Fontes de Alencar, rel. para acórdão Min. Francisco Peçanha Martins, j. 03.12.2003, *DJ* 11.04.2005, p. 169.

99

STJ, 4.^a Turma, REsp 924.649/RS, rel. Min. Aldir Passarinho Júnior, j. 17.05.2007, *DJ* 06.08.2007, p. 531.

100

Daniel Mitidiero, *Colaboração no Processo Civil*, cit.

101

STJ, 2.^a Turma, REsp 397.384/SC, rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 07.02.2006, *DJ* 20.03.2006, p. 232.

102

STJ, 5.^a Turma, REsp 259.963/SP, rel. Min. Edson Vidigal, j. 22.08.2000, *DJ* 25.09.2000, p. 134.

© desta edição [2018]

Comentários ao CPC - v. XVI - Marinoni - Ed. 2018

TÍTULO II - DOS RECURSOS

CAPÍTULO II. DA APELAÇÃO

Capítulo II. Da Apelação

Art. 1.009. Da sentença cabe apelação.

§ 1.º As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões.

§ 2.º Se as questões referidas no § 1.º forem suscitadas em contrarrazões, o recorrente será intimado para, em 15 (quinze) dias, manifestar-se a respeito delas.

§ 3.º O disposto no *caput* deste artigo aplica-se mesmo quando as questões mencionadas no art. 1.015 integrarem capítulo da sentença.

1. Apelação. A apelação é o mais tradicional recurso no processo civil.¹ Trata-se do recurso padrão, cuja origem remonta à *appellatio* do processo civil romano da *cognitio extra ordinem*, sendo por essa razão sua disciplina aplicável no que couber também aos demais recursos.²

Do ponto de vista do debate proporcionado na apelação, existem basicamente duas soluções que emergem do direito comparado: a configuração da apelação como *novum iudicium* ou como *revisio prioris instantiae*. No primeiro caso, admite-se ampla rediscussão da causa, inclusive com a formulação de novas alegações de fato não apresentadas por qualquer razão ao juízo de primeiro grau (ampla admissão do *ius novorum*). No segundo, restringe-se o debate apenas àquilo que já foi deduzido e decidido perante o juízo de primeiro grau, ressalvadas exceções ligadas à impossibilidade de alegação (como sucede com o direito brasileiro, art. 1.014, CPC/2015).³

A tendência que se verifica no direito comparado está não só na adoção do modelo da apelação *revisio prioris instantiae*, mas inclusive da diminuição da área de questões suscetíveis de discussão perante o tribunal.⁴ Embora o direito brasileiro tenha desenhado a apelação como *revisio prioris instantiae* (arts. 1.013 e 1.014, CPC/2015),⁵ não deu o passo adiante a fim de restringir a área de impugnabilidade da sentença.

Da sentença – terminativa (art. 485, CPC/2015) ou definitiva (art. 487, CPC/2015) – cabe apelação no prazo de 15 (quinze) dias (art. 1.003, § 5.º, CPC/2015). Pouco importa, aliás, que o juiz tenha resolvido na sentença questões que, acaso decididas em momento anterior do procedimento, desafiariam o recurso de agravo de instrumento: decididas na sentença, o recurso cabível é o de apelação (art. 1.015, § 3.º, CPC/2015). De acordo com o Código de 2015, também das decisões interlocutórias não impugnáveis imediatamente por força de agravo de instrumento caberá o recurso de apelação (art. 1.009, §§ 1.º e 2.º).

É controversa na doutrina a existência ou não de sentenças parciais de mérito no direito brasileiro – sentenças que apreciam definitivamente o mérito da causa incidentalmente.⁶ Reconhecidas ou não, é certo que as decisões definitivas de mérito que o juiz prola ao longo do procedimento (por exemplo, art. 356, CPC/2015) são recorríveis por agravo de instrumento (art. 356, § 5.º, CPC/2015), porquanto o novo Código optou por não introduzir apelações parciais (incidentais, por instrumento) no direito brasileiro. O indeferimento liminar da reconvenção constitui decisão interlocutória e é passível de agravo de instrumento (art. 354, parágrafo único,

CPC). A decisão que exclui um dos litisconsortes do processo, sem extingui-lo, constitui decisão interlocutória, cujo recurso cabível é o agravo de instrumento (art. 1.015, VII, CPC). Porém, a antecipação de tutela concedida na sentença, em atenção à unirrecorribilidade recursal, deve ser combatida apenas com o recurso de apelação (art. 1.013, § 5.º, CPC).

2. Regra da decisão final. No novo Código, além de o recurso de apelação servir para atacar a sentença, ele também visa a impugnar todas as questões decididas ao longo do processo de conhecimento que não comportarem recurso de agravo de instrumento (art. 1.009, § 1.º, CPC/2015). Com isso, ao limitar a recorribilidade das decisões interlocutórias em separado a hipóteses taxativas (art. 1.015, CPC/2015), o novo processo civil brasileiro procura acentuar a oralidade do procedimento comum, aproximando-se da regra da *final decision*⁷ do direito estadunidense (pela qual apenas a sentença final é apelável, nada obstante as várias exceções existentes), cuja proximidade com o processo civil romano pós-clássico nesse particular é notória.⁸

Todas as decisões interlocutórias não passíveis de imediata recorribilidade mediante agravo de instrumento (art. 1.015, CPC/2015) são infensas à preclusão imediata e podem ser debatidas como preliminar de apelação ou de contrarrazões (art. 1.015, §§ 1.º e 2.º, CPC/2015). Em outras palavras, quando há previsão de agravo de instrumento contra a decisão interlocutória, há preclusão imediata, acaso não tenha sido interposto o recurso; quando não há, dá-se a preclusão diferida, isto é, condicionada à não impugnação da questão como preliminar da apelação ou nas suas contrarrazões.⁹ Impugnadas nas contrarrazões, a parte contrária será intimada para contrarrazoar no prazo legal (art. 1.015, § 2.º, CPC/2015).

O art. 1.009, §§ 1.º e 2.º, fala em questões “suscitadas” em “preliminar”. Duas observações: a uma, suscitar aí significa impugnar, isto é, voltar-se contra a solução dada à questão; a duas, preliminar aí não tem o significado técnico de questão preliminar – como a decisão interlocutória ocorreu antes da sentença, a fim de que se possa encadear de forma mais apropriada o debate, o legislador determina que a respectiva irresignação seja exposta antes daquela concernente à sentença.

3. Fundamentos. Na apelação pode-se buscar a substituição da sentença por vício de forma (*error in procedendo*) e/ou por vício de julgamento (*error in judicando*). Vale dizer: por motivos capazes de gerar a sua invalidade e/ou por motivos capazes de apontar a sua injustiça.

Em regra, no direito romano pós-clássico, a *appellatio* constituía o recurso voltado contra a *sententia*, isto é, contra as decisões de mérito que faziam *res judicata*. Em outras palavras, em regra, a apelação tinha por objetivo discutir apenas a justiça da decisão, comportando apenas a alegação de *errores in judicando*. Foi apenas no direito do *jus commune* que a apelação amalgamou também os motivos de nulidade, antes reservados às *querelas nullitatis sanabilis* e *insanabilis*. Em geral, a partir daí a apelação absorveu na tradição romano-canônica tanto os motivos que levam à injustiça como os que levam à invalidade da sentença.¹⁰

Permite-se apontar a inadequação formal da sentença (por exemplo, sentença carente de fundamentação, arts. 93, IX, CF/1988, e 489, §§ 1.º e 2.º, CPC/2015) e a inadequação dos juízos fático-jurídicos ali apresentados (valoração inadequada da prova, inadequada seleção e interpretação da legislação aplicável ao caso etc.). Sentença prolatada com vício de forma deve ser anulada na instância recursal e baixados os autos para prolação de nova decisão no primeiro grau de jurisdição (salvo se aplicável o art. 1.013, § 3.º, CPC/2015). Sentença prolatada com vício de julgamento deve ser simplesmente substituída por outra decisão na instância recursal, que deverá reapreciar o caso apresentado pelas partes.

Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I – os nomes e a qualificação das partes;

II – a exposição do fato e do direito;

III – as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV – o pedido de nova decisão.

§ 1.º O apelado será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 2.º Se o apelado interpuser apelação adesiva, o juiz intimará o apelante para apresentar contrarrazões.

§ 3.º Após as formalidades previstas nos §§ 1.º e 2.º, os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz, independentemente de juízo de admissibilidade.

1. Forma. O art. 1.010 do CPC impõe a forma com que deve o recorrente redigir o recurso de apelação. Concerne, portanto, à regularidade formal do recurso. Seu não atendimento leva ao não conhecimento do recurso por ausência de requisito extrínseco de admissibilidade recursal, acaso não sanado oportunamente (art. 932, parágrafo único, CPC/2015). É imprescindível, porém, que seja viabilizada a possibilidade de sanação do vício, sob pena de violação do dever de colaboração do juiz, especificamente do dever de prevenção e da frustração da primazia do mérito aí implicada (arts. 6.º, 317 e 932, parágrafo único, CPC/2015).

O art. 1.010, incs. II e III, do CPC/2015 impõe ao recorrente o ônus de contrastar efetivamente a sentença nas suas razões recursais. Já se decidiu que “ao interpor o recurso de apelação, deve o recorrente impugnar especificamente os fundamentos da sentença, não sendo suficiente a mera remissão aos termos da petição inicial e a outros documentos constantes nos autos”.¹¹ Ainda: “a reprodução na apelação das razões já deduzidas na contestação não determina a negativa de conhecimento do recurso, especialmente quando as razões ali esposadas são suficientes à demonstração do interesse pela reforma da sentença”.¹² Sendo o processo uma comunidade argumentativa de trabalho, um diálogo devidamente regrado, as posições do juiz e das partes evoluem ao longo do procedimento em contraditório. Assim como há ônus de alegar e dever de decidir no primeiro grau, a passagem para o segundo grau de jurisdição é marcada pela existência de um ônus de impugnação específica do recorrente a respeito dos motivos que o levam a recorrer.

2. Independentemente de juízo de admissibilidade. A apelação deve ser interposta mediante petição dirigida ao juiz de primeiro grau (art. 1.010, *caput*, CPC/2015). Depois de oportunizada as contrarrazões (inclusive, se for o caso, a propósito da apelação adesiva, art. 1.010, §§ 1.º e 2.º, CPC/2015), o juiz de primeiro grau remeterá a apelação ao tribunal independentemente de juízo de admissibilidade. O juízo de primeiro grau não tem mais competência para deixar de conhecer o recurso de apelação (art. 1.010, § 3.º, CPC/2015).

3. Possibilidade de retratação. Embalado pela necessidade de sempre que possível prestigiar-se a prolação de decisões de mérito em detrimento de decisões processuais (arts. 6.º, 317 e 932, parágrafo único, CPC/2015), o Código de 2015 ampliou a possibilidade de retratação da sentença: atualmente, todas as sentenças terminativas (art. 485, CPC/2015) são passíveis de retratação (art. 485, § 7.º, CPC/2015). Assim, uma vez interposta a apelação, tem o juiz o prazo de 5 (cinco) dias para retratar-se – apenas não o fazendo é que determinará a intimação da parte contrária para as contrarrazões.

Art. 1.011. Recebido o recurso de apelação no tribunal e distribuído imediatamente, o relator:

I – decidi-lo-á monocraticamente apenas nas hipóteses do art. 932, incisos III a V;

II – se não for o caso de decisão monocrática, elaborará seu voto para julgamento do recurso pelo órgão colegiado.

1. Relator. Recebido o recurso de apelação no tribunal, esse deve ser imediatamente distribuído ao relator, ao qual cumpre exercer todos os poderes inerentes à relatoria (por exemplo, arts. 932 e 933, CPC/2015), inclusive aqueles concernentes à aferição da admissibilidade recursal e atinentes às providências tendentes a evitar a prolação de decisões-surpresas (arts. 10 e 931, CPC/2015). O fato de a decisão encontrar-se sujeita ao recurso de apelação faz com que a sua eficácia não seja produzida (em outras palavras, a apelação é dotada de efeito suspensivo, art.

1.012, CPC/2015).

Todavia, nas hipóteses em que a sentença de primeiro grau tem eficácia imediata, pode a parte interessada postular a concessão de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal ao relator (art. 1.012, § 3.º, CPC/2015). A parte interessada pode buscar a concessão do efeito suspensivo ou a antecipação da tutela recursal dirigindo-se diretamente ao tribunal por petição própria, acaso o recurso ainda não tenha sido remetido (art. 299, parágrafo único, CPC/2015).

2. Decisão monocrática. Pode o relator decidir a apelação monocraticamente a fim de não a conhecer (desde que, em sendo o caso, tenha viabilizado a possibilidade de sanação do vício, art. 932, parágrafo único, CPC/2015, e desde que não seja possível conhecê-la no mérito a fim de beneficiar a parte a que o defeito formal aproveitaria, art. 488, CPC/2015), de negar provimento ou de dar provimento, tudo conforme o art. 932, incs. III a V, do CPC/2015.

Assim como em outras passagens, o art. 1.011, inc. I, do CPC/2015 revela um equívoco de orientação em que incidiu o legislador a respeito do tema dos *precedentes*. O que autoriza o julgamento monocrático do relator não é o fato de a tese do autor encontrar-se fundamentada em “súmulas” e “julgamento de casos repetitivos” (leia-se, incidente de resolução de demandas repetitivas e recursos repetitivos) ou em incidente de “assunção de competência”. É o fato de se encontrar fundamentado em *precedente* do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça ou em *jurisprudência* formada nos Tribunais de Justiça e nos Tribunais Regionais Federais em sede de incidente de resolução de demandas repetitivas ou em incidente de assunção de competência capaz de revelar razões adequadas e suficientes para solução do caso concreto.

O que os arts. 932, incs. III, IV e V, e 1.011, inc. I, do CPC autorizam, portanto, é o julgamento monocrático no caso de haver *precedente* do STF ou do STJ ou *jurisprudência* firmada em incidente de resolução de demandas repetitivas ou em incidente de assunção de competência nos Tribunais de Justiça ou nos Tribunais Regionais Federais. Esses precedentes podem ou não ser oriundos de casos repetitivos e podem ou não ter adequadamente suas razões retratadas em súmulas.

3. Voto. Não sendo o caso de decidir monocraticamente a apelação, o relator elaborará o seu voto a fim de submetê-lo ao debate colegiado. Segue-se à elaboração do voto a inclusão do feito em pauta para o julgamento colegiado.

Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1.º Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

- I – homologa divisão ou demarcação de terras;
- II – condena a pagar alimentos;
- III – extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado;
- IV – julga procedente o pedido de instituição de arbitragem;
- V – confirma, concede ou revoga tutela provisória;
- VI – decreta a interdição.

§ 2.º Nos casos do § 1.º, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença.

§ 3.º O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1.º poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:

I – tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;

II – relator, se já distribuída a apelação.

§ 4.º Nas hipóteses do § 1.º, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.

1. Efeito suspensivo. O direito brasileiro não admite como regra a eficácia imediata da sentença. Vale dizer: não admite como regra, em sendo o caso, o cumprimento imediato da sentença.¹³

De um lado, trata-se de opção evidentemente questionável, na medida em que não permite uma adequada distribuição do peso do tempo no processo de acordo com a evidência da posição jurídica sustentada pela parte. Observe-se que quem tem de suportar o tempo de tramitação do recurso é a parte que dele precisa para lograr uma situação mais vantajosa no processo. De outro lado, essa mesma opção encerra uma incômoda contradição em nosso sistema de tutela dos direitos, porquanto o direito brasileiro, ao mesmo tempo em que admite a eficácia imediata da tutela antecipatória, lastreada em cognição sumária (juízo de probabilidade), não permite, salvo em contadas exceções, a eficácia imediata da sentença de procedência, que tem esteio em cognição exauriente (juízo de verdade). O novo Código perdeu a oportunidade de corrigir essa evidente contradição em nosso sistema. Note-se que a sentença de procedência tem a sua eficácia inibida pela contingência de encontrar-se sujeita ao recurso de apelação. Ao referir que a apelação tem “efeito suspensivo” (art. 1.012, *caput*, CPC/2015), não permite o nosso legislador que a sentença, enquanto sujeita ao recurso de apelação – durante o prazo para sua interposição – e enquanto se aguarda o julgamento do tribunal, produza seus efeitos. Rigorosamente, pois, a apelação não suspende o efeito da sentença de procedência: não permite a sua produção.

2. Cumprimento imediato. Existem situações, contudo, em que a legislação permite a produção de efeitos desde que prolatada a sentença. Sendo o caso, nessas hipóteses será possível o cumprimento imediato da sentença (art. 1.012, § 2.º, CPC/2015). Essas situações estão arroladas no próprio Código de Processo Civil (art. 1.012, CPC/2015) e na legislação extravagante.¹⁴

O recebimento do recurso sem efeito suspensivo tem por objetivo permitir a tutela do direito de forma mais tempestiva, contornando a demora que seria necessária para o julgamento da apelação, concretizando o direito fundamental ao processo com duração razoável (arts. 5.º, LXXVIII, CRFB, e 4.º, CPC/2015). Por vezes, o que determina essa adequação do processo é o direito material posto em juízo (por exemplo, direito aos alimentos); outras vezes, porém, o que interessa é simplesmente uma maior adequação do ônus do tempo do processo (por exemplo, confirmação da antecipação da tutela ou julgamento de improcedência dos embargos do executado). Em todos os casos, porém, o que se procura promover é a tempestividade da tutela jurisdicional.

Dentre as hipóteses do art. 1.012 do CPC/2015, três suscitam desde logo algumas considerações: i) alimentos; ii) embargos do executado; e iii) tutela provisória.

A sentença que condena ao pagamento de alimentos produz efeitos de maneira imediata. Tem o juiz o dever de receber a apelação sem efeito suspensivo. Não interessa a natureza dos alimentos para que incida o art. 1.012, § 1.º, inc. II, do CPC/2015.

O Superior Tribunal de Justiça tem decisões no sentido de que a sentença que majora a prestação alimentar também produz efeitos imediatamente, não tendo efeito suspensivo a apelação que a ataca.¹⁵ Não assim, todavia, consoante a jurisprudência dessa mesma Corte, a sentença que exonera o demandante do dever de pagar alimentos, que desafia recurso de apelação com efeito suspensivo.¹⁶ Se a sentença julga ao mesmo tempo procedente o pedido de reconhecimento de paternidade e o pedido condenatório ao pagamento de alimentos, a “apelação interposta, quanto à condenação à prestação alimentícia, será recebida tão somente no efeito devolutivo”,¹⁷ devendo ser recebida, quanto à parte que julgou o reconhecimento de paternidade, com efeito suspensivo.

A sentença que extingue sem resolução de mérito ou julga improcedente o pedido formulado

nos embargos à execução produz efeitos imediatos, tendo a apelação que ser recebida apenas no efeito devolutivo (art. 1.012, § 1.º, III, CPC/2015). Analogamente, o Superior Tribunal de Justiça sumulou o entendimento de que “a apelação interposta contra sentença que julga embargos à arrematação tem efeito meramente devolutivo” (Súmula 331, STJ).

Normalmente, os embargos à execução são recebidos sem efeito suspensivo. Porém, se recebidos com efeito suspensivo, a sentença de improcedência tem o condão de submeter o exequente ao regime da execução de decisão provisória (art. 520, CPC/2015), que deve ser observado enquanto pendente de julgamento a apelação.

A apelação que ataca a sentença que confirma, concede ou revoga tutela provisória tem de ser recebida apenas no efeito devolutivo (art. 1.012, § 1.º, V, CPC/2017). Note-se que o legislador permite expressamente a possibilidade de concessão de tutela provisória na sentença. Com isso, o legislador visa a prestar tutela imediata às situações em que, nada obstante a ausência de concessão de antecipação da tutela em momento anterior à sentença, a parte ainda necessita de tutela urgente. O juiz aí tem o dever de antecipar a tutela na sentença. Esse dever jurisdicional decorre da necessidade de compreensão do Código de Processo Civil como direito constitucional aplicado, como uma concretização do direito fundamental à tutela jurisdicional adequada e efetiva dos direitos.

3. Efeito suspensivo *ope judicis*. Nas hipóteses em que a sentença é passível de imediato cumprimento (art. 1.012, §§ 1.º e 2.º, CPC/2015), pode o apelante postular a outorga de efeito suspensivo ao apelo justamente para inibir a eficácia da sentença. Nesse caso, o apelante tem o ônus de formular o pedido na forma dos §§ 3.º e 4.º do art. 1.012 do CPC/2015. A concessão de efeito suspensivo *ope judicis* à apelação depende da demonstração da probabilidade de provimento do recurso e da existência de perigo na demora.

Note-se que o legislador aparentemente subordina a concessão de efeito suspensivo à apelação à demonstração de “risco de dano grave ou de difícil reparação” (art. 1.012, § 4.º, CPC/2015). É claro que aí o legislador andou novamente mal: o que interessa para a concessão do efeito suspensivo é o *perigo na demora* – que pode ser um *perigo de ilícito* (tutela contra o ilícito, art. 497, parágrafo único, CPC/2015) ou um *perigo de dano*. Isto é, a caracterização da situação de urgência a partir de um perigo de um ilícito ou de um perigo de dano. Supor, por exemplo, que em uma demanda em que se discute apenas o ilícito é necessário alegar e provar “risco de dano grave ou de difícil reparação” para obtenção de efeito suspensivo na apelação é colocar em discussão tema que não compõe o objeto do processo.

Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

§ 1.º Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado.

§ 2.º Quando o pedido ou a defesa tiver mais de um fundamento e o juiz acolher apenas um deles, a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento dos demais.

§ 3.º Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando:

I – reformar sentença fundada no art. 485;

II – decretar a nulidade da sentença por não ser ela congruente com os limites do pedido ou da causa de pedir;

III – constatar a omissão no exame de um dos pedidos, hipótese em que poderá julgá-lo;

IV – decretar a nulidade de sentença por falta de fundamentação.

§ 4.º Quando reformar sentença que reconheça a decadência ou a prescrição, o tribunal, se

possível, julgará o mérito, examinando as demais questões, sem determinar o retorno do processo ao juízo de primeiro grau.

§ 5.º O capítulo da sentença que confirma, concede ou revoga a tutela provisória é impugnável na apelação.

1. Efeito devolutivo. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria efetivamente impugnada pela parte (*tantum devolutum quantum appellatum* – art. 1.013, *caput*, CPC). Ao que é devolvido ao conhecimento do tribunal pelo efeito devolutivo há proibição de *reformatio in pejus*, na medida em que não se pode admitir que determinada questão levada ao tribunal exclusivamente em função do *interesse* da parte em reexaminá-la possa redundar em seu desfavor.¹⁸

A apelação tem por objeto aquilo que foi decidido pela sentença. O recurso pode atacá-la no todo ou em parte (art. 1.002, CPC). Não se admite, no juízo de apelação, a invocação de causa de pedir estranha ao processo – não decidida, portanto, pela sentença. Há proibição de inovação no juízo de apelo, ressalvado o disposto no art. 1.014 do CPC/2015.

O efeito devolutivo é determinado pelo pedido formulado pela parte na apelação. A *extensão* da cognição do tribunal é determinada nesse momento. Tem-se aí o que a doutrina denomina como extensão do efeito devolutivo (efeito devolutivo horizontal) ou simplesmente efeito devolutivo.¹⁹

A apelação devolve ao conhecimento do tribunal aquilo que foi decidido pela sentença, sendo-lhe vedado, em regra, conhecer de matéria diversa da decidida em primeiro grau de jurisdição – seja na sentença, seja nas decisões interlocutórias não passíveis de recurso imediato. É possível ao tribunal conhecer de matéria diversa da decidida pela sentença nos casos dos arts. 1.009, §§ 1.º e 2.º, e 1.013, §§ 3.º e 4.º, do CPC/2015, que amplia em extensão a cognição do órgão recursal.

2. Efeito translativo. Independentemente de efetiva impugnação pela parte, restam submetidas ao tribunal, em face do efeito translativo, as questões conhecíveis de ofício (por exemplo, arts. 337, § 5.º, 485, § 3.º, 487, II, CPC/2015), “todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado” (art. 1.013, § 1.º, CPC/2015) – vale dizer, ainda que o magistrado tenha se omitido em apreciá-las em sentença, nada obstante suscitadas e discutidas pelas partes no processo, e todos os fundamentos arguidos pelas partes no primeiro grau de jurisdição que podem servir para solução do caso levado a juízo (art. 1.013, § 2.º, CPC/2015).²⁰ Nesse caso, o tribunal pode decidir a respeito sem a proibição de *reformatio in pejus*, já que a matéria é translada ao conhecimento do tribunal independentemente de qualquer manifestação de vontade da parte. Para grifar essa diferença, parte da doutrina costuma falar a propósito em profundidade do efeito devolutivo (efeito devolutivo vertical) ou em efeito translativo.²¹

3. Causa madura. Nos casos de extinção do processo sem resolução de mérito (arts. 485 e 1.013, § 3.º, CPC/2015) e nos casos em que a sentença não resolveu o mérito da causa em toda a sua extensão (como ocorre, por exemplo, quando há o acolhimento de alegação de prescrição ou decadência, arts. 487, II, e 1.013, § 4.º, CPC/2015),²² o tribunal, conhecendo da apelação, poderá julgar desde logo o mérito, se a causa estiver em condições de imediato julgamento.

A aplicação do art. 1.013, § 3.º, do CPC/2015 independe de requerimento da parte.²³ O art. 1.013, § 3.º, do CPC/2015 autoriza que o tribunal julgue desde logo a causa – ainda que a partir de matéria não apreciada em primeiro grau – desde que as partes não tenham nada mais a alegar ou provar. Vale dizer: as causas que admitem a aplicação do art. 1.013, § 3.º, do CPC/2015 são as causas maduras: os seus incisos são apenas exemplos.

Causa madura é aquela cujo processo já se encontra com todas as alegações necessárias feitas e todas as provas admissíveis colhidas. Assim, o que realmente interessa para aplicação do art. 1.013, § 3.º, do CPC/2015 é que a causa comporte imediato julgamento pelo tribunal – por já se encontrar devidamente instruída. Estando madura a causa – observada a necessidade de um processo justo no seu amadurecimento (art. 5.º, LIV, CF/1988) – nada obsta que o tribunal,

conhecendo da apelação, avance sobre questões não versadas na sentença para resolvê-la no mérito.

4. Tutela provisória. O capítulo da sentença que confirma, concede ou revoga a tutela provisória é impugnável mediante apelação (arts. 1.009, § 3.º, e 1.013, § 4.º, CPC/2015). Rigorosamente, trata-se de disposição deslocada: cuidando do cabimento do recurso de apelação, o seu local apropriado é tão somente o art. 1.009 do CPC/2015.

Art. 1.014. As questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior.

1. Questões de fato. A apelação possibilita uma revisão do juízo sentencial (*revisio prioris instantiae*). Não se presta, portanto, como regra, a possibilitar a apreciação de temas novos, não propostos ao juízo de primeiro grau (*novum iudicium*). Todavia, as questões de fato, não propostas no juízo inferior, poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior. Situações excepcionais autorizam esse conhecimento.

Assim, a superveniência do fato à publicação da sentença autoriza a sua invocação na apelação (art. 493, CPC/2015). Se o fato é superveniente, evidentemente não poderia ser alegado em momento anterior. A ignorância do fato pela parte também autoriza a sua alegação na apelação, desde que se possa provar que essa ignorância advém de efetiva impossibilidade em conhecê-lo em momento anterior. A efetiva impossibilidade de comunicação de determinado fato ao advogado ou ao juiz também possibilita a invocação desse mesmo fato na apelação. No entanto, a questão já conhecida pela parte no momento da propositura da demanda ou do oferecimento da defesa e não alegada não pode ser proposta no juízo de apelação.²⁴ É imprescindível que essa impossibilidade decorra de causa objetiva – e não de incúria da parte.

2. Prova nova. A prova nova, surgida posteriormente à prolação da sentença, pode ser produzida perante o tribunal por força do art. 1.014 do CPC/2015. A novidade da prova atesta a impossibilidade de produção em momento anterior, caracterizando a força maior na sua não apresentação.

NOTAS DE RODAPÉ

1

Monograficamente, Flávio Cheim Jorge, *Apelação cível*, São Paulo: Ed. RT, 1998; Rodrigo Barioni, *Efeito devolutivo da apelação civil*, São Paulo: Ed. RT, 2007; Ricardo Aprigliano, *A apelação e seus efeitos*, São Paulo: Atlas, 2003; Gleydson Kleber Lopes de Oliveira, *Apelação no direito processual civil*, São Paulo: Ed. RT, 2009; Fernanda Pantoja, *Apelação cível: novas perspectivas de um antigo recurso – Um estudo crítico de direito nacional e comparado*, Curitiba: Juruá, 2010.

2

Sobre as origens da apelação no direito romano, Riccardo Orestano, *L'appello civile in diritto romano*, 2. ed., Torino: Giappichelli, 1953. Sobre a sua introdução no direito luso-brasileiro, Luiz Carlos de Azevedo, *Origem e introdução da apelação no direito lusitano*, São Paulo: FIEO, 1976.

3

Amplamente, Corrado Ferri, *Profili dell'appello limitato*, Padova: Cedam, 1979.

4

Dondi, Ansanelli e Comoglio, *Processi civili in evoluzione* – Una prospettiva comparata. Milano: Giuffrè, 2015, p. 291-306.

5

Sérgio Bermudes, *Comentários ao Código de Processo Civil*, 2. ed., São Paulo: Ed. RT, 1977, vol. VII, p. 133.

6

Monograficamente, com amplas indicações bibliográficas, Pedro Pozza, *Sentença parcial de mérito*, Curitiba: Juruá, 2015; Sidney Pereira de Souza Júnior, *Sentenças parciais no processo civil* – Consequências no âmbito recursal, São Paulo: Método, 2009.

7

Kevin Clermont, *Principles of civil procedure*, 3. ed., St. Paul: West, 2012, p. 142-149.

8

Sobre o assunto, Mauro Cappelletti, Il processo civile italiano nel quadro della contrapposizione *civil law* – *common law* (Appunti storico-comparativi), *Processo e Ideologie*, Bologna: Il Mulino, 1969, p. 287 e ss. (há tradução disponível em português de Hermes Zaneti Júnior em Mauro Cappelletti, *Processo, ideologias e sociedade*, Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris Editor, 2010, vol. II).

9

Nessa linha, Rodrigo Barioni, Preclusão diferida, o fim do agravo retido e a ampliação do objeto da apelação no novo Código de Processo Civil, *Revista de Processo*, n. 243, São Paulo: Ed. RT, 2015; Didier Júnior e Carneiro da Cunha, *Curso de direito processual civil*, 13. ed., Salvador: JusPodivm, 2016, vol. III, p. 165.

10

É a conhecida lição de Piero Calamandrei, *Soppravvivenza della querela nullitatis nel processo civile vigente*, *Rivista di Diritto Processuale*, Padova: Cedam, 1951.

11

STJ, REsp 722.008/RJ, 5.^a Turma, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 22.05.2007, *DJ* 11.06.2007, p. 353.

12

STJ, REsp 604.548/RS, 3.^a Turma, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 02.12.2004, *DJ* 17.12.2004, p. 536.

13

Sobre o assunto, Federico Carpi, *La provvisoria esecutorietà della sentenza*, Milano: Giuffrè, 1979; Gianpaolo Impagnatiello, *La provvisoria esecuzione e l'inibitoria nel processo civile*, Milano: Giuffrè, 2010; Luiz Guilherme Marinoni, *Tutela antecipatória, julgamento antecipado e execução imediata da sentença*, São Paulo: Ed. RT, 1997; Paulo Lucon, *Eficácia das decisões e execução provisória*, São Paulo: Ed. RT, 2000.

14

Por exemplo, art. 14, §§ 1.º e 3.º, Lei 12.016, de 2009, art. 14, Lei 7.347, de 1985, art. 28, Decreto-lei 3.365, de 1941, art. 58, V, Lei 8.245, de 1991. Quanto ao art. 58, V, Lei 8.245, de 1991 – que não se aplica aos casos ressaltados no parágrafo único do art. 1.º dessa mesma lei –, já se decidiu que se trata de norma especial, a qual exclui a incidência do art. 1.012 do CPC (STJ, AgRg no REsp 665.692/SC, 5.ª Turma, rel. Min. Gilson Dipp, j. 04.11.2004, *DJ* 13.12.2004, p. 445).

15

STJ, REsp 28.144/SP, 4.ª Turma, rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, j. 27.09.1994, *DJ* 24.10.1994, p. 28760.

16

STJ, REsp 9.393/SP, 4.ª Turma, rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, j. 18.06.1991, *DJ* 25.11.1991, p. 17079.

17

STJ, REsp 214.835/PR, 4.ª Turma, rel. Min. Barros Monteiro, j. 23.11.1999, *DJ* 21.02.2000, p. 132.

18

Amplamente, Manoel Caetano Ferreira Filho, *Comentários ao Código de Processo Civil*, São Paulo: Ed. RT, 2000, vol. VII.

19

Falam em extensão do efeito devolutivo ou efetivo devolutivo horizontal, José Carlos Barbosa Moreira, *Comentários ao Código de Processo Civil*, 15. ed., Rio de Janeiro: Forense, 2009, vol. V, p. 430-448; Araken de Assis, *Manual dos recursos*, 7. ed., São Paulo: Ed. RT, 2015, p. 429-449; Didier Júnior e Carneiro da Cunha, *Curso de direito processual civil*, 13. ed., Salvador: JusPodivm, 2016, vol. III, p. 177-184. Fala em efeito devolutivo simplesmente, Nelson Nery Junior, *Princípios fundamentais – Teoria geral dos recursos*, 5. ed., São Paulo: Ed. RT, 2000, p. 415-420.

20

STJ, REsp 556.025/RS, 2.ª Turma, rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 27.02.2007, *DJ* 16.03.2007, p. 332.

21

Falam em profundidade do efeito devolutivo ou efetivo devolutivo vertical, José Carlos Barbosa Moreira,

Comentários ao Código de Processo Civil, 15. ed., Rio de Janeiro: Forense, 2009, vol. V, p. 430-448,; Araken de Assis, *Manual dos recursos*, 7. ed. São Paulo: Ed. RT, 2015, p. 429-449; Didier Júnior e Carneiro da Cunha, *Curso de direito processual civil*, 13. ed., Salvador: JusPodivm, 2016, vol. III, p. 177-184. Fala em efeito translativo, Nelson Nery Junior, *Princípios fundamentais – Teoria geral dos recursos*, 5. ed., São Paulo: Ed. RT, 2000, p. 415-420.

22

STJ, REsp 719.462/SP, 4.ª Turma, rel. Min. Jorge Scartezzini, j. 20.09.2005, *DJ* 07.11.2005, p. 305.

23

STJ, REsp 819.165/ES, 1.ª Turma, rel. Min. Luiz Fux, j. 19.06.2007, *DJ* 09.08.2007, p. 320.

24

STJ, RMS 9.023/DF, 5.ª Turma, rel. Min. Felix Fischer, j. 13.04.1999, *DJ* 07.06.1999, p. 111.

© desta edição [2018]

Comentários ao CPC - v. XVI - Marinoni - Ed. 2018

TÍTULO II - DOS RECURSOS

CAPÍTULO III. DO AGRAVO DE INSTRUMENTO

Capítulo III. Do Agravo de Instrumento

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I – tutelas provisórias;

II – mérito do processo;

III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI – exibição ou posse de documento ou coisa;

VII – exclusão de litisconsorte;

VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1.º;

XII – *(Vetado.)*

XIII – outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

1. Agravo de Instrumento. Ao contrário da apelação, cuja origem romana é notória, o recurso de agravo constitui criação tipicamente lusitana, remontando ao processo anterior às Ordenações Afonsinas, nada obstante apenas nelas comece a “se delinear com maior clareza”.¹ O recurso de agravo surgiu da restrição imposta à possibilidade de apelação contra interlocutórias, corrente no processo comum, firmando-se a partir daí como recurso próprio ao seu ataque.²

2. Cabimento. No Código Buzaid, o agravo era gênero no qual ingressavam duas espécies: o agravo retido e o agravo de instrumento. Toda e qualquer decisão interlocutória era passível de agravo suscetível de interposição imediata por alguma dessas duas formas.³

O Código de 2015 alterou esses dois dados ligados à conformação do agravo: o agravo retido desaparece do sistema (as questões resolvidas por decisões interlocutórias não suscetíveis de agravo de instrumento só poderão ser atacadas nas razões de apelação, art. 1.009, § 1.º, do CPC/2015) e o agravo de instrumento passa a ter cabimento apenas contra as decisões interlocutórias expressamente arroladas pelo legislador (art. 1.015, do CPC/2015). Todas as demais

decisões interlocutórias não imediatamente recorríveis devem ser impugnadas mediante preliminar de apelação ou preliminar das suas contrarrazões (art. 1.009, §§ 1.º e 2.º, do CPC/2015). Com a postergação da impugnação das questões decididas no curso do processo para as razões de apelação ou para as suas contrarrazões e com a previsão de rol taxativo das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, o legislador procurou a um só tempo prestigiar a estruturação do procedimento comum a partir da oralidade (que exige, na maior medida possível, irrecurribilidade em separado das decisões interlocutórias), preservar os poderes de condução do processo do juiz de primeiro grau e simplificar o desenvolvimento do procedimento comum.

3. Rol taxativo. A fim de limitar o cabimento do agravo de instrumento, o legislador vale-se da técnica da enumeração taxativa das suas hipóteses de conhecimento. Isso não quer dizer, porém, que não se possa utilizar a analogia para interpretação das hipóteses contidas nos textos. Como é amplamente reconhecido, o raciocínio analógico perpassa a interpretação de todo o sistema jurídico, constituindo ao fim e ao cabo um elemento de determinação do direito.

O fato de o legislador construir um rol taxativo não elimina a necessidade de interpretação para sua compreensão: em outras palavras, a taxatividade não elimina a equivocidade dos dispositivos e a necessidade de se adscrever sentido aos textos mediante interpretação. Alguns exemplos calham.

O legislador refere que cabe agravo de instrumento, por exemplo, contra as decisões interlocutórias que versarem sobre “tutelas provisórias” (art. 1.015, I, do CPC/2015). Isso obviamente quer dizer que tanto o deferimento como o indeferimento de tutela sumária desafiam agravo de instrumento. Mas não só: também a decisão que posterga a análise do pedido de antecipação da tutela fundada na urgência para depois da contestação versa sobre “tutela provisória”, porque aí há no mínimo um juízo negativo a respeito da urgência na obtenção do provimento.

A decisão interlocutória que defere o pedido de redistribuição do ônus da prova é suscetível de agravo de instrumento (art. 1.015, XI, do CPC/2015), assim como a decisão que nega a redistribuição – em ambos os casos há atribuição de vantagem a um dos litigantes no que tange à regulação do ônus da prova, de modo que a lei disse menos do que gostaria de dizer (*lex minus dixit quam voluit*). Do contrário, há violação da regra da igualdade e, em especial, do direito fundamental à paridade de armas no processo civil (arts. 5.º, I, CF/1988, e 7.º, do CPC/2015).

A questão, hoje, se encontra sob discussão no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. Tendo iniciado pela admissão de agravo de instrumento contra decisão que trata da competência (por analogia com a decisão que rejeita a convenção de arbitragem), a matéria encontra-se afetada à Corte Especial em termos mais amplos, discutindo-se a natureza do rol do art. 1.015, CPC: se taxativo ou exemplificativo⁴. A consequência direta dessa discussão está na preclusão, ou não, da possibilidade de debater as questões suscetíveis de agravo de instrumento no momento do julgamento da apelação. Optando-se pela inexistência de rol taxativo, é preciso salvaguardar a confiança das partes que optaram por não recorrer de determinadas decisões, por força de uma interpretação mais estrita do dispositivo ora comentado⁵ (art. 927, § 3º, CPC).

4. Também caberá. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação, na fase de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário (art. 1.015, parágrafo único, do CPC/2015). No primeiro caso, a justificativa do cabimento do agravo está em que inexistente previsão de apelação no procedimento que visa à liquidação. No segundo e no terceiro, a apelação, embora possa ter lugar, não é usual – em outras palavras, não é um ato necessário do procedimento, salvo para nele colocar fim. O quarto caso justifica-se pela necessidade de imediata revisão das decisões interlocutórias em inúmeras situações que envolvem o processo de inventário.

5. Demais casos. Além dos casos mencionados no art. 1.015, do CPC/2015, também caberá agravo de instrumento: i) decisão que extingue parcialmente o processo (art. 354, parágrafo único, do CPC/2015); e ii) decisão que julga antecipadamente parcela do mérito (art. 356, § 5.º, do CPC/2015).

6. Mandado de segurança. Alguém poderia imaginar que, inexistindo recurso previsto para contrastar determinada decisão interlocutória imediatamente, caberia a impetração de mandado de segurança. É preciso ver, porém, que – bem ou mal – o legislador fez uma *nítida escolha política* ao desenhar o recurso de agravo de instrumento como o delineou. Daí que o cabimento do mandado de segurança está subordinado a uma questão prévia: saber se a escolha realizada pelo legislador é constitucional ou não.

A princípio, não há que se falar em inconstitucionalidade e, portanto, na admissão de mandado de segurança contra decisão interlocutória não passível de recurso imediato. Apenas se verificada violação do núcleo duro do direito fundamental à tutela jurisdicional adequada, efetiva e tempestiva é que se poderá cogitar da impetração de mandado de segurança. Fora daí há afronta à esfera de autonomia do legislador.

Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos:

- I – os nomes das partes;
- II – a exposição do fato e do direito;
- III – as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido;
- IV – o nome e o endereço completo dos advogados constantes do processo.

1. Forma. O agravo de instrumento deve ser interposto diretamente no tribunal competente para dele conhecer. A petição de agravo deve identificar as partes, conter a exposição fático-jurídica da controvérsia e as razões do pedido de reforma da decisão e o nome e o endereço completo dos advogados constantes do processo. A petição de agravo deve atacar efetivamente a decisão que se quer reformada.

O agravo de instrumento que não obedece ao art. 1.016, do CPC/2015, não deve ser conhecido por ausência de regularidade formal da peça recursal – obviamente apenas depois de oportunizada a sanação do vício (art. 932, parágrafo único, do CPC/2015). Todavia, não é necessária a declinação do nome e endereço dos advogados das partes na petição de agravo se é possível recolhê-los em folhas personalizadas utilizadas pelos mesmos ou nas procurações juntadas ao instrumento de agravo.⁶ Se uma das partes ainda não tem procurador constituído nos autos, evidentemente não se pode exigir do agravante que decline o nome e o endereço do advogado do agravado ou junte procuração da outra parte. Não é necessário, nessas condições, que o agravante comprove a ausência de citação da outra parte ou a ausência de advogado no processo mediante certidão, haja vista que inexistente exigência legal nesse sentido.⁷

Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída:

I – obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado;

II – com declaração de inexistência de qualquer dos documentos referidos no inciso I, feita pelo advogado do agravante, sob pena de sua responsabilidade pessoal;

III – facultativamente, com outras peças que o agravante reputar úteis.

§ 1.º Acompanhará a petição o comprovante do pagamento das respectivas custas e do porte de retorno, quando devidos, conforme tabela publicada pelos tribunais.

§ 2.º No prazo do recurso, o agravo será interposto por:

- I – protocolo realizado diretamente no tribunal competente para julgá-lo;

II – protocolo realizado na própria comarca, seção ou subseção judiciárias;

III – postagem, sob registro, com aviso de recebimento;

IV – transmissão de dados tipo fac-símile, nos termos da lei;

V – outra forma prevista em lei.

§ 3.º Na falta da cópia de qualquer peça ou no caso de algum outro vício que comprometa a admissibilidade do agravo de instrumento, deve o relator aplicar o disposto no art. 932, parágrafo único.

§ 4.º Se o recurso for interposto por sistema de transmissão de dados tipo fac-símile ou similar, as peças devem ser juntadas no momento de protocolo da petição original.

§ 5.º Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do *caput*, facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia.

1. Instrumento. O instrumento de agravo deve ser formado com as peças mencionadas no art. 1.017, do CPC/2015. Trata-se de ônus do agravante bem formar o instrumento do agravo. Essas peças podem ser divididas em peças obrigatórias ou em peças facultativas. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os documentos apresentados por cópia para formação do instrumento de agravo gozam de “presunção de veracidade”, se na “oportunidade de resposta a parte contrária não questiona a sua autenticidade”.⁸

2. Obrigatórias. O art. 1.017, I, do CPC/2015, arrola quais são as peças obrigatórias para a formação do instrumento do agravo. As peças obrigatórias são tão somente aquelas mencionadas no art. 1.017, I, do CPC/2015. A certidão da intimação da decisão serve para aferição da tempestividade do recurso – daí que qualquer outro documento oficial que desempenhe a mesma finalidade pode lhe substituir. Inexistindo quaisquer dessas peças, tem o advogado de declará-lo (art. 1.017, II, do CPC/2015).

3. Facultativas. O agravante pode, facultativamente, instruir o agravo com outras peças que “entender úteis” (art. 1.017, III, do CPC/2015). As peças facultativas obviamente não são de juntada obrigatória para a formação do instrumento de agravo. O juízo a respeito da utilidade ou não de outras peças processuais foi expressamente deferido à parte pelo legislador infraconstitucional. Entendendo úteis para o deslinde da controvérsia outras peças que não as juntadas pela parte, o órgão jurisdicional tem o dever de determinar a respectiva juntada em prazo adequado.

4. Obrigatórias, facultativas e colaboração. Rigorosamente, em um processo organizado a partir da ideia de colaboração do juiz para com as partes (art. 6.º, do CPC/2015), próprio do Estado Constitucional, é vedado ao tribunal – qualquer que seja o tribunal – não conhecer de recurso por deficiências formais sanáveis (arts. 932, parágrafo único, e 1.017, § 3.º, do CPC/2015). É por essa razão que os viola o dever de auxílio para com os litigantes o órgão jurisdicional que não admite recurso sem possibilitar a prévia regularização formal do instrumento.

5. Preparo. A petição de agravo de instrumento deve ser acompanhada do respectivo preparo (art. 1.017, § 1.º, do CPC/2015). O preparo deve ser comprovado no momento de interposição do agravo de instrumento (art. 1.007, do CPC/2015).

6. Interposição. O agravo de instrumento será interposto: I – protocolo realizado diretamente no tribunal competente para julgá-lo; II – protocolo realizado na própria comarca, seção ou subseção judiciárias; III – postagem, sob registro, com aviso de recebimento; IV – transmissão de dados tipo fac-símile, nos termos da lei; V – outra forma prevista em lei (art. 1.017, § 2.º, do CPC/2015). Se o recurso for interposto por sistema de transmissão de dados tipo fac-símile ou similar, as peças devem ser juntadas no momento de protocolo da petição original (art. 1.017, § 4.º, do CPC/2015).

7. Processo eletrônico. Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incs. I e II do *caput* do art. 1.017 do CPC/2015, “facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia” (art. 1.017, § 5.º, do CPC/2015).

Art. 1.018. O agravante poderá requerer a juntada, aos autos do processo, de cópia da petição do agravo de instrumento, do comprovante de sua interposição e da relação dos documentos que instruíram o recurso.

§ 1.º Se o juiz comunicar que reformou inteiramente a decisão, o relator considerará prejudicado o agravo de instrumento.

§ 2.º Não sendo eletrônicos os autos, o agravante tomará a providência prevista no *caput*, no prazo de 3 (três) dias a contar da interposição do agravo de instrumento.

§ 3.º O descumprimento da exigência de que trata o § 2.º, desde que arguido e provado pelo agravado, importa inadmissibilidade do agravo de instrumento.

1. Juntada. O agravante tem o ônus de requerer a juntada aos autos do processo de primeiro grau de cópia da petição do agravo de instrumento e do comprovante de sua interposição, tendo ainda o ônus de informar a relação de documentos que instruíram o recurso, salvo se se tratar de processo eletrônico (art. 1.018, *caput*, e § 2.º, do CPC). Não tem o ônus de juntar cópia dos documentos que formaram o agravo. Basta relacioná-los na petição que requer a juntada da cópia do agravo e do comprovante de sua interposição⁹.

O prazo para juntada é de 3 (três) dias. Trata-se de prazo próprio, cuja inobservância gera preclusão temporal.¹⁰ A juntada de cópia da petição de agravo de instrumento e do comprovante de sua interposição tem por finalidade propiciar ao órgão jurisdicional de primeiro grau o juízo de retratação (art. 1.018, § 1.º, do CPC/2015).

2. Inadmissibilidade. O não cumprimento do disposto no art. 1.018, do CPC/2015, importa inadmissibilidade do agravo de instrumento, desde que arguido e provado pelo agravado. Vedado ao juiz, portanto, agir de ofício.¹¹ O agravado deve alegar e provar o não cumprimento do disposto no art. 1.018, do CPC/2015, em suas contrarrazões, sob pena de preclusão consumativa.¹²

A rigor, o art. 1.018, § 3.º, do CPC/2015, enfraquece a coerência substancial do Código de 2015. Se é verdade que o juiz tem o dever de prevenção, inerente à colaboração, do qual inclusive decorre a regra da primazia do mérito, então não há sentido em prever-se a inadmissibilidade recursal por vício absolutamente sanável. E mais: cuja única consequência desfavorável é impedir a retratação da decisão prolatada, providência que só pode ser tomada como no interesse do próprio recorrente. Tudo aconselha a revogação do art. 1.018, § 3.º, do CPC/2015.

Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;

II – ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso;

III – determinará a intimação do Ministério Público, preferencialmente por meio eletrônico, quando for o caso de sua intervenção, para que se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias.

1. Decisão monocrática. Pode o relator decidir o agravo de instrumento monocraticamente a fim de não conhecê-lo (desde que, em sendo o caso, tenha viabilizado a possibilidade de sanação do vício, art. 932, parágrafo único, do CPC/2015, e desde que não seja possível conhecê-lo no mérito

a fim de beneficiar a parte a que o defeito formal aproveitaria, analogicamente, art. 488, do CPC/2015) ou de negar provimento, tudo conforme o art. 932, III e IV, do CPC/2015.

Aqui cabe a mesma observação feita a propósito da apelação.

Assim como em outras passagens, o art. 1.019, *caput*, do CPC/2015, revela um equívoco de orientação em que incidiu o legislador a respeito do tema dos *precedentes*. O que autoriza o julgamento monocrático do relator não é o fato de a tese do autor encontrar-se fundamentada em “súmulas” e “julgamento de casos repetitivos” (leia-se, incidente de resolução de demandas repetitivas e recursos repetitivos) ou em incidente de “assunção de competência”. É o fato de se encontrar fundamentado em *precedente* do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça ou em *jurisprudência* formada nos Tribunais de Justiça e nos Tribunais Regionais Federais em sede de incidente de resolução de demandas repetitivas ou em incidente de assunção de competência capaz de revelar razões adequadas e suficientes para solução do caso concreto.

O que os arts. 932, III e IV, e 1.019, *caput*, do CPC/2015, autorizam, portanto, é o julgamento monocrático no caso de haver *precedente* do STF ou do STJ ou *jurisprudência* firmada em incidente de resolução de demandas repetitivas ou em incidente de assunção de competência nos Tribunais de Justiça ou nos Tribunais Regionais Federais. Esses precedentes podem ou não ser oriundos de casos repetitivos e podem ou não ter adequadamente suas razões retratadas em súmulas.

2. Efeito suspensivo. O agravo não tem, em regra, efeito suspensivo. Pode o relator, contudo, suspender liminarmente a decisão recorrida, atribuindo efeito suspensivo ao recurso até ulterior julgamento (art. 1.019, I, do CPC/2015). Os requisitos para concessão de efeito suspensivo são aqueles mencionados no art. 1.012, § 4.º, do CPC/2015 – analogicamente aplicável.

A outorga de efeito suspensivo é a medida adequada quando se pretende simplesmente suspender os efeitos da decisão recorrida. O relator não pode agregar efeito suspensivo ao agravo de ofício, sendo imprescindível o requerimento da parte (analogicamente, art. 1.012, § 3.º, do CPC/2015). Deferido o efeito suspensivo, deve o relator comunicar ao juiz da causa a sua decisão.

3. Antecipação da tutela recursal. Quando o recorrente pretende a concessão de tutela jurisdicional ao direito negada pela decisão recorrida, obviamente não se mostra adequado postular a outorga de efeito suspensivo ao agravo, já que suspender uma omissão jurisdicional não produz qualquer efeito no plano concreto. É de rigor que se requeira nesse caso a antecipação da tutela recursal – vale dizer, que o relator conceda exatamente aquela providência que foi negada pela decisão recorrida. O relator pode fazê-lo, deferindo total ou parcialmente a antecipação da tutela recursal (arts. 294, 300, 311 e 1.019, I, do CPC/2015).

Os requisitos para concessão da antecipação da tutela variam de acordo com o contexto litigioso em que se insere o recorrente. Dependem, em suma, da espécie de tutela do direito que se quer antecipada. Se o recorrente pretende, por exemplo, a obtenção de tutela inibitória antecipada, tem o ônus de apontar a relevância do fundamento de seu pedido e o justificado receio de ineficácia do provimento final (art. 497, parágrafo único, do CPC/2015). Como a tutela é contra o ilícito, nenhuma consideração deve o recorrente fazer – e nem se lhe pode exigir o relator que o faça – a respeito de dano, dolo ou culpa. Se o recorrente pretende, por outra, tutela ressarcitória antecipada, então tem o ônus de apontar a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano (art. 300, do CPC/2015). A tutela aí é contra o dano e, como tal, suscita a apreciação do dano e do regime de responsabilidade a que se submete a parte contrária (responsabilidade subjetiva, responsabilidade objetiva etc.).

A antecipação da tutela recursal deve ser postulada pela parte, sendo vedada a atuação de ofício do relator (art. 294, do CPC/2015). É claro que pode o juiz, porém, consultar a parte a respeito de seu interesse na obtenção da tutela (art. 6.º, do CPC/2015). Deferida a antecipação da tutela recursal, deve o relator comunicar ao juiz da causa a sua decisão.

4. Resposta. O agravado, em respeito ao contraditório, deve ser ouvido no prazo de 15 (quinze) dias, na forma do art. 1.019, II, do CPC/2015. Poderá juntar documentação que entenda

conveniente.

5. Ministério Público. Se a participação do Ministério Público no processo é obrigatória, tendo em conta a natureza da causa, deve ser intimado para opinar a respeito do agravo interposto no prazo de 15 (quinze) dias, preferencialmente por meio eletrônico. A ausência de intimação do Ministério Público é vício de forma que pode dar lugar à decretação de nulidade do julgamento, acaso da sua não intervenção se verifique prejuízo para os fins de justiça do processo.

6. Decisão do relator. Passível de agravo interno (art. 1.021, do CPC/2015).

Art. 1.020. O relator solicitará dia para julgamento em prazo não superior a 1 (um) mês da intimação do agravado.

1. Julgamento. Em prazo não superior a 1 (um) mês da intimação do agravado, o relator pedirá dia para julgamento (art. 1.020, do CPC/2015). Trata-se de prazo impróprio, infenso à preclusão.

NOTAS DE RODAPÉ

1

Alfredo Buzaid, *Do Agravo de Petição no Sistema do Código de Processo Civil*, 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1956, p. 36.

2

Sobre o assunto, José Rogério Cruz e Tucci e Luiz Carlos de Azevedo, *Lições de História do Processo Civil Lusitano*, São Paulo: Ed. RT, 2009, p. 251-258.

3

Monograficamente, Teresa Arruda Alvim Wambier, *Os Agravos*, 4. ed. São Paulo: Ed. RT, 2006; Eduardo Chemale Selistre Peña, *O Recurso de Agravo*, Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2008; Carlos Silveira Noronha, *Do Agravo de Instrumento*, 3. ed., Rio de Janeiro: Forense, 1995; Moacyr Lobo da Costa, *O Agravo no Direito Lusitano*, Rio de Janeiro: Borsoi, 1974; Alfredo Buzaid, *Do Agravo de Petição no Sistema do Código de Processo Civil*, 2. ed., São Paulo: Saraiva, 1956.

4

STJ, 4ª Turma, REsp 1.679.909/RS, rel. Min. Luís Felipe Salomão, j. 14.11.2017, *DJe* 01.02.2018. Contra, STJ, 2ª Turma, REsp 1.700.308/PB, rel. Min. Herman Benjamin, j. 17.04.2018, *DJe* 23.05.2018. A questão hoje se encontra afetada à Corte Especial do STJ nos autos do REsp 1.704.520/MT, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 20.02.2018, *DJe* 28.02.2018.

5

Interpretação mais estrita que também encontra guarida na boa doutrina (conforme, por todos, Luís Guilherme Aidar Bondioli, *Comentários ao Código de Processo Civil*, 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 121, vol. XX), dada a mais alta importância para a proteção da confiança do jurisdicionado.

6

STJ, 1.^a Turma, REsp 633.614/PR, rel. Min. José Delgado, j. 01.06.2004, *DJ* 09.08.2004, p. 194.

7

STJ, 1.^a Turma, REsp 427.216/MG, rel. Min. José Delgado, j. 25.06.2002, *DJ* 09.09.2002, p. 179.

8

STJ, 1.^a Turma, AgRg no Ag 782.446/RJ, rel. Min. Luiz Fux, j. 14.08.2007, *DJ* 20.09.2007, p. 227.

9

STJ, 5.^a Turma, REsp 758.284/MA, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 14.06.2007, *DJ* 06.08.2007, p. 632.

10

STJ, 3.^a Turma, REsp 903.354/SP, rel. Min. Ari Pargendler, j. 12.12.2006, *DJ* 02.04.2007, p. 272.

11

STJ, 2.^a Turma, REsp 795.957/RS, rel. Min. Francisco Peçanha Martins, j. 06.12.2005, *DJ* 06.03.2006, p. 367.

12

STJ, 5.^a Turma, REsp 805.553/MG, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 18.10.2007, *DJ* 05.11.2007, p. 352.

© desta edição [2018]

Comentários ao CPC - v. XVI - Marinoni - Ed. 2018

TÍTULO II - DOS RECURSOS

CAPÍTULO IV. DO AGRAVO INTERNO

Capítulo IV. Do Agravo Interno

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1.º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2.º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3.º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4.º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5.º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4.º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

1. Cabimento. Assim como ocorria no direito anterior, o agravo interno serve para levar determinada questão decidida pelo relator ao colegiado de que faz parte. Quando o relator exerce monocraticamente qualquer das suas atribuições legais (art. 932 do CPC/2015), a decisão monocrática por ele prolatada pode ser impugnada perante o colegiado mediante agravo interno (art. 1.021 do CPC/2015). A concentração de poderes no relator ora visa à adequação da tutela jurisdicional (por exemplo, art. 932, II do CPC/2015), ora visa a estimular a economia processual e à fidelidade à jurisprudência vinculante e aos precedentes (por exemplo, art. 932, III a V do CPC/2015).¹

Os poderes do relator e a correlata recorribilidade da sua decisão registra duas importantes evoluções do direito brasileiro. A uma, o debate a respeito do papel da jurisprudência e dos precedentes no processo civil brasileiro foi paulatinamente acompanhado pela introdução legislativa de técnicas processuais voltadas à harmonização das decisões judiciais – notadamente de instrumentos de compatibilização vertical e horizontal das orientações das Cortes. Uma das técnicas de que se valeu o legislador para incentivar a conformação à jurisprudência e aos precedentes foi o incremento dos poderes do relator no julgamento dos recursos: a partir de determinado momento, o relator poderia não conhecer de um recurso, desprovê-lo monocraticamente por não se encontrar em consonância com a orientação do próprio órgão fracionário que integra ou das Cortes Supremas – isto é, do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça – ou dar provimento ao recurso dirigido contra decisão contrária a precedentes das Cortes Supremas. A duas, a atipicização da técnica antecipatória – que no plano recursal levou à atipicização da possibilidade de outorga de efeito suspensivo a recursos e de concessão de antecipação da tutela recursal – fez com que o relator deixasse igualmente de exercer uma função de simples guia do julgamento colegiado, qualificando-o igualmente como responsável pela prestação de tutelas sumárias enquanto pendente o processamento dos recursos

de sua competência.

2. Impugnação específica. O recurso tem sua admissibilidade condicionada à impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada (art. 1.021, § 1.º do CPC/2015). Especificamente quando voltado a atacar decisões monocráticas fundadas na jurisprudência do próprio órgão fracionário ou nos precedentes das Cortes Supremas (art. 932, III a V do CPC/2015), a admissibilidade do agravo interno está igualmente condicionada à demonstração da distinção do caso decidido com o caso anterior (analogamente, art. 1.042, § 1.º, II do CPC/2015).

O agravo interno que não patrocina específica impugnação da decisão agravada ou que não realizada adequada distinção entre os casos não deve ser conhecido pelo órgão colegiado. A imposição legal de atenção ao caso concreto (arts. 319, III, e 489, § 1.º, I do CPC/2015) como meio de evitar a litigância padronizada, sem conexão com os fatos da causa, evidenciada pela necessidade de impugnação específica dos fundamentos da decisão e de elaboração de distinções entre casos, não grava apenas as partes e seus advogados. Na mesma linha, o novo Código veda ao relator se limitar à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (art. 1.021, § 3.º do CPC/2015). Com isso o novo Código não só estimula a atenção para o caso concreto, mas também visa a prestigiar um diálogo congruente entre o juiz e as partes como meio adequado para obtenção de uma solução mais amadurecida e completa.

3. Procedimento. O agravo interno será interposto no prazo de quinze dias (art. 1.003, § 5.º do CPC/2015) e será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso em idêntico prazo, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com expressa inclusão em pauta (por força da regra da publicidade de todos os atos processuais, arts. 5.º, LX, 93, IX, CRFB, 11, 188 e 934 do CPC/2015).

4. Decisão de única ou última instância. No direito anterior, o Superior Tribunal de Justiça decidiu pela necessidade de interposição de agravo interno da decisão do relator para o colegiado como etapa imprescindível voltada ao esgotamento da instância ordinária para posterior viabilização da interposição de recurso extraordinário ou de recurso especial. É provável que essa orientação seja reproduzida em relação aos arts. 932, III a V, e 1.021, do novo Código.

É preciso, contudo, evitá-la: isso porque, se uma das finalidades da outorga de poderes ao relator está em patrocinar a economia processual, o prestígio à jurisprudência e aos precedentes e a duração razoável do processo, então constitui óbvio contrassenso exigir-se que o órgão fracionário volte a decidir o que já decidiu anteriormente e que já foi anunciado pelo relator do recurso apenas para efeitos de esgotamento da instância. É preciso perceber que, sendo possível ao relator julgar em atenção à jurisprudência do seu órgão fracionário ou aos precedentes das Cortes Supremas, o próprio relator constitui a última instância recursal. Rigorosamente, o agravo interno só é cabível para demonstrar distinção entre os casos. Note-se que a exigência de interposição de agravo interno como simples meio de esgotamento da instância está em desacordo com a própria finalidade da atribuição de poder ao relator para decidir. Se a intenção é abreviar o exame dos recursos, eliminando a demora do julgamento colegiado, não há sentido em obrigar à interposição do agravo interno, sob pena de transformar – mais uma vez – a boa intenção do legislador em uma frustrante e penosa duplicação de recursos.

5. Julgamento. O agravo interno será julgado pelo colegiado e admitirá ou não sustentação oral pelas partes de acordo com a natureza do recurso de que originado. Assim, no agravo interno originário de recurso de apelação ou recurso ordinário ou no agravo interno decorrente de recurso especial ou de recurso extraordinário caberá sustentação oral. Pouco importa o veto presidencial nesse particular: a opção pelo julgamento monocrático – sobre a qual a parte não tem qualquer ingerência – não pode importar em solapamento do direito à sustentação das razões na sessão de julgamento. Se é possível sustentá-las quando não há julgamento monocrático, por uma questão de igualdade é necessário assegurar o direito à sustentação oral também quando há o julgamento monocrático. Fora daí submete-se o direito da parte à sustentação oral a uma condição cuja implementação escapa completamente de seu controle.

6. Multa. Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou

improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor da causa devidamente atualizado (art. 1.021, § 4.º do CPC/2015). Note-se que nesse caso há dever de imposição da multa, na medida em que com isso o legislador busca resguardar a seriedade na interposição do recurso, evitando a proliferação de recursos meramente protelatórios ou temerários (trata-se, portanto, de técnica voltada não só a promoção da boa-fé processual, art. 5.º do CPC/2015, mas também a concretização do direito ao processo com duração razoável, arts. 5.º, LXXVIII, CF/1988, e 4.º do CPC/2015). Condenado o agravante, a interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4.º, à exceção do beneficiário de gratuidade judiciária e da Fazenda Pública, que farão o pagamento ao final (art. 1.021, § 5.º do CPC/2015).

NOTAS DE RODAPÉ

1

Amplamente, Pedro Miranda de Oliveira, *Agravo Interno e Agravo Regimental*, São Paulo: Ed. RT, 2014; Delosmar Domingos de Mendonça Júnior, *Agravo Interno*, São Paulo: Ed. RT, 2009.

© desta edição [2018]

Comentários ao CPC - v. XVI - Marinoni - Ed. 2018

TÍTULO II - DOS RECURSOS

CAPÍTULO V . DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Capítulo V . Dos Embargos de Declaração

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1.º.

1. Embargos de Declaração. O recurso de embargos de declaração, assim como o recurso de agravo de instrumento, também constitui legado da tradição lusitana para o direito brasileiro.¹ Mediante a oposição de embargos declaratórios, a parte visa a aprimorar a entrega da tutela jurisdicional, oportunizando ao órgão jurisdicional prolator de determinada decisão que a esclareça, desfaça contradição ou integre-a (art. 1.022, CPC).² Se bem utilizados, os embargos declaratórios constituem poderoso instrumento de colaboração no processo, permitindo um juízo plural, aberto e ponderado a partir de um diálogo que visa a um efetivo aperfeiçoamento da tutela jurisdicional.

A nota mais marcante do recurso de embargos de declaração está em que a sua oposição não visa propriamente a modificação do julgado. Essa é a razão pela qual se diz que esse recurso é de simples *declaração*. Os embargos de declaração não têm por função modificar ou reformar a decisão embargada, mas apenas torná-la mais clara, consistente ou completa. Daí a razão pela qual, do ponto de vista procedimental, os embargos de declaração em regra não exigem a realização do contraditório mediante a oportunização de contrarrazões.

Nada obstante, pode ocorrer que, *em função da obscuridade, contradição ou da omissão*, os embargos declaratórios acabem acarretando modificação ou reforma da decisão embargada. Nesses casos, diz-se que os embargos declaratórios possuem *efeitos infringentes*, isto é, modificativos da decisão embargada. Como nenhuma decisão definitiva pode ser tomada sem que a parte potencialmente prejudicada seja ouvida (arts. 7.º, 9.º e 10, CPC/2015), é imprescindível que o relator, vislumbrando a possibilidade de outorgar efeitos infringentes ao julgado, determine a oitiva da parte embargada (art. 1.023, § 2.º, CPC/2015).

2. Cabimento. Cabem embargos declaratórios quando a parte *narra* obscuridade, contradição ou omissão em qualquer espécie de decisão judicial – decisões interlocutórias, sentenças, acórdãos ou decisões monocráticas de relator. Se a obscuridade, contradição ou omissão de fato *existe* é uma questão de mérito do recurso de embargos.

O Código de 1973, art. 535, referia que os embargos declaratórios eram cabíveis contra

sentenças e acórdãos. Todavia, a interpretação pacífica desse dispositivo já apontava para a necessidade de tê-los como cabíveis diante de qualquer espécie de decisão judicial: decisões interlocutórias, sentenças, acórdãos e decisões monocráticas. Nesse particular, portanto, o art. 1.022, *caput*, CPC/2015, apenas explicitou a interpretação assente do dispositivo.

As hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios são basicamente quatro: obscuridade, contradição, omissão e erro material. Para que os embargos sejam cabíveis – e, pois, idôneos para interromper o prazo para os demais recursos (art. 1.026, CPC/2015) – é preciso que a parte *alegue* obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Se a parte não alega quaisquer desses vícios, os embargos não devem ser conhecidos, não se operando a interrupção do prazo recursal.

Decisão obscura é a decisão a que falta clareza. A obscuridade concerne à redação da decisão. A obscuridade compromete a adequada compreensão da ideia exposta na decisão judicial.

A decisão é contraditória quando encerra duas ou mais proposições ou dois ou mais enunciados inconciliáveis. A contradição ocorre entre proposições e os enunciados que se encontram *dentro da mesma decisão*. Obviamente, não configura contradição o antagonismo entre as razões da decisão e as alegações das partes.³ A contradição pode se estabelecer entre afirmações constantes do relatório, da fundamentação, do dispositivo e da ementa (art. 489, § 3º, CPC/2015).⁴ A decisão deve ser analisada como um todo para efeitos de aferição do dever de não contradição.

A apreciação que o órgão jurisdicional deve fazer dos fundamentos levantados pelas partes em seus arrazoados tem de ser completa (art. 489, § 1º, IV, CPC/2015). Vale dizer: a fundamentação da decisão deve ser completa – razão pela qual cabem embargos declaratórios quando for omitido “ponto sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento” (art. 1.022, II, CPC/2015). A omissão judicial a respeito de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o órgão jurisdicional constitui flagrante denegação de justiça. Viola o direito fundamental à tutela jurisdicional (art. 5º, XXXV, CF/1988), o direito ao contraditório como direito de influência (arts. 5º, LV, CF/1988, e 9º e 10, CPC/2015) e o correlato dever de fundamentação como dever de diálogo (art. 93, IX, CF/1988, 11 e 489, § 1º, CPC/2015).

O parâmetro a partir do qual se deve aferir a completude da fundamentação das decisões judiciais passa longe da *simples constância na decisão do esquema lógico-jurídico mediante o qual o juiz chegou à sua conclusão*. Partindo-se da compreensão do direito fundamental ao contraditório como direito à participação, como direito a influenciar e convencer o órgão jurisdicional (arts. 5º, LV, CF/1988, 9º e 10º, CPC/2015), a completude da fundamentação só pode ser aferida em função dos fundamentos arguidos pelas partes (aí entendidos como todos os argumentos capazes de infirmar, em tese, a conclusão adotada no julgado, art. 489, § 1º, IV, CPC/2015), na medida em que o direito fundamental ao contraditório impõe o dever de o órgão jurisdicional considerar seriamente as razões apresentadas pelas partes em seus arrazoados.⁵ A própria ideia de processo civil regido pela colaboração – em que o juiz tem dever de diálogo – aponta para essa solução (art. 6º, CPC/2015). Daí a razão pela qual, opostos embargos declaratórios em face de omissão judicial, tem a parte direito a obter “comentário sobre todos os pontos levantados” no recurso.⁶

Cabem embargos de declaração para sanção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I, CPC/2015). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.

§ 1º Aplica-se aos embargos de declaração o art. 229.

§ 2º O juiz intimará o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos, caso seu eventual acolhimento implique a modificação da decisão embargada.

1. Prazo. Os embargos declaratórios devem ser opostos no prazo de 5 (cinco) dias. A oposição dos embargos ocorre com o protocolo da petição no juízo ou tribunal. Todavia, se a petição dos embargos foi simplesmente anexada aos autos do processo, tendo a parte entregue os autos que se encontravam em seu poder em cartório ou secretaria dentro do prazo legal, deve-se considerar tempestivo o recurso.⁷

2. Petição escrita. A petição dos embargos deve ser dirigida ao juiz prolator da decisão ou ao relator do acórdão no tribunal. Os embargos declaratórios devem constar de petição escrita, tendo o embargante de apontar expressamente o ponto da decisão que reputa obscuro ou contraditório, não se submetendo a preparo. Sendo o caso de omissão, deve indicar qual o fundamento que deveria ter sido considerado pelo tribunal e não o foi. Sendo o caso de erro material, tem o ônus de identificá-lo precisamente. Falta regularidade formal aos embargos que não se revestem dessas características, não podendo, pois, ser conhecidos. Antes de não os conhecer, porém, deve o relator viabilizar a sanção do vício (art. 932, parágrafo único, CPC/2015).

3. Embargos de declaração com efeitos infringentes. Nada obstante o recurso de embargos de declaração vise apenas ao aperfeiçoamento da decisão judicial, patrocinando esclarecimento de obscuridade, desfazimento de contradição, supressão de omissão e correção de erro material, não se prestando, como regra, à obtenção de modificação do julgado, pode ocorrer de o acolhimento dos embargos declaratórios provocar uma alteração na substância da decisão embargada (art. 1.023, § 2.º, CPC/2015). Nesse caso, em que as hipóteses típicas de cabimento dos embargos declaratórios provocam a alteração do julgado, diz-se que os embargos declaratórios apresentam efeitos infringentes – modificativos – da decisão embargada.

Observe-se que o embargante não pretende diretamente a rediscussão da causa e conseguinte modificação no entendimento exposto pelo órgão jurisdicional na decisão com a oposição de embargos declaratórios com efeitos infringentes. O que pretende é o esclarecimento da obscuridade, o desfazimento da contradição e a supressão da omissão, que, indiretamente, acabam por modificar o julgado. Afora as hipóteses legais, admitem-se excepcionalmente embargos declaratórios com efeitos infringentes, ainda, contra decisões teratológicas, absurdas, em que é evidente o descompasso da decisão com o contexto fático-jurídico da causa.⁸

4. Contrarrazões. Como os embargos de declaração não possuem, em regra, o condão de modificar substancialmente o julgado, é desnecessária a intimação da parte contrária para contrarrazoá-los (art. 1.024, CPC/2015). Todavia, antevendo o órgão julgador a possibilidade de outorgarem-se efeitos infringentes aos embargos de declaração, acarretando alteração na decisão embargada, é imprescindível a intimação da parte contrária para que possa exercer o direito fundamental ao contraditório, oferecendo contrarrazões ao recurso (art. 1.023, § 2.º, CPC/2015). Decisão prolatada em embargos de declaração que modifica o julgado embargado sem a oitiva da parte contrária é nula por ofensa ao direito ao contraditório (arts. 9.º e 10, CPC/2015).

Art. 1.024. O juiz julgará os embargos em 5 (cinco) dias.

§ 1.º Nos tribunais, o relator apresentará os embargos em mesa na sessão subsequente, proferindo voto, e, não havendo julgamento nessa sessão, será o recurso incluído em pauta automaticamente.

§ 2.º Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidirá monocraticamente.

§ 3.º O órgão julgador conhecerá dos embargos de declaração como agravo interno se entender ser este o recurso cabível, desde que determine previamente a intimação do recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, complementar as razões recursais, de modo a ajustá-las às exigências do art. 1.021, § 1.º.

§ 4.º Caso o acolhimento dos embargos de declaração implique modificação da decisão embargada, o embargado que já tiver interposto outro recurso contra a decisão originária tem o

direito de complementar ou alterar suas razões, nos exatos limites da modificação, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da intimação da decisão dos embargos de declaração.

§ 5.º Se os embargos de declaração forem rejeitados ou não alterarem a conclusão do julgamento anterior, o recurso interposto pela outra parte antes da publicação do julgamento dos embargos de declaração será processado e julgado independentemente de ratificação.

1. Julgamento. O órgão jurisdicional julgará os embargos em cinco dias. Nos tribunais, o relator apresentará os embargos em mesa na sessão subsequente, proferindo voto. Não havendo julgamento nessa sessão, será o recurso incluído em pauta automaticamente (art. 1.024, § 1.º, CPC/2015).

Os embargos de declaração devem ser analisados pelo próprio prolator da decisão, tendo em conta que ele foi o prolator da decisão embargada, sendo a pessoa mais autorizada a esclarecer-lhe o conteúdo e a ideia, que complementarará, se for o caso, a decisão anteriormente lançada. Nessa linha, quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidirá monocraticamente (art. 1.024, § 2.º, CPC/2015).

2. Conversão. Na sessão de julgamento, pode ocorrer de o órgão judicial entender que os embargos declaratórios são incabíveis, porque a interposição de agravo interno seria, em realidade, adequado à espécie (art. 1.021, CPC/2015). Nessa hipótese, pode o órgão julgador conhecer dos embargos declaratórios como se fossem agravo interno, desde que determine previamente a intimação do recorrente para, no prazo de cinco dias, complementar as razões recursais nos moldes exigidos do recurso de agravo interno (art. 1.024, § 3.º, CPC/2015). Também aqui o Código de 2015 procura viabilizar uma “decisão de mérito justa e efetiva” para o caso concreto (art. 6.º, CPC/2015), evitando soluções puramente formais aos litígios.

3. Complementação. Pode ocorrer entre a data da publicação da decisão embargada e a oposição dos embargos declaratórios de a parte contrária ter interposto outro recurso contra a decisão originária. Caso o acolhimento dos embargos declaratórios implique modificação da decisão embargada, o embargado que já tiver interposto outro recurso contra a decisão originária tem direito de complementar ou alterar suas razões, nos exatos limites da modificação, no prazo de 15 dias, contados do primeiro dia útil subsequente ao da intimação da decisão dos embargos declaratórios (art. 1.024, § 4.º, CPC/2015).

4. Desnecessidade de ratificação. Pode ocorrer entre a data da publicação da decisão embargada e a oposição dos embargos declaratórios de a parte contrária ter interposto outro recurso contra a decisão originária. Se os embargos de declaração forem rejeitados ou não alterarem a conclusão do julgamento anterior, o recurso interposto pela outra parte, antes da publicação do julgamento dos embargos, será processado e julgado independentemente de ratificação (art. 1.024, § 5.º, CPC/2015).

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

1. Prequestionamento. Muitas vezes os embargos declaratórios são utilizados como meio de prequestionamento de questões constitucionais ou de questões federais, isto é, são utilizados como meio de provocar a pronúncia do órgão julgador a respeito da aplicação de determinadas normas constitucionais ou federais ao caso concreto. Nesses casos, os embargos são normalmente fundados na omissão (art. 1.022, II, CPC/2015).

Contudo, pode ocorrer de, mesmo existindo omissões, o órgão jurisdicional não as reconhecer, o que poderá ocasionar a indevida inadmissão ou rejeição do recurso. A fim de evitar duplicações recursais (um primeiro recurso especial voltado a analisar a violação do art. 1.022, CPC/2015, e um segundo voltado a analisar a questão anteriormente omitida de forma indevida), o Código de 2015

refere que se consideram “incluídos no acórdão os elementos que o embargante pleiteou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade” (art. 1.025, CPC/2015). Vale dizer: o novo Código reconheceu a possibilidade de os embargos de declaração viabilizarem o reconhecimento direto das omissões apontadas pelo órgão responsável por julgar o recurso extraordinário ou o recurso especial que os embargos declaratórios visam a preparar, quando opostos das decisões dos Tribunais Regionais Federais e dos Tribunais de Justiça. Obviamente, a inclusão ficta das questões no acórdão recorrido fica condicionada ao reconhecimento da respectiva relevância pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça.⁹

Nesse caso, para melhor organização do debate perante as Cortes Supremas, a demonstração das omissões indevidamente omitidas deve ser destacada preliminarmente no recurso extraordinário ou no recurso especial. Depois de vencida a etapa de demonstração da omissão é que a parte deve expor o mérito do recurso.

Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso.

§ 1.º A eficácia da decisão monocrática ou colegiada poderá ser suspensa pelo respectivo juiz ou relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, se houver risco de dano grave ou de difícil reparação.

§ 2.º Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

§ 3.º Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final.

§ 4.º Não serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 (dois) anteriores houverem sido considerados protelatórios.

1. Efeito suspensivo. Os embargos declaratórios não têm efeito suspensivo (art. 1.026, CPC/2015). Se a decisão embargada não tiver sua eficácia suspensa pelo fato de a decisão encontrar-se sujeita a outro recurso com efeito suspensivo, então durante o período de julgamento dos embargos declaratórios nada obsta a eficácia imediata da decisão embargada.

Pode o relator, porém, outorgar efeito suspensivo ao recurso de embargos declaratórios (art. 1.026, § 1.º, CPC/2015). Para tanto, a parte tem de demonstrar em primeiro lugar a probabilidade de provimento dos embargos (acaso se vislumbre a possibilidade de infringência do julgado) ou do recurso que ainda será interposto tendente à alteração da decisão embargada. O que interessa para caracterização do *fumus boni iuris* capaz de viabilizar a concessão do efeito suspensivo é a possibilidade de posterior modificação do julgado embargado. Em segundo lugar, a parte tem de demonstrar a ocorrência do perigo na demora na prestação da tutela jurisdicional recursal. Embora o Código fale aqui em perigo de dano, é certo que o perigo de ilícito também justifica a atribuição de efeito suspensivo aos embargos.

2. Interrupção do prazo. Desde que conhecidos os embargos de declaração, esses interrompem o prazo para a interposição de outros recursos por qualquer das partes.¹⁰ Observe-se que o conhecimento dos embargos de declaração depende da narrativa do embargante no sentido da existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. A efetiva existência desses vícios constitui o mérito dos embargos declaratórios.

Para que o órgão jurisdicional conheça dos embargos basta a afirmação do recorrente no sentido da existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material – além, é claro, do

atendimento dos demais requisitos de admissibilidade recursal. O prazo para a interposição de outros recursos é interrompido. Vale dizer: após o julgamento dos embargos, o prazo é devolvido por inteiro às partes para interposição de outros recursos. A oposição de embargos de declaração não interrompe o prazo para interposição de embargos declaratórios pela parte contrária da mesma decisão.

3. Manifestamente protelatórios. O recurso manifestamente protelatório é aquele que tem por escopo unicamente retardar o andamento do processo. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que não se considera recurso manifestamente protelatório o recurso em tese cabível pela legislação vigente.¹¹ Ainda, que “embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório” (Súmula 98, STJ). Não pode ser considerado protelatório o recurso interposto para esgotar a instância ordinária, objetivando o acesso às instâncias extraordinárias, já que aí o intuito do recorrente passa ao largo de unicamente retardar o andamento do processo. O art. 1.026, § 2.º, CPC/2015, constitui regra especial em relação ao art. 80, VII, CPC/2015, com o que afasta a sua aplicação.

Sendo interpostos embargos declaratórios manifestamente protelatórios, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa (art. 1.026, § 2.º, CPC/2015). Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final (art. 1.026, § 3.º, CPC/2015). Por fim, não serão admitidos novos embargos de declaração se os dois anteriores houverem sido considerados protelatórios (art. 1.026, § 4.º, CPC/2015). O órgão jurisdicional tem o dever de sancionar o embargante cujo intuito recursal é manifestamente protelatório.¹²

4. Depósito. Aplicada a multa, o depósito do valor respectivo constitui requisito de admissibilidade de qualquer outro recurso posterior, que não deve ser conhecido na ausência do depósito (art. 1.026, § 3.º, CPC/2015). A Fazenda Pública pode ser sancionada com a multa a que alude o art. 1.026, §§ 2.º e 3.º, CPC/2015.

No entanto, o próprio art. 1.026, § 3.º, CPC/2015, refere que o depósito do valor da multa não constitui requisito de admissibilidade de qualquer outro recurso para Fazenda Pública. Todavia, há aí flagrante violação do direito fundamental à paridade de armas no processo civil (arts. 5.º, I, CF/1988, e 7.º, CPC/2015). Há diferenciação indevida, porque não fundada em critérios que permitem aferir a racionalidade da distinção: assim, a dispensa de depósito pressupõe vantagem destituída de causa. O fato de a Fazenda Pública ter que recolher ao final a multa não mitiga a violação à igualdade no processo civil.

No mais, sendo excessivo o valor da multa – a ponto de comprometer o acesso da parte aos demais recursos – é possível afastar excepcionalmente a necessidade de seu depósito prévio ao recurso, por afronta ao direito fundamental à tutela jurisdicional (art. 5.º, XXXV, CF/1988).

NOTAS DE RODAPÉ

1

José Rogério Cruz e Tucci e Luiz Carlos de Azevedo, *Lições de História do Processo Civil Lusitano*. São Paulo: Ed. RT, 2009, p. 260-264.

2

Monograficamente, Luís Eduardo Simardi Fernandes, *Embargos de Declaração*. São Paulo: Ed. RT, 2003; Luís Guilherme Aidar Bondioli, *Embargos de Declaração*. São Paulo: Saraiva, 2005; Sandro Marcelo Kozikoski, *Embargos de Declaração – Teoria Geral e Efeitos Infringentes*. São Paulo: Ed. RT, 2004; Sônia Márcia Hase de Almeida Baptista, *Dos Embargos de Declaração*. São Paulo: Ed. RT, 1993; Teresa Arruda Alvim Wambier, *Omissão Judicial e Embargos de Declaração*. São Paulo: Ed. RT, 2005.

3

STJ, 2.^a Turma, REsp 928.075/PE, rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007, *DJ* 18.09.2007, p. 290.

4

STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, j. 16.02.2000, *DJ* 03.04.2000, p. 102.

5

STF, Pleno, MS 25.787/DF, rel. Min. Gilmar Mendes, j. em 08.11.2006, *DJ* 14.09.2007, p. 32.

6

STJ, Corte Especial, EREsp 95.441/SP, rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j. 08.04.1999, *DJ* 17.05.1999.

7

STJ, 1.^a Turma, AgRg nos EDcl no AgRg no REsp 861.433/SE, rel. Min. Francisco Falcão, rel. para acórdão Min. Luiz Fux, j. 26.06.2007, *DJ* 25.10.2007, p. 128.

8

STJ, 1.^a Turma, EDcl nos EDcl no AgRg no Ag 314.971/ES, rel. Min. Luiz Fux, j. 24.11.2004, *DJ* 31.05.2004, p. 219.

9

Guilherme Rizzo Amaral, *Comentários às Alterações do Novo CPC*. São Paulo: Ed. RT, 2015, p. 1.043.

10

STJ, 4.^a Turma, EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg no Ag 816.356/MG, rel. Min. Fernando Gonçalves, j. 20.11.2007, *DJ* 03.12.2007, p. 318.

11

STJ, 6.^a Turma, REsp 215.418/SP, rel. Min. Vicente Leal, j. 16.05.2000, *DJ* 29.05.2000, p. 194.

STJ, 1.^a Seção, EDcl no AgRg no EREsp 869.231/SP, rel. Min. Humberto Martins, j. 24.10.2007, *DJ* 19.11.2007, p. 183.

© desta edição [2018]

Comentários ao CPC - v. XVI - Marinoni - Ed. 2018

TÍTULO II - DOS RECURSOS

CAPÍTULO VI. DOS RECURSOS PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E PARA O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Capítulo VI. Dos Recursos para o Supremo Tribunal Federal e para o Superior Tribunal de Justiça

1. Recursos para o STF e para o STJ. Ao Supremo Tribunal Federal e ao Superior Tribunal de Justiça são deferidas competências originárias (arts. 102, I, e 105, I, CF), recursais ordinárias (arts. 102, II, e 105, II, CF) e recursais extraordinárias (arts. 102, III, e 105, III, CF). Como instâncias recursais, podem funcionar como instâncias ordinárias, em que devem examinar recursos ordinários, e como instâncias extraordinárias, em que têm de conhecer e julgar recursos extraordinários e recursos especiais. A finalidade acometida pela Constituição à instância ordinária diverge agudamente da finalidade deferida à instância extraordinária: enquanto essa visa outorgar unidade ao direito, aquela tem por desiderato servir como instância revisora – isto é, de controle das decisões recorridas.

Seção I

Do Recurso Ordinário

Art. 1.027. Serão julgados em recurso ordinário:

I – pelo Supremo Tribunal Federal, os mandados de segurança, os *habeas data* e os mandados de injunção decididos em única instância pelos tribunais superiores, quando denegatória a decisão;

II – pelo Superior Tribunal de Justiça:

a) os mandados de segurança decididos em única instância pelos tribunais regionais federais ou pelos tribunais de justiça dos Estados e do Distrito Federal e Territórios, quando denegatória a decisão;

b) os processos em que forem partes, de um lado, Estado estrangeiro ou organismo internacional e, de outro, Município ou pessoa residente ou domiciliada no País.

§ 1.º Nos processos referidos no inc. II, alínea “b”, contra as decisões interlocutórias caberá agravo de instrumento dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, nas hipóteses do art. 1.015.

§ 2.º Aplica-se ao recurso ordinário o disposto nos arts. 1.013, § 3.º, e 1.029, § 5.º.

1. Recurso ordinário. Trata-se de recurso que possibilita tanto a revisão como a anulação das decisões mencionadas no arts. 102, II, *a*, 105, II, *b* e *c*, CF/1988, e 1.027, CPC/2015. Como instância revisora, cujo desiderato está em possibilitar o duplo grau de jurisdição, pode-se nela discutir sem qualquer limitação questões fático-jurídicas, não se aplicando as Súmulas 279, STF (“para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”), e 7.º, STJ (“a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”)¹. A expressão “quando denegatória a decisão” (art. 1.027, I e II, *a*, CPC/2015), consoante observa a jurisprudência, “deve ser interpretada em sentido amplo, abarcando tanto o acórdão denegatório da ordem como aquele que extingue o processo, sem julgamento de mérito”.²

2. Recurso ordinário para o STF. A decisão denegatória de mandado de segurança, habeas data e mandado de injunção decididos em única instância pelo Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral e Superior Tribunal Militar desafia recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal (art. 102, II, *a*, CF/1988). A decisão concessiva é recorrível, sendo o caso, por recurso extraordinário (art. 102, III, CF/1988).

O recurso ordinário devolve e translada para o Supremo Tribunal Federal toda a matéria versada na causa – de ordem constitucional e infraconstitucional.³ Já admitiu o Supremo Tribunal Federal a conversão de recurso extraordinário interposto inadequadamente em recurso ordinário, aplicando a regra da fungibilidade recursal⁴ – nada obstante o teor da Súmula 272, STF (“não se admite como recurso ordinário recurso extraordinário de decisão denegatória de mandado de segurança”). A decisão pela fungibilidade é acertada e é a que melhor se adequa ao sistema do novo Código, que privilegia a prolação de decisões de mérito em detrimento de decisões meramente processuais para os litígios.

A decisão denegatória que desafia a interposição de recurso ordinário é a decisão denegatória do colegiado do tribunal superior – se aplicado na origem o art. 932, III a V, CPC/2015, a jurisprudência entende que o acesso ao recurso ordinário fica condicionado à interposição do agravo interno (art. 1.021, CPC/2015) ao colegiado.⁵ O Supremo Tribunal Federal não tem competência para conhecer originariamente de mandado de segurança contra atos de outros tribunais (Súmula 624, STF: “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer originariamente de mandado de segurança contra atos de outros tribunais”).

3. Recurso ordinário para o STJ. A decisão denegatória de mandado de segurança decidido em única instância pelos Tribunais Regionais Federais e pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal e Territórios desafia recurso ordinário para o Superior Tribunal de Justiça (art. 105, II, *b*, CF/1988). A decisão concessiva é recorrível, conforme o caso, por recurso especial e/ou recurso extraordinário (arts. 102, III, e 105, III, CF/1988). Também caberá recurso ordinário para o Superior Tribunal de Justiça nas causas em que forem partes, de um lado, Estado estrangeiro ou organismo internacional e, do outro, Município ou pessoa residente ou domiciliada no País (art. 105, II, *c*, CF/1988).

O recurso ordinário presta-se à discussão de questões constitucionais e infraconstitucionais perante o Superior Tribunal de Justiça⁶ (STF), tendo ampla devolutividade e translatividade.⁷ O Superior Tribunal de Justiça já se negou a aplicar a regra da fungibilidade recursal na hipótese de interposição de recurso especial no lugar de recurso ordinário, entendendo aí a existência de erro grosseiro.⁸ Essa orientação tem de ser revista, tendo em conta a necessidade de se prestigiar a prolação de decisões de mérito em detrimento de decisões processuais (arts. 6.º e 932, parágrafo único, CPC/2015).

Se aplicado na origem o art. 932, III a V, CPC/2015, a jurisprudência entende que o acesso ao recurso ordinário para o Superior Tribunal de Justiça está condicionado à interposição de agravo interno (art. 1.021, CPC/2015), a fim de que esgotada a instância. O Superior Tribunal de Justiça não tem competência para conhecer originariamente de mandado de segurança contra atos de outros tribunais (Súmula 41, STJ: “o Superior Tribunal de Justiça não tem competência para processar e julgar, originariamente, mandado de segurança contra ato de outros tribunais ou dos respectivos órgãos”).

4. Agravo de instrumento. As causas em que forem partes, de um lado, Estado estrangeiro ou organismo internacional e, do outro, Município ou pessoa residente ou domiciliada no País são de competência originária do juiz federal (art. 109, II, CF/1988). O recurso ordinário, no entanto, não é de competência do Tribunal Regional Federal – é de competência do Superior Tribunal de Justiça (art. 105, II, *c*, CF/1988). O juízo competente para conhecer do recurso ordinário também é competente para conhecer dos agravos interpostos contra as decisões interlocutórias. Assim, das decisões interlocutórias caberá agravo para o Superior Tribunal de Justiça (art. 1.027, § 1.º, CPC/2015).

5. Causa madura. Aplica-se ao recurso ordinário o art. 1.013, §§ 3.º e 4.º, CPC/2015, que

permitem o imediato julgamento na instância revisora da causa madura (art. 1.027, § 2.º, CPC/2015). Trata-se de aplicação autorizada pela analogia.

6. Tutela provisória. É cabível pedido de tutela provisória em recurso ordinário. O pedido deve ser postulado na forma do art. 1.029, § 5.º, CPC/2015 (art. 1.027, § 2.º, CPC/2015).

Art. 1.028. Ao recurso mencionado no art. 1.027, II, alínea “b”, aplicam-se, quanto aos requisitos de admissibilidade e ao procedimento, as disposições relativas à apelação e o Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.

§ 1.º Na hipótese do art. 1.027, § 1.º, aplicam-se as disposições relativas ao agravo de instrumento e o Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.

§ 2.º O recurso previsto no art. 1.027, I e II, alínea “a”, deve ser interposto perante o tribunal de origem, cabendo ao seu presidente ou vice-presidente determinar a intimação do recorrido para, em 15 (quinze) dias, apresentar as contrarrazões.

§ 3.º Findo o prazo referido no § 2.º, os autos serão remetidos ao respectivo tribunal superior, independentemente de juízo de admissibilidade.

1. Admissibilidade, procedimento e efeitos. Ao recurso ordinário aplica-se o regramento da apelação. O art. 1.013, CPC/2015, é integralmente aplicável.⁹ Pode o relator, ainda, julgá-lo monocraticamente nas hipóteses do art. 932, III a V, CPC/2015¹⁰ (STJ).

O recurso ordinário, consoante à jurisprudência, deve ser recebido com efeito suspensivo. A propósito, cumpre registrar ainda que, “denegado o mandado de segurança pela sentença, ou no julgamento do agravo, dela interposto, fica sem efeito a liminar concedida, retroagindo os efeitos da decisão contrária” (Súmula 405, STF).

O prazo para interposição de recurso ordinário é de 15 (quinze) dias (art. 1.003, § 5.º, CPC/2015). Ao agravo de instrumento previsto no art. 1.027, § 1.º, CPC/2015, aplica-se, no que couber, o regramento constante dos arts. 1.016 a 1.020, CPC/2015, bem como o constante do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.

2. Interposição. O recurso ordinário deve ser interposto perante o tribunal de origem, cabendo ao seu presidente ou vice-presidente determinar a intimação do recorrido para, em 15 (quinze) dias, apresentar as contrarrazões. Logo em seguida, os autos serão remetidos ao Supremo Tribunal Federal ou ao Superior Tribunal de Justiça, conforme o caso, independentemente de juízo de admissibilidade (art. 1.028, § 3.º, CPC/2015).

3. Processamento no STF e no STJ. O Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça disciplina o julgamento do recurso ordinário em mandado de segurança nos arts. 247 e 248. A Lei 8.038/1990 cuida do tema nos arts. 33 a 35.

Seção II

Do Recurso Extraordinário e do Recurso Especial

1. O STF e o STJ como Cortes Supremas. A compreensão do recurso extraordinário e do recurso especial no Código de 2015 pressupõe a percepção de uma diferente função atribuída às Cortes Supremas no direito brasileiro, o que levou igualmente à outorga de uma eficácia diversa às suas decisões. A possibilidade de julgamento de questões mesmo diante da desistência de recurso extraordinário ou de recurso especial (art. 998, parágrafo único, CPC/2015), desconsideração de vícios formais não graves (art. 1.029, § 3.º, CPC/2015), a existência de livre trânsito entre o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça para admissibilidade recursal (arts. 1.032 e 1.033, CPC/2015), a concentração de julgamentos em bloco (recursos repetitivos, arts. 1.036 a 1.041, CPC/2015), assim como a eficácia de precedente que se projeta a partir das razões de suas decisões (arts. 926 e 927, CPC/2015) pressupõem a caracterização do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça como verdadeiras Cortes Supremas, isto é, como cortes de

interpretação e de precedentes – e não mais como simples cortes de controle e de jurisprudência.

Contudo, essa transformação – que, como já observamos,¹¹ deslocou o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça do âmbito de influência do modelo de cortes superiores para o modelo de cortes supremas – obviamente não foi apenas obra do processo civil. Na verdade, a mudança do perfil do recurso extraordinário e do recurso especial decorre mais de uma alteração na compreensão do significado do direito em geral, oriunda especialmente da teoria da interpretação, do que propriamente de uma alteração cifrada ao tecido processual.

É preciso perceber que, partindo-se do pressuposto de que a norma jurídica constitui resultado e não objeto da interpretação, facilmente se conclui que a tarefa de uma corte de vértice não pode ser a de tutela da norma do legislador contra eventual arbítrio do judiciário (simplesmente porque o direito antes da interpretação é duplamente indeterminado), mas deve ser de colaboração com o legislador a fim de que se logre unidade do direito – e, portanto, vigência efetiva, e não apenas imaginária ou retórica, dos princípios da segurança jurídica, da liberdade e da igualdade de todos perante o direito. O julgamento de um recurso extraordinário ou de um recurso especial constitui, portanto, uma oportunidade para que o Supremo Tribunal Federal ou o Superior Tribunal de Justiça outorguem adequada interpretação ao direito, adscrevendo significado ao discurso do legislador (aos textos constitucionais e legais), reduzindo com isso o grau de indeterminação inerente ao direito.

Em outras palavras, durante muito tempo a interpretação do direito foi apenas um meio para que essas cortes de vértice lograssem o fim do controle dos casos evidenciados pelas decisões judiciais recorridas. Com o redimensionamento do papel dessas cortes, o controle das decisões tomadas no caso concreto (a aplicação do direito à espécie, como menciona o art. 1.034, CPC/2015) é apenas um meio a fim de que a real finalidade dessas cortes possa ser desempenhada: o oferecimento de razões capazes de diminuir a indeterminação do direito mediante adequada interpretação. Se antes a interpretação era o meio e o controle do caso era o fim, agora o controle do caso é o meio que proporciona o atingimento do fim da interpretação.

A compreensão do contexto teórico em que aparece essa silenciosa e profunda reforma nas fundações do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça é imprescindível para que se possa entender o material com que trabalham essas Cortes Supremas no julgamento de recursos extraordinários e de recursos especiais, a função paradigmática que desempenham na nossa ordem jurídica e a eficácia que se deve outorgar aos seus julgados. Enquanto as Cortes de Justiça – os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais – assumiram o posto de cortes de controle e de jurisprudência, cuja preocupação é voltada para a prolação de uma decisão justa e para o fomento do debate a respeito dos mais diversos significados que o discurso do legislador pode assumir no âmbito interpretativo, as Cortes Supremas galgaram o posto de cortes de interpretação e de precedentes, cuja missão está não apenas na guarda da Constituição e do direito federal, mas na sua efetiva reconstrução interpretativa, decidindo-se quais os significados devem prevalecer a respeito das dúvidas interpretativas suscitadas pela prática forense, e na sua vocação de guia interpretativo para todos os envolvidos na administração da Justiça Civil e para a sociedade como um todo.¹²

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça não podem ser pensados como cortes que apenas declaram o sentido prévio, intrínseco e unívoco da Constituição e da legislação infraconstitucional federal. A potencial equivocidade da linguagem¹³ – fruto da ambiguidade, implicabilidade, superabilidade e abrangibilidade dos enunciados textuais – impede que se considere o processo de interpretação do Direito como algo neutro e cujo resultado é unívoco. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, pelo contrário, são cortes que *outorgam sentido* à Constituição e à legislação infraconstitucional federal e visam *reduzir a equivocidade* dos enunciados linguísticos em que o Direito comumente é vazado. *São cortes, em última análise, que decidem o sentido da Constituição e da legislação infraconstitucional federal.*

Isso significa duas coisas da mais alta importância: a primeira, que *a atividade de interpretação é uma atividade de reconstrução*. Não se trata de simples atividade de *descoberta lógico-cognitiva*, nem de *pura construção* normativa.¹⁴ Interpretar implica individualizar, valorar e decidir. Sob

esse aspecto conceitual, a propósito, *inexiste qualquer diferença entre a interpretação da Constituição e da interpretação da legislação infraconstitucional federal* – em ambos os casos é necessário individualizar sentidos possíveis, valorá-los e escolher aquele que encontra maior suporte na ordem jurídica.¹⁵ Sendo a linguagem potencialmente equívoca, interpretar significa ao fim e ao cabo *decidir* a respeito da melhor interpretação possível que deve ser dada à legislação em um determinado contexto. Assim, longe de ter um *papel periférico* na teoria do Direito, a interpretação ocupa um *posto central* na experiência jurídica contemporânea,¹⁶ tendo em conta que o *significado normativo não é prévio ao processo de interpretação*.¹⁷ Imaginar que o processo interpretativo não implica valorações e escolhas do intérprete *serve apenas para deixar sem qualquer teorização e longe da possibilidade de qualquer tipo de controle jurídico e social as inúmeras decisões tomadas ao longo da interpretação*. Vale dizer: *serve apenas como um alibi teórico*. É por essa razão que a doutrina observa que o formalismo interpretativo oitocentista – notadamente da *Ecole de l'Exégèse* e da *Begriffsjurisprudenz* – deixa o juiz tão livre para decidir quanto ao antiformalismo na sua feição mais radical ligada ao movimento do direito livre – notadamente da *libre recherche scientifique* e da *Freirechtsbewegung* –, na medida em que ambos não viabilizam a tematização das valorações e escolhas inerentes ao processo interpretativo.¹⁸

Vale dizer: a *atividade interpretativa* impõe a *outorga de sentido* a textos e a elementos não textuais da ordem jurídica. O *resultado da interpretação* não é obtido por simples operações lógicas, mas decorre da individualização de sentidos possíveis, valorações e decisões entre os significados concorrentes que devem ser atribuídos aos enunciados linguísticos. Para tanto, devem o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, cada qual circunscrito ao âmbito de sua competência constitucional, *justificar lógico-argumentativamente suas decisões*, outorgando adequado sentido ao material fático-jurídico da causa e, muito especialmente, aos princípios, regras e postulados que têm o dever de interpretar e observar para viabilização da unidade do Direito (arts. 926 e 927, CPC/2015). A *justificação judicial*, em outras palavras, é o núcleo-duro da atividade do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, a partir da qual as *partes* podem aferir a *fundamentação* e a *sociedade civil e demais cortes judiciárias* podem reconhecer o *precedente* de seus julgados (arts. 6.º, 489, §§ 1.º e 2.º, 926 e 927, CPC/2015).

A segunda, que *inexiste uma única resposta correta para problemas interpretativos* – nem para os chamados casos fáceis (*easy cases*), nem para os chamados casos difíceis (*hard cases*).¹⁹ Toda interpretação depende de *escolhas* juridicamente guiadas que devem ser realizadas pelo intérprete – o que obviamente não infirma a possibilidade de um *discurso justificativo racional intersubjetivamente controlável* capaz de conduzir à adequada interpretação da legislação.²⁰ A alocação de um caso dentro da categoria fácil ou difícil, como é evidente, por si só depende de prévia valoração e escolha e, pois, de uma decisão que envolve interpretação.²¹ Isso quer dizer que *do ponto de vista do sistema de distribuição de justiça* o sentido da norma em *todos os casos* deve ser decidido por quem está *legitimado institucionalmente para tanto*, isto é, por quem a Constituição determina semelhante atribuição. Em nossa ordem constitucional, é o *Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça* que devem, mediante um processo lógico-argumentativo, *afirmar qual é o significado que deve ser dado à Constituição e à legislação infraconstitucional federal nos mais diversos contextos fático-jurídicos em que essas devem ser atuadas* (arts. 102, III, e 105, III, CF/1988).

A atividade interpretativa que culmina com a afirmação de um resultado normativo é fruto de um *processo lógico-argumentativo* que tem sua expressão material na *justificação judicial* de uma determinada decisão. Trata-se de uma *concepção* de interpretação jurídica orientada em termos gerais para promoção do império do Direito (“legality”) mediante uma atividade guiada pela racionalidade (“rationality”).²² A *justificação judicial* é o meio pelo qual se pode aferir a *racionalidade* da atividade interpretativa e do seu *resultado*. A atividade interpretativa é racional se apresenta *justificação interna* e *justificação externa*.²³ O resultado da interpretação é racional se é *universalizável e coerente*.

De um lado, uma decisão apresenta *justificação interna* (*interne Rechtfertigung*) sempre que o *dispositivo decorre logicamente da fundamentação* e que essa contempla *todos os fundamentos* arguidos pelas partes. Na justificação interna, portanto, interessa a *correção lógica* e a *completude*

da motivação da decisão.²⁴ Daí que a justificação interna é uma justificação *formal* que responde à *necessidade de não contradição* no discurso jurídico.²⁵ É o campo em que a *lógica* atua no processo interpretativo,²⁶ no qual o julgador raciocina de forma *dedutiva* para solução das questões.²⁷

De outro, uma decisão tem justificação externa (externe Rechtfertigung) sempre que as premissas adotadas na decisão são adequadas. A justificação externa, portanto, concerne à adequação das escolhas das premissas empregadas na justificação interna. Nessa linha, constitui uma justificação material que responde à necessidade de adoção de razões suficientes para tomada de decisão,²⁸ envolvendo o exame tanto de normas como de fatos,²⁹ na medida em que entre ambos existe uma absoluta implicação.³⁰ É o campo em que a argumentação atua no processo interpretativo,³¹ no qual o julgador individualiza, valora e decide de forma não dedutiva.³²

Como campo próprio da argumentação jurídica, entram em consideração na justificação externa, por exemplo, as normas jurídicas, as normas sobre interpretação, as normas preferenciais argumentativas e as construções doutrinárias empregadas na decisão.³³ Em outras palavras, encontra-se no âmbito da justificação externa o *material* que à disposição do intérprete para consecução do processo interpretativo. No que concerne às normas jurídicas, impende observar que quanto *maior a abertura semântica, maior a justificativa* que deve ser empreendida para sua aplicação. Isso vale para todas as espécies normativas, mas ganha especial relevo no direito brasileiro para a aplicação dos *princípios jurídicos* e para concretização de *termos vagos* empregados pelo legislador.³⁴ Em todo e qualquer caso, o processo argumentativo que justifica as escolhas ligadas às premissas do raciocínio judiciário deve ser orientado por *códigos interpretativos*, os quais fornecem *diretrizes primárias*, que servem para atribuição de significado a enunciados textuais (por exemplo, *diretrizes para interpretação linguística, para interpretação da intenção do legislador e para interpretação teleológica*), *diretrizes secundárias*, que servem para disciplina e valoração da utilização das diretrizes primárias (por exemplo, *diretrizes seletivas e procedimentais*, dentre as quais se destacam as *preferenciais*) e *diretrizes terciárias*, que servem para outorgar uma direção ao processo interpretativo como um todo (por exemplo, *diretriz que entende que o fim da interpretação está na promoção da segurança jurídica*).³⁵ Dentre as diretrizes secundárias de maior importância para o processo argumentativo encontram-se aquelas que erigem *diretrizes preferenciais* – que, por exemplo, determinam a prevalência *prima facie*, nesta ordem, de *argumentos linguísticos* (*linguistic arguments*), *sistemáticos* (*systemic arguments*) e *teleológicos* (*teleological-evaluative arguments*).³⁶ Vale dizer: argumentos *linguísticos* são preferíveis a argumentos *sistemáticos*, argumentos *sistemáticos* são preferíveis a argumentos *teleológicos* e assim por diante.³⁷

O resultado da interpretação é racional sempre que a justificação guarda em si a capacidade de *universalização* (“universalization in justification”).³⁸ Como enfaticamente observa a doutrina, “there is no justification without universalization”.³⁹ Em outras palavras, a justificação tem que ter condições de ser *replicável* para os casos futuros idênticos ou semelhantes, isto é, tem de ser idônea para servir como *precedente*. Sem replicabilidade (“replicability”) da justificação, não há *objetividade* e *imparcialidade* na interpretação⁴⁰ – e isso obviamente *independe da efetiva vigência de um sistema de precedentes obrigatórios por força de uma norma específica de direito positivo*, sendo uma *simples decorrência do caráter lógico-argumentativo do Direito*.⁴¹

Por fim, o produto da interpretação tem de ser *coerente*. A interpretação tem de ser capaz de ser reconduzida a “um conjunto, internamente consistente, formal e materialmente, de princípios e regras” amalgamadas por “princípios fundamentais” comuns.⁴² Racionalidade, universabilidade e coerência na justificação visam assegurar a *correção* da interpretação.⁴³ Em outras palavras, isto quer dizer no fundo que *a correção da interpretação é assegurada, de um lado, pela racionalidade da atividade de justificação e, por outro, pela capacidade de universalização e pela coerência do seu resultado*.

Para atuarem de forma adequada, dando unidade ao Direito, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça devem trabalhar lógico-argumentativamente, interpretando de maneira justificada, universalizável e coerente os enunciados constitucionais e

infraconstitucionais federais. É a partir desse *método* interpretativo que essas cortes poderão fornecer *boas razões* para *pacificar* o entendimento judicial a respeito de determinada questão e para *desenvolver* o direito brasileiro, ofertando para o sistema *verdadeiros precedentes* capazes de promover a igualdade e segurança jurídica para toda a sociedade civil. Isso significa que o problema da *fidelidade ao Direito*, portanto, passa a ser um problema fundamentalmente dinâmico e metodológico.⁴⁴ Vale dizer: *a partir do exato momento em que essas cortes começarem a atuar sistematicamente dessa maneira é que serão capazes de outorgar sentido adequado à legislação e de fazê-lo conhecido e efetivo.*

Como parece evidente, não é possível promover a unidade do Direito sem uma “common interpretation of the law”⁴⁵ pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça, dado que *sem interpretação não há sentido normativo* que deve ser *observado* dentro da ordem jurídica. A produção de sentidos normativos de forma *racional* – justificada, universalizável e coerente – constitui *elemento essencial* para promoção da tutela dos direitos no Estado Constitucional.

A propósito, é exatamente essa a linha que vem prevalecendo nas Cortes Supremas.

Já teve a oportunidade de decidir o Supremo Tribunal Federal: “Ingresso na carreira da magistratura. Art. 93, I, CRFB. EC 45/2004. Triênio de atividade jurídica privativa de bacharel em Direito. Requisito de experimentação profissional. Momento da comprovação. Inscrição definitiva. Constitucionalidade da exigência. ADI 3.460. Reafirmação do precedente pela Suprema Corte. Papel da corte de vértice. Unidade e estabilidade do direito. Vinculação aos seus precedentes. *Stare decisis*. Princípios da segurança jurídica e da isonomia. Ausência dos requisitos de superação total (*Overruling*) do precedente. 1. A exigência de comprovação, no momento da inscrição definitiva (e não na posse), do triênio de atividade jurídica privativa de bacharel em Direito como condição de ingresso nas carreiras da magistratura e do ministério público (arts. 93, I e 129, §3º, CRFB - na redação da Emenda Constitucional n. 45/2004) foi declarada constitucional pelo STF na ADI 3.460. 2. Mantidas as premissas fáticas e normativas que nortearam aquele julgamento, reafirmam-se as conclusões (*ratio decidendi*) da Corte na referida ação declaratória. 3. O papel de Corte de Vértice do Supremo Tribunal Federal impõe-lhe dar unidade ao direito e estabilidade aos seus precedentes. 4. Conclusão corroborada pelo Novo Código de Processo Civil, especialmente em seu artigo 926, que ratifica a adoção – por nosso sistema – da regra do *stare decisis*, que ‘densifica a segurança jurídica e promove a liberdade e a igualdade em uma ordem jurídica que se serve de uma perspectiva lógico-argumentativa da interpretação’ (MITIDIERO, Daniel. *Precedentes*: da persuasão à vinculação. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016). 5. A vinculação vertical e horizontal decorrente do *stare decisis* relaciona-se umbilicalmente à segurança jurídica, que ‘impõe imediatamente a imprescindibilidade de o direito ser cognoscível, estável, confiável e efetivo, mediante a formação e o respeito aos precedentes como meio geral para obtenção da tutela dos direitos’ (Mitidiero, Daniel. Cortes superiores e cortes supremas: do controle à interpretação, da jurisprudência ao precedente. São Paulo: Revista do Tribunais, 2013). 6. Igualmente, a regra do *stare decisis* ou da vinculação aos precedentes judiciais ‘é uma decorrência do próprio princípio da igualdade: onde existirem as mesmas razões, devem ser proferidas as mesmas decisões, salvo se houver uma justificativa para a mudança de orientação, a ser devidamente objeto de mais severa fundamentação. Daí se dizer que os precedentes possuem uma força presumida ou subsidiária’ (ÁVILA, Humberto. *Segurança jurídica*: entre permanência, mudança e realização no Direito Tributário. São Paulo: Malheiro, 2011). 7. Nessa perspectiva, a superação total de precedente da Suprema Corte depende de demonstração de circunstâncias (fáticas e jurídicas) que indiquem que a continuidade de sua aplicação implicam ou implicarão inconstitucionalidade. 8. A inocorrência desses fatores conduz, inexoravelmente, à manutenção do precedente já firmado. 9. Tese reafirmada: ‘é constitucional a regra que exige a comprovação do triênio de atividade jurídica privativa de bacharel em Direito no momento da inscrição definitiva’. 10. Recurso extraordinário desprovido”⁴⁶.

Outra não é a posição do Superior Tribunal de Justiça: “Tenho dito, em votos justamente voltados a fazer prevalecer o entendimento consagrado no, agora superado, HC 84.078/MG, que nenhum acréscimo às instituições e ao funcionamento do sistema de justiça criminal resulta da

não vinculação de magistrados à clara divisão de competências entre os diversos órgãos judiciários, com base na qual cabe ao Superior Tribunal de Justiça a interpretação do direito federal e ao Supremo Tribunal Federal a interpretação da Constituição da República. Em verdade, como acentua a doutrina mais abalizada: ‘a violação à interpretação ofertada pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça é uma insubordinação institucional da mais alta gravidade no Estado Constitucional. E isso não só pelo fato de existir uma divisão de trabalho muito clara entre Cortes de Justiça e Cortes de Precedentes, mas fundamentalmente pelo fato de a violação ao precedente encarnar um duplo e duro golpe no Direito – a um só tempo viola-se autoridade da legislação, consubstanciada na interpretação a ela conferida, e viola-se a autoridade do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça como Cortes Supremas, constitucionalmente encarregadas de dar a última palavra a respeito do significado da Constituição e da legislação infraconstitucional federal. Nesse contexto, afastar-se do precedente deve ser visto como uma falta grave em relação ao dever judicial de fidelidade ao Direito. Em duas palavras, deve ser visto como uma evidente arbitrariedade’ (MITIDIERO, Daniel. *Cortes Superiores e Cortes Supremas. Do Controle à Interpretação, da Jurisprudência ao Precedente*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 96-97). No mesmo sentido: “o juiz é uma ‘peça’ no sistema de distribuição de justiça e não alguém que é investido de Poder estatal para satisfazer as suas vontades. Para que esse sistema possa adequadamente funcionar, cada um dos juízes deve se comportar de modo a permitir que o Judiciário possa se desincumbir do seu dever de prestar a tutela jurisdicional de forma isonômica e sem ferir a coerência do direito e a segurança jurídica. Portanto, a absurda e impensada ideia de dar ao juiz o poder de julgar o caso como quiser, não obstante ter o Tribunal Superior já conferido os seus contornos, é hoje completamente insustentável. Desconsidera que as Supremas Cortes, na atualidade, têm a função de dar sentido ao Direito e desenvolvê-lo ao lado do Legislativo’ (MARINONI, Luiz Guilherme. *O STJ enquanto Corte de Precedentes: Recompreensão do Sistema Processual da Corte Suprema*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 129-130)”⁴⁷.

Enquanto Cortes Supremas, portanto, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça não têm como função controlar a aplicação da Constituição e da legislação federal aos casos concretos – ou melhor, essa atividade é apenas um subproduto da sua função preponderante. Consequentemente, não têm como função uniformizar a aplicação da Constituição e da legislação federal a todos os casos: a função do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça está em outorgar unidade ao direito, a fim de que inexistam decisões discrepantes (e, portanto, não uniformes), depois de assentados os respectivos precedentes constitucionais e federais.

É claro que isso não quer dizer que o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça atuam como *legisladores* na nossa ordem constitucional. A diferença entre o legislador e o juiz não está em que o primeiro cria a norma e o segundo apenas a declara – como pressupunham a “ideology of bound judicial decision-making”⁴⁸ e a doutrina processual civil italiana da primeira metade de Novecentos,⁴⁹ aceita por muito tempo pela doutrina processual civil brasileira sem qualquer filtro crítico.⁵⁰ Isso porque a *norma é o resultado da interpretação*, não o seu pressuposto. O legislador outorga textos que, interpretados judicialmente, geram normas jurídicas. A propósito, a diferença entre o legislador e as Cortes Supremas também não está em que o primeiro pode atuar de forma positiva e negativa, ao passo que os segundos só poderiam atuar de forma negativa (como *legisladores negativos*).⁵¹ E isso por duas razões: a uma, porque a atuação interpretativa dessas cortes é uma *atuação reconstrutiva* e, portanto, de *definição positiva de normas* a partir de *textos* legislativos; a duas, porque existem *situações jurídicas jurisdicionlizáveis* em que a aplicação da norma que prevê a *igualdade* de todos perante o Direito exige igualmente *atuação positiva* dessas cortes.⁵²

Na verdade, a diferença entre a legislação e a jurisdição está em que o legislador propõe enunciados linguísticos sem qualquer necessidade de justificação, ao passo que o juiz só pode decidir reconstruindo sentidos normativos mediante justificação. Portanto, é a *necessidade de justificação* para tomada de decisões que distingue a legislação da jurisdição no Estado Constitucional.⁵³ Dentro dessa linha, é evidente que o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça *não atuam como legisladores*, na medida em que não podem decidir sem justificação (art. 93, IX, CF/1988). Ambos, contudo, *colaboram estreitamente* com o legislador para

promoção do império do Direito. É tarefa do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça outorgar unidade ao Direito no Brasil mediante adequada interpretação da Constituição e da legislação, o que implica inevitavelmente individualizar, valorar e decidir a respeito de sentidos possíveis em que os enunciados linguísticos podem ser compreendidos.

2. Recurso extraordinário e recurso especial. Ao contrário dos recursos ordinários (apelação, agravo de instrumento, agravo interno, embargos declaratórios e recurso ordinário – arts. 1.009 a 1.028, CPC/2015), o recurso extraordinário e o recurso especial não visam diretamente à tutela do direito da parte (não visam à prolação de uma “decisão de mérito justa e efetiva” para o caso concreto, art. 6.º, CPC/2015). Objetivam precipuamente a unidade do direito brasileiro – mediante a compreensão da Constituição (recurso extraordinário, art. 102, III, CF/1988) e do direito infraconstitucional federal (recurso especial, art. 105, III, CF/1988). Vale dizer: visam à coerência e a universabilidade da ordem jurídica (art. 926, CPC/2015). Em outras palavras, enquanto as Cortes de Justiça estão preocupadas com a prolação de uma decisão justa, desenvolvendo um discurso jurídico ligado à tutela dos direitos em uma perspectiva particular, as Cortes Supremas estão preocupadas em canalizar seus esforços para a formação de precedentes, fomentando um discurso jurídico ligado à tutela do direito em uma perspectiva geral.⁵⁴

Para tanto, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça se valem do caso concreto delineando no recurso extraordinário e no recurso especial, utilizando-o como um meio para viabilização de uma adequada interpretação da Constituição e do direito federal. É claro que o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, conhecendo do recurso extraordinário e do recurso especial, têm de julgar a causa, aplicando o direito à espécie (art. 1.034, CPC/2015). Essa disposição, porém, deve ser compreendida apenas para sinalizar que o recurso extraordinário e o recurso especial não têm apenas função cassacional, prestando-se a possibilitar a substituição da decisão recorrida. O controle do caso concreto, com a aplicação do direito à espécie, é um meio que o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça empreendem para alcançar o verdadeiro fim do recurso extraordinário e do recurso especial – viabilizar uma adequada interpretação capaz de outorgar unidade ao direito (art. 926, CPC/2015). Apresentando a decisão, ao mesmo tempo, causa constitucional e causa federal, cabe a interposição simultânea de recurso extraordinário e de recurso especial.

3. Causa constitucional e causa federal. O recurso extraordinário e o recurso especial são recursos de fundamentação vinculada – o âmbito de discussão propiciado por esses recursos vai desde logo circunscrito à causa constitucional ou à causa federal evidenciada no processo. Mais propriamente: evidenciada na decisão recorrida. Daí a razão pela qual “é inadmissível o recurso extraordinário quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada” (Súmula 282, STF). A questão enfrentada no voto vencido, contudo, serve para caracterização da causa constitucional ou da causa federal (art. 941, § 3.º, CPC/2015 – superada a Súmula 320, STJ). É imprescindível que a questão constitucional ou a questão federal esteja estampada na decisão recorrida, na medida em que “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” (Súmula 279, STF). “A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial” (Súmula 7, STJ). “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário” (Súmula 280, STF), sendo que “a simples interpretação de cláusula contratual não enseja recurso especial” (Súmula 5, STJ). O Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado no sentido de que “não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida” (Súmula 636, STF). Ainda: “não cabe recurso extraordinário por violação de lei federal, quando a ofensa alegada for a regimento de tribunal” (Súmula 399, STF). “Não cabe recurso extraordinário contra acórdão de Tribunal de Justiça que defere pedido de intervenção estadual em Município” (Súmula 637, STF). “Não cabe recurso extraordinário contra decisão proferida no processamento de precatórios” (Súmula 733, STF).

4. **Prequestionamento e embargos de declaração.** Para que o recurso extraordinário seja admitido, é imprescindível que a causa constitucional ou federal esteja evidenciada na decisão recorrida. Não é necessário que o acórdão recorrido tenha feito referência expressa aos dispositivos da Constituição ou da legislação federal. Basta que a decisão recorrida tenha enfrentado a tese jurídica que envolve a compreensão da Constituição ou do direito federal – é

irrelevante a “ausência de menção dos dispositivos constitucionais atinentes aos temas versados”.⁵⁵

Se o tribunal de origem não enfrenta expressamente a causa constitucional ou federal, então tem a parte de opor embargos declaratórios a fim de prequestioná-la, provocando a manifestação do tribunal de origem a respeito do tema (art. 1.022, II, CPC/2015 – Súmula 356, STF: “o ponto omissio da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”). Se, todavia, o tribunal de origem desacolhe os embargos de declaração, declarando que não há omissão no acórdão recorrido, está o recorrente autorizado a desde logo interpor recurso extraordinário ou recurso especial para discutir a matéria constitucional perante o Supremo Tribunal Federal e a matéria federal perante o Superior Tribunal de Justiça. A omissão indevida constituirá matéria de análise preliminar no recurso extraordinário ou no recurso especial. Isso porque, como refere o art. 1.025, CPC/2015, consideram-se “incluídos no acórdão os elementos que o embargante pleiteou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

5. Única ou última instância. A decisão que comporta impugnação por recurso extraordinário ou por recurso especial é a decisão de única ou última instância (arts. 102, III, e 105, III, CF/1988). Vale dizer: a interposição de recurso extraordinário ou de recurso especial está condicionada ao prévio esgotamento da instância ordinária. Pouco importa que a decisão de última instância tenha sido tomada em agravo de instrumento (Súmula 86, STJ: “cabe recurso especial contra acórdão proferido no julgamento de agravo de instrumento”).

Se, na instância ordinária, o relator julgou o recurso monocraticamente (art. 932, III a V, CPC/2015), a jurisprudência entende que é imprescindível a interposição do agravo interno para o colegiado (art. 1.021, CPC/2015), sob pena de não configurado o esgotamento da instância exigido para o conhecimento do recurso extraordinário e do recurso especial⁵⁶. Observe-se que a decisão para desafiar recurso extraordinário ou recurso especial tem de ser decisão de última instância.

Não se pode confundir, por fim, decisão definitiva com decisão de última instância – uma decisão provisória (como aquelas que decidem a respeito da tutela antecipada e da tutela cautelar) pode constituir decisão de última instância. A última instância caracteriza-se por carregar o último pronunciamento do tribunal sobre a questão tal como ela se apresenta naquele momento procedimental. Se há urgência em prover, a decisão do tribunal ordinário que concede ou nega a antecipação de tutela, por exemplo, é a última decisão ordinária a respeito da necessidade ou não de tutela de urgência (contra, todavia, Súmula 735, STF: “não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”).

6. Cabimento recurso extraordinário. O art. 102, III, CF/1988, arrola as hipóteses em que tem cabimento o recurso extraordinário. Basta a afirmação da parte para que o recurso seja cabível. Se efetivamente a afirmação da parte se verifica ou não constitui o mérito do recurso extraordinário.

A aplicação de norma (princípio, regra ou postulado) à situação por ela não alcançada vale por contrariá-la.⁵⁷ O Supremo Tribunal Federal tem precedentes no sentido de que a alegação de violação do devido processo legal, da motivação, do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional constitui “ofensa meramente reflexa ao texto da Constituição, circunstância essa que impede a utilização do recurso extraordinário”.⁵⁸ Tem igualmente, todavia, orientação mais consentânea à natureza fundamental do direito ao processo justo e à tutela jurisdicional adequada e efetiva no sentido de que a violação à cláusula do devido processo legal deve ser examinada caso a caso a fim de saber-se se há ou não violação da Constituição por conta de infração de normas processuais fundamentais.⁵⁹

O Supremo Tribunal Federal tem precedentes entendendo possível a “confirmação da decisão recorrida por fundamento constitucional diverso daquele em que se alicerçou o acórdão recorrido e em cuja inaplicabilidade ao caso se baseia o recuso extraordinário: manutenção, lastreada na garantia da irredutibilidade de vencimentos, da conclusão do acórdão recorrido, não obstante fundamentado este na violação do direito adquirido. Recurso extraordinário: letra a: alteração da

tradicional orientação jurisprudencial do STF, segundo a qual só se conhece do RE, a, se for para dar-lhe provimento: distinção necessária entre o juízo de admissibilidade do RE, a – para o qual é suficiente que o recorrente alegue adequadamente a contrariedade pelo acórdão recorrido de dispositivos da Constituição nele prequestionados – e o juízo de mérito, que envolve a verificação da compatibilidade ou não entre a decisão recorrida e a Constituição, ainda que sob prisma diverso daquele em que se hajam baseado o Tribunal *a quo* e o recurso extraordinário”.⁶⁰

7. Cabimento recurso especial. O art. 105, III, CF/1988, arrola as hipóteses em que tem cabimento o recurso especial. Basta a afirmação da parte para que o recurso seja cabível. Se efetivamente a afirmação da parte se verifica ou não constitui o mérito do recurso especial. A inadmissão de recurso especial quando presente qualquer das alíneas do art. 105, III, CF/1988, importa na sua violação. Assim: “recurso extraordinário. Decisão do Superior Tribunal de Justiça que inadmite recurso especial. Cabimento. Hipótese excepcional. Admite-se recurso extraordinário contra decisão do Superior Tribunal de Justiça que, no exame do cabimento de recurso especial, assenta proposição contrária em tese ao disposto no art. 105, III e alíneas da Constituição Federal. Acórdão do Superior Tribunal de Justiça que entendeu não caber recurso especial contra acórdão de Tribunal de Justiça proferido em agravo de instrumento. O termo ‘causa’ empregado no art. 105, III, da Constituição compreende qualquer questão federal resolvida em única ou última instância, pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos tribunais dos Estados, Distrito Federal e Territórios, ainda que mediante decisão interlocutória”.⁶¹

8. Recurso extraordinário, recurso especial e direito probatório. O recurso extraordinário e o recurso especial não se prestam a propiciar nova valoração da prova dos autos (Súmula 279, STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”; Súmula 7, STJ: “a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”). Servem, contudo, para viabilizar a adequada interpretação capaz de proporcionar a devida aplicação das normas de direito probatório. Vale dizer: eventuais violações às normas sobre a admissão da prova (que envolve a verificação da pertinência, relevância e controvérsia da alegação), sobre o modelo de constatação das alegações de fato empregado pelo julgador (prova acima da dúvida razoável, prova clara e convincente, preponderância de prova etc.), sobre as regras sobre o ônus da prova (principalmente no que tange à inversão do encargo probatório), sobre as categorias das máximas de experiência, sobre as dispensas de prova, entre outras, desafiam a interposição de recursos, conforme o caso, ao Supremo Tribunal Federal ou ao Superior Tribunal de Justiça.

Uma coisa é a valoração da prova dos autos; outra é a violação sobre normas sobre a prova – o primeiro caso não autoriza recurso extraordinário ou recurso especial; autoriza-o, todavia, o segundo. Daí que é possível afirmar que o STF e o STJ devem julgar os respectivos recursos *pressupondo a valoração probatória das alegações de fato* realizada pela instância ordinária. É o que, por exemplo, determina a *Zivilprozessordnung* alemã ao *Bundesgerichtshof* no âmbito do recurso de *Revision* (§ 559, n. 2, segundo o qual o tribunal de revisão (*Revisionsgericht*) está vinculado (*bindend*) à verdade ou à falsidade das alegações de fato (*tatsächliche Behauptung wahr oder nicht wahr*) proclamada pelo tribunal de apelo). Vinculados à verificação das alegações de fato ocorrida nas instâncias ordinárias, pode o STF e o STJ reverem a interpretação e a aplicação de normas de direito probatório.

9. Recurso extraordinário, recurso especial e juizados especiais. “É cabível recurso extraordinário contra decisão proferida por juiz de primeiro grau nas causas de alçada, ou por turma recursal de juizado especial cível e criminal” (Súmula 640, STF). “Não cabe recurso especial contra decisão proferida por órgão de segundo grau dos Juizados Especiais” (Súmula 203, STJ).

Subseção I Disposições Gerais

Art. 1.029. O recurso extraordinário e o recurso especial, nos casos previstos na Constituição Federal, serão interpostos perante o presidente ou o vice-presidente do tribunal recorrido, em petições distintas que conterão:

I – a exposição do fato e do direito;

II – a demonstração do cabimento do recurso interposto;

III – as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão recorrida.

§ 1.º Quando o recurso fundar-se em dissídio jurisprudencial, o recorrente fará a prova da divergência com a certidão, cópia ou citação do repositório de jurisprudência, oficial ou credenciado, inclusive em mídia eletrônica, em que houver sido publicado o acórdão divergente, ou ainda com a reprodução de julgado disponível na rede mundial de computadores, com indicação da respectiva fonte, devendo-se, em qualquer caso, mencionar as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados.

§ 2.º (*Revogado.*)

* § 2.º revogado pela Lei 13.256/2016.

§ 3.º O Supremo Tribunal Federal ou o Superior Tribunal de Justiça poderá desconsiderar vício formal de recurso tempestivo ou determinar sua correção, desde que não o repute grave.

§ 4.º Quando, por ocasião do processamento do incidente de resolução de demandas repetitivas, o presidente do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça receber requerimento de suspensão de processos em que se discuta questão federal constitucional ou infraconstitucional, poderá, considerando razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, estender a suspensão a todo o território nacional, até ulterior decisão do recurso extraordinário ou do recurso especial a ser interposto.

§ 5.º O pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário ou a recurso especial poderá ser formulado por requerimento dirigido:

I – ao tribunal superior respectivo, no período compreendido entre a publicação da decisão de admissão do recurso e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-lo;

* Inciso I do § 5.º com redação determinada pela Lei 13.256/2016.

II – ao relator, se já distribuído o recurso;

III – ao presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido, no período compreendido entre a interposição do recurso e a publicação da decisão de admissão do recurso, assim como no caso de o recurso ter sido sobrestado, nos termos do art. 1.037.

* Inciso III do § 5.º com redação determinada pela Lei 13.256/2016.

1. Cabimento. Preliminarmente, o recorrente tem o ônus de demonstrar o cabimento do recurso extraordinário ou do recurso especial à luz dos permissivos constitucionais (arts. 102, III, § 3.º, e 105, III, CF/1988, e art. 1.035, CPC/2015). Tem de apontar no que consiste, na decisão recorrida, a causa constitucional ou a causa federal.⁶² Não basta que o recorrente discorra “aleatoriamente” sobre a matéria versada na causa – tem de demonstrar no que precisamente a decisão recorrida viola a Constituição ou o direito infraconstitucional federal.⁶³

2. Fatos do caso. Em recurso extraordinário e em recurso especial a parte não apenas pode, mas na verdade tem o ônus de caracterizar os fatos do caso – ou melhor, de delinear o caso em todos os seus aspectos fático-jurídicos (art. 1.029, I, CPC/2015). Daí que é tecnicamente incorreto afirmar que não se pode conhecer de fatos em recurso extraordinário e em recurso especial: o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça podem conhecer de fatos, porque do contrário não teriam como conhecer do próprio caso levado à consideração mediante recurso extraordinário e recurso especial.

O material que pode ser trabalhado em recurso extraordinário e em recurso especial, portanto, é composto de fatos e de direito – até mesmo porque fato e direito se interpenetram no processo de

delimitação do caso, interpretação e aplicação do direito.⁶⁴ O que não é possível é rediscutir a existência ou inexistência dos fatos em recurso extraordinário e em recurso especial (Súmula 279, STF, e Súmula 7, STJ). Vale dizer: o recorrente tem que trabalhar com o caso em seu recurso partindo da narrativa fática estabelecida pela decisão recorrida. Consequentemente, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça não podem considerar existente fato considerado inexistente e, considerar inexistente fato considerado existente pela decisão recorrida. Essa perspectiva teórica explica a razão pela qual, por exemplo, é possível obter do Superior Tribunal de Justiça pronúncia voltada ao adequado dimensionamento da reparação de danos civis, notadamente de danos morais.⁶⁵ Em situações dessa ordem, discute-se o caso em todos os seus aspectos, mas não se interfere na conformação do caso outorgada pela decisão recorrida.

3. **Interpretação de cláusulas negociais.** Ao tempo em que identificado como simples corte de controle e de jurisprudência – portanto, sem função interpretativa precípua e sem força de precedente – era comum excluir de forma absoluta do conhecimento do Superior Tribunal de Justiça discussões a respeito da adequada interpretação de cláusulas negociais (Súmula 5, STJ: “a simples interpretação de cláusula contratual não enseja recurso especial”). Dito de outro modo, o recorrente não poderia fundar o seu recurso especial na necessidade de outorgar adequada interpretação à determinada cláusula negocial.

No entanto, é preciso perceber que a vedação à obtenção de adequada interpretação de cláusula negocial deve cobrir apenas as cláusulas que interessam apenas ao caso concreto e que não têm potencial paradigmático. Tomada como uma corte de interpretação e de precedentes, o Superior Tribunal de Justiça em recurso especial pode – e deve – se pronunciar sobre cláusulas negociais típicas, notadamente quando se revelem de vasta utilização no tráfego jurídico (por exemplo, fixação da abusividade ou não de uma cláusula inserida em contratos de adesão).⁶⁶

4. **Razões.** Devem ser suficientes e completas. Suficientes, porque “é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia” (Súmula 284, STF). “Nega-se provimento ao agravo quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia” (Súmula 287, STF).

Sendo insuficientes as razões, tem o relator de determinar o esclarecimento, na medida em que a narrativa insuficiente constitui vício sanável (arts. 6.º, 139, IX, e 932, parágrafo único, CPC/2015), acaso vislumbre a possibilidade de, a partir do caso, dar unidade ao direito (art. 926, CPC/2015). Não sanadas, cumpre ao relator não conhecer do recurso. Completas, na medida em que “é inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles” (Súmula 283, STF). “É inadmissível recurso especial, quando o acórdão recorrido assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer um deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso extraordinário” (Súmula 126, STJ).

5. **Exposição analítica.** O material admitido ao debate em recurso extraordinário e em recurso especial deve ser exposto na petição do recurso de uma determinada forma. O recurso extraordinário ou recurso especial pode estar fundado em uma violação à Constituição ou à legislação federal que aporte ao Supremo Tribunal Federal ou ao Superior Tribunal de Justiça sem qualquer apoio em precedentes dessas Cortes ou pode estar fundado em uma violação à Constituição ou à legislação federal que aporte ao Supremo Tribunal Federal ou ao Superior Tribunal de Justiça denunciando a violação de precedentes constitucionais ou federais pela decisão recorrida.

No primeiro caso, pela ausência de casos já decididos pelas Cortes Supremas sobre o assunto, o recurso extraordinário ou recurso especial deve ser redigido mostrando argumentativamente que a interpretação dada pela decisão recorrida não é a mais adequada, porque viola a Constituição ou a legislação federal. Como não há questões ou casos a serem comparados, dispensa-se o cotejo analítico entre os casos. No entanto, no segundo caso, exige-se que as questões ou os casos sejam comparados em todos os seus aspectos fático-jurídicos relevantes, na medida em que é necessário perceber as semelhanças e as diferenças entre os casos para saber se o precedente invocado se

aplica ou não.

Isso quer dizer que não é apenas no caso de recurso especial por dissídio jurisprudencial que o recorrente tem o ônus de mencionar as “circunstâncias fáticas que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados” (arts. 105, III, c, CF/1988, e 1.029, § 1.º, CPC/2015 – hipótese em que também deve fazer prova da divergência na forma legal). Em um sistema de precedentes obrigatórios, sempre que o recorrente, em recurso extraordinário ou em recurso especial, tiver interesse em demonstrar que a decisão recorrida violou a interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal à Constituição ou pelo Superior Tribunal de Justiça à legislação federal, é imprescindível que tenha o cuidado de bem identificar na petição do recurso os casos de que oriundas as interpretações conflitantes – do contrário, será praticamente impossível aplicar o precedente ou distinguir adequadamente os casos.

A propósito, é exatamente por essa razão que há vedação ao não conhecimento de recurso extraordinário ou de recurso especial de forma genérica (arts. 93, IX, CF/1988, e 489, § 1.º, CPC/2015 – a revogação do § 2.º do art. 1.029, CPC/2015, pela Lei 13.256/2016, por essa razão, rigorosamente não altera essa imposição, que tem raiz constitucional e responde a uma necessidade ligada à concretização de um adequado sistema de precedentes obrigatórios. Vale dizer: de um sistema preocupado em outorgar unidade do direito e não simplesmente em gerir quantitativamente recursos).

Em qualquer caso, porém, o recorrente tem o ônus de demonstrar nas suas razões recursais a causa constitucional ou a causa federal que pretende ver examinada pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça. Vale dizer: tem o ônus de apontar na decisão recorrida a questão constitucional ou a questão federal que entende equivocadamente tratada. Na prática, esse requisito é chamado de prequestionamento – nada obstante prequestionar seja na verdade uma atividade voltada ao enfrentamento pelo órgão que prolatou a decisão recorrida de determinada questão.⁶⁷ Além disso, tem o ônus de demonstrar nas suas razões por que motivos o Supremo Tribunal Federal ou o Superior Tribunal de Justiça devem conhecer do recurso extraordinário ou do recurso especial. No atual desenho dessas Cortes Supremas, a justificação da admissibilidade do recurso extraordinário ou do recurso especial está na possibilidade de, a partir de seu julgamento, promover-se a unidade do direito brasileiro – tanto em sua dimensão retrospectiva (decidindo questão interpretativa controversa) como prospectiva (decidindo questão nova, desenvolvendo o direito legislado).

6. Dissídio jurisprudencial. O recurso especial com base no art. 105, III, c, CF/1988, só pode ser conhecido se o recorrente demonstrar analiticamente a divergência – transcrevendo os trechos dos acórdãos que configurem o dissídio e mencionando as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados (arts. 1.029, § 1.º, CPC/2015). Não basta a simples transcrição de ementas dos julgados.⁶⁸ É imprescindível verificar, consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, se os acórdãos alegadamente divergentes enfrentaram os mesmos ou semelhantes problemas fático-jurídicos, sem o que não pode restar configurada a divergência jurisprudencial⁶⁹ (STJ).

É por essa razão que o art. 1.029, § 1.º, CPC/2015, refere que o recorrente tem o ônus de “mencionar as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados”. Não autoriza a interposição de recurso especial por dissídio jurisprudencial a divergência entre julgados do mesmo tribunal (Súmula 13, STJ: “a divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial”). Ademais, a prova da divergência deve ser feita mediante certidão, cópia ou citação do repositório de jurisprudência, oficial ou credenciado, inclusive em mídia eletrônica, em que houver sido publicado o acórdão divergente, ou ainda com a reprodução de julgado disponível na rede mundial de computadores, com indicação da respectiva fonte (art. 1.029, § 1.º, CPC/2015).

Por fim, é preciso ter presente, que “não se conhece do recurso extraordinário fundado em divergência jurisprudencial, quando a orientação do plenário do Supremo Tribunal Federal já se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida” (Súmula 286, STF). “Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da

decisão recorrida” (Súmula 83, STJ).

7. Fundamento genérico. Seja na admissibilidade do recurso extraordinário, seja na admissibilidade do recurso especial, é vedado o não conhecimento do recurso com base em fundamento genérico. Trata-se de solução decorrente do direito ao contraditório como direito de influência e do dever de fundamentação como dever de debate (arts. 7.º, 9.º, 10, 11 e 489, § 1.º, IV, CPC/2015).

Note-se que não é apenas no caso de recurso especial fundado em dissídio jurisprudencial que existe vedação à inadmissibilidade genérica – como parecia sugerir o revogado § 2.º do art. 1.029, CPC/2015 (Lei 13.256/2016). Em todo e qualquer caso de interposição de recurso extraordinário ou de recurso especial a admissibilidade deve ser examinada levando em consideração as peculiaridades do caso.

Exemplificativamente, isso quer dizer que, quando o recorrente alegar violação à Constituição ou à legislação federal apoiando-se em precedentes constitucionais ou precedentes federais, a vedação ao não conhecimento genérico significa que o órgão jurisdicional tem o dever de examinar as circunstâncias fático-jurídicas do caso para demonstrar a existência de distinção que impede o conhecimento do recurso (art. 489, § 1.º, I, III, V e VI, CPC/2015). A vedação ao não conhecimento por fundamento genérico (art. 489, § 1.º, I, III, V e VI, CPC/2015) é a resposta simétrica ao ônus de exposição analítica das razões (art. 1.029, § 1.º, CPC/2015).

8. Desconsideração vício formal. Como a função do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça em recurso extraordinário e em recurso especial é de outorga de adequada interpretação ao direito e de formação de precedentes, o juízo de admissibilidade dos recursos tem de ser lido no influxo de sua nova função. Esse novo dimensionamento da função dessas Cortes Supremas levou à possibilidade de conhecimento de recurso extraordinário ou de recurso especial ainda que esses recursos padeçam de vício formal.

Como refere o art. 1.029, § 3.º, CPC/2015, “o Supremo Tribunal Federal ou o Superior Tribunal de Justiça poderá desconsiderar vício formal de recurso tempestivo ou determinar sua correção, desde que não o repute grave”. Certamente entra no conceito de vício formal não grave a inexistência de preliminar articulada demonstrando o prequestionamento da causa constitucional ou da causa federal – desde que seja possível vislumbrar a questão devidamente estampada na decisão recorrida. O limite colocado pelo legislador à sanção é apenas a tempestividade recursal. Trata-se de estímulo ao conhecimento do mérito do recurso extraordinário e do recurso especial, desde que, a partir do seu julgamento, possam as Cortes Supremas outorgar unidade ao direito mediante adequada interpretação.

Com a passagem de uma função de controle, historicamente vinculada ao *jus litigatoris*, para uma função de interpretação, ligada ao *jus constitutionis*, o foco desloca-se de um caso que interessa às partes e cuja decisão visa atuar retrospectivamente para uma definição de uma questão que interessa à sociedade e cuja decisão se destina a atuar prospectivamente (arts. 926 e 927, CPC/2015).

9. Suspensão em todo o território nacional. O art. 1.029, § 4.º, CPC/2015, apresenta uma lógica curiosa – a possibilidade de a formação de um precedente do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça ter que esperar a formação de jurisprudência vinculante mediante incidente de resolução de demandas repetitivas. Trata-se de expediente que visa outorgar preferência à solução do incidente de resolução de demandas repetitivas em detrimento da formação de precedentes.

Na verdade, a solução adequada seria a declaração da perda de objeto do incidente de resolução de demandas repetitivas diante da existência de caso repetitivo no âmbito do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. Vale dizer: suspendem-se todos os processos com questões idênticas em todo o território nacional até que o Supremo Tribunal Federal ou o Superior Tribunal de Justiça – prioritariamente – se manifestem sobre a questão.

Outra solução interpretativa seria pressupor que o art. 1.029, § 4.º, CPC/2015, viabilizaria a suspensão dos processos pendentes apenas nas Cortes de Justiça (Tribunais Regionais Federais e Tribunais de Justiça), pressupondo-se ainda a inexistência de recurso extraordinário ou de recurso especial pendente de apreciação sobre a mesma matéria. Nessa linha, instituiu-se uma preferência horizontal entre o incidente formado em determinado tribunal em detrimento de outros eventualmente também instaurados. Tendo em conta, porém, que entre as funções das Cortes de Justiça se aloca a de fomento do debate interpretativo, o ideal é que se viabilizasse um debate o mais amplo possível nas Cortes de Justiça a respeito do tema. O art. 1.029, § 4.º, CPC, revela que a finalidade precípua do incidente de resolução de demandas repetitivas está em permitir a concentração de esforços dos litigantes interessados na sua solução. Os ideais de amplo debate das questões e da formação de precedentes parecem perder espaço diante desse dispositivo.

10. Tutela provisória. O recurso extraordinário e o recurso especial não têm efeito suspensivo. A concessão de tutela provisória nesses recursos, porém, poderá ocorrer mediante requerimento formulado pela parte interessada e dirigido ao Supremo Tribunal Federal ou ao Superior Tribunal de Justiça, no período compreendido entre a publicação da decisão de admissão do recurso e sua distribuição (art. 1.029, § 5.º, I, CPC/2015) ou ao relator, acaso já distribuído o recurso (art. 1.029, § 5.º, II, CPC/2015). Quando, porém, o recurso extraordinário ou o recurso especial da parte estiver pendente de admissibilidade na origem, o pedido de tutela provisória deve ser formulado perante o presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido (art. 1.029, § 5.º, III, CPC/2015). Permanecem em vigor, portanto, as Súmulas 634 e 635, STF (respectivamente, “não compete ao Supremo Tribunal Federal conceder medida cautelar para dar efeito suspensivo a recurso extraordinário que ainda não foi objeto de juízo de admissibilidade na origem” e “compete ao Presidente do Tribunal de origem decidir o pedido de medida cautelar em recurso extraordinário ainda pendente de seu juízo de admissibilidade”). A concessão de tutela provisória em recurso extraordinário e em recurso especial submete-se à demonstração da probabilidade de provimento do recurso e do perigo na demora da tutela jurisdicional (art. 300, CPC/2015).

Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:

I – negar seguimento:

a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;

b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos;

II – encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos;

III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional;

IV – selecionar o recurso como representativo de controvérsia constitucional ou infraconstitucional, nos termos do § 6.º do art. 1.036;

V – realizar o juízo de admissibilidade e, se positivo, remeter o feito ao Supremo Tribunal Federal ou ao Superior Tribunal de Justiça, desde que:

a) o recurso ainda não tenha sido submetido ao regime de repercussão geral ou de julgamento

de recursos repetitivos;

b) o recurso tenha sido selecionado como representativo da controvérsia; ou

c) o tribunal recorrido tenha refutado o juízo de retratação.

§ 1.º Da decisão de inadmissibilidade proferida com fundamento no inciso V caberá agravo ao tribunal superior, nos termos do art. 1.042.

§ 2.º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.

* Artigo com redação determinada pela Lei 13.256/2016.

1. Contrarrazões. Recebida a petição do recurso no tribunal de origem, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão remetidos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido. Trata-se de óbvia manifestação do direito ao contraditório.

2. Juízo de Admissibilidade. O Código de 2015 pretendia impor uma nova sistemática de admissibilidade do recurso extraordinário e do recurso especial. De acordo com o seu desenho original, o tribunal de origem não teria mais, em regra, competência para realizar o juízo de admissibilidade, sendo que apenas no caso de recursos sobrestados – por força do julgamento de repercussão geral ou de recursos repetitivos – é que o tribunal de origem teria competência para examinar a admissibilidade recursal.

A Lei 13.256/2016 alterou semelhante procedimento. Com a nova redação do art. 1.030, CPC/2015, o juízo de admissibilidade do recurso extraordinário e do recurso especial permanece sendo em um primeiro momento tarefa do presidente ou do vice-presidente do tribunal de origem. Negada a admissibilidade, esse juízo sucessivamente é outorgado ao colegiado do tribunal recorrido (agravo interno) e à instância extraordinária competente (agravo em recurso extraordinário ou em recurso especial para o STF ou STJ). O juízo positivo de admissibilidade não desafia recurso.

3. Negar Seguimento. Inadmissibilidade. O presidente ou vice-presidente tem o dever de negar seguimento, isto é, inadmitir, o recurso extraordinário “que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral” (art. 1.030, I, *a*, CPC/2015) e o recurso extraordinário ou o recurso especial “interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos” (art. 1.030, I, *b*, CPC/2015).

Note-se que aí o que está em jogo é apenas o juízo de admissibilidade do recurso: vale dizer, um juízo a respeito da existência de *alegação de violação* à Constituição e à lei federal. Obviamente que não compete ao tribunal recorrido *afirmar a existência ou inexistência de efetiva violação* da Constituição ou da lei federal, porque este juízo foi reservado pela Constituição ao próprio Supremo Tribunal Federal (art. 102, III) e ao próprio Superior Tribunal de Justiça (art. 105, III). Em outras palavras, *o legislador infraconstitucional federal não pode retirar do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça a última palavra a respeito da existência de efetiva violação ou não da Constituição ou da legislação federal*. Aliás, é o próprio legislador que também o afirma no art. 1.035, § 3.º, I, CPC/2015 – só é possível aferir a existência de contrariedade a precedente ou à jurisprudência dominante do STF, sumulada ou não, acaso primeiro se viabilize o conhecimento do STF sobre a questão; do contrário, a última palavra a respeito pertenceria aos tribunais ordinários, que poderiam cancelar, por ausência de distinção, violações à Constituição e à lei federal.

Ora, tendo a interpretação da Corte Suprema valor em si mesma, sendo o móvel que legitima

sua existência e outorga sua função, eventual dissenso na sua observância pelos seus próprios membros ou por outros órgãos jurisdicionais deve ser encarado como um fato grave, como um desrespeito e um ato de rebeldia diante da sua autoridade, que deve ser evitado e, em sendo o caso, prontamente eliminado pelo sistema jurídico e pela sua própria atuação. E é exatamente por essa razão, por exemplo, que a “review on a writ of certiorari” pela *Supreme Court* estadunidense é admitida em questões importantes em que precedentes da corte foram violados ou não foram empregados quando deveriam (Rule 10, *Rules of the Supreme Court*) e que o recurso de *Revision* para o *Bundesgerichtshof* alemão é admitido quando é necessário para assegurar a igualdade de tratamento diante da jurisprudência (“die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung eine Entscheidung des Revisionsgericht erfordert”, § 543, 2, 2, segunda parte, Zivilprozessordnung). Se a interpretação a ser dada ao Código de 2015 levar ao afastamento da revisão da aplicação do precedente pelo próprio Supremo Tribunal Federal e pelo próprio Superior Tribunal de Justiça, corre-se o risco de a unidade do direito soçobrar, afastando-se perigosamente nossas Cortes Supremas das suas congêneres no direito comparado.⁷⁰

Assim, partindo-se de uma adequada interpretação do Código, em sendo o caso, a parte interessada tem à sua disposição tanto instrumentos tópicos (agravo interno e agravo em recurso extraordinário ou recurso especial, sucessivamente) como instrumento heterotópico (ação rescisória) para viabilizar a apreciação da violação à Constituição ou à lei federal.

4. Instrumentos Tópicos para Distinção. Agravo Interno, Agravo em RE e Agravo em Resp. Negado seguimento com base no art. 1.030, I, CPC/2015, é possível mostrar a distinção entre a questão ou o caso invocado no recurso extraordinário ou no recurso especial mediante a interposição de agravo interno para o colegiado do tribunal recorrido a que pertence o presidente ou vice-presidente (art. 1.030, § 2.º, CPC/2015). Reconhecida a distinção, o recurso deve ser provido, tendo o recurso extraordinário ou o recurso especial de ser remetido à instância competente (arts. 102, III, e 105, III, CF/1988, e 1.030, V, *a*, CPC/2015). Não reconhecida a distinção, cabe agravo em recurso extraordinário ou agravo em recurso especial (arts. 102, III, e 105, III, CF/1988, e 1.042, CPC/2015).

Note-se que a ressalva da parte final do art. 1.042, CPC/2015, merece interpretação conforme a Constituição: como é a própria Constituição que defere ao STF e ao STJ a última palavra a respeito da existência ou não de violação à Constituição e à lei federal (arts. 102, III, e 105, III, CF/2015), não é possível interpretar o art. 1.042, CPC/2015, no sentido de vedação ao cabimento do agravo. Aliás, além de não ser hierarquicamente possível do ponto de vista normativo essa interpretação, também não o é do ponto de vista da coerência: se é o próprio legislador que institui a repercussão geral da questão no recurso que impugnar acórdão que contrarie precedente ou jurisprudência, sumulada ou não, do STF, como imaginar que é o tribunal local que fará o juízo a respeito da existência ou não de efetiva violação da orientação do STF? É evidente que aí o que se defere ao tribunal recorrido é apenas a aferição de alegação de violação.

A propósito, é por essa razão que, ao pretender vedar o agravo em recurso extraordinário e o agravo em recurso especial, o legislador confundiu o juízo de admissibilidade com o juízo de mérito dos recursos, porque a ausência de distinção, quando devida, equivale à afirmação de inexistência de violação à ordem jurídica. Isso quer dizer que a ressalva do art. 1.042, CPC/2015, para não evidenciar evidente supressão de competência constitucional, deve ser entendido como hipótese em que o cabimento do agravo é simplesmente condicionado à prévia interposição do agravo interno. Lida sistematicamente (arts. 1.º, 8.º e 926, CPC/2015), a ressalva constitui hipótese de postergação, não de inadmissão recursal.

Daí que é necessário entender que da decisão do presidente ou vice-presidente que inadmite o recurso extraordinário ou o recurso especial com base no art. 1.030, I, CPC, cabe agravo interno (art. 1.030, § 2.º, CPC/2015). Se permanecer a indistinção, cabe agravo em recurso extraordinário ou agravo em recurso especial (arts. 102, III, e 105, III, CF/1988, e 1.042, CPC/2015) para que o STF ou o STJ, conforme o caso, afirme se é ou não é o caso de distinção. Interpretar de modo diverso significa suprimir do STF e do STJ o poder de afirmar os seus próprios precedentes mediante as devidas distinções e, ao fim e ao cabo, não permitir o próprio desenvolvimento do direito mediante adições de paulatinas ampliações e restrições.

5. Instrumento Heterotópico para Distinção. Ação Rescisória. Não sendo reconhecida a distinção no processo originário, cabe ação rescisória para evidenciar a necessidade de distinção (art. 966, § 5.º, CPC/2015).

6. Retratação. Se o acórdão recorrido violar – divergência pressupõe mesma hierarquia – precedente do STF ou do STJ, o presidente ou vice-presidente encaminhará o processo ao órgão julgador para realização de juízo de retratação (art. 1.030, II, CPC/2015). Dessa decisão não cabe recurso. A rigor, a única hipótese em que está permitida a manutenção do julgado é aquela em que o órgão julgador reconhece e aponta uma distinção entre o precedente e o caso encaminhado. Do contrário, a retratação decorre da necessidade de fidelidade à ordem jurídica (arts. 926 e 927, CPC/2015).

Apontada a distinção e refutada a necessidade de retratação, o recurso extraordinário ou o recurso especial deve ser objeto de juízo de admissibilidade pelo presidente ou vice-presidente (art. 1.030, V, CPC/2015). O mesmo vale para a hipótese – inconstitucional e ilegal – de manutenção da decisão violadora do precedente constitucional ou federal (art. 1.030, V, c, CPC/2015).

7. Sobrestamento. Se o presidente ou vice-presidente percebe que a questão constitucional ou federal afirmada no recurso extraordinário ou especial encontra-se pendente de julgamento perante o STF ou STJ, cumpre sobrestar o recurso (art. 1.030, III, CPC/2015). Vale dizer: suspender a apreciação da sua admissibilidade. O sobrestamento equivocado desafia recurso de agravo interno (art. 1.030, § 2.º, CPC/2015), cujo cabimento está condicionado à demonstração da distinção entre os casos.

8. Seleção. Ao presidente ou vice-presidente compete selecionar o recurso como representativo da controvérsia (arts. 1.030, IV, e 1.036, §§ 1.º e 6.º, CPC/2015). Dessa decisão não cabe recurso. Selecionado o recurso, esse deve ser remetido à instância extraordinária competente (art. 1.030, V, b, CPC/2015). Eventuais recursos versando idêntica questão devem ser sobrestados (art. 1.030, III, CPC/2015).

9. Admissão e Remessa. Não sendo o caso de inadmissão (art. 1.030, I, CPC), de retratação (art. 1.030, II, CPC/2015), de recurso extraordinário submetido ao regime da repercussão geral e pendente de apreciação (arts. 1.030, V, a, e 1.035, § 7.º, segunda parte, CPC/2015) ou de controvérsia repetitiva (art. 1.030, III, IV e V, a, segunda parte, *a contrario sensu*, CPC/2015), o presidente ou vice-presidente realizará o juízo de admissibilidade e, se positivo, remeterá o feito ao STF ou STJ. Semelhante decisão não desafia qualquer recurso.

10. Inadmissão, Agravo em RE e Agravo em Resp. Inadmitido o recurso extraordinário ou o recurso especial nas hipóteses do art. 1.030, V, CPC/2015, caberá diretamente agravo em recurso extraordinário ou agravo em recurso especial (arts. 1.030, § 1.º, e 1.042, CPC/2015).

Art. 1.031. Na hipótese de interposição conjunta de recurso extraordinário e recurso especial, os autos serão remetidos ao Superior Tribunal de Justiça.

§ 1.º Concluído o julgamento do recurso especial, os autos serão remetidos ao Supremo Tribunal Federal para apreciação do recurso extraordinário, se este não estiver prejudicado.

§ 2.º Se o relator do recurso especial considerar prejudicial o recurso extraordinário, em decisão irrecorrível, sobrestará o julgamento e remeterá os autos ao Supremo Tribunal Federal.

§ 3.º Na hipótese do § 2.º, se o relator do recurso extraordinário, em decisão irrecorrível, rejeitar a prejudicialidade, devolverá os autos ao Superior Tribunal de Justiça para o julgamento do recurso especial.

1. Interposição simultânea. Interpostos simultaneamente recurso extraordinário e recurso especial, deve esse ser apreciado antes daquele (art. 1.031, CPC/2015). Concluído o julgamento do recurso especial, substituída a decisão do tribunal de origem no que tiver sido objeto do recurso (art. 1.008, CPC/2015), devem os autos ser encaminhados ao Supremo Tribunal Federal para análise do recurso extraordinário, acaso não tenha esse restado prejudicado (art. 1.031, § 1.º, CPC/2015).

O julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça pode ensejar, em tese, novo recurso extraordinário.⁷¹ Sendo o caso, nada obsta que o Superior Tribunal de Justiça não conheça do recurso especial, encaminhando desde logo o recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal.⁷²

2. Inversão da ordem. Se, no Superior Tribunal de Justiça, o relator do recurso especial entender que o recurso extraordinário é prejudicial à apreciação do recurso especial – “há relação de prejudicialidade entre o recurso especial e o extraordinário quando o julgamento do primeiro pode cair no vazio a depender do resultado do julgado do segundo”⁷³ (STJ) –, deverá sobrestar o julgamento do recurso especial, remetendo os autos ao Supremo Tribunal Federal para análise do recurso extraordinário. Essa decisão é irrecorrível (art. 1.031, § 2.º, CPC/2015).

O relator do recurso extraordinário no Supremo Tribunal Federal, contudo, pode entender de maneira diversa – no sentido da inexistência de prejudicialidade –, com o que devolverá, por decisão irrecorrível, ao Superior Tribunal de Justiça os autos para análise do recurso especial (art. 1.031, § 3.º, CPC/2015). Não pode o Superior Tribunal de Justiça suscitar conflito de competência negativo com o Supremo Tribunal Federal.

Art. 1.032. Se o relator, no Superior Tribunal de Justiça, entender que o recurso especial versa sobre questão constitucional, deverá conceder prazo de 15 (quinze) dias para que o recorrente demonstre a existência de repercussão geral e se manifeste sobre a questão constitucional.

Parágrafo único. Cumprida a diligência de que trata o *caput*, o relator remeterá o recurso ao Supremo Tribunal Federal, que, em juízo de admissibilidade, poderá devolvê-lo ao Superior Tribunal de Justiça.

1. Livre trânsito. Como a função do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça em recurso extraordinário e em recurso especial é de outorga de adequada interpretação ao direito e de formação de precedentes, o juízo de admissibilidade dos recursos tem de ser lido no influxo de sua nova função. Esse novo dimensionamento da função dessas Cortes Supremas levou à instituição de livre trânsito de recursos entre essas duas Cortes (arts. 1.032 e 1.033, CPC/2015).⁷⁴

Se a pronúncia das Cortes Supremas somente se justifica a fim de que se outorgue unidade ao direito, com o que a sua legitimidade está coarctada ao exercício da função de adequada interpretação do direito constitucional ou do direito federal, não há sentido algum em se deixar de conhecer recurso que efetivamente veicula questão que merece ser resolvida, apenas porque foi endereçado equivocadamente. Com a passagem de uma função de controle, historicamente vinculada ao *jus litigatoris*, para uma função de interpretação, ligada ao *jus constitutionis*, o foco desloca-se de um caso que interessa às partes e cuja decisão visa atuar retrospectivamente para uma definição de uma questão que interessa à sociedade e cuja decisão se destina a atuar prospectivamente (arts. 926 e 927, CPC/2015). Daí a razão pela qual tem o Superior Tribunal de Justiça de remeter ao Supremo Tribunal Federal o recurso especial que versa sobre questão constitucional. É vedado ao Superior Tribunal de Justiça simplesmente não conhecer do recurso especial por inadequação do objeto (art. 1.032, CPC/2015).

2. Dever de prevenção. Identificado pelo relator que o recurso especial versa sobre questão constitucional, esse tem o dever de prevenir a parte que a não adequação do recurso aos moldes do recurso extraordinário levará ao seu não conhecimento (arts. 6.º, 932, parágrafo único, e 1.032, CPC/2015). Assim, o relator assinalará o prazo de 15 (quinze) dias para que o recorrente se manifeste sobre a existência de repercussão geral e enfrente a questão constitucional.

Cumprida a diligência, o relator remeterá o recurso para o Supremo Tribunal Federal, independentemente de juízo de admissibilidade. O Supremo Tribunal Federal poderá devolver o recurso por entender que o recurso na realidade não trata de questão constitucional (art. 1.032, parágrafo único, CPC/2015).

Art. 1.033. Se o Supremo Tribunal Federal considerar como reflexa a ofensa à Constituição afirmada no recurso extraordinário, por pressupor a revisão da interpretação de lei federal ou de

tratado, remetê-lo-á ao Superior Tribunal de Justiça para julgamento como recurso especial.

1. Livre trânsito. Como a função do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça em recurso extraordinário e em recurso especial é de outorga de adequada interpretação ao direito e de formação de precedentes, o juízo de admissibilidade dos recursos tem de ser lido no influxo de sua nova função. Esse novo dimensionamento da função dessas Cortes Supremas levou à instituição de livre trânsito de recursos entre essas duas Cortes (arts. 1.032 e 1.033, CPC/2015).

Se a pronúncia das Cortes Supremas se justifica a fim de que se outorgue unidade ao direito, com o que a sua legitimidade está coarctada ao exercício da função de adequada interpretação do direito constitucional ou do direito federal, não há sentido algum em se deixar de conhecer recurso que efetivamente veicula questão que merece ser resolvida apenas porque foi endereçado equivocadamente. Com a passagem de uma função de controle, historicamente vinculada ao *jus litigatoris*, para uma função de interpretação, ligada ao *jus constitutionis*, o foco desloca-se de um caso que interessa às partes e cuja decisão visa atuar retrospectivamente para uma definição de uma questão que interessa à sociedade e cuja decisão se destina a atuar prospectivamente (arts. 926 e 927, CPC/2015). Daí a razão pela qual tem o Supremo Tribunal Federal de remeter ao Superior Tribunal de Justiça o recurso extraordinário que versa sobre questão federal ou sobre questão decorrente de tratado – e, portanto, em que vislumbra apenas ofensa reflexa à Constituição. É vedado ao Supremo Tribunal Federal não conhecer do recurso extraordinário por inadequação do objeto (art. 1.033, CPC/2015).

2. Dever de prevenção. Identificado pelo relator que o recurso extraordinário versa sobre questão federal, esse tem o dever de prevenir a parte que a não adequação do recurso aos moldes do recurso extraordinário levará ao seu não conhecimento (arts. 6.º, 932, parágrafo único, e 1.033, CPC/2015). Assim, o relator assinalará o prazo de 15 (quinze) dias para que o recorrente possa enfrentar a questão federal (analogicamente, art. 1.032, *caput*, CPC/2015).

Cumprida a diligência, o relator remeterá o recurso para o Superior Tribunal de Justiça. O Superior Tribunal de Justiça não poderá devolver ao Supremo Tribunal Federal o recurso. Pode, no entanto, entender que não há questão federal ou questão decorrente de tratado.

Art. 1.034. Admitido o recurso extraordinário ou o recurso especial, o Supremo Tribunal Federal ou o Superior Tribunal de Justiça julgará o processo, aplicando o direito.

Parágrafo único. Admitido o recurso extraordinário ou o recurso especial por um fundamento, devolve-se ao tribunal superior o conhecimento dos demais fundamentos para a solução do capítulo impugnado.

1. Aplicando o direito à espécie. Admitido o recurso extraordinário ou o recurso especial, o Supremo Tribunal Federal ou o Superior Tribunal de Justiça julgará a causa, aplicando o direito à espécie (art. 1.034, CPC/2015). Isso quer dizer que o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça não são órgãos cassacionais, isto é, que se limitam, em sendo o caso, a anular a decisão recorrida com reenvio para novo julgamento. Nessa perspectiva, esses tribunais são cortes de revisão: cortes que conhecem de alegações de violações à Constituição e à legislação federal e que, em sendo o caso, desde logo decidem a controvérsia estampada no recurso extraordinário e no recurso especial.⁷⁵

2. Efeito devolutivo e efeito translativo. Admitido o recurso extraordinário ou o recurso especial por um fundamento, devolve-se ao tribunal o conhecimento dos demais fundamentos para a solução do capítulo impugnado (art. 1.034, parágrafo único, CPC/2015). Vale dizer: além dos fundamentos efetivamente arguidos pelo recorrente, os demais fundamentos eventualmente existentes para solução da questão impugnada poderão ser igualmente conhecidos, sendo aí transladados ao conhecimento da Corte Suprema. Nessa linha, vem decidindo o Superior Tribunal de Justiça: “1. Não se conhece do recurso especial quanto aos dispositivos de lei não prequestionados na origem. Incidência das Súmulas 283 e 356/STF. 2. Até mesmo as questões de ordem pública, passíveis de conhecimento *ex officio*, em qualquer tempo e grau de jurisdição ordinária, não podem ser analisadas no âmbito do recurso especial se ausente o requisito do

prequestionamento. 3. Excepciona-se a regra se o recurso especial ensejar conhecimento por outros fundamentos, ante o efeito translativo dos recursos, que tem aplicação, mesmo que de forma temperada, na instância especial. Precedentes da Turma”.⁷⁶ Ainda: “Processual civil e tributário. Recurso especial Efeito translativo. Conhecimento de ofício de questões de ordem pública (arts. 267, § 3.º, e 301, § 4.º, CPC). Possibilidade, nos casos em que o não enfrentamento dessas questões conduz a um julgamento sem nenhuma relação de pertinência com a demanda proposta. Alegação de ofensa aos arts. 467, 515, § 1.º e 535, do CPC não configurada. (...). 1. Quando eventual nulidade processual ou falta de condição da ação ou de pressuposto processual impede, a toda evidência, que o julgamento do recurso cumpra sua função de ser útil ao desfecho da causa, cabe ao tribunal, mesmo de ofício, conhecer da matéria, nos termos previstos no art. 267, § 3.º e no art. 301, § 4.º do CPC. Nesses limites é de ser reconhecido o efeito translativo como inerente também ao recurso especial”.⁷⁷

Art. 1.035. O Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrível, não conhecerá do recurso extraordinário quando a questão constitucional nele versada não tiver repercussão geral, nos termos deste artigo.

§ 1.º Para efeito de repercussão geral, será considerada a existência ou não de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.

§ 2.º O recorrente deverá demonstrar a existência de repercussão geral para apreciação exclusiva pelo Supremo Tribunal Federal.

§ 3.º Haverá repercussão geral sempre que o recurso impugnar acórdão que:

I – contrarie súmula ou jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal;

II – (*Revogado.*);

* Inciso II revogado pela Lei 13.256/2016.

III – tenha reconhecido a inconstitucionalidade de tratado ou de lei federal, nos termos do art. 97 da Constituição Federal.

§ 4.º O relator poderá admitir, na análise da repercussão geral, a manifestação de terceiros, subscrita por procurador habilitado, nos termos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.

§ 5.º Reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional.

§ 6.º O interessado pode requerer, ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal de origem, que exclua da decisão de sobrestamento e inadmita o recurso extraordinário que tenha sido interposto intempestivamente, tendo o recorrente o prazo de 5 (cinco) dias para manifestar-se sobre esse requerimento.

§ 7.º Da decisão que indeferir o requerimento referido no § 6.º ou que aplicar entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos caberá agravo interno.

* § 7.º com redação determinada pela Lei 13.256/2016.

§ 8.º Negada a repercussão geral, o presidente ou o vice-presidente do tribunal de origem negará seguimento aos recursos extraordinários sobrestados na origem que versem sobre matéria idêntica.

§ 9.º O recurso que tiver a repercussão geral reconhecida deverá ser julgado no prazo de 1 (um)

ano e terá preferência sobre os demais feitos, ressalvados os que envolvam réu preso e os pedidos de *habeas corpus*.

§ 10. (Revogado.)

* § 10 Revogado pela Lei 13.256/2016.

§ 11. A súmula da decisão sobre a repercussão geral constará de ata, que será publicada no diário oficial e valerá como acórdão.

1. Repercussão geral. Trata-se de requisito intrínseco de admissibilidade do recurso extraordinário (arts. 102, § 3.º, CF/1988, e 1.035, CPC/2015). A demonstração de repercussão geral da questão debatida no recurso extraordinário consiste em decisivo passo para construção de nosso processo justo (art. 5.º, LIV, CF/1988), concretizando a um só tempo o direito fundamental à tutela jurisdicional prestada em prazo razoável (arts. 5.º, LXXVIII, CF/1988, e 4.º, CPC/2015) e a necessidade de racionalização da atividade judiciária.⁷⁸

A função dessa técnica processual é selecionar os recursos que devem ser conhecidos pelo Supremo Tribunal Federal. Somente os recursos em que a questão constitucional apresente repercussão geral devem ser conhecidos pelo Supremo Tribunal Federal, porque somente a partir desses casos pode o Supremo desempenhar a sua função de outorga de unidade ao direito mediante adequada interpretação da Constituição. A unidade do direito que se busca com a atuação do Supremo Tribunal Federal é a unidade prospectiva e retrospectiva do direito – nessa, busca-se a compatibilização das decisões judiciais; naquela, o desenvolvimento do direito brasileiro para que responda de maneira constitucionalmente adequada aos novos problemas sociais.

O requisito da repercussão geral no recurso extraordinário aplica-se a todos os recursos extraordinários, independentemente da natureza da matéria neles versada.⁷⁹ A argumentação da repercussão geral não vincula o Supremo Tribunal Federal. Vale dizer: pode o Supremo Tribunal Federal admitir o recurso extraordinário por fundamento diverso daquele invocado pelo recorrente.

2. Relevância e transcendência. Existe repercussão geral no recurso extraordinário quando a causa constitucional nele debatida apresenta relevância e transcendência (art. 1.035, § 1.º, CPC/2015). Nosso Código de Processo Civil refere que “haverá repercussão geral sempre que o recurso impugnar acórdão que: I – contrarie súmula ou jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal; II – (revogado); III – tenha reconhecido a inconstitucionalidade de tratado ou de lei federal, nos termos do art. 97 da CF” (art. 1.035, § 3.º, CPC/2015).

Haverá repercussão geral não propriamente quando o recurso impugnar acórdão que contrarie súmula ou jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, mas em que se alegue a violação de precedentes do Supremo Tribunal Federal.

A relevância da causa deve ser aquilatada do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. Basta que a causa seja relevante sob um desses pontos de vista. Não é necessário que o seja sob todos. Há relevância sob o ponto de vista jurídico, por exemplo, quando o acórdão recorrido toma por inconstitucional determinada norma infraconstitucional.

A transcendência da controvérsia constitucional levada ao conhecimento do Supremo Tribunal Federal pode ser caracterizada tanto em uma perspectiva qualitativa como quantitativa. Na primeira, interessa para individualização da transcendência o importe da questão debatida para a sistematização e desenvolvimento do direito; na segunda, o número de pessoas suscetíveis de alcance, atual ou futuro, pela decisão daquela questão pelo Supremo e, bem assim, a natureza do direito posto em causa. Observe-se que eventuais questões envolvendo a reta observância ou a frontal violação de direitos fundamentais, materiais ou processuais, tendo em conta a dimensão objetiva desses, apresentam a princípio transcendência. Constituindo os direitos fundamentais, objetivamente considerados, uma tábua mínima de valores de determinada sociedade em dado

contexto histórico, cujo respeito interessa a todos, natural que se reconheça, num primeiro momento, a transcendência de questões envolvendo, por exemplo, afirmações concernentes a violações ou ameaças de violações das limitações ao poder constitucional de tributar, ou aos direitos fundamentais inerentes ao processo justo. São exemplos de transcendência qualitativa. Demandas envolvendo direitos individuais homogêneos, direitos coletivos e direitos difusos, tanto em seus aspectos materiais como processuais, também contam, em tese, com a nota da transcendência, mas já aí na perspectiva quantitativa.

3. Repercussão Geral e Julgamento de Casos Repetitivos. A Lei 13.256/2016 revogou o inc. II do § 3.º do art. 1.035, CPC/2015. Embora não tenha revogado expressamente o art. 987, § 1.º, CPC/2015, tem-se que entender que esse também está revogado. É que o objetivo evidente da revogação está em permitir que o STF possa bem dimensionar a sua agenda, autogovernando-se do ponto de vista da sua pauta de julgamentos. Dada a simetria existente entre o STF e o STJ – ambas são cortes de interpretação e de precedentes – a mesma solução existente para uma se aplica à outra. Isso quer dizer que também no incidente de resolução de demandas repetitivas o cabimento do recurso extraordinário está condicionado à demonstração da repercussão geral da questão debatida.

4. Causas com repercussão geral. Dentre outras, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que têm repercussão geral as causas envolvendo as limitações constitucionais ao poder de tributar, que são verdadeiros direitos fundamentais dos contribuintes, e aquelas que dizem respeito à extensão do direito fundamental à saúde, notadamente no que concerne à existência ou não de direito a medicamento de alto custo a ser fornecido pelo Estado.⁸⁰ Quanto às causas envolvendo as limitações constitucionais ao poder de tributar, o Supremo já decidiu que tem repercussão geral a controvérsia atinente: i) à necessidade ou não de lei complementar para disciplina da prescrição e decadência em matéria de contribuições previdenciárias;⁸¹ ii) à incidência do imposto de renda pessoa física;⁸² iii) ao alcance da imunidade sobre o lucro na exportação em tema de contribuição social⁸³ e iv) à existência ou não de responsabilidade solidária do sócio sobre tributo devido pela empresa.⁸⁴

5. Causas sem repercussão geral. Dentre outras, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que não surgem com repercussão geral as causas envolvendo a possibilidade de modificação do valor de multa coercitiva após o trânsito em julgado da decisão⁸⁵ e a controvérsia a respeito da existência ou não de dano indenizável e seu dimensionamento em tema de responsabilidade civil.⁸⁶

6. Competência. Somente o Supremo Tribunal Federal pode apreciar a existência ou não de repercussão geral da questão debatida no recurso extraordinário (arts. 102, § 3.º, CRFB, e 1.035, § 2.º, CPC/2015). Excepcionalmente, a partir de julgamento que decida pela inexistência de repercussão geral em recurso extraordinário repetitivo, o tribunal de origem poderá declarar inadmissível o recurso (arts. 1.035, § 8.º, e 1.039, parágrafo único, CPC/2015). Dessa decisão cabe agravo em recurso extraordinário, cuja admissibilidade está condicionada à demonstração de *distinção* entre os casos (art. 1.042, CPC).

7. Amicus curiae. É possível (art. 1.035, § 4.º, CPC/2015). A decisão do relator que admite ou inadmite a participação do *amicus curiae* é irrecorrível (arts. 138, CPC/2015, e 323, § 2.º, RISTF). Admitida a sua participação, a fim de que seja mais aberto e plural o juízo a respeito da existência ou não de repercussão geral, poderá o *amicus curiae* manifestar-se por escrito, oferecendo razões no sentido da configuração ou não da repercussão geral da questão debatida. O *amicus curiae* tem direito a realizar sustentação oral. A manifestação do *amicus curiae* tem de se dar mediante procurador devidamente habilitado (isto é, advogado munido de procuração).

8. Quórum. O Plenário do Supremo Tribunal Federal tem de se manifestar por dois terços de seus membros para inadmitir o recurso extraordinário por ausência de repercussão geral da questão nele debatida (art. 102, § 3.º, CF/1988).

9. Momento. Não há necessidade de o Plenário do Supremo Tribunal Federal manifestar-se, prioritária e isoladamente, sobre a existência ou não de repercussão geral da questão debatida no

recurso extraordinário. O relator encarregado do recurso pode desde logo analisar todos os requisitos de admissibilidade do recurso extraordinário. O art. 932, III a V, CPC/2015, pode ser aplicado (art. 21, § 1.º, RISTF). Vencido o juízo de admissibilidade pelo relator, deverá submeter à Turma a apreciação da existência ou não de repercussão geral (art. 323, RISTF). Manifestando-se essa favoravelmente à existência de repercussão geral por 4 (quatro) de seus membros, tem a Turma desde logo de apreciar o mérito do recurso. Não alcançado esse quórum, deve o Plenário manifestar-se a respeito da existência ou não de repercussão geral.

10. Deliberação eletrônica. De acordo com o RISTF, a deliberação a respeito da existência ou não de repercussão geral ocorre mediante meio eletrônico (arts. 323 e 324, RISTF). O relator examina a questão e submete a sua solução eletronicamente aos demais Ministros. Os demais membros do colegiado contam com 20 (vinte) dias para pronunciarem-se a respeito do tema. Acaso não cheguem manifestações em número suficiente para rejeição da repercussão geral, essa é reconhecida automaticamente.

11. Suspensão. Reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional (art. 1.035, § 5.º, CPC/2015).

12. Recurso equivocadamente sobrestado. Pode ocorrer de determinado processo ser equivocadamente sobrestado por força do art. 1.035, § 5.º, CPC/2015 – por exemplo, por uma equivocada identificação da questão nele tratada. Nessa hipótese, o interessado poderá requerer, alegando distinção entre os casos, que o seu processo tenha curso (art. 1.037, § 9.º, CPC/2015). Esse requerimento será dirigido ao juiz, se o processo sobrestado estiver em primeiro grau, ao relator, se o processo sobrestado estiver no tribunal de origem, ao relator do acórdão recorrido, se for sobrestado, no tribunal de origem, o recurso extraordinário, ou ao relator do recurso extraordinário, no Supremo Tribunal Federal, cujo processamento houver sido sobrestado (art. 1.037, § 10, CPC/2015). Ouvida a parte contrária (art. 1.037, § 11, CPC/2015) e reconhecida a distinção, conforme o caso, o processo terá curso, o recurso extraordinário será remetido ao Supremo Tribunal Federal ou será levado a julgamento (art. 1.037, § 12, CPC/2015). Da decisão que não reconhecer a distinção caberá agravo de instrumento, se o processo estiver em primeiro grau, ou agravo interno, se a decisão for de relator (art. 1.037, § 13, CPC/2015).

13. Recurso inutilmente sobrestado. Pode acontecer, ainda, de o recurso ser inutilmente sobrestado, tendo em conta a sua intempestividade. Nesse caso, poderá o interessado requerer o seu imediato não conhecimento ao presidente ou vice-presidente ao tribunal de origem (art. 1.035, § 6.º, CPC/2015). Se houver indeferimento, dessa decisão caberá agravo interno (art. 1.035, § 7.º, primeira parte, CPC/2015).

14. Não reconhecimento. A decisão que nega a existência de repercussão geral tem eficácia panprocessual, valendo para todos os recursos que versem sobre idêntica controvérsia (art. 1.035, § 8.º, CPC/2015). Nesse caso, a Presidência do Supremo Tribunal Federal está autorizada a não conhecer liminarmente o recurso extraordinário, indeferindo-o (arts. 13, V, c, e 327, *caput*, RISTF). Idêntica prerrogativa compete ao relator do recurso, acaso a Presidência não o tenha feito desde logo (art. 327, § 1.º, RISTF). Dessa decisão caberá agravo (art. 327, § 2.º, RISTF).

Reconhecida a inexistência de repercussão geral da questão debatida no recurso extraordinário, ainda, dispensa-se o recorrente, em sendo o caso, de interpor simultaneamente recurso extraordinário e recurso especial do acórdão local que se assenta em fundamento constitucional e infraconstitucional (Súmula 126, STJ – “é inadmissível recurso especial, quando o acórdão recorrido assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso extraordinário”). Basta, nesse caso, insurgir-se contra a decisão por recurso especial. Com o reconhecimento de inexistência de repercussão geral, o tribunal de origem está autorizado a não conhecer dos recursos extraordinários sobrestados na origem (art. 1.030, I, a, CPC/2015).

15. Reconhecimento. O recurso que tiver a repercussão geral reconhecida deverá ser julgado

no prazo de um ano e terá preferência sobre os demais feitos, ressalvados os que envolvam réu preso e o pedido de *habeas corpus* (art. 1.035, § 9.º, CPC/2015). A inobservância do prazo de um ano, porém, com a revogação do § 10 do art. 1.035, CPC/2015, pela Lei 13.256/2016, não acarreta retomada automática do trâmite de processamento dos recursos sobrestados.

16. Aplicação do Precedente para Inadmissibilidade Recursal. A segunda parte do § 7.º do art. 1.035, CPC/2015, refere que caberá agravo interno da decisão “que aplicar entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos”. Que decisão é essa? Se for a decisão de inadmissibilidade do presidente ou do vice-presidente do tribunal de origem, então a previsão é desnecessária, porque já contemplada (art. 1.030, I, e § 2.º, CPC/2015). Se for a decisão do relator no STF, igualmente, porque aí rege a espécie a regra geral (art. 1.021, CPC/2015).

Pela colocação da matéria, parece que se trata da primeira hipótese. Percebendo o presidente ou vice-presidente do tribunal de origem que a questão recorrida já foi decidida pelo STF, cumpre inadmitir o recurso (art. 1.030, I, CPC/2015). Dessa decisão caberá agravo interno, acaso a parte entenda que é o caso de demonstrar distinção entre as questões ou os casos decididos (arts. 1.030, § 2.º, e 1.035, § 7.º, segunda parte, CPC/2015). Não reconhecida a distinção, caberá agravo em recurso extraordinário (interpretação conforme a Constituição dos arts. 1.030, § 2.º e 1.035, § 7.º, segunda parte, CPC/2015 – conforme ao art. 102, III, CF/1988).

17. Súmula. A súmula da decisão sobre a repercussão geral constará de ata, que será publicada no diário oficial e valerá como acórdão.

Subseção II

Do Julgamento dos Recursos Extraordinário e Especial Repetitivos

1. Os precedentes das Cortes Supremas: impossibilidade de relacionar a eficácia obrigatória apenas às decisões proferidas em recurso repetitivo. O art. 927, CPC/2015, mediante equívoco que não atrapalha o devido desenvolvimento teórico e prático do sistema de precedentes, estranhamente limitou a eficácia obrigatória dos precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça aos “acórdãos” proferidos “em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos”. Como está claro, o legislador relacionou a eficácia obrigatória dos precedentes com a resolução de recursos múltiplos e, assim, com a otimização da prestação jurisdicional.

Ocorre que os precedentes das Cortes Supremas têm eficácia obrigatória por razões teóricas e constitucionais que sequer estão ao dispor da cogitação da lei. Estas razões, como é evidente, nada têm a ver com a existência de demandas em massa ou de recursos múltiplos sobre uma mesma questão de direito. De qualquer forma, tais razões não eram do conhecimento do legislador, que, por isso mesmo, fez o melhor que podia, elaborando um sistema equivocados que, se não ajuda muito, também não atrapalha.

É interessante que o art. 927 do CPC/2015 enumera, como primeira decisão que deve ser observada pelos tribunais e juízes, a proferida pelo Supremo Tribunal Federal em controle de constitucionalidade. Realmente, a ideia de atingir a todos é absolutamente natural à decisão que, no controle objetivo, declara a inconstitucionalidade ou a constitucionalidade de norma. Não foi por outra razão que se elaborou a fórmula da coisa julgada *erga omnes* para emprestar-lhe a devida autoridade. Mas a decisão proferida em sede de controle concentrado, em si, não constitui precedente obrigatório. Só há precedente quando há *ratio decidendi*, de modo que, para se falar em eficácia obrigatória, é necessário aludir à *ratio decidendi* ou aos fundamentos determinantes da decisão de inconstitucionalidade. Lembre-se da decisão do Supremo Tribunal Federal na Reclamação 1.987, quando se disse que “o ato impugnado não apenas contrastou a decisão definitiva proferida na ADIn 1.662, como, essencialmente, está em confronto com os seus motivos determinantes”.⁸⁷ Demonstrou-se que a decisão contra a qual se reclamou negou os motivos determinantes ou a *ratio decidendi* da decisão proferida na ADIn 1.662. Note-se que a *ratio decidendi* da decisão de inconstitucionalidade da lei municipal X obviamente aplica-se à lei Y de

outro município quando a sua dicção é igual ou similar a da lei X, antes declarada inconstitucional. O juiz ou tribunal que tem à sua frente a lei Y, ao tomar em conta a *ratio decidendi* da decisão de inconstitucionalidade da lei X, deve deixar de aplicar a lei Y por inconstitucionalidade.

Por isso mesmo, a eficácia obrigatória das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal em controle incidental não advém da circunstância de a decisão proferida em controle principal ter eficácia *erga omnes*. A eficácia *erga omnes*, inerente ao dispositivo das decisões proferidas em ação direta, não exclui o efeito obrigatório ou vinculante da *ratio decidendi* de qualquer decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, pouco importando se em controle principal ou em controle incidental.

Nos sistemas em que o controle é deferido a todos os juízes, os precedentes constitucionais das Cortes Supremas não podem deixar de ter eficácia obrigatória.⁸⁸ Não se trata de opção técnica, ainda que ótima à eficiência da distribuição da justiça, mas de algo que, quando ausente, impede o funcionamento do controle de constitucionalidade, nega a razão de ser da Corte Suprema e debilita a força normativa da Constituição. De modo que simplesmente não há como admitir, no atual estágio do direito brasileiro, que todos os juízes possam fazer controle de constitucionalidade sem vincular-se aos precedentes firmados em recurso extraordinário.

A eficácia obrigatória dos precedentes constitucionais é uma mera decorrência da função do Supremo Tribunal Federal, de garantir a unidade do direito constitucional. No caso de interpretação da Constituição, não apenas de declaração de inconstitucionalidade, a eficácia do precedente inevitavelmente transcende o caso particular. A definição da interpretação ou a atribuição de sentido à Constituição é elemento de orientação da sociedade e, por conta disso, de regulação dos casos futuros.

Razões da mesma importância também conferem valor obrigatório aos precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Quando há consciência de que a norma não está na lei, resta claro que a interpretação dos textos legais pode variar conforme o juiz.⁸⁹ Nesse sentido a lei não é suficiente para garantir a igualdade perante o direito, nem a segurança jurídica. Assim, deixa de ser possível pensar que a Suprema Corte pode controlar as decisões com base no “sentido exato da lei” – como queria Calamandrei⁹⁰ –, mas se torna viável admitir que lhe é autorizado atribuir sentido ao direito mediante a definição da interpretação adequada.

A interpretação capaz de atribuir sentido ao direito não é uma operação meramente lógica. As diretivas interpretativas não constituem regras lógicas, mas critérios que são eleitos e preenchidos mediante juízos de valor e opções do juiz, que conduzem a um resultado-interpretação que expressa a sua vontade. Por outro lado, quando se diz que o juiz, além do texto legal, toma em conta os princípios e fundamentos que estão por detrás dele, a decisão não deixa de ser construção e passa a ser mera declaração, pois a solução do caso não deriva objetivamente daqueles, mas é construída de forma mais ou menos discricionária com o auxílio deles. Mediante a interpretação, o juiz reconstrói o direito a partir do texto, de elementos extratextuais da ordem jurídica e por meio de diretivas interpretativas e valorações.⁹¹

A decisão da Suprema Corte, não só em virtude das regras legais que convidam o intérprete à sua concretização segundo as circunstâncias do caso e da imprescindibilidade de a lei ser conformada aos ditados da Constituição, mas também pela circunstância de que resulta de uma atividade interpretativa que contém juízos de valor e decisões sobre conteúdos externos ao texto da lei, certamente agrega sentido ou substância à ordem legislativa. Essa, em outras palavras, não é suficiente para orientar a sociedade ou para sozinha espelhar o direito que regula a vida social. O direito necessita da colaboração do Judiciário e, nesse contexto, em especial da “última palavra” das Cortes Supremas.

Ao atribuir sentido ao direito a partir de valorações devidamente racionalizadas, a decisão da Suprema Corte revela uma “criação” não apenas por fazer surgir algo que não preexiste à interpretação ou que não decorre logicamente da lei, mas também por ser expressão de uma vontade do Judiciário.⁹² Aliás, a discussão sobre se o juiz “cria direito” perde sentido quando se supõe que uma decisão é criativa se a sua formulação não está determinada pela lei, mas exige a

participação da vontade do intérprete. É possível dizer que a criatividade própria à interpretação judicial que se ampara na lei muda o direito apenas “incrementadamente” (incrementally).⁹³ Na verdade, a decisão que interpreta a lei agrega algo de novo à ordem jurídica legislada, mas não a invalida ou a integra.⁹⁴ Confere conteúdo a uma ordem jurídica que não se limita à legislação, mas que é composta pela lei e pelos precedentes das Cortes Supremas.⁹⁵

A observação de que a decisão interpretativa passa a preencher uma ordem jurídica de maior amplitude supõe, como não poderia deixar de ser, que a decisão não se limita aos litigantes envolvidos no caso, mas se estende a toda a coletividade com o caráter de direito. Segundo a Constituição brasileira, cabe ao Superior Tribunal de Justiça definir a interpretação da lei federal e garantir a sua unidade, evitando decisões divergentes dos tribunais ordinários. Isso quer dizer que a decisão do Superior Tribunal de Justiça institui o sentido do direito que deve orientar a vida em sociedade e pautar as decisões judiciais.

Se as decisões da Suprema Corte não se limitam a revelar a lei, mas representam regras determinadas pela interpretação, não há como pensar em correção das decisões a partir do “sentido exato da lei”.⁹⁶ Pelo mesmo motivo, o sistema de correção é certamente incapaz de garantir a uniformidade da interpretação. Como as regras resultam da interpretação, os precedentes da Suprema Corte obrigam os juízes e tribunais para que a segurança jurídica e a igualdade não sejam violadas. Assim, a eficácia obrigatória da *ratio decidendi* e, desse modo, do precedente, constitui apenas consequência da função da Corte Suprema de atribuir sentido ao direito e garantir a sua unidade.

Passou o tempo da mítica unidade do direito objetivo, quando o também ilusório sistema de correção das decisões em nome da garantia da uniformidade da interpretação era apresentado como válido. Hoje cabe à Suprema Corte atribuir sentido ao direito mediante precedentes, os quais devem guiar a resolução dos casos similares em nome da tutela da igualdade. Melhor explicando: o sistema de precedentes é meio de tutela da igualdade, na medida em que a interpretação não mais é método para a revelação da norma contida na lei, porém meio para a elaboração do seu significado. Portanto, o Superior Tribunal de Justiça só pode ser visto como Corte de Precedentes, que, ao atribuir significado ao direito, por mera consequência deve garantir a igualdade e a segurança jurídica.

Importa lembrar que nem toda decisão de Corte Suprema – tomada em ação originária ou em recurso – constitui precedente. Embora a Corte deva atribuir sentido ao direito, o exercício da sua função é estimulado pelo recurso do litigante, que deseja ver o caso resolvido em seu favor. Contudo, quando o recurso abre oportunidade para a Corte atuar, a solução do caso concreto é um pretexto para esta se desincumbir da sua real missão. Isso quer dizer que o julgamento do recurso não deve mais ser pensado como uma mera solução do caso concreto. Assim, também não pode mais importar apenas a parte dispositiva da decisão da Corte, que corrige ou não a decisão objeto do recurso. Quando se pensa na definição do sentido do direito importam os fundamentos determinantes da solução do recurso ou do caso. São as razões de decidir ou, mais precisamente, as razões determinantes da solução do recurso ou do caso que assumem relevo quando se tem em conta uma decisão que, além de dizer de respeito aos litigantes, projeta-se sobre todos e passa a servir de critério para a solução dos casos futuros.

Quando a importância do julgamento é deslocada da resolução do recurso para as razões que determinam a interpretação adequada, não somente é relevante debater estas razões, mas igualmente perceber que o entendimento que pode levar a uma solução favorável por maioria pode ser incapaz de propiciar a elaboração de um precedente. Num julgamento pode haver maioria em relação ao resultado ou ao provimento do recurso, mas não existir maioria quanto aos fundamentos que determinaram o resultado. Dois ou mais fundamentos podem ter sustentado o resultado ou o provimento do recurso, sem com que nenhum deles tenha sido compartilhado pela maioria dos membros do colegiado. Quando isso ocorre há resolução do recurso, mas não *ratio decidendi* e, portanto, precedente.⁹⁷

Tudo isso quer dizer que não há qualquer racionalidade na ideia de que apenas as decisões firmadas em “em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos” devem ser

observadas pelos juízes e tribunais (art. 927, III, CPC/2015). Essa suposição é tão equivocada quanto a do inc. II do § 3.º do art. 1.035 do CPC/2015, revogada antes de o código entrar em vigor. De acordo com o inciso revogado, haveria repercussão geral sempre que o recurso extraordinário se voltasse contra “acórdão proferido em julgamento de casos repetitivos”.

Nem todos os casos repetitivos têm razão para serem apreciados pelas Cortes Supremas. O recurso extraordinário apenas deve ser admitido quando, a despeito de impugnar decisão proferida em incidente de resolução de demandas, traz em seu bojo questão constitucional dotada de repercussão geral. A existência de demandas repetitivas não tem significado para o efeito do reconhecimento de repercussão geral pela simples razão de que a função do Supremo Tribunal Federal é desenvolver o direito e não resolver de demandas de massa. Um “caso repetitivo” que não contém questão constitucional de repercussão geral não tem motivo para ser analisado pelo Supremo Tribunal Federal.

É preciso perceber que o elemento que define a atuação das Cortes Supremas não está na estrutura individual ou coletiva do litígio, mas na qualidade da questão de direito nele envolvida. Um caso repetitivo, assim como um caso individual, pode eventualmente conter uma questão constitucional dotada de repercussão geral e, apenas nessa hipótese, ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Como é óbvio, casos repetitivos podem envolver questões de direito de simples resolução e sem qualquer significação para o desenvolvimento do direito. Nessas situações, a discussão do caso não deve ultrapassar as barreiras dos tribunais estaduais e regionais federais, sob pena, inclusive, de ser estabelecida uma ideia teoricamente grosseira, de que a função dos tribunais é resolver apenas litígios individuais.

Do mesmo modo, o Superior Tribunal de Justiça não tem por que atuar apenas em razão de o recurso especial ter sido interposto contra decisão proferida em incidente de resolução de demandas repetitivas. O Superior Tribunal de Justiça só tem motivo para julgar recurso especial quando são demonstrados os pressupostos para tanto – presentes no art. 105, III da CF/1988. Fora daí a existência de casos repetitivos não tem qualquer relevância.

A razão que mostra que não cabe recurso à Corte Suprema apenas pela circunstância de a decisão impugnada tratar de “caso repetitivo” demonstra que a tarefa de outorga de unidade ao direito não é uma decorrência da existência de múltiplos casos ou recursos. Evidencia que não se pode limitar a eficácia obrigatória dos precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça aos “casos repetitivos” e, também, que a própria técnica dos recursos repetitivos é incompatível com a função das Cortes Supremas.

2. A inadequação da relação entre recursos repetitivos e Cortes Supremas. Bem vistas as coisas, falar em recursos extraordinário e especial repetitivos é algo curioso. A função das Cortes Supremas é claramente incompatível com a difusão de recursos perguntando sobre a solução de uma mesma questão de direito. Não há mais dúvida de que as Cortes Supremas devem a sua existência à necessidade de definição do sentido e desenvolvimento do Direito. Para tanto a Corte não apenas precisa contar com casos que lhe permitam exercer a sua função, como não tem qualquer necessidade de ter a sua disposição vários recursos versando sobre a mesma questão. Na verdade, recursos repetitivos jamais deveriam chegar a uma Corte Suprema. Se o primeiro recurso é admitido e, portanto, conhecido para se julgar a questão de direito, todos os outros, contendo idêntica questão, certamente não têm qualquer razão para serem admitidos, devendo ficar suspensos, na espera do julgamento do primeiro recurso admitido.

Note-se que o reconhecimento da repercussão geral leva o relator do caso a determinar “a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional” (art. 1.035, § 5.º, CPC/2015). Ora, se o reconhecimento da repercussão geral conduz à suspensão do processamento dos demais recursos, ou o primeiro recurso – que pode ser o primeiro dos vários repetitivos – tem repercussão geral e, assim, é admitido, sobrestando-se os demais, ou não tem e, então, é inadmitido, ocorrendo o mesmo com os outros recursos. Não há racionalidade em pensar em recurso extraordinário repetitivo quando o recurso extraordinário não prescinde da repercussão geral da questão constitucional, suficiente para paralisar o processamento de todos os recursos versando sobre a

mesma questão.

O legislador do Código de Processo Civil de 2015 equivocou-se ao supor que as Cortes Supremas têm a função de contribuir para a otimização do julgamento das demandas idênticas que se repetem em massa. Essa obviamente não é a função de qualquer Corte Suprema do mundo contemporâneo. Lembre-se que o art. 1.035, § 3.º, II do CPC/2015 afirmava a existência de repercussão geral no caso de o recurso extraordinário impugnar “acórdão proferido em julgamento de casos repetitivos”, mas o parlamento revogou a norma em tempo, antes da entrada em vigor do código.⁹⁸ Isso tem grande importância: evidencia que o legislador percebeu que a função de uma Corte Suprema não é rever decisões proferidas em casos repetitivos, o que significa que também não é trabalhar com a lógica da técnica dos recursos repetitivos.

Admite-se falar em recurso repetitivo no âmbito do Superior Tribunal de Justiça apenas porque esta Corte Suprema ainda não dispõe da repercussão geral enquanto filtro capaz de propiciar a seleção dos casos adequados a permitir o exercício da função de desenvolvimento do direito. Como o Superior Tribunal de Justiça tem que admitir todos os recursos especiais em que, por exemplo, demonstra-se contrariedade à lei federal, não pode simplesmente admitir um recurso e paralisar o processamento dos demais. De forma que para o Superior Tribunal de Justiça é possível pensar que a técnica dos recursos repetitivos tem alguma vantagem, livrando-o do julgamento de recursos múltiplos que trazem uma mesma questão de direito. Isso, porém, é uma óbvia anomalia numa Corte Suprema. Não ter um filtro semelhante à repercussão geral significa ser uma Corte de correção, destinada a resolver casos e corrigir decisões.⁹⁹ Uma Corte voltada ao desenvolvimento do direito não precisa tomar conhecimento de todas as decisões equivocadas, já que a sua função não é dar tutela aos litigantes, mas elaborar precedentes para orientar a sociedade e regular os casos futuros.¹⁰⁰

3. A técnica dos recursos repetitivos como reprise do incidente de resolução de demandas repetitivas nas Cortes Supremas. Seria possível imaginar que a técnica dos recursos repetitivos, ao contrário do incidente de resolução de demandas repetitivas, não se destina ao julgamento de questão prejudicial à resolução de demandas repetitivas, mas ao julgamento de questão replicada em diversos recursos, relacionados a demandas idênticas ou a demandas de conteúdos completamente diferentes.

Contudo, não é assim. A intenção do legislador foi clara em outorgar ao recurso repetitivo a função de resolução da questão que afeta processos pendentes. Embora o art. 1.036 do CPC/2015 aluda apenas a “multiplicidade de recursos extraordinários ou especiais com fundamento em idêntica questão de direito”, o art. 1.037, II do CPC/2015 afirma que o relator, na decisão de afetação, “determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional”. Enquanto isso, o art. 1.040 diz que, publicada a decisão, i) será negado seguimento aos recursos especiais ou extraordinários sobrestados na origem – se o acórdão recorrido coincidir com a orientação da Corte Suprema; ii) o órgão que proferiu o acórdão recorrido reexaminará o processo de competência originária, a remessa necessária ou o recurso anteriormente julgado – se o acórdão recorrido contrariar a orientação da Corte Suprema; e iii) os processos suspensos em primeiro e segundo grau de jurisdição retomarão o curso para julgamento e aplicação da tese firmada pela Corte Suprema.

As normas (arts. 1.037, II, 1.039 e 1.040, CPC/2015) que determinam a suspensão dos recursos especiais e extraordinários e dos processos pendentes e subordinam o julgamento dos casos suspensos à decisão proferida pela Corte Suprema constituem evidência de que a técnica do recurso repetitivo tem o objetivo de definir questão que afeta demandas pendentes e repetitivas.

4. Concentração do julgamento da questão e exclusão da participação dos litigantes presentes nos demais recursos. A existência de múltiplos recursos versando sobre uma mesma questão de direito é o bastante para a afetação de recurso para o julgamento da questão de direito mediante a técnica dos recursos repetitivos. Aqui, embora se possa também pensar na resolução de questão de direito em prol da otimização da prestação jurisdicional, há a paralisação do andamento dos demais recursos – pior: “de todos os processos pendentes” (art. 1.037, II, CPC/2015)

–, excluindo-se os litigantes da discussão da questão de direito contra a qual se rebelaram mediante o exercício do direito de ação.

É certo que, em face do efeito obrigatório de um precedente, aqueles que não o discutiram estarão sujeitos a ele nos casos futuros. Porém, depois da afetação do recurso e da instituição do modelo de julgamento baseado na técnica do recurso repetitivo, as partes dos recursos que restam suspensos não tem alternativa a não ser assistir ao julgamento da questão que já impugnaram. Significa que a técnica dos recursos repetitivos não apenas submete casos em andamento a um precedente, mas exclui aqueles que impugnam a decisão da discussão perante a Corte.

No caso de recurso repetitivo, confere-se especial atenção ao conteúdo da discussão travada nos recursos selecionados. Fala-se que os recursos selecionados no tribunal ou na Corte Suprema devem ser “representativos da controvérsia” (art. 1.036, §§ 1.º e 5.º, CPC/2015). Aliás, outorga-se ao relator, na Corte Suprema, a possibilidade de selecionar “outros recursos representativos da controvérsia” e de, no momento da decisão de afetação, requisitar a diferentes tribunais “a remessa de um recurso representativo da controvérsia” (arts. 1.036, § 4.º e 1.037, III CPC/2015). Por fim, o § 6.º do art. 1.036 do CPC/2015 esclarece que “somente podem ser selecionados recursos admissíveis que contenham abrangente argumentação e discussão a respeito da questão a ser decidida”.

Uma Corte Suprema não pode ter o exercício da sua função prejudicada ou indevidamente limitada pelos litigantes. Se a decisão da Corte interessa ao desenvolvimento do direito e à sociedade, aquilo que se entende poder afastar o juiz da adequada resolução de um litígio, por constituir manifestação da liberdade da parte, não vale quando a Corte está diante de um recurso que lhe oferece possibilidade de exercer a sua função. Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça já teve oportunidade de indeferir pedido de desistência do recurso especial, ainda que subscrito pelas duas partes, para decidir o caso e firmar precedente que reputou relevante para o desenvolvimento do direito.¹⁰¹ Na mesma perspectiva deve ser compreendido o art. 1.029, § 3.º, ao dizer que “o Supremo Tribunal Federal ou o Superior Tribunal de Justiça poderá desconsiderar vício formal de recurso tempestivo ou determinar sua correção, desde que não o repute grave”.

Contudo, quando se está a elaborar precedente diante de casos pendentes que restam suspensos, a necessidade de a Corte buscar a essência da discussão pode assumir outra conotação, em que não importaria apenas a circunstância de a Corte não estar decidindo para as partes, porém o fato de a Corte estar a decidir uma questão para partes que recorreram e ficaram proibidas de participar.

O art. 1.038, I do CPC/2015 afirma que o relator poderá “solicitar ou admitir manifestação de pessoas, órgãos ou entidades com interesse na controvérsia, considerando a relevância da matéria e consoante dispuser o regimento interno”. Na verdade, a admissão da participação de terceiros, na hipótese, além de ter relação com a relevância da matéria, vincula-se também à circunstância de se estar resolvendo os recursos de muitos em recurso de um ou de alguns poucos.

Numa Corte Suprema que não trabalha com filtros como a repercussão geral, há dificuldade em admitir a não participação daqueles que podem ser prejudicados pela decisão a ser tomada no recurso. É preciso ter em conta que o requisito da repercussão geral elimina a suposição de que o recurso extraordinário é um direito subjetivo da parte, de modo que, no Supremo Tribunal Federal, não há problema em admitir um recurso, paralisando-se os demais. Na verdade, a verdadeira solução para esta questão está na instituição de um filtro semelhante à repercussão geral no Superior Tribunal de Justiça.¹⁰² Enquanto isso não ocorrer, a falta de participação dos interessados deverá ser compreendida de modo diferente no recurso especial. Nesse recurso, ao contrário do que acontece no recurso extraordinário, a participação do *amicus* tem necessidade de compensar a não participação direta dos vários recorrentes, e não apenas viabilizar uma mais aprofundada discussão da questão de direito.

5. Participação dos legitimados e do Ministério Público Federal e compensação da não participação dos recorrentes. Nos recursos repetitivos autoriza-se a intervenção de terceiro “com interesse na controvérsia”. O terceiro intervém como *amicus curiae*, figura processual típica do

direito anglo-americano, mas já admitida no Supremo Tribunal Federal há algum tempo.

A intervenção do *amicus* no recurso repetitivo não se funda no ideal que deu origem à figura no direito inglês.¹⁰³ O terceiro não intervém apenas para auxiliar a Corte ou para, de forma neutra, esclarecer os fatos para que a Corte não decida de forma equivocada. A intervenção, embora não ocorra em razão do litigante, mas de terceiros não representados, objetiva que a questão de direito seja resolvida em favor de uma das partes. De modo que a intervenção é, por assim dizer, parcial. Esclareça-se, aliás, que mesmo no *common law*, especialmente nos Estados Unidos, há bastante tempo o *amicus curiae* deixou de ser um “disinterested bystander” para se tornar um sujeito que ativamente participa do processo em nome de terceiros interessados no êxito de uma das partes.¹⁰⁴

Alguém poderia supor que o *amicus* só tem razão para intervir para abordar ponto que não pôde ser esclarecido pelas partes e que, portanto, não há lógica em dar-lhe oportunidade para apresentar argumentos jurídicos. Porém, não é correto pensar que a intervenção só pode se dar para esclarecer questão técnica ou fato que exija esclarecimento especializado. É certo que na França a figura do *amicus* é construída a partir das regras relativas às *verifications personnelles* do juiz, a princípio equiparando-se o *amicus* a um perito ou técnico. Ocorre que mesmo na França, e sem qualquer resistência no *common law*, admite-se que o juiz consulte um terceiro acerca de questões jurídicas.

Nos Estados Unidos, o *amicus* pode esclarecer qualquer questão, de fato ou estritamente de direito, porque a sua intervenção ocorre para o completo esclarecimento da controvérsia em nome dos terceiros insuficientemente representados. E isso se dá exatamente porque o precedente poderá prejudicar as partes não adequadamente representadas. Com efeito, a intervenção de *amicus* em nome de terceiros interessados na formação de precedente não é incomum nos Estados Unidos.¹⁰⁵

Na verdade, a dificuldade em compreender a possibilidade de o *amicus* falar sobre questões jurídicas decorre da dificuldade em se aceitar que a intervenção possa se dar para suprir a deficiência de argumentação da parte, ainda que para beneficiar terceiros. Isso fica mais fácil de ser aceito quando se percebe que o precedente firmado em recurso repetitivo é, igualmente, a decisão de um caso que também pertence a terceiros que já recorreram.

Muito embora a Corte Suprema esteja a firmar um precedente que atribui sentido ao direito, é preciso lembrar que o recurso especial ainda é franqueado a todos que podem afirmar violação da lei ou divergência jurisprudencial. Por isso, admitir o afastamento daqueles que já interpuseram recursos especiais, excluindo-os do exercício do direito de influenciar a Corte, exige atenção. Vale dizer: a figura do *amicus* não deve ser vista da mesma forma no Superior Tribunal de Justiça e no Supremo Tribunal Federal.

Em virtude da fraca e insuficiente regulamentação do recurso repetitivo, no Superior Tribunal de Justiça o direito fundamental à participação no processo exige a abertura e o chamamento à participação dos legitimados à tutela dos terceiros que podem ser prejudicados pela decisão e, inclusive, do Ministério Público. Uma vez amplamente noticiada a possibilidade de intervenção (art. 979, § 3.º, CPC/2015/2015), a participação do *amicus* deve ser a mais ampla possível. Não há como retirar daqueles que representam terceiros o direito de apresentar petições escritas, realizar sustentação oral e, inclusive, apresentar embargos de declaração. O modo de participação do *amicus* deve ser visto como o contraponto num procedimento em que a Corte emite decisão que resolve recursos de terceiros que têm o direito de influenciá-la.

Art. 1.036. Sempre que houver multiplicidade de recursos extraordinários ou especiais com fundamento em idêntica questão de direito, haverá afetação para julgamento de acordo com as disposições desta Subseção, observado o disposto no Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e no do Superior Tribunal de Justiça.

§ 1.º O presidente ou o vice-presidente de tribunal de justiça ou de tribunal regional federal selecionará 2 (dois) ou mais recursos representativos da controvérsia, que serão encaminhados ao

Supremo Tribunal Federal ou ao Superior Tribunal de Justiça para fins de afetação, determinando a suspensão do trâmite de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitem no Estado ou na região, conforme o caso.

§ 2.º O interessado pode requerer, ao presidente ou ao vice-presidente, que exclua da decisão de sobrestamento e inadmita o recurso especial ou o recurso extraordinário que tenha sido interposto intempestivamente, tendo o recorrente o prazo de 5 (cinco) dias para manifestar-se sobre esse requerimento.

§ 3.º Da decisão que indeferir o requerimento referido no § 2.º caberá apenas agravo interno.

* § 3.º com redação determinada pela Lei 13.256/2016.

§ 4.º A escolha feita pelo presidente ou vice-presidente do tribunal de justiça ou do tribunal regional federal não vinculará o relator no tribunal superior, que poderá selecionar outros recursos representativos da controvérsia.

§ 5.º O relator em tribunal superior também poderá selecionar 2 (dois) ou mais recursos representativos da controvérsia para julgamento da questão de direito independentemente da iniciativa do presidente ou do vice-presidente do tribunal de origem.

§ 6.º Somente podem ser selecionados recursos admissíveis que contenham abrangente argumentação e discussão a respeito da questão a ser decidida.

1. Julgamento em bloco. Além de exame individual, o recurso extraordinário ou o recurso especial pode ainda ser julgado em bloco – é o que o novo Código chama de julgamento de recursos extraordinários e especiais repetitivos (arts. 1.036 a 1.041, CPC/2015). Não há qualquer sentido em obrigar o Supremo Tribunal Federal ou o Superior Tribunal de Justiça a afirmar inúmeras vezes a mesma solução a respeito de determinada questão. Sendo o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça cortes de interpretação e de precedentes, a completa análise de determinada questão em uma única oportunidade é tendencialmente suficiente para que essas Cortes tenham por adimplidas suas funções paradigmáticas. Por essa razão, o ideal é que o STF e o STJ sequer recebessem recursos repetitivos. Nada obstante, tendo recebido semelhantes recursos, o respectivo julgamento em bloco acaba harmonizando-se com o novo perfil do recurso extraordinário e do recurso especial.

2. Cinco estágios. O procedimento que visa à solução dos recursos repetitivos obedece a cinco estágios distintos: i) seleção de recursos fundados em idêntica controvérsia de direito (art. 1.036, CPC/2015); ii) afetação da questão como repetitiva (art. 1.037, CPC/2015); iii) instrução da controvérsia (art. 1.038, CPC/2015); iv) decisão da questão repetida (art. 1.038, § 3.º, CPC/2015); e v) irradiação dos efeitos da decisão para os casos repetidos (arts. 1.039 a 1.041, CPC/2015).

3. Aferição. O procedimento para a aferição da existência de múltiplos recursos fundados em idêntica controvérsia de direito inicia com a seleção de recursos e pode ocorrer por iniciativa do presidente ou vice-presidente dos tribunais locais (art. 1.036, § 1.º, CPC/2015) ou por iniciativa do relator de determinado recurso extraordinário ou recurso especial (art. 1.036, § 5.º, CPC/2015). Em quaisquer dos casos, o órgão jurisdicional selecionará recursos representativos da controvérsia admissíveis que contenham abrangente argumentação e discussão a respeito da questão (art. 1.036, § 6.º, CPC/2015).

A seleção realizada pelo tribunal local pode ser complementada pelo relator do recurso no Supremo Tribunal Federal ou no Superior Tribunal de Justiça (art. 1.036, § 4.º, CPC/2015). Se iniciado pelo presidente ou vice-presidente de tribunal local, esse determinará a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitem no estado ou na região. Se, porém, sobrestado recurso extraordinário ou recurso especial inutilmente, haja vista a sua intempestividade, poderá o interessado requerer desde logo a declaração de sua inadmissibilidade (art. 1.036, § 2.º, CPC/2015). Não reconhecida, cabe agravo interno (art. 1.036, § 3.º, CPC/2015).

Art. 1.037. Selecionados os recursos, o relator, no tribunal superior, constatando a presença do pressuposto do *caput* do art. 1.036, proferirá decisão de afetação, na qual:

I – identificará com precisão a questão a ser submetida a julgamento;

II – determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional;

III – poderá requisitar aos presidentes ou aos vice-presidentes dos tribunais de justiça ou dos tribunais regionais federais a remessa de um recurso representativo da controvérsia.

§ 1.º Se, após receber os recursos selecionados pelo presidente ou pelo vice-presidente de tribunal de justiça ou de tribunal regional federal, não se proceder à afetação, o relator, no tribunal superior, comunicará o fato ao presidente ou ao vice-presidente que os houver enviado, para que seja revogada a decisão de suspensão referida no art. 1.036, § 1.º.

§ 2.º (*Revogado.*)

* § 2.º revogado pela Lei 13.256/2016.

§ 3.º Havendo mais de uma afetação, será prevento o relator que primeiro tiver proferido a decisão a que se refere o inciso I do *caput*.

§ 4.º Os recursos afetados deverão ser julgados no prazo de 1 (um) ano e terão preferência sobre os demais feitos, ressalvados os que envolvam réu preso e os pedidos de *habeas corpus*.

§ 5.º (*Revogado.*)

* § 5.º revogado pela Lei 13.256/2016.

§ 6.º Ocorrendo a hipótese do § 5.º, é permitido a outro relator do respectivo tribunal superior afetar 2 (dois) ou mais recursos representativos da controvérsia na forma do art. 1.036.

§ 7.º Quando os recursos requisitados na forma do inciso III do *caput* contiverem outras questões além daquela que é objeto da afetação, caberá ao tribunal decidir esta em primeiro lugar e depois as demais, em acórdão específico para cada processo.

§ 8.º As partes deverão ser intimadas da decisão de suspensão de seu processo, a ser proferida pelo respectivo juiz ou relator quando informado da decisão a que se refere o inciso II do *caput*.

§ 9.º Demonstrando distinção entre a questão a ser decidida no processo e aquela a ser julgada no recurso especial ou extraordinário afetado, a parte poderá requerer o prosseguimento do seu processo.

§ 10. O requerimento a que se refere o § 9.º será dirigido:

I – ao juiz, se o processo sobrestado estiver em primeiro grau;

II – ao relator, se o processo sobrestado estiver no tribunal de origem;

III – ao relator do acórdão recorrido, se for sobrestado recurso especial ou recurso extraordinário no tribunal de origem;

IV – ao relator, no tribunal superior, de recurso especial ou de recurso extraordinário cujo processamento houver sido sobrestado.

§ 11. A outra parte deverá ser ouvida sobre o requerimento a que se refere o § 9.º, no prazo de 5 (cinco) dias.

§ 12. Reconhecida a distinção no caso:

I – dos incisos. I, II e IV do § 10, o próprio juiz ou relator dará prosseguimento ao processo;

II – do inciso III do § 10, o relator comunicará a decisão ao presidente ou ao vice-presidente que houver determinado o sobrestamento, para que o recurso especial ou o recurso extraordinário seja encaminhado ao respectivo tribunal superior, na forma do art. 1.030, parágrafo único.

§ 13. Da decisão que resolver o requerimento a que se refere o § 9.º caberá:

I – agravo de instrumento, se o processo estiver em primeiro grau;

II – agravo interno, se a decisão for de relator.

1. A delimitação da questão submetida a julgamento e o problema da decisão da questão em separado. O art. 1.037, I, CPC/2015, afirma que o relator, na decisão de afetação, “identificará com precisão a questão a ser submetida a julgamento”. Há que se identificar uma questão que seja comum aos recursos repetitivos. Afinal, a hipótese é de recursos múltiplos que estão a tratar da mesma questão. Essa questão, de acordo com o inc. I do art. 1037, deve ser identificada com precisão pelo relator.

A técnica do recurso repetitivo se destina à solução de uma questão presente em vários recursos e não simplesmente de um dos recursos que se repetem. A questão, uma vez julgada, dá origem a uma “tese firmada” pela Corte, que deve ser reafirmada em todos os recursos repetitivos, ou melhor, em todos os recursos cuja solução depende da mesma questão. Essa questão é exatamente aquela de que depende a solução do recurso ou a conclusão acerca da alegada violação da norma.

O interessante, no entanto, é que no recurso repetitivo não apenas se discute e decide a questão, mas se decide a respeito da questão sem preocupação com as outras eventuais questões capazes de determinar o provimento do recurso ou permitir a conclusão de violação da norma. De acordo com o § 7.º do art. 1.037 que, “quando os recursos requisitados na forma do inc. III do *caput* contiverem outras questões, além daquela que é objeto da afetação, caberá ao tribunal decidir esta em primeiro lugar e depois as demais, em acórdão específico para cada processo”.

Os múltiplos recursos podem envolver uma questão e vários fundamentos ou mais de uma questão. Os recursos que deram origem ao recurso repetitivo, caso envolvam outras questões, podem eventualmente ser providos mesmo que a questão tenha sido decidida de modo contrário aos recorrentes. Isso significa que o recurso repetitivo é, realmente, um recurso em que se “julga questão”.

Para decidir, a Corte deve analisar todos os argumentos apresentados à solução da “questão”. Como no recurso repetitivo se decide sobre a questão, na eventualidade de mais de uma questão delimitada para julgamento a conclusão só pode ser a de que elas devem ser decididas em separado. O problema é que o delineamento da questão depende do caso concreto e, assim, é preciso evitar a confusão entre questão e fundamento, mediante a consideração dos próprios casos que dão origem ao recurso repetitivo. Se os recursos especiais dependem da solução de questão que abarca dois ou mais fundamentos, não é possível pretender discutir os fundamentos como se fossem questões em sede de recurso repetitivo.

Mas há outro problema em tudo isso. Se o objeto da técnica dos recursos repetitivos é uma questão de direito e não um recurso ou um caso, é preciso atenção em face dos recursos que contêm outras questões e diante da hipótese em que a decisão de afetação delimita mais de uma questão de direito para julgamento.

Lembre-se que, se o recurso requisitado nos termos do inc. III do art. 1.037 contiver outras questões, essas deverão ser decididas – após a decisão da questão delimitada – “em acórdão específico para cada processo” (§ 7.º do art. 1.037, CPC/2015). Ora, se um próprio recurso

“representativo da controvérsia” pode conter outras questões de direito, a questão de direito delimitada não precisa ser “essencial” para o julgamento dos recursos repetitivos, o que significa que, além dela, podem existir outras, conforme cada recurso. Em alguns casos, portanto, após a decisão do repetitivo pode ser necessário resolver outra questão de direito para a completa resolução do recurso. Também por isso, ou seja, porque em um recurso repetitivo pode ser delimitada mais de uma questão de direito para julgamento, em todas estas situações as questões de direito devem ser decididas em separado.

A discussão a respeito da necessidade de decidir questões autônomas em separado é oportuna no direito brasileiro, em que se começa a pensar na importância da elaboração de *rationes decidendi* ou precedentes para o desenvolvimento do direito, a orientação da sociedade e a regulação dos casos futuros. Recorde-se que uma das mais importantes discussões – ainda não definida – travadas sobre a teoria dos precedentes concentra-se no problema das decisões destituídas de fundamento sustentado pela maioria da Corte.¹⁰⁶

Nos Estados Unidos, depois de se ter tentando resolver o problema mediante critérios que não tiveram sucesso, como o do *narrowest grounds*,¹⁰⁷ passou-se a falar na técnica de votação em separado.¹⁰⁸ Esclarece-se que, quando a solução de um recurso envolve a solução de duas ou mais questões, em princípio há possibilidade de tomar o voto de cada julgador a respeito do recurso ou separar as questões, tomando-se o voto dos julgadores em relação a cada uma delas. Nesse sentido, fala-se em votação “case-by-case” e em votação “issue-by-issue”. O modelo “case-by-case” reflete a visão de cada juiz sobre o resultado do caso ou do recurso em sua totalidade, enquanto o modelo “issue-by-issue” reflete a visão de cada juiz a respeito das questões.¹⁰⁹ Quando se percebe que a escolha de uma ou outra técnica de tomada de decisão pode gerar resultados opostos, alude-se a um paradoxo, falando-se, então, de “doctrinal paradox”.¹¹⁰

Kornhauser e Sager, em artigo que ainda é discutido intensamente, formulam um exemplo em que a Corte é posta diante de um caso em que se alega violação da Quinta e da Quarta Emendas, respectivamente sob os argumentos de admissão como prova de confissão involuntária e de materiais obtidos mediante busca ilegal no automóvel do acusado. Considerando essas alegações – com base nas quais pede-se um “new trial” –, os juristas elaboram exemplo com a seguinte votação: i) quatro Justices afirmam não ter ocorrido violação de nenhuma das Emendas; ii) três Justices entendem que ambas as Emendas foram violadas; iii) um Justice declara que apenas a Quarta Emenda foi violada e iv) um Justice admite unicamente a violação da Quinta Emenda.¹¹¹ Diante disso, tomando-se em conta o modelo do “case-by-case”, ou seja, o modelo em que se pode votar com base em um ou outro fundamento para resolver o recurso, chega-se no seguinte resultado: quatro Justices concluem que não deve haver “new trial” e cinco Justices declaram que deve haver “new trial”. Porém, quando empregada a técnica da “issue-by-issue”, ou seja, a técnica mediante a qual cada uma das questões é votada em separado, alcançando-se o resultado a partir da soma dos votos obtidos em relação a cada uma das questões, chega-se numa votação com sentido inverso. Lembre-se que a violação tanto da Quarta quanto da Quinta Emenda foi rejeitada por cinco votos a quatro. Quando se impõe a votação em separado das questões, cada julgador deve novamente votar para a definição do recurso com base nos resultados parciais acerca das questões. Isso quer dizer que, mesmo o Justice que, na primeira votação, afirmou violadas as duas Emendas, deve posteriormente votar no sentido de que não deve ser realizado um “new trial”, uma vez que não pode fugir dos resultados parciais relativos às questões. O resultado, assim, seria unânime, pois os nove Justices declarariam a desnecessidade de “new trial”.

Costuma-se invocar o caso *National Mutual Insurance Co. v. Tidewater Transfer Co.*, em que se decidiu por 3+2-2-2 (resultado de 5 a 4) para confirmar uma lei que conferiu diversidade de jurisdição federal para os cidadãos do Distrito de Columbia, para demonstrar a incoerência das decisões em que as *rationes* são sustentadas por minorias da Corte. Nesse caso, os três Justices que firmaram a *opinion* majoritária declararam que, embora o Distrito de Columbia não seja um estado nos termos do artigo III, a lei constituía o exercício constitucional do poder do Congresso sob o artigo I, seção 17. A essa *opinion* somou-se uma *opinion* concorrente – sustentada por dois Justices –, no sentido de que a palavra “state”, inserida no artigo III, deveria ser lida de modo a compreender o Distrito de Columbia.

Como não se conseguiu extrair uma *ratio* a partir das *opinions* majoritária e concorrente, várias cortes inferiores aderiram ao resultado (não a qualquer dos fundamentos) de *Tidewater*, atribuindo-lhe valor precedental. Porém, parte da doutrina estadunidense enxergou em *Tidewater* um problema bem mais grave.¹¹² Não existiria apenas um obstáculo de incompatibilidade de *rationes* ou de impossibilidade de encontro de uma *ratio* com base no critério do “narrowest grounds”.¹¹³ Pretendeu-se evidenciar que a decisão plural, compartilhada por cinco Justices, constituiu uma associação de duas *opinions* minoritárias vencidas com larga margem, e que a vontade da Corte, por isso, não estaria presente nem nos fundamentos minoritários (3+2) nem no resultado (de 5 a 4) a que chegou a Suprema Corte.¹¹⁴ Significa que existiria um grande equívoco em atribuir efeito de precedente ao resultado de *Tidewater*, nos termos em que fizeram várias cortes inferiores.

Argumentam Kornhauser e Sager que nenhum Justice em *Tidewater* parece ter pensado que o método de votação “issue-by-issue” constituiria a resposta apropriada diante do problema.¹¹⁵ A ideia dos juristas é de que, para se evitar a decisão plural que se formou com base na conjugação dos fundamentos minoritários (3+2), cada questão ou fundamento deveria ter sido discutido e votado em separado, no modelo “issue-by-issue”. Realmente, o resultado de cinco a quatro, em que cinco significa duas *opinions* de três e dois, deriva da adoção do método mediante o qual a Suprema Corte tradicionalmente vota, do “case-by-case”.

O modelo “issue-by-issue”, ao obrigar a discussão e a votação de cada questão em separado, pode ser visto como uma alternativa para evitar decisões plurais, em que o resultado prevalece a despeito de as *opinions* serem claramente minoritárias. Quando se adota tal modelo, mais importa delinear um fundamento que tenha o respaldo da maioria do que obter um julgamento compartilhado pela maioria. Note-se, portanto, que o modelo de votação por questão, que costuma ser explicado mediante a alusão às decisões “paradoxais”, objetiva eliminar a prevalência de *opinions* não instituídas pela maioria ou, em outros termos, as próprias decisões plurais.

Nos Estados Unidos, a preocupação está centrada no fundamento utilizado pelos Justices para a solução do caso. O fundamento deve ser sustentado pela maioria da Corte porque se entende que não há sentido em resolver recurso sem firmar precedente. No Brasil, porém, obviamente admite-se julgar recurso sem firmar precedente, até porque a tradição de *civil law* sempre foi esta. A preocupação deve ser a de dar condições às Cortes Supremas para elaborar precedente quando do julgamento do recurso. Isso porque não se pode ver no julgamento de uma Corte Suprema uma obrigação de instituir precedente. As Cortes Supremas devem resolver recursos com a intenção de firmar precedentes, mas não há motivo para não se aceitar com naturalidade um julgamento em que a maioria do colegiado não compartilhou um fundamento – e, assim, instituiu *ratio decidendi*.

De qualquer maneira, a *ratio decidendi* forma-se, aqui como em qualquer outro lugar, quando um fundamento é compartilhado pela maioria do colegiado. Contudo, uma questão de direito, quando circunscrita para definição por colegiado, tem no seu resultado determinado valor precedental, que é tanto maior quanto mais limitada for a questão definida. Portanto, o resultado do julgamento em recurso repetitivo, ainda que proferido sem que nenhum fundamento tenha sido compartilhado pela maioria, tem efeito para obrigar os magistrados que estão diante de recursos repetitivos, ou melhor, de recursos em que está presente a mesma questão de direito que foi decidida. Isso não quer dizer que, eventualmente, o resultado (a decisão) do recurso repetitivo não possa ser determinado por fundamento compartilhado pela maioria do colegiado. Quando isso ocorre, além do efeito obrigatório do resultado do recurso sobre as questões de direito idênticas replicadas em outros casos e recursos, forma-se *ratio decidendi*, surgindo eficácia obrigatória ao fundamento afirmado pela maioria.¹¹⁶

Contudo, os fundamentos para a resolução da questão de direito certamente não devem ser decididos de forma separada. O que é decidido de forma individualizada é a questão de direito delimitada como objeto de julgamento, nos termos do art. 1.037, I, CPC/2015, bem como a questão de direito que eventualmente remanesceu em recurso representativo da controvérsia (art. 1037, III e § 7.º do CPC/2015) ou em outro recurso que tenha sido visto como repetitivo. Na hipótese em que for delimitada mais de uma questão para julgamento mediante a decisão de afetação, ou cada

questão é decidida em separado ou não se tem decisão sobre questão, mas decisão de um caso composto por mais de uma questão.

Na verdade, o mais importante é saber se existe questão de direito que deve ser decidida em separado no âmbito dos recursos especial e extraordinário. Não se fala aqui, obviamente, das questões preliminares ao julgamento do mérito do recurso. Considerando-se, por exemplo, o recurso especial, imagine-se hipótese em que um recurso afirma que a decisão contrariou várias normas da legislação federal.

Embora a doutrina e a prática sequer cogitem sobre a impossibilidade de se prover um recurso quando os votos afirmam a violação de distintas normas, há aí uma questão de grande importância. Num colegiado composto por cinco Ministros, dar provimento ao recurso com base em dois votos que afirmam contrariedade à norma X e outro que declara que foi contrariada a norma Y revela uma decisão descomprometida com a tutela do ordenamento jurídico, na medida em que a maioria não está a dizer que alguma norma foi violada, mas a declarar que a norma X e a norma Y não foram violadas, respectivamente por três a dois e quatro a um. Para evitar o provimento de recurso com base em votos que afirmam contrariedade a normas diferentes, não só é preciso definir, no início do julgamento, as alegações de violação de norma que serão objeto da discussão, como também é necessário votar cada uma delas em separado. Mediante a técnica da votação em separado, tendo cada um dos julgadores que votar sobre a alegação de contrariedade a uma específica norma, elimina-se a possibilidade de a norma ser considerada apenas por um ou alguns julgadores e, mais importante do que isso, tem-se uma decisão do colegiado a respeito de se a decisão contrariou a norma.¹¹⁷

Deve-se sempre exigir votação em separado em relação a cada um dos pressupostos constitucionais para o provimento dos recursos extraordinário e especial, decidindo-se de forma separada todas as alegações relativas à contrariedade a norma da Constituição, inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, validade de lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição, validade de lei local contestada em face de lei federal (art. 102, III, CF/1988), contrariedade ou negativa de vigência a tratado ou lei federal; validade de ato de governo local contestado em face de lei federal e divergência sobre a interpretação de lei federal (art. 105, III, CF/1988).

Se isso deve ocorrer no julgamento dos recursos extraordinário e especial, obviamente também deve acontecer em caso de recurso repetitivo. Tudo bem visto, as questões devem ser delimitadas, nos termos do art. 1.037, I, do CPC/2015 de acordo com as normas que serão discutidas pelo colegiado e, por conseguinte, decididas em separado.

2. Afetação. Reunidos os recursos selecionados, acaso o relator constate a efetiva existência de multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, afetará a questão para julgamento. Nessa oportunidade, o relator identificará com precisão a questão a ser submetida a julgamento, determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão afetada e tramitem em todo o território nacional, e requisitará aos presidentes e vice-presidentes de todos os tribunais locais a remessa de um recurso representativo da controvérsia (art. 1.037, CPC/2015). Recebidos os recursos repetidos de todo o país, pode o relator retratar-se da decisão de afetação, com o que determinará a revogação da suspensão (art. 1.037, § 1.º, CPC/2015). Havendo mais de uma afetação, será prevento o relator que primeiro tiver proferida a decisão de afetação (art. 1.037, § 3.º, CPC/2015). Os recursos afetados deverão ser julgados no prazo de um ano e terão preferência sobre os demais feitos, ressalvados os que envolvam réu preso e o pedido de *habeas corpus*. Com a revogação do § 5.º do art. 1.037, CPC, pela Lei 13.256/2016, o não julgamento do recurso no prazo de um ano não implica automática retomada do curso dos processos em todo o território nacional. A desafetação não impede nova afetação por outro relator (art. 1.037, § 6.º, CPC/2015).

3. Distinção. As partes têm o direito de ser intimadas da decisão de suspensão por força da afetação da questão (art. 1.037, § 8.º, CPC/2015). Isso porque pode ocorrer indevido sobrestamento de determinado processo por equivocada identificação da questão nele tratada. Nesse caso, a parte poderá demonstrar a distinção entre os casos, requerendo o prosseguimento do seu processo (art.

1.037, § 9.º, CPC/2015).

Esse requerimento será dirigido ao juiz, se o processo sobrestado estiver em primeiro grau, ao relator, se o processo sobrestado estiver no tribunal de origem, ao relator do acórdão recorrido, se for sobrestado, no tribunal de origem, recurso especial ou extraordinário, ou ao relator do recurso especial ou extraordinário, cujo processamento houver sido sobrestado (art. 1.037, § 10, CPC/2015). Antes de decidi-lo, o órgão judicial deve oportunizar o contraditório (art. 1.037, § 11, CPC/2015). Reconhecida a distinção, o processo terá prosseguimento na forma legal (art. 1.037, § 12, CPC/2015). Não reconhecida, conforme o caso, caberá agravo de instrumento ou agravo interno (art. 1.037, § 13, CPC/2015).

Art. 1.038. O relator poderá:

I – solicitar ou admitir manifestação de pessoas, órgãos ou entidades com interesse na controvérsia, considerando a relevância da matéria e consoante dispuser o regimento interno;

II – fixar data para, em audiência pública, ouvir depoimentos de pessoas com experiência e conhecimento na matéria, com a finalidade de instruir o procedimento;

III – requisitar informações aos tribunais inferiores a respeito da controvérsia e, cumprida a diligência, intimará o Ministério Público para manifestar-se.

§ 1.º No caso do inciso III, os prazos respectivos são de 15 (quinze) dias, e os atos serão praticados, sempre que possível, por meio eletrônico.

§ 2.º Transcorrido o prazo para o Ministério Público e remetida cópia do relatório aos demais ministros, haverá inclusão em pauta, devendo ocorrer o julgamento com preferência sobre os demais feitos, ressalvados os que envolvam réu preso e os pedidos de *habeas corpus*.

§ 3.º O conteúdo do acórdão abrangerá a análise dos fundamentos relevantes da tese jurídica discutida.

* § 3.º com redação determinada pela Lei 13.256/2016.

1. Instrução. A fim de instruir a controvérsia, poderá o relator requisitar informações aos tribunais locais. Com o objetivo de tornar a decisão mais aberta e completa possível, o relator poderá igualmente solicitar ou admitir a manifestação de pessoas, órgãos ou entidades com interesse na controvérsia (vale dizer, poderá admitir a participação de *amicus curiae*, arts. 138 e 1.038, I, CPC/2015). Poderá igualmente fixar data para, em audiência pública, ouvir depoimentos de pessoas com experiência e conhecimento na matéria (art. 1.038, II, CPC/2015). O Ministério Público será igualmente ouvido a respeito do caso repetido (art. 1.038, III, CPC/2015).

2. Decisão. Na sessão destinada à decisão da controvérsia, o debate concernente à controvérsia deve abranger todos os fundamentos relevantes suscitados para solução da questão, sendo imprescindível que o acórdão reflita essa análise completa da questão (art. 1.038, § 3.º, CPC/2015). Trata-se de necessidade oriunda não só da raiz constitucional do dever de fundamentação (arts. 93, IX, CF/1988, e 489, § 1.º, IV, CPC/2015), mas também da compreensão da justificação das decisões das Cortes Supremas como fonte de razões futuramente invocáveis como precedentes (arts. 102, III, e 105, III, CF/1988, e 926, CPC/2015). Daí porque a expressão “fundamentos relevantes” significa “fundamentos capazes de orientar a respeito do significado do direito constitucional ou do direito federal posto em juízo”. Sempre que o fundamento for capaz de oferecer uma pauta de conduta, deve ser analisado no conteúdo do acórdão, sob pena de o STF e o STJ se demitirem de seus papéis de cortes de interpretação e de precedentes.

3. Decisão sobre Questão não Delimitada. É vedado ao órgão colegiado decidir questão não delimitada na decisão de afetação por força do direito ao contraditório das partes (arts. 5.º, LV, CF/1988, e 10, CPC – a revogação do § 2.º do art. 1.037, CPC/2015, não altera a solução do problema, que responde ao imperativo constitucional do contraditório). Isso obviamente não quer dizer, porém, que não possa o Supremo Tribunal Federal ou o Superior Tribunal de Justiça alterar a

qualificação jurídica outorgada pelos recursos representativos à questão repetida, porque mesmo em sede de recurso extraordinário ou de recurso especial vige a regra do *Iura novit curia*.

Como nossas Cortes Supremas têm por função dar unidade ao Direito mediante sua adequada interpretação, respondendo o recurso extraordinário e o recurso especial mais ao *jus constitutionis* que ao *jus litigatoris*, resulta daí a existência de um *acentuado autocontrole da corte* a respeito da sua própria atuação. Tendo em conta que o caso concreto levado pela parte é apenas um meio para que a corte desempenhe sua função interpretativa,¹¹⁸ não estando sua atuação teleologicamente a ele condicionada, pode o STF e o STJ aproveitarem o caso narrado pela parte para, a partir dele, dar unidade ao Direito, *ainda que para tanto tenha de se pronunciar sobre questões que pertencem à matéria* que envolve o caso, mas que não foram efetivamente impugnadas pela parte. É o que, por exemplo, podem fazer o Bundesgerichtshof alemão e a Cour de Cassation francesa. O § 557, 3, Zivilprozessordnung refere que essa corte está autorizada a fazer valer motivos de revisão não arguidos pelas partes no recurso (“das Revisionsgericht ist an die geltend gemachten Revisionsgründe nicht gebunden”). O artigo 620, n. 2, *Nouveau Code de Procédure Civile*, não por acaso introduzido a partir do reconhecimento da função “jurisdictionnelle et normative”¹¹⁹ da *Cour de Cassation*, igualmente autoriza esse tribunal a cassar a decisão atacada levando em consideração de ofício um motivo de puro direito (“peut, sauf disposition contraire, casser la décision attaquée en relevant d’office un moyen de pur droit”), com o que pode dispor “sur fond des affaires” mediante uma “substitution des motifs”.¹²⁰ A Corte Suprema, por assim dizer, *autogoverna-se*.

Todavia, tomando o debate esse rumo, deve o relator suspender a sessão de julgamento e intimar todas as partes a fim de preservado o contraditório, indicando especificamente qual o possível novo enquadramento jurídico da questão ou qual questão da causa será devidamente enfrentada (arts. 7.º, 9.º, 10 e 11, CPC/2015). Ademais, quando os recursos afetados contiverem outras questões, além daquela que é objeto do julgamento, caberá ao tribunal decidir essa em primeiro lugar e depois as demais, lavrando acórdão específico para cada processo (art. 1.037, § 7.º, CPC/2015).

Art. 1.039. Decididos os recursos afetados, os órgãos colegiados declararão prejudicados os demais recursos versando sobre idêntica controvérsia ou os decidirão aplicando a tese firmada.

Parágrafo único. Negada a existência de repercussão geral no recurso extraordinário afetado, serão considerados automaticamente inadmitidos os recursos extraordinários cujo processamento tenha sido sobrestado.

1. Irradiação. Resolvida a questão, a solução formulada deverá disciplinar todos os casos idênticos (arts. 1.039 e 1.040, CPC/2015). Vale dizer: as razões oriundas do julgamento servem tendencialmente como precedente e nessa linha devem irradiar seus efeitos para todas as questões idênticas ou semelhantes.

Se o recurso tiver por objeto questão atinente à prestação de serviço concedido, permitido ou autorizado, o resultado do julgamento será comunicado ao órgão, ao ente ou à agência reguladora competente para fiscalização da efetiva aplicação, por parte dos entes sujeitos à regulação, da tese adotada (art. 1.040, IV, CPC/2015). Decidido o recurso representativo da controvérsia, os órgãos colegiados têm o dever, conforme o caso, de inadmitir, desprover ou aplicar a tese aos demais recursos versando idêntica controvérsia (art. 1.039, CPC/2015 – o Código fala em declarar “prejudicados” os demais recursos, mas é certo que está querendo se referir aí, em sendo o caso, à necessidade de inadmissão ou de desprovemento do recurso). Ainda, negada a existência de repercussão geral no recurso extraordinário afetado e no representativo da controvérsia, serão considerados automaticamente inadmitidos os recursos extraordinários cujo processamento tenha sido sobrestado (art. 1.039, parágrafo único, CPC/2015).

Art. 1.040. Publicado o acórdão paradigma:

I – o presidente ou o vice-presidente do tribunal de origem negará seguimento aos recursos especiais ou extraordinários sobrestados na origem, se o acórdão recorrido coincidir com a

orientação do tribunal superior;

II – o órgão que proferiu o acórdão recorrido, na origem, reexaminará o processo de competência originária, a remessa necessária ou o recurso anteriormente julgado, se o acórdão recorrido contrariar a orientação do tribunal superior;

III – os processos suspensos em primeiro e segundo graus de jurisdição retomarão o curso para julgamento e aplicação da tese firmada pelo tribunal superior;

IV – se os recursos versarem sobre questão relativa à prestação de serviço público objeto de concessão, permissão ou autorização, o resultado do julgamento será comunicado ao órgão, ao ente ou à agência reguladora competente para fiscalização da efetiva aplicação, por parte dos entes sujeitos a regulação, da tese adotada.

§ 1.º A parte poderá desistir da ação em curso no primeiro grau de jurisdição, antes de proferida a sentença, se a questão nela discutida for idêntica à resolvida pelo recurso representativo da controvérsia.

§ 2.º Se a desistência ocorrer antes de oferecida contestação, a parte ficará isenta do pagamento de custas e de honorários de sucumbência.

§ 3.º A desistência apresentada nos termos do § 1.º independe de consentimento do réu, ainda que apresentada contestação.

1. Publicação. Publicado o acórdão oriundo do julgamento dos recursos repetitivos: I – o presidente ou vice-presidente do tribunal de origem negará seguimento aos recursos especiais ou extraordinários sobrestados na origem, se o acórdão recorrido coincidir com a orientação do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça; II – o órgão que proferiu o acórdão recorrido, na origem, reexaminará a causa de competência originária, a remessa necessária ou o recurso anteriormente julgado, na hipótese de o acórdão recorrido contrariar o precedente constitucional ou federal; III – os processos suspensos em primeiro e segundo grau de jurisdição retomarão o seu curso para julgamento e aplicação do precedente firmado (art. 1.040, CPC/2015).

2. Desistência. A parte pode desistir da ação em curso no primeiro grau de jurisdição, antes de proferida a sentença, se a questão nela discutida for idêntica à resolvida pelo recurso representativo da controvérsia (art. 1.040, § 1.º, CPC/2015). Se a desistência ocorrer antes de oferecida a contestação, a parte ficará isenta do pagamento de custas e de honorários de sucumbência (art. 1.040, § 2.º, CPC/2015). A desistência nesse caso independe de consentimento do réu, ainda que já apresentada a contestação (art. 1.040, § 3.º, CPC/2015).

Art. 1.041. Mantido o acórdão divergente pelo tribunal de origem, o recurso especial ou extraordinário será remetido ao respectivo tribunal superior, na forma do art. 1.036, § 1.º.

§ 1.º Realizado o juízo de retratação, com alteração do acórdão divergente, o tribunal de origem, se for o caso, decidirá as demais questões ainda não decididas cujo enfrentamento se tornou necessário em decorrência da alteração.

§ 2.º Quando ocorrer a hipótese do inciso II do *caput* do art. 1.040 e o recurso versar sobre outras questões, caberá ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, depois do reexame pelo órgão de origem e independentemente de ratificação do recurso, sendo positivo o juízo de admissibilidade, determinar a remessa do recurso ao tribunal superior para julgamento das demais questões.

* § 2.º com redação determinada pela Lei 13.256/2016.

1. Fidelidade ao Direito. Rigorosamente, tendo em conta a função de outorga de unidade ao direito reconhecida ao Supremo Tribunal Federal e ao Superior Tribunal de Justiça, a necessidade de racionalização da atividade judiciária e o direito fundamental à duração razoável do processo, o tribunal de origem não pode recusar a aplicação do precedente ao caso concreto, porque aí

estará simplesmente negando o seu dever de fidelidade ao direito.¹²¹ Estará negando a própria autoridade do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça como órgãos institucionais dotados de autoridade para dar a última palavra a respeito do significado do direito constitucional e do direito federal em nosso país.¹²²

Se, porém, o tribunal de origem violar o precedente, o recurso deve ser remetido ao Supremo Tribunal Federal ou ao Superior Tribunal de Justiça (art. 1.041, CPC/2015). Realizado o juízo de retratação, com alteração do acórdão divergente, o tribunal de origem, se for o caso, decidirá as demais questões ainda não decididas, cujo enfrentamento se tornou necessário em decorrência da alteração (art. 1.041, § 1.º, CPC/2015). Quando houver o reexame da causa com o fito de alinhamento à tese vencedora e o recurso versar sobre outras questões, caberá ao presidente do tribunal local, depois do reexame pelo órgão de origem e independentemente de ratificação do recurso, determinar a remessa do recurso ao Supremo Tribunal Federal ou ao Superior Tribunal de Justiça para julgamento das demais questões, desde que positivo o seu juízo de admissibilidade (art. 1.041, § 2.º, CPC/2015).

Seção III

Do Agravo em Recurso Especial e em Recurso Extraordinário

Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.

* *Caput* com redação determinada pela Lei 13.256/2016.

I – (Revogado.);

* Inciso I revogado pela Lei 13.256/2016.

II – (Revogado.);

* Inciso II revogado pela Lei 13.256/2016.

III – (Revogado.)

* *Inciso III* revogado pela Lei 13.256/2016.

§ 1.º (Revogado.):

I – (Revogado.);

II – (Revogado.):

a) (Revogada.);

b) (Revogada.).

* § 1.º revogado pela Lei 13.256/2016.

§ 2.º A petição de agravo será dirigida ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal de origem e independe do pagamento de custas e despesas postais, aplicando-se a ela o regime de repercussão geral e de recursos repetitivos, inclusive quanto à possibilidade de sobrestamento e do juízo de retratação.

* § 2.º com redação determinada pela Lei 13.256/2016.

§ 3.º O agravado será intimado, de imediato, para oferecer resposta no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 4.º Após o prazo de resposta, não havendo retratação, o agravo será remetido ao tribunal superior competente.

§ 5.º O agravo poderá ser julgado, conforme o caso, conjuntamente com o recurso especial ou extraordinário, assegurada, neste caso, sustentação oral, observando-se, ainda, o disposto no regimento interno do tribunal respectivo.

§ 6.º Na hipótese de interposição conjunta de recursos extraordinário e especial, o agravante deverá interpor um agravo para cada recurso não admitido.

§ 7.º Havendo apenas um agravo, o recurso será remetido ao tribunal competente, e, havendo interposição conjunta, os autos serão remetidos ao Superior Tribunal de Justiça.

§ 8.º Concluído o julgamento do agravo pelo Superior Tribunal de Justiça e, se for o caso, do recurso especial, independentemente de pedido, os autos serão remetidos ao Supremo Tribunal Federal para apreciação do agravo a ele dirigido, salvo se estiver prejudicado.

1. Cabimento. Em seu desenho original, o novo Código pretendia alterar a sistemática de admissibilidade do recurso extraordinário e do recurso especial para que esse fosse realizado em regra apenas no STF e no STJ (art. 1.030, parágrafo único, CPC). Isso quer dizer que normalmente o seu eventual não conhecimento por decisão do relator do recurso no STF e no STJ seria suscetível de agravo interno para o próprio colegiado da respectiva Corte Suprema (art. 1.021, CPC/2015).

Quando, porém, deferia-se ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal local o juízo de admissibilidade do recurso extraordinário ou do recurso especial, nos casos que envolvessem a sistemática de julgamento fundada na inexistência de repercussão geral e de julgamentos baseados na sistemática dos recursos repetitivos, o recurso cabível do não conhecimento do recurso e do não reconhecimento de intempestividade recursal seria o recurso de agravo em recurso extraordinário ou agravo em recurso especial (art. 1.042, CPC/2015).

A Lei 13.256/2016 alterou esse programa inicial e procurou manter o sistema de admissibilidade do recurso extraordinário e do recurso especial muito próximo ao do Código revogado. Segundo prevê o art. 1.030, CPC, se o presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido inadmitir o recurso extraordinário ou o recurso especial com base em entendimento firmado em julgamento com repercussão geral ou tomado no procedimento dos recursos repetitivos (art. 1.030, CPC/2015), o recurso cabível é o agravo interno para o colegiado local (art. 1.030, § 2.º, CPC/2015). Se, porém, o presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido inadmitir o recurso fora dessas hipóteses (com base no art. 1.030, V, CPC/2015), o recurso cabível é o agravo em recurso extraordinário ou agravo em recurso especial (arts. 1.030, § 1.º, e 1.042, CPC/2015).

É preciso perceber, porém, que a ressalva final do art. 1.042, CPC/2015, merece interpretação conforme a Constituição (arts. 102, III, e 105, III, CF/1988). Isso quer dizer que essa ressalva serve apenas para *postergar o cabimento* do agravo em recurso extraordinário ou do agravo em recurso especial para depois do julgamento do agravo interno pelo tribunal local. Interpretar de modo diverso significa suprimir do STF e do STJ o poder de afirmar os seus próprios precedentes mediante as devidas distinções e, ao fim e ao cabo, não permitir o próprio desenvolvimento do direito mediante adições de paulatinas ampliações e restrições. Em outras palavras: a Constituição defere ao STF e ao STJ o poder de afirmar a existência ou inexistência de efetiva violação à Constituição (art. 102, III) e à lei federal (art. 105, III).

É exatamente por essa razão, por exemplo, que a “review on a writ of certiorari” pela Supreme Court estadunidense é admitida em questões importantes em que precedentes da corte foram violados ou não foram empregados quando deveriam (Rule 10, Rules of the Supreme Court) e que o recurso de Revision para o Bundesgerichtshof alemão é admitido quando é necessário para assegurar a igualdade de tratamento diante da jurisprudência (“die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung eine Entscheidung des Revisionsgericht erfordert”, § 543, 2, 2, segunda parte, Zivilprozessordnung). Se a interpretação a ser dada ao Código de 2015 levar ao total afastamento da revisão da aplicação do precedente pelo próprio Supremo Tribunal Federal e pelo próprio

Superior Tribunal de Justiça, corre-se o risco de a unidade do direito soçobrar, afastando-se perigosamente nossas Cortes Supremas das suas congêneres no direito comparado.¹²³

Portanto, o que o legislador infraconstitucional pode fazer é deferir o juízo de admissibilidade aos tribunais locais, isto é, permitir a aferição da existência ou não de *alegação de violação* à Constituição ou à lei federal. Quando, porém, o legislador procura encerrar a discussão a respeito da existência ou não de distinções entre casos nas instâncias ordinárias, ele suprime do STF e do STJ competência constitucional, porque permite que as instâncias ordinárias afirmem a existência ou inexistência de efetiva violação à Constituição ou à lei federal.

Perceba-se o ponto: se é o caso de distinção e a presidência ou vice-presidência do tribunal local entende que não é, o que ocorre é a violação da norma por ausência de subsunção. Daí a imprescindibilidade de cabimento do agravo em recurso extraordinário ou agravo em recurso especial.

2. Prazo. O prazo para sua interposição é de quinze dias (art. 1.003, § 5.º, CPC/2015), sendo que a sua petição deve ser dirigida ao presidente ou vice-presidente do tribunal de origem. A sua interposição independe do pagamento de custas e despesas postais (art. 1.042, § 2.º, CPC/2015).

3. Razões. Nas suas razões, tem o recorrente de demonstrar expressamente, sob pena de não conhecimento do agravo, a admissibilidade do recurso extraordinário ou do recurso especial, patrocinando efetivo enfrentamento da decisão de inadmissibilidade prolatada na origem. Ainda: em sendo o caso, tem de demonstrar analiticamente as distinções entre o caso tratado no recurso extraordinário ou no recurso especial e o caso invocado como paradigma pelo juízo de admissibilidade realizado na origem. Fora daí o recurso é inadmissível por ausência de regularidade formal.

4. Contrarrazões. O agravado será intimado de imediato para oferecer resposta no prazo de quinze dias. Após esse lapso temporal, o recurso será remetido ao Supremo Tribunal Federal ou ao Superior Tribunal de Justiça.

5. Julgamento conjunto. Sendo oportuno, o agravo poderá ser julgado conjuntamente ao recurso extraordinário ou recurso especial a que ligado, sendo assegurado, nesse caso, direito à sustentação oral (art. 1.042, § 5.º, CPC/2015). Isso quer dizer que o Supremo Tribunal Federal ou o Superior Tribunal de Justiça podem, na mesma sentada, dar provimento ao agravo para conhecer desde logo do recurso extraordinário ou do recurso especial – a fim de negar ou dar provimento.

6. Interposição conjunta. Na hipótese de interposição conjunta de recursos extraordinário e especial, o agravante tem o ônus de interpor um agravo para cada recurso não admitido. Havendo apenas um agravo, o recurso será remetido para o tribunal competente. Havendo interposição conjunta, os autos serão remetidos ao Superior Tribunal de Justiça. Concluído o julgamento do agravo pelo Superior Tribunal de Justiça e, se for o caso, do recurso especial, independentemente de pedido, os autos serão remetidos ao Supremo Tribunal Federal para apreciação do agravo a ele dirigido, salvo se estiver prejudicado (art. 1.042, §§ 6.º a 8.º, CPC/2015).

Seção IV

Dos Embargos de Divergência

Art. 1.043. É embargável o acórdão de órgão fracionário que:

I – em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo os acórdãos, embargado e paradigma, de mérito;

II – (*Revogado.*);

* Inciso II revogado pela Lei 13.256/2016.

III – em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer

outro órgão do mesmo tribunal, sendo um acórdão de mérito e outro que não tenha conhecido do recurso, embora tenha apreciado a controvérsia;

IV – (Revogado.).

* Inciso IV revogado pela Lei 13.256/2016.

§ 1.º Poderão ser confrontadas teses jurídicas contidas em julgamentos de recursos e de ações de competência originária..

§ 2.º A divergência que autoriza a interposição de embargos de divergência pode verificar-se na aplicação do direito material ou do direito processual.

§ 3.º Cabem embargos de divergência quando o acórdão paradigma for da mesma turma que proferiu a decisão embargada, desde que sua composição tenha sofrido alteração em mais da metade de seus membros.

§ 4.º O recorrente provará a divergência com certidão, cópia ou citação de repositório oficial ou credenciado de jurisprudência, inclusive em mídia eletrônica, onde foi publicado o acórdão divergente, ou com a reprodução de julgado disponível na rede mundial de computadores, indicando a respectiva fonte, e mencionará as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados.

§ 5.º. (Revogado.).

* § 5.º revogado pela Lei 13.256/2016.

1. Cabimento. Quando o art. 1.043, CPC/2015, arrola as hipóteses de cabimento dos embargos de divergência, o que está por detrás dessa previsão é a viabilização de uma oportunidade de debate institucional para que uma determinada questão constitucional ou federal possa ser definida pela corte responsável em dar a última palavra a respeito de significado do direito para toda a administração da Justiça Civil. Em outras palavras: para a formação de um precedente.¹²⁴

Na lógica de uma corte de interpretação e de precedentes, os embargos de divergência não podem ser vistos como instrumento que se presta a simplesmente fazer prevalecer uma das decisões divergentes de acordo com a maioria episódica dos membros de um determinado colegiado. Isso porque essas decisões divergentes não são espelhos de aplicações diferentes de uma mesma lei, uma correta e outra errada, de modo a ter os embargos de divergência o objetivo de definir a interpretação correta ou exata da lei para o caso concreto – como era próprio à lógica das cortes de controle e de jurisprudência.

Decisões divergentes, em uma corte de interpretação e de precedentes, atribuem significados ao direito a partir de valorações e, nessa perspectiva, não podem ser compreendidas em toda a sua extensão com base na lógica do “certo-errado”. A divergência decorre, em regra, de opções valorativas, diretivas interpretativas e, muitas vezes, de diferentes opções teóricas, ideológicas ou dogmáticas, o que fecha em imensa medida qualquer espaço para que se possa cogitar de uma decisão que se aproxime do verdadeiro ou falso.

É por isso que as decisões divergentes não devem ser vistas como meros momentos de aplicação da mesma lei, mas sim como oportunidades em que a mesma Constituição ou uma mesma lei é interpretada. Diferentes situações de interpretação exigem, por parte de quem vai definir o sentido que deve prevalecer, uma reconstrução discursiva dos diferentes casos e das distintas justificações que deram origem aos diferentes resultados interpretativos. Isso é imprescindível para se ter em conta as razões da divergência. Assim, por exemplo, se a divergência é fruto de uma opção de valor ou de uma escolha dogmática e quais os efetivos fundamentos de uma ou outra decisão interpretativa.

Isso quer dizer que os embargos de divergência só terão sentido a partir do momento em que houver reconstrução discursiva dos casos e decisões interpretativas que suportam as decisões

divergentes, tendo o colegiado o dever de analisar as diferentes interpretações refazendo o percurso justificativo de ambas. Os embargos de divergência não constituem o palco em que o discurso interpretativo tem início, mas sim o palco de sua reconstrução. Decisões divergentes abrem oportunidade para que as diferentes justificativas sejam comparadas a fim de que se defina qual é a que encontra maior suporte na ordem jurídica. Os embargos de divergência, portanto, constituem meios mais do que apropriados para formação de precedentes – ao contrário do que surpreendentemente supôs o legislador ao omiti-lo do rol do art. 927, CPC/2015.

2. Divergência. Como o que interessa é o conteúdo desses julgamentos, poderão ser confrontadas teses jurídicas contidas em julgamentos de recursos e de ações de competência originária (§ 1.º do art. 1.043, CPC). Como é possível haver divergência tanto a respeito da interpretação do direito material como do direito processual, é cabível embargos de divergência para solucioná-la em ambos os casos (art. 1.043, § 2.º, CPC/2015).

Como as questões referentes à admissibilidade recursal são questões processuais, a revogação do inc. II do art. 1.043, CPC, pela Lei 13.256/2016 não significa igualmente vedação ao cabimento dos embargos de divergência em semelhante hipótese. Ainda, são cabíveis embargos de divergência quando o acórdão paradigma for da mesma turma que proferiu a decisão embargada, desde que sua composição tenha sofrido alteração em mais da metade de seus membros (art. 1.043, § 3.º, CPC/2015).

3. Razões. Nas suas razões, o recorrente tem o ônus de identificar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados (art. 1.043, § 4.º, *in fine*, CPC/2015). O recorrente provará a divergência com certidão, cópia ou citação de repositório oficial ou credenciado de jurisprudência, inclusive em mídia eletrônica, onde foi publicado o acórdão divergente, ou com a reprodução de julgado disponível na rede mundial de computadores, indicando a respectiva fonte.

4. Fundamento genérico. Congruentemente com o ônus de identificação das circunstâncias que tornam idênticos ou semelhantes os casos confrontados (art. 1.043, § 4.º, *in fine*, CPC/2015), é vedado ao tribunal inadmitir o recurso com base em fundamento genérico de que as circunstâncias fáticas são diferentes, sem demonstrar a existência da distinção (a revogação do § 5.º do art. 1.043, CPC, pela Lei 13.256/2016 não altera a solução desse problema, que tem raiz constitucional, art. 93, IX, CF/1988, e decorre da compreensão do processo civil como uma comunidade argumentativa de trabalho, arts. 6.º, 10 e 489, § 1.º, IV, V e VI, CPC/2015). Trata-se de decorrência do direito ao contraditório como direito de influência e do dever de fundamentação como dever de debate (arts. 7.º, 9.º, 10, 11 e 489, § 1.º, IV, V e VI, CPC/2015).

Art. 1.044. No recurso de embargos de divergência, será observado o procedimento estabelecido no regimento interno do respectivo tribunal superior.

§ 1.º A interposição de embargos de divergência no Superior Tribunal de Justiça interrompe o prazo para interposição de recurso extraordinário por qualquer das partes.

§ 2.º Se os embargos de divergência forem desprovidos ou não alterarem a conclusão do julgamento anterior, o recurso extraordinário interposto pela outra parte antes da publicação do julgamento dos embargos de divergência será processado e julgado independentemente de ratificação.

1. Julgamento. O julgamento dos embargos de divergência obedecerá ao procedimento estabelecido no regimento interno do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça. A interposição de embargos de divergência no Superior Tribunal de Justiça interrompe o prazo para interposição de recurso extraordinário por qualquer das partes. Se os embargos de divergência forem desprovidos ou não alterarem a conclusão do julgamento anterior, o recurso extraordinário interposto pela outra parte antes da publicação do julgamento dos embargos de divergência será processado e julgado independentemente de ratificação.

NOTAS DE RODAPÉ

1

STJ, 2ª Turma, AgRg no RMS 11.573/SE, rel. Min. Humberto Martins, j. 04.09.2007, *DJ* 17.09.2007, p. 230.

2

STJ, 1ª Turma, RMS 20.627/SP, rel. Min. José Delgado, j. 07.03.2006, *DJ* 03.04.2006, p. 225.

3

STF, Pleno, RMS 20.976/DF, rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 07.12.1989, *DJ* 16.02.1990, p. 928.

4

STF, 2ª Turma, RMS 21.328/DF, rel. Min. Carlos Velloso, j. 11.12.2001, *DJ* 03.05.2002, p. 22.

5

STF, 2ª Turma, QO no RMS 24.237/AL, rel. Min. Celso de Mello, j. 16.04.2002, *DJ* 03.05.2002, p. 22.

6

STF, 1ª Turma, AgRg no Ag 144.895/SE, rel. Min. Ilmar Galvão, j. 27.10.1992, *DJ* 20.11.1992, p. 21.615.

7

STJ, 1ª Turma, RMS 21.885/SP, rel. Min. Luiz Fux, j. 04.10.2007, *DJ* 05.11.2007, p. 223.

8

STJ, 2ª Turma, AgRg no Ag 146.214/RJ, rel. Min. Aldir Passarinho Júnior, j. 16.03.1999, *DJ* 31.05.1999, p. 117.

9

STJ, 1ª Turma, RMS 21.885/SP, rel. Min. Luiz Fux, j. 04.10.2007, *DJ* 05.11.2007, p. 223.

10

STJ, 2ª Turma, AgRg no RMS 11.573/SE, rel. Min. Humberto Martins, j. 04.09.2007, *DJ* 17.09.2007, p. 230.

11

Amplamente, com as devidas indicações bibliográficas, Luiz Guilherme Marinoni, O STJ enquanto Corte de Precedentes, cit. Daniel Mitidiero, Cortes Superiores e Cortes Supremas – do Controle à Interpretação, da Jurisprudência ao Precedente, cit. Nessa mesma linha, igualmente, Hermes Zaneti Júnior, O Valor Vinculante dos Precedentes, 3. Ed. Salvador: JusPodium, 2017; Teresa Arruda Alvim e Bruno Dantas, Recurso Especial, Recurso Extraordinário e a Nova Função dos Tribunais Superiores no Direito Brasileiro, 4. Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017.

12

STF, Pleno, RE 733.433/MG, em especial o voto do Min. Edson Fachin; STJ, 6ª Turma, HC 274.806/SP, rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 14.02.2014, *DJe* 18.02.2014.

13

Giovanni Tarello, *L'Interpretazione della Legge*. Milano: Giuffrè, 1980, p. 27; Riccardo Guastini, *Interpretare e Argomentare*, Milano: Giuffrè, 2011, p. 39-46; Pierluigi Chiassoni, *Tecnica dell'Interpretazione Giuridica*, Bologna: Il Mulino, 2007, p. 56.

14

Humberto Ávila, *Teoria dos Princípios – Da Definição à Aplicação dos Princípios Jurídicos*, 12. ed., São Paulo: Malheiros, 2011, p. 31-35; Riccardo Guastini, *Interpretare e Argomentare*, Milano: Giuffrè, 2011, p. 413; Vittorio Villa, *Una Teoria Pragmaticamente Orientata dell'Interpretazione Giuridica*, Torino: Giappichelli, 2012, p. 112-116.

15

Riccardo Guastini, *Interpretare e Argomentare*, Milano: Giuffrè, 2011, p. 350-351; Vittorio Villa, *Una Teoria Pragmaticamente Orientata dell'Interpretazione Giuridica*, Torino: Giappichelli, 2012, p. 34-35; Giorgio Pino, *Diritti e Interpretazione – Il Ragionamento Giuridico nello Stato Costituzionale*, Bologna: Il Mulino, 2010, p. 115-118.

16

Como sintetiza Vittorio Villa, *Una Teoria Pragmaticamente Orientata dell'Interpretazione Giuridica*, Torino: Giappichelli, 2012, p. 2-3: “la teoria dell’interpretazione occupa oggi un posto assolutamente cruciale nella teoria del Diritto (e, più in generale, nella filosofia del diritto) contemporanea. Intendiamoci, la teoria dell’interpretazione ha sempre avuto un posto importante all’interno della teoria giuridica. Non c’è manuale o trattato di teoria del diritto che non abbia dedicato alcune pagine o un capitolo intero a questo tema. Se prendiamo le grandi teorie del diritto del secolo scorso, notiamo, però, che l’interpretazione viene tutto sommato considerata come un ‘argomento di settore’, sia pure di importanza decisiva. Se, ad esempio, guardiamo all’opera di Kelsen, ci accorgiamo che nella Dottrina Pura del Diritto l’interpretazione giuridica è discussa nell’ultimo capitolo, e dunque dopo che sono stati affrontati e risolti, in via pregiudiziale, tutti i problemi che Kelsen considera di carattere fondamentale: i problemi, cioè, legati all’identificazione e all’attribuzione di validità alle norme giuridiche e poi all’inserimento di queste norme all’interno di un sistema che le ricomprenda. Per Kelsen, insomma, l’interpretazione interviene su di un diritto di cui è già stata accertata, in modo indipendente rispetto all’interpretazione, l’esistenza (alla luce

della categoria della validità). Il discorso non cambia se prendiamo in considerazione l'opera di un altro grande teorico del Diritto del secolo scorso, Alf Ross. Anche in Diritto e Giustizia il capitolo sull'interpretazione è soltanto il quarto, e trova posto dopo che, nei capitoli precedenti, l'autore ha affrontato il problema dell'esistenza normativa del diritto (esistenza che per lui non può che essere una 'esistenza empirica'). Oggi, invece, un buon numero di testi che si pongono l'ambizioso obiettivo di presentare una concezione generale, una visione di insieme del Diritto, pongono l'interpretazione, o l'argomentazione (per il momento non mi interessa fare questa distinzione) come idea centrale, vero e proprio fulcro attorno al quale far ruotare la trattazione".

17

Daí a razão pela qual, por exemplo, a "statutorification" do *Common Law* estadunidense não conduz pura e simplesmente à primazia da legislação sobre a jurisdição (como propõe Guido Calabresi, *A Common Law for the Age of Statutes*, Cambridge: Harvard University Press, 1982, p. 163-166). As Cortes Supremas, mesmo diante do *Statutory Law*, mantêm a última palavra a respeito do significado do Direito, justamente porque sem interpretação não há norma.

18

Gino Gorla, *L'Interpretazione del Diritto*, Milano: Giuffrè, 1941, p. 34-35. Para uma crítica geral do formalismo oitocentista, entendido como "the ideology of bound judicial decision-making", e do antiformalismo ligado ao movimento do direito livre, entendido como "the ideology of free judicial decision-making", Jerzy Wróblewski, *The Judicial Application of Law*, Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 1992, p. 273-304.

19

Assim, Aulis Aarnio, *The Rational as Reasonable – A Treatise on Legal Justification*, Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 1987, p. 158-165; Aleksander Peczenik, *On Law and Reason*, Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 1989, p. 305-307; Riccardo Guastini, *Interpretare e Argomentare*, Milano: Giuffrè, 2011, p. 420-424; Humberto Ávila, *Segurança Jurídica*, São Paulo: Malheiros, 2011, p. 303. Sobre o assunto, consulte-se ainda o ensaio seminal de Adolf Merkl, *Sul Problema dell'Interpretazione* (1916), *Il Duplice Volto del Diritto – Il Sistema Kelseniano e altri Saggi*, tradução de Carmelo Geraci, Milano: Giuffrè, 1987, p. 255-279, bem como Enrico Diciotti, *Verità e Certezza nell'Interpretazione della Legge*. Torino: Giappichelli, 1999, p. 202-218; Vittorio Villa, *Una Teoria Pragmaticamente Orientata dell'Interpretazione Giuridica*, Torino: Giappichelli, 2012, p. 75-116; Vito Velluzzi, *Sulla Nozione di "Interpretazione Giuridica Corretta"*, *Tra Teoria e Dogmatica – Sei Studi intorno all'Interpretazione*, Pisa: Edizioni ETS, 2012, p. 19-32.

20

Enrico Diciotti, *Interpretazione della Legge e Discorso Razionale*, Torino: Giappichelli, 1999, p. 523; Pierluigi Chiassoni, *Tecnica dell'Interpretazione Giuridica*, Bologna: Il Mulino, 2007, p. 142; Vittorio Villa, *Una Teoria Pragmaticamente Orientata dell'Interpretazione Giuridica*, Torino: Giappichelli, 2012, p. 175-180.

21

Michele Taruffo, *La Corte di Cassazione e la Legge*, *Il Vertice Ambiguo – Saggi sulla Cassazione Civile*,

Bologna: Il Mulino, 1991, p. 79; Vittorio Villa, *Una Teoria Pragmaticamente Orientata dell'Interpretazione Giuridica*, Torino: Giappichelli, 2012, p. 41.

22

Jerzy Wróblewski, *The Judicial Application of Law*, Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 1992, p. 307-311.

23

Robert Alexy, *Theorie der juristischen Argumentation*, Frankfurt im Main: Suhrkamp, 1983, p. 273; Aulis Aarnio, *The Rational as Reasonable – A Treatise on Legal Justification*, Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 1987, p. 119-120; Riccardo Guastini, *L'Interpretazione dei Documenti Normativi*, Milano: Giuffrè, 2004, p. 123-137; Pierluigi Chiassoni, *Tecnica dell'Interpretazione Giuridica*, Bologna: Il Mulino, 2007, p. 14-15. A distinção entre “justificação interna” e “justificação externa” na teoria da argumentação é devida notoriamente a Jerzy Wróblewski, *Legal Decision and Its Justification*, *Logique et Analyse*, n. 14, 1971, p. 412. Para um amplo debate, Jerzy Wróblewski, *The Judicial Application of Law*, Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 1992, especialmente p. 209-262.

24

A necessidade de *completude* da motivação decorre do direito ao contraditório das partes, entendido como *direito de influência* das partes e *dever de diálogo* judicial, que coloca o *juiz como um dos sujeitos do contraditório* (Daniel Mitidiero, *Colaboração no Processo Civil – Pressupostos Sociais, Lógicos e Éticos*, 2. ed., São Paulo: Ed. RT, 2011, p. 87-103, com ampla referência bibliográfica).

25

Pierluigi Chiassoni, *Tecnica dell'Interpretazione Giuridica*, Bologna: Il Mulino, 2007, p. 14.

26

Giovanni Tarello, *L'Interpretazione della Legge*, Milano: Giuffrè, 1980, p. 75-85.

27

Riccardo Guastini, *Interpretare e Argomentare*, Milano: Giuffrè, 2011, p. 258.

28

Pierluigi Chiassoni, *Tecnica dell'Interpretazione Giuridica*, Bologna: Il Mulino, 2007, p. 15.

29

Pierluigi Chiassoni, *Tecnica dell'Interpretazione Giuridica*,. Bologna: Il Mulino, 2007, p. 14-15.

Giovanni Tarello, *L'Interpretazione della Legge*, Milano: Giuffrè, 1980, p. 33.

Giovanni Tarello, *L'Interpretazione della Legge*, Milano: Giuffrè, 1980, p. 85-99.

Riccardo Guastini, *Interpretare e Argomentare*, Milano: Giuffrè, 2011, p. 258.

Robert Alexy, *Theorie der juristischen Argumentation*, Frankfurt im Main: Suhrkamp, 1983, p. 285.

Como observa Cláudio Michelin, “a expressão ‘princípio jurídico’ tem tido uma presença frequente em decisões judiciais e na doutrina brasileiras. A expressão foi popularizada entre os profissionais e teóricos do direito no Brasil a partir de uma leitura direta ou, frequentemente, indireta de autores como Ronald Dworkin e Robert Alexy. Ironicamente, um conceito que foi originalmente elaborado como uma forma de estabelecer critérios de racionalidade que limitam a discricionariedade judicial é mais comumente associado no Brasil a um instrumento que permite ao juiz mais liberdade em relação à lei e ao direito posto. De fato, os princípios são muitas vezes utilizados por tribunais e doutrinadores como uma forma de eliminar dificuldades postas por regras complexas e/ou que destoam da concepção de justiça do juiz ou escritor. Na maior parte da América Latina os princípios dworkinianos foram recebidos não tanto como uma reação à crítica *realista* ao formalismo na argumentação jurídica, mas como uma forma de reação ao próprio *formalismo* interpretativo tardio que, segundo alguns, caracterizava a região. No caso particular do Brasil, a inserção dos princípios na argumentação jurídica faz parte da segunda geração de ataques ao formalismo jurídico, que se segue à primeira geração composta pelo amplo espectro de teorias relacionadas direta ou indiretamente ao chamado ‘direito alternativo’. Essa segunda onda de ataque ao formalismo atingiu o seu alvo e o paradigma formalista de argumentação não é mais a regra no Brasil (se é que um dia foi). Todavia, o ataque ao formalismo atingiu muito mais do que o seu alvo declarado. O que se coloca em questão a partir do modo como os princípios jurídicos vêm sendo utilizados tanto na doutrina como na prática do direito brasileiro é a própria noção de que o direito é algo criado dinamicamente pela comunidade política e não algo derivado de um conjunto abstrato e vago de bens ou valores por especialistas que têm um *insight* privilegiado sobre como esses bens e valores fundamentais devem conformar nossas instituições e decisões políticas. Ou seja, o que está em jogo é a legitimidade democrática desse “arranjo institucional” (Princípios e Coerência na Argumentação Jurídica. In: Ronaldo Porto Macedo Júnior; Catarina Helena Cortada Barbieri (coords.), *Direito e Interpretação – Racionalidades e Instituições*, São Paulo: Saraiva, 2011, p. 261-262). Para uma adequada teoria dos princípios, Humberto Ávila, *Teoria dos Princípios – Da Definição à Aplicação dos Princípios Jurídicos*, 12. ed., São Paulo: Malheiros, 2011; para uma adequada teoria das cláusulas gerais e dos conceitos indeterminados, Judith Martins-Costa, *A Boa-Fé no Direito Privado*, São Paulo: Ed. RT, 2000, p. 273-348.

36

Como observam Neil MacCormick e Robert Summers, “in this model, the first three of our categories form the ground for a prima facie ordering of arguments. When the interpretative conditions for linguistic arguments are satisfied, these arguments should be tried out prior to consideration of any other arguments; one should move to considering systemic arguments only after a preliminary scrutiny of the output of linguistic ones, and only if there is some reason to doubt the satisfactoriness of the linguistically interpretation; likewise, one should move to the teleological-evaluative arguments (if at all) only after scrutiny of the former two” (Interpretation and Justification. In: Neil MacCormick; Robert Summers (coords.), *Interpreting Statutes – A Comparative Study*, Aldershot: Dartmouth, 1991, p. 530).

37

Humberto Ávila, *Segurança Jurídica*, São Paulo: Malheiros, 2011, p. 273 e 278.

38

Neil MacCormick, *Rhetoric and the Rule of Law*, Oxford: Oxford University Press, 2005, p. 97.

39

Neil MacCormick, *Rhetoric and the Rule of Law*, Oxford: Oxford University Press, 2005, p. 99.

40

Neil MacCormick, *Rhetoric and the Rule of Law*, Oxford: Oxford University Press, 2005, p. 91; Eisenberg Melvin, *The Nature of the Common Law*, Cambridge: Harvard University Press, 1991, p. 8-12.

41

Neil MacCormick, *Rhetoric and the Rule of Law*, Oxford: Oxford University Press, 2005, p. 91.

42

Cláudio Michelon, Princípios e Coerência na Argumentação Jurídica. In: Ronaldo Porto Macedo Júnior; Catarina Helena Cortada Barbieri (coords.), *Direito e Interpretação – Racionalidades e Instituições*, São Paulo: Saraiva, 2011, p. 267; Humberto Ávila, *Segurança Jurídica*, São Paulo: Malheiros, 2011, p. 273. Sobre a coerência na argumentação em geral, Neil MacCormick, *Rhetoric and the Rule of Law*. Oxford: Oxford University Press, 2005, p. 189-213; Id., *Legal Reasoning and Legal Theory* (1978). Oxford: Oxford University Press, 2003, p. 152-194.

43

Para uma análise do raciocínio jurídico interpretativo na perspectiva argumentativa, com apreciação e aproveitamento crítico das lições de Tarello, Perelman, Guastini, Wróblewski e Alexy, Pierluigi Chiassoni,

44

Pierluigi Chiassoni, *Tecnica dell'Interpretazione Giuridica*, Bologna: Il Mulino, 2007, p. 142.

45

Zenon Bankowski, Neil MacCormick, Lech Morawski e Alfonso Ruiz Miguel, Rationales for Precedent. In: MacCormick, Neil; Summers, Robert (coords.), *Interpreting Precedents – A Comparative Study*. Aldershot: Dartmouth, 1997, p. 486.

46

STF, Pleno, RE 655.265/RS, rel. Min. Luiz Fux, rel. para Acórdão Min. Edson Fachin, j. 13.04.2016, *DJe* 05.08.2016. Na mesma linha, STF, RE 994.607/MG, rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 23.08.2017, *DJe* 28.08.2017.

47

STJ, AREsp 634.051/SP, rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 01.08.2017, *DJe* 07.08.2017.

48

Jerzy Wróblewski, *The Judicial Application of Law*, Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 1992, p. 273-283, especialmente p. 274-278.

49

Por todos, Giuseppe Chiovenda, *Principii di Diritto Processuale Civile* (3. ed., 1923), *ristampa inalterata*, Napoli: Jovene Editore, 1965, p. 301.

50

Como denunciado por Ovídio Baptista da Silva, *Processo e Ideologia – O Paradigma Racionalista*, Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 84-150.

51

É a conhecida proposta de Hans Kelsen para justificar a diferença entre a atividade do legislador e a atividade da Corte Constitucional e para assinalar os limites da atuação da Corte, conforme *Quem Deve ser o Guardião da Constituição?* (1930-1931), tradução de Alexandre Krug. Jurisdição Constitucional, São Paulo: Martins Fontes, 2003, p. 239-298. Na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a propósito, é tradicional e constante a alusão ao Supremo Tribunal Federal como “legislador negativo” (entre outros, STF, Pleno, RP 1.417/DF, rel. Min. Moreira Alves, j. 09.12.1987, *DJ* 15.04.1988, p. 8.397; STF, Pleno, ADI 652/MA, rel. Min. Celso de Mello, j. 02.04.1992, *DJ* 02.04.1993, p. 5.615; STF, 1ª Turma, AgRg no RE

493.324/RS, rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 27.11.2007, *DJ* 19.12.2007, p. 47).

52

Como observa Humberto Ávila, *Teoria da Igualdade Tributária*, São Paulo: Malheiros, 2008, p. 179-186.

53

Luiz Guilherme Marinoni, *Curso de Processo Civil – Teoria Geral do Processo*, São Paulo: Ed. RT, 2006, p. 21-139, vol. I. Hoje, Marinoni, Arenhart e Mitidiero, *Novo Curso de Processo Civil*, vol. I, cit.

54

Monograficamente, Luiz Guilherme Marinoni, *O STJ enquanto Corte de Precedentes*, São Paulo: Ed. RT, 2013; Daniel Mitidiero, *Cortes Superiores e Cortes Supremas – do Controle à Interpretação*, da Jurisprudência ao Precedente, São Paulo: Ed. RT, 2013; Rodolfo de Camargo Mancuso, *Recurso Extraordinário e Recurso Especial*, 6. ed., São Paulo: Ed. RT, 1999; Danilo Knijnik, *O Recurso Especial e a Revisão da Questão de Fato pelo Superior Tribunal de Justiça*, Rio de Janeiro: Forense, 2005; Gleydson Kleber Lopes de Oliveira, *Recurso Especial*, São Paulo: Ed. RT, 2002; José Saraiva, *O Recurso Especial e o STJ*, São Paulo: Saraiva, 2002; Leonardo Castanho Mendes, *O Recurso Especial*, São Paulo: Ed. RT, 2006; R. Ives Braghittoni, *Recurso Extraordinário*. São Paulo: Atlas, 2007; Teresa Arruda Alvim Wambier, *Recurso Especial, Recurso Extraordinário e Ação Rescisória*, 2. ed., São Paulo: Ed. RT, 2008; Pedro Miranda de Oliveira, (...); Rodrigo Barioni, *Ação Rescisória e Recursos para os Tribunais Superiores*, São Paulo: Ed. RT, 2013; Nelson Luiz Pinto, (...).

55

STF, Pleno, RE 141.788/CE, rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 06.05.1993, *DJ* 18.06.1993, p. 12.114; STJ, 2ª Turma, AgRg no REsp 502.632/MG, rel. Min. Eliana Calmon, j. 21.10.2003, *DJ* 24.11.2003, p. 264.

56

STJ, 1ª Turma, REsp 753.805/RJ, rel. Min. Luiz Fux, j. 17.05.2007, *DJ* 04.06.2007, p. 306.

57

STF, 1ª Turma, AgRg no RE 191.476/SC, rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 06.06.2006, *DJ* 30.06.2006, p. 358.

58

STF, 2ª Turma, AgRg no Ag 360.265/RJ, rel. Min. Celso de Mello, j. 13.08.2002, *DJ* 20.09.2002, p. 109.

59

STF, 1ª Turma, RE 398.407/RJ, rel. Min. Marco Aurélio, j. 21.09.2004, *DJ* 17.12.2004, p. 57.

60

STF, Pleno, RE 298.695/SP, rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 06.08.2003, *DJ* 24.10.2003, p. 12.

61

STF, 1ª Turma, RE 153.831/SP, rel. Min. Ellen Gracie, j. 30.12.2002, *DJ* 14.03.2003, p. 39.

62

STJ, 6ª Turma, AgRg no Ag 756.278/BA, rel. Min. Hamilton Carvalhido, j. 08.03.2007, *DJ* 28.05.2007, p. 406.

63

STJ, 1ª Turma, AgRg no REsp 326.001/PR, rel. Min. Francisco Falcão, j. 25.10.2005, *DJ* 13.03.2006, p. 185.

64

Amplamente, com as devidas indicações bibliográficas, Daniel Mitidiero, *Precedentes – da Persuasão à Vinculação*, São Paulo: Ed. RT, 2016; Júlio Lanes, *Fato e Direito no Processo Civil Cooperativo*, São Paulo: Ed. RT, 2015; Danilo Knijnik, *O Recurso Especial e a Revisão da Questão de Fato pelo Superior Tribunal de Justiça*, Rio de Janeiro: Forense, 2005.

65

Amplamente, Paulo de Tarso Sanseverino, *Princípio da Reparação Integral*, São Paulo: Saraiva, 2010.

66

Nessa linha, Mauro Bove, *Il Sindacato della Corte di Cassazione – Contenuto e Limiti*, Milano: Giuffrè, 1993, p. 176-190; Daniel Mitidiero, Cortes Superiores e Cortes Supremas, cit.

67

José Miguel Garcia Medina, *O Prequestionamento nos Recursos Extraordinário e Especial*, 2. ed., São Paulo: Ed. RT, 1999, p. 311.

68

STJ, 4ª Turma, AgRg no REsp 853.943/CE, rel. Min. Fernando Gonçalves, j. 20.11.2007, *DJ* 03.12.2007, p. 320.

69

STJ, 1ª Turma, AgRg no Ag 922.832/SP, rel. Min. Luiz Fux, j. 13.11.2007, *DJ* 29.11.2007, p. 225.

70

71

STJ, 2ª Turma, EDcl no REsp 396.796/RS, rel. Min. Eliana Calmon, j. 10.02.2004, *DJ* 17.05.2004, p. 170.

72

STJ, 1ª Turma, AgRg no REsp 550.433/RS, rel. Min. Teori Zavascki, j. 25.11.2003, *DJ* 15.12.2003, p. 223.

73

STJ, 2ª Turma, EDcl no REsp 396.796/RS, rel. Min. Eliana Calmon, j. 10.02.2004, *DJ* 17.05.2004, p. 170.

74

Luiz Guilherme Marinoni, O STJ enquanto Corte de Precedentes, cit.; Daniel Mitidiero, Cortes Superiores e Cortes Supremas, cit.

75

Sobre a cassação e a revisão, Michele Taruffo, Cassazione e revisione: un problema nella storia delle istituzioni giudiziarie, Il vertice ambiguo, cit.; Frédérique Ferrand, Cassation française et révision allemande, Paris: PUF, 1993.

76

STJ, 2ª Turma, REsp 790.407/SP, rel. Min. Castro Meira, j. 05.12.2006, *DJ* 14.12.2006, p. 332.

77

STJ, 1ª Turma, REsp 641.904/DF, rel. Min. Teori Zavascki, j. 13.12.2005, *DJ* 06.02.2006, p. 201.

78

A literatura sobre o tema é ampla. Consulte-se, entre outros, Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero, *Repercussão Geral no Recurso Extraordinário*, 2. ed., São Paulo: Ed. RT, 2008; Bruno Dantas, *Repercussão Geral*, São Paulo: Ed. RT, 2008; Guilherme Azem, (...); Ulisses, (...).

79

STF, Pleno, QO no Ag 664.567/RS, rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 18.06.2007, *DJ* 06.09.2007, p. 37.

80

STF, RG no RE 566.471/RN, rel. Min. Marco Aurélio, j. 15.11.2007, *DJ* 07.12.2007, p. 16.

81

STF, RG no RE 559.943/RS, rel. Min. Carmen Lúcia, j. 05.12.2007, *DJ* 07.12.2007, p. 16

82

STF, RG no RE 561.908/RS, rel. Min. Marco Aurélio, j. 08.11.2007, *DJ* 07.12.2007, p. 16.

83

STF, RG no RE 564.413/SC, rel. Min. Marco Aurélio, j. 12.12.2007, *DJ* 14.12.2007, p. 20.

84

STF, RG no RE 567.932/RS, rel. Min. Marco Aurélio, j. 29.11.2007, *DJ* 14.12.2007, p. 20.

85

STF, RG no RE 556.385/MT, rel. Min. Menezes Direito, j. 29.11.2007, *DJ* 07.12.2007, p. 16.

86

STF, RG no RE 565.138/BA, rel. Min. Menezes Direito, j. 29.11.2007, *DJ* 07.12.2007, p. 16.

87

STF, Pleno, Rcl 1.987, rel. Min. Maurício Corrêa, *DJ* 21.05.2004.

88

É intuitivo que, num sistema que ignora o precedente obrigatório, não há racionalidade em dar a todo e qualquer juiz o poder de controlar a constitucionalidade da lei. Sem considerar a realidade brasileira, advertiu Mauro Cappelletti que a introdução no *civil law* do método americano de controle de constitucionalidade conduziria à consequência de que uma lei poderia não ser aplicada por alguns juízes e tribunais que a entendessem inconstitucional, mas, no mesmo instante e época, ser aplicada por outros juízes e tribunais que a julgassem constitucional. Lembrou o jurista italiano que nada impediria que o juiz que aplicasse determinada lei não a considerasse no dia seguinte ou vice-versa, ou, ainda, que se formassem verdadeiras facções jurisprudenciais nos diferentes graus de jurisdição, simplesmente por uma visão distinta dos órgãos jurisdicionais inferiores, em geral compostos de juízes mais jovens e, assim, mais propensos a ver uma lei como inconstitucional, exatamente como aconteceu na Itália no período entre 1948 e 1956. Advertiu Cappelletti que da adoção de um sistema de controle de constitucionalidade deferido a todos os juízes pode decorrer uma grave situação de incerteza jurídica e de conflito entre órgãos do judiciário. (Mauro Cappelletti, *Il controllo giudiziario di costituzionalità delle leggi nel diritto comparato*, Milano: Giuffrè, 1968, p. 62 e ss).

“Secondo la teoria che converremo di chiamare ‘cognitivistica’ – ma talora della ‘formalistica’ – la quale risale alle dottrine giuridiche dell’Illuminismo, l’interpretazione (ivi inclusa quella giudiziale) è *atto di scoperta o conoscenza del significato*” (Riccardo Guastini, *Interpretare e argomentare*, Milano: Giuffrè, 2011, p. 63-64) Mas hoje não se pensa num significado unívoco intrínseco ao texto legal. Não há uma relação de sinonímia entre o texto e o resultado obtido com a atividade interpretativa, de modo que a interpretação está longe de poder ser uma atividade de descoberta para a declaração da norma. Como diz Guastini, “l’operazione intellettuale che conduce dall’enunciato al significato – o, se si preferisce, l’operazione di identificazione del significato – altro non è che l’interpretazione. La *disposizione* è dunque l’*oggetto* dell’interpretazione, la *norma* è il suo *risultato*. O, detto altrimenti, *la disposizione è fonte della norma attraverso l’interpretazione*”. (Riccardo Guastini, *Interpretare e argomentare*, cit., 409). Ver Giovanni Tarello, Il “problema” dell’interpretazione: una formulazione ambigua, *Rivista internazionale di filosofia del diritto*, p. 349-357, 1966; Giovanni Tarello, *L’interpretazione della legge*, Milano: Giuffrè, 1980; Riccardo Guastini, Disposizione vs. norma, *Giurisprudenza costituzionale*, p. 3-14, 1989; Pierluigi Chiassoni, *Tecnica dell’interpretazione giuridica*, Bologna: Il Mulino, 2007, p. 62; Mario Jori e Anna Pintore, *Manuale di teoria generale del diritto*, Torino: Giappichelli, 1995, p. 205 e ss; Enrico Dicioti, *Interpretazione della legge e discorso razionale*, Torino: Giappichelli, 1999, p. 200 e ss; Rodolfo Sacco, *Interpretazione del diritto. Dato oggettivo e spirito dell’interprete. Diritto, giustizia e interpretazione*, Roma/Bari: Laterza, p. 111 e ss, 1998.

A função das Cortes de Cassação de *civil law* foram definidas, como não poderia deixar de ser, a partir de valores e pressupostos teóricos de um determinado momento histórico. A formação positivista e cognitivista de Calamandrei tem íntima ligação com a ideia de “uniformidade” como meio de controle da exata interpretação da lei. Ocorre que o pressuposto teórico que determinou a ideia de que a Corte Suprema se destina a controlar a exata interpretação da lei foi completamente desgastado com o passar do tempo. Tal pressuposto está assentado na teoria formalista ou cognitiva da interpretação, que, por sua vez, é informada pelos valores do Estado legislativo. V. Piero Calamandrei, La genesi logica della sentenza civile, *Opere Giuridiche*, Napoli: Morano, 1965, vol. 1; Piero Calamandrei, La cassazione civile – disegno generale dell’istituto, *Opere Giuridiche*, vol. VII, cit; Michele Taruffo, Cassazione e revisione: un problema nella storia delle istituzioni giudiziarie, *Il vertice ambiguo – Saggi sulla cassazione civile*, Bologna: Il Mulino, 1991.

Jerzy Wróblewski, Lenguaje jurídico e interpretación jurídica. *Sentido y hecho en el derecho*, México: Fontamara, 2008, p. 136 e ss.

Genaro Carriò. *Notas sobre derecho y lenguaje*, cit., p. 24-51; Giovanni Tarello, Il “problema” dell’interpretazione: una formulazione ambigua. *Rivista internazionale di filosofia del diritto*, 1966, p. 355.

M. Shapiro, Stability and change in judicial decision-making: incrementalism or stare decisis? *Law and the behavioral sciences*. Indianápolis-Kansas-Nova Iorque: ed. L. M. Friedman & S. Macaulay, 1977.

Jerzy Wróblewski, *Constitución y teoría general de la interpretación jurídica*, cit., p. 83; Jerzy Wróblewski, Legal syllogism and rationality of judicial decision, *Rechtstheorie*, cit; Jerzy Wróblewski, Transparency and doubt. Understanding and interpretation in pragmatics and in Law, *Law and Philosophy*, 1988.

Segundo Wróblewski (*Constitución y teoría general de la interpretación jurídica*, cit., p. 89), na justificação das decisões interpretativas os juízos de valor desempenham o papel mais importante, uma vez que a fórmula normal das decisões interpretativas justificadas emprega diretivas interpretativas e juízos de valor, mas esses determinam a escolha e o uso das diretivas. Wróblewski demonstra que, por haver valoração na eleição e aplicação das diretivas interpretativas, não há como falar em interpretação verdadeira ou correta. Diz que qualificar de “verdadeira” uma decisão interpretativa conduz a consequências desconcertantes, sendo por isso preferível falar de decisões interpretativas justificadas por argumentos concretos e perguntar sobre as razões para aceitá-los, apresentando-se a cadeia de raciocínios justificativos até onde seja pragmaticamente necessário e possível dentro de um marco do discurso jurídico concreto. Quando se substitui a ideia de “interpretação exata” pela de “interpretação dotada de razões apropriadas”, a Corte Suprema naturalmente é investida do poder de definir a interpretação adequada ou de atribuir sentido ao direito, surgindo, como consequência, a sua legitimidade para garantir a unidade do direito que proclama.

Como escreve Taruffo, a função da Cassação não mais pode ser vista como a de assegurar a exatidão formal da interpretação, uma vez que isso equivaleria a fazer prevalecer a interpretação formalista, fundada apenas sobre critérios formais. Cabe à Cassação, isto sim, estabelecer qual é a interpretação justa – ou mais justa – da norma com base nas diretivas e eleições interpretativas mais corretas, ou seja, aceitáveis a partir das “melhores razões” (Michele Taruffo, *La Corte di Cassazione e la legge. Il vertice ambiguo. Saggi sulla Cassazione civile*, cit., p. 104).

V. Luiz Guilherme Marinoni, *O Julgamento nas Cortes Supremas*, cit.

Antes da revogação do inc. II do § 3.º do art. 1.035, escreveu-se: “um caso repetitivo, assim como outro qualquer, apenas deve ser conhecido pelo Supremo Tribunal Federal quando envolver questão de repercussão geral. E é apenas por isso, e não por outra razão, que dá origem a precedente. É certo que o art. 1.035, § 3.º do CPC/2015 afirma que ‘haverá repercussão geral sempre que o recurso impugnar acórdão que: ii) tenha sido proferido em julgamento de casos repetitivos’. Porém, para que essa norma não tenha o significado de um grosseiro equívoco, torna-se necessário interpretá-la mediante conjugação à norma do § 1.º do mesmo art. 1.035, que diz que, ‘para efeito de repercussão geral, será considerada a existência ou não de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo’. Nessa linha, o Supremo Tribunal Federal só terá motivo para discutir recurso extraordinário interposto contra acórdão que julgou ‘casos repetitivos’ quando esses

espelharem questão de repercussão geral” (Luiz Guilherme Marinoni, O “problema” do incidente de resolução de demandas repetitivas e dos recursos extraordinário e especial repetitivos, *Revista de Processo*, vol. 249, p. 413).

99

“... não deveria haver motivo para usar esse modelo recursal [técnica dos recursos repetitivos] apenas para otimizar o trabalho das Cortes Supremas, uma vez que estas, na verdade, jamais deveriam se confrontar com vários recursos. Note-se que a repercussão geral, no Supremo Tribunal Federal, já é suficiente para suspender os recursos extraordinários que versam a mesma questão. No Superior Tribunal de Justiça, caso já existisse filtro recursal similar, o mesmo poderia ocorrer” (Luiz Guilherme Marinoni, O “problema” do incidente de resolução de demandas repetitivas e dos recursos extraordinário e especial repetitivos, *Revista de Processo*, vol. 249, p. 413-414).

100

O writ of certiorari confere à Suprema Corte estadunidense ampla discricionariedade para selecionar os recursos (Rule 10, *Rules of the Supreme Court*) O certiorari, que nasceu para reduzir o número de recursos afetos à Suprema Corte, tornou-se instrumento indispensável para a Corte desenvolver a sua função. O instituto não apenas permitiu à Corte racionalizar o seu tempo, dedicando-o aos casos mais importantes, mas sobretudo lhe deu condições de fixar soluções para casos de notável importância para o desenvolvimento da sociedade estadunidense. V. Edward A. Hartnett, Questioning Certiorari: some reflections seventy-five years after the judges’ bill. *Columbia Law Review*, vol. 100, n. 7, New York, Nov. 2010, p. 1643-1738; Margareth M. Cordray e Richard Cordray, The philosophy of Certiorari: jurisprudential considerations in Supreme Court case selection. *Washington University Law Quarterly*, vol. 82, n. 2, Saint Louis, 2004, p. 389-452; Saul Brenner, Granting Certiorari by the United States Supreme Court: An Overview of the Social Science Studies. *Law Library Journal*, vol. 92, n. 2, Chicago, 2000, p. 193-201; Robert W. Bennett, Judicial Review in the United States. *Annuario di Diritto Comparato e di Studi Legislativi*, Napoli: Edizione Scientifiche Italiane, 2011, p. 155-182; Vittoria Barsotti, *L’Arte di Tacere – Strumenti e Tecniche di non Decisione della Corte Suprema degli Stati Uniti*, Torino: Giappichelli, 1999.

101

No REsp 1.308.830, a 3ª Turma do STJ indeferiu, em Questão de Ordem, requerimento de desistência do recurso especial, que contou com a anuência do recorrido. Disse a Ministra relatora que o julgamento do recurso especial, por importar à definição do sentido do direito federal, não pode ficar à livre disposição dos litigantes. Deixou-se claro o caráter de precedente da decisão que resolve uma questão federal, consignando-se que deve ser levado em conta o papel atribuído ao STJ pela Constituição, “que transcende o de ser simplesmente a última palavra em âmbito infraconstitucional, sobressaindo o dever de fixar teses de direito que servirão de referência para as instâncias ordinárias de todo o país. A partir daí, infere-se que o julgamento dos recursos submetidos ao STJ ultrapassa o interesse individual das partes nele envolvidas, alcançando toda a coletividade para a qual suas decisões irradiam efeitos” (REsp 1.308.830, Questão de Ordem, 3ª Turma, rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 19.06.2012). Essa tese apenas pode ser admitida quando se constata que o STJ não é uma mera Corte de Revisão posta ao interesse do jurisdicionado. Supõe, sem qualquer dúvida, que o STJ tem uma função pública, de colaboração para o florescimento do direito adequado ao convívio social em todo o território nacional. Ver Luiz Guilherme Marinoni, *O STJ enquanto Corte de Precedentes*, 2. ed., cit., p. 185 e ss.

102

Luiz Guilherme Marinoni, *O STJ enquanto Corte de Precedentes*, 2. ed., cit., p. 146 e ss.; Daniel Mitidiero, *Cortes Superiores e Cortes Supremas*, cit.

103

Samuel Krislov, The *amicus curiae* brief. From friendship to advocacy. *Yale Law Journal*, 72, 1963, p. 694 e ss.

104

Michael K. Lowman, The litigating *amicus curiae*: when does the party begin after the friends leave? *The American University Law Review*, 41, 1992, p. 1243-1299.

105

David S. Ruder, The development of legal doctrine through *amicus* participation: the SEC experience. *Wisconsin Law Review*, 1989, p. 1.167 e ss.

106

Adam S. Hochschild, The Modern Problem of Supreme Court Plurality Decision: Interpretation in Historical Perspective, *Washington University Journal of Law & Policy*, vol. 4, p. 279 e ss; Linda Novak, The precedential value of Supreme Court Plurality Decisions, *Columbia Law Review*, vol. 80, n. 4 (May, 1980), p. 761 e ss; John F. Davis e William L. Reynolds, Juridical Cripples: Plurality Opinions in the Supreme Court, *Duke Law Journal*, vol. 59, 1974, p. 67 e ss.

107

O teste denominado de “narrowest grounds” geralmente é relacionado ao caso *Marks v. United States*, decidido pela Suprema Corte estadunidense em 1977. Trata-se, basicamente, de uma tentativa de extrair dos fundamentos minoritários elementos compartilhados, capazes de permitir a configuração de uma razão ou de um entendimento comum. V. John F. Davis e William L. Reynolds, Juridical Cripples: Plurality Opinions in the Supreme Court, *Duke Law Journal*, vol. 59, 1974, p. 67 e ss.

108

Lewis A. Kornhauser e Lawrence G. Sager, The One and the Many: Adjudication in Collegial Courts, *California Law Review*, vol. 81, 1993, p. 11; Lewis A. Kornhauser e Lawrence G. Sager, The many as one: integrity and group choice in paradoxical cases, *Philosophy & Public Affairs*, vol. 32, 2004, p. 249 e ss

109

Lewis A. Kornhauser e Lawrence G. Sager, The One and the Many: Adjudication in Collegial Courts, *California Law Review*, vol. 81, 1993, p. 11.

110

“The fact that a court in a rather simple case of this sort could face a choice between two voting protocols, each of which seems quite reasonable, indeed natural, to follow and yet discover that the outcome of the case will turn on the choice between them, is the product of a structural paradox latent in appellate adjudication. We can call this the doctrinal paradox” (Lewis A. Kornhauser e Lawrence G. Sager, *The One and the Many: Adjudication in Collegial Courts*, *California Law Review*, vol. 81, 1993, p. 11-12). V. William V. Gehrlein e Dominique Lepelley, *Voting Paradoxes and Group Coherence*, Heidelberg: Springer, 2011.

111

Lewis A. Kornhauser e Lawrence G. Sager, *The One and the Many: Adjudication in Collegial Courts*, *California Law Review*, vol. 81, 1993, p. 14 e ss.

112

Lewis A. Kornhauser e Lawrence G. Sager, *The One and the Many: Adjudication in Collegial Courts*, *California Law Review*, vol. 81, 1993, p. 20 e 25 e ss.

113

V. Linda Novak, *The precedential value of Supreme Court Plurality Decisions*, *Columbia Law Review*, vol. 80, n. 4, May, 1980; Adam S. Hochschild, *The Modern Problem of Supreme Court Plurality Decision: Interpretation In Historical Perspective*, *Washington University Journal of Law & Policy*, vol. 4; Luiz Guilherme Marinoni, *O Julgamento nas Cortes Supremas*, cit., capítulo IV.

114

“In particular, in cases where the doctrinal paradox arises, judgment and reason are immediately and inexorably pulled apart, to the potential detriment of the orderly development of legal doctrine. Consider *Tidewater*, where substantial majorities of the Justices rejected both the proposition that the District of Columbia was a ‘State’ within the meaning of Article III, and the proposition that Congress had the power to extend the jurisdiction of Article III courts. The two minorities, however, held differently, and, in case-by-case voting the conjoined minorities dictated the outcome of the case. Obviously, the Court as an entity articulated *no* justification for its outcome. Each justification offered was in fact rejected by a substantial majority of the Court. This conflict between justifying reasons and case judgment is the most objectionable and perplexing feature of the case” (Lewis A. Kornhauser e Lawrence G. Sager, *The One and the Many: Adjudication in Collegial Courts*, *California Law Review*, vol. 81, 1993, p. 32).

115

Lewis A. Kornhauser e Lawrence G. Sager, *The One and the Many: Adjudication in Collegial Courts*, *California Law Review*, vol. 81, 1993, p. 14 e 19.

116

A diferença é a de que a *ratio decidendi*, ao contrário da eficácia obrigatória do resultado, aplica-se a todos

os casos que, embora diferentes, racionalmente não tem razão para ser solucionados de modo distinto. Lembre-se que o espaço para distinção, diante de *ratio decidendi*, é muito maior do que o que surge em face de decisão de questão de direito. Nessa última hipótese basta perguntar se a questão de direito é igual; na primeira é preciso investigar se o caso, apesar de distinto, racionalmente não exige a aplicação do precedente.

117

Cf. Luiz Guilherme Marinoni, *O Julgamento nas Cortes Supremas*, cit., capítulo VI, item 6.8.

118

Vittoria Barsotti, *L'arte di tacere – Strumenti e tecniche di non decisione della Corte Suprema degli Stati Uniti*, op. cit., p. 292.

119

Loïc Cadiet, *Le rôle institutionnel et politique de la cour de cassation en france: tradition, transition, mutation?* *Annuario di Diritto Comparato e di Studi Legislativi*, Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane, 2011, p. 190-191.

120

Michele Comastri, *Giudizio di cassazione e poteri officiosi in ordine alle questioni di merito*, op. cit., p. 228.

121

STJ, 6ª Turma, HC 274.806/SP, rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 14.02.2014, *DJe* 18.02.2014.

122

STF, Plenário, RE 733.433/MG, especialmente o voto do Min. Edson Fachin.

123

Daniel Mitidiero, *Cortes Superiores e Cortes Supremas*, cit.

124

Luiz Guilherme Marinoni, *O STJ enquanto Corte de Precedentes*, cit.

Referências Bibliográficas

AARNIO, Aulis. *The Rational as Reasonable – A Treatise on Legal Justification*. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 1987.

ABBUD, André. *Homologação de Sentenças Arbitrais Estrangeiras*. São Paulo: Atlas, 2008.

ALEXY, Robert. *Theorie der Grundrechte*. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1986.

_____. *Theorie der juristischen Argumentation*. Frankfurt im Main: Suhrkamp, 1983.

_____. *Teoria da argumentação jurídica*. São Paulo: Landy, 2001.

ALLEN, Ronald; PARDO, Michael. *The myth of the law-fact distinction*. Northwestern University Law Review, 2003.

ALONSO GARCÍA, Enrique. *La interpretación de la constitución*. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1984.

ALVARO DE OLIVEIRA, Carlos Alberto. *O Juiz e o Princípio do Contraditório*. Revista de Processo. São Paulo: Ed. RT, 1993, n. 71.

_____. *A Garantia do Contraditório. Do Formalismo no Processo Civil*, 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2003.

_____. *Do Formalismo no Processo Civil*, 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2003.

_____; MITIDIERO, Daniel. *Curso de Processo Civil*. São Paulo: Atlas, 2012, vol. II.

AMARAL, Guilherme Rizzo. *Comentários às Alterações do Novo CPC*. São Paulo: Ed. RT, 2015.

ANDRIOLI, Virgilio. *Commento al codice di procedura civile*. Napoli: Jovene, 1964, vol. 1.

ANSANELLI, Vincenzo; DONDI, Angelo; COMOGLIO, Paolo. *Processi Civili in Evoluzione – Una Prospettiva Comparata*. Milano: Giuffrè, 2015.

APRIGLIANO, Ricardo. *Ordem Pública e Processo*. São Paulo: Atlas, 2011.

_____. *A Apelação e seus Efeitos*. São Paulo: Atlas, 2003.

ARAGÃO, Egas Dirceu Moniz de. *A Correição Parcial*. Curitiba, 1958.

ARENHART, Sérgio Cruz. *A Tutela Coletiva de Interesses Individuais*. São Paulo: Ed. RT, 2013.

_____. *O Recurso de Terceiro Prejudicado e as Decisões Vinculantes*. In: ARRUDA ALVIM WAMBIER, Teresa; NERY JÚNIOR, Nelson (coords.), *Aspectos Polêmicos e Atuais dos Recursos Cíveis e Assuntos Afins*. São Paulo: Ed. RT, 2007, vol. XI.

_____; MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. *Novo Curso de Processo Civil*. São Paulo:

Ed. RT, 2015, vol. I.

_____. Novo Curso de Processo Civil. São Paulo: Ed. RT, 2015, vol. II.

_____. Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Ed. RT, 2015.

ARRUDA ALVIM, Teresa. Recurso Especial, Recurso Extraordinário e Ação Rescisória. 2. ed. São Paulo: Ed. RT, 2008.

_____. Os Agravos. 4. ed. São Paulo: Ed. RT, 2006.

_____. Omissão Judicial e Embargos de Declaração. São Paulo: Ed. RT, 2005.

_____. Introdução. In: ARRUDA ALVIM, Teresa (coord.). Direito jurisprudencial. São Paulo: Ed. RT, 2014.

ARRUDA ALVIM, Teresa; DANTAS, Bruno. Recurso especial, recurso extraordinário e a nova função dos tribunais superiores no direito brasileiro. 4. ed. São Paulo: Ed. RT, 2017.

ASCARELLI, Tulio. Giurisprudenza costituzionale e teoria dell'interpretazione. Rivista de diritto processuale. Padova: Cedam, 1957.

ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos. São Paulo: Ed. RT, 2007.

_____. Manual dos Recursos, 7. ed. São Paulo: Ed. RT, 2015.

ATYIAH, P. S.; SUMMERS, Robert. Form and Substance in Anglo-American Law. Oxford: Oxford University Press, 1987.

ÁVILA, Ana Paula. A Modulação dos Efeitos Temporais pelo STF no Controle Concentrado. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2009.

ÁVILA, Humberto. Teoria dos Princípios (2003), 15. ed. São Paulo: Malheiros, 2014.

_____. Segurança Jurídica. São Paulo: Malheiros, 2011.

_____. Teoria da igualdade tributária. São Paulo: Malheiros, 2008.

AZEVEDO, Luiz Carlos de. Origem e Introdução da Apelação no Direito Lusitano. São Paulo: FIEO, 1976.

_____; CRUZ E TUCCI, José Rogério. Lições de História do Processo Civil Romano. São Paulo: Ed. RT, 2001.

_____. Lições de História do Processo Civil Lusitano. São Paulo: Ed. RT, 2009.

BAHIA, Alexandre; NUNES, Dierle; PEDRON, Flávio; THEODORO JÚNIOR, Humberto. Novo CPC – Fundamentos e Sistematização. Rio de Janeiro: Forense, 2015.

BAPTISTA, Sônia Márcia Hase de Almeida. Dos Embargos de Declaração. São Paulo: Ed. RT, 1993.

BAPTISTA DA SILVA, Ovídio Araújo. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Ed. RT, 2000, vol. I.

_____. Curso de Processo Civil, 5. ed. São Paulo: Ed. RT, 2000, vol. I.

_____. Processo e Ideologia – O Paradigma Racionalista. Rio de Janeiro: Forense, 2004.

BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil (1974), 15. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2009, vol. V.

_____. Questões Prejudiciais e Questões Preliminares. Direito Processual Civil. Rio de Janeiro: Borsoi, 1971.

_____. Considerações sobre a chamada “relativização” da coisa julgada material, Relativização da coisa julgada, Salvador: JusPodium, 2008.

BARBOZA, Estefânia Maria de Queiroz. Precedentes Judiciais e Segurança Jurídica. São Paulo: Saraiva, 2014.

BARIONI, Rodrigo. Ação rescisória e recursos para os Tribunais Superiores. São Paulo: Ed. RT, 2013.

_____. Efeito Devolutivo da Apelação Civil. São Paulo: Ed. RT, 2007.

_____. Preclusão Diferida, o Fim do Agravo Retido e a Ampliação do Objeto da Apelação no Novo Código de Processo Civil. Revista de Processo. São Paulo: Ed. RT, 2015, n. 243.

BARSOTTI, Vittoria. L'Arte di Tacere – Strumenti e Tecniche di non Decisione della Corte Suprema degli Stati Uniti. Torino: Giappichelli, 1999.

BARZOTTO, Luís Fernando. O Positivismo Jurídico Contemporâneo – uma Introdução a Kelsen, Ross e Hart (1999), 2. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2007.

BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Efetividade do Processo e Técnica Processual. São Paulo: Malheiros, 2006.

BENDITT, Theodore. The Rule of Precedent. In: GOLDSTEIN, Laurence (coord.), Precedent in Law. Oxford: Oxford University Press, 1987.

BENNETT, Robert. Judicial Review in the United States. Annuario di Diritto Comparato e di Studi Legislativi. Nápoles: Edizione Scientifiche Italiane, 2011.

BENTHAM, Jeremy. Rationale of judicial evidence. London: Hunt and Clarke, 1827.

BERALDO, Leonardo de Faria. A flexibilização da coisa julgada que viola a Constituição, Coisa julgada inconstitucional. Rio de Janeiro: América Jurídica, 2002.

BERMUDES, Sérgio. Comentários ao Código de Processo Civil, 2. ed. São Paulo: Ed. RT, 1977, vol. VII.

BIX, Brian. A Dictionary of Legal Theory. Oxford: Oxford University Press, 2004.

BOBBIO, Norberto. Teoria Generale del Diritto (1957 – 1958). Torino: Giappichelli, 1993.

_____. Il Positivismo Giuridico (1960-1961) (1979), 2. Ed. Torino: Giappichelli, 1996.

_____. Lições de Filosofia do Direito. Trad. Márcio Pugliese, Edson Bini e Carlos Rodrigues. São Paulo: Ícone, 1995.

BONDIOLI, Luís Guilherme Aidar. Embargos de Declaração. São Paulo: Saraiva, 2005.

_____. Comentários ao Código de Processo Civil. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2017, vol. XX.

BOVE, Mauro. Il Sindacato della Corte di Cassazione – Contenuto e Limiti. Milano: Giuffrè, 1993.

BRAGA, Paula Sarno; DIDIER JÚNIOR, Fredie; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Curso de Direito Processual Civil (2007), 10. ed. Salvador: JusPodium, 2015, vol. II.

BRAGHITTONI, R. Ives. Recurso Extraordinário. São Paulo: Atlas, 2007.

BRENNER, Saul. Granting Certiorari by the United States Supreme Court: An Overview of the

Social Science Studies. Law Library Journal, Chicago, 2000, vol. 92, n. 2.

BUENO, Cássio Scarpinella. *Amicus Curiae no Processo Civil Brasileiro – Um Terceiro Enigmático*, 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2012.

BUSTAMANTE, Thomas da Rosa de. *Bustamante, Teoria do Precedente Judicial – A Justificação e a Aplicação de Regras Jurisprudenciais*. São Paulo: Noeses, 2012.

BUZAID, Alfredo. *Do Agravo de Petição no Sistema do Código de Processo Civil*. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1956.

CABRAL, Antonio do Passo. *Nulidades no Processo Moderno*. Rio de Janeiro: Forense, 2009.

_____. *O Novo Procedimento-Modelo (Musterverfahren) Alemão: uma Alternativa às Ações Coletivas*. Revista de Processo. São Paulo: Ed. RT, 2007, n. 147.

_____. *Il Principio del Contraddittorio come Diritto d'Influenza e Dovere di Dibattito*. Rivista di Diritto Processuale. Padova: Cedam, 2005.

CADIET, Loïc. *Le rôle institutionnel et politique de la cour de cassation en france: tradition, transition, mutation?* Annuario di Diritto Comparato e di Studi Legislativi. Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane, 2011.

_____; JEULAND, Emmanuel. *Droit Judiciaire Privé* (1992), 8. ed. Paris: LexisNexis, 2013.

_____; NORMAND, Jacques; MEKKI, Soraya Amrani. *Théorie Générale du Procès*. Paris: PUF, 2010.

CALABRESI, Guido. *A Common Law for the Age of Statutes*. Cambridge: Harvard University Press, 1982.

CALAMANDREI, Piero. *La Cassazione Civile*. In: CAPPELLETTI, Mauro (org.), *Opere Giuridiche*. Napoli: Morano Editore, 1976, vol. VII.

_____. *Soppravvivenza della Querela Nullitatis nel Processo Civile Vigente*. Rivista di Diritto Processuale. Padova: Cedam, 1951.

CÂMARA, Alexandre Freitas. *O Novo Processo Civil Brasileiro*. São Paulo: Atlas, 2015.

_____. *Ação Rescisória*, 3. ed. São Paulo: Atlas, 2014.

CAMINKER, Evan H. *Sincere and Strategic Voting Norms on Multimember Courts*. Michigan Law Review, 1999, vol. 67.

CANOTILHO, José Joaquim Gomes. *Direito constitucional e teoria da constituição*, Coimbra: Almedina, 2002.

CAPONI, Remo. *L' Appello nel Sistema delle Impugnazioni Civili (Note di Comparazione Anglo-Tedesca)*. Rivista di Diritto Processuale. Padova: Cedam, 2009.

_____. *La Riforma dei Mezzi di Impugnazione*. Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile. Milano: Giuffrè, 2012.

_____. *L'efficacia del giudicato civile nel tempo*. Milano: Giuffrè, 1991.

CAPPELLETTI, Mauro. *Il controllo giudiziario di costituzionalità delle leggi nel diritto comparato*. Milano: Giuffrè, 1968.

_____. *Il Processo Civile Italiano nel Quadro della Contrapposizione “Civil Law” – “Common Law” (Appunti Storico-comparativi), Processo e Ideologie*. Bologna: Il Mulino, 1969.

- _____. *Processo, Ideologias e Sociedade*. Tradução de Hermes Zaneti Júnior. Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris Editor, 2010, vol. II.
- CARDOZO, Benjamin. *The Nature of Judicial Process*. New Haven: Yale University Press, 1921.
- CARNELUTTI, Francesco. *Sistema del diritto processuale*. Padova: Cedam, 1936, vol. I.
- _____. *La prova civile*, 2. ed., Roma: Atteneo, 1947.
- CARPI, Federico. *La provvisoria esecutorietà della sentenza*. Milano: Giuffrè, 1979.
- _____; COLESANTI, Vittorio; TARUFFO, Michele. *Commentario breve al Codice di Procedura Civile*. Padova: Cedam, 1988.
- CARRATA, Antonio. *Il Principio della non Contestazione nel Processo Civile*. Milano: Giuffrè, 1995.
- CARRIÒ, Genaro. *Notas sobre Derecho e Language*. Buenos Aires: Abeledo Perrot, 1979.
- CARVALHO, Fabiano. *Ação Rescisória*. São Paulo: Saraiva, 2010.
- CAVALLARI, Ciacchia. *La contestazione nel processo civile*. Milano: Giuffrè, 1993, vol. 2.
- CERINO-CANOVA, Augusto. *“Impugnazioni Civili”, Studi di Diritto Processuale Civile*. Padova: Cedam, 1992.
- CHIASSONI, Pierluigi. *Tecnica dell’ Interpretazione Giuridica*. Bologna: Il Mulino, 2007.
- _____. *I Precedenti Civili sono Vinculanti? Considerazioni sull’ art. 360-bis CPC. Diritti Umani, Sentenze Elusive, Clausole Ineffabili – Scritti di Realimo Militante*. Roma: Aracne, 2011.
- _____. *“The Philosophy of Precedent: Conceptual Analysis and Rational Reconstruction”, On the Philosophy of Precedent*. Stuttgart: Franz Steiner, 2012.
- _____. *Positivismo Giuridico – Una Investigazione Analitica*. Modena: Mucchi Editore, 2013.
- _____. *Disposición y norma: una distinción revolucionaria. Disposición. vs norma*, Lima: Palestra, 2011.
- CHINCOLI, Vanessa. *O Direito Fundamental ao Contraditório no Processo Civil. Conceito e Possíveis Aplicações*. In: MITIDIERO, Daniel (coord.), *O Processo Civil no Estado Constitucional*. Salvador: JusPodium, 2012.
- CHIOVENDA, Giuseppe. *Principii di diritto processuale civile*. Napoli: Jovene, 1906.
- _____. *Instituições de direito processual civil*. São Paulo: Saraiva, 1965, vol. I.
- _____. *Sulla cosa giudicata, Saggi di diritto processuale civile (reeimpresão)*. Milano: Giuffrè, 1993, vol. II.
- _____. *Lodovico Mortara. Rivista di Diritto Processuale Civile*. Padova: Cedam, 1937.
- CLERMONT, Kevin. *Principles of Civil Procedure*, 3. ed. St. Paul: West, 2012.
- COING, Helmut. *Grundzüge der Rechtsphilosophie* (1950), 5. ed. Berlin: Walter de Gruyter, 1993.
- COLESANTI, Vittorio. *Sentenza civile (revocazione della)*. *Novissimo Digesto Italiano*, 1969, vol. XVI.
- _____; CARPI, Federico; TARUFFO, Michele. *Commentario breve al Codice di Procedura Civile*. Padova: Cedam, 1988.

- COLLIA, Filippo. L'ordinanza per il pagamento di somme non contestate nel processo del lavoro. *Rivista di Diritto Processuale*. Milano: Giuffrè, 1994.
- COMASTRI, Michele. Giudizio di Cassazione e Poteri Officiosi in Ordine alle Questioni di Merito. Torino: Giappichelli, 2012.
- COMOGLIO, Luigi Paolo. La Garanzia dell' Azione ed il Processo Civile. Padova: Cedam, 1970.
- _____. Le Garanzie Fondamentali del 'Giusto Processo', Etica e Tecnica del "Giusto Processo. Torino: Giappichelli, 2004.
- _____. Note Riepilogative su Azione e Forme di Tutela, nell' Ottica della Domanda Giudiziale. *Rivista di Diritto Processuale*. Padova: Cedam, 1993.
- COMOGLIO, Luigi Paolo; FERRI, Corrado; TARUFFO, Michele. Lezioni sul processo civile. Bologna: Il Mulino, 1995.
- _____; DONDI, Angelo; ANSANELLI, Vincenzo. Processi Civili in Evoluzione – Una Prospettiva Comparata. Milano: Giuffrè, 2015.
- CORDRAY, Margareth; CORDRAY, Richard. The philosophy of Certiorari: jurisprudential considerations in Supreme Court case selection. *Washington University Law Quarterly*, Saint Louis, 2004, vol. 82, n. 2.
- CORSALE, Massimo. Certezza del diritto e crisi di legittimità. Milano: Giuffrè, 1979.
- COSTA, Moacyr Lobo da. O Agravo no Direito Lusitano. Rio de Janeiro: Borsoi, 1974.
- COUTO, Mônica Bonetti. Recurso Adesivo – Um Exame à Luz da Teoria Geral dos Recursos. Curitiba: Juruá, 2007.
- COUTURE, Eduardo. Las Garantías Constitucionales del Proceso Civil (1948), *Estudios de Derecho Procesal Civil*. Buenos Aires: Ediar, 1948, t. I.
- _____. Fundamentos del derecho procesal civil. Buenos Aires: Depalma, 1951.
- CRAMER, Ronaldo. Ação Rescisória por Violação da Norma Jurídica, 2. ed. Salvador: JusPodium, 2012.
- CRISAFULLI, Vezio. Disposizione (e norma). *Enciclopedia del Diritto*. Milano: Giuffrè, 1964.
- CROSS, Rupert; HARRIS, J. W. Precedent in English Law (1961), 4. ed. Oxford: Oxford University Press, 2004.
- CRUZ E TUCCI, José Rogério. Precedente Judicial como Fonte do Direito. São Paulo: Ed. RT, 2004.
- _____; AZEVEDO, Luiz Carlos de. Lições de História do Processo Civil Romano. São Paulo: Ed. RT, 2001.
- _____. Lições de História do Processo Civil Lusitano. São Paulo: Ed. RT, 2009.
- CUNHA, Leonardo Carneiro da. A Atendibilidade dos Fatos Supervenientes no Processo Civil – Uma Análise Comparativa entre o Sistema Português e o Brasileiro. Coimbra: Almedina, 2012.
- _____. Jurisdição e Competência (2008), 2. ed. São Paulo: Ed. RT, 2013.
- _____; DIDIER JÚNIOR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil (2006), 13. ed. Salvador: JusPodium, 2016, vol. III.
- CURRIE, Brainerd. Mutuality of Collateral Estoppel: Limits of the Bernherd Doctrine. Stanford

Law Review, 1957, vol. 9.

DALL'AGNOL JÚNIOR, Antônio. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Ed. RT, 2000, vol. II.

DANTAS, Bruno. Repercussão Geral. São Paulo: Ed. RT, 2008.

DANTAS, Marcelo. Reclamação Constitucional no Direito Brasileiro. Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris Editor, 2000.

DAVIS, R. A Re-examination of the Doctrine of MacPherson v. Buick and its Application and Extension in the State of New York. Fordham Law Review, 1955.

DAVIS, John F.; REYNOLDS, William J. Juridical Cripples: Plurality Opinions in the Supreme Court, Duke Law Journal, 1974, vol. 59.

DELANEY, Sarah K. Stare decisis v. The 'New Majority': the Michigan Supreme Court's Practice of Overruling Precedent, 1998-2002. Albany Law Review, 2003, vol. 66.

DELGADO, José Augusto. Efeitos da coisa julgada e os princípios constitucionais. Coisa julgada inconstitucional. Rio de Janeiro: América Jurídica, 2002.

DEMOLOMBE, Charles. Cours de Code Napoléon. Paris: Lahure, 1880, vol. I.

DENTI, Vittorio. La Giustizia Civile (1989), 2. ed. Bologna: Il Mulino, 2004.

_____. Un progetto per la giustizia civile. Bologna: Il Mulino, 1982.

_____. Questioni pregiudiziali, Novissimo digesto italiano, vol. 14.

DIAS, Ronaldo Brêtas de Carvalho. Fraude no processo civil. Belo Horizonte: Ed. Del Rey, 2001.

DICIOTTI, Enrico. Interpretazione della legge e discorso razionale. Torino: Giappichelli, 1999.

_____. Verità e Certezza nell' Interpretazione della Legge. Torino: Giappichelli, 1999.

DIDIER JÚNIOR, Fredie. Pressupostos Processuais e Condições da Ação. São Paulo: Saraiva, 2005.

_____. Recurso de Terceiro, 2. ed. São Paulo: Ed. RT, 2005.

_____. Fundamentos do Princípio da Cooperação no Direito Processual Civil Português. Coimbra: Coimbra Editora, 2010.

_____. Curso de Direito Processual Civil (2003), 18. ed. Salvador: JusPodium, 2016, vol. I.

_____. O Direito de Ação como Complexo de Situações Jurídicas. Revista de Processo. São Paulo: Ed. RT, 2012, n. 210.

_____. In: CABRAL, Antonio do Passo; CRAMER, Ronaldo (coords.). Comentários ao Novo Código de Processo Civil. Rio de Janeiro: Forense, 2015.

_____; CUNHA, Leonardo Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil (2006), 13. ed. Salvador: JusPodium, 2016, vol. III.

_____; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Curso de Direito Processual Civil (2007), 10. ed. Salvador: JusPodium, 2015, vol. II.

DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil. 3. Ed. São Paulo: Malheiros, 2003, vol. I.

- _____. Capítulos de sentença. São Paulo: Malheiros, 2014.
- _____. Relativizar a coisa julgada material. Coisa julgada inconstitucional. Rio de Janeiro: América Jurídica, 2002.
- DOMIT, Otávio. Iura Novit Curia e Causa de Pedir – O Juiz e a Qualificação Jurídica dos Fatos no Processo Civil Brasileiro. São Paulo: Ed. RT, 2016.
- DONDI, Angelo; ANSANELLI, Vincenzo; COMOGLIO, Paolo. Processi Civili in Evoluzione – Una Prospettiva Comparata. Milano: Giuffrè, 2015.
- DUXBURY, Neil. The Nature and Authority of Precedent. Cambridge: Cambridge University Press, 2008.
- DWORKIN, Ronald. Taking Rights Seriously. Cambridge (Mass.): Harvard University Press, 1977.
- _____. A Matter of Principle. Cambridge (Mass.): Harvard University Press, 1985
- _____. Law's Empire. Cambridge (Mass.): Harvard University Press, 1986.
- _____. Justice for Hedgehogs. Cambridge (Mass.): Harvard University Press, 2011.
- _____. Law as Interpretation. Texas Law Review, vol. 60.
- EISENBERG, Melvin. The Nature of the Common Law. Cambridge: Harvard University Press, 1991.
- ESSER, Joseph. Richterrecht, Gerichtsgebrauch und Gewohnheitsrecht. In: ESSER, Josef; THIEME, Hans (coords.). Festschrift für Fritz von Hippel zum 70 Geburtstag. Tübingen, Mohr Siebeck, 1967.
- FABRÍCIO, Adroaldo Furtado. A Ação Declaratória Incidental. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1995.
- FARIA, Juliana Cordeiro; THEODORO JÚNIOR, Humberto. A coisa julgada inconstitucional e os instrumentos processuais para o seu controle. Coisa julgada inconstitucional. Rio de Janeiro: América Jurídica, 2002.
- FARIA, Márcio Carvalho. As Funções das Cortes Superiores, os Recursos Excepcionais e a Necessária Revisão dos Parâmetros Interpretativos em Relação à Lealdade Processual (Parte Um). Revista de Processo. São Paulo: Ed. RT, 2015, n. 247.
- _____. As Funções das Cortes Superiores, os Recursos Excepcionais e a Necessária Revisão dos Parâmetros Interpretativos em Relação à Lealdade Processual (Parte Dois). Revista de Processo. São Paulo: Ed. RT, 2015, n. 248.
- FAZZALARI, Elio. Revocazione (dir. proc. civ.). Enciclopedia del Diritto. Milano: Giuffrè, 1989, vol. XL.
- FEDERMAN, Howard. Judicial Overruling. Time for a New General Rule. Michigan Bar Journal, 2004.
- FENET, Pierre-Antoine. Recueil complet des travaux préparatoires du Code civil. Paris: Videcoq, 1836, Tome Cinquième.
- FERNANDES, Luís Eduardo Simardi. Embargos de Declaração. São Paulo: Ed. RT, 2003.
- FERRAND, Frédérique. Cassation Française et Révision Allemande. Paris: PUF, 1993.
- _____. In: GUINCHARD, Serge (coord.), Droit Processuel – Droit Commum et Droit Comparé du

Procès Équitable, 4. ed. Paris: Dalloz, 2007.

_____. La Juridiction Judiciaire Suprême en Droit Comparé: Missions, Filtrage, Intensité du Contrôle. In: DRAGO, Guillaume; FAUVARQUE-COSSON, Bénédicte; GORÉ, Marie (coords.). *L'Accès au Juge de Cassation*. Paris: LGDJ, 2015.

FERRARESE, Maria Rosaria. Dal “verbo” legislativo a chi dice l’“ultima parola”: le Corti Costituzionali e la rete giudiziaria. *Annuario di Diritto Comparato e di Studi Legislativi*. Nápoles: Edizioni Scientifiche Italiane, 2011.

FERREIRA FILHO, Manoel Caetano. *Comentários ao Código de Processo Civil*. São Paulo: Ed. RT, 2000, vol. VII.

FERREIRA NETO, Arthur Maria. *Metaética e a Fundamentação do Direito*. Porto Alegre: Elegancia Juris, 2015.

FERRI, Corrado. *Profili dell’ Appello Limitato*. Padova: Cedam, 1979.

_____; COMOGLIO, Luigi Paolo; TARUFFO, Michele. *Lezioni sul processo civile*. Bologna: Il Mulino, 1995.

FISS, Owen. The political theory of the class action. *Washington and Lee Law Review*, 1996, vol. 53.

FRANCIS, Joseph. Three Cases on Possession – Some Further Observations. *St. Louis Law Review*, 1928, n. 14.

FREEDMAN, Warren. *Res Judicata and Collateral Estoppel*. Westport: Quorum, 1988.

FREIRE, Rodrigo da Cunha Lima. In: WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; DIDIER JÚNIOR, Fredie; TALAMINI, Eduardo; DANTAS, Bruno (coords.). *Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil*. São Paulo: Ed. RT, 2015.

GARCÍA PASCUAL, Cristina; VIDAL GIL, Ernesto. *Creación Judicial del Derecho. Sentido y razón del derecho – enfoques socio-jurídicos para la sociedad democrática*. Madrid: Hacer Editorial, 1992.

GERHARDT, Michael. *The Power of Precedent*. Oxford: Oxford University Press, 2008.

GINSBURG, Tom. *Judicial review in new democracies: constitutional courts in Asian cases*, Cambridge: Cambridge University Press, 2003.

GLOW, Lisa. Offensive Collateral Estoppel in Arizona: Fair Litigation v. Judicial Economy. *Arizona Law Review*, 1988, vol. 30.

GOLDMAN, Brian. Should the Supreme Court stop inviting amici curiae to defend abandoned lower court decisions? *Stanford Law Review*, 2011, vol. 63.

GOLDSCHMIDT, James. *Der Prozess als Rechtslage*. Berlin: Springer, 1925.

GOODHART, Arthur. “Determining the Ratio Decidendi of a Case”, *Essays in Jurisprudence and the Common Law*. Cambridge: Cambridge University Press, 1931.

_____. “Three Cases on Possession”, *The Cambridge Law Journal*, 1928, n. 3.

_____. Precedent in English and Continental Law. *Law Quaterly Review*, vol. 50, 1934.

GORLA, Gino. *Diritto Comparato e Diritto Comune Europeo*. Milano: Giuffrè, 1981.

_____. *L’ Interpretazione del Diritto*. Milano: Giuffrè, 1941.

- GOTTWALD, Peter; SCHWAB, Karl Heinz. *Verfassung und Zivilprozeß*. Bielefeld: Giesecking, 1984.
- _____; ROSENBERG, Leo; SCHWAB, Karl Heinz. *Zivilprozessrecht*, 17. ed. München: C. H. Beck, 2010.
- GRECO, Leonardo. *Eficácia da declaração erga omnes de constitucionalidade ou inconstitucionalidade em relação à coisa julgada anterior. Relativização da coisa julgada*. Salvador: JusPodium, 2008.
- GRIMM, Dieter. *Human rights and judicial review in Germany. Human rights and judicial review*. London: Springer, 1994.
- GUASTINI, Riccardo. *Teoria e Dogmatica delle Fonti*. Milano: Giuffrè, 1998.
- _____. *Teoria del Diritto – Approccio Metodologico*. Modena: Mucchi Editore, 2002.
- _____. *Interpretare e Argomentare*. Milano: Giuffrè, 2011.
- _____. *A interpretação: objetos, conceitos, teorias. Das fontes às normas*. São Paulo: Quartier Latin, 2005.
- _____. *“Trama aberta” – Ciência Jurídica, Interpretação. Das fontes às normas*. São Paulo: Quartier Latin, 2005.
- _____. *Disposizione vs. Norma. Giurisprudenza costituzionale*, 1989.
- _____. *Se i giudici creino diritto. Istituzioni e dinamiche del diritto*. Milano: Giuffrè, 2009.
- HART, Herbert. *The Concept of Law*. Oxford: Clarendon Press, 1993.
- HARTNETT, Edward. *Questioning Certiorari: some reflections seventy-five years after the judges’ bill*. *Columbia Law Review*. vol. 100, n. 7, New York, Nov. 2010.
- HAZARD JR., Geoffrey. *Preclusion as to issues of law: the legal system’s interest*. *Iowa Law Review*, 1984.
- _____; JAMES JR., Fleming; LEUBSDORF, John. *Civil Procedure*. Boston-Toronto-London: Little, Brown and Co., 1992.
- HEINITZ, Ernesto. *I Limiti Oggettivi della Cosa Giudicata*. Padova: Cedam, 1937.
- HERSHKOFF, Helen. *Aggregation of parties, claims, and actions*. In: CHASE, Oscar; HERSHKOFF, Helen (coords.). *Civil litigation in comparative context*. New York: Thomson/West, 2007.
- HOLMES JUNIOR, Oliver Wendell. *The Common Law (1881)*. Cambridge: Harvard University Press, 1963.
- HOCHSCHILD, Adam. *The Modern Problem of Supreme Court Plurality Decision: Interpretation in Historical Perspective*. *Washington University Journal of Law & Policy*, vol. 4.
- IMPAGNATTIELO, Gianpaolo. *La provvisoria esecutorietà delle sentenze costitutive*, *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 1992.
- _____. *La Provvisoria Esecuzione e l’Inibitoria nel Processo Civile*. Milano: Giuffrè, 2010.
- JAMES JR., Fleming; HAZARD JR., Geoffrey; LEUBSDORF, John. *Civil Procedure*. Boston-Toronto-London: Little, Brown and Co., 1992.
- JEULAND, Emmanuel; CADIET, Loïc. *Droit Judiciaire Privé (1992)*, 8. ed. Paris: LexisNexis, 2013.

- JOBIM, Marco Félix. A Técnica do Distinguishing a Partir da Análise do Julgamento do Caso Escola vs. Coca-Cola Bottling Co. Revista de Processo. São Paulo: Ed. RT, 2014, n. 237.
- JOLOWICZ, J. A. The Role of the Supreme Court at the National and International Level. In: YESSIOU-FALTSI, Pelayia (coord.). The Role of the Supreme Courts at the National and International Level – Reports for the Thessaloniki International Colloquium. Thessaloniki: Sakkoulas Publications, 1998.
- JORGE, Flávio Cheim. Apelação Cível. São Paulo: Ed. RT, 1998.
- JORI, Mario; PINTORE, Anna. Manuale di teoria generale del diritto. Torino: Giappichelli, 1995.
- KARLAN, P.; TUSHNET, M.; SUNSTEIN, C.; SEIDMAN, P.; STONE, G. Constitutional law. 5. ed., New York: Aspen, 2005.
- KAUFMANN, Arthur. Rechtsphilosophie (1994), 2. ed. München: C. H. Beck, 1997.
- KELSEN, Hans. Reine Rechtslehre (1. ed., 2. ed., 1960), 2. ed. Wien: Österreich, 2000.
- _____. Jurisdição constitucional. São Paulo: Martins Fontes, 2003.
- KEMMERICH, Clóvis. O Direito Processual da Idade Média. Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris Editor, 2006.
- KERN, Christoph. The Role of the Supreme Court. Revista de Processo. São Paulo: Ed. RT, 2014, n. 228.
- KNIFFIN, Margaret. Overruling Supreme Courts Precedents: Anticipatory Action by United States Courts of Appeals. Fordham Law Review, 1982.
- KNIJNIK, Danilo. O Recurso Especial e a Revisão da Questão de Fato pelo Superior Tribunal de Justiça. Rio de Janeiro: Forense, 2005.
- KORNHAUSER, Lewis; SAGER, Lawrence. The One and the Many: Adjudication in Collegial Courts. California Law Review, 1993, vol. 81.
- _____; _____. The many as one: integrity and group choice in paradoxical cases, Philosophy & Public Affairs, 2004, vol. 32.
- KOZIKOSKI, Sandro Marcelo. Embargos de Declaração – Teoria Geral e Efeitos Infringentes. São Paulo: Ed. RT, 2004.
- KRIELE, Martin. Theorie der Rechtsgewinnung entwickelt am Problem der Verfassungsinterpretation. Berlin: Duncker & Humblot, 1967.
- KRISLOV, Samuel. The amicus curiae brief. From friendship to advocacy. Yale Law Journal, 72, 1963.
- LACERDA, Galeno. Comentários ao Código de Processo Civil. 7. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1998, vol. VIII, t. I.
- LANES, Júlio. Fato e Direito no Processo Civil Cooperativo. São Paulo: Ed. RT, 2014.
- _____. In: WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; DIDIER JÚNIOR, Fredie; TALAMINI, Eduardo; DANTAS, Bruno (coords.). Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil. São Paulo: Ed. RT, 2015.
- LEAL, Victor Nunes. Passado e Futuro da Súmula do STF. Revista de Direito Administrativo. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 1981, n. 145.

- LEDERMAN, Howard Yale. "Judicial overruling" Michigan Bar Journal. 2004, vol. 83.
- LEONEL, Ricardo de Barros. In: BUENO, Cássio Scarpinella (Coord.). Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Saraiva, 2017, vol. IV.
- LEUBSDORF, John; JAMES JR., Fleming; HAZARD JR., Geoffrey. Civil Procedure. Boston-Toronto-London: Little, Brown and Co., 1992.
- LIEBMAN, Enrico Tullio. Parte o 'capo' di sentenza. Rivista di diritto processuale. Padova: Cedam, 1964.
- _____. Limites objetivos da coisa julgada. Estudos sobre o Processo Civil Brasileiro. São Paulo: Saraiva, 1947.
- _____. Manual de Direito Processual Civil. Tradução de Cândido Rangel Dinamarco. Rio de Janeiro: Forense, 1984, vol. I.
- LOWMAN, Michael. The litigating amicus curiae: when does the party begin after the friends leave? The American University Law Review, 41, 1992.
- LUCERTINI, Elena. La Riforma dell' Appello Civile in Germania: il Declino del Giudizio "de Novo". Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile. Milano: Giuffrè, 2006.
- LUCON, Paulo. Eficácia das Decisões e Execução Provisória. São Paulo: Ed. RT, 2000.
- MACCORMICK, Neil. Legal Reasoning and Legal Theory (1978). Oxford: Oxford University Press, 2003.
- _____. "Why Cases Have Rationes and What These Are", Precedent in Law. Oxford: Oxford University Press, 1987.
- _____. The ethics of legalism. Ratio Juris, 1989, 2.
- _____. Rhetoric and the Rule of Law. Oxford: Oxford University Press, 2005.
- _____; SUMMERS, Robert. Interpreting Precedents – A Comparative Study. Aldershot: Ashgate Dartmouth, 1997.
- MACÊDO, Lucas Buril de. Precedentes Judiciais e o Direito Processual Civil. Salvador: JusPodium, 2015.
- MACEDO JÚNIOR, Ronaldo Porto. Do Xadrez à Cortesia – Dworkin e a Teoria do Direito Contemporânea. São Paulo: Saraiva, 2013.
- MACHADO, Fábio Cardoso. Por que Realmente os Precedentes Importam? In: MACEDO, Elaine; HIDALGO, Daniela (coords.). Jurisdição, Direito Material e Processo – Os Pilares da Obra Ovidiana e seus Reflexos na Aplicação do Direito. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2015.
- MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Recurso Extraordinário e Recurso Especial. 6. ed. São Paulo: Ed. RT, 1999.
- MANDRIOLI, Crisanto. L'azione esecutiva, Milano: Giuffrè, 1955.
- MARANHÃO, Juliano. Positivismo Jurídico Lógico-Inclusivo. São Paulo: Marcial Pons, 2012.
- MARINONI, Luiz Guilherme. Tutela Antecipatória, Julgamento Antecipado e Execução Imediata da Sentença. São Paulo: Ed. RT, 1997.
- _____. Técnica Processual e Tutela dos Direitos. 5. ed. São Paulo: Ed. RT, 2012.

- _____. Antecipação da Tutela. 12. ed. São Paulo: Ed. RT, 2012.
- _____. Precedentes Obrigatórios (2010), 4. ed. São Paulo: Ed. RT, 2016.
- _____. O STJ enquanto Corte de Precedentes (2013), 2. ed. São Paulo: Ed. RT, 2014.
- _____. A Ética dos Precedentes. São Paulo: Ed. RT, 2014.
- _____. Julgamento nas Cortes Supremas. São Paulo: Ed. RT, 2015.
- _____. A Intangibilidade da Coisa Julgada diante da Decisão de Inconstitucionalidade (2008), 4. ed. São Paulo: Ed. RT, 2016.
- _____. Abuso de Defesa e Parte Incontroversa da Demanda. 2. ed. São Paulo: Ed. RT, 2007.
- _____. O “problema” do incidente de resolução de demandas repetitivas e dos recursos extraordinário e especial repetitivos. Revista de Processo. São Paulo: Ed. RT, 2015, vol. 249.
- _____; MITIDIERO, Daniel. Código de Processo Civil Comentado. 5. ed. São Paulo: Ed. RT, 2013.
- _____. Repercussão Geral no Recurso Extraordinário. 3. ed. São Paulo: Ed. RT, 2012.
- _____; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo Curso de Processo Civil. São Paulo: Ed. RT, 2015, vol. I.
- _____. Novo Curso de Processo Civil. São Paulo: Ed. RT, 2015, vol. II.
- _____. Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Ed. RT, 2015.
- _____; MITIDIERO, Daniel; SARLET, Ingo. Curso de Direito Constitucional (2012), 5. ed. São Paulo: Ed. RT, 2016.
- MARKMAN, Stephen. Precedent: Tension between Continuity in the Law and the Perpetuation of Wrong Decisions. Texas Review of Law and Politics, 2004.
- MARTINS-COSTA, Judith. A Boa-Fé no Direito Privado. São Paulo: Ed. RT, 2000.
- MATTOS, Sérgio. Devido Processo Legal e Proteção de Direitos. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2009.
- MEDEIROS, Rui. A decisão de inconstitucionalidade. Lisboa: Universidade Católica Ed., 1999.
- MEDINA, José Miguel Garcia. O Prequestionamento nos Recursos Extraordinário e Especial, 2. ed., São Paulo: Ed. RT, 1999.
- MELLO, Cláudio. Verdade Moral e Método Jurídico na Teoria Constitucional de Ronald Dworkin. In: LISBOA, Wladimir; STORCK, Alfredo (coords.). Normatividade & Argumentação – Ensaio de Filosofia Política e do Direito. Porto Alegre: Linus Editores, 2013.
- MELLO, Patrícia Perrone Campos. Precedentes. Rio de Janeiro: Renovar, 2008.
- MEKKI, Soraya Amrani; CADIET, Loïc; NORMAND, Jacques. Théorie Générale du Procès. Paris: PUF, 2010.
- MENCHINI, Sergio. I limiti oggettivi del giudicato civile. Milano: Giuffrè, 1987.
- MENDES, Leonardo Castanho. O Recurso Especial. São Paulo: Ed. RT, 2006.
- MENDONÇA JÚNIOR, Delosmar Domingos de. Agravo Interno. São Paulo: Ed. RT, 2009.
- MENESTRINA, Francesco. La Pregiudiciale nel Processo Civile. Milano: Giuffrè, 1963.

- MERKL, Adolf. “Sul Problema dell’ Interpretazione” (1916), *Il Duplice Volto del Diritto – Il Sistema Kelseniano e altri Saggi*. Tradução de Carmelo Geraci. Milano: Giuffrè, 1987.
- MERRYMAN, John Henry. *The Civil Law Tradition: an Introduction to the Legal Systems of Europe and Latin America*. Standford: Standford University Press, 2007.
- MESSUTI, G. Silenzio della parte e dolo revocatorio. *Rivista di diritto processuale*. Padova: Cedam, 1984.
- MICHELMAN, Frank. Justification (and justifiability) of law in a contradictory world. *Nomos XXVIII: Justification*. New York: New York University Press, 1986, vol. 71.
- MICHELON JÚNIOR, Cláudio. Aceitação e Objetividade – Uma Comparação entre as teses de Hart e do Positivismo Jurídico Precedente sobre a Linguagem e o Conhecimento do Direito. São Paulo: Ed. RT, 2004.
- _____. Princípios e Coerência na Argumentação Jurídica. In: MACEDO JÚNIOR, Ronaldo Porto; BARBIERI, Catarina Helena Cortada (coords.). *Direito e Interpretação – Racionalidades e Instituições*. São Paulo: Saraiva, 2011.
- MILLAR, Robert Wyness. The historical relation of estoppel by record to res judicata. *Illinois Law Review*, 1940-1941.
- MITIDIERO, Daniel. *Colaboração no Processo Civil – Pressupostos Sociais, Lógicos e Éticos* (2009), 3. ed. São Paulo: Ed. RT, 2015.
- _____. Cortes Superiores e Cortes Supremas – do Controle à Interpretação, da Jurisprudência ao Precedente (2013), 2. ed. São Paulo: Ed. RT, 2014.
- _____. Antecipação da Tutela – da Tutela Cautelar à Técnica Antecipatória (2012), 2. ed. São Paulo: Ed. RT, 2014.
- _____. Precedentes – da Persuasão à Vinculação. São Paulo: Ed. RT, 2016.
- _____. O Processualismo e a Formação do Código Buzaid. *Revista de Processo*. São Paulo: Ed. RT, 2010, n. 183.
- _____. Fundamentação e Precedente – Dois Discursos a Partir da Decisão Judicial. *Revista de Processo*. São Paulo: Ed. RT, 2012, n. 206.
- _____. Por uma Reforma da Justiça Civil no Brasil: um Diálogo entre Mauro Cappelletti, Vittorio Denti, Ovídio Baptista e Luiz Guilherme Marinoni. *Revista de Processo*. São Paulo: Ed. RT, 2011, n. 199.
- _____. A Tutela dos Direitos como Fim do Processo Civil no Estado Constitucional. *Revista de Processo*. São Paulo: Ed. RT, 2014, n. 229.
- _____; ALVARO DE OLIVEIRA, Carlos Alberto. *Curso de Processo Civil*. São Paulo: Atlas, 2012, vol. II.
- _____; MARINONI, Luiz Guilherme. *Código de Processo Civil Comentado*. 5. ed. São Paulo: Ed. RT, 2013.
- _____. *Repercussão Geral no Recurso Extraordinário*. 3. ed. São Paulo: Ed. RT, 2012.
- _____; MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz. *Novo Curso de Processo Civil*. São Paulo: Ed. RT, 2015, vol. I.
- _____. *Novo Curso de Processo Civil*. São Paulo: Ed. RT, 2015, vol. II.

- _____. Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Ed. RT, 2015.
- _____; MARINONI, Luiz Guilherme; SARLET, Ingo. Curso de Direito Constitucional (2012), 5. ed. São Paulo: Ed. RT, 2016.
- MONTESANO, Luigi. Norma e formula legislativa nel giudizio costituzionale. Rivista di Diritto Processuale. Padova: Cedam, 1958.
- MONTROSE, J. L. Ratio decidendi and the House of Lords. The Modern Law Review. 1957, vol. 20.
- _____. The ratio decidendi of a case. The Modern Law Review. 1957, vol. 20.
- MORATO, Leonardo. Reclamação e sua Aplicação para o Respeito da Súmula Vinculante. São Paulo: Ed. RT, 2007.
- MORTARA, Lodovico. Commentario del Codice e delle leggi di procedura civile, Milano: Vallardi, 1923.
- _____. Manuale della procedura civile, Torino: Torinese, 1921.
- MÜLLER, Julio Guilherme. O Papel Fundamental do Superior Tribunal de Justiça no Contexto do Estado Democrático de Direito: Reflexões a Partir do Interesse Público de Uniformização da Interpretação da Legislação Infraconstitucional. Revista de Processo. São Paulo: Ed. RT, 2014, n. 238.
- MÜßIG, Ulrike. El Juez Legal – Una Comparación Histórica, desde el Derecho Canónico hasta la Convención Europea de los Derechos Humanos, con Especial Énfasis en el Desarrollo del Derecho en Alemania, Inglaterra y Francia (2003). Tradução de Anne Cullmann, Ignacio Czeguhn e Antonio Sánchez Aranda. Madrid: Dykinson, 2014.
- NELSON, Caleb. Stare Decisis and Demonstrably Erroneous Precedents. Virginia Law Review, 2001, n. 87.
- NERY JÚNIOR, Nelson. Teoria Geral dos Recursos. 7. ed. São Paulo: Ed. RT, 2014.
- _____; NERY, Rosa Maria Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Ed. RT, 2015.
- NERY, Rosa Maria Andrade; NERY JÚNIOR, Nelson. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Ed. RT, 2015.
- NEVES, Antonio Castanheira. O Instituto dos “Assentos” e a Função Jurídica dos Supremos Tribunais. Coimbra: Coimbra Editora, 1983.
- NICOLETTI, Carlos Alberto. La revocazione della sentenza. Milano: Giuffrè, 1988.
- NONKES, Steven. Reducing the unfair effects of non-mutual issue preclusion through damages limits. Cornell Law Review, 2009, vol. 94.
- NORMAND, Jacques; CADIET, Loïc; MEKKI, Soraya Amrani. Théorie Générale du Procès. Paris: PUF, 2010.
- NORONHA, Carlos Silveira. Do Recurso Adesivo. 2. ed., Rio de Janeiro: Forense, 1987.
- _____. Do Agravo de Instrumento. 3. ed., Rio de Janeiro: Forense, 1995.
- NOVAK, Linda. The precedential value of Supreme Court plurality decisions. Columbia Law

Review, 1980.

NUNES, Dierle; BAHIA, Alexandre; PEDRON, Flávio; THEODORO JÚNIOR, Humberto. Novo CPC – Fundamentos e Sistematização. Rio de Janeiro: Forense, 2015.

OLIVEIRA, Gleydson Kleber Lopes de. Apelação no Direito Processual Civil. São Paulo: Ed. RT, 2009.

_____. Recurso Especial. São Paulo: Ed. RT, 2002.

OLIVEIRA, Pedro Miranda de. Agravo Interno e Agravo Regimental. São Paulo: Ed. RT, 2014.

OLIVEIRA, Rafael Alexandria de; DIDIER JÚNIOR, Fredie; BRAGA, Paula Sarno. Curso de Direito Processual Civil (2007), 10. ed. Salvador: JusPodivm, 2015, vol. II.

ORESTANO, Riccardo. L' Appello Civile in Diritto Romano, 2. ed. Torino: Giappichelli, 1953.

OTEIZA, Eduardo. La Función de las Cortes Supremas en la América Latina – Historia, Paradigmas, Modelos, Contradicciones y Perspectivas. In: OTEIZA, Eduardo (coord.). Reforma Procesal Civil. Buenos Aires: Rubinzal – Culzoni Editores, 2010.

PACHECO, José da Silva. A 'Reclamação' no STJ e no STF de acordo com a Nova Constituição. Revista dos Tribunais. São Paulo: Ed. RT, 1989, vol. 646.

PANTOJA, Fernanda. Apelação Cível: Novas Perspectivas de um Antigo Recurso – Um Estudo Crítico de Direito Nacional e Comparado. Curitiba: Juruá, 2010.

PARDO, Michael; ALLEN, Ronald. The myth of the law-fact distinction. Northwestern University Law Review, 2003.

PATTI, Salvatore. Prove-Disposizioni generali, Commentario del Codice Civile, Bologna/Roma: Zanichelli/Foro Italiano, 1987.

PECZENIK, Aleksander. The Binding Force of Precedent. In: MACCORMICK, Neil; SUMMERS, Robert (coords.). Interpreting Precedents – A Comparative Study. Aldershot: Ashgate Dartmouth, 1997.

_____. On Law and Reason (1989). 2. ed. Dordrecht: Springer, 2009.

PEDRO, Flávio; BAHIA, Alexandre; NUNES, Dierle; THEODORO JÚNIOR, Humberto. Novo CPC – Fundamentos e Sistematização. Rio de Janeiro: Forense, 2015.

PEÑA, Eduardo Chemale Selistre. O Recurso de Agravo. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2008.

PEREA, Ashley. Broad discretion: a choice in applying offensive non-mutual collateral estoppel. Arizona State Law Journal, 2008, vol. 40.

PEREIRA, Paula Pessoa. Legitimidade dos Precedentes – Universabilidade das Decisões do STJ. São Paulo: Ed. RT, 2014.

PERELMAN, Chaïm. Lógica jurídica: nova retórica, São Paulo: Martins Fontes, 2000.

PEREZ, Marcela Melo. In: CABRAL, Antonio do Passo; CRAEMER, Ronaldo (coords.). Comentários ao Novo Código de Processo Civil. Rio de Janeiro: Forense, 2015.

PICARDI, Nicola. La Vocazione del Nostro Tempo per la Giurisdizione. Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile. Milano: Giuffrè, 2004.

PINO, Giorgio. Diritti e Interpretazione – Il Ragionamento Giuridico nello Stato Costituzionale.

Bologna: Il Mulino, 2010.

PINTORE, Anna; JORI, Mario. Manuale di teoria generale del diritto. Torino: Giappichelli, 1995.

PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Comentários ao Código de Processo Civil (1975), 3. ed., atualizada por Sérgio Bermudes. Rio de Janeiro: Forense, 1999, t. VII.

_____. Tratado da ação rescisória. 5. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1976.

PORTES, Maira. “Instrumentos para Revogação de Precedentes no Sistema de Common Law”, MARINONI, Luiz Guilherme (coord.), A Força dos Precedentes – Estudos dos Cursos de Mestrado e Doutorado em Direito Processual Civil da UFPR. Salvador: JusPodivm, 2010.

PORTO, Sérgio. Ação Rescisória Atípica. São Paulo: Ed. RT, 2009.

_____; USTÁRROZ, Daniel. Manual dos Recursos Cíveis. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2007.

POSTEMA, Gerald. Legal Philosophy in the Twentieth Century: the Common Law World. Dordrecht: Springer, 2011.

POZZA, Pedro. Sentença Parcial de Mérito. Curitiba: Juruá, 2015.

PROTO PISANI, Andrea. Lezioni di Diritto Processuale Civile. 4. ed. Napoli: Jovene Editore, 2002.

PUGLIESE, Giovanni. Giudicato. Enciclopedia del Diritto. Milano: Giuffrè, 1969, vol. XVIII.

QUEIROZ, Cristina. Direitos fundamentais (teoria geral). Coimbra: Coimbra Ed., 2002.

RAMOS, Elival da Silva. Controle de constitucionalidade no Brasil: perspectivas de evolução. São Paulo: Saraiva, 2010.

RAPISARDA, Cristina. Profili della tutela civile inibitoria. Padova: Cedam, 1987.

RASSELLI, Alessandro. Sentenze determinative e classificazione delle sentenze. Scritti giuridici in onore di Francesco Carnelutti. Padova: Cedam, 1950, vol. 2.

REALE, Miguel. Lições Preliminares de Direito (1973), 27. ed. São Paulo: Saraiva, 2014.

RÊGO, Bruno de Moraes. Ação rescisória e a retroatividade das decisões de controle de constitucionalidade das leis no Brasil. Porto Alegre: Fabris, 2001.

REYNOLDS, William J.; DAVIS, John F. Juridical Cripples: Plurality Opinions in the Supreme Court. Duke Law Journal, 1974, vol. 59.

RICHARDSON, Eli. Taking issue with preclusion: reinventing Collateral Estoppel. Mississippi Law Journal, 1995, vol. 65.

RIMMELSPACHER, Bruno. Materiellrechtlicher Anspruch und Streitgegenstandsprobleme im Zivilprozess. München: Beck, 1970.

RIZZI, Sergio. Ação rescisória. São Paulo: Ed. RT, 1979.

ROSENBERG, Leo; SCHWAB, Karl Heinz; GOTTWALD, Peter. Zivilprozessrecht, 17. ed. München: C. H. Beck, 2010.

ROSITO, Francisco. Teoria dos Precedentes Judiciais. Curitiba: Juruá, 2012.

RUDER, David. The development of legal doctrine through amicus participation: the SEC experience. Wisconsin Law Review, 1989.

- RUTANO, Leandro. Ação Rescisória por violação à norma jurídica. Dissertação de mestrado. Universidade Federal do Paraná (UFPR), 2016.
- SACCO, Rodolfo. Interpretazione del diritto. Dato oggettivo e spirito dell'interprete. Diritto, giustizia e interpretazione. Roma/Bari: Laterza, 1998.
- SAGER, Lawrence; KORNHAUSER, Lewis. The One and the Many: Adjudication in Collegial Courts. California Law Review, 1993, vol. 81.
- ____; _____. The many as one: integrity and group choice in paradoxical cases. Philosophy & Public Affairs, 2004, vol. 32.
- SALLES, Carlos Alberto. Precedentes e Jurisprudência no Novo CPC: Novas Técnicas Decisórias? O Novo Código de Processo Civil – Questões Controvertidas. São Paulo: Atlas, 2015.
- SANSEVERINO, Paulo de Tarso. Princípio da Reparação Integral. São Paulo: Saraiva, 2010.
- SARAIVA, José. O Recurso Especial e o STJ. São Paulo: Saraiva, 2002.
- SARLET, Ingo. Valor de Alçada e Limitação ao Acesso ao Duplo Grau de Jurisdição: Problematização em Nível Constitucional à Luz de um Conceito Material de Direitos Fundamentais. Revista da Ajuris. Porto Alegre, 1996, n. 66.
- ____; MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Curso de Direito Constitucional (2012), 5. ed. São Paulo: Ed. RT, 2016.
- SAVIGNY, Karl Friedrich von. System des heutigen römischen Rechts. Berlin: Veit und Comp., 1840, t. I.
- SCARSELLI, Giuliano. La condanna con riserva, Milano: Giuffrè, 1989.
- SCHAUER, Frederick. Thinking like a Lawyer. Cambridge (Mass.): Harvard University Press, 2009.
- ____. Precedent. Stanford Law Review, 1987, vol. 39, n. 3.
- SCHWAB, Karl Heinz; GOTTWALD, Peter. Verfassung und Zivilprozeß. Bielefeld: Giesecking, 1984.
- ____; ROSENBERG, Leo; GOTTWALD, Peter. Zivilprozessrecht, 17. ed. München: C. H. Beck, 2010.
- SCOFIELD, Robert. Goodhart's Concession: Defending Ratio Decidendi from Logical Positivism and Legal Realism in the First Half of the Twentieth Century. King's College Law Journal, 2005, vol. 16.
- SCOTT, Austin. Collateral estoppel by judgment. Harvard Law Review, 1942.
- SEGAL, Joshua. Rebalancing fairness and efficiency: The offensive use of collateral estoppel in § 1983 actions. Boston University Law Review, 2009, vol. 89.
- SEIDMAN, P.; TUSHNET, M.; SUNSTEIN, C.; KARLAN, P.; STONE, G. Constitutional law. 5. ed., New York: Aspen, 2005.
- SHANNON, Bradley Scott. The Retroactive and Prospective Application of Judicial Decisions. Harvard Journal of Law & Public Policy. Cambridge, 2003, vol. 26.
- SHAPIRO, David. Some thoughts on intervention before Courts. Agencies, and arbitrators. Harvard Law Review, 81, 1968.

SHAPIRO, M. Stability and change in judicial decision-making: incrementalism or stare decisis? Law and the behavioral sciences. Indianapolis-Kansas-Nova Iorque: Ed. L. M. Friedman & S. Macaulay, 1977.

SILVA, Paula Costa e. Acto e Processo. Coimbra: Coimbra Editora, 2003.

SILVESTRI, Elisabeta. L'amicus curiae: uno strumento per la tutela degli interessi non rappresentati. Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile. Milano: Giuffrè, 1997.

SILVESTRI, Gaetano. Le Corti Supreme negli ordinamenti costituzionali contemporanei. Le Corti Supreme. Milano: Giuffrè, 2001.

SIMPSON, A. W. B. The ratio decidendi of a case. The Modern Law Review, 1957, vol. 20.

_____. The ratio decidendi of a case. The Modern Law Review, 1958, vol. 21.

SOUSA, Miguel Teixeira de. Sobre o Sentido e a Função dos Pressupostos Processuais. Revista de Processo. São Paulo: Ed. RT, 1991, n. 63.

SOUZA, André Pagani. Vedação das Decisões-Surpresa no Processo Civil. São Paulo: Saraiva, 2014.

SOUZA JÚNIOR, Sidney Pereira de. Sentenças Parciais no Processo Civil – Consequências no Âmbito Recursal. São Paulo: Método, 2009.

STONE, G.; TUSHNET, M.; SUNSTEIN, C.; KARLAN, P.; SEIDMAN, P. Constitutional law. 5. Ed., New York: Aspen, 2005.

STONE, Julius. The Ratio of the Ratio Decidendi. The Modern Law Review, 1959, vol. 22.

SUMMERS, Robert; ATIYAH, P. S. Form and Substance in Anglo-American Law. Oxford: Oxford University Press, 1987.

_____; MACCORMICK, Neil. Interpreting Precedents – A Comparative Study. Aldershot: Ashgate Dartmouth, 1997.

SUNSTEIN, C.; TUSHNET, M.; KARLAN, P.; SEIDMAN, P.; STONE, G. Constitutional law. 5. ed, New York: Aspen, 2005.

TALAMINI, Eduardo; WLADECK, Felipe. In: BUENO, Cássio Scarpinella (Coord.). Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Saraiva, 2018, vol. IV.

TARELLO, Giovanni. Il Realismo Giuridico Americano. Milano: Giuffrè, 1962.

_____. L' Interpretazione della Legge. Milano: Giuffrè, 1980.

TARUFFO, Michele. La Motivazione della Sentenza Civile. Padova: Cedam, 1975.

_____. Il Vertice Ambiguo – Saggi sulla Cassazione Civile. Bologna: Il Mulino, 1991.

_____. Precedente e Giurisprudenza. Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile. Milano: Giuffrè, 2007.

_____. Le Funzioni delle Corti Supreme. Cenni Generali. Annuario di Diritto Comparato e di Studi Legislativi. Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane, 2011.

_____. “Idee per una Teoria della Giusta Decisione”, Sui Confini – Scritti sulla Giustizia Civile. Bologna: Il Mulino, 2002.

_____. “Collateral estoppel” e giudicato sulle questioni. Rivista di Diritto Processuale. Padova:

Cedam, 1972.

____; COMOGLIO, Luigi Paolo; FERRI, Corrado. Lezioni sul processo civile. Bologna: Il Mulino, 1995.

____; CARPI, Federico; COLESANTI, Vittorio. Commentario breve al Codice di Procedura Civile. Padova: Cedam, 1988.

TARZIA, Giuseppe. Il Progetto Vassalli per il Processo Civile. Rivista di Diritto Processuale. Padova: Cedam, 1989.

____. I Provvedimenti Urgenti sul Processo Civile Approvati dal Senato. Rivista di Diritto Processuale. Padova: Cedam, 1990.

____. Lineamenti del nuovo processo di cognizione. Milano: Giuffrè, 1991.

TELES, Miguel Galvão. Inconstitucionalidade pretérita. Nos dez anos da Constituição. Lisboa: Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 1987.

THEODORO JÚNIOR, Humberto; FARIA, Juliana Cordeiro. A coisa julgada inconstitucional e os instrumentos processuais para o seu controle. Coisa julgada inconstitucional. Rio de Janeiro, América Jurídica, 2002.

THEODORO JÚNIOR, Humberto; BAHIA, Alexandre; NUNES, Dierle; PEDRON, Flávio. Novo CPC – Fundamentos e Sistematização. Rio de Janeiro: Forense, 2015.

THURMON, Mark Alan. When the Court Divides: Reconsidering the Precedential Value of Supreme Court Plurality Decisions. Duke Law Journal, 1992, vol. 42.

TOMMASINI, Raffaele. “Invalidità: b) Diritto Privato”. Enciclopedia del Diritto. Milano: Giuffrè, 1972, vol. XXII.

TRAYNOR, Roger. Quo Vadis, Prospective Overruling: a Question of Judicial Responsibility. Hastings Law Journal, 1999, vol. 50.

TREANOR, William Michael. Prospective Overruling and the Revival of Unconstitutional Statutes. Columbia Law Review, New York, 1993, vol. 93.

TROCKER, Nicolò. Processo Civile e Costituzione. Milano: Giuffrè, 1974.

TUNC, André. La Cour Suprême Idéale. In: BELLET, Pierre; TUNC, André (coords.). La Cour Judiciaire Suprême – Une Enquête Comparative. Paris: Economica, 1978.

TUSHNET, M.; SUNSTEIN, C.; KARLAN, P.; SEIDMAN, P.; STONE, G. Constitutional law, 5. ed., New York: Aspen, 2005.

USTÁRROZ, Daniel; PORTO, Sérgio. Manual dos Recursos Cíveis. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2007.

UZELAC, Alan; VAN RHEE, C. H. Appeals and other Means of Recourse against Judgments in the Context of the Effective Protection of Civil Rights and Obligations. In: UZELAC, Alan; VAN RHEE, C. H. (coords.). Nobody’s Perfect – Comparative Essays on Appeals and other Means of Recourse against Judicial Decisions Matters. Cambridge: Intersentia, 2014.

VAN RHEE, C. H.; UZELAC, Alan. Appeals and other Means of Recourse against Judgments in the Context of the Effective Protection of Civil Rights and Obligations. In: UZELAC, Alan; VAN RHEE, C. H. (coords.). Nobody’s Perfect – Comparative Essays on Appeals and other Means of Recourse against Judicial Decisions Matters. Cambridge: Intersentia, 2014.

VANBERG, Georg. The politics of constitutional review in Germany. Cambridge: Cambridge

University Press, 2005.

VASCONCELLOS, Rita de Cássia Corrêa de. *Princípio da Fungibilidade – Hipóteses de Incidência no Processo Civil Brasileiro Contemporâneo*. São Paulo: Ed. RT, 2007.

VELLUZZI, Vito. “Sulla Nozione di ‘Interpretazione Giuridica Corretta’”, *Tra Teoria e Dogmatica – Sei Studi intorno all’ Interpretazione*. Pisa: Edizioni ETS, 2012.

VERDE, Giuseppe. *Prova*. *Enciclopedia del diritto*. Milano: Giuffrè, 1988, vol. XXXVII.

VERGOTTINI, Giuseppe de. *Diritto costituzionale*. Padova: Cedam, 2010.

VESPAZIANI, Alberto. *Interpretazioni del bilanciamento dei diritti fondamentali*. Padova: Cedam, 2002.

VIDAL GIL, Ernesto; GARCÍA PASCUAL, Cristina. *Creación Judicial del Derecho. Sentido y razón del derecho – enfoques socio-jurídicos para la sociedad democrática*. Madrid: Hacer Editorial, 1992.

VILLA, Vittorio. *Il Positivismo Giuridico: Metodi, Teorie e Giudizi di Valore*. Torino: Giappichelli, 2004.

_____. *Una Teoria Pragmaticamente Orientata dell’ Interpretazione Giuridica*. Torino: Giappichelli, 2012.

VILLATA, Stefano. *Impugnazioni di delibere assembleari e cosa giudicata*. Milano: Giuffrè, 2006.

VIOLA, Francesco; ZACCARIA, Giuseppe. *Diritto e interpretazione: Lineamenti di teoria ermeneutica del diritto*. Roma: Laterza, 1999.

VOLPINI, Diego. *L’oggetto del giudicato nell’esperienza americana*. Padova: Cedam, 2007.

WAMBAUGH, Eugene. *The Study of Cases (1892)*, 2. ed. Boston: Little, Brown & Co., 1894.

WASSERMANN, Rudolf. *Der soziale Zivilprozess*. Neuwied-Darmstadt: Luchterhand, 1978.

WEBER, Max. *A ética protestante e o “espírito” do capitalismo* (edição de Antônio Flávio Pierucci). São Paulo: Companhia das Letras, 2004.

WIEACKER, Franz. *Privatrechtsgeschichte der Neuzeit unter besonderer Berücksichtigung der deutschen Entwicklung (1967)*. 2. ed. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1996.

WRÓBLEWSKI, Jerzy. *The Judicial Application of Law*. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 1992.

_____. *Constitución y teoría general de la interpretación jurídica*. Madrid: Civitas, 2001.

_____. *Sentido y hecho en el derecho*. México: Fontamara, 2008.

_____. *Functions of law and legal certainty*. *Anuario de Filosofía del Derecho*. 1973-1974, XVII.

_____. *Transparency and doubt. Understanding and interpretation in pragmatics and in Law*. *Law and Philosophy*, 1988.

_____. *Legal syllogism and rationality of judicial decision*. *Rechtstheorie*. Berlin: Duncker & Humblot, 1974, vol. 5.

YARSHELL, Flávio. *Ação rescisória – juízos rescindente e rescisório*. São Paulo: Malheiros, 2005.

ZACCARIA, Giuseppe. *La Giurisprudenza come Fonte di Diritto – Un’Evoluzione Storica e Teorica*. Napoli: Editoriale Scientifica, 2007.

- _____. *Complessità della ragione giuridica. Questioni di interpretazione*. Padova: Cedam, 1996.
- _____; VIOLA, Francesco. *Diritto e interpretazione: Lineamenti di teoria ermeneutica del diritto*. Roma: Laterza, 1999.
- ZANETI JÚNIOR, Hermes. *A Constitucionalização do Processo*. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2014.
- _____. *O Valor Vinculante dos Precedentes*. Salvador: JusPodivm, 2014.
- _____. *O Valor Vinculante dos Precedentes*. 3. ed. Salvador: JusPodium, 2017.
- _____. In: CABRAL, Antonio do Passo; CRAMER, Ronaldo (coords.). *Comentários ao Novo Código de Processo Civil*. Rio de Janeiro: Forense, 2015.
- ZIPPELIUS, Reinhold. *Rechtsphilosophie* (1982), 6. ed. München: C. H. Beck, 2011.
- ZUFELATO, Camilo. *Precedentes Judiciais Vinculantes à Brasileira no Novo CPC: Aspectos Gerais. O Novo Código de Processo Civil – Questões Controvertidas*. São Paulo: Atlas, 2015.

© desta edição [2018]

Índice Alfabético-remissivo

Ação anulatória

–conceito, **art. 966, 2**

–hipóteses, **art. 966, 14**

Ação rescisória

–capítulo da decisão e rescindibilidade, **art. 966, 5**

–competência e deslocamento de competência, **art. 968, 8**

–conceito, **art. 966, 1**

–cumulação de ações rescisórias, **art. 968, 3**

–decisões rescindíveis, **art. 966, 3**

–decisão sobre a questão prejudicial e rescindibilidade, **art. 966, 4**

–depósito prévio, **art. 968, 5 e 6**

–dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida, **art. 966, 8**

–erro de fato, **art. 966, 13**

–falsidade da prova, **art. 966, 11**

–hipóteses, **art. 966, 6 a 13**

–indeferimento da petição inicial, **art. 968, 2**

–instrução, **art. 972, 1.**

–juiz impedido ou absolutamente incompetente, **art. 966, 7**

–julgamento, **art. 971, 1 e 2; art. 973, 3; art. 974, 1 a 6**

–julgamento liminar, **art. 968, 7**

–legitimidade, **art. 967, 1 a 6**

–ofensa à coisa julgada, **art. 966, 9**

–pedido rescindente e pedido rescisório, **art. 968, 4**

–petição inicial, **art. 968, 1**

- prazo, **art. 975**, 1 a 5
- prevaricação, concussão ou corrupção do juiz, **art. 966**, 6
- procedimento, **art. 970**, 1 a 4; **art. 973**, 1 e 2
- prova nova, **art. 966**, 12
- simulação ou colusão entre as partes, **art. 966**, 8
- trânsito em julgado, **art. 975**, 2
- tutela provisória, **art. 969**, 1 a 4
- violação manifesta de norma jurídica, **art. 966**, 10

Aceitação da decisão

- conceito, **art. 1.000**, 1
- depósito do valor da condenação e multa, **art. 1.000**, 3
- expressa ou tácita, **art. 1.000**, 2
- litisconsórcio, **art. 1.000**, 4

Agravo de instrumento

- cabimento, **art. 1.015**, 2 a 5
- comunicação ao juízo de primeiro grau, **art. 1.018**, 1 e 2
- conceito, **art. 1.015**, 1
- decisão monocrática, **art. 1.019**, 1 a 6
- forma, **art. 1.016**, 1
- instrumento, **art. 1.017**, 1
- interposição, **art. 1.017**, 6
- julgamento, **art. 1.020**, 1
- mandado de segurança como sucedâneo de agravo de instrumento, **art. 1.015**, 6
- peças, **art. 1.017**, 2 a 3
- preparo, **art. 1.017**, 5
- processo eletrônico, **art. 1.017**, 7

Agravo em recurso especial e em recurso extraordinário

- cabimento, **art. 1.042**, 1
- contrarrazões, **art. 1.042**, 4
- interposição conjunta, **art. 1.042**, 6
- julgamento conjunto, **art. 1.042**, 5

–prazo, **art. 1.042**, 2

–razões, **art. 1.042**, 3

Agravo interno

–cabimento, **art. 1.021**, 1

–conceito, **art. 1.021**, 1

–decisão de única ou última instância, **art. 1.021**, 4

–impugnação específica, **art. 1.021**, 2

–julgamento, **art. 1.021**, 5

–multa, **art. 1.021**, 6

–procedimento, **art. 1.021**, 3

Amicus curiae

–incidente de resolução de demandas repetitivas, **art. 983**, 1

–recursos repetitivos, **art. 1.038**, 1

–repercussão geral, **art. 1.035**, 7

Apelação

–cabimento, **art. 1.009**, 1 e 2; **art. 1.013**, 4

–causa madura, **art. 1.013**, 3

–conceito, **art. 1.009**, 1

–cumprimento imediato, **art. 1.012**, 2

–efeito devolutivo, **art. 1.013**, 1

–efeito suspensivo, **art. 1.012**, 1

–efeito translativo, **art. 1.013**, 2

–fato novo, **art. 1.014**, 1

–*final decision*, **art. 1.009**, 2

–forma, **art. 1.010**, 1

–fundamentos, **art. 1.009**, 3

–juízo de admissibilidade, **art. 1.010**, 2

–juízo de retratação, **art. 1.010**, 3

–julgamento, **art. 1.011**, 1 a 3

–*novum iudicium*, **art. 1.009**, 1

–prova nova, **art. 1.014**, 2

–*revisio prioris instantiae*, **art. 1.009**, 1

–tutela provisória para obtenção de efeito suspensivo *ope judicis*, **art. 1.012**, 3

Capítulo da decisão

–rescindibilidade, **art. 966**, 5

Desistência do recurso

–conceito, **art. 998**, 1

–litisconsórcio, **art. 998**, 2

–precedente, **art. 998**, 3

Despacho

–irrecorribilidade, **art. 1.001**, 1

Embargos de declaração

–Cabimento, **art. 1.022**, 2

–complementação, **art. 1.024**, 3

–conceito, **art. 1.022**, 1

–contrarrazões, **art. 1.023**, 4

–conversão, **art. 1.024**, 2

–depósito de multa, **art. 1.026**, 4

–desnecessidade de ratificação,
art. 1.024, 4

–efeito suspensivo, **art. 1.026**, 1

–efeitos infringentes, **art. 1.023**, 3

–interrupção do prazo, **art. 1.026**, 2

–julgamento, **art. 1.024**, 1

–manifestamente protelatórios,
art. 1.026, 3

–prazo, **art. 1.023**, 1

–prequestionamento, **art. 1.025**, 1

Embargos de divergência

–cabimento, **art. 1.043**, 1

–divergência, **art. 1.043**, 2

–julgamento, **art. 1.044**, 1

–razões, **art. 1.043**, 3

–vedação à inadmissibilidade por fundamento genérico, **art. 1.043**, 4

Fungibilidade

–norma fundamental do direito recursal, **Liv. III**, Tít. II, 3.4

Irretroatividade de precedente sobre a coisa julgada

–impossibilidade de rescindibilidade, **art. 966**, 9 e 10

Interesse recursal

–conceito, **art. 996**, 1

Legitimidade recursal

–conceito, **art. 996**, 1

–Ministério Público, **art. 996**, 5

–parte vencida, **art. 996**, 2

–terceiro juridicamente prejudicado,

art. 996, 3

Prazo recursal

–contagem, **art. 1.003**, 1

–correio, **art. 1.003**, 4

–feriado local, **art. 1.003**, 6

–fluência, **art. 1.003**, 1

–interrupção, **art. 1.004**, 1

–previsão, **art. 1.003**, 5

–protocolo, **art. 1.003**, 3

Preparo

–colaboração, **art. 1.007**, 1

–conceito, **art. 1.007**, 1

–deserção, **art. 1.007**, 3

–dispensa, **art. 1.007**, 2

Querela nullitatis insanabilis

–conceito, **art. 966**, 2

Questão prejudicial

–rescindibilidade da decisão, **art. 966**, 4

Reclamação

- cabimento, **art. 988**, 2
- cognição *secundum eventum probationis*, **art. 988**, 3
- competência, **art. 988**, 5
- conceito, **art. 988**, 1 e 4
- esgotamento das instâncias ordinárias, **art. 988**, 6
- procedimento, **arts. 989 a 993**

Recurso

- conceito, **Liv. III, Tít. II**, 1
- classificação, **Liv. III, Tít. II**, 2
- efeitos, **Liv. III, Tít. II**, 5; **art. 995**, 1 a 4; **art. 1.005**, 1 e 2; **art. 1.008**, 1
- espécies, **art. 994**, 1
- juízo de admissibilidade e juízo de mérito, **Liv. III, Tít. II**, 4; **art. 996**, 1 a 5
- normas fundamentais, **Liv. III, Tít. II**, 3; **art. 994**, 2
- prazo para recorrer, **art. 1.003**, 1 a 6
- recurso principal e recurso adesivo,
art. 997, 1 a 7
- recurso total e recurso parcial,
art. 1.002, 1

Recurso especial e recurso extraordinário

- admissibilidade, **Liv. III, Tít. II, Cap. IV, S. II**, 2 a 9; **art. 1.030**, 2 a 10.
- cabimento, **art. 1.029**, 1
- cláusulas negociais, **art. 1.029**, 3
- colaboração, unidade do direito e desconsideração de vício formal, **art. 1.029**, 8
- contrarrazões, **art. 1.030**, 1
- cortes supremas, unidade do direito e precedentes, **Liv. III, Tít. II, Cap. IV, Seq. II**, 1
- dissídio jurisprudencial, **art. 1.029**, 6
- efeito devolutivo e efeito translativo,
art. 1.034, 2
- exposição analítica, **art. 1.029**, 5
- fatos do caso, **art. 1.029**, 2

- interposição simultânea, **art. 1.031**, 1 e 2
- livre trânsito, **arts. 1.032** e 1.033
- razões, **art. 1.029**, 4
- repercussão geral, **art. 1.035**, 1 a 17
- revisão e não cassação, **art. 1.034**, 1
- suspensão em todo o território nacional, **art. 1.029**, 9
- tutela provisória, **art. 1.029**, 10
- vedação ao não conhecimento por fundamento genérico, **art. 1.029**, 7

Recurso ordinário

- cabimento, **art. 1.027**, 1 a 6
- procedimento, **art. 1.028**, 1 a 3

Recursos repetitivos

- afetação, **art. 1.036**, 3; **art. 1.037**, 2
- amicus curiae*, **art. 1.038**, 1
- cinco estágios, **art. 1.036**, 2
- decisão, **art. 1.038**, 2
- delimitação da questão, **art. 1.037**, 1; **art. 1.038**, 3
- desistência, **art. 1.040**, 2
- distinção, **art. 1.037**, 3
- instrução, **art. 1.038**, 1
- julgamento em bloco, **art. 1.036**, 1
- precedentes, **art. 1.039**, 1; **art. 1.041**, 1
- publicação, **art. 1.040**, 1

Reformatio in pejus

- proibição, **Liv. III, Tít. II**, 3.5

Renúncia ao recurso

- conceito, **art. 999**, 1
- litisconsórcio, **art. 999**, 2

Resolução de demandas repetitivas

- coisa julgada sobre questão, **Liv. III, Tít. I, Cap. VIII**, 1
- collateral estoppel*, **Liv. III, Tít. I, Cap. VIII**, 1

- incidente, arts. 976 a 987
- recurso especial e recurso extraordinário, **art. 987, 1**
- representação adequada, **Liv. III, Tít. I, Cap. VIII, 1.16**
- revisão, **art. 986, 1**
- stare decisis*, **Liv. III, Tít. I, Cap. VIII, 1**
- tese jurídica, **art. 985, 1**

© desta edição [2018]